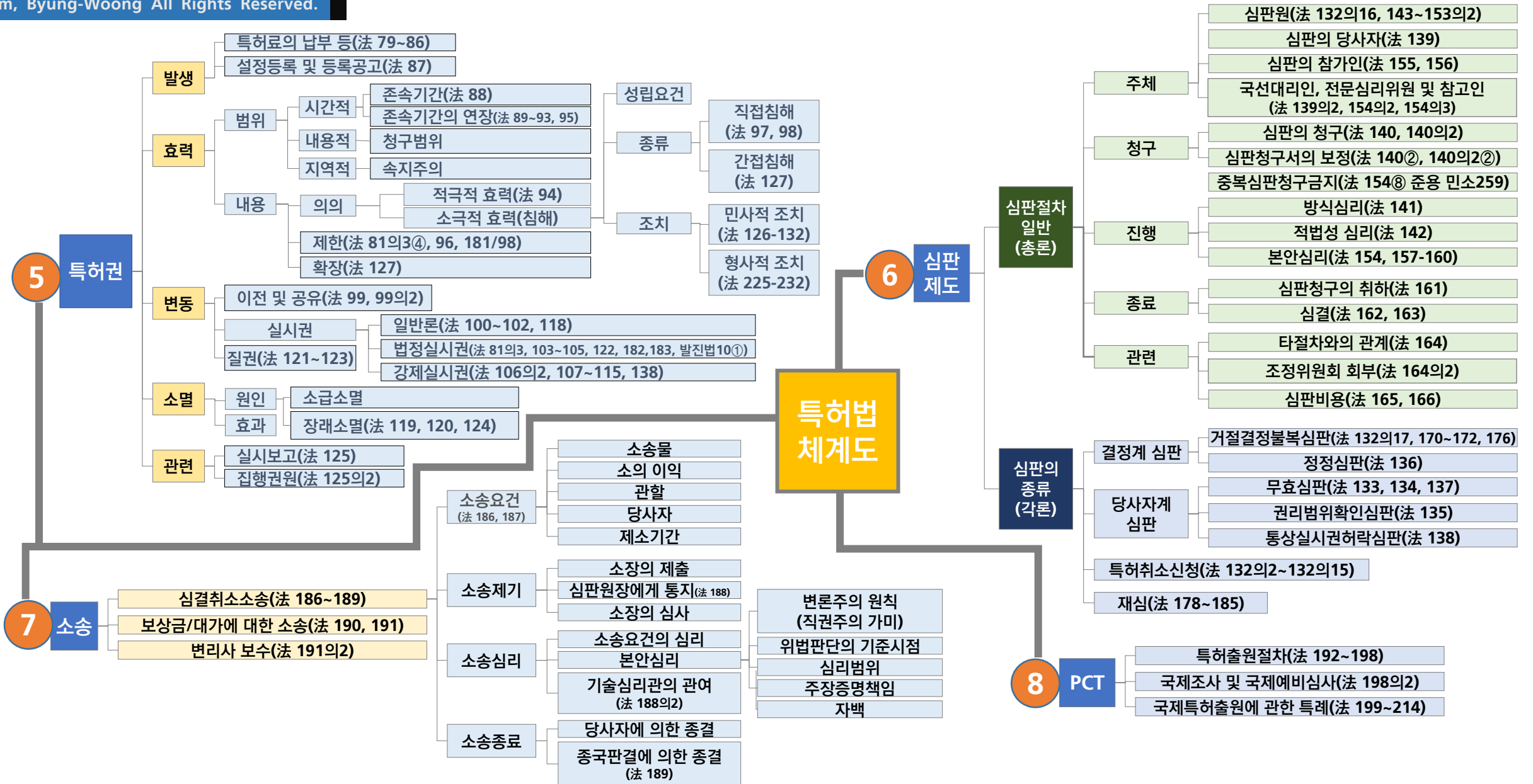


특허법 강의노트

Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

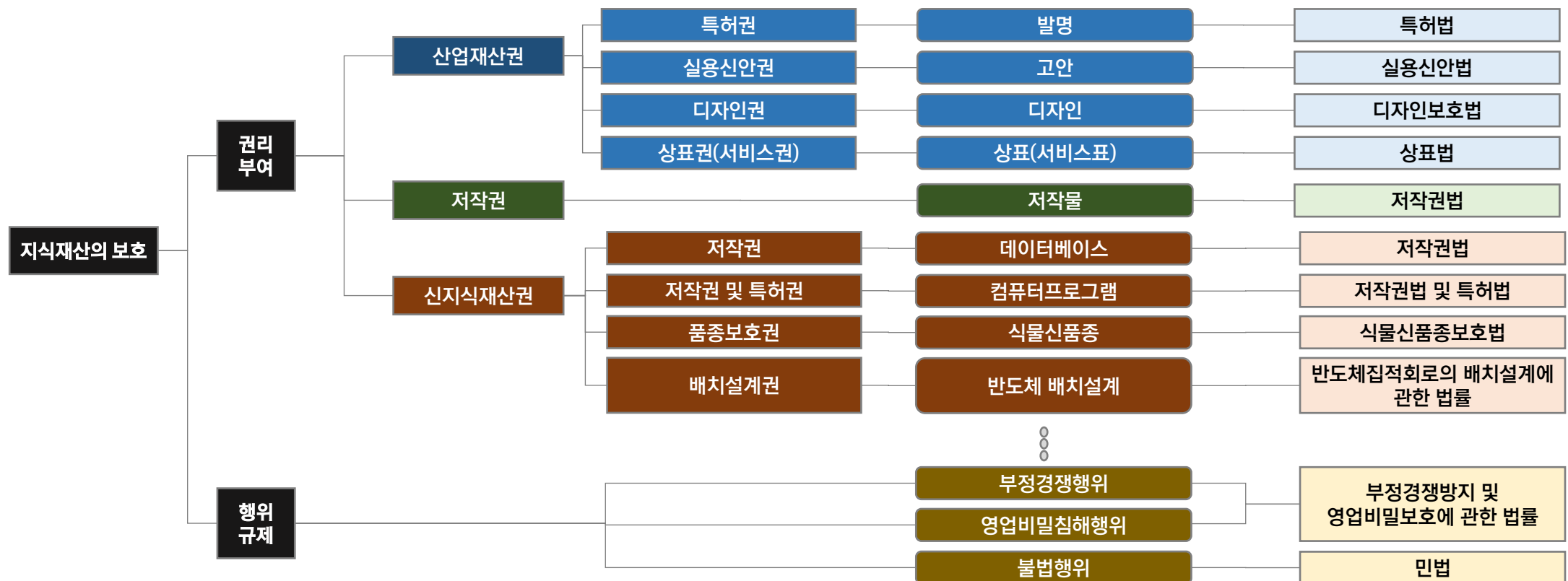
2026





기존의 전통적인 분류에 의하면 지식재산권은 보호의 목적에 따라 산업발전에 이바지할 수 있는 창작물 등을 객체로 하는 권리인 산업재산권과 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지할 수 있는 창작물을 객체로 하는 권리인 저작권으로 구별된다. 산업재산권(Industrial property)은 발명, 고안, 디자인, 상표 등을 보호하는 권리인 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권으로 다시 분류할 수 있다.

한편, 지식재산권의 보호 객체인 지식재산은 그 개념이 고정되어 있다기보다는 경제·사회 또는 문화의 변화나 과학기술의 발전에 따라 그 외연이 점차 확대되어 종래와는 다른 새로운 개념(예를 들어, 컴퓨터 프로그램, 반도체 배치설계, 식물신품종, 데이터베이스 등)에서의 보호되어야 할 지식재산이 등장하고 있다. 이러한 새로운 지식재산에 대해서는 기존의 전통적인 권리의 테두리 안에서 보호하거나 새로운 법을 제정하여 권리로써 보호하려는 노력을 하고 있으며, 이를 신지식재산권이라고 부르고 있다.



디자인권(Design Right)

- 보호대상: 물품의 외관
ex) 자체 형상, 전방램프 형상, 의자형상 등
- 권리해석: 물품의 도면
- 침해판단: 디자인의 동일 또는 유사
- 보호기간: 등록된 후 출원일로부터 20년

특허권(Patent Right)/ 실용신안권(Utility model Right)

- 보호대상: 기술
ex) ABS브레이크, 변속기, 의자높낮이 조절 등
- 권리해석: 청구범위
- 침해판단: 청구범위에 기재된 발명 실시 여부
- 보호기간: 등록된 후 출원일로부터 20년(특허), 10년(실용신안)



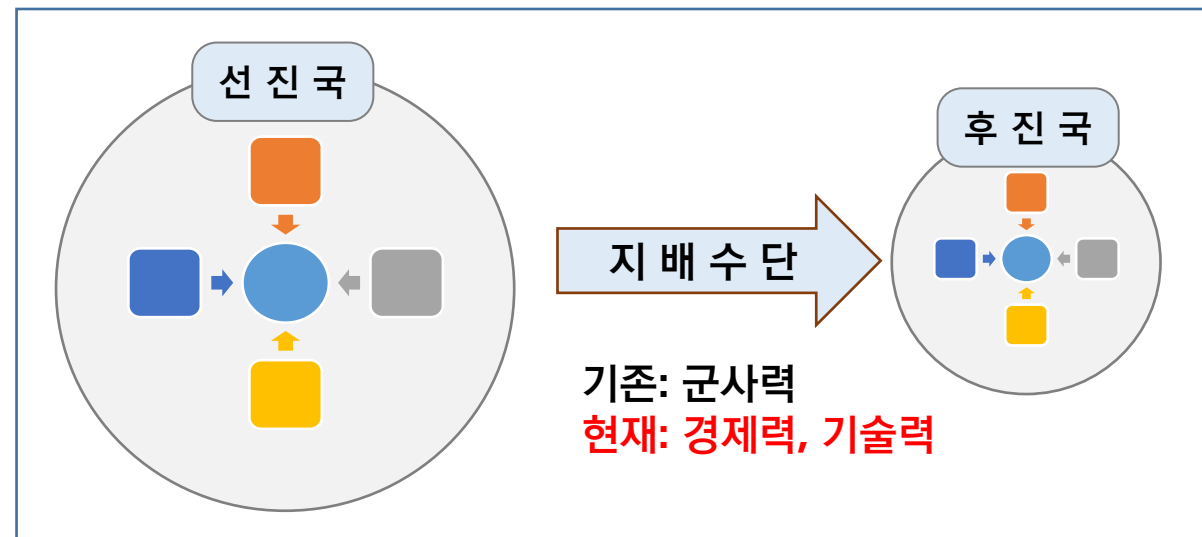
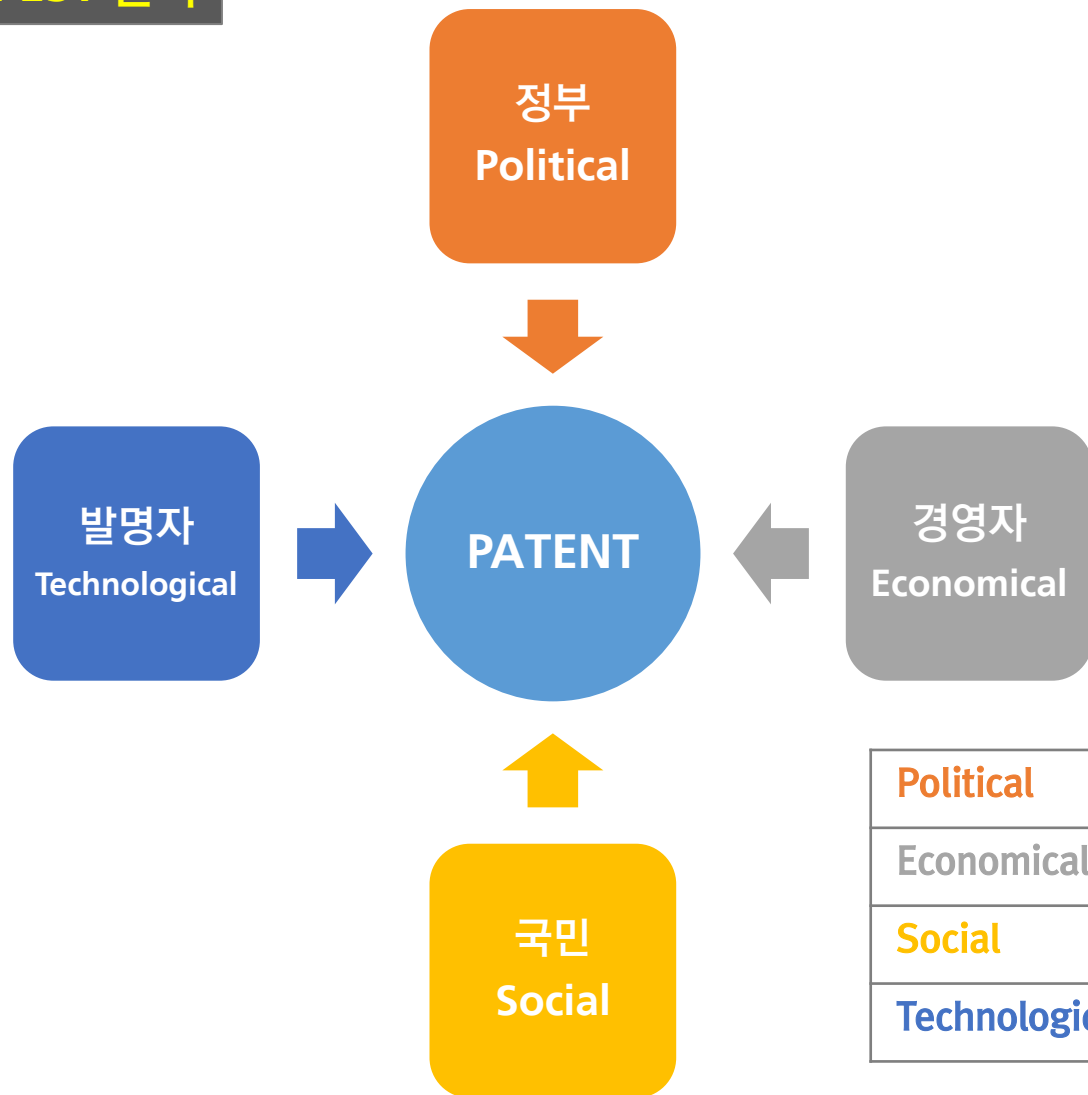
상표권(Trademark Right)

- 보호대상: 상품의 명칭
ex) 자동차 명칭(제네시스), 제작사 명칭(현대)
- 권리해석: 문자, 도형 등의 상표권본
- 침해판단: 상표의 동일 또는 유사
- 보호기간: 등록일로부터 10년
* 갱신가능(반영구적 보호)

저작권(Copy Right)

- 보호대상: 인간의 사상과 감정을 표현한 창작물
ex) 디지털 콘텐츠, 멜로디
- 권리해석: 저작물에 대한 표현
- 침해판단: 저작물의 카피(Copy)
- 보호기간: 저작자 사후 70년

PEST 분석



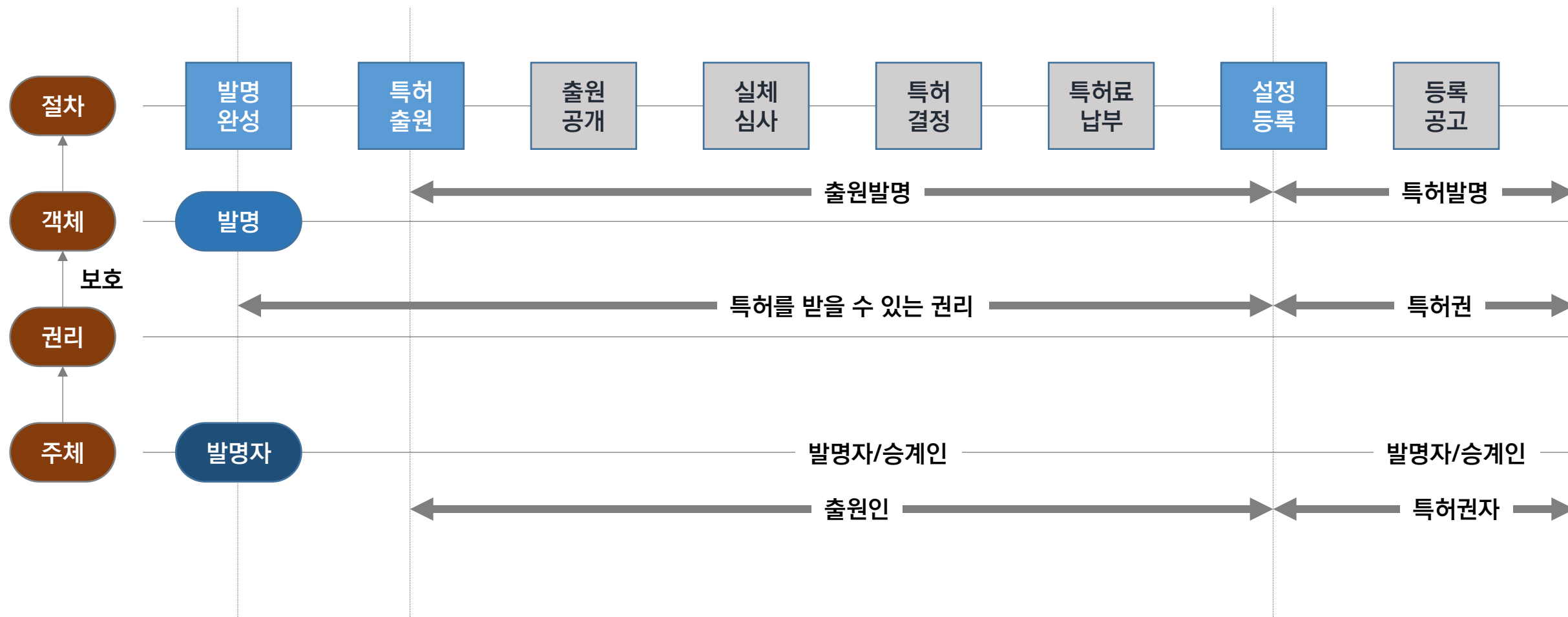
- 비밀공개설
- 발명장려설
- 과당경쟁방지설
- 국제교류설

Political	산업발전을 위한 토대
Economical	수익을 창출하기 위한 수단(ROI)
Social	발명이라는 객체를 보호하는 권리
Technological	종래의 문제점을 개선한 것

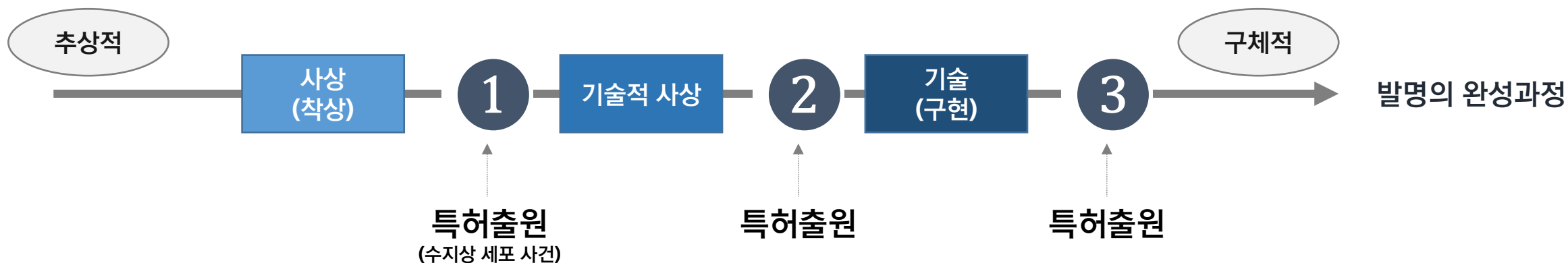
특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 그 목적으로 한다(法 1). 즉, 특허법은 **발명의 보호·장려**라는 사익적 측면과 제3자의 이용 도모라는 공익적 측면의 조화를 통해 기술발전을 촉진시키고, 그 결과 산업발전에 이바지하고자 한다. 특허법의 목적을 규정하고 있는 제1조 이외의 나머지 규정들은 특허법의 목적을 달성하기 위해 존재한다고 할 수 있다. 따라서 제1조의 특허법의 목적은 **모든 조문의 해석기준**이 되며, 나머지 규정들이 서로 충돌할 때는 제1조에 부합하게 해석하여야 한다.



정의 규정의 만족으로 발생한 발명은 등록 전에는 **특허를 받을 수 있는 권리**에 의하여, 등록 후에는 **특허권**에 의하여 보호를 받게 된다. 이와 같은 발명 중 특허출원에 서 등록 전까지의 발명을 **출원발명**이라 지칭하며, 등록 후의 발명을 **특허발명**이라 지칭한다.



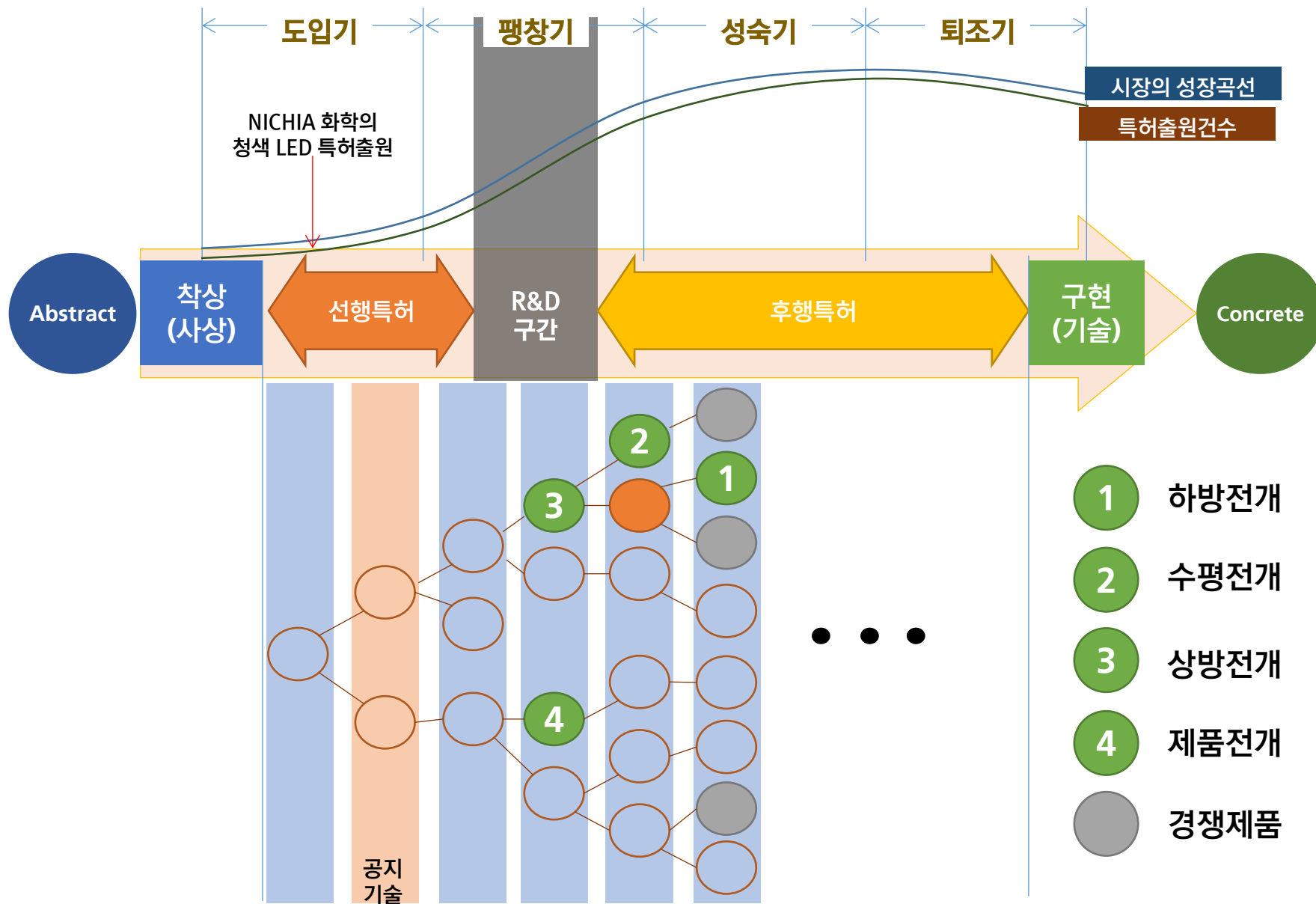
①의 시기에 특허출원을 하는 경우 특허출원일 당시 미완성발명이기 때문에 특허를 받을 수 없다. 즉, **발명은 출원일 당시 단순한 사상이어서는 아니 되고 기술적 사상이어야 한다.** ②③의 시기에 특허출원을 하는 경우 특허출원일 당시 완성된 발명으로서 특허를 받을 수 있다. 다만, 기술적 사상일 때인 ②의 시기 이후에 특허출원을 하는 것이 기술로서 구현된 때인 ③의 시기에 특허출원을 하는 것보다 더 넓은 권리범위를 가진 특허로서 보호될 가능성이 높다. 즉, **발명은 기술적 사상이면 되고 기술 자체로 제한되는 것은 아니기 때문에**, 구체적인 기술보다는 기술적 사상을 특허로서 보호하는 것이 바람직하다고 할 것이다. 물론 강력한 특허망을 구축하기 위해서는 기술적 사상과 기술에 해당하는 발명 모두를 특허로 보호하여야 한다.

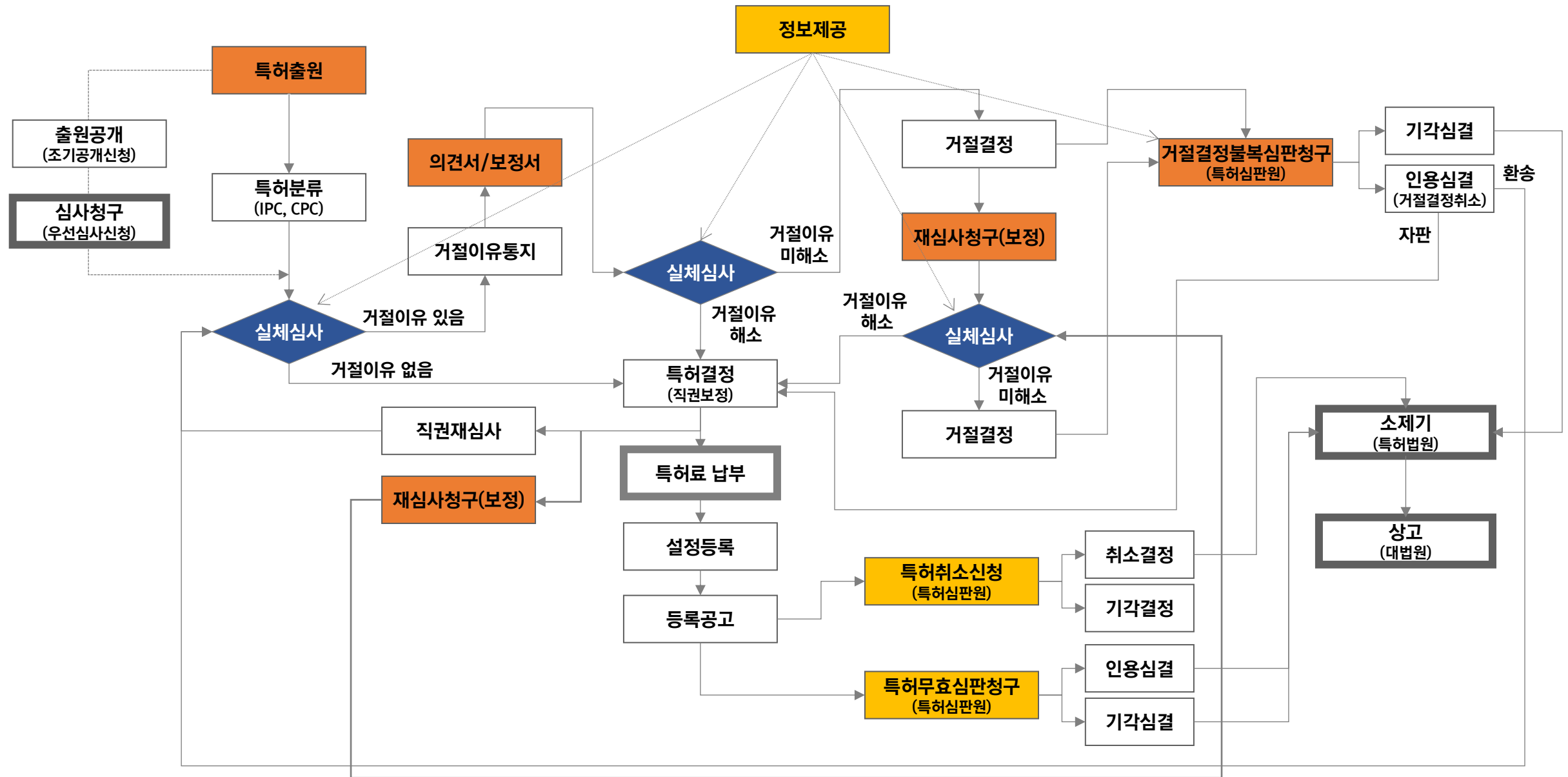


대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결 【거절사정(특)】

특허출원발명의 **출원일 당시** 수지상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 아니하여 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, **출원일 이후** 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다.

선행 특허 (기본특허)	후행 특허 (개량특허)
개념	개선
기본발명	개량발명
High Return	Low Return
High Risk	Low Risk



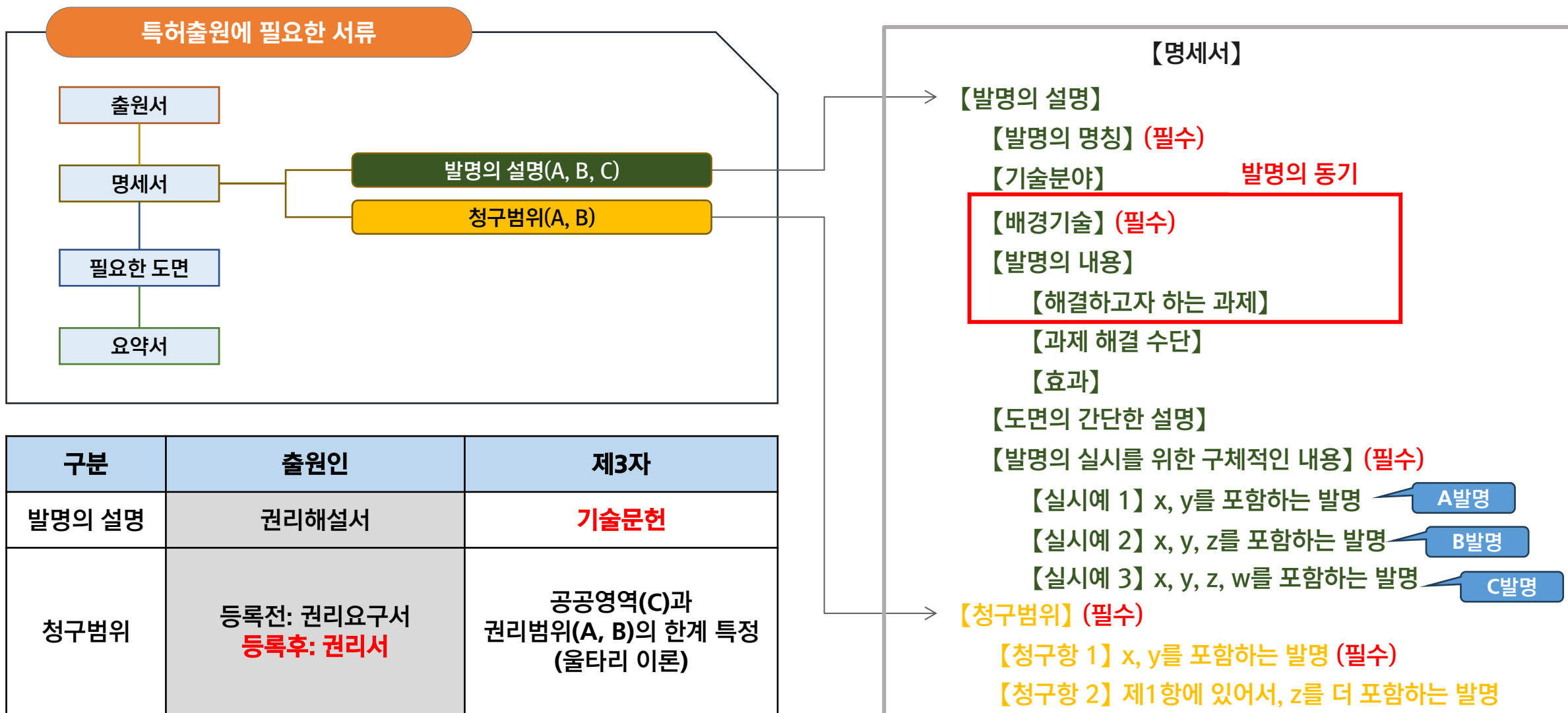


요건	내 용	거절이유	정보제공사유	특허무효사유	특허취소사유
주체적	- 외국인의 권리능력(法 25) - 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자(法 33①본문) - 특허를 받을 수 없는 자(法 33①단서) - 공동출원(法 44)	○	○	○*	
실체적	- 산업상 이용가능성(法 29①본문) - 신규성(法 29①각호) - 진보성(法 29②) - 확대된 선출원(法 29③④⑤⑥⑦) - 선출원주의(法 36①②③)	○	○	○**	○***
	- 불특허발명(法 32) - 일반적 발명의 설명 기재(法 42③ I) - 청구범위 기재(法 42④) - 신규사항추가금지(法 47②) - 분할출원의 범위를 벗어난 경우(法 52①) - 분리출원의 범위를 벗어난 경우(法 52의2①) - 변경출원의 범위를 벗어난 경우(法 53①)				
조약	조약을 위반한 경우	○	○	○	
절차적	- 발명의 설명 중 배경기술 기재(法 42③ II) - 다항제 기재방법(法 42⑧) - 하나의 특허출원의 범위(法 45)	○			
후발적 무효사유	특허 후 특허권자가 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우			○	

* 단, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자(法 33①본문) 위반과 공동출원(法 44) 위반은 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에 제외

** 단, 신규사항추가금지(法 47②)는 원문의 범위(法 47②전단)를 벗어난 경우, 분리출원의 경우 원출원의 최초 명세서/도면에 기재된 범위(法 52의2①각호외의 부분 전단)를 벗어난 경우에만 특허무효사유에 해당

*** 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)와 제36조 제1항 내지 제3항에 한하되, 등록특허공보에 게재된 선행기술을 기초로는 불가/심판실무상 제29조제1항본문 위반도 제외



* 심사관은 청구범위의 청구항별로 거절이유를 판단하지만, 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 출원 전체를 거절결정하며, 이를 출원일체의 원칙(All or Nothing Rule)이라고 한다.

외국어 발음표기 문자 형성방법 사건(2001허3453)

문제가 된 청구항은 「외국어 발음표기 문자를 형성하는 방법에 있어서, 문제에 대한 한글과 외국어의 발음상의 차이에 의하여 표기시에 차이가 생기는 문자들의 표시를 위하여 해당 문자의 발음시에 형성되는 사람의 목구멍의 형상과 혀소리가 발음상 변화를 일으키는 현상과 이에 따른 입술모양에 따라서 문자를 변형시켜서 형성하는 것을 특징으로 하는 외국어 발음표기 문자의 형성방법」으로서 이와 같은 외국어 발음표기문자의 형성방법은 인위적인 약속에 지나지 않기 때문에 자연법칙을 이용한 것이 아니다

마법천자문 사건(2009허351)

특허발명은 학습만화에 관한 것으로 그 기술 분야는 만화 및 애니메이션 산업분야라 할 것이므로, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이라면 특허발명에 개시된 기술적 수단을 이용하여 특허발명을 용이하게 반복 실시할 수 있을 것으로 보이고, 발명의 실시자에 따라 그 효과에 있어서 어느 정도의 차이가 발생할 수 있음은 이 특허발명의 경우뿐만 아니라 다른 발명의 경우에도 마찬가지라 할 것이고, 특허발명에 반복재현성이 있는지 여부를 판단함에 있어 발명의 실시자를 특허발명이 속하는 기술분야인 만화 및 애니메이션 산업분야의 통상의 기술자로 보아야 할 것인 점에 비추어 보면, 발명의 실시자에 따라 특허발명의 반복실시가 어렵다고 할 정도로 그 효과가 달라진다고 볼 수 없다.

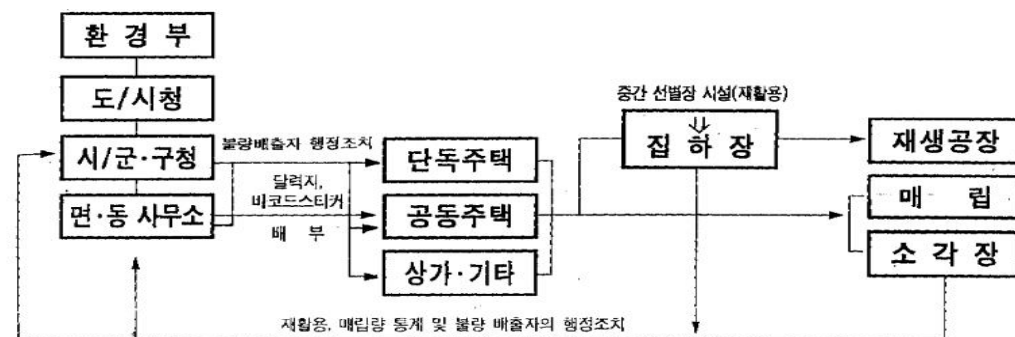


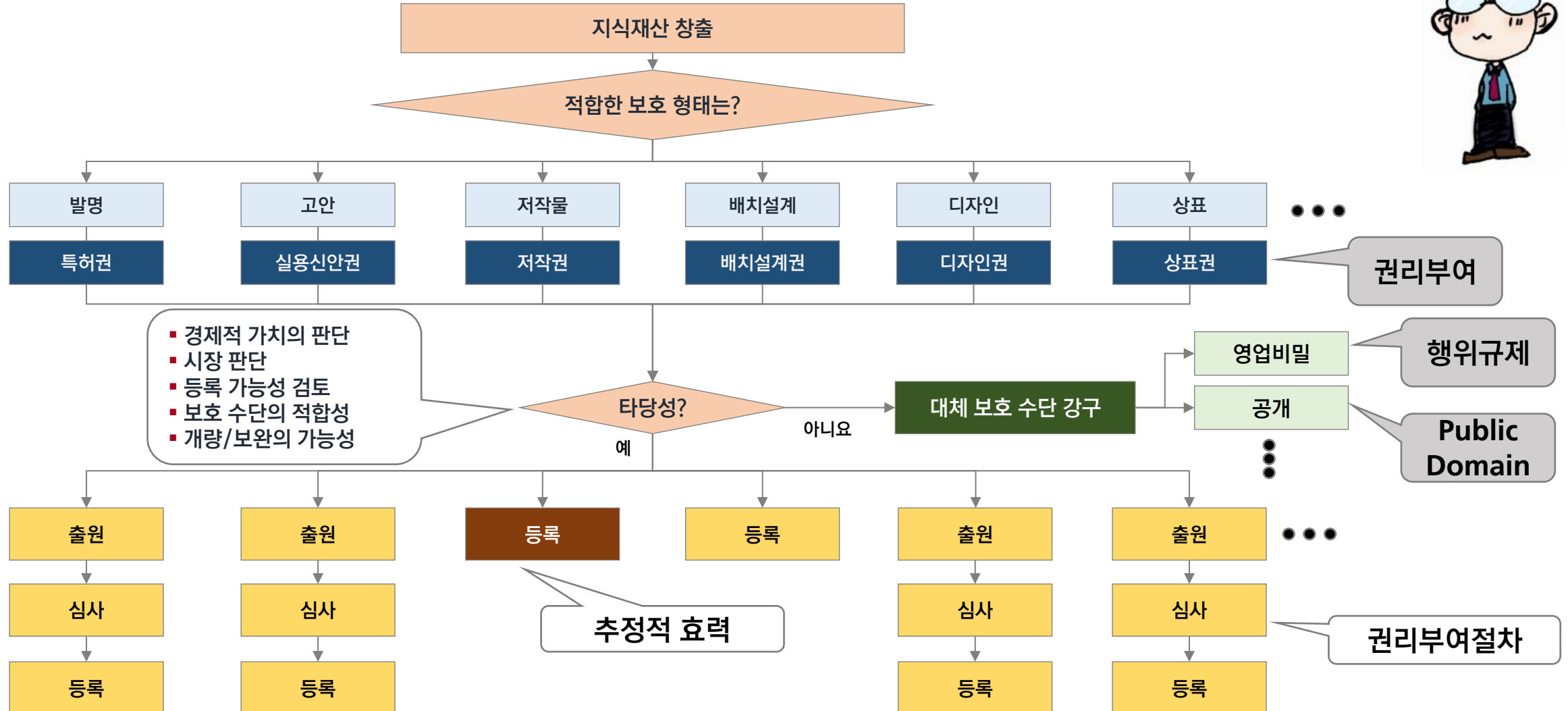
수치제어장치의 가감속 제어방법 사건(97후2597)

출원발명이 기본워드에서 서브워드를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 하고 워드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 것으로서, 결국 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브워드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있다는 이유로 그 출원발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다.

재활용 쓰레기 종합 관리 방법 사건(2001후3149)

「배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커와, 배출쓰레기가 표시된 달력지는 관할 관청에서 각 배출자에게 배포하고 각 배출자들은 정해진 규정에 의해 정확하게 분리된 쓰레기를 규정 쓰레기 봉투에 담아서 배출하되 반드시 배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하며, 수거자는 배출된 쓰레기를 요일별로 정확하게 분리 수거하여 집하장으로 이송하여 재활용쓰레기와 매립 소각될 쓰레기를 선별하여 처리과정을 거치며, 잘못분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 각 과정에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하도록 하는 생활쓰레기 재활용종합관리방법」은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온 라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로 이를 특허법 제29조 제1항 본문의 「산업상 이용할 수 있는 발명」이라고 할 수 없다





발명자 또는 승계인은 발명의 보호전략을 달리할 수 있다. 구체적으로 **특허출원**을 통해 발명을 보호할 수도 있으나, 특허를 획득하더라도 침해 판정이 어렵거나 제품의 경쟁력을 좌우하는 핵심기술인 경우 **노하우**로 보호하는 방안을 강구할 수 있다. 또한, 시간과 비용을 들여 특허를 확보할 의도는 없으나 타인의 특허권 확보를 저지하려는 경우에는 발명을 **공개**할 수도 있다. 발명을 공개할 때에는 공개일, 공개내용에 대한 증명의 용이성을 위해 지식재산처의 인터넷기술공지제도를 활용해 보는 것을 검토해 볼 만 하다.



발명자는 발명이 특허나 노하우로 보호가치가 없다고 판단되는 경우 발명을 공개시킬 수 있다. 발명이 공개되어 공지기술의 지위를 가지는 경우 **타인의 특허등록을 저지**시킬 수 있으며, 착오로 타인의 특허출원이 등록되더라도 권리범위를 부정하여 발명자를 역공격하는 것을 막을 수 있다. 즉, 시간과 비용을 들여 특허를 확보할 의도는 없으나 타인의 특허권 행사로부터 사업상의 불이익을 받는 것을 방지하고자 하는 경우 발명의 공개를 고려해 볼 수 있다. 실무적으로 가장 주의하여야 할 점은 타인의 특허출원 전에 공지기술의 지위를 가진다는 점을 **발명자가 증명하여야** 한다는 것이다. 따라서 발명자는 공지기술이 된 시점 및 내용을 명확하게 확인할 수 있는 방법을 강구하여야 하며, **지식재산처의 인터넷 기술공지제도를 활용**하는 것을 고려해 볼 수 있다.

항목	내용
이용 효과	- 방어목적(타인의 등록저지)의 출원을 하는 경우 - 법적 대응을 위해 공증기관의 공증을 받고자 하는 경우 - 연구개발을 위해 기술동향이 필요한 경우 - 타인의 특허에 대한 권리범위의 부정
이용 제한	- 출원절차를 밟아 특허권 행사를 하고자 하는 경우 - 영업비밀로 보호해야 될 기술에 해당되는 경우
이용 절차	지식재산처 사이트에 접속한 후 사이버 공지를 신청하고 공지자료실에 공개를 원하는 기술내용을 등록하면 됨

인터넷 위차 HOME 지식재산제도 인터넷기술공지 인터넷 기술공지 자료실

인터넷 기술 공지

인터넷 기술공지 자료실

고객이 궁금해하시는 특허정보의 모든것을 알려드립니다.

인터넷 기술공지 자료를 제공하는 게시판입니다.

- ▶ 날짜를 입력하여 자료를 검색하거나, 첨부된 자료를 다운로드 할 수 있습니다.
- ▶ 인터넷 기술공지의 게시글은 등록 후에는 수정이 불가능합니다.
- ▶ 인터넷 기술공지는 본사이트 공지자료실과 특허정보검색(KIPRIS)에서 검색이 가능하며 KIPRIS plus를 통해 공개됩니다.
- ▶ 기간으로 조회할 경우 2010년 1월 1일은 20100101으로 입력하시기 바랍니다.

총 : 4543건, 1/455(Page)

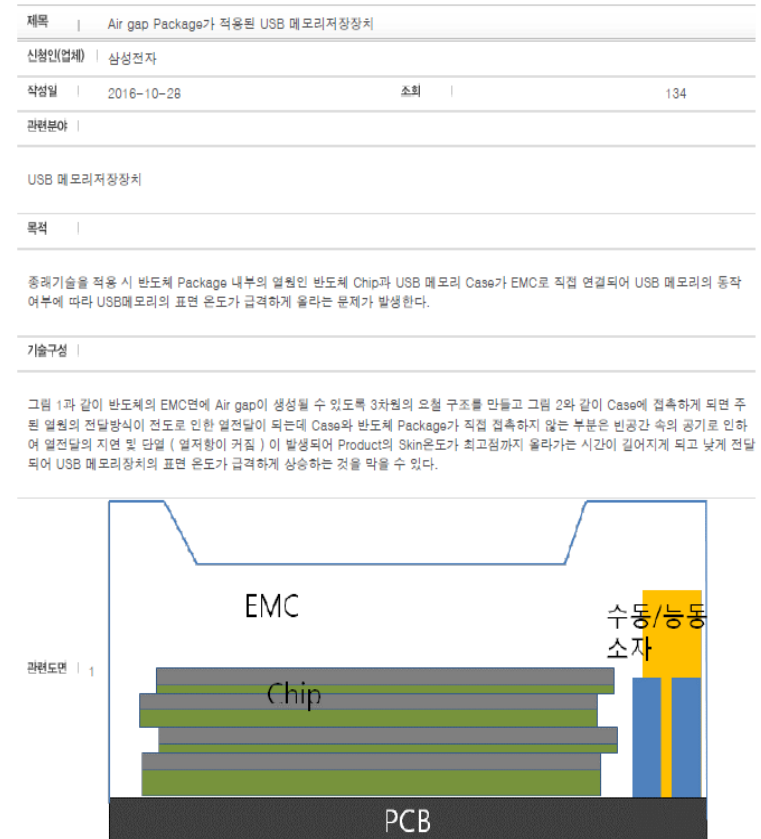
년월일 : ~ 선택

검색
취소

공개번호	제목	작성자	작성일	조회
2017-5	윤성 인식 및 심박수 체크 위험 긴급 알림	고재찬	2017-02-08	21
2017-4	부정선거 방지 용지	명희송	2017-01-28	30
2017-3	스마트폰의 사진기능을 이용한 PC나 TV등의 웹URL 전송기술	김준	2017-01-21	28
2017-2	7미리 무선	우현숙	2017-01-20	28
2017-1	모바일 Address Link Solution 주소 링크 솔루션	양동화	2017-01-08	39
2016-57	냉자켓	서강원	2016-11-22	105
2016-56	T8V backside pad metallurgy	삼성전자	2016-11-11	111
2016-55	스크린도어 safety zone	디지털컨설팅	2016-11-02	114
2016-54	Air gap Package가 적용된 USB 메모리저장장치	삼성전자	2016-10-28	132
2016-53	반도체 장비 PMO1040-D 설비의 Inflow 억제 Resin Supply 구조 와 작...	삼성전자	2016-09-30	144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

공공 I-PIN 인증 공지신청

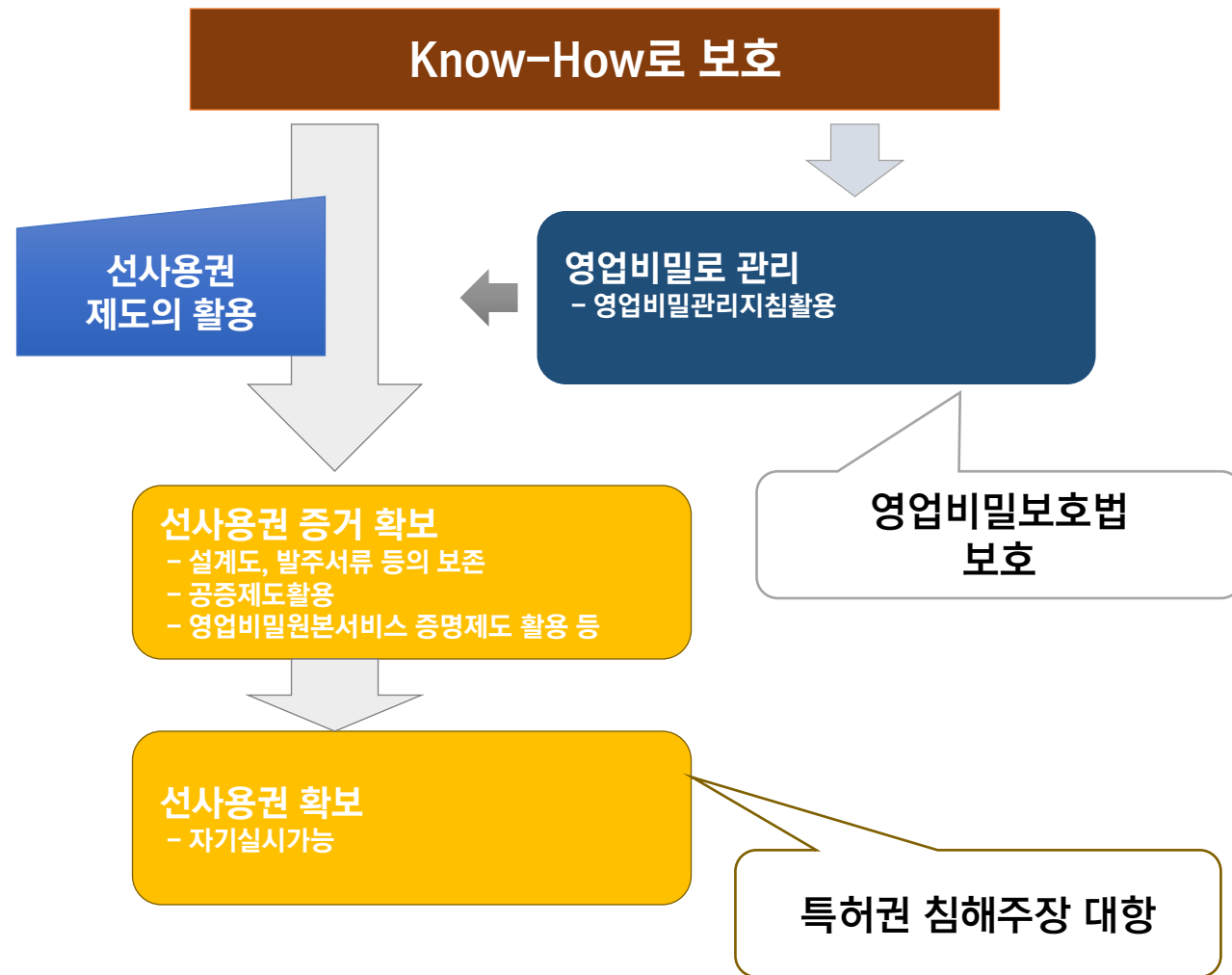


발명의 보호가치는 있으나 특허로 보호하기에는 적당하지 않는 경우가 있다. 예를 들어, 특허권을 행사하기 위해서는 침해 피의자의 실시가 특허권의 침해라는 것을 특허권자가 증명을 하여야 하는데, 제조방법의 경우 제품에 녹아 있기 때문에 실제로 제품이 특허를 받은 제조방법에 의하여 생산되었는지 증명하기가 쉽지 않을 수 있다. 이 경우 발명자는 발명을 공개시키지 않음으로써 노하우로 보호하는 것을 고려해 볼 수 있다. 특허는 일정기간 경과 이후에 일반 공중이 이를 자유롭게 사용할 수 있도록 공개하는 조건으로 국가가 강력한 보호수단을 제공하는 것을 말하며, 국가는 이를 통하여 산업발전에 이바지라는 목적을 실현할 수 있다. 반면 노하우는 이를 보유하고 있는 자 스스로가 적극적으로 비밀로서 유지·관리할 것이 요구되며, 국가는 노하우가 영업비밀에 해당할 때 이를 부정한 수단에 의하여 취득하거나 부정 공개행위를 한 경우에만 보호해주고 있다.

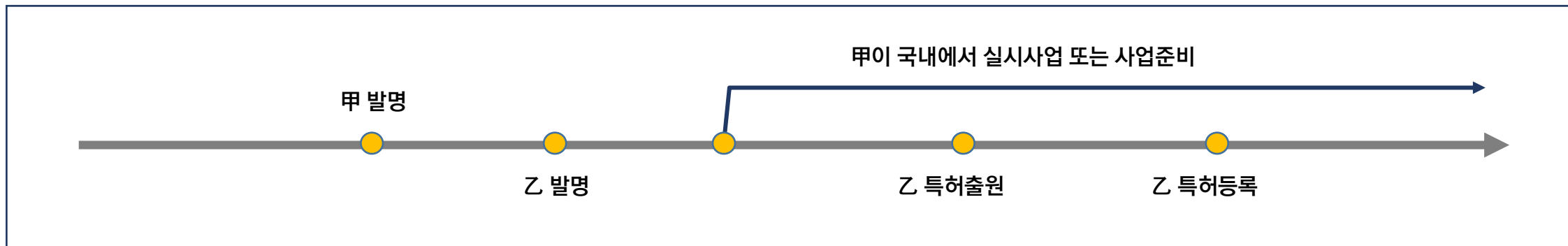
구 분	특 허	노 하 우
공개여부	有	無
성립요건	발명의 정의 규정(法 2 I) 만족	특별한 정의 규정 ×
특허요건	필요	불필요
보호기간	일정기간	비밀이 유지되는 한 제한 × (단, 타인이 특허를 받더라도 일정한 경우 특허법 제96조제1항제3호, 제103조에 의하여 보호 가능)
보호범위	청구범위기재발명	불명확
독점 · 배타성	有	無
침해에 대한 구제	특허법상 권리에 의한 민형사상 조치: 권리부여	계약내용에 의하여 보호 (단, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 또는 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 등에 의하여 일정 행위를 민형사상 규제가능: 행위규제)

• 영업비밀로 보호한 경우의 문제점

- 비밀의 영속성을 유지하기 어려움
- 영업비밀이 이미 유출된 경우 회수가 불가능
- 영업 비밀의 요건(비공지성, 경제적 유용성 및 비밀 관리성)의 증명이 곤란한 경우가 많음
- 역설계에 의한 영업 비밀의 획득은 적법한 행위로 인정됨
- 국가별 제도 등의 상이로 인하여 보호의 곤란성



선사용권



선사용권	내 용
의의 및 효력	선사용권이란 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업 또는 그 사업준비를 하고 있는 자에게 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다(특허법 제103조). 선사용권이 있는 경우 특허권의 침해가 되지 않는다.
증명책임	특허권자(乙)의 출원시에 제3자(甲)가 국내에서 선의로 실시사업 또는 사업준비를 하고 있는 경우에만 선사용권이 발생하는데, 이는 제3자가 증명을 해야 한다.
증명방법	▪ 기술관련서류, 사업관련서류, 제품, 영상 등을 잘 관리 ▪ 공증사무소의 공증 활용 ▪ 영업비밀 원본 증명 서비스 제도 활용(영업비밀보호센터 www.tradesecret.co.kr)

영업비밀원본서비스 증명제도 활용



영업비밀 보호 관점



영업비밀 관리 입증

"일반정보와 영업비밀을 구분"하여 관리한 사실과 "정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 의지 표시"를 입증할 수 있으며, "분쟁에 대비한 영업비밀 관리 증거 확보"가능



거래 협상 시 기술유출 방지

납품 협상, 기술제휴, 기술이전, 공동 연구개발 등을 위한 사전 협상과정에서 자사 영업비밀을 제공해야 하는 경우 원본등록 사실을 상대방에 고지함으로써 기술탈취 방지 가능



직원이직 시 영업비밀 보호

연구개발 정보, 기술 노하우 및 고객정보 등 자사 영업비밀을 취급하던 직원이 퇴사하는 경우 경업금지약정 체결과 함께 현실적인 영업비밀 유출 방지수단으로 작용



임직원 영업비밀 보호 인식제고

사내외에 원본등록 등록 사실 고지를 통하여 자사 영업비밀 유출 시 형사처벌 될 수 있다는 경각심을 일깨워 임직원의 영업비밀 보호 인식 제고와 유출심리 억제 효과 발생

법적분쟁 대비 관점



특허분쟁 대비(선사용권 입증)

자사에서 영업비밀로 관리하고 있는 기술에 대하여 타사에서 특허 침해소송 제기 시 특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권)에 따른 무상통상실시권 주장 증빙자료로 활용



연구개발 중인 기술보호(모인 특허출원 대비)

자사에서 연구개발 중인 기술이 제3자에게 유출되어 모인(형령) 특허출원이 발생하는 경우 특허법 제34조 및 제35조에 따른 정당한 권리자 주장을 위한 입증자료로 활용



경진대회 출품작·아이디어 보호

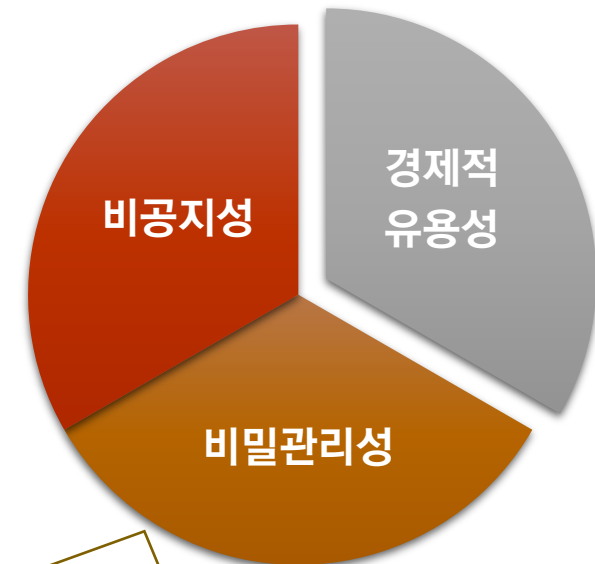
정부부처, 지자체, 공공기관 및 사기업 등에서 주최하는 아이디어 공모전에 응모하는 경우 제안 아이디어 또는 출품작의 권리자임을 입증

영업비밀이란 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다(부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제2호). 영업비밀은 영업상의 이익 또는 사실상의 자산으로 이해되고 있으나, **공개의 대가로 배타적 권리를 부여하는 것이 아니고 공시제도가 존재하는 것도 아니므로 물건 또는 산업재산권과 같은 권리성은 인정되지 않는다.**

영업비밀의 예시

기술 정보	▪ 제조 공정, 설계 도면, 실험 데이터, 연구 리포트, 생산 방법 등 ▪ 컴퓨터 프로그램 ▪ 제조 시설의 배치 방법 ▪ 의약품의 원료나 성분 또는 이들의 배합비 등의 know-how로 효능이 높은 특수약품을 제조하는 방법 ▪ 기능성이 있는 디자인 (자동차 디자인, 건축디자인 등) ▪ 독특한 식료품의 맛, 향기 등에 대한 know-how (코카콜라 맛 등).
경영 정보	▪ 고객명부, 대리점명부, 거래선의 루트, 원료구입처, 신용리스트, 가격산정기준, 상품공급조건, 할인율, 판매계획, 합병계획, 신제품의 생산계획, 상품의 원가, 사원의 급여나 수당의 액수, 신입사원모집방법 등 ▪ 특정상품에 대한 고객의 성별·연령별·직업별·소득수준별·계절별 소비성향과 향후 소비추이를 예측할 수 있는 지표설정 등에 필요한 정보활동·마케팅활동 등에 관한 각종 매뉴얼류 등

영업비밀의 성립요건



- 정보접근자의 제한조치
- 정보접근자의 비공개 의무부과
- 정보접근자에게 영업비밀인 것을 알 수 있도록 하는 조치(대외비 등)

원칙적으로 제2조제1호의 정의규정을 만족하는 발명에 대하여 성립성이 인정되나, 예외적으로 정의규정을 만족하지 않거나 만족 여부가 상당히 애매함에도 불구하고 성립성이 인정되는 발명(컴퓨터 프로그램 관련 발명, 식물발명, 미생물 발명, 용도발명)이 있다.

종류	정의 규정의 만족 여부	성립성 인정 조건
식물발명	자연법칙의 이용 △ (일정한 확실성 및 반복가능성)	- 발명의 특성을 재현할 수 있는 육종경과를 상세히 적은 경우 발명의 성립성이 인정된다.
미생물발명	자연법칙의 이용 △ (일정한 확실성 및 반복가능성)	- 통상의 기술자가 미생물 등을 쉽게 입수할 수 없는 경우에는 특허출원 전에 미생물을 국내기탁기관, 지정기탁기관 또는 국제기탁기관에 기탁하고, 출원서에 그 취지를 적고 그 증명서류를 첨부하여야 하며, 명세서에 수탁번호를 적어야만 발명의 성립성이 인정된다. 다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다. - 다만, 통상의 기술자가 미생물 등을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 입수방법을 명세서에 적으면 된다(승 2, 3).
용도발명	창작성 ×	- 발견이지만 물질로부터 새로운 용도를 발견하고 이를 새로운 용도로 이용하는 과정에서 존재하는 창작적 요소가 보호할 가치가 있는 경우 발명의 성립성이 인정된다.
컴퓨터 프로그램 관련 발명	자연법칙의 이용 × (전체적으로 이용)	- 소프트웨어가 하드웨어의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있는 경우 발명의 성립성이 인정된다(97후2507).

발명의 성립성

발견이지만 용도발명으로 성립성 인정

발명의 설명의 기재

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 발명의 설명 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다(대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727).

산업상 이용가능성

의약발명은 인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니하여야만 산업상 이용가능성이 인정

불특허발명

그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하지 아니하여야만 공서양속에 위반되거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당하지 않음

청구범위의 기재

[1] 의약용도발명의 구성요소: 원칙은 **물질 + 용도(질병, 약효)**로 기재

[2] **물질 + 약리기전**: 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호가 정한 청구항의 명확성 요건을 충족(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후5215).

[3] **물질 + 약리기전 + 용도(질병, 약효)**: 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다. 따라서, 정정심판에서 약리기전을 추가하는 정정을 하는 경우 용도를 2번 기재하는 것에 지나지 않아서 청구범위의 감축이라 할 수 없기 때문에 정정을 인정할 수 없고(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238), 거절결정불복심판에서 물질 + 약리기전 + 용도로 청구범위가 기재된 경우 물질 + 용도로 발명을 특정해야 함(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664).

[4] **물질 + 용도(질병, 약효) + 투여용법/투여용량**: 투여용법/투여용량은 새로운 용도로서 발명의 구성요소로 인정(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768).

신규성

화학물질이나 의약품 등의 경우에는 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었다고 볼 수 없어 신규성이 상실되지 아니한다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 주장하는 자가 증명하여야 한다(특허법원 2018. 1. 11. 선고 2017나1247).

진보성

[1] 특정한 투여용법이나 투여용량으로 인하여 나타난 유리한 효과가 통상의 기술자의 기술수준에서 예측되는 범위를 넘는 현저한 경우 이거나 또는 통상의 기술자가 당해 **의약발명의 약리효과가 온전히 유지되면서 독성이나 부작용이 최소화**되는 특정한 투여용법이나 투여용량을 선행발명 또는 공지의 발명으로부터 예측할 수 없었던 경우에는 그 진보성이 부정되지 아니한다(특허법원 2017. 2. 3. 선고 2016후830).

[2] 의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 **선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다**(대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502).

대법원 2022. 04. 05. 선고 2018후10923 판결 【등록무효(특)】

사실
관계

본 건은 선행발명의 화합물인 타일로신과 화학 구조는 동일하지만 5.0, 9.0 및 10.5° 2θ의 피크를 포함하는 분말 X선 회절 스펙트럼 값으로 특정된 구성을 갖는 타일로신 제 I 형 결정형에 관한 발명이라는 점에서 차이가 있는 ‘이 사건 제1항 발명’이 선행발명에 의해 진보성이 부정되는지 여부가 쟁점이 된 사안이다. 대법원은, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정 변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제 I 형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않다는 등의 이유로 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다고 단정할 수 없다고 보아, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기환송하였다.

판결
요지

의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다.

한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다).

결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조). 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조).

□ 국조실 주관으로 지식재산처, 문체부, 과기정통부는 프로그램을 물건에 포함하지 않는 대신, SW를 온라인 전송하는 경우까지 보호하는 데 합의('18.3), 제94조(특허권의 효력)에 “알면서”라는 인지요건 부가하여 관련 산업의 위축 불식

○ 각국은 다양한 형태로 ‘특허기술이 포함된 SW의 온라인 전송 행위’를 특허침해로 규정, SW 특허를 실효적으로 보호하고 있으나, 한국은 보호하지 못하는 문제점 발생

- 기존 특허법에 의한 청구항의 보호범위

구분	프로그램이 설치된 장치				프로그램이 저장된 기록매체			프로그램
	생산	사용	양도	수입	생산	양도	수입	온라인 전송
장치 청구항	○	○	○	○	×	×	×	×
기록매체 청구항	△	△	△	△	○	○	○	×
방법 청구항	×	○	×	×	×	×	×	×(개정법 ○)

제2조제3호(나)목의 개정

○ 이에 SW 온라인 전송행위에 가장 적합하게 해석될 수 있는 영국의 “방법의 사용을 청약하는 행위(offer it for use)”를 채택

- SW의 실행은 방법의 사용에 해당하고, SW를 전송하는 것은 방법을 사용하도록 청약하는 행위로 해석

○ “알면서”라는 인지요건에 의해, SW를 전송하여 특허를 침해하는 경우는 ① 특허권 존속 중에 ② 정당한 권원 없는 자가 ③ 업으로서 실시하며, ④ 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 경우만 해당

- 제130조(과실의 추정) 규정이 적용되지 않으며, 특허권자로부터 침해경고를 받은 이후에 실시를 중단하면 비침해

제94조제2항의 신설

□ ‘방법의 사용을 청약하는 행위’의 실시 형태(‘특허법 개정안의 산업계 영향 분석에 관한 연구’, ‘19.4월, 법무법인 다래)

- ① 방법발명(프로그램 특허)이 구현된 프로그램이나 데이터를 정보통신망을 통하여 파일(File)형태로 상대방에게 제공(전송)하는 행위
- ② 방법발명(프로그램 특허)이 구현된 프로그램이나 데이터를 매체(USB 등)를 통하여 제공하는 행위
- ③ 온라인 플랫폼에 방법발명(프로그램 특허)이 구현된 프로그램이나 데이터를 업로드하는 행위
- ④ 프로그램 특허의 일부만을 정보통신망을 통하여 전송하고, 이를 전송받은 자가 이를 다운로드하여 전체 프로그램을 실행할 수 있도록 하는 행위
- ⑤ 클라우드컴퓨팅을 이용하여 일방이 클라우드 서버에 프로그램을 업로드하고, 타방이 이를 다운로드하거나 이를 다운로드함이 없이 프로그램을 사용할 수 있도록 하는 행위
- ⑥ 프로그램특허의 내용이 포함된 카탈로그나 책자 등을 문서 또는 전자파일로 배포하는 행위

WTO/TRIPs 제27조제3항의 규정에서는 식물변종의 발명에 관해서는 불특허대상으로 할 수 있되 이를 불특허대상으로 한 경우에는 특별법으로 보호하여야 함을 의무화하고 있다. 이에 구법 제31조에서는 “무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.”고 규정하는 한편, 식물신품종 보호법에 의하여 식물품종을 보호하고 있었다. 다만, 현대 과학기술의 발달에 따라 유성번식식물이라도 유전공학적인 방법으로 반복생식할 수 있다면 특허법의 테두리 안에서 보호할 필요가 있기 때문에 2006. 10. 1. 시행된 현행법(法律 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서는 제31조를 삭제하였다.

특허법상 보호		유성	무성	비고
동물발명		보호	보호	
식물발명	구법	비보호	보호	식물신품종 보호법에 의하여 보호
	현행법	보호	보호	

물건발명과 방법발명의 구별은 발명의 명칭이나 청구범위의 표현에 따라 결정되는 것이 아니라 발명의 실체에 따라 정하여진다. 구체적으로 발명의 실체가 「**時の 요소**」를 발명구성상의 필수요건으로 하는 때에는 방법발명으로 보고, 이와 같은 **時の 요소**를 필요로 하지 아니한 것일 때에는 물건발명으로 보는 것이 원칙이다. 예를 들어, 「A 와 B 로 구성된 것을 특징으로 하는 물건」과 「B 와 A 로 구성된 것을 특징으로 하는 물건」은 동일한 물건발명이지만, 「X 공정 후 Y 공정을 거치는 물건의 제조방법」과 「Y 공정 후 X 공정을 거치는 물건의 제조방법」은 구성요소 사이의 **時の 흐름**이 변화되었기 때문에 동일한 방법발명이라 할 수 없다.

구별기준



구별실익1

실시의 정의를 달리함

A:B1:B2

물건발명

그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

방법발명

그 방법을 사용하는 행위 또는 **그 방법의 사용을 청약하는 행위**

제법발명

그 방법을 사용하는 행위 또는 **그 방법의 사용을 청약하는 행위** 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

구별실익2

A1:A2,B

실용신안등록을 받기 위해서는 물품의 형상, 구조 또는 그 조합에 관한 고안, 즉 **물품성**이 있는 고안이어야 한다(實用 4①). 따라서 **물품성**이 있는 협의의 물건발명의 경우에만 물질발명이나 방법발명과 달리 실용신안으로 보호받을 수 있다.

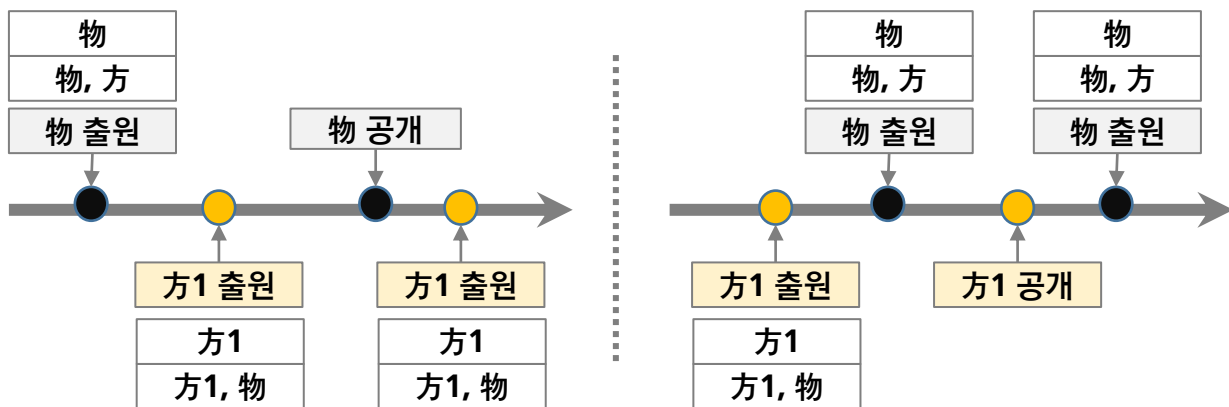
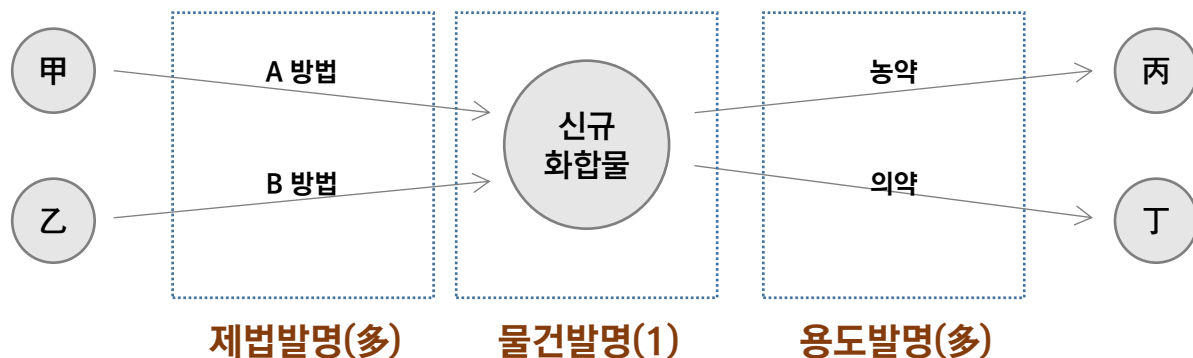
구 별	실용신안보호대상	도면 첨부
협의의 물건발명	○(∵물품의 형상·구조·조합에 관한 고안)	필수
물질발명/방법발명	×	선택

구별실익3

A:B2

물건발명(物) : 제법발명(方) = 1 : 多

물건발명이 신규성 또는 진보성이 있는 경우 제법발명 또는 용도발명은 당연히 신규성 또는 진보성이 있다. 반면 물건발명이 신규성 또는 진보성이 없는 경우 제법발명 또는 용도발명은 개별적으로 신규성 또는 진보성 여부를 판단하여야 한다.



실시 : 물건발명(物) ⊃ 제법발명(方)

物 실시

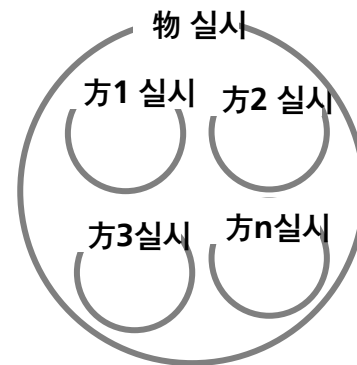
그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

方 실시

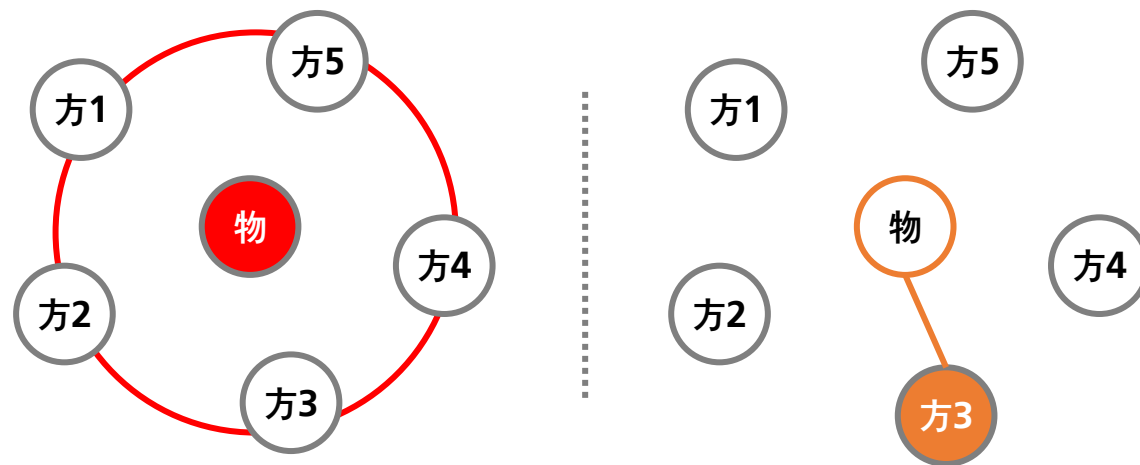
그 방법을 사용하는 행위(물건의 생산)

그 방법의 사용을 청약하는 행위
(물건생산의 청약)*

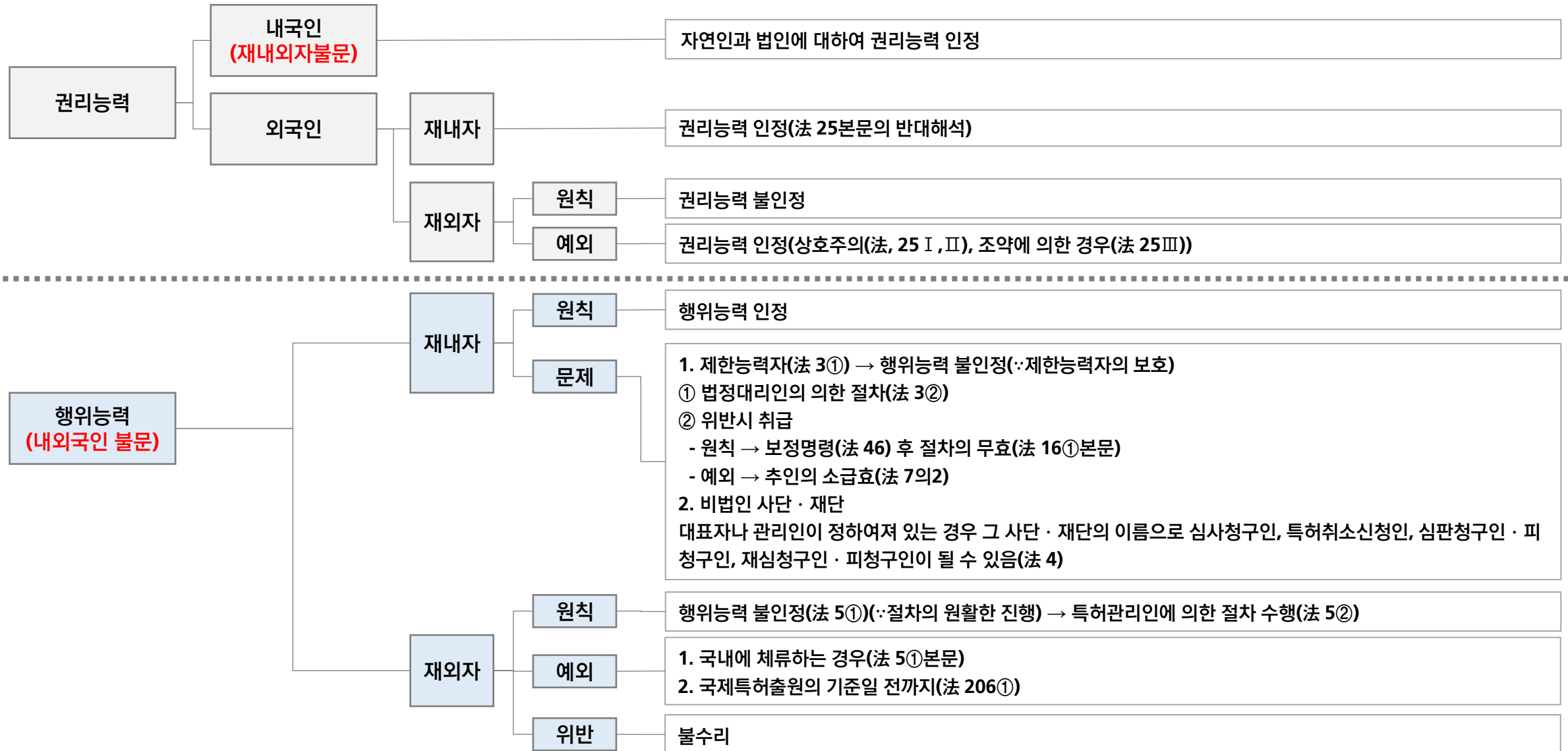
그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

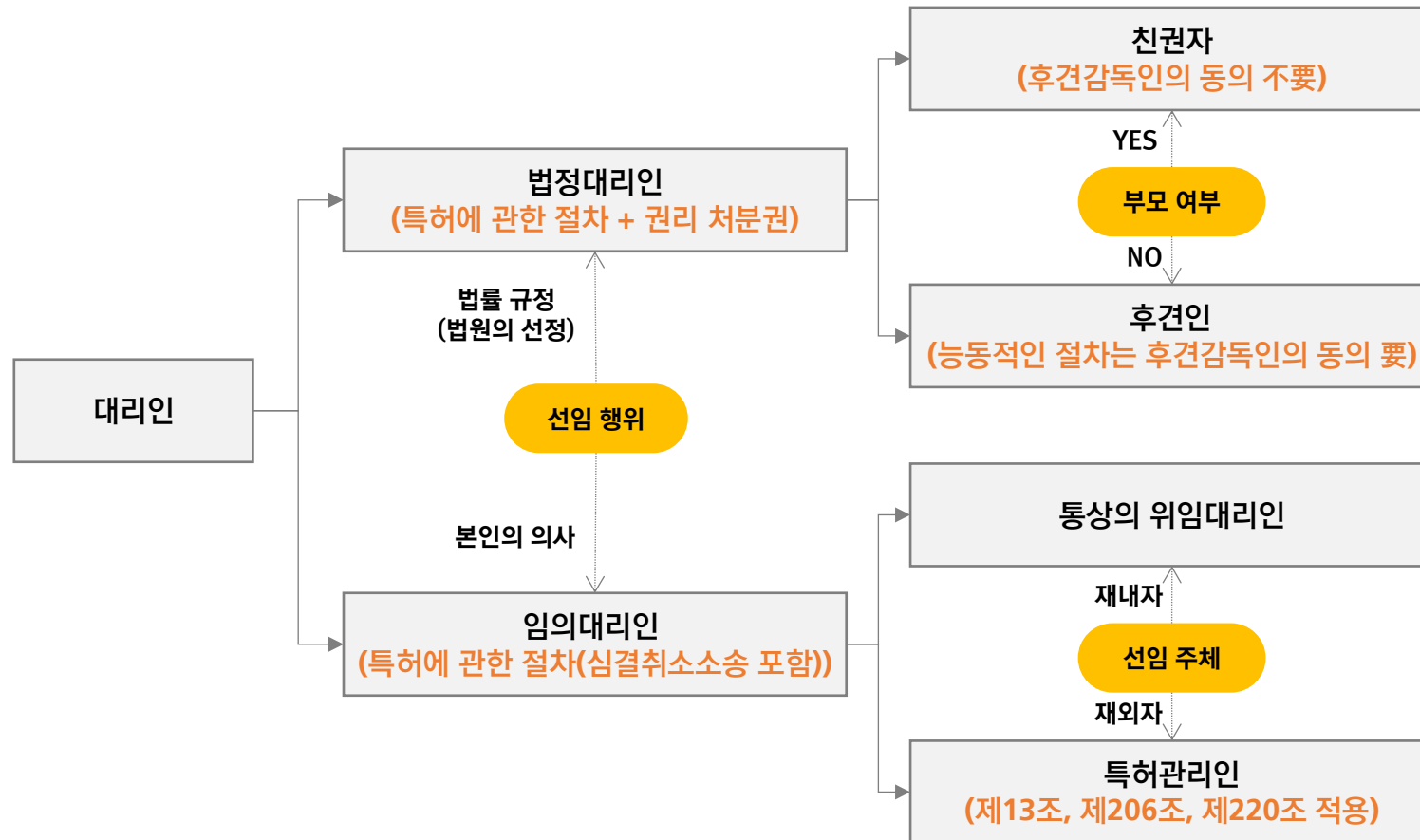


특허권의 효력 : 물건발명(物) ⊃ 제법발명(方)



* 물건생산의 청약은 물건발명의 실시(물건발명에 대한 특허권 침해)에 해당하지 않음





제13조(재외자의 재판관할) 재외자의 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 특허관리인이 있으면 그 특허관리인의 주소 또는 영업소를, 특허관리인이 없으면 지식재산처 소재지를 「민사소송법」 제11조에 따른 재산이 있는 곳으로 본다.

제206조(재외자의 특허관리인의 특례) ① 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.
 ② 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 총리령으로 정하는 기간에 특허관리인을 선임하여 지식재산처장에게 신고하여야 한다.
 ③ 제2항에 따른 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

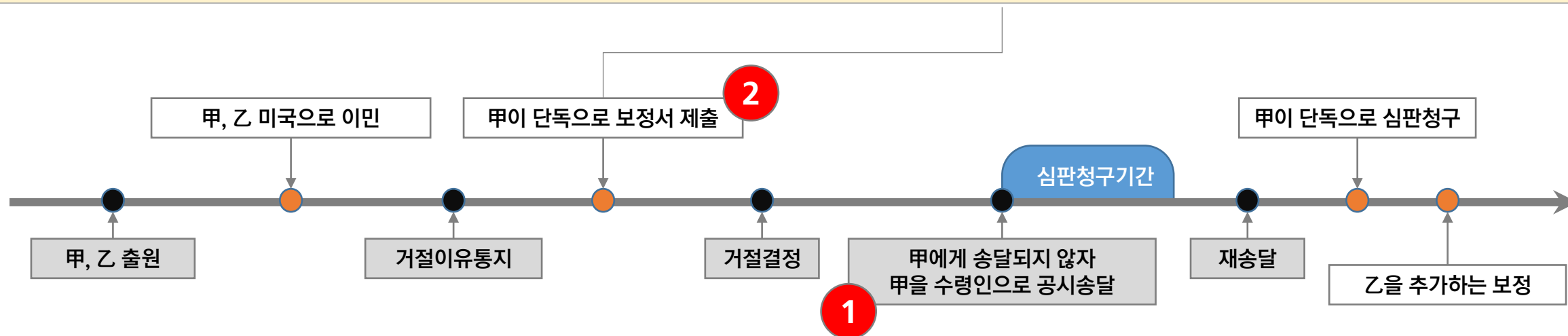
제220조(재외자에 대한 송달) ① 재외자로서 특허관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다.
 ② 재외자로서 특허관리인이 없으면 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.
 ③ 제2항에 따라 서류를 항공등기우편으로 발송한 경우에는 그 발송일에 송달된 것으로 본다.

대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결 【거절결정(특)】

[1] 출원발명의 공동출원인에 대한 공시송달의 요건: 공동출원인에 대하여 특허법 제219조 제1항에 의한 공시송달을 실시하기 위해서는 '공동출원인 전원의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 때'에 해당하여야 하고, 이러한 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 공동출원인 중 1인에 대하여 이루어진 공시송달은 부적법하고 그 효력이 발생하지 않는다.

[2] 지식재산처장이 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 재외자의 서류를 반려하지 않고 특허에 관한 절차를 진행한 경우, 사후에 그 절차상 하자를 주장할 수 있는지 여부(소극): 지식재산처장은 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 서류를 반려하지 아니하고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 진행한 이후에는 특허법 제5조 제1항에 위반된다는 이유로 제출된 서류의 절차상 하자를 주장할 수는 없다.

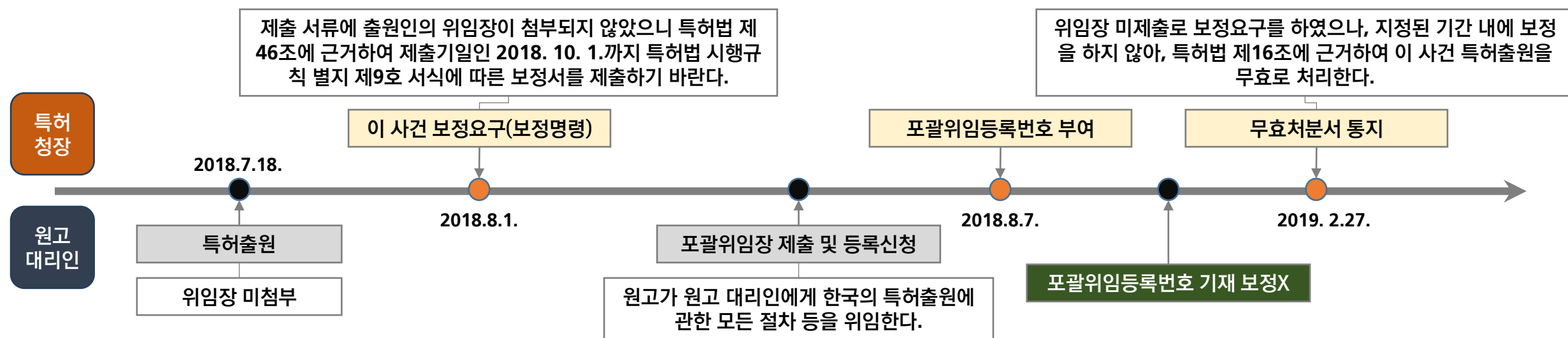
지식재산처장이 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 재외자의 서류를 반려하지 않고 특허에 관한 절차를 진행한 경우, i) 특허관리인제도는 지식재산처가 국내에 거주하지 않는 자와 직접 절차를 수행함에 따른 번잡과 절차지연을 피함으로써 원활한 절차수행이 가능하도록 하기 위함에 그 의의가 있는 점, ii) 재외자라 하더라도 국내에 체재하는 경우에는 직접 절차를 밟을 수 있는 점, iii) 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 그 절차를 밟은 경우에 이를 특허거절이유나 특허무효사유로는 하고 있지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 지식재산처장은 사후에 이를 이유로 제출된 서류의 절차상 하자를 주장할 수는 없다.



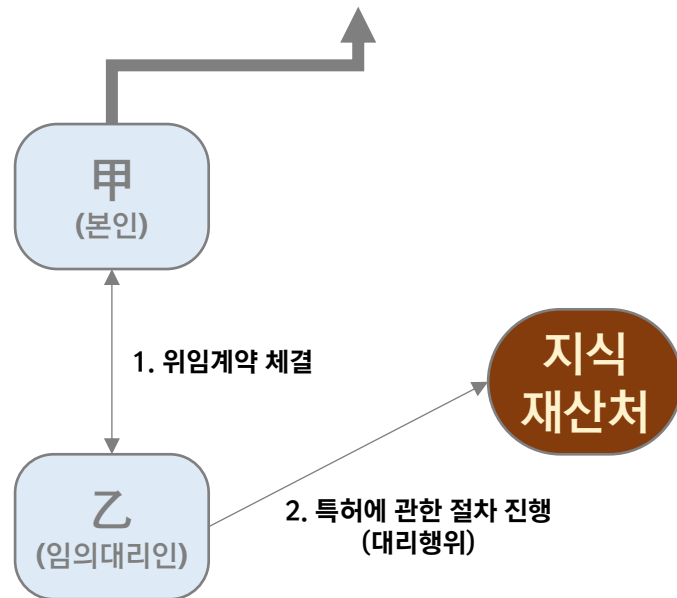
대법원 2023. 7. 13. 선고 2021두63099 판결 【특허출원 무효처분 취소】

[1] 특허법 제46조 제2호는 지식재산처장 등이 특허에 관한 절차가 특허법 또는 특허법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 지식재산처장 등에게 제출할 수 있다고 규정하면서, 보정명령에 대한 의견서나 그 제출에 관하여는 특정한 방식을 요구하지 않고 있다. 한편 특허법 시행규칙 제13조 제1호는 특허법 제46조에 따라 보정을 하려는 자는 특허법 시행규칙 별지 제9호 서식의 보정서에 보정 내용을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장 등에게 제출하도록 규정하고 있으나, 이는 행정청의 편의를 위한 규정으로 보정 내용을 증명하는 서류의 제출은 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위라고 해석되고, 이러한 경우 행정청으로서 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있다. 따라서 특허법 제46조에 따른 지식재산처장 등의 보정명령을 받은 사람으로부터 지식재산처장 등에게 보정 내용을 증명하는 서류가 제출되었을 때에는 그 표제 등의 여하를 불문하고 이를 위 보정명령에 대한 의견서 제출로 보아야 한다(대법원 1995. 11. 7. 선고 94누10061 판결, 대법원 2000. 6. 9. 선고 98두2621 판결 등 참조).

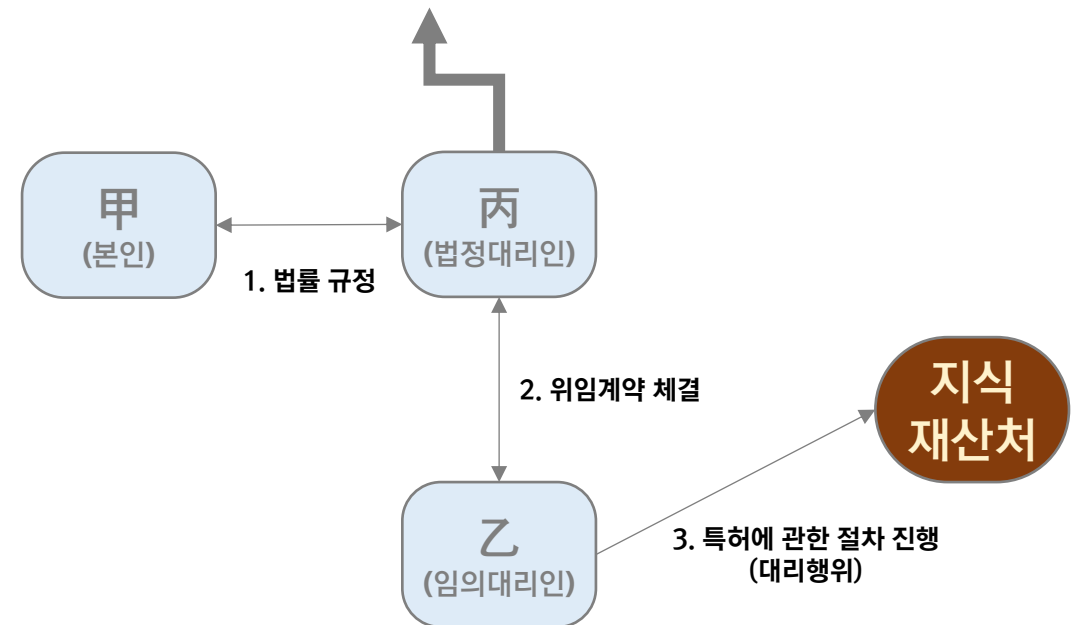
[2] 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인에게 대리권을 수여하는 데에는 일정한 방식이 요구되지 않고, 다만 그 대리권의 증명은 특허법 제7조에 따라 서면으로써 하여야 한다. 그런데 특허법 시행규칙 제5조의2 제1항은 대리인에게 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 특허에 관한 절차 진행을 포괄위임 하려는 경우에는 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다고 규정하므로, 이미 출원한 사건의 특허에 관한 절차 또한 포괄위임의 대상이 되고, 포괄위임등록 신청을 위해 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 지식재산처장에게 제출한 이상 포괄위임 대상 사건에 관한 대리권의 서면 증명은 이루어졌다고 볼 수 있다.



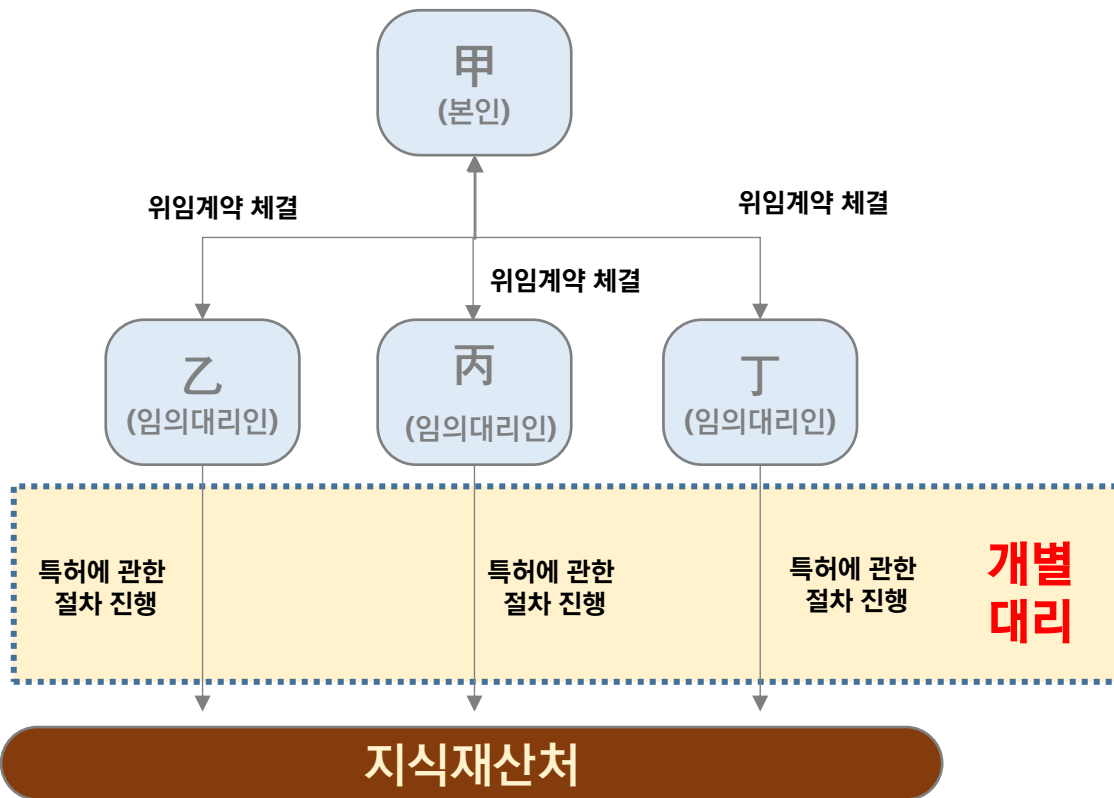
3. 사망, 행위능력 상실, 합병에 의한 소멸, 수탁자의 신탁임무 종료



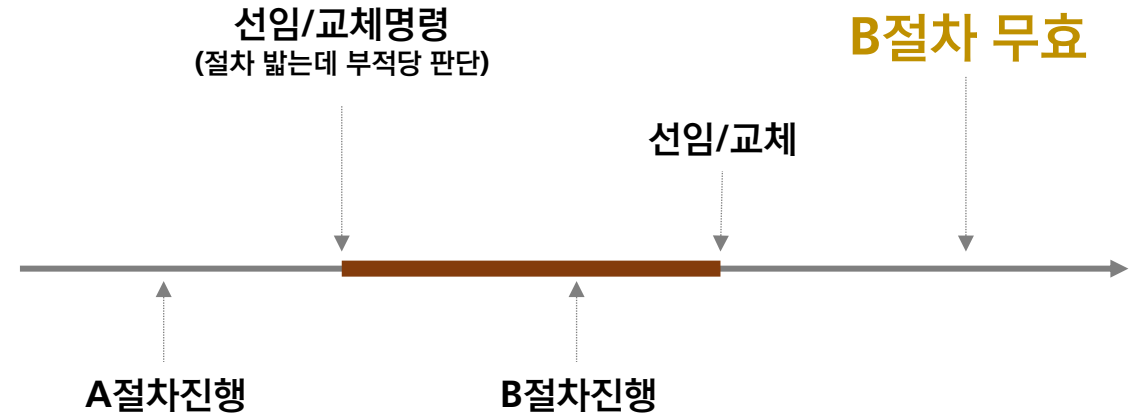
4. 사망, 행위능력 상실, 대리권 소멸이나 변경



개별대리



선임 및 교체



구 별		내 용
출원 및 심판 청구	출원	1. 특허출원 → 공유자 모두가 공동출원하여야 하며(法 44), 이에 위반시 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①). 다만, 등록 후 법원에 이전청구 가능하고(法 99의2), 이전청구에 기초하여 이전등록이 있으면 특허무효사유에서 제외 2. 존속기간연장등록출원 → 공유자 모두가 공동출원하여야 하며(法 90③, 92의3③), 이에 위반시 거절이유(法 91, 92의4), 무효사유(法 134①②)
	심판 청구	1. 특허무효심판(法 133), 특허권의 존속기간 연장등록무효심판(法 134), 정정무효심판(法 137) 또는 권리범위확인심판(法 135)을 청구하는 자가 2인 이상이 있는 때에는 그 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다(法 139①). 2. 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 139③). 이에 위반시 심결각하.
그 밖의 절차		1. 대표자를 선정하지 아니한 경우 ① 원칙 → 각자대표(法 11①본문) ② 예외 → 제11조 제1항 각호에 해당하는 경우 모두대표(法 11①각호) 2. 대표자를 선정한 경우 ① 원칙 → 대표자대표(法 11①단서) ② 문제되는 경우 → 제11조 제1항 각호에 해당하는 경우 모두의 동의 ③ 대표자의 증명(法 11②) → 서면으로 증명

복수 당사자 예시

공동발명

甲, 乙, 丙

출원 및
심판청구

출원

- 甲, 乙, 丙 전원

심판청구

- 甲, 乙, 丙 전원

그 밖의
절차

대표자 선정

- 甲, 乙, 丙 각자 절차 수행
- 단, 제11조제1항 각호는
甲, 乙, 丙 전원 절차 수행

대표자 선정
(甲 선정)

- 甲만이 절차 수행
- 단, 제11조제1항 각호는
乙, 丙의 동의

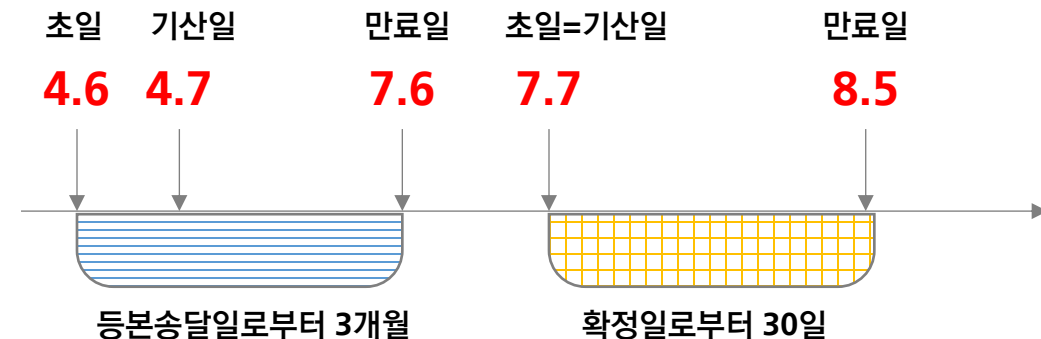


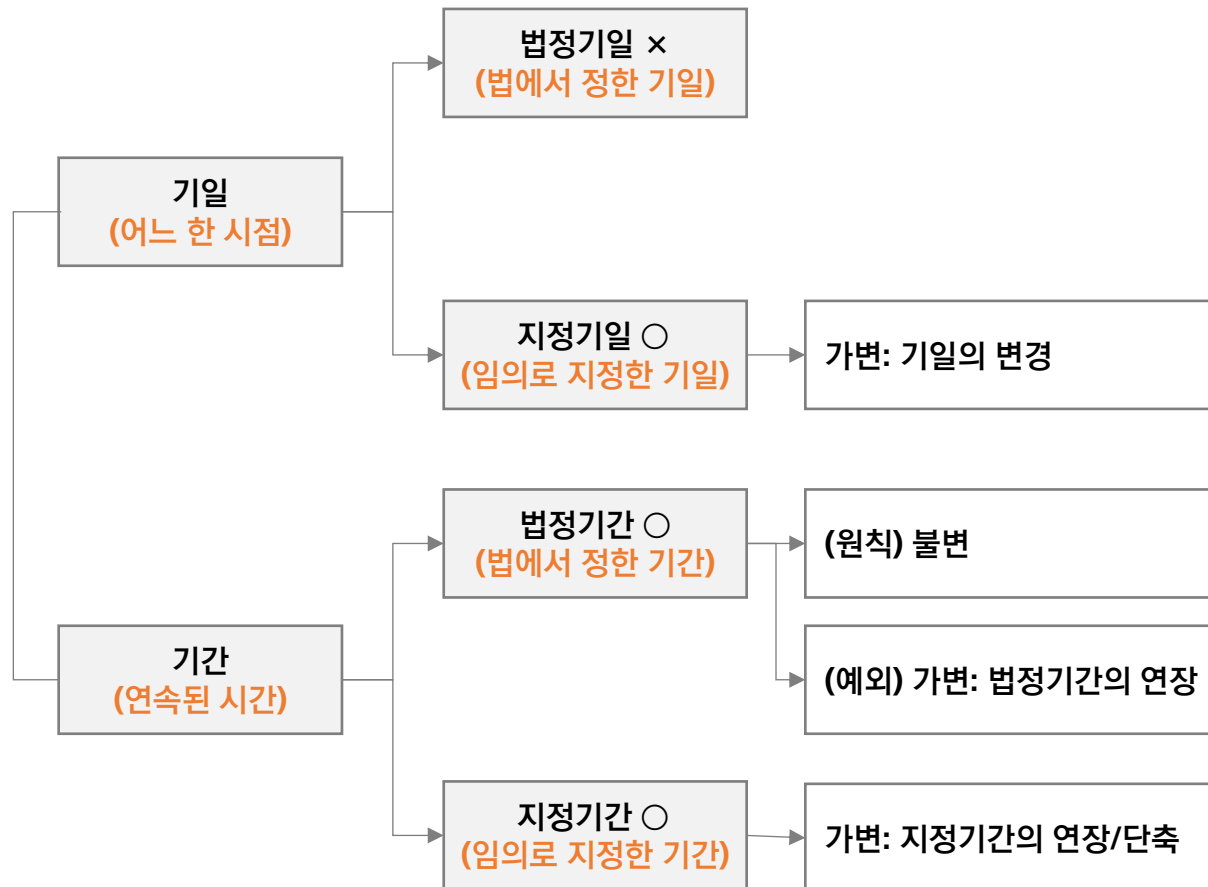
- 문제의 사실관계에서 파악
- 원칙: 초일의 다음날 = 기산일
- 예외: 오전 0시 시작의 경우 초일 = 기산일 (기간의 연장, 확정된 날 등)
- 일, 주: 자연적 계산방법(정확+불편)
- 월, 년: 역법적 계산방법(부정확+편리)
- 원칙: 최후 월의 기산일 전일로 만료
- 예외
 - 해당일이 없는 경우: 그 월의 마지막 날로 만료
 - 해당일이 공휴일(노동절, 토요일 포함)인 경우: 다음날로 만료 (다만, 당사자가 밝아야 하는 특허에 관한 절차(지식재산처 절차에 한함)에 한함)

2017년 2월 20일부터 1개월과 30일의 만료일은?
(단, 오전 0시부터 시작하지 않음)

	1개월	30일
초일	2.20	2.20
기산일	2.21	2.21
계산방법	역법적	자연적
만료일	3.21의 전일=3.20	30-7=23일 3.23의 전일=3.22 * 계산일수 - 그 달의 소요일수(말일-기산일)=잔존일수 * 잔존일수를 다음달로 넘겨 계산

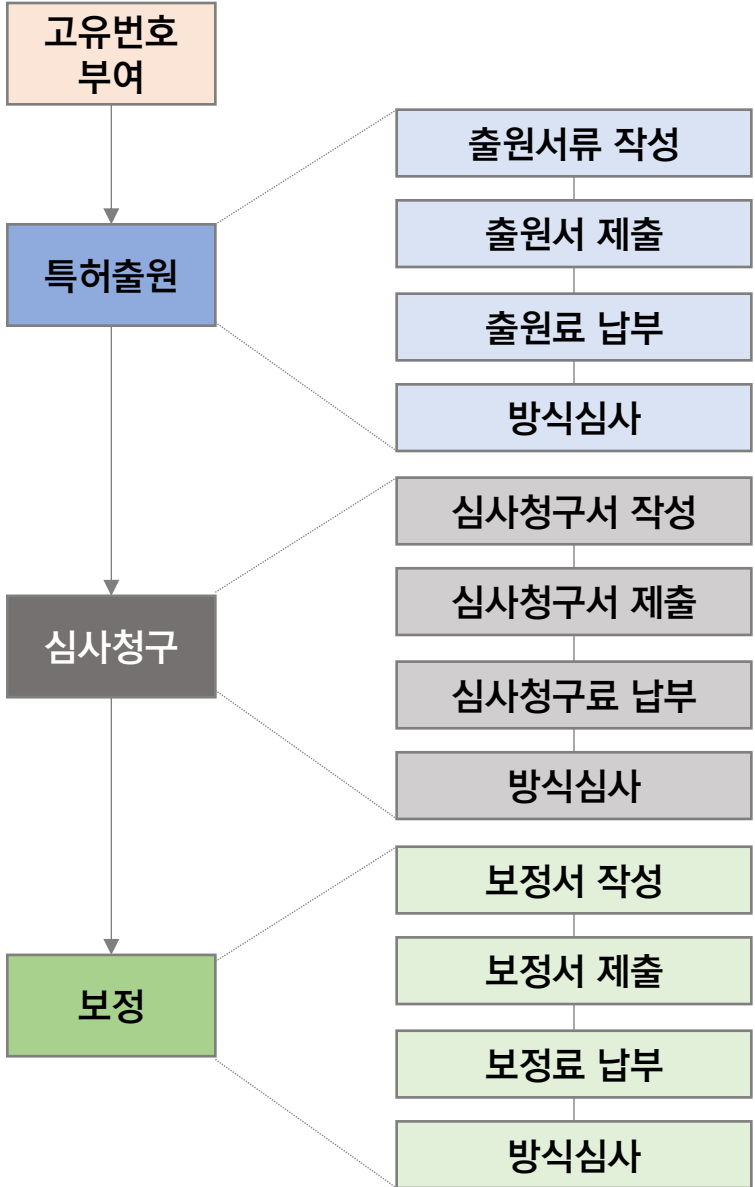
2023년 4월 6일에 거절결정등본이 송달되었고, 불복하지 않아 거절결정확정된 경우 그 확정일로부터 30일은?



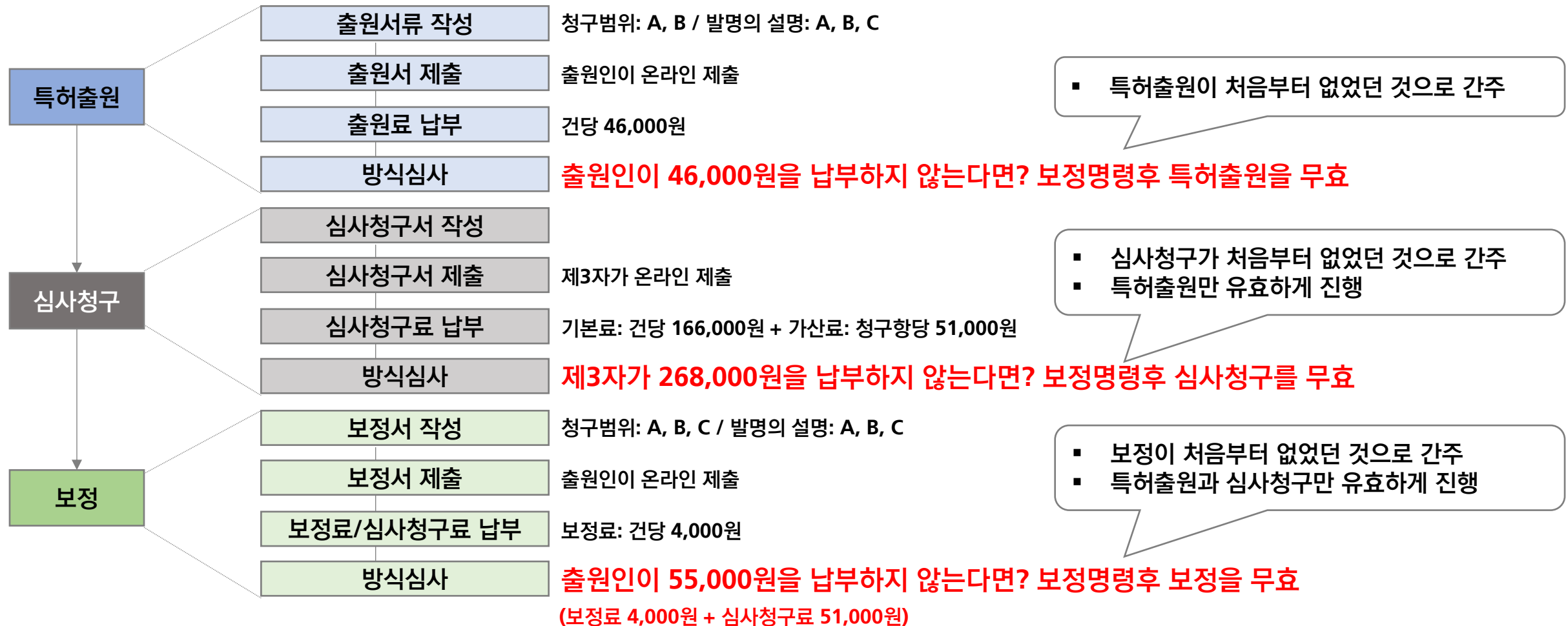


구 분		법정기간의 연장 (法 15①)	지정기간의 연장 · 단축(法 15②)	지정기일의 변경 (法 15③)
성 격		재량행위		
요 건	주 체	1. 지식재산처장 2. 청구 또는 직권	1. 지식재산처장, 특허심판원장, 심판장, 심사관 2. 단축 - 청구 3. 연장 - 청구 또는 직권	1. 심판장 2. 청구 또는 직권
	대 상	거절결정불복심판의 청구기간(法 132의17): 거절결정등본송달일로부터 3개월	모든 지정기간	모든 지정기일
효 과		1회에 한해 30일 이내 기간의 연장 (단, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장가능)	기간의 단축 또는 연장 (단, 이해관계인의 이익 부당 침해×)	기일의 변경

구 분		내 용
고유번호의 부여 및 기재 (法 28의2)		1. 신청에 의한 부여(法 28의2①②) 2. 직권에 의한 부여(法 28의2③) 3. 기재의 효과 → 주소에 같음(法 28의2④) 4. 대리인번호의 준용(法 28의2⑤)
특허에 관한 서류의 작성		특허법에서 정한 양식에 따라 서류를 작성(양식주의, 요식주의)
특허에 관한 서류의 제출	서면에 의한 제출 (法 28)	* 효력발생시기 1. 원칙 - 도달주의 2. 예외 - 우편의 경우 발신주의(통신일부인, 우편물 수령증에 의하여 판단) 3. 예외의 예외 - 우편의 경우라도 등록신청서류와 국제출원에 관한 서류는 도달주의
	전자문서에 의한 제출 (法 28의 3, 4)	1. 종류 - 온라인 제출과 전자적 기록매체 제출(法 28의3①) 2. 절차 - 전자문서이용신고 후 전자서명, 전자문서는 전자서명한 자가 제출한 것으로 간주(法 28의4) 3. 효력 ① 서면과 동일한 효력(法 28의3②) ② 정보통신망을 이용하여 제출한 전자문서는 접수번호 확인할 수 있을 때, 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 간주(法 28의3③)
수수료의 납부		1. 특허에 관한 절차를 밟은 자가 수수료 납부(法 82①) 2. 접수번호 부여받아 다음날까지 납부
방식심사	흠결이 없는 경우	
	흠결이 있는 경우	보정가능 (法 46)한 경미한 흠결의 경우
		보정불가능 (施規 11)한 중대한 흠결의 경우



지식재산처장 등은 절차보정사유(法 46)에 해당함을 이유로 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 그 보정을 명한 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있으며, 무효가 된 경우 해당 특허에 관한 절차는 처음부터 없었던 것으로 본다(法 16①). 그러나 무효처분 이외의 절차는 계속 유효하게 진행된다.



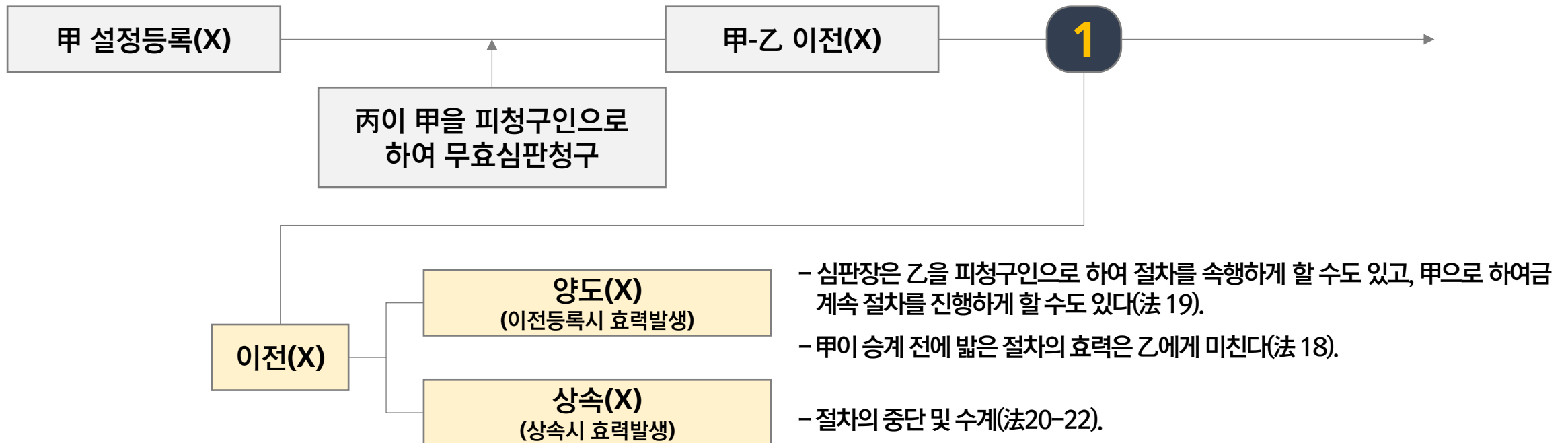


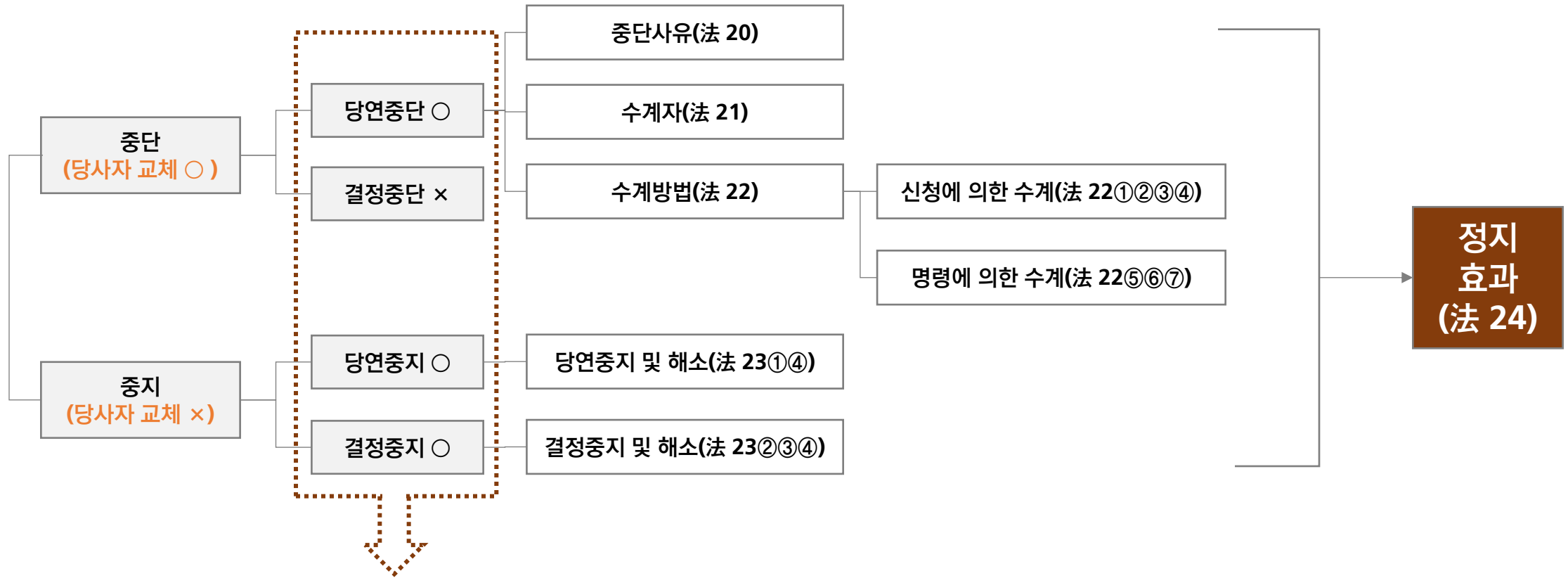
대법원 1967. 6. 27. 선고 67후1 판결 【실용신안등록무효】

특허사건에 있어서의 당사자 적격에 관한 법리를 오해한 위법이 있는 사례: 특허의 등록무효를 구하는 특허사건은 그가 가지고 있는 특허의 등록을 대상으로 하여 그 등록의 무효사유를 주장하여, 이에 대한 심판을 구하는 것이니 만큼, 심판청구인으로서 그 등록이 존재하는 한 언제나 그 권리자를 상대로 같은 사유를 주장하여 무효심판을 구할 필요와 그 이익이 있는 것이라고 할 것임에 반하여 특허법이나 민사소송법상 사건 계속 중, 그 등록권리의 특별승계가 있는 경우 승계인으로 하여금 당사자의 지위를 당연히 승계케 하는 규정이 없으므로, 등록무효심판 계속 중 피심판청구인이 그 등록권리를 제3자에게 이전하였다 하더라도 당사자로서의 지위에는 영향을 받지 아니한다.

대법원 1977. 12. 27. 선고 76후33 판결 【권리범위확인】

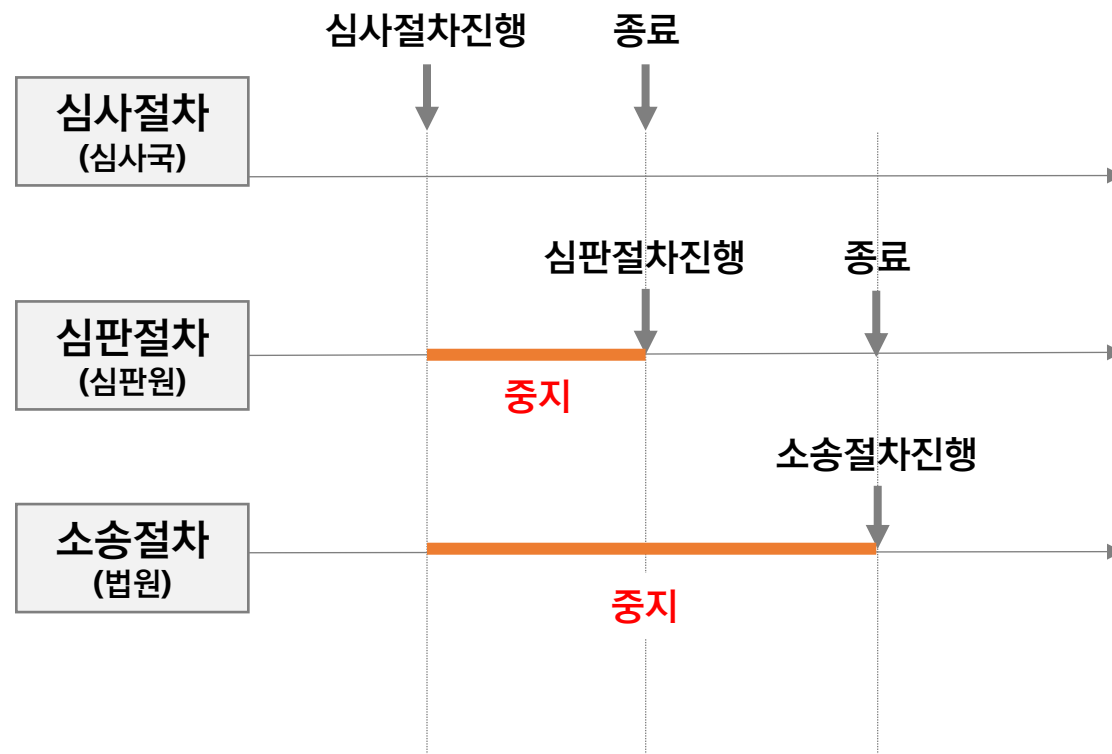
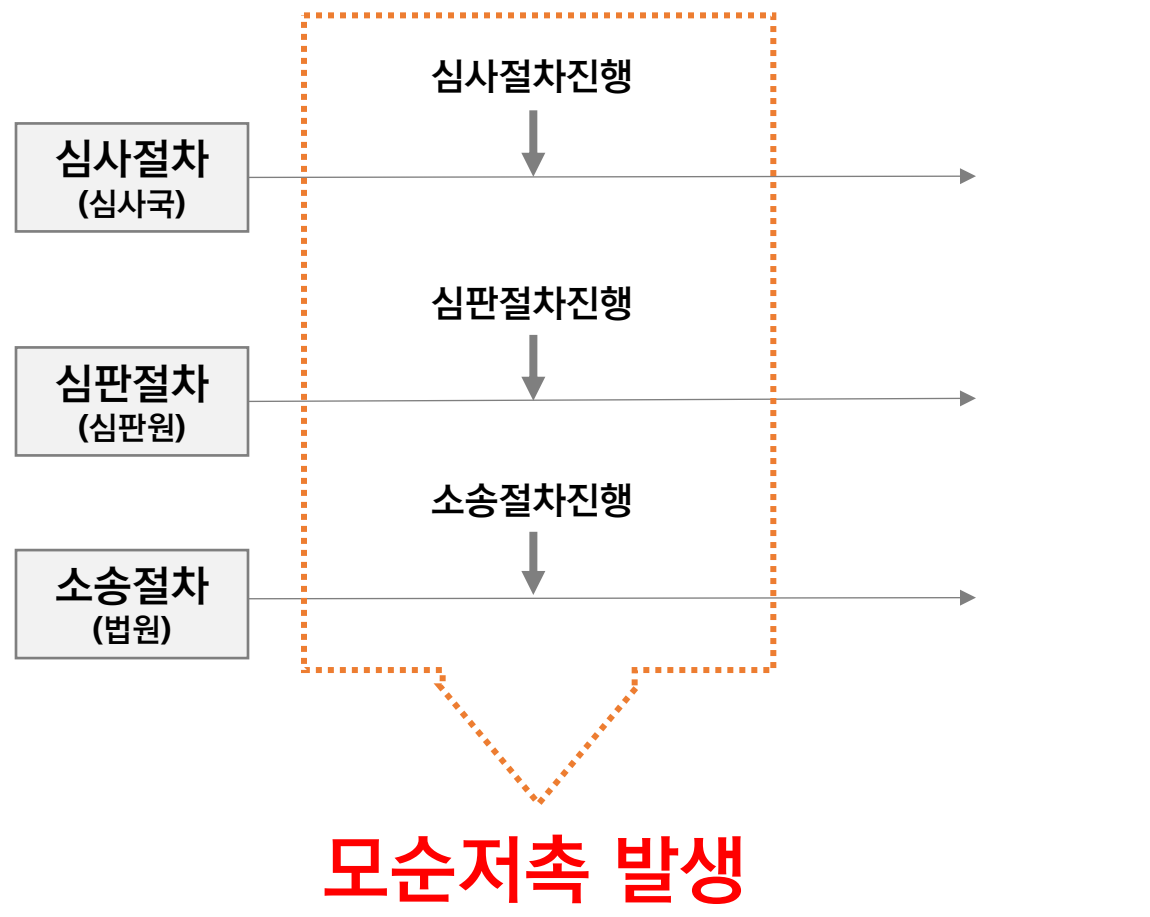
실용신안권의 권리범위확인심판청구인이 그 심판 계속 중에 그 실용신안 물건의 제조판매영업권을 양도하였다 하더라도 본법상의 이해관계인임에는 변함이 없으므로 심판청구인에 대한 심결이나 판결의 효력은 그 승계인에게도 미치는 것이므로 심판청구인은 종국에 이르기까지 당사자로서 자기 또는 승계인을 위하여 행위할 당사자 적격을 가진다.



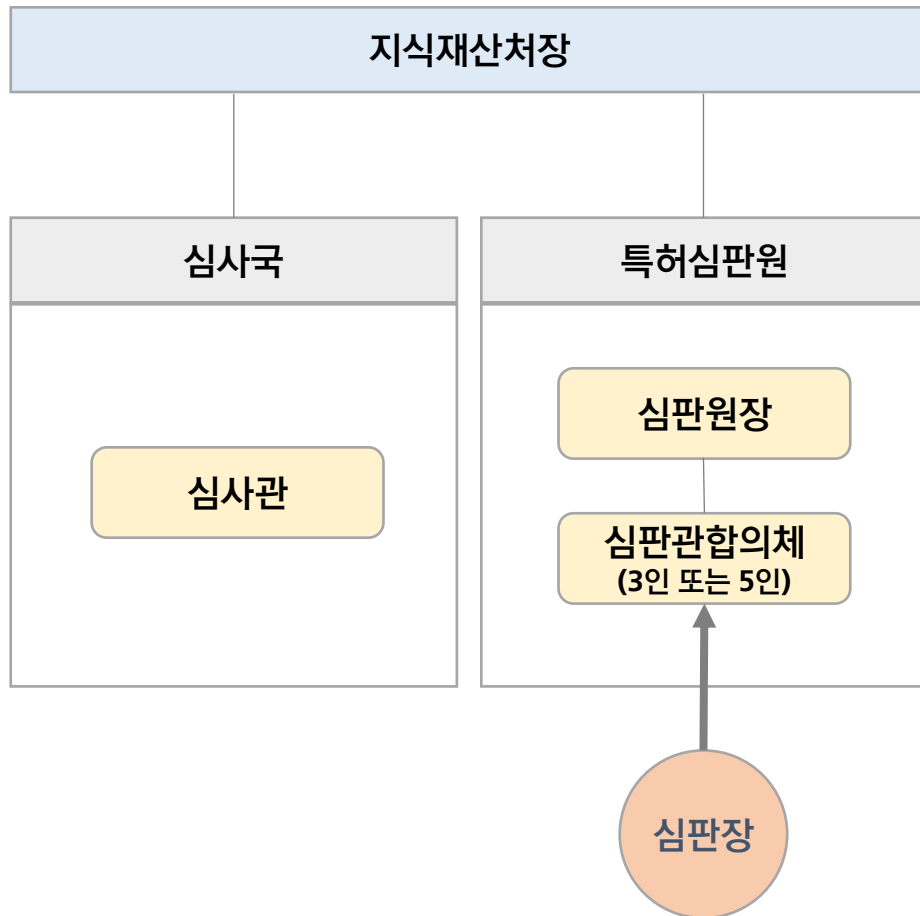


구분	절차 정지	절차 정지의 해소
당연중단	사유발생	사유소멸 & 수계
당연중지	사유발생	사유소멸
결정중지	사유발생 & 결정	사유소멸 & 결정

특허출원의 심사에 있어서 필요한 경우에는 특허취소신청에 대한 결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 심사절차를 **중지할 수 있다**(法 78①). 심판장은 심판에서 필요하면 **직권 또는 당사자의 신청에 따라** 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 **중지할 수 있다**(法 164①). 법원은 소송에서 필요하면 **직권 또는 당사자의 신청에 따라** 특허여부결정, 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 **중지할 수 있다**(法 78②, 164②). 심사와 심판 또는 소송중인 사건들이 상호 관련성이 있을 때 이 사건들 간에 **상호 모순 · 저촉되는 결과를 예방**하고, 나아가 심사, 심판 및 소송 등의 소송경제를 도모하기 위해서이다. 다만, 절차를 중지할 것인지 여부는 **재량사항**이다.



지식재산처의 구조



주체별 공통 역할

구분		심사국	심판원
절차사무	대리인 선임/교체(法 10)	지식재산처장	심판장
	절차의 속행(法 19)		
	취지통지(法 22)		
	부분송달(法 108, 132의4, 147, 156)		
	등본송달(法 67, 132의14, 162)		
실체사무	의견제출기회의 부여 (法 63, 132의13, 157, 159)	심사관	심판장
실체심사/실체심리		심사관	심판관합의체

총칙

목적(法 1)

정의(法 2)

행위능력(法 3~5①, 7의2)

대리인(法 3②, 5②~10, 12)

복수당사자 대표(法 11)

재외자의 재판관할(法 13)

기일과 기간(法 14, 15)

특허에 관한 절차 일반(法 16, 28~28의5)

추후보완(法 17, 67의3)

절차의 효력의 승계 및 절차의 속행(法 18, 19)

절차의 정지(法 20~24, 78, 164)

발명의 성립성(法 2)

원칙: 발명의 정의 규정 만족

예외: 탄력적 해석

식물발명

미생물발명

용도발명

컴퓨터프로그램관련발명

행위능력(法 3~5①)

재내자

원칙

예외(法 3, 4)

재외자

원칙(法 5①)

예외

대리인(法 3②, 5②~10, 12)

대리인의 종류(法 3 ②, 5②)

대리권의 내용

대리권의 범위(法 6)

대리권의 증명(法 7)

대리권의 불소멸(法 8)

개별대리(法 9)

대리인의 선임/개임(法 10)

민사소송법의 준용(法 12)

복수당사자 대표(法 11)

출원 및 심판청구

출원(法 44, 90, 92의3)

심판청구(法 139)

그 밖의 절차

대표자 불선정(法 11①본문)

대표자 선정(法 11①단서)

총칙



기일과 기간(法 14, 15)



특허에 관한 절차 일반(法 16, 28~28의5)



절차의 정지(法 20~24, 78, 164)

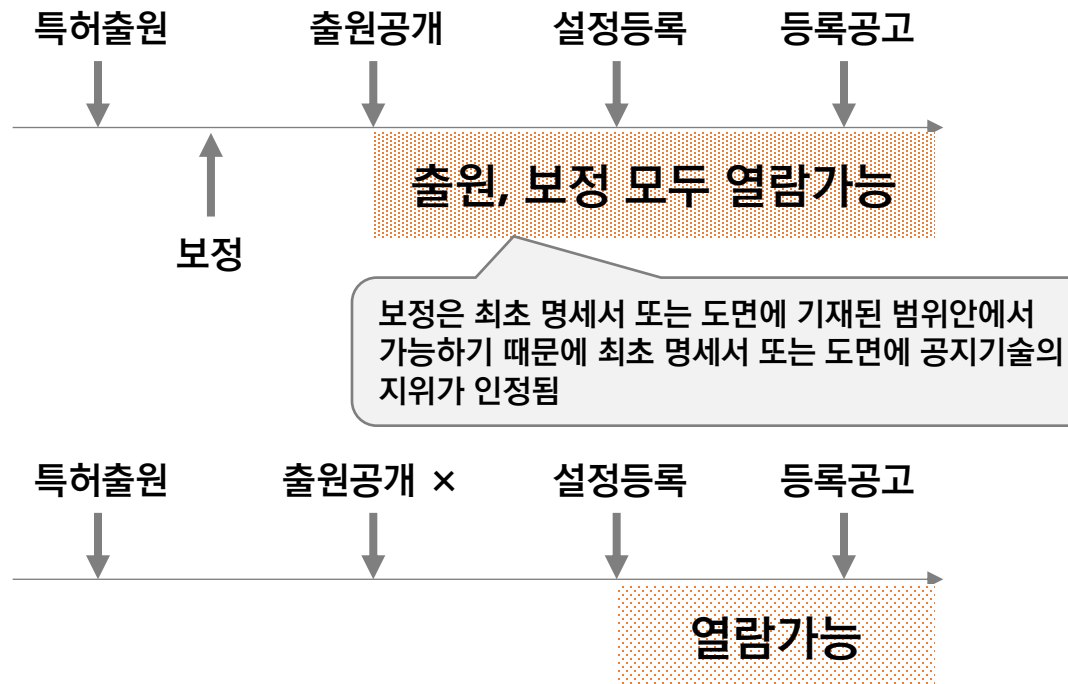


보칙

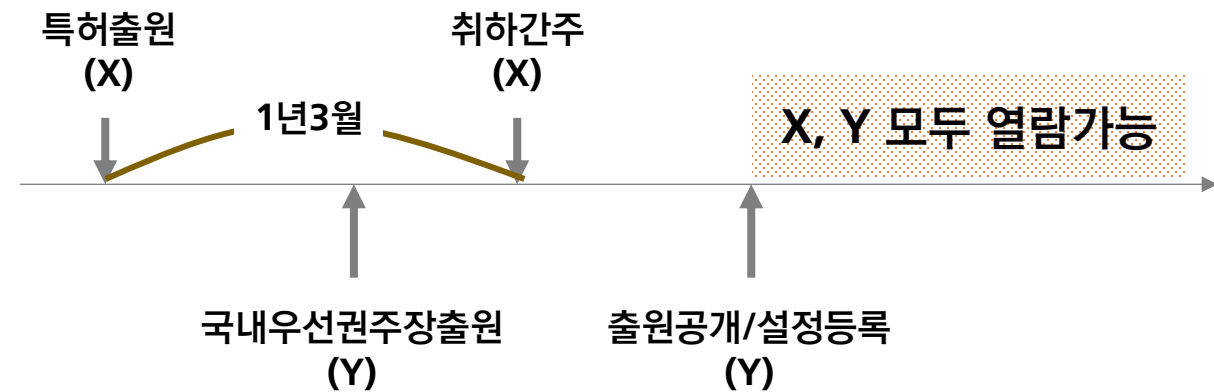


특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다(法 216①). 지식재산처장 또는 특허심판원장은 신청이 있더라도 i) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(국내 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류, ii) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 특허거절결정에 대한 심판(法 132의17)에 관한 서류, iii) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류 중 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다(法 216②).

출원공개 또는 설정등록된 후부터 최초 명세서 또는 도면의 공지기술 지위 인정



국내우선권주장의 적법성을 판단하기 위해서 국내우선권주장출원이 출원공개 또는 설정등록된 후부터 선출원의 열람을 허가함



* 변경출원을 제외하고 있는 것은 입법불비라고 판단됨

		용도발명	의약발명
의의		물질로부터 새로운 속성을 발견하고 새로운 용도로 이용하는 과정에서 창작적 요소가 존재하는 발명을 말한다.	사람의 질병을 진단·치료·처리·예방을 하는 물질인 의약의 발명 이외에 둘 이상의 의약을 혼합하여 하나의 의약을 조제하는 방법의 발명까지 포함한 개념이다.
특허 요건 및 특허 출원	성 립 성	1.발견이지만 창작적 요소가 보호가치가 있어 발명의 성립성 인정 2.그 용도가 당시까지 알려지지 않았던 새로운 것이면 충분하고, 그 물질이나 그 물질의 다른 용도가 출원 이전에 공지되어 있어야 하는 것은 아님	의약발명 중 물질발명의 대부분은 천연물질에서 인체의 치료에 필요한 특정 성분을 발견하고 추출하여 의약으로 이용하는 바, 용도발명의 일종
	기타	물건발명/방법발명 중 택일하여 청구항 기재 가능	1.약리기전이 명확히 밝혀지지 아니한 이상 일정한 확실성 및 반복가능성이 미약하여 목적달성이 현저히 의심스럽기 때문에 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 발명의 설명의 기재요건을 충족 2.청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 명세서 등 발명의 설명의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 적법 3.청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소는 아님 4.의약의 투여용법과 투여용량도 용도발명의 구성요소에 해당함 5.의약발명은 인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니하기 때문에 산업상 이용가능성(法 29①본문)이 인정되고, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하지 아니하기 때문에 공서양속에 위반되거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명(法 32)에 해당하지 않음 6.화학물질이나 의약품 등의 경우에는 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없어 신규성이 상실되지 아니함 7.특정한 투여용법이나 투여용량으로 인하여 나타난 유리한 효과가 통상의 기술자의 기술수준에서 예측되는 범위를 넘는 현저한 경우이거나 또는 통상의 기술자가 당해 의약발명의 약리효과가 온전히 유지되면서 독성이나 부작용이 최소화되는 특정한 투여용법이나 투여용량을 선행발명 또는 공지의 발명으로부터 예측할 수 없었던 경우에 진보성을 인정받을 수 있음
특 허 권	효 력	용도발명은 물건발명을 그대로 이용한 것이므로 선출원되어 특허된 물건발명과 이용관계임 → 용도발명의 특허권자는 물건발명의 특허권자의 허락을 받거나(法 98), 통상실시권허여심판(法 138)에 의하지 아니하고는 용도발명을 실시 불가	1.「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고를 위한 연구 또는 시험의 경우에는 특허권의 효력이 미치지 아니함(法 96① I) 2.둘 이상의 의약[사람의 질병의 진단·경감·치료·처치(處置) 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다]이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니함(法 96 ②). 3.특허발명을 실시하려는 자는 수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 지식재산처장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다(法 107).
	제 한		
	확 장	1.허가 등에 따른 존속기간의 연장가능 2.연장등록된 특허권의 효력은 용도에 사용되는 물건에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미침	1.허가 등에 따른 존속기간의 연장가능 2.연장등록된 특허권의 효력은 용도에 사용되는 물건에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미침

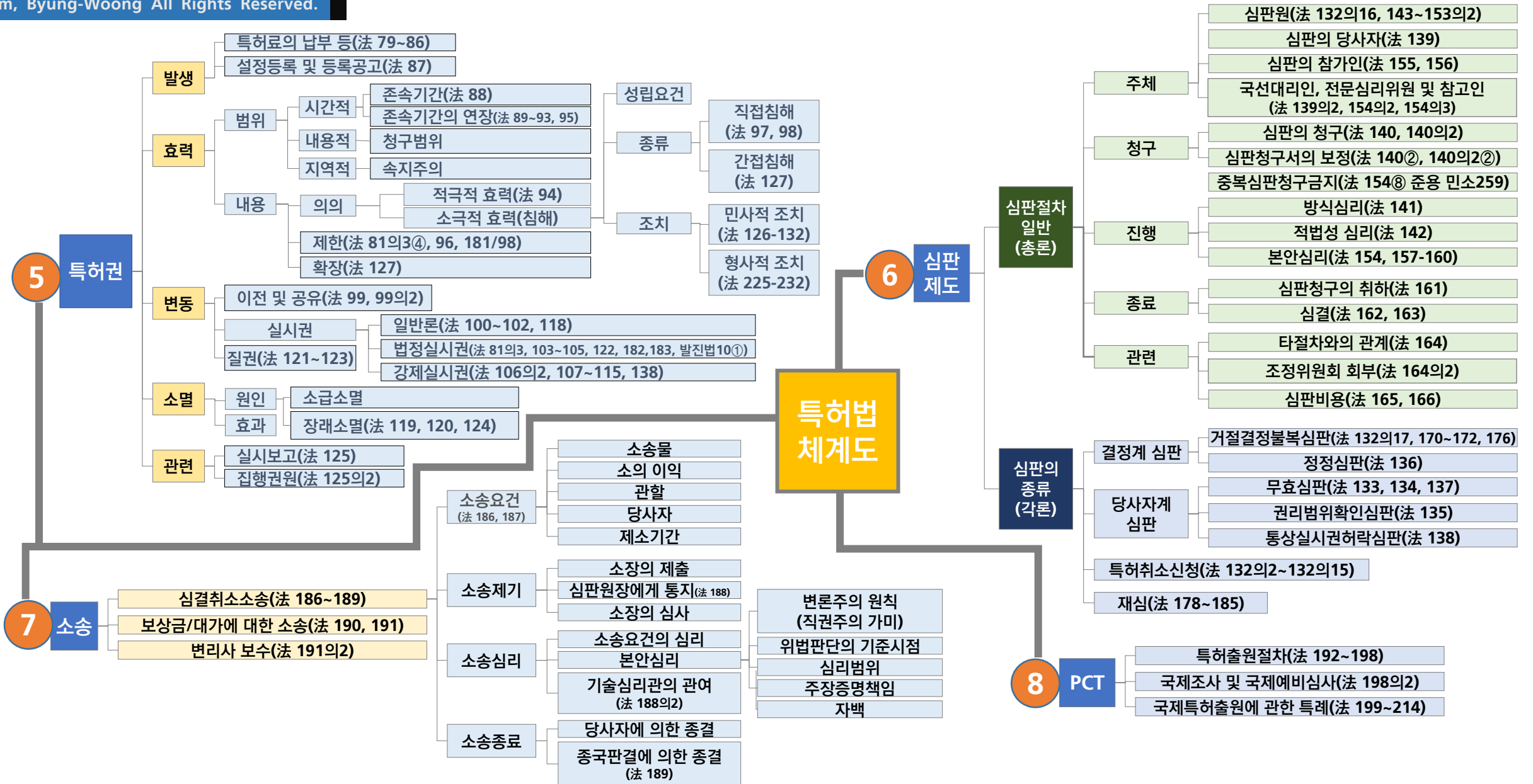
		전자상거래 관련 발명	미생물발명	식물발명
의의		영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터 기술에 의하여 구현된 발명을 말한다.	미생물이란 곰팡이·세균 등 미세크기의 생명을 가진 물체로서, 미생물발명이란 미생물 자체의 발명, 미생물을 생산하는 방법에 관한 발명, 미생물을 이용하는 발명 등을 총칭한다.	반복생식할 수 있는 변종식물에 대한 발명을 말한다.
특허 요건 및 특허 출원	성 립 성	1.자연법칙을 100% 이용하지 않지만 시대적 흐름에 부응하고 자 예외적으로 성립성 인정 2.성립성이 인정되기 위해서는 S/W가 H/W의 물리적 변환을 야기시키는 과정이 발명의 설명에 상세히 기재되어야 함	1.통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 없는 미생물발명의 경우 전에 기탁기관에 해당 미생물을 기탁하고, 특허출원인은 특허출원서에 취지를 적어야 한다. 기탁하지 않을 경우 미완성 발명이 되어 발명의 성립성이 인정되지 않으며, 산업상 이용가능성(法29①본문) 또는 명세서기재(法42③ I) 위반을 이유로 거절이유(法62), 정보제공사유(法63의2), 특허무효사유(法133①)에 해당. 한편, 쉽게 입수할 수 없는데 출원 전까지 기탁하지 아니하고, 특허출원 후에 미생물을 기탁한 경우에는 신규사항추가(法47②전단)에 해당 2.통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물은 반드시 국내에 현존할 필요×(99허8653) 3.출발 미생물만 기탁하면 되지 중간생성물이나 최종생성물까지 기탁할 필요×(90후1260). 4.통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물인지 여부는 출원시를 기준으로 판단(96후658).	1.구법 제31조를 삭제함으로써 동물발명과 마찬가지로 유/무성 무관하게 특허법상 보호 2.육종경과를 상세히 기재하여야 성립성 인정
	기타	컴퓨터 기술을 중심으로 진보성을 판단	1.쉽게 입수가능하지 않은 경우 - 국내기탁기관/지정기탁기관/국제기탁기관에 기탁, 특허출원서에 그 취지를 기재하고 증명서류 제출(단, 국내 소재지가 있는 국내/국제기탁기관에 기탁한 경우에는 증명서류 제출 생략 가능), 수탁번호 기재 --> 기탁절차가 부적법한 경우 그 절차를 무효(재량) 2.쉽게 입수가능한 경우 - 입수방법기재	식물기탁으로 명세서 기재를 보충하거나 대체 不可
특 허 권	효 력	1.컴퓨터 프로그램 실행(방법의 사용)을 위한 온라인 전송행위(청약)를 방법발명의 실시의 일 유형으로 포섭(法 2Ⅲ나). 2.다만, 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 제한하고 있다(法 94②). 따라서 방법의 사용을 청약하는 행위에는 특허법 제130조의 과실추정 규정 불적용		
	제 한			
	확 장		허가 등에 따른 존속기간의 연장가능	
비고			1.미생물의 분양 ① 출원공개/설정등록 ② 의견서 작성에 필요 ③ 기탁한 자료부터 분양에 대한 허락을 받은 자 2.제3자에게 이용금지	WTO/TRIPs 제27조제3항의 규정에서는 식물변종의 발명에 관해서는 불특허대상으로 할 수 있되 이를 불특허대상으로 한 경우에는 특별법으로 보호해야 함을 의무화

특허법 강의노트

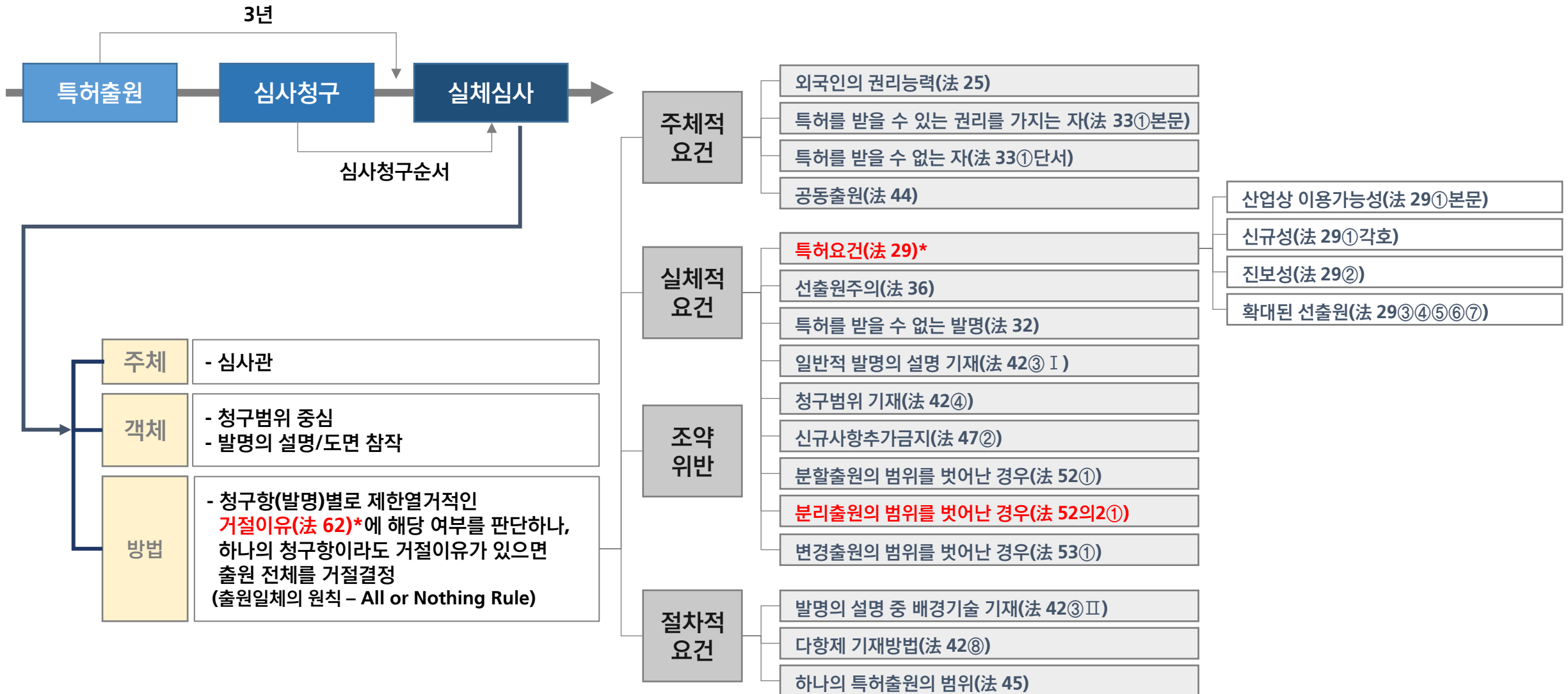
Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

2026





특허법상 협의의 특허요건은 제29조에서 규정하고 있는 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 및 확대된 선출원을 의미하고, 광의의 특허요건은 제62조에서 규정하고 있는 거절이유에 해당하지 아니한 것을 의미하는데, 일반적으로 **특허요건이라 함은 후자를 지칭**한다.



제29조
제1항
본문

산업상 이용할 수 있는 발명

(협의) 산업상 이용가능성 + 발명의 성립성

(광의) 산업상 이용가능성

발명의 성립성의 관점

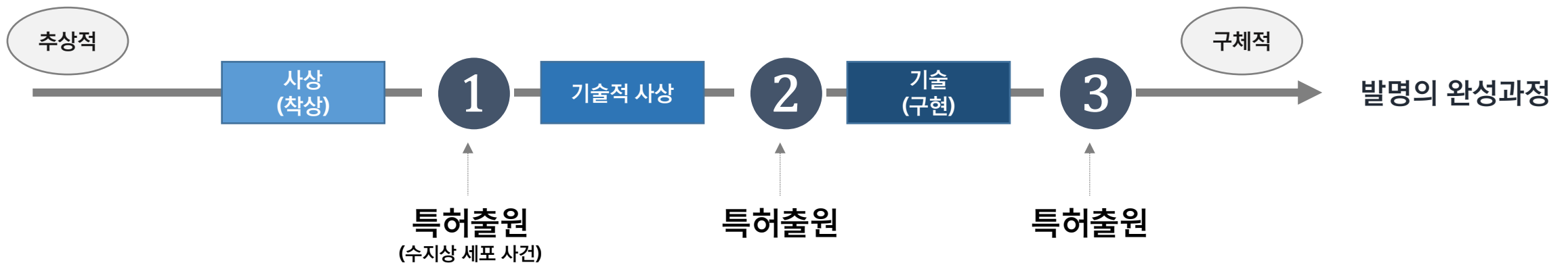
발명의 기술적 사상이면 되지 꼭 기술이어야 하는 것은 아니다.

발명의 기술적 사상이어야 하며 사상이어서는 안된다.

산업상 이용가능성의 관점

발명이 즉시 이용되어야 하는 것은 아니며, 장래에 이용될 가능성만 있으면 된다.

발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다.



대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결 【거절사정(특)】

특허출원발명의 출원일 당시 수지상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 아니하여 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다.

- 오케스트라 연주기법에 의한 피부미용법

- 인간을 대상으로 하는 수술방법, 치료방법, 진단방법
- 혈액투석방법
- 온구기를 사용하여 사람의 등 부위의 경혈과 배 부위의 경혈을 자극하는 방법

치료/비치료 효과
혼재된 경우

① 분리가능 & ② 청구항이 비치료적 용도 한정 & ③ 치료 효과가 비치료 효과를 달성하기 위한 과정에서 부수적인 효과인 경우 산업상 이용가능성 인정

그렇지 아니하면, 산업상 이용가능성 불인정

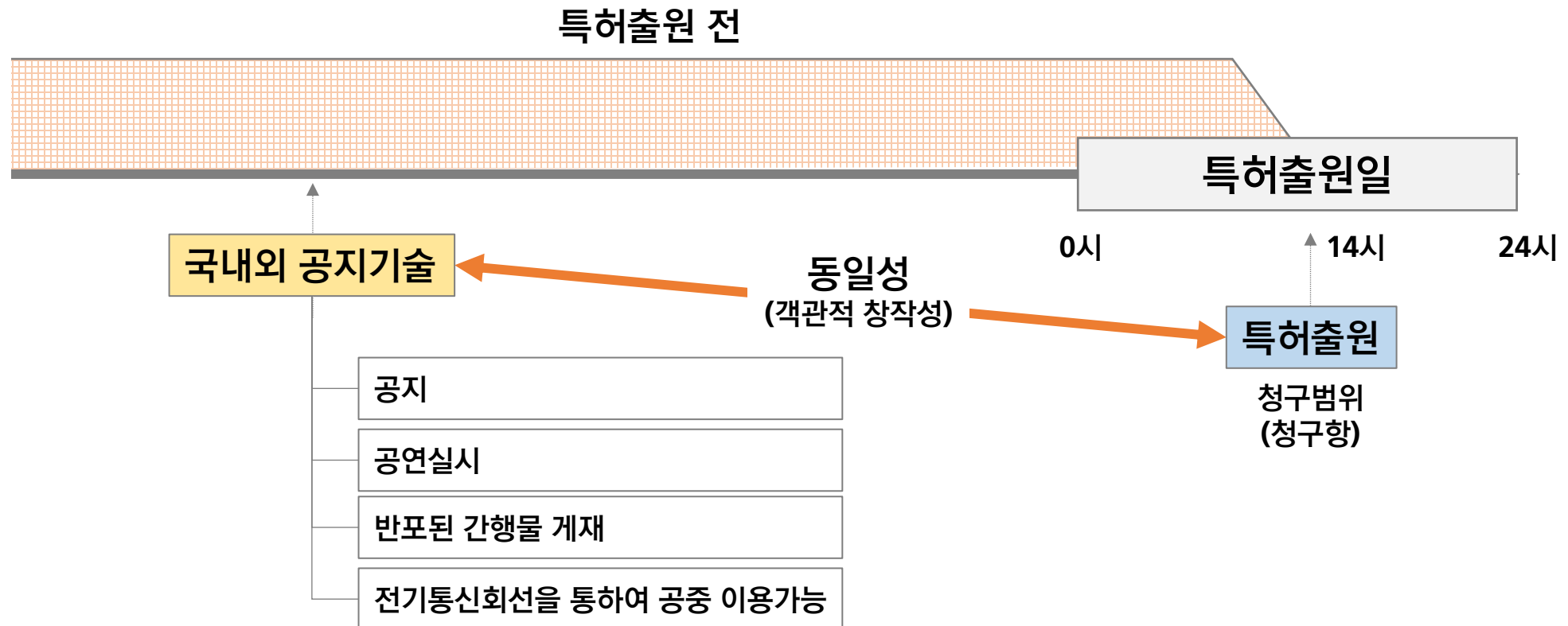
- 모발의 웨이브방법

산업상 이용가능성	의료업	비의료업	비고(제32조 위반 여부는 별개)
인체를 직접적인 구성요소로 하는 경우	불인정	인정	단 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 경우 불특허발명에 해당
인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니하는 경우	인정	인정	

- 사람으로부터 자연적으로 배출된 것/채취된 것을 처리하는 방법
- 인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니한 의료행위에 사용하는 의료기기·장치 및 의약품(혈액투석장치)
- 사람의 등과 배 부위의 경혈을 자극하는 온구기
- 인간 이외의 동물에 한정함을 청구범위에 명시
- 진단방법이라고 할지라도 의사의 임상적 판단을 포함하지 아니한 경우
- 의료기기의 작동방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법 발명(다만, 그 구성에 인체와 의료기기 간의 상호작용이 인체에 직접적이면서 일시적이 아닌 영향을 주는 경우 또는 실질적인 의료행위를 포함하는 경우를 제외)

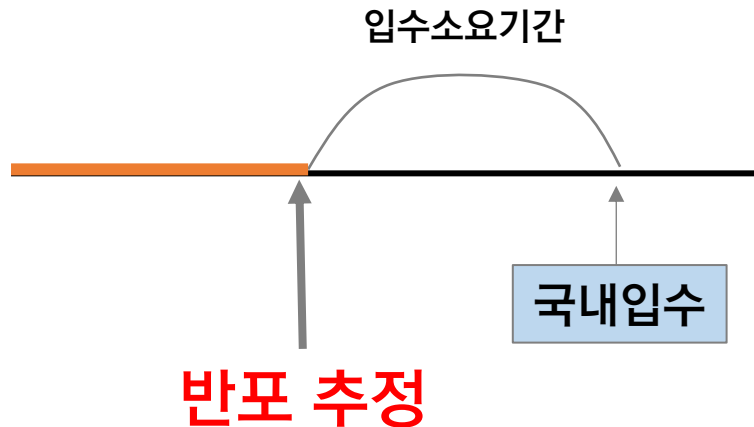
제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명

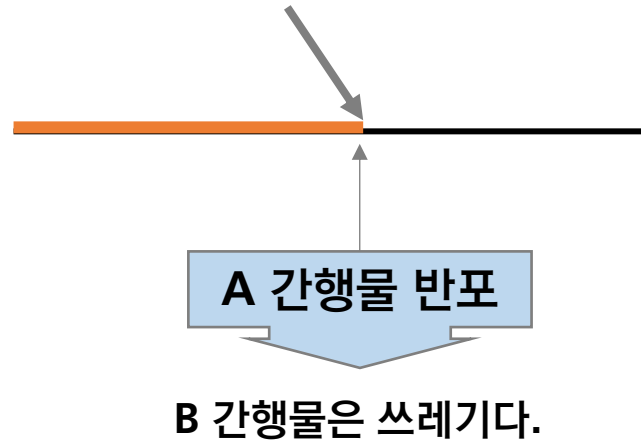


간행물의 발행시기가 기재되어 있지 아니한 경우에는 i) 외국간행물로서 국내에 입수된 시기가 분명한 때에는 그 입수된 시기로부터 발행국에서 국내에 입수되는데 소요되는 통상의 기간을 소급한 시기에 반포된 것으로 추정하고, ii) 해당 간행물에 대하여 서평·발췌 카탈로그 등을 게재한 간행물이 있으면 그 발행시기로부터 해당 간행물의 반포시기를 추정하며, iii) 해당 간행물에 관하여 중판 또는 재판 등이 있고, 여기에 초판의 발행시기가 기재되어 있을 때에는 그 초판의 발행일을 반포시기로 추정한다. 다만 재판의 경우에는 재판과 초판의 인용하는 부분의 내용이 상호 일치할 것을 전제로 한다. iv) 그 밖에 적당한 근거가 있으면 그것으로부터 반포시기를 추정 또는 인정한다. 다만, 이와 같은 추정은 반증에 의하면 얼마든지 번복될 수 있다.

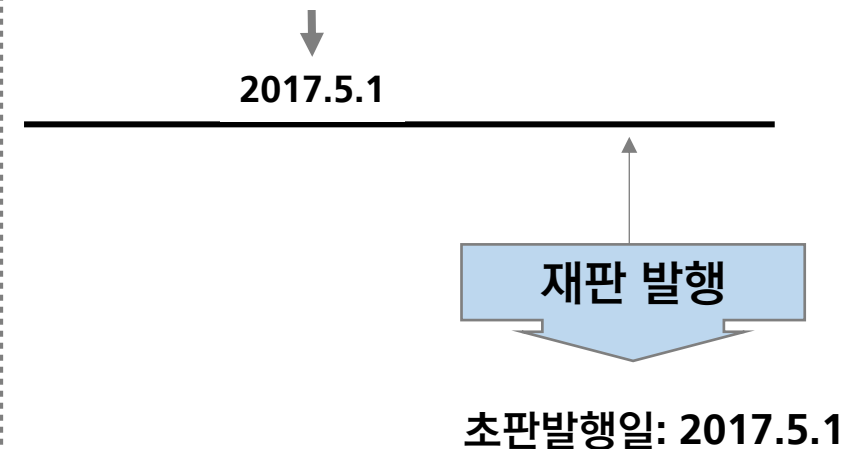
최대한 늦게 반포된 것으로 추정 또는 간주



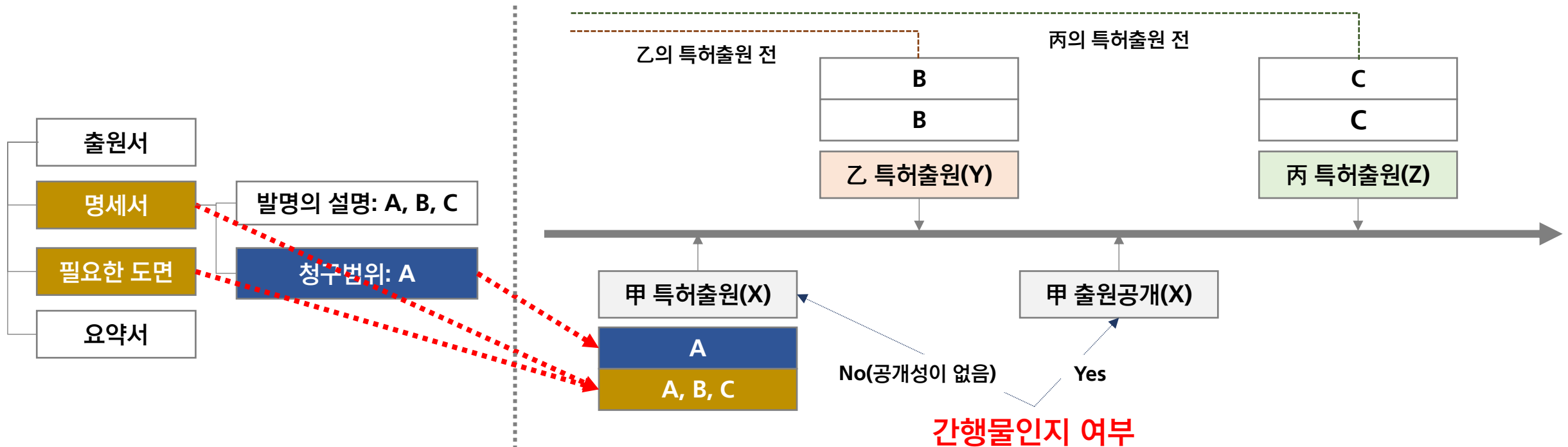
B 간행물 반포 추정



반포 추정
(단, 초판과 재판의 인용부분 일치)

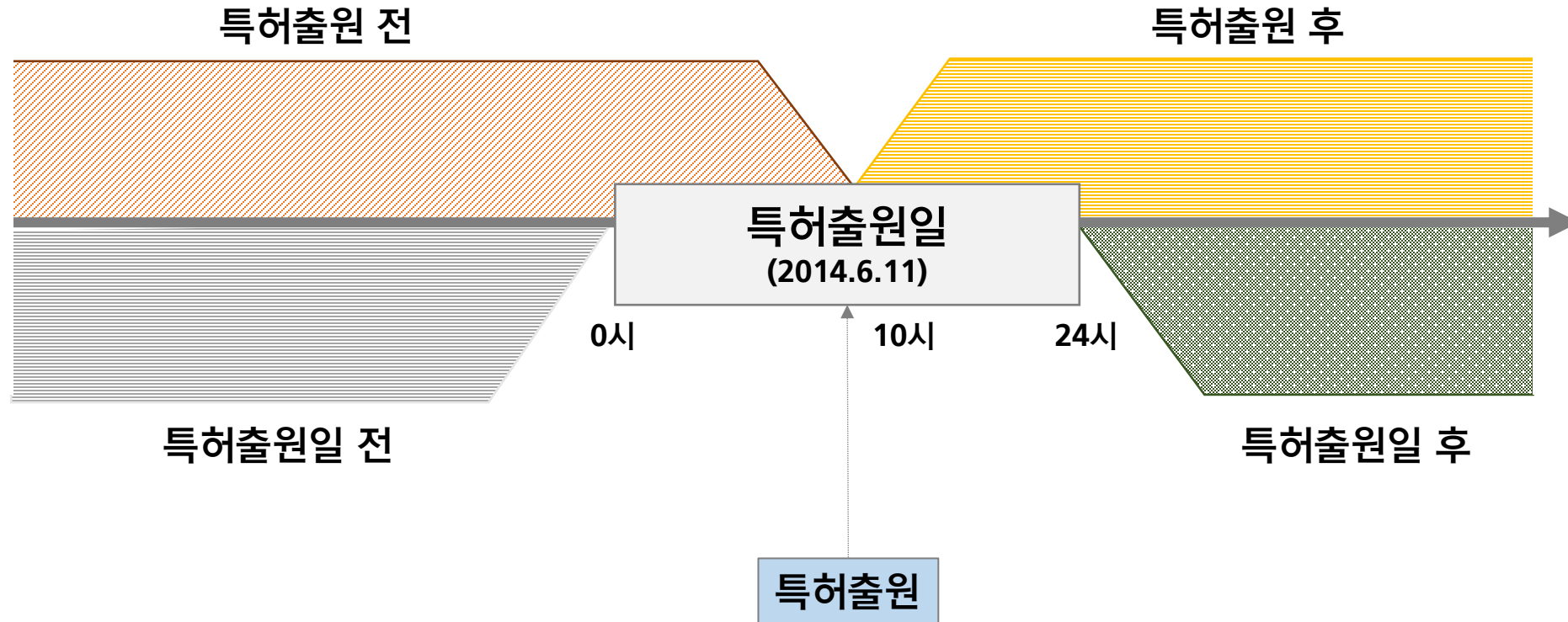


甲 출원(X)은 발명의 내용을 포함하고 있어 정보성이 있으나 **지식재산처 직원이 비밀유지의무가 있는 특정인**이기 때문에 공개성이 없어 간행물이라 할 수 없다. 한편 甲 출원(X)의 출원공개는 출원된 내용을 공개공보에 게재하여 일반 공중에게 발명의 내용을 알리는 것이기 때문에 **정보성과 공개성이 있어** 간행물이라 할 수 있다. 따라서 乙의 출원(Y)은 특허출원(Y) 전에 공지기술이 없어 신규성이 상실되지 아니하지만, 丙의 출원(Z)은 특허출원(Z) 전에 甲 출원의 공개(X)에 의한 공지기술이 있고, 그 공지기술과 丙의 출원(Z)의 청구범위에 기재된 발명인 C가 동일성이 있어 신규성이 상실된다. 물론, 乙의 출원(Y)은 신규성이 상실되지는 아니하지만 확대된 선출원 위반으로 특허를 받을 수 없다.



丙 출원 기준: 일반적으로 丙 출원일로부터 1년 6개월전에 출원된 것(甲 출원)만 검색을 할 수 있으며, 그 사이에 있는 출원된 것(乙 출원)은 비밀상태를 유지함

특허출원을 2014년 6월 11일 오전 10시에 한 경우 특허출원 전이란 2014년 6월 11일 10시 전을 의미하고, 특허출원일 전이란 2014년 6월 11일 전을 의미한다. 즉, **특허출원 전은 2014년 6월 11일 오전 0시부터 오전 10시 전까지를 포함하는 의미**라는 점에서 특허출원일 전과 구별된다.

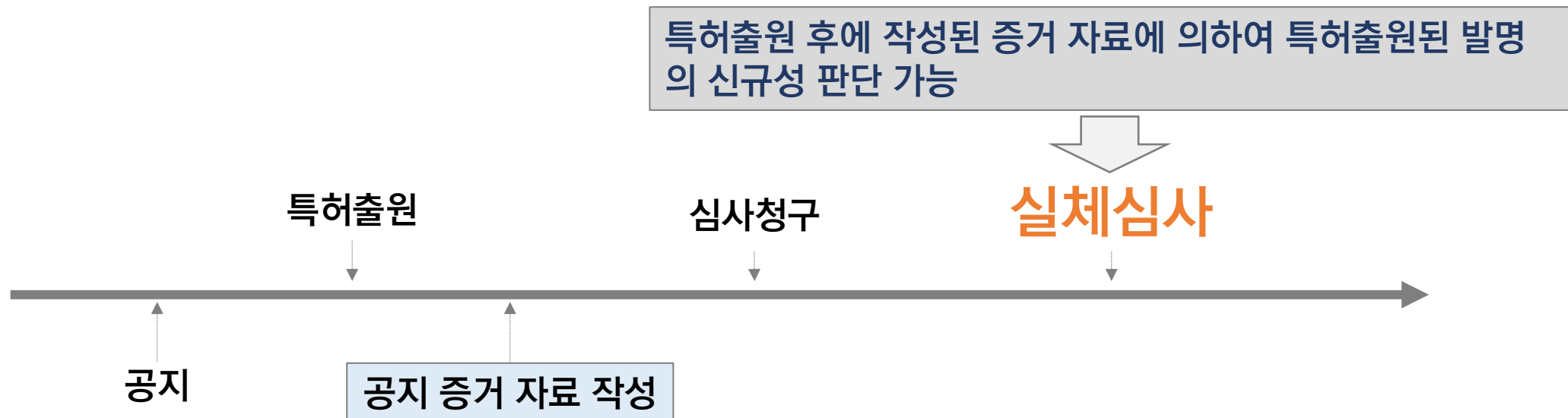


대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결 【정정(특)】

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제1항 제1호 소정의 ‘특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명’에서 ‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 인정할 수 있다.

[2] 의견서 제출기회를 부여하는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제4항은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하나, 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용된다.

[3] 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아니라도 정정거절이유를 보충하는 것이라면 새로운 정정거절이유라고 할 수 없으므로, 특허법원이 그 증거를 채용하여 정정청구를 기각한 심결이 정당하다는 사유의 하나로 삼았다고 하여 심리범위를 일탈하였다고 할 수 없다.





A유형

보정, 우선권주장출원, 정정심판 등 소급효 인정

B유형

신규성, 확대된 선출원

C유형

선출원주의

D유형

무권리자, 허위표시

A

보정

제47조 제2항에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다. 또한, 보정된 사항이 주지관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 및 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 최초 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어서 허용될 수 없다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결).

우선권 주장출원

그런데 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다. 따라서 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다. 그리고 여기서 '우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항'이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999).

정정심판

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에 할 수 있다(특허법 제136조 제2항). 여기서 '명세서 또는 도면에 기재된 사항'이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 상위개념을 하위개념으로 정정하였다고 하더라도 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다(대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404 판결).

B

신규성

특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다는 법리(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 등 참조)와 기록에 나타난 이 사건 특허발명이 해결하고자 하는 과제 및 효과 등을 종합하면, 이 사건 특허발명과 선행발명에서 차이가 나는 부분은 그 기술적 사상에 영향을 미치지 않는 단순한 설계변경에 해당하거나 그 과제해결을 위한 미세한 차이에 지나지 아니하므로 양 발명은 실질적으로 동일하다고 본 원심의 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고 이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 신규성에 관한 법리오해나 진보성에 관한 법리오해 등의 위법이 없다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결).

확대된

발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다. 두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다. 그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조).

선출원

특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 특허청구범위나 발명의 상세한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 선출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다. 이 경우 전후로 출원된 양 발명의 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 부분적으로만 일치하더라도 그 차이가 발명의 포섭 범위를 달리한 데 지나지 아니하는 때에는 양 발명은 특별한 사정이 없는 한 실질적 동일성이 있다 할 것이다. 또한 양 발명의 구성의 차이가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게는 이미 널리 알려져 활용되고 있는 기술을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하여 새로운 작용효과가 발생한다고 보기 어려운 경우에도 마찬가지라 할 것이다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후726 판결).

실질적 동일성 중 범위가 다른 경우

실질적 동일성 중 범주가 다른 경우

C

선출원주의

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제36조를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 **대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져 보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧 바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다**(대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결).

구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있는바, 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, **비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다**(대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결).

실질적 동일성 중 구성이 변경된 경우: 진보성 판단에 준하여 판단

D

허위표시

특허법 제224조 제3호는 같은 조 제1호의 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건을 생산·사용·양도하기 위하여 광고 등에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시(이하 '특허된 것 등으로 표시'라 한다)를 하는 행위를 금지하고 있다. 위 규정의 취지는 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 약용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, **특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다**(대법원 2015. 8. 13. 선고 2013도10265판결).

무권리자

발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 **발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다**(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463판결).

진보성 × + 등 + 기술적 사상의 창작 기여 ×

구분		인용대상	본원발명	동일성 인정여부	비고
문언적 동일		a+b(직접 기재)	a+b	인정	
내재적 동일성		a+b(직접 기재와 마찬가지로)	a+b	인정	
실질적 동일성	범주 상이	물건발명	제법발명	일반적 불인정	
		제법발명	물건발명	일반적 인정	
	범위 상이	부가	a+b	일반적 불인정	결합발명
			a+b+c	일반적 인정	
		한정	A+b (A는 a의 상위개념)	일반적 불인정	선택발명
			a+b	일반적 인정	
	구성 변경	a+b1	a+b	일반적 불인정*	

- 협의의 동일성(신규성, 확대된 선출원의 지위): 과제해결을 위한 구체적 수단에서 **주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제** 등에 불과하여 **새로운 효과** 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말한다.
- 광의의 동일성(선출원주의): 그 변경이 목적달성을 위한 구체화 수단으로서 **통상의 기술자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의 기술수단의 단순한 치환, 부가 또는 삭제** 등에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 **효과에 각별한 차이**가 생기지 않는 경우를 말한다.

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결 【등록무효(특)】

물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다. 한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

(1) 선행발명 1은 “에어로졸 디포지션 방법에 의해 형성된 PZT 후막의 미세구조 및 전기적 특성”이라는 제목의 논문으로, 공지된 물건 그 자체가 아니라 공지된 문헌이어서, 선행발명 1에서 대비 대상이 되는 것은 선행발명 1에 제시된 제조방법에 의하여 제조된 막 형상 구조물이다.

(2) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 취성 재료 미립자를 상온에서 고속분사하여 기재 표면에 충돌시킴으로써 미립자를 변형 또는 파쇄하여 제작된 막 형상구조물에 관한 것이라는 점에서 공통되고, 그 결과 입자간 결합력이 더 높은 복합 구조물이 형성된다.

(3) 다만, 이 사건 제1항 발명은 ‘결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것’을 구성요소로 하는 반면, 선행발명 1에는 이에 대응하는 기재가 없고(차이점 1), 이 사건 제1항 발명은 ‘구조물의 일부가 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커부’를 구성요소로 하는데, 선행발명 1에는 ‘100-150nm 두께의 손상층은 증착되는 동안초미세 PZT 입자들의 기계적 충격(anchor)부로 되어 있다’고 기재되어 있다(차이점 2).

(4) 차이점 1에 대하여

(가) 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 사전처리를 통하여 취성 재료 미립자에 내부 변형을 부여하는 것이 바람직하다는 내용이 기재되어 있으나, 선행발명 1에는 이에 관한 언급이 없고, 이 사건 제1항 발명은 ‘원료 미립자의 파쇄로부터 재결합까지가 순간적으로 행해지기 때문에 결합 시에 미세 단편 입자들의 표면 부근에서 원자의 확산이 거의 일어나지 않고, 따라서 결정자끼리의 계면의 원자 배열에 흐트러짐이 없으며, 용해층인 입계층(유리층)은 거의 형성되지 않는다’고 그 결합 원리를 설명하는 반면, 선행발명 1은 위와 같은 우수한 효과를 내는 실제 결합 메커니즘은 규명되지 않았다고 하고 있다.

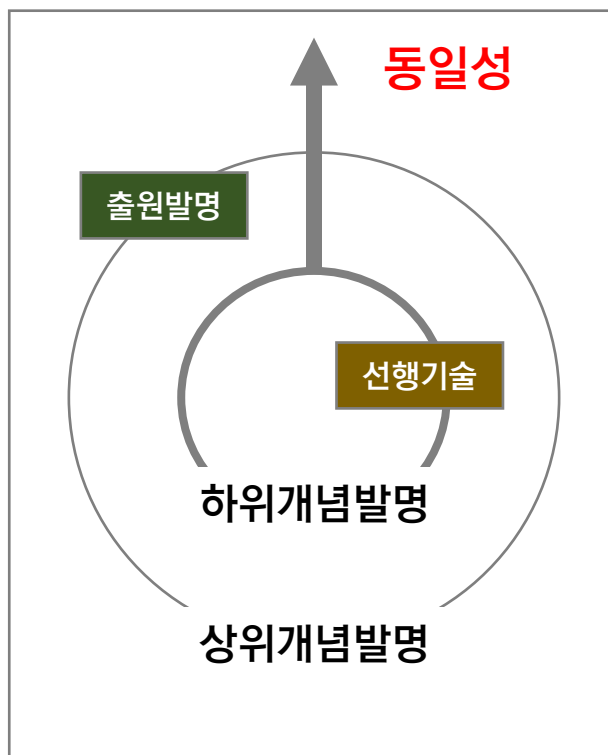
(나) 한편, 이 사건 특허발명의 공동발명자 중 1인인 소외인이 이 사건 특허발명의 우선일인 1999.

10. 12. 이후인 2002년경 공동저자로 발표한 선행발명 1과 동일한 제막 방식의 막 형상 구조물에 관한 논문 “미립자, 초미립자의 충돌 고화 현상을 이용한 세라믹 박막 형성 기술”(갑 제12호증)에서는, 선행발명 1의 막 형상 구조물에 대한 TEM(투과전자현미경) 촬영 사진과 이보다 더 개선된 방식인 HR TEM(고분해능 투과전자현미경) 촬영 사진을 개시하고[도6(a),(b)] ‘이들은 가열 없이 Si 기판 상에 실온 성막된 PZT 후막의 열처리 전후의 TEM 이미지이다. 막 안에 원료분말의 형태는 관찰되지 않고, 각각의 결정은 서로 결합되어 치밀한 막을 형성하고 있다. 또한 막 안에는 원료분말에 가까운 크기의 결정자가 부분적으로 보이지만, HR TEM 이미지 또는 전자선회절 이미지로부터도 결정자 간, 입자 간에 비정질층이나 상이한 모양은 거의 볼 수 없었고, 전체적으로 20nm 이하의 미세결정으로 구성되어 있다’고 설명하고 있다. 즉, 위 논문에 의하면 선행발명 1에 개시된 사진의 막 형상 구조물 역시 결정자 사이의 계면에 비정질층인 입계층이 존재하지 않는다는 것이다.

(다) 그런데 위 논문에 의하면 선행발명 1에 기재된 제조방법을 따른 하나의 실시례가 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 구성을 가진다는 점은 알 수 있지만, 더 나아가 선행발명 1에 기재된 제조방법을 따랐을 때 필연적으로 비정질층이 존재하지 않는 결과물에 도달할 것인지를 알 수 있는 자료는 없다. 오히려, 선행발명 1은 원료 미립자의 사전처리 공정을 언급하고 있지 않은 반면, 이 사건 제1항 발명의 명세서에서는 사전처리를 통한 내부 변형의 중요성을 강조하고 있을 뿐만 아니라 적절한 내부 변형의 정도(0.25~2.0%)와 방법 등까지 기재하는 등으로 비정질층이 부존재하는 복합 구조물을 성공적으로 제조하기 위한 제조방법을 더 구체적으로 공개하고 있다.

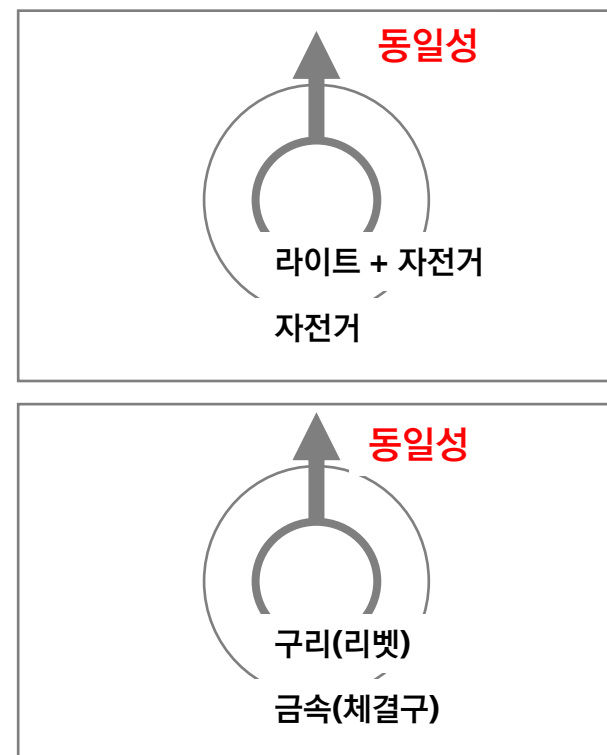
(라) 이러한 점에 비추어 보면, 비정질층의 부존재가 선행발명 1에 개시된 막 형상 구조물의 내재된 구성이라는 점이 증명되었다고 보기 어려우므로, 두 발명이 동일하다고 할 수 없다. 따라서 차이점 2에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명의 신규성이 부정되지 않는다.

선행기술이 출원발명과 관계에서 하위개념이 되는 유형은 **구성요소를 한정하거나(내적 부가), 구성요소를 부가(외적 부가)한 발명**이 있다. 구체적인 예로는 구성요소를 한정한 선택발명과 구성요소를 부가한 결합발명을 들 수 있다. 특히, 구성요소를 더 많이 부가하면 할수록 권리범위가 좁아지게 되는 것을 **다기재협범위의 원칙**이라고 한다. 이는 등록 후 **구성요소완비의 원칙(All Element Rule)**에 의하여 침해 여부를 판단할 때 하나의 구성요소라도 삭제하면 비침해가 되기 때문이다.

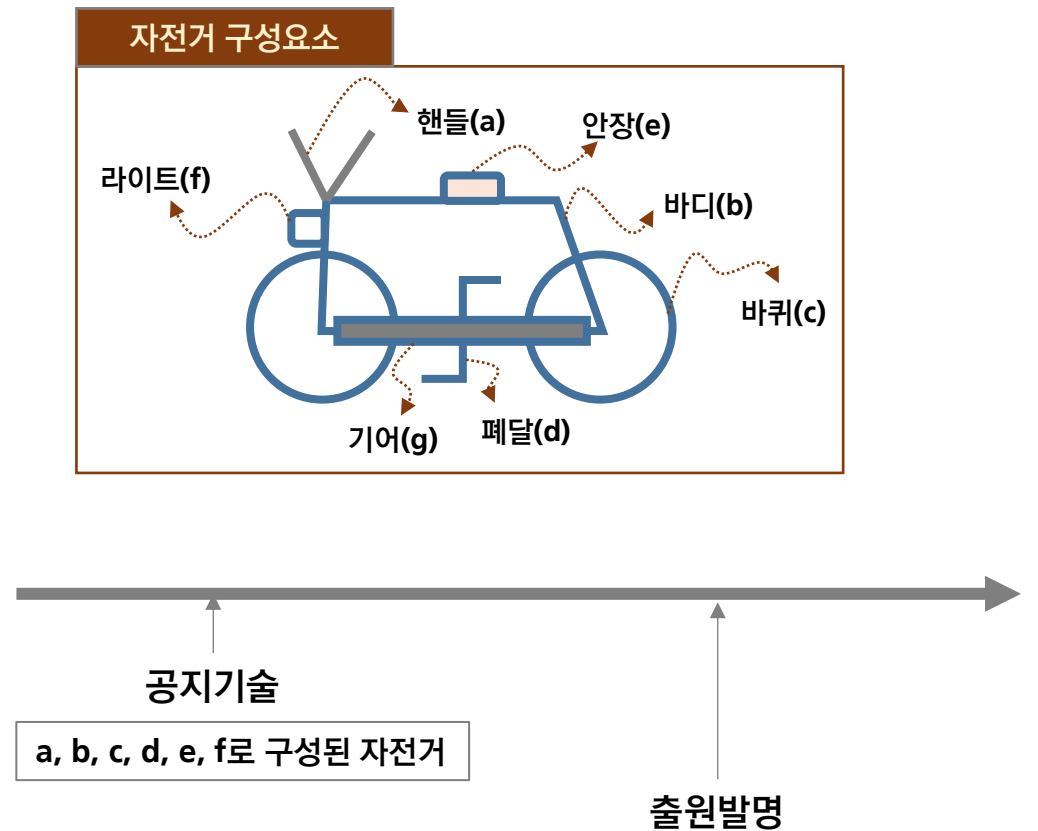


외적 부가

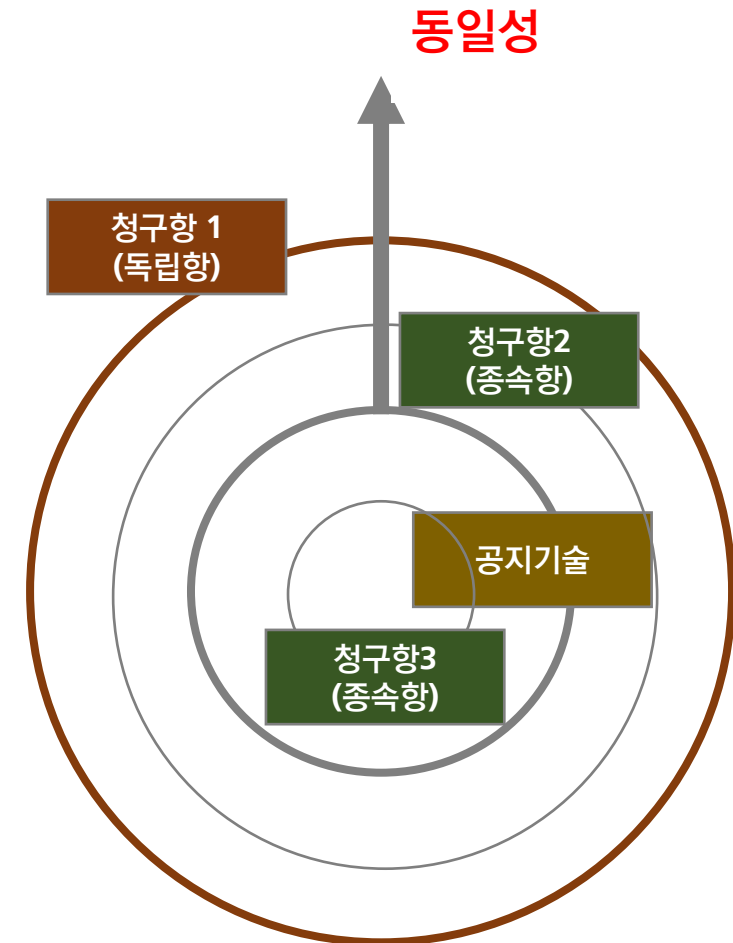
내적 부가



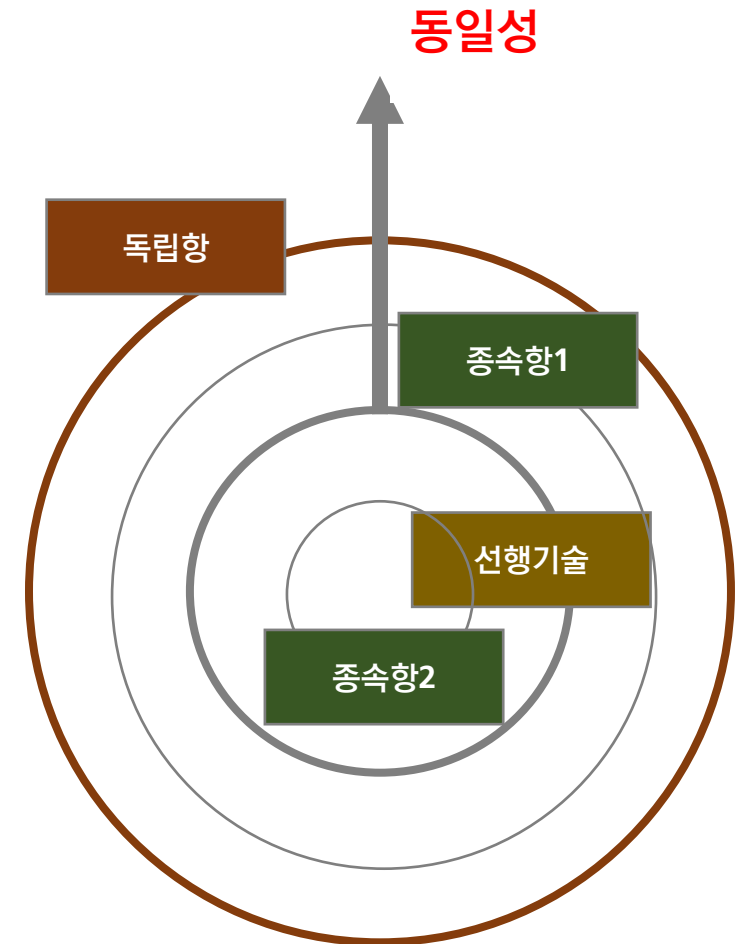
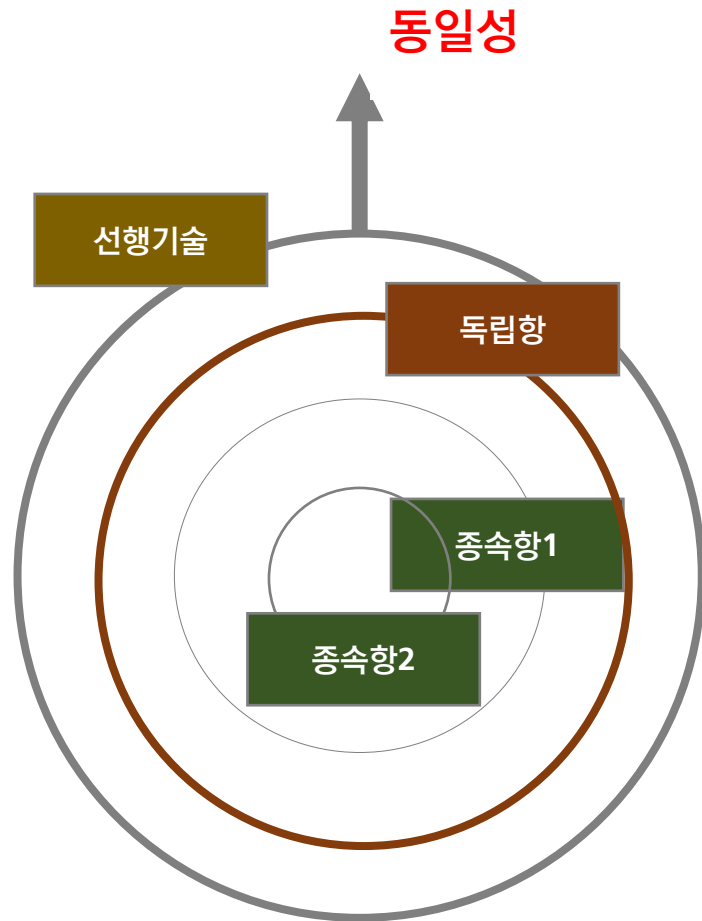
청구항 1과 청구항 2에 기재된 발명은 다기재 협범위의 원칙에 따라 공지기술보다 상위개념이기 때문에 공지기술과 동일성이 있어 신규성이 상실되나 청구항 3에 기재된 발명은 공지기술보다 하위개념이기 때문에 공지기술과 동일성이 없어 신규성이 상실되지 아니한다. 다만, 출원일체의 원칙(All or Nothing Rule)에 의하여 청구항 1과 청구항 2를 삭제보정하지 아니한 경우 출원 전체가 특허를 받을 수 없게 된다.



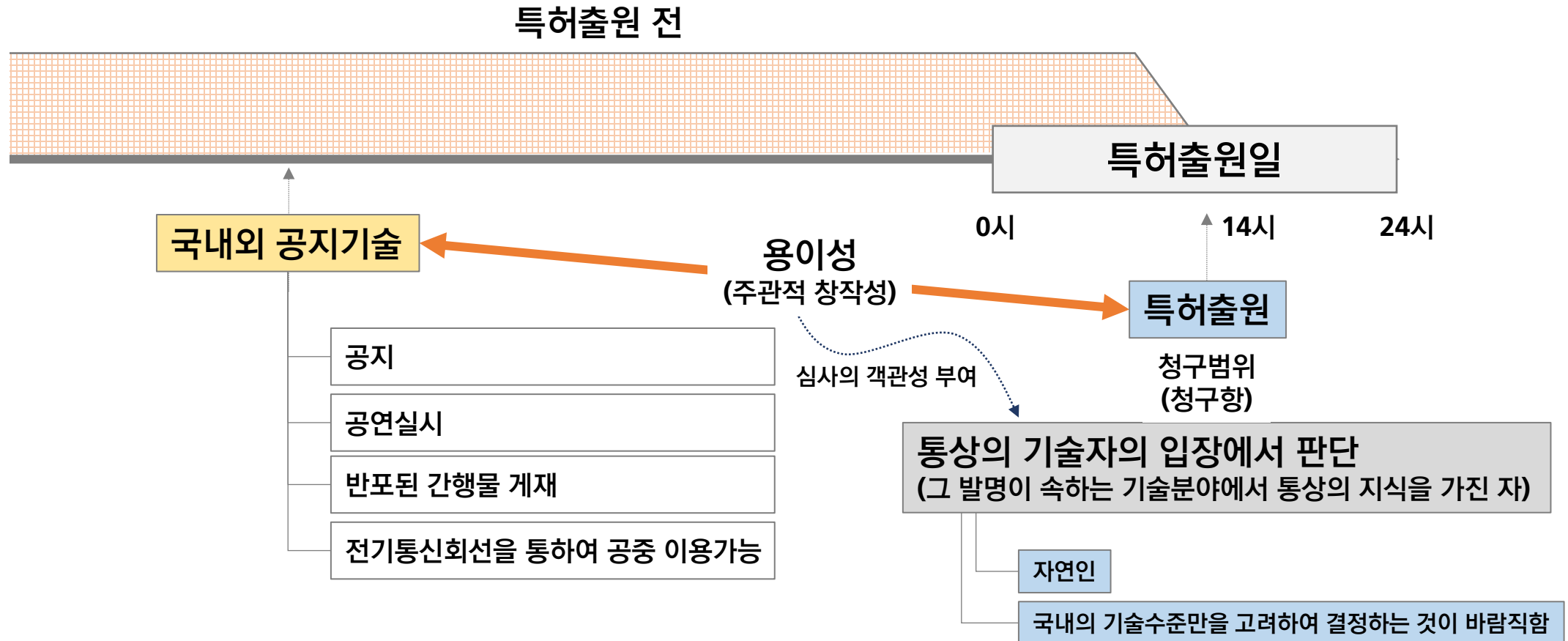
1. a, b, c 및 d를 포함하는 것을 특징으로 하는 자전거
2. 제1항에 있어서, e를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자전거
3. 제2항에 있어서, f와 g를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자전거



종속항이란 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화한 청구항을 말하기 때문에, 종속항은 독립항과의 관계에서 하위개념발명이다. 따라서, 독립항의 신규성이 있는 경우 종속항은 당연히 신규성이 있다. 반대로 독립항의 신규성이 없는 경우 종속항은 개별적으로 신규성 여부를 판단하여야 한다.

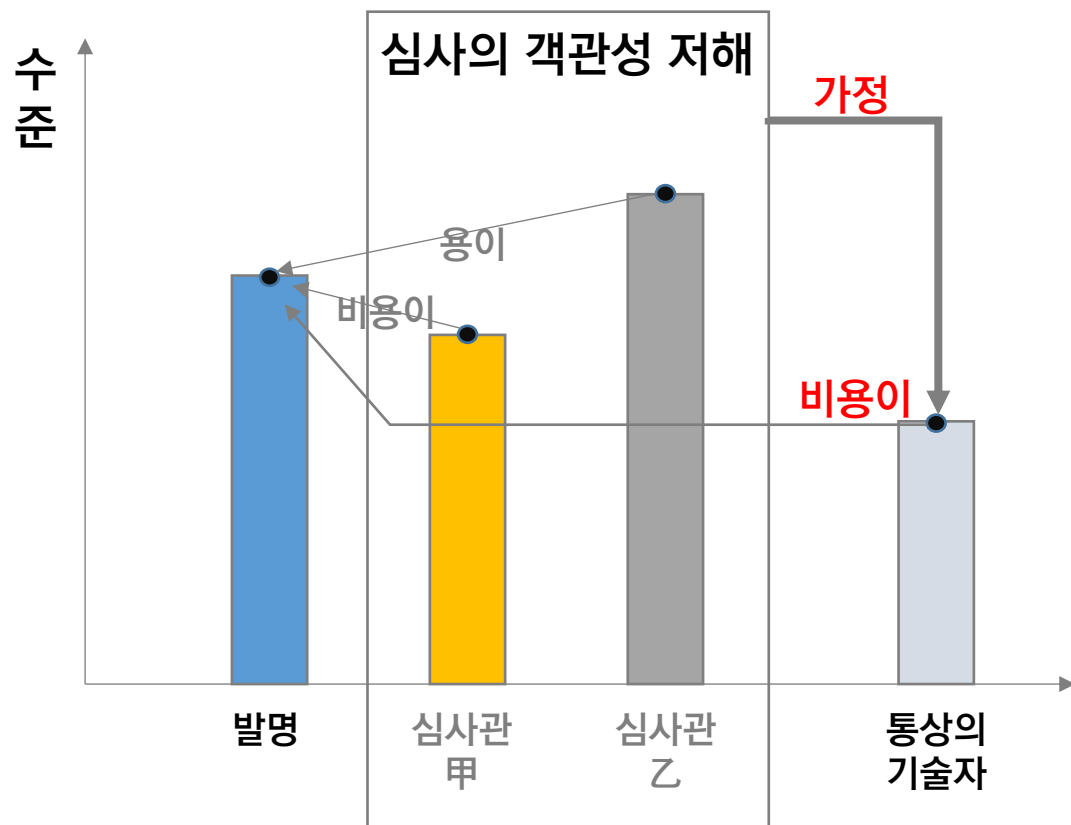


제29조(특허요건) ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

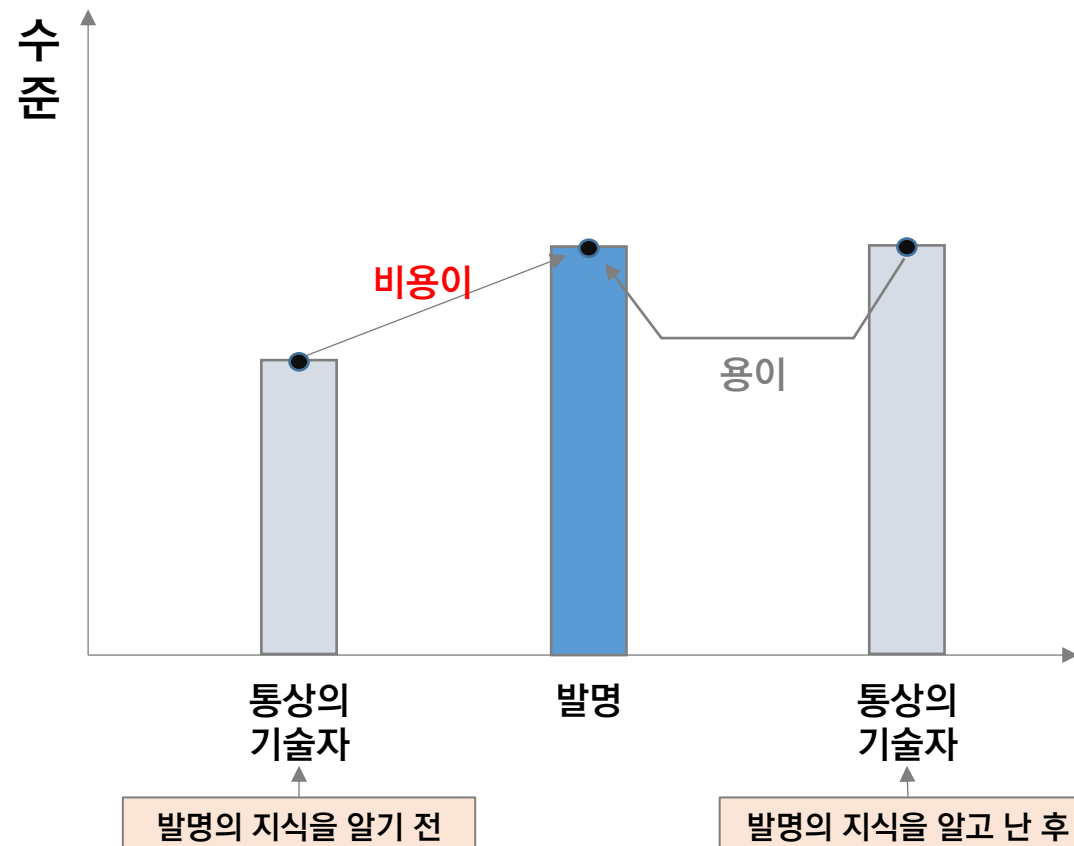


통상의 기술자란 심사관이 진보성 판단에 객관성을 부여하기 위해 가정한 상상의 인물로서 자연인이다. 한편, 심사관은 **해당 발명의 출원 전의 상태**로 돌아가서 해당 발명의 지식을 알지 못한다는 상태에서 발명의 진보성 여부를 따져보아야 한다. 그 이유는 통상의 기술자로서 해당 발명의 이론을 알고 난 후에는 공지기술로부터 해당 특허의 발명적 해결을 손쉽게 이끌어 낼 수 있는 경우가 극히 많기 때문이다.

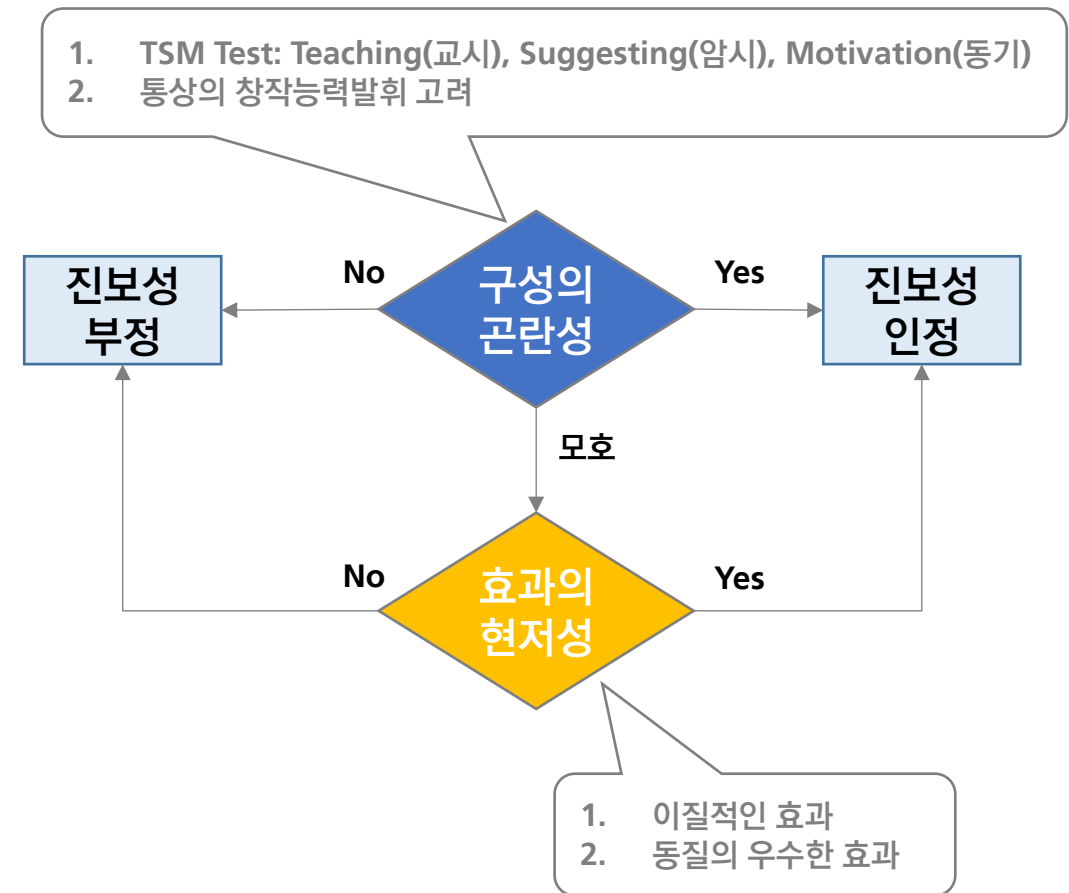
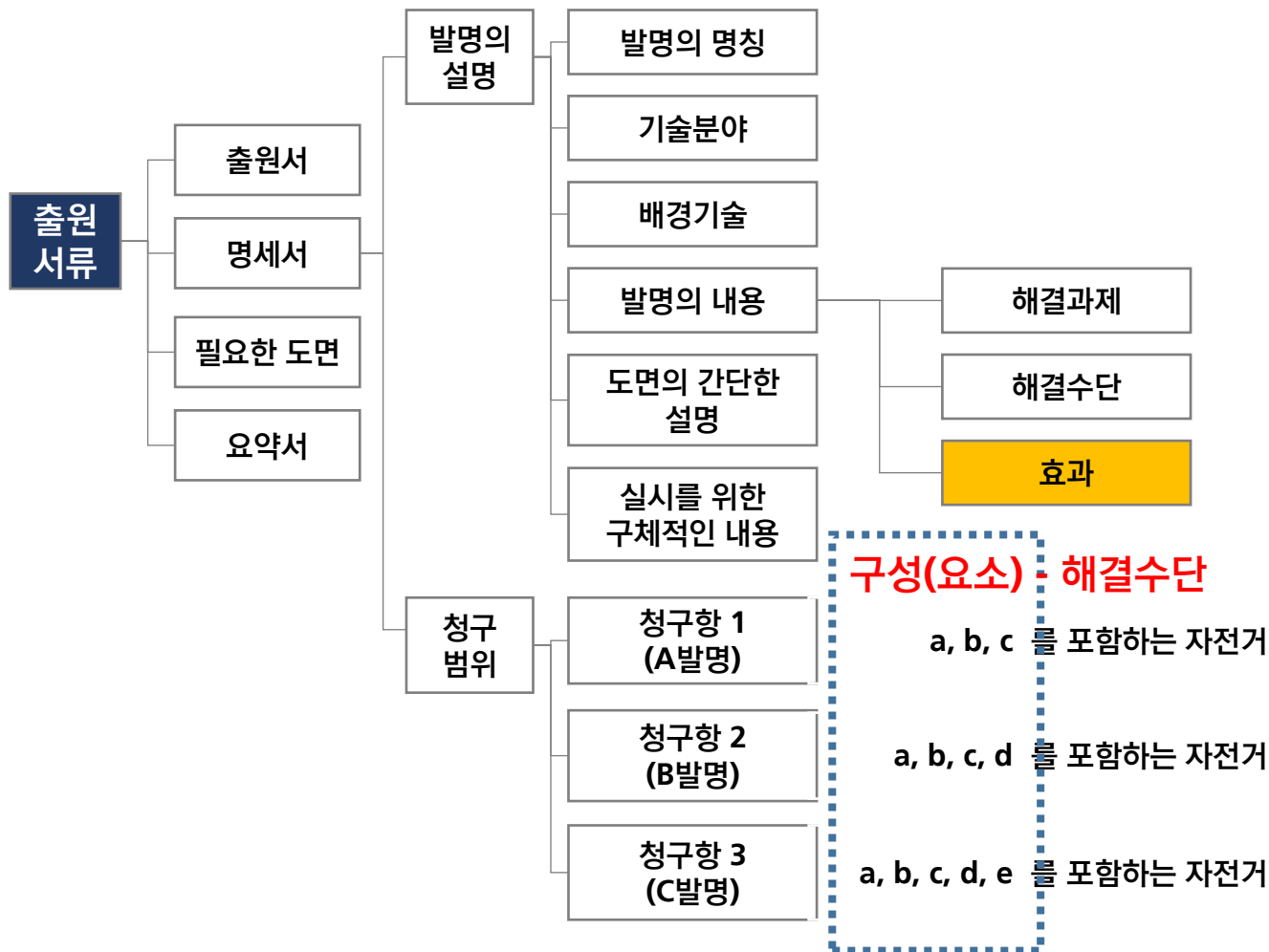
통상의 기술자의 개념



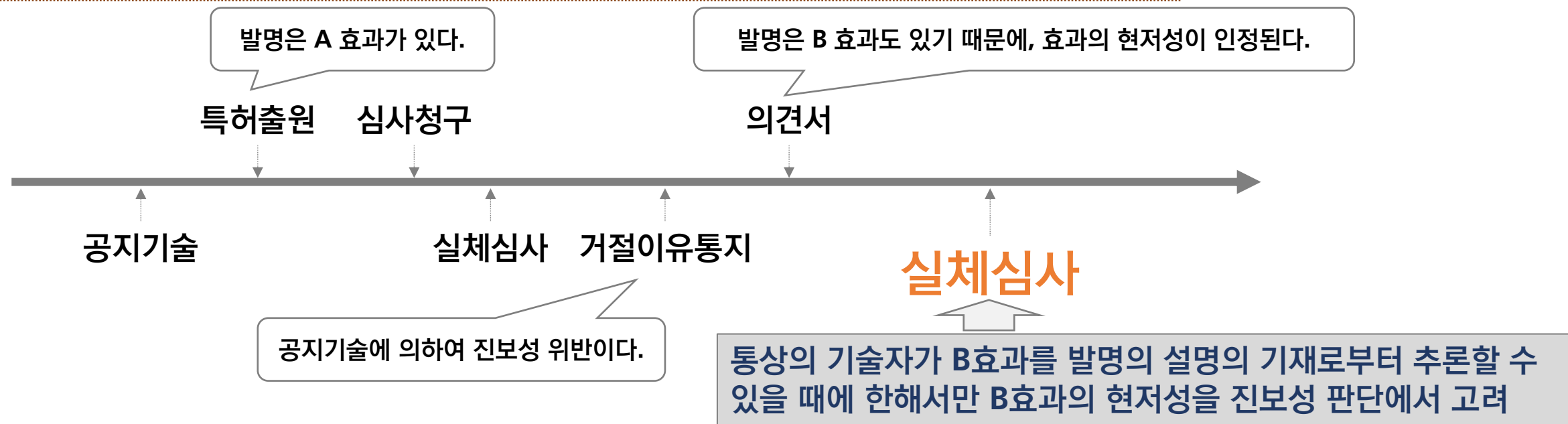
사후적 고찰의 금지



진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 특허된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술과 비교하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 특허발명의 진보성을 인정하여야 한다. 즉, 구성(요소)의 곤란성과 효과의 현저성에 따라 용이성을 판단하고 있다.



효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후 10609). 특허발명의 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 출원일 이후에 의견서 등에서 주장·증명하는 그 효과도 참작하여 진보성을 판단한다(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234). 그러나 발명의 설명에 기재되어 있지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재로부터 통상의 기술자가 미루어 짐작할 수 없는 경우에는 의견서 등에서 주장·증명하는 효과는 참작해서는 아니 된다.

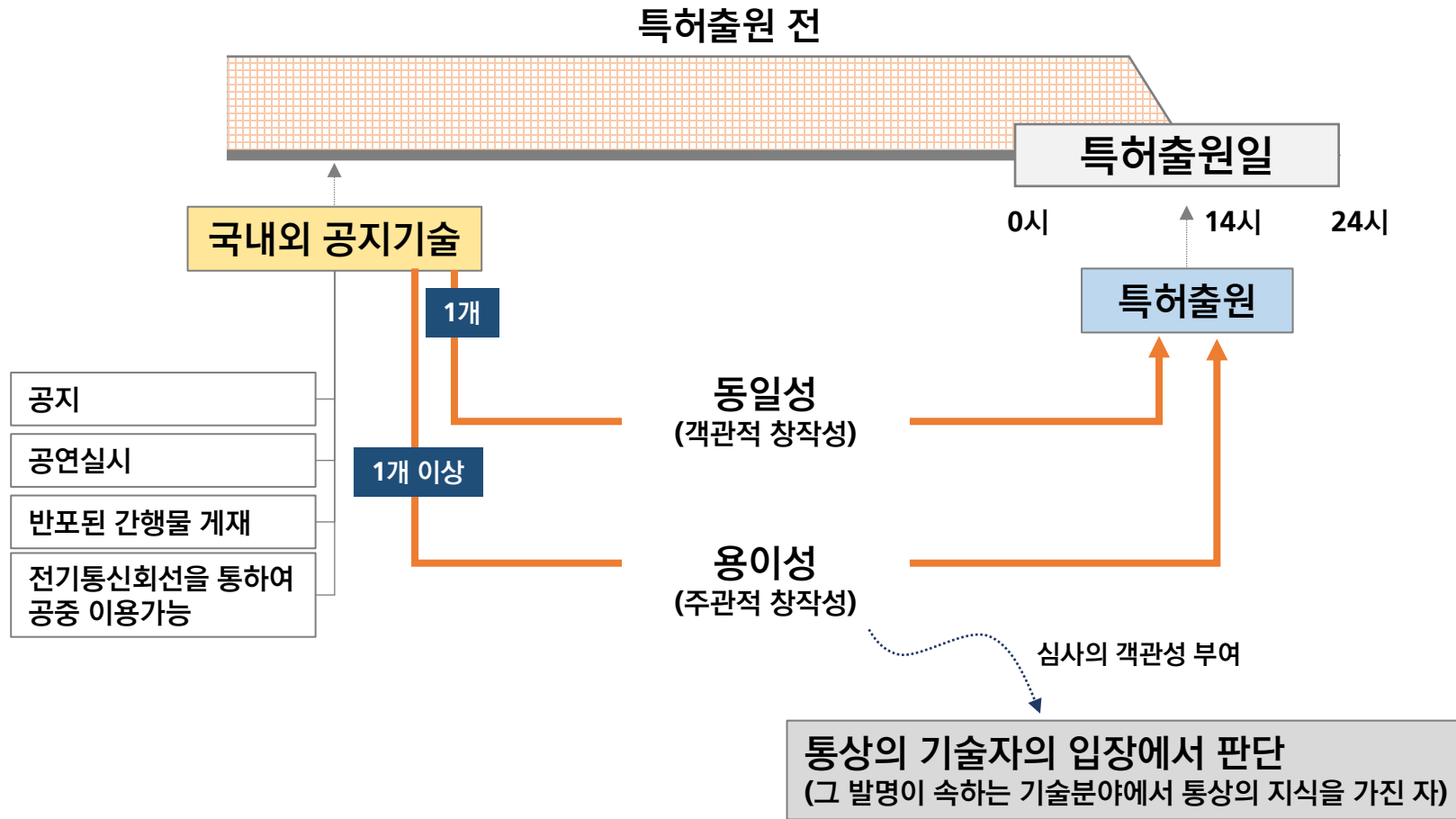


긍정 CASE

만일, 선택발명의 효과가 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609)

부정 CASE

수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있어야 한다는 점이, 출원 명세서에 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서 기재 자체를 통하여 인식할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은 이상 추후 **실험 자료**에 의하여 인정되거나 확인되는 수치한정의 기술적 의의를 가지고서 당해 수치한정 발명의 진보성 여부를 판단할 수는 없다(특허법원 2009. 5. 22. 선고 2008허1722).



구분	구성	효과
실질적 동일성	주지관용기술의 부가/삭제/변경	새로운 효과 ×
용이성	곤란성 ×	현저한 효과 ×

통상의 기술자가 채용하는
정도의 구성의 변경

출원 발명	인용 대상1	인용 대상2	인용 대상3	조합 (OR)
A	○	○	○	○
B	○	○	×	○
C	×	○	○	○
D	×	○	×	○
설명	- 인용대상2에 출원발명의 구성요소가 모두 포함되어 있기 때문에 동일성이 있음			

출원 발명	인용 대상1	인용 대상2	인용 대상3	조합 (OR)
A	○	×	○	○
B	○	○	×	○
C	×	×	○	○
D	×	○	×	○
설명	- 인용대상 1 내지 3 각각에 출원발명의 구성요소가 모두 포함되어 있지 않기 때문에 동일성이 없음 - 인용대상 1 내지 3을 조합하면 출원발명의 구성요소가 모두 포함되어 있기 때문에 용이성이 있음 - 단, 출원발명의 구성의 결합에 특유의 과제해결원리에 기초한 결합관계가 있다면 그 결합관계 역시 구성으로 파악해야 함			

출원 발명	인용 대상1	인용 대상2	인용 대상3	조합 (OR)
A	○	×	○	○
B	○	○	×	○
C	×	×	×	×
D	×	○	×	○
설명	- 인용대상 1 내지 3 각각에 출원발명의 구성요소가 모두 포함되어 있지 않기 때문에 동일성이 없음 - 인용대상 1 내지 3을 조합하더라도 출원발명의 구성요소가 모두 포함되어 있지 않기 때문에 용이성이 없음			

출원 발명	인용 대상1	인용 대상2	인용 대상3	조합 (OR)
A	○	×	○	○
B	○	○	×	○
C	×	×	△(C1)	△
D	×	○	×	○
설명	- C1에서 C를 도출하는 것에 대한 곤란성이 없고 효과의 현저성이 없다면 용이함 - 그렇지 아니하면 용이성이 없어서 등록가능함			

출원 발명	인용 대상1	인용 대상2	인용 대상3	조합 (OR)
A	○	×	○	○
B	○	○	×	○
C	△(C1)	×	×	△
D	○	○	×	○
설명	- C1과 C의 차이가 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 불과하여 그 차이로 인하여 새로운 효과가 발생하지 않는다면 동일성이 있음 - C1에서 C를 도출하는 것에 대한 곤란성이 없고 효과의 현저성이 없다면 용이함 - 그렇지 아니하면 용이성이 없어서 등록가능함			

청구항에 기재된 발명은 전체로서 고려되어야 하며 구성요소 각각이 공지 또는 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정할 수 없다. 즉, 진보성 판단의 기초가 되는 기술적 구성의 곤란성을 평가할 때, 과제해결원리를 배제한 채 청구항에 기재된 구성을 하나하나 분해한 후 선행기술의 대응 구성요소로부터 도출이 곤란한지만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제해결원리에 기초하여 그 발명에 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 **결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체**로서의 구성의 곤란성을 살펴봐야 하며, 이 때 **결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려**하여야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609). 구체적으로, 여러 공지기술을 인용하여 특허의 진보성을 판단할 때 그 인용되는 공지기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 교시(teaching), 암시(suggesting), 동기(motivation) 등이 공지기술에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 특허 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 조합 또는 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 주합발명으로서 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277 참고).

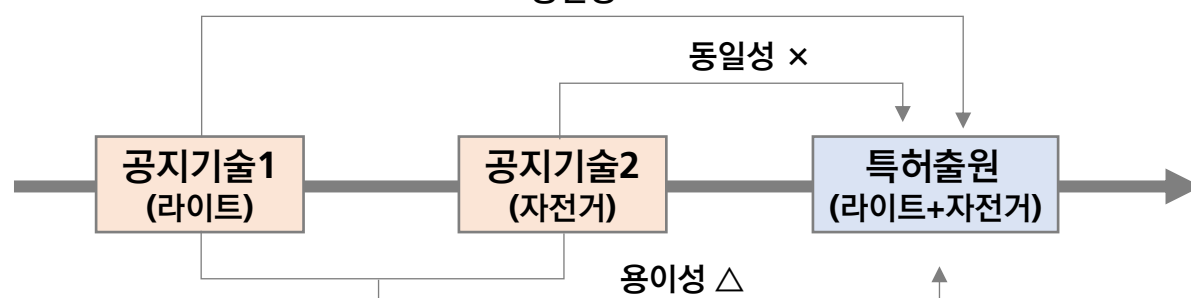
◆ 신규성(法 29①각호) 판단

- 공지기술과 일대일 매칭
- 상위개념이 공지기술이고 하위개념이 출원발명인 경우 일반적으로 동일성이 없어 신규성 상실×

동일성 ×

동일성 ×

용이성 △



◆ 진보성(法 29②) 판단

- 둘 이상의 공지기술을 조합가능
- 공지기술 A와 공지기술 B의 결합, 채택의 곤란성, 효과의 현저성 ○ → 진보성 인정(조합발명 - Combination)
- 공지기술 A와 공지기술 B의 결합, 채택의 곤란성, 효과의 현저성 × → 진보성 부정(주합발명 - Aggregation)

구성요소	공지기술1	공지기술2	분석(OR)
라이트(A)	O	X	O
결합(B)	△	X	△
자전거(C)	X	O	O
소결	신규성은 인정되나, 진보성 인정 여부는 불명확함		

공지기술 A + 다른 기재(@)

특허출원
(a1, a2, a3 중 어느 하나)

a1의 효과: e1, e2, e3

a2의 효과: e4, e5

a3의 효과: e6, e7

* A가 상위개념이고, a1, a2, a3가 A를 한정하 하위개념발명

신규성
요건

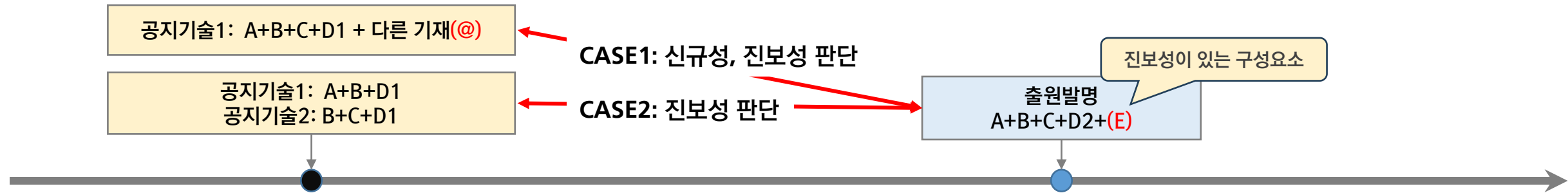
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명(@)이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 참조).

진보성
요건

선택발명에 포함되는 하위개념들 모두(a1, a2, a3)가 공지된 상위개념인 선행발명과 비교하여 구성의 곤란성이 인정되어야 한다. 구성의 곤란성이 인정되는지 여부와 관련해서는 i) 상위개념의 크기, ii) 선행발명이 선택발명을 선택할 동기를 제공하거나 선행발명에 암시가 있는지 여부, iii) 선행발명에 기재된 하위개념발명과 선택발명이 구조적으로 유사한지 여부 등이 고려되어야 한다. 예를 들어, 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 다만, 구성의 곤란성을 따져 보지 않고 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단해서는 안 된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609).

선택발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의학 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609).

효과의 현저성에 의해 진보성을 판단할 때 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명과 비교하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명(a1)의 모든 종류의 효과(e1, e2, e3)가 아니라 그 중 일부(e3)라도 선행발명과 비교하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 참조). 한편, 선택발명에 포함되는 하위개념의 실시형태 중 가장 열등한 것의 효과(a1 > a2 > a3)가 선행발명에 개시된 실시형태 중 가장 우수한 것의 효과와 비교하여 현저하다는 관계가 인정되지 않는다면, 선택발명에 포함되는 하위개념의 실시형태 중 일부의 효과가 선행발명에 개시된 실시형태 중 일부의 효과보다 뛰어나 보인다고 하여 선택발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 볼 수는 없다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2013후1887).

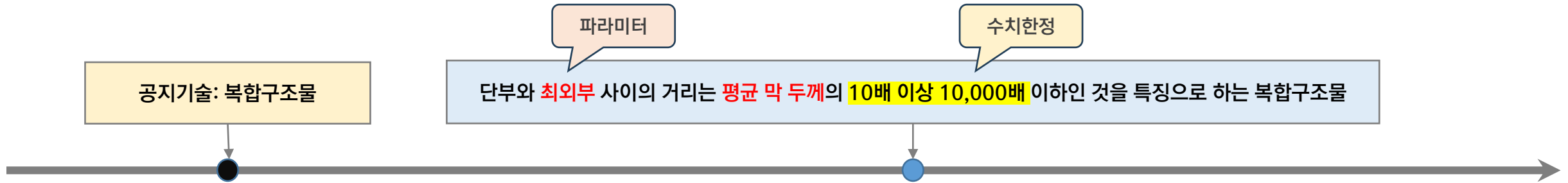
신규성
요건

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이(D1, D2)가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명(@)에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정(D2)이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명(@)에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편 수치한정(D2)이 공지된 발명과 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다(대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015).

진보성
요건

그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에는 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가(E)되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정(D2)이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 특허발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로, 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성이 부정된다(대법원 2023. 7. 13. 선고 2022후10180).

수치한정한 범위 전체(D2)에서 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있어야 한다는 점, 출원 명세서에 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서 기재 자체를 통하여 인식할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은 이상 추후 실험자료에 의하여 인정되거나 확인되는 수치한정의 기술적 의의를 가지고서 당해 수치한정 발명의 진보성 여부를 판단할 수는 없다(특허법원 2009. 5. 22. 선고 2008허1722).



신규성 요건

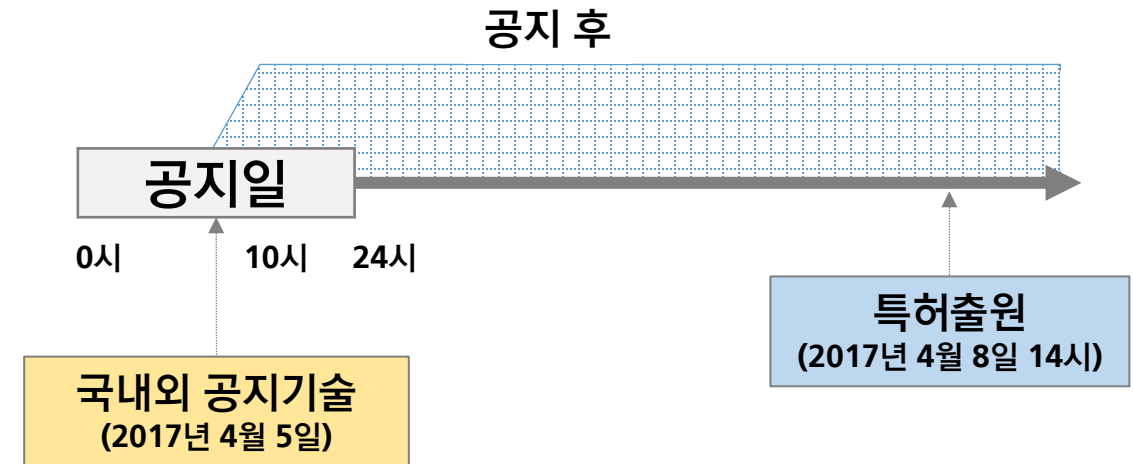
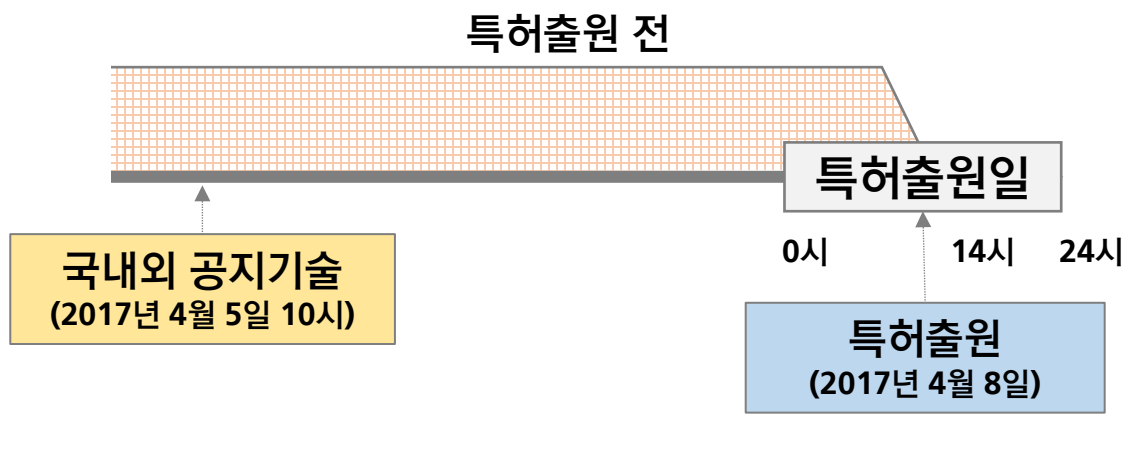
새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 ‘파라미터 발명’과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다(대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결).

진보성 요건

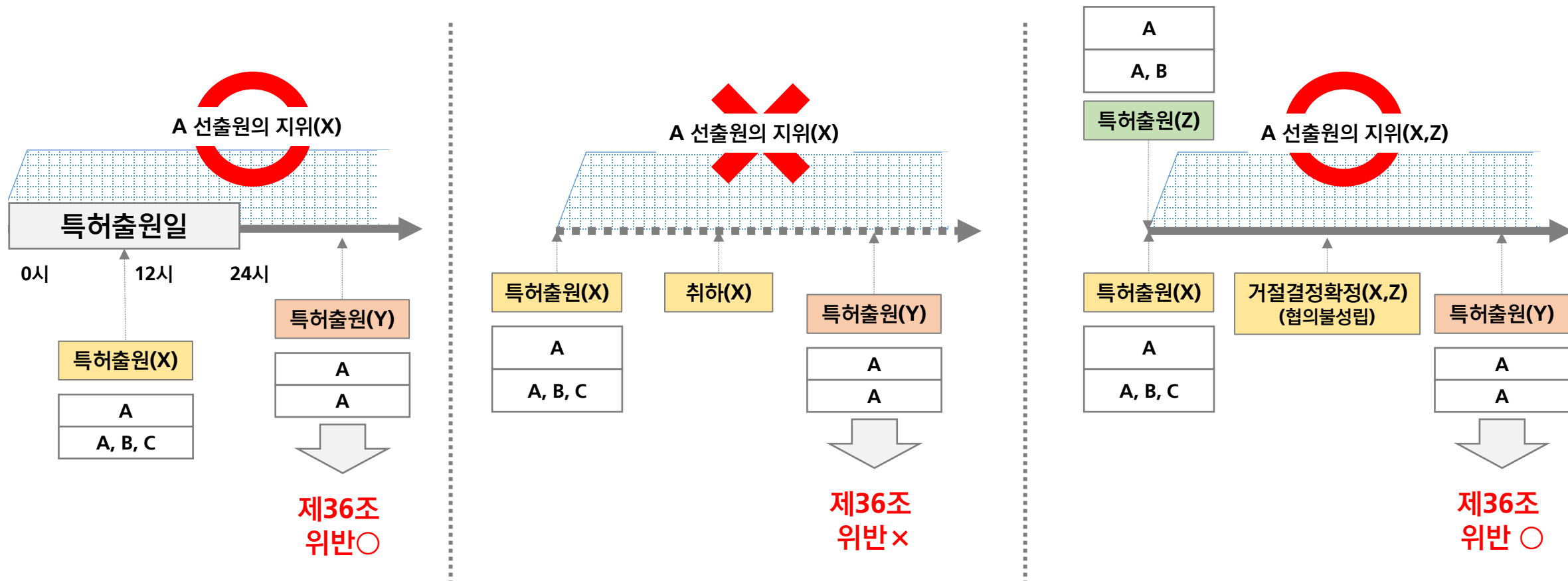
파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. 한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결).

- * 분석기기 등의 발달로 인해 특정 파라미터를 발견해 내기 용이하게 되어 파라미터 발명의 출원이 증가함
- * 파라미터 발명은 물질의 구조를 특정하여 청구범위를 기재하는 것이 아니라, 그 물질이 갖는 물성이나 특성에 대한 파라미터를 사용하여 청구범위가 특정되므로 권리범위를 넓게 설정할 수 있고, 권리침해의 주장 및 증명이 쉬움
- * 또한, 새로이 창작된 파라미터를 이용하는 경우 그 파라미터에 대응되는 선행기술을 찾고 확인하기 어렵기 때문에 현실적으로 등록가능성이 높음

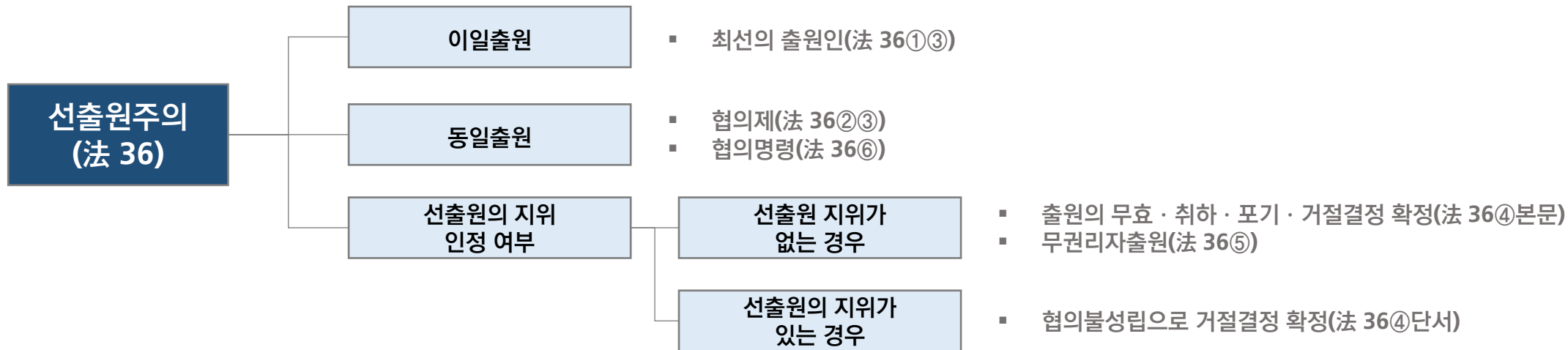
국내외에서 공지된 후부터 공지기술의 지위가 인정되어 이와 동일한 발명은 신규성 위반으로, 이로부터 용이한 발명은 진보성 위반으로 특허를 받을 수 없게 된다.



선출원주의에서 **선후출원의 판단은 선출원의 지위가 있음을 전제**로 한다. 예를 들어, 甲이 A 발명을 먼저 출원하고 乙이 A 발명을 나중에 출원했다고 하더라도 甲의 출원이 무효, 포기 등으로 선출원의 지위가 없어졌다면 乙의 출원은 선출원주의에 위반되지 아니한다. i) 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 특허거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우, ii) 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원의 경우에는 선출원의 지위가 없다(法 36④⑤). 그러나 동일자 출원에 대하여 제36조제2항단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 협의 불성립 등으로 특허거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선출원의 지위가 인정된다(法 36④단서).

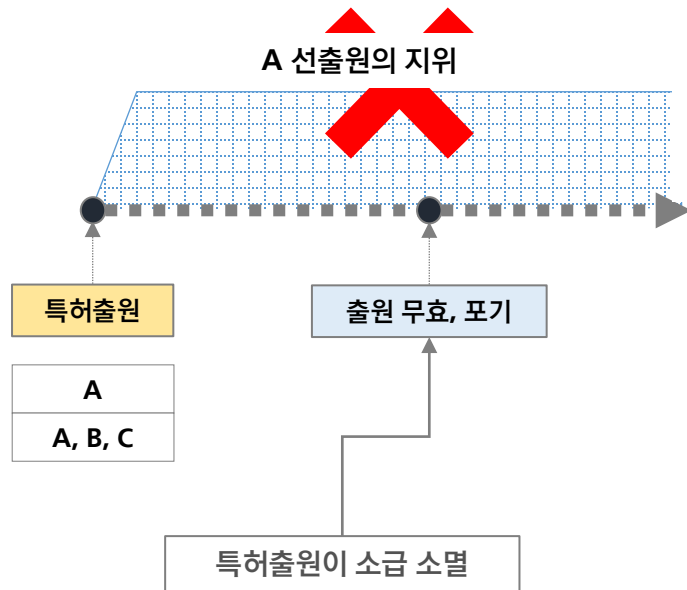


- 제36조(선출원)** ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
 ② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
 ③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.
 ④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 대하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
 2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
 ⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.
 ⑥ 지식재산처장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

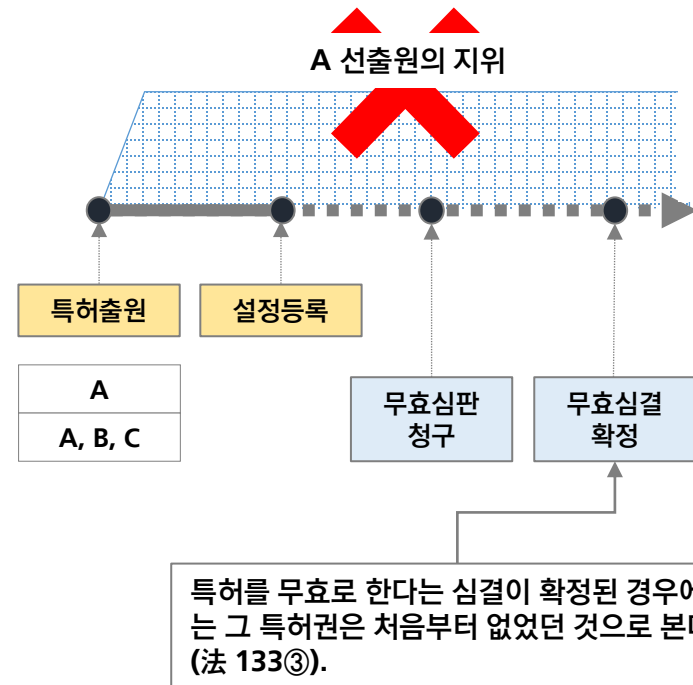


대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결에서는 “동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다.”라고 판시하였고, 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결에서는 “특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다.”고 판시하여, 특허권의 무효와 포기에 대하여 달리 취급하고 있다.

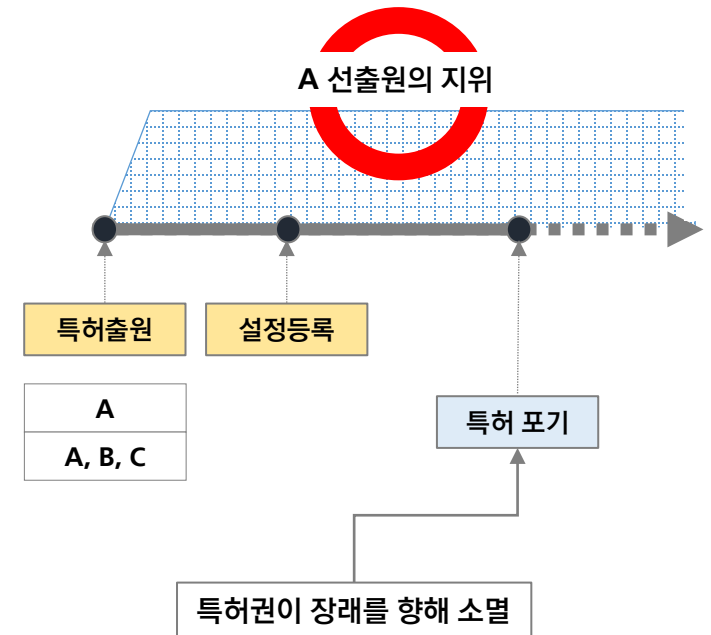
A 선출원의 지위



A 선출원의 지위



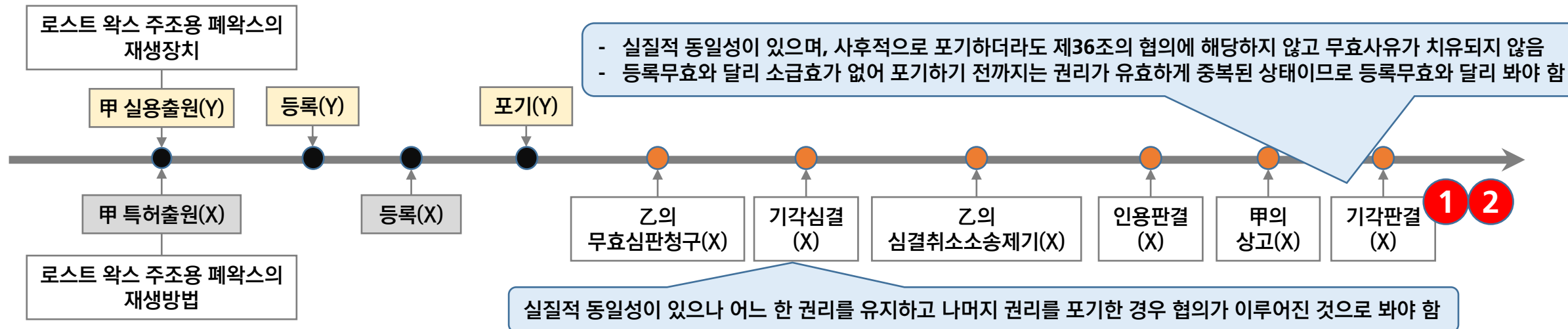
A 선출원의 지위



대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결【등록무효(특)】

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제36조를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 **두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로**, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

[2] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제36조 제3항 등의 적용에 있어 특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 **1) 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 2) 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 3) 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 4) 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다.**



(실질적 동일성의 비판) 출원인이 서로 상이하다고 판단하여 별개의 출원으로 출원한 복수의 발명을 그 구성의 차이에도 불구하고 '실질적으로 동일'하다고 판단하여 모두 무효로 하는 것은, 1) 이와 같은 복수의 출원을 하나의 출원서에 복수의 청구항으로 기재하여 출원하는 경우라면 모두 유효하게 등록될 수 있었을 것이라는 점과, 2) 유사한 복수의 발명을 출원일을 달리하여 출원하는 경우에는 독점권을 부당하게 연장시키는 효과가 발생할 수도 있으나, 출원일이 동일하므로 유사한 복수의 발명을 출원하여 독점권을 향유할 수 있는 기간을 부당하게 연장하는 점이 없다는 점, 3) 특히 발명의 범주의 차이에도 불구하고 동일하다고 판단한 경우에서 물건의 발명과 방법의 발명은 특허권자가 누릴 수 있는 권리의 내용에 있어 큰 차이가 있다는 점, 4) 선출원 판단시의 실질적 동일성 개념의 적용은 미국에서 선출원에 비하여 진보성이 부정되는 후출원이 등록이 되지 아니하는 점과 일견 유사한 점이 있으나 미국에서도 이 경우 기간의 포기서(terminal disclaimer) 제출로 동일인의 경우 경합발명이 모두 등록이 가능하다는 점을 상기하면, 상기와 같은 결과는 매우 부당한 것이라고 생각된다.

(2005후3017) 특허권의 포기에 대해서는 선출원의 지위가 인정됨

문언적 해석

법규정(법리)의
취지

특허법의 목적

다른 법률과의
형평성

제36조에 선출원의 지위 불인정 사유로 규정되어 있지 않음

제120조에 의한 특허권의 포기는 특허권의 포기는 출원의 포기와 달리 소급효가 인정되지 않음

제120조에 의한 특허권의 포기는 제101조제1항제1호에 따라 등록이 효력발생요건인데
대외적인 공시방법으로 충분하지 않음

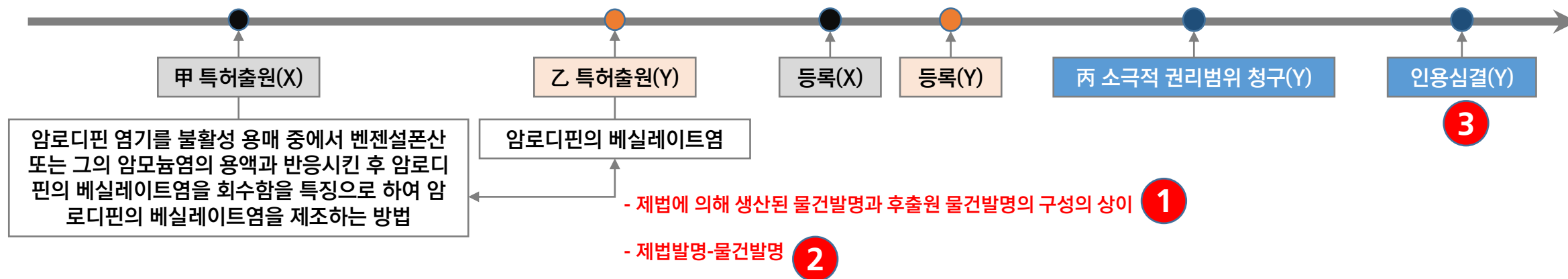
제120조에 의한 특허권의 포기는 특허권자가 시기와 대상을 임의로 정할 수 있어서 법적 안정
성을 해침

대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결 【권리범위확인(특)】

[1] 구 특허법(1990.1.13.법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것)제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선출원주의를 채택하고 있다. 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용 효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다.

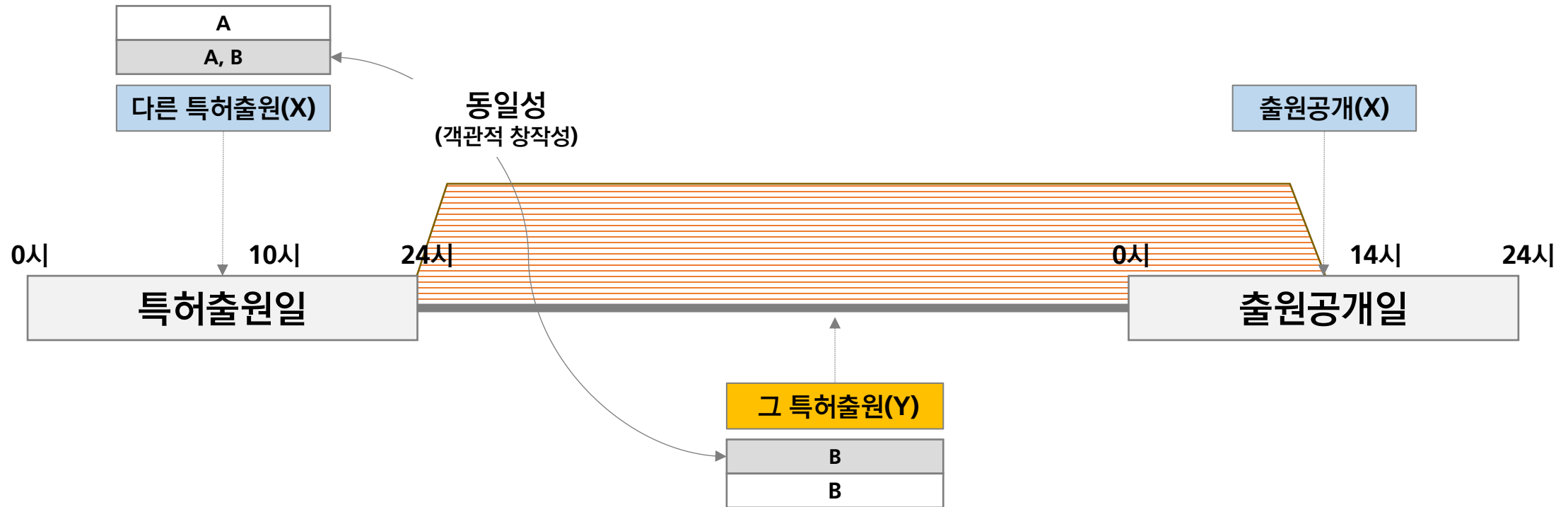
[2] 구 특허법(1990.1.13.법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것)제11조 제1항을 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

[3] 등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선출원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선출원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.

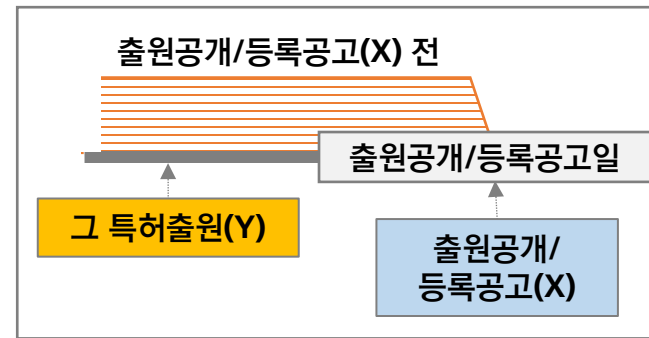
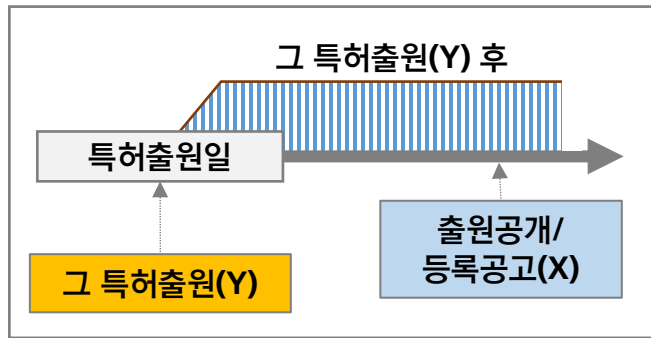
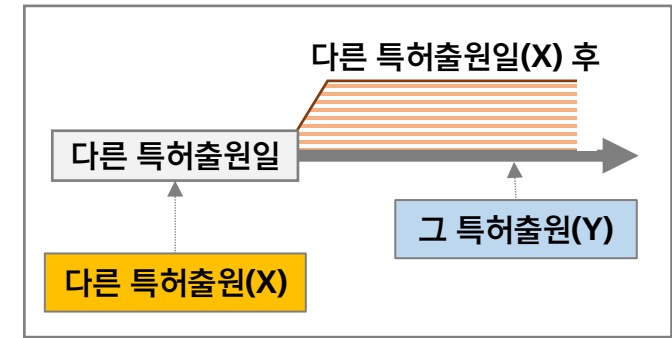
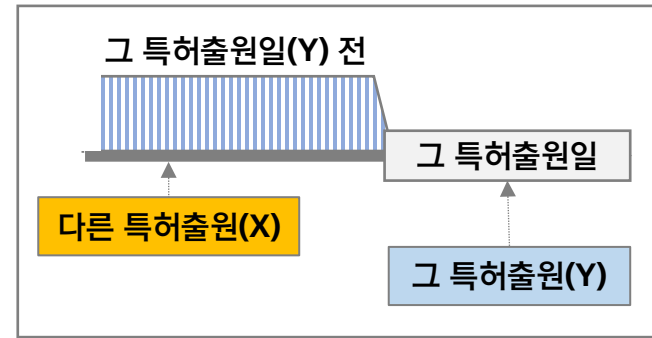


제29조(특허요건) ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

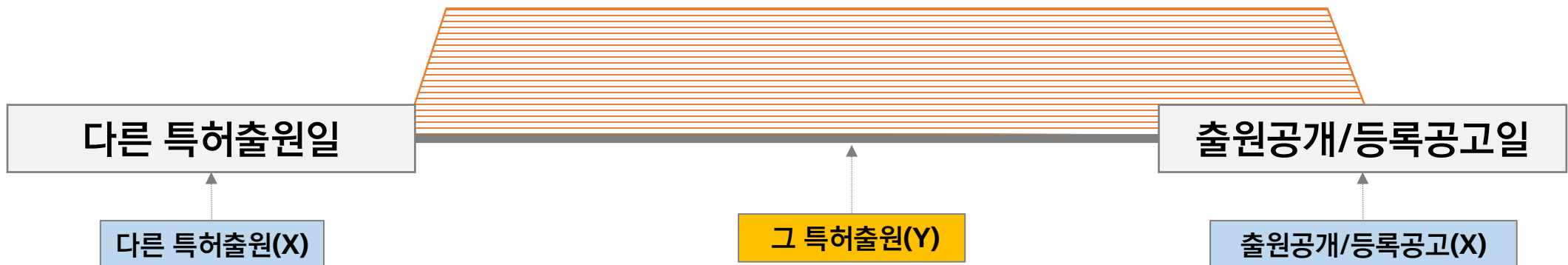
1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공개된 특허출원일 것



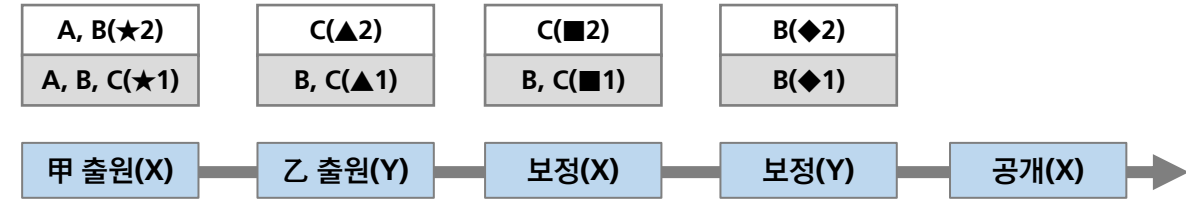
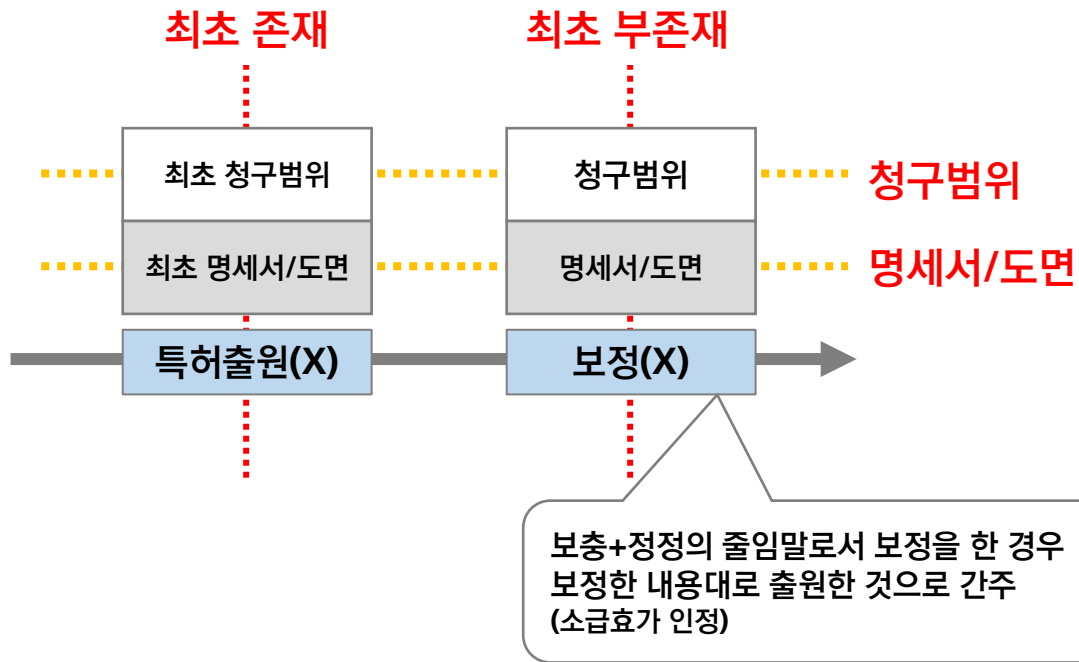
그 특허출원일(Y) 전에 출원된 다른 특허출원(X)일 것
= 다른 특허출원일(X) 후 그 특허출원(Y)이 있을 것



그 특허출원(Y) 후에 출원공개나 등록공고된 다른 특허출원(X)일 것
= 다른 특허출원(X)의 출원공개나 등록공고 전에 그 특허출원(Y)이 있을 것



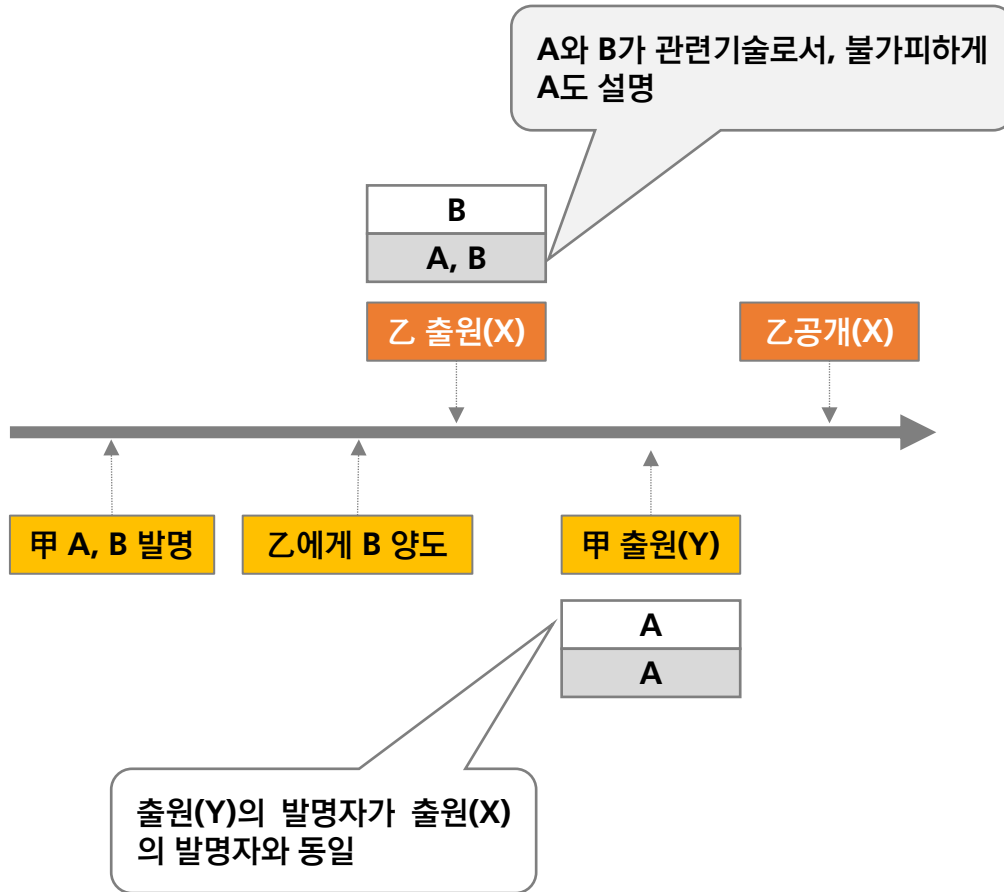
최초란 출원할 때 처음으로 첨부된 것을 기준으로 한다는 의미이며, **보정을 했을 때 판단대상을 결정하는 기준**이 된다. 구체적으로, 최초 단어가 있으면 보정과 상관없이 가장 처음 첨부된 것을 기준으로 판단하고, 최초 단어가 없으면 보정했을 때 가장 나중 것을 기준으로 판단한다.



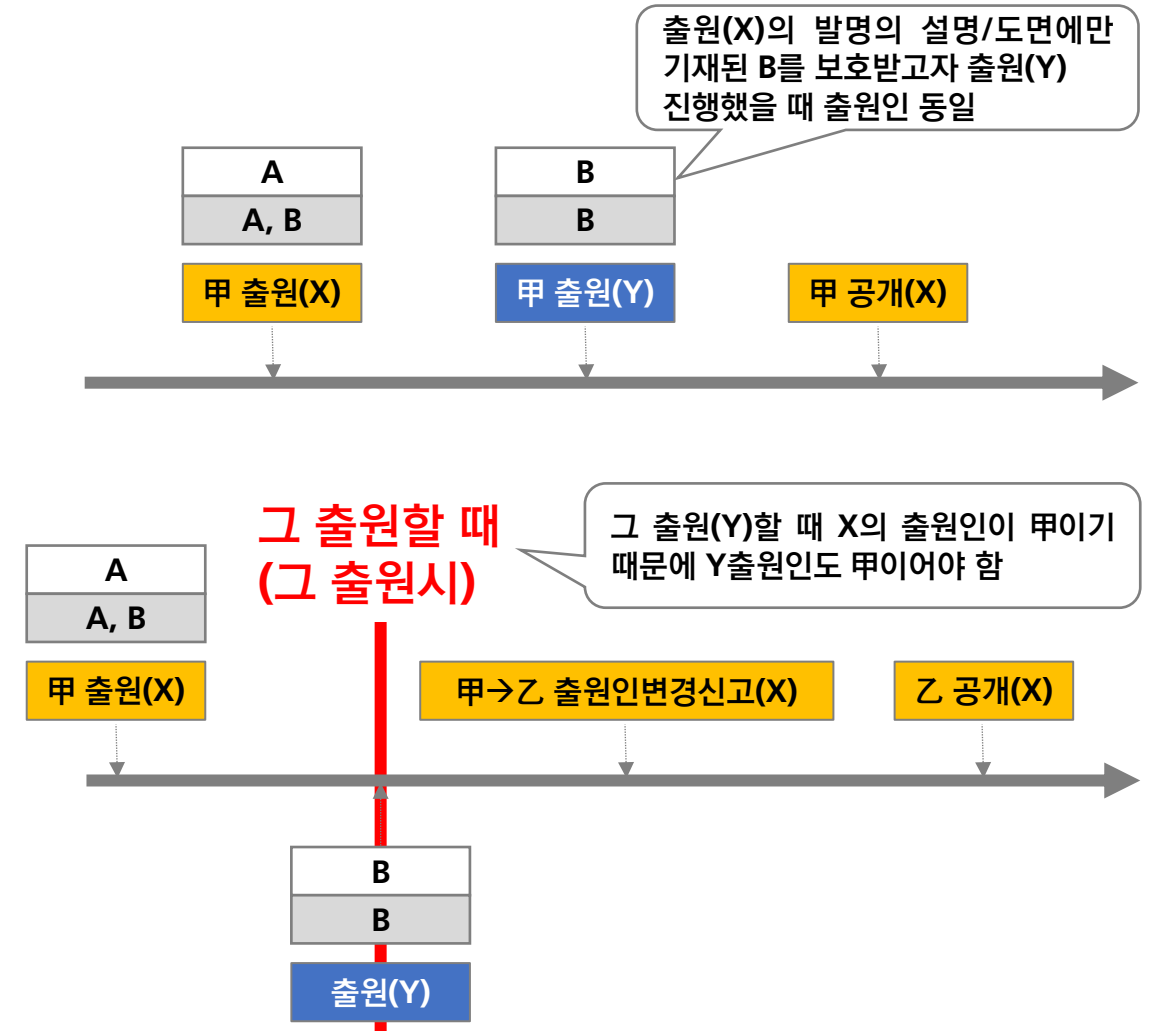
판단대상	선(다른) 출원	후(그) 출원
선출원주의	청구범위(■2)	청구범위(◆2)
확대된 선출원의 지위	최초 명세서/도면(★1)	청구범위(◆2)

X 출원의 최초 명세서 또는 도면은 ★1, 최초 청구범위는 ★2를 의미하고, 명세서 또는 도면은 ■1, 청구범위는 ■2를 의미한다. Y 출원의 등록가능성과 관련하여서는, Y 출원의 청구범위에 기재된 발명(◆2)이 X 출원과 관련하여 확대된 선출원, 선출원주의에 위반되는지 여부가 문제이다. 확대된 선출원 위반 여부는 X 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명(★1)과 비교하여 동일성이 있는지 판단하고, 선출원주의 위반 여부는 X 출원의 청구범위에 기재된 발명(■2)과 비교하여 동일성이 있는지 판단한다.

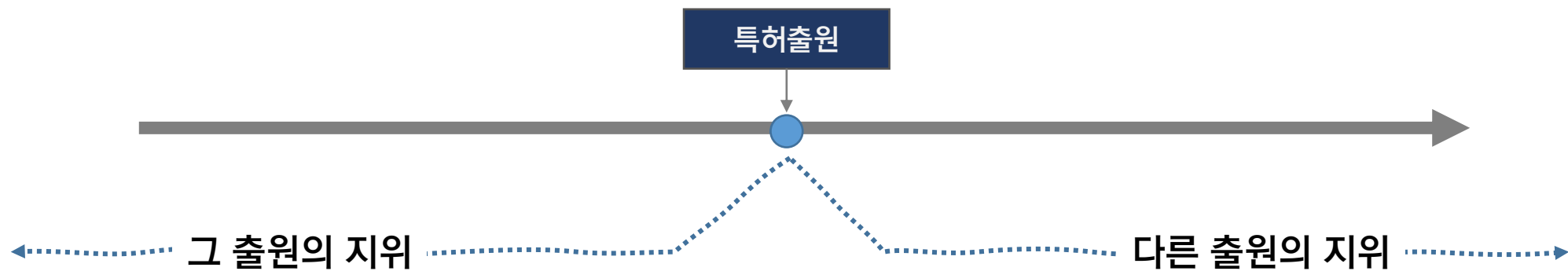
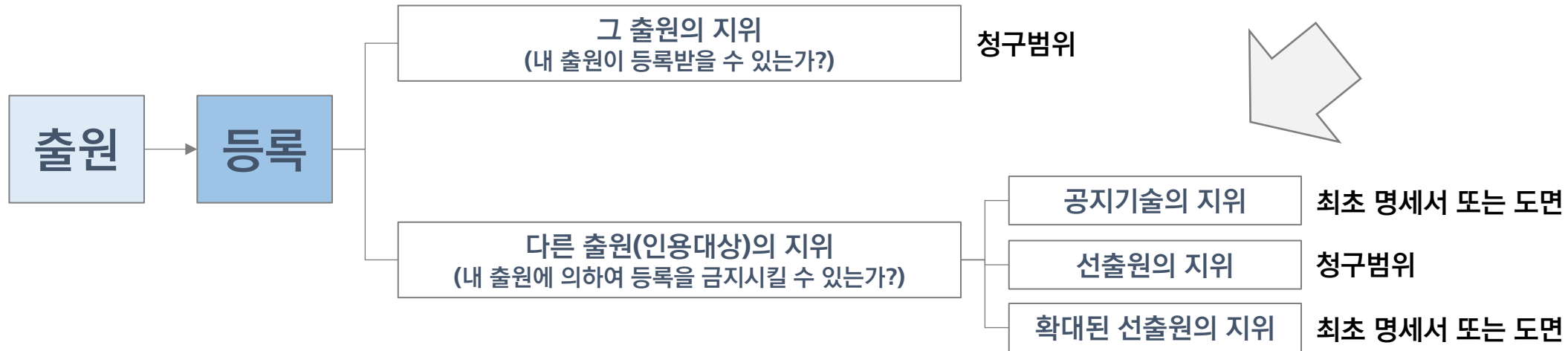
발명자 동일



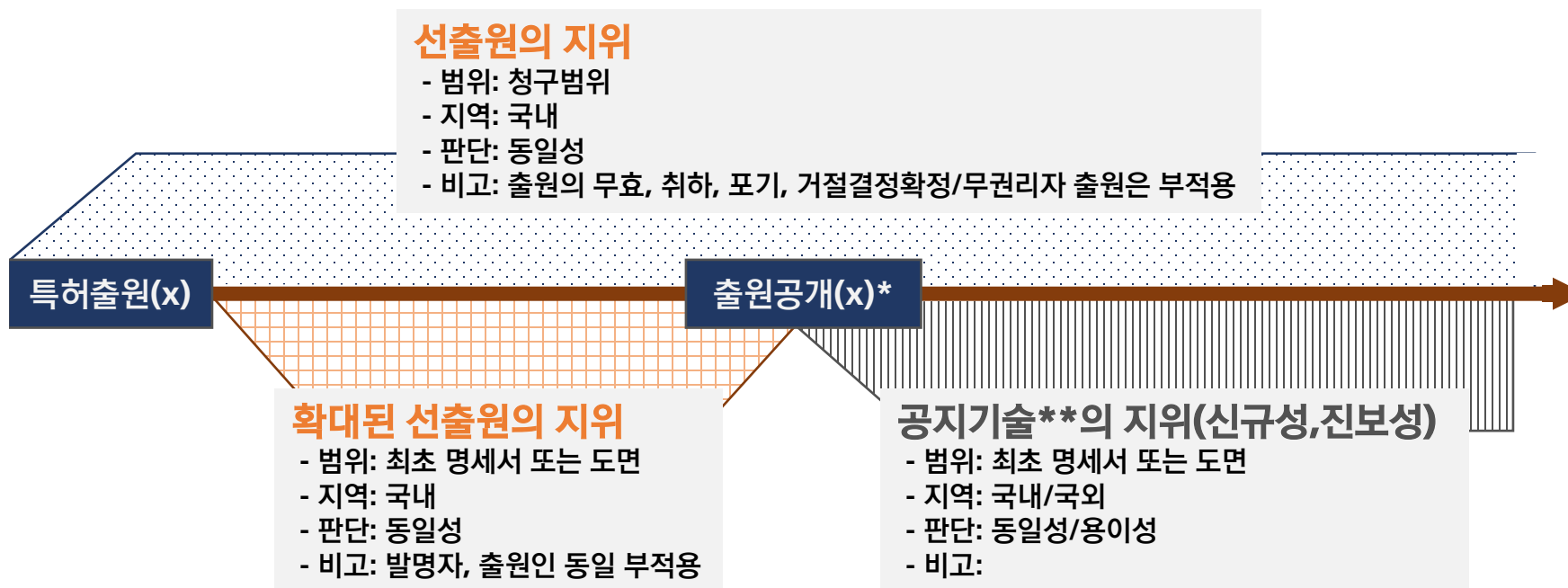
그 특허출원한 때의 출원인 동일



등록금지적 효력



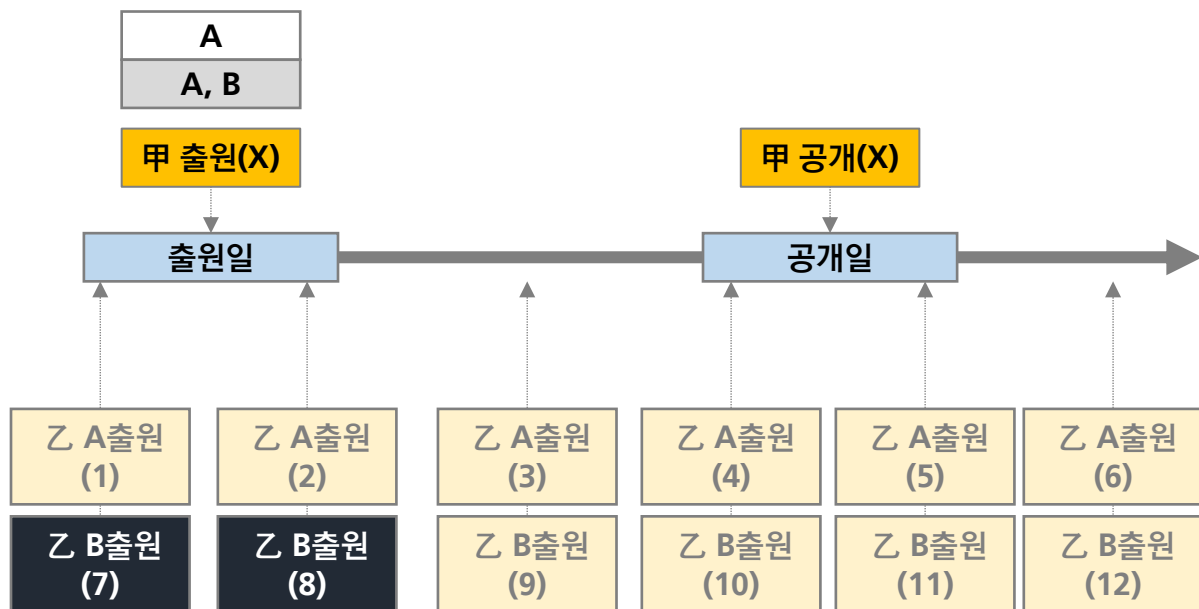
다른 출원의 지위	공지기술의 지위	선출원의 지위	확대된 선출원의 지위
시기	출원공개 또는 설정등록된 후부터 발생(法 216)	출원한 날부터 발생	출원한 날의 다음날부터 발생하여 출원공개 또는 등록공개 전까지 인정
범위	최초 명세서 또는 도면	청구범위	최초 명세서 또는 도면
지역	국제주의	국내주의	국내주의
판단	동일성과 용이성 판단	동일성 판단	동일성 판단
비고		출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정(단, 협의불성립으로 거절결정이 확정된 경우는 제외)된 경우나 무권리자 출원의 경우 부적용	발명자나 그 특허출원할 때의 출원인 동일의 경우 부적용



* 출원공개(x)는 일반적으로 특허출원(x)한 날로부터 1년 6개월이 지난 후이나, 1) 조기공개신청을 하거나 2) 그 전에 실체심사하여 등록된 경우에는 1년 6개월 전에 공개될 수도 있다.

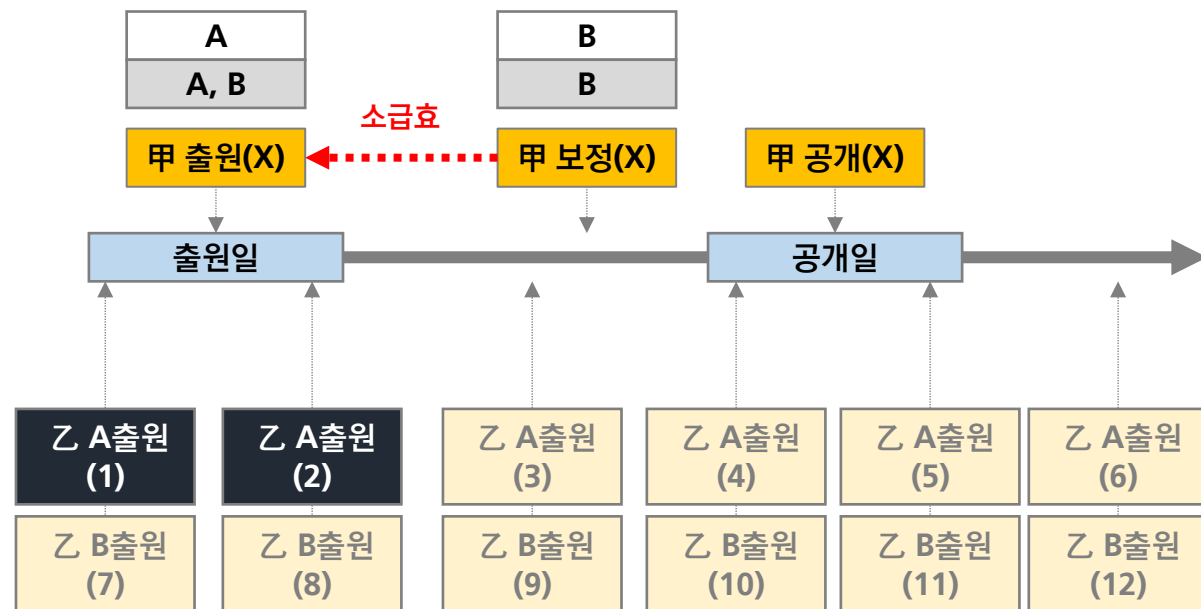
** 공지기술의 지위는 1) 공지, 2) 공연실시, 3) 반포된 간행물에 게재 또는 4) 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 경우에 인정이 된다. 그 중에서 출원공개(x)는 반포된 간행물에 게재에 해당한다. 다만, 특허출원(x) 자체는 공개되지 않기 때문에 공지기술의 지위를 갖지 않는다.

시기



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
신규성 위반	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○
선출원 위반	○ 협의	○ 협의	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
확선 위반	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○	×	×

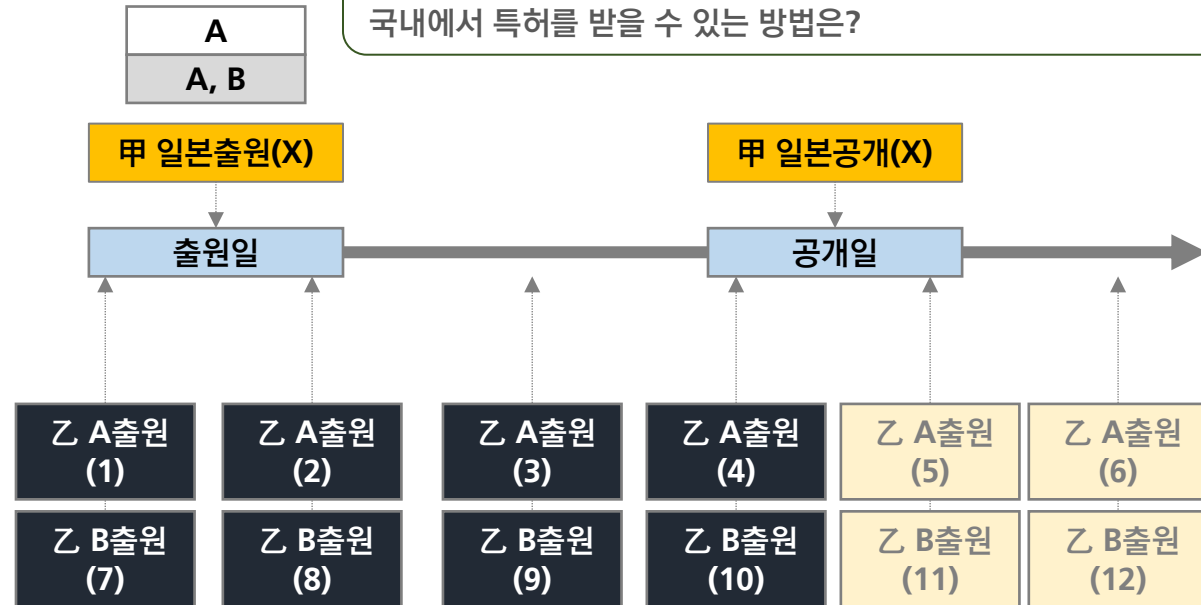
범위



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
신규성 위반	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○
선출원 위반	×	×	×	×	×	×	○ 협의	○ 협의	○	○	○	○
확선 위반	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○	×	×

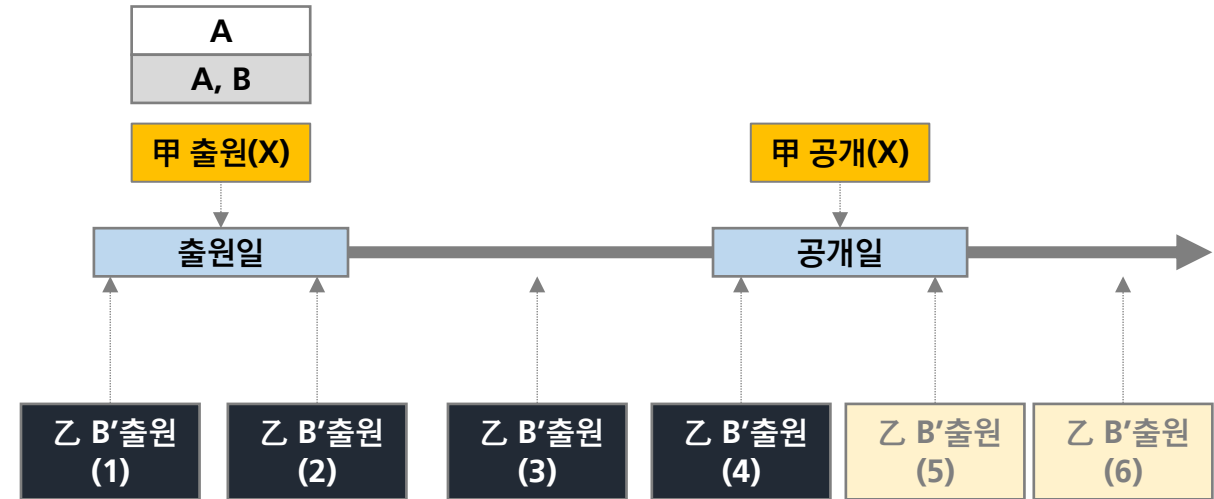
지역

외국에서 시장조사를 하던 중 괜찮은 아이템을 발견했는데, 국내에서 조사해 보니 아무도 특허등록을 해 놓지 않은 상태이다. 국내에서 특허를 받을 수 있는 방법은?



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
신규성 위반	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○
선출원 위반	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
확선 위반	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

판단

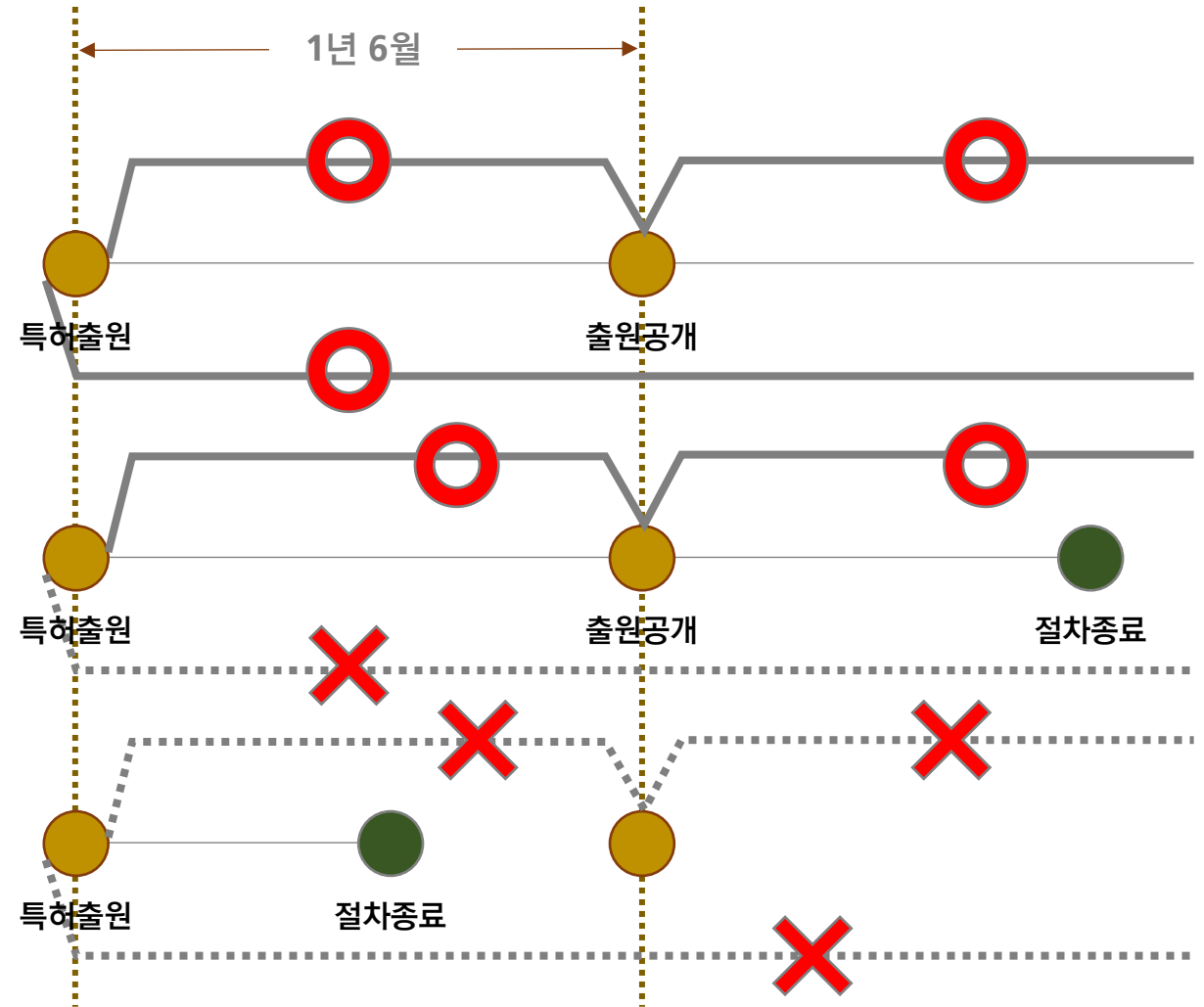


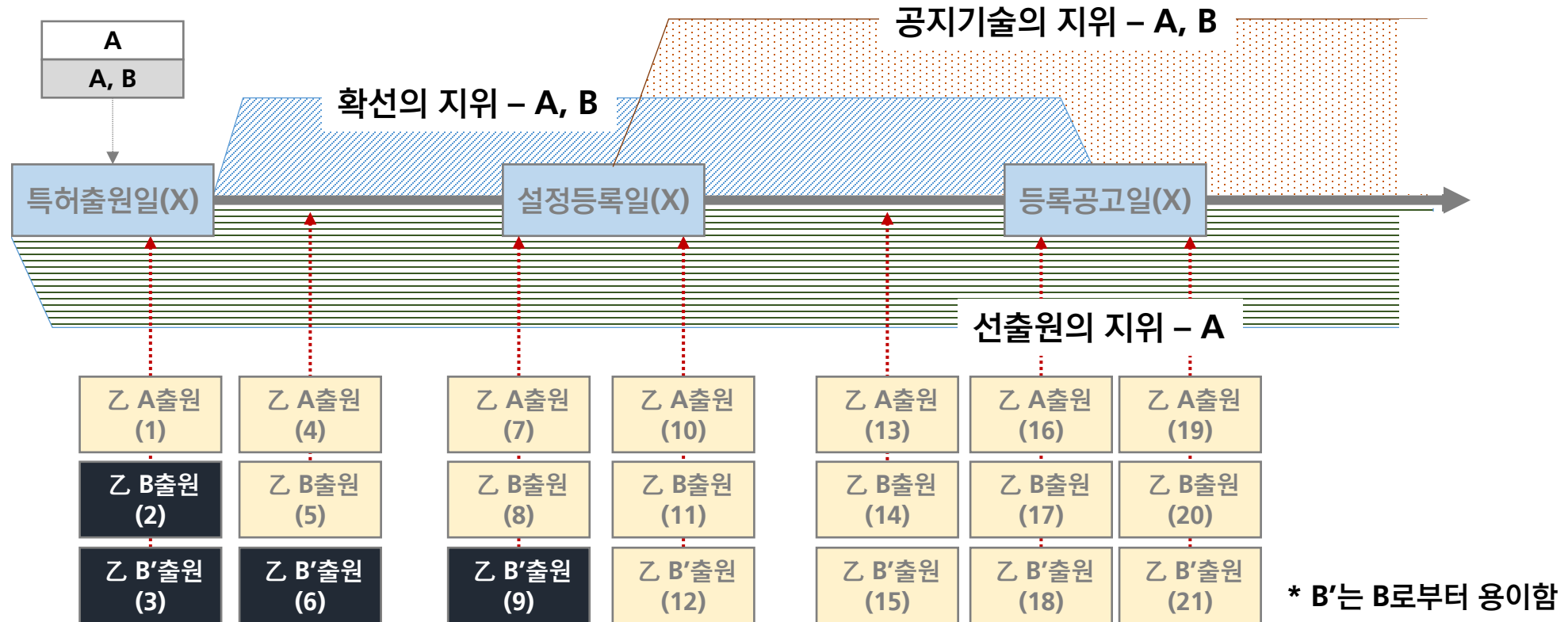
* B'는 B로부터 용이함

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
신규성 위반	×	×	×	×	×	×
진보성 위반	×	×	×	×	○	○
선출원 위반	×	×	×	×	×	×
확선 위반	×	×	×	×	×	×

출원공개 전 출원의 무효, 취하, 포기, 거절결정 확정에 의하여 출원 절차가 종료되면 등록금지적 효력이 남지 않는다. 한편, 출원공개 후 출원 절차가 종료되면 공지기술의 지위와 확대된 선출원의 지위가 남지만 선출원의 지위는 남지 않게 된다.

시기	선출원의 지위	확대된 선출원의 지위	공지기술의 지위
공개 전 소멸	불인정	불인정	불인정
공개 후 소멸	불인정	인정	인정



[illegible]

1차적으로 시기적 기준에 의하여 신규성, 진보성, 선출원주의, 확대된 선출원 중 논점을 추출한 후, 2차적으로 객체적, 지역적 기준 및 판단방법을 고려하여 구체적인 등록가능성을 판단한다.

출원(일) 기준으로 앞쪽 영역을 살펴서,
출원이 있는 경우 제36조, 제29조제3항(단, 출원 후 공개가 있어야 함)을
공개가 있는 경우 제29조제1항 및 제2항을
논점으로 추출함

제29조, 제36조 中
논점의 추출
(시기)

비교
(객체, 지역, 방법)

결론도출

제36조+제29조제1항제2항

④

제36조+(제29조제3항+제29조제1항제2항 中 하나)

③

제36조+제29조제3항

②

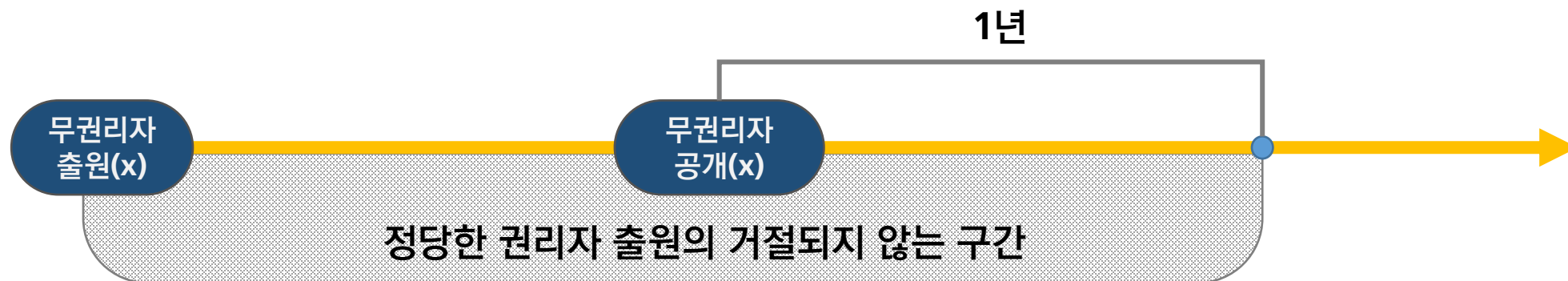
제36조

①

특허출원(X)

출원공개(X)

* 정당한 권리자 출원이 무권리자 출원일로 소급효가 인정되지 않을 때 정당한 권리자 출원이 무권리자 출원 또는 공개에 의하여 거절되지 않는 구간?



등록금지적 효력	미완성발명출원	무권리자출원
선출원의 지위	불인정(제36조제4항)	불인정(제36조 제5항)
확대된 선출원의 지위	불인정(判例)	인정 (단, 정당한 권리자 출원에 대해서는 발명자가 동일하여 불인정)
공지기술의 지위	인정(判例)	인정 (단, 정당한 권리자 출원에 대해서는 의사에 반한 공지이기 때문에 공지된 날로부터 12개월 이내에 정당한 권리자가 출원한 경우 불인정)

제41조(국방상 필요한 발명 등) ① 정부는 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 받은 경우에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.

② 정부는 특허출원된 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다.

③ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대해서는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

④ 제2항에 따라 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.

⑥ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.

⑦ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 및 비밀취급의 절차, 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 수용, 보상금 지급의 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제106조(특허권의 수용) ① 정부는 특허발명이 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허권을 수용할 수 있다.

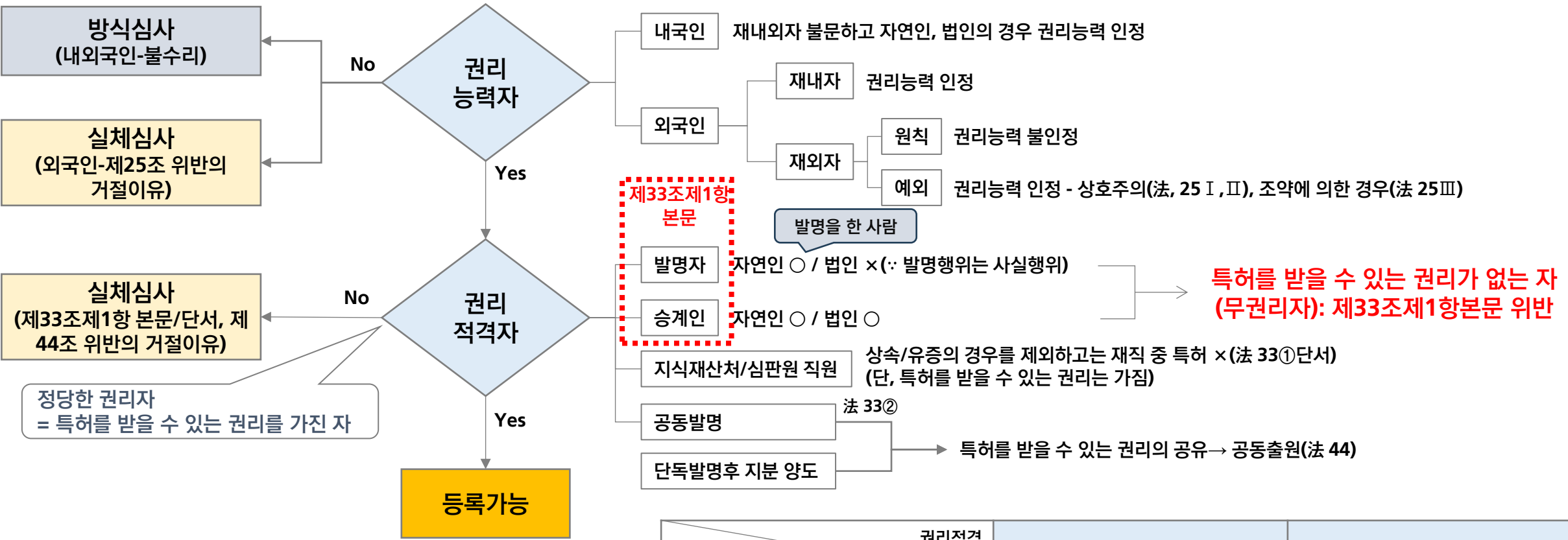
② 특허권이 수용되는 경우에는 그 특허발명에 관한 특허권 외의 권리는 소멸된다.

③ 정부는 제1항에 따라 특허권을 수용하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

④ 특허권의 수용 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

구분	법 규정	취 급	요 건	보 상	비 고
등록 전	제41조 제1항	외국에의 출원금지	국방상 필요	○(法41③)	1. 위반시 특허를 받을 수 있는 권리 포기, 보상금청구권 포기 간주(法 41⑤⑥) 2. 위반시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형(法 229의3), 양벌규정 적용(法 230)
		비밀취급명령			
	제41조 제2항	불특허	전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요	○(法 41④)	
		수용			
등록 후	제106조 제1항	수용		○(法 106③)	1. 특허권 이외의 권리 소멸(法 106②) 2. 질권자는 보상받지 못함(·물상대위가능(法 123))

출원인이 되기 위해서는 i) 일반적인 권리의 주체가 될 수 있는 능력인 권리능력이 있어야 하며, ii) 권리능력이 있는 자라 하더라도 해당 발명에 대한 권리의 주체가 될 수 있는 권리적격이 있어야 한다.



권리적격		발명자	승계인
권리능력	자연인	○	○
	법 인	×(∵ 발명행위가 사실행위)	○

제33조제1항본문 위반

제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.
→ 제33조제1항본문 위반인 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자를 무권리자라고 한다.

- 발명자가 아닌 자로서 승계인이 아닌 자(모인자)
- 구성을 변경했지만 진보성이 없는 등 기술적 사상의 창작에 기여하지 않은 자(2009후2463)
- 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 승계인이 다시 특허를 받을 수 있는 권리를 재양도한 후 출원한 자(2006허6143)
- 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 스스로 출원한 경우 (2008허3018)

- 무권리자 출원일지라도 정당한 권리자로 출원인변경이 된 경우에는 제33조제1항본문 위반 하자 치유
- 착오로 등록되었을지라도 정당한 권리자에게 이전등록한 경우에는 제33조제1항본문 위반 하자 치유(法 133①Ⅱ단서)

제44조 위반

제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유*인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

* 구법에서는 제33조제2항에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에 적용

특허를 받을 수 있는 권리의 공유		단독발명후 지분이전	공동발명
제44조 위반	구법	불인정 (계약상 채무불이행)	인정
	현행법	인정	인정

- 공동발명하여 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 단독으로 출원한 경우
- 단독발명후 지분의 일부를 이전하여 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 단독으로 출원한 경우

판단시 기준

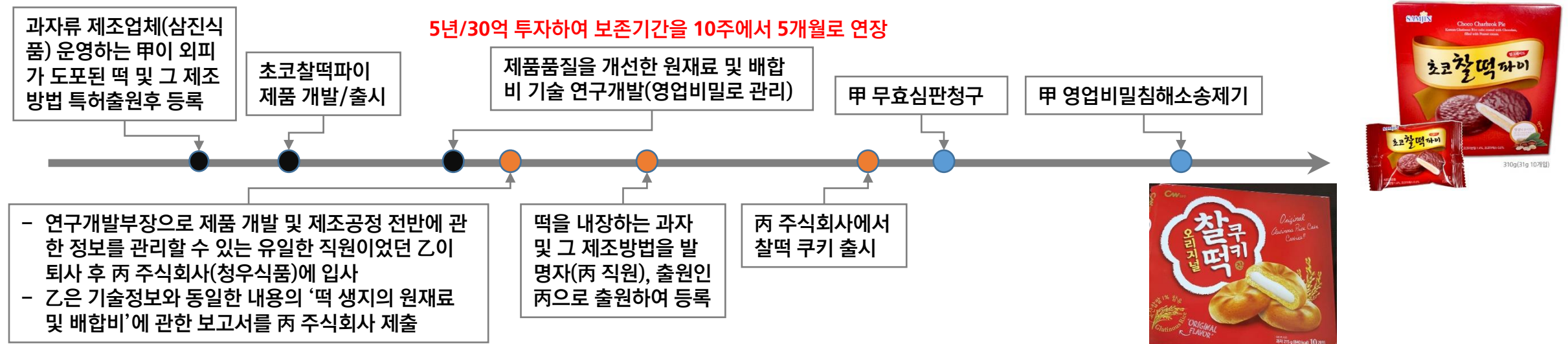
- 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우인데 일부가 지분 모두를 이전받아 단독 권리자가 된다면 제44조 위반 하자 치유 (2004허5894)
- 착오로 등록되었을지라도 다른 공유자에게 지분을 이전등록한 경우에는 제44조 위반 하자 치유(法 133①Ⅱ단서)

대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 【등록무효(특)】

甲이 경영하는 개인업체 연구개발부장 乙이 丙 회사로 전직하여 甲의 영업비밀[이하 ‘모인(冒認)대상발명’이라 한다]을 丙 회사 직원들에게 누설함으로써 丙 회사가 甲의 모인대상발명을 변형하여 명칭이 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 특허발명을 출원하여 특허등록을 받은 사안에서, 특허발명의 특징적인 부분인 ‘떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인 구성 2’는 모인대상발명의 구성과 실질적인 차이가 없고, 丙 회사가 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 丙 회사가 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다는 이유로, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 따라 그 등록이 무효이다.

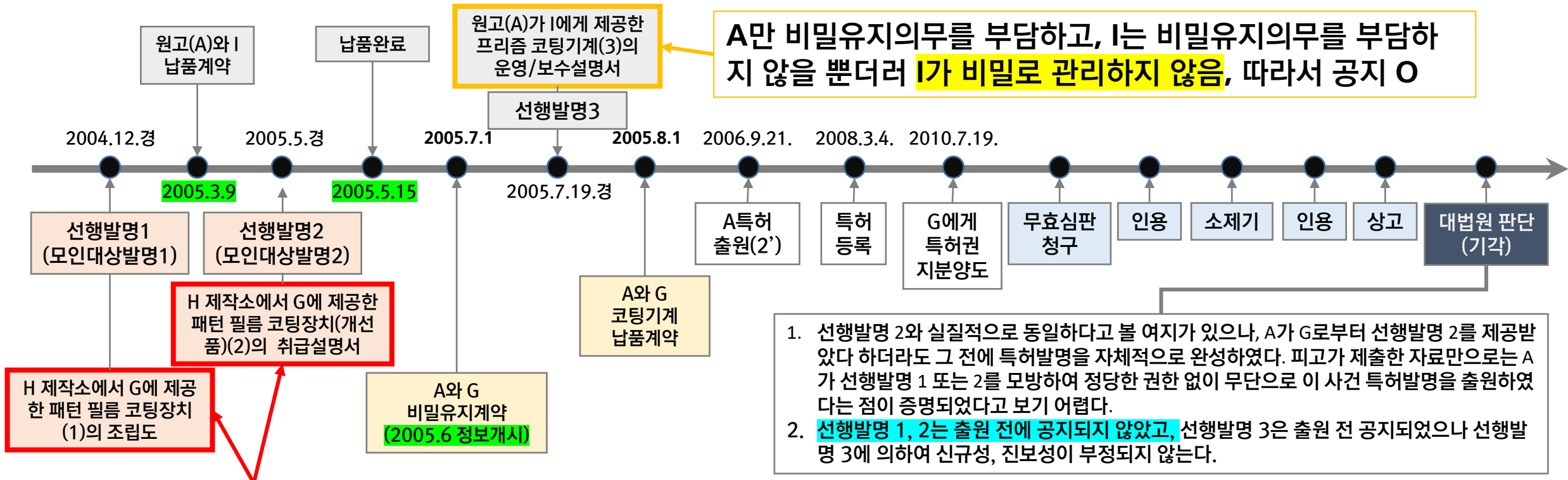
의정부지방법원 2011. 9. 8. 선고 2009가합7325

과자류 제조업체를 운영하는 甲이 ‘외피가 도포된 떡 및 그 제조방법’에 관한 특허발명 등록을 마치고 ‘초코찰떡파이’라는 제품을 개발·출시한 후 상당한 시간과 비용을 투입하여 제품 품질을 개선한 ‘원재료 및 배합비’에 관한 기술을 연구·개발하였는데, 甲 업체의 연구개발부장으로 제품 개발 및 제조공정 전반에 관한 정보를 관리할 수 있는 유일한 직원이었던 乙이 퇴사 후 丙 주식회사에 입사하여 위 기술정보와 동일한 내용의 ‘떡 생지의 원재료 및 배합비’에 관한 보고서를 제출하여 丙 회사가 ‘찰떡쿠기’라는 제품을 출시·판매한 사안에서, 甲의 기술정보가 상당한 인적·물적 시설을 투입하여 개발한 것으로 甲 업체의 주력 상품인 찰떡초코파이의 핵심 기술이고, 일반적으로 알려져 있지 아니함은 물론, 甲이 乙을 포함한 전 직원들에게서 영업비밀 준수에 관한 서약서를 받는 등 기술정보를 엄격하게 관리하여 비밀로 유지·관리하여 온 점 등에 비추어, 위 기술정보는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에 정한 영업비밀에 해당하고, 丙 회사가 乙을 통하여 취득한 위 영업비밀을 이용하여 찰떡쿠기의 개발에 성공하거나 또는 개발 성공에 필요한 시간적·인적·물적 비용을 상당 부분 단축·절감하였다고 보이고, 영업비밀과 丙 회사의 기술 사이에 일부 차이점이 존재하더라도, 丙 회사가 위 영업비밀을 자신의 영업활동에 이용하여 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용한 이상, 영업비밀을 침해하였다고 보이므로, 丙 회사는 영업비밀 침해행위로 인하여 甲이 입은 손해를 배상할 책임이 있다(단, 영업비밀의 보호기간을 乙이 甲 업체를 퇴직한 날을 기준으로 3년으로 인정함).



대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결【등록무효(특)】

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(이하 '무권리자'라고 한다)이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다. 한편 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 등 참조).

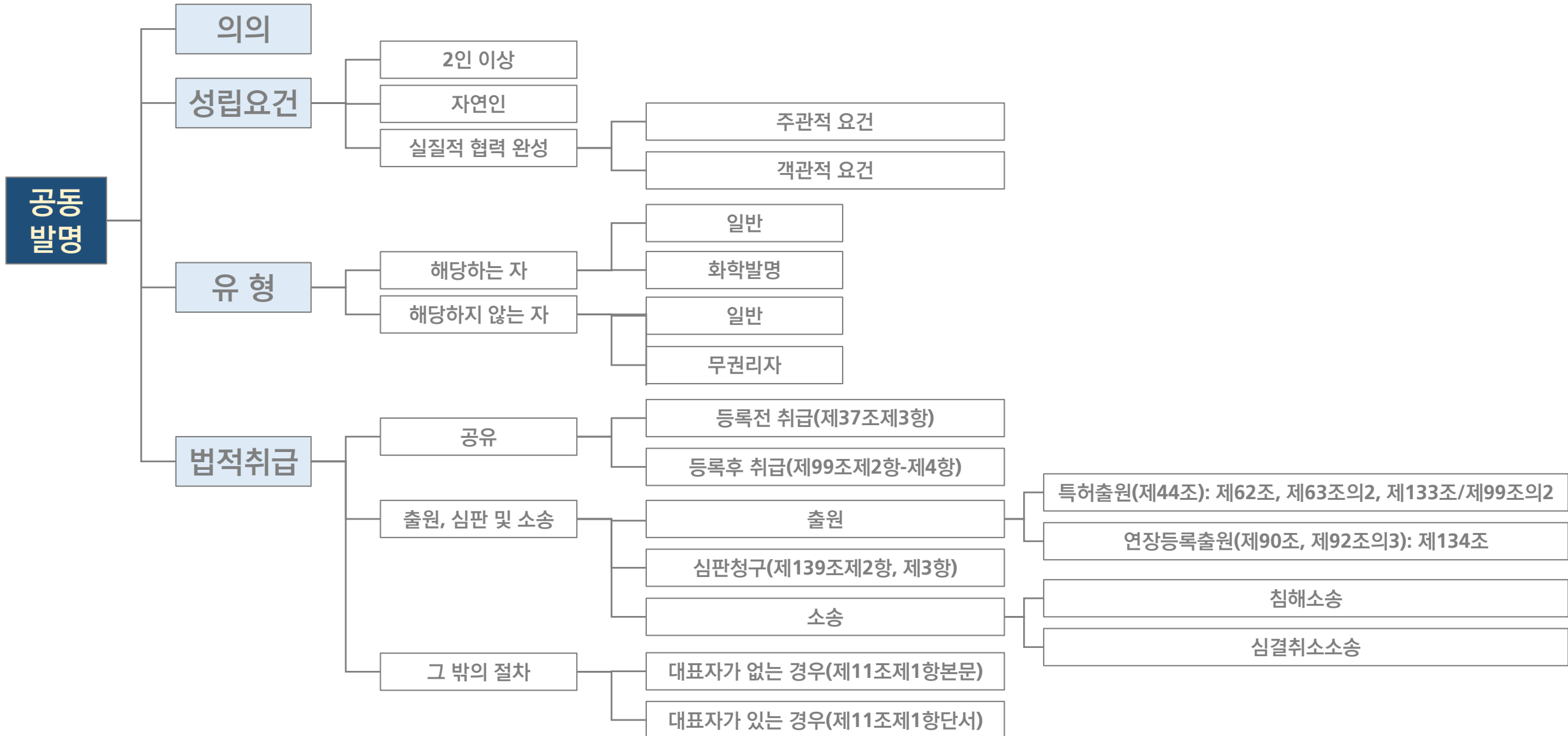


공동발명이란 **2명 이상의 자연인이 실질적으로 협력하여 함께 완성한 발명**을 말한다. 공동발명자가 되기 위해서는 이루는 기술적 사상의 창작에 실질적 협력하였다는 객관적 요건과 상호 협력하여 발명행위를 수행한다는 주관적 요건이 필요하다. 실질적 협력이란 발명의 착상단계에서 구체화하는 단계에 실질적으로 관여하는 것을 의미한다. 따라서 단순한 보조자, 관리자, 위탁자, 자본주 등은 공동발명자가 되지 못한다.

발명자에 해당하는 자	발명자에 해당하지 아니한 자
- 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상한 자 - 타인의 착상에 의거 연구를 하여 발명을 완성하게 한 자 - 타인의 착상에 대하여 구체화하는 기술적 수단을 부가하여 발명을 완성한 자 - 구체화하기 위해서 약간 불완전한 착상을 하고 타인에게 일반적인 지식의 조언 또는 지도를 얻어 발명을 완성한 자 - 타인의 발명에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하는 발명을 한 자 - 화학발명의 경우 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여한 자	- 발명자에게 자금을 제공하거나 설비이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순후원자, 위탁자) - 희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 아니한 자(단순 관리자) - 타인이 제시한 착상 속에서 실용성이 있을 것을 선택한 것에 지나지 아니한 자 - 그 발명에 관하여 착상만 하고 구체화하는 과정에서 실질적으로 관여하지 아니한 자 - 발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 제시된 제도, 실험 등을 한 것에 지나지 아니한 자(단순보조자) - 단지, 일반 지식의 조언 또는 제시를 주기만 한 자 - 구성을 변경했지만 기술적 사상의 창작에 기여하지 않은 자

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 【직무 발명 보상금】

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, i) 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, ii) 연구자를 일반적으로 관리하였거나, iii) 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, iv) 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, i) 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, ii) 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, iii) 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 **화학발명의 경우에는** 그 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 **실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점**에서 공동발명자인지를 결정하여야 한다



서울고등법원 2024. 5. 16. 선고 2023누52088 특허출원무효처분 취소 청구의 소

[1] 원고가 이 법원에서 주장하는 사유는 제1심에서의 주장과 크게 다르지 않고, 제1심 및 이 법원에 제출된 증거와 이 법원에서의 변론 내용을 종합하여 보더라도 제1심의 판단은 정당한 것으로 인정된다. 이에 이 법원이 기재할 이유는 원고가 이 법원에서 강조하거나 새롭게 한 주장에 대하여 제2항에서 추가로 판단하는 것 외에는 제1심판결의 이유와 같으므로 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제420조 본문에 따라 이를 인용한다.

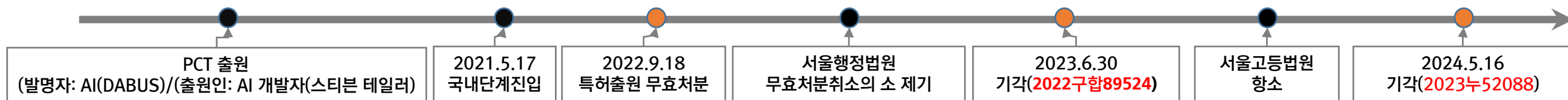
[원심판결: 서울행정법원 2023. 6. 30. 선고 2022구합89524 특허출원무효처분 취소 청구의 소]

- 특허법 제2조 제1호는 ‘발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.’고 규정하고 있다. 그런데 ‘기술’ 자체가 아닌 ‘기술적 사상’이란 결국 인간의 사유를 전제로 하는 것이고, ‘창작’ 역시 인간의 정신적 활동을 전제로 하는 것이다. 또한 발명행위는 이른바 사실행위로써, 발명행위를 하게 되면 특허법상 발명자지위가 부여되고 특허권이 발명자에게 원시적으로 귀속되므로(특허법 제33조 제1항, 소위 ‘발명자주의’), 발명자의 지위는 원칙적으로 권리능력이 전제가 되어야 한다. 그런데 민법에서는 ‘사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.’고 규정하여 원칙적으로 자연인에게만 권리능력이 부여된다는 점을 명시하고 있고(제3조), 다만 제한된 범위 내에서 법인에게도 권리능력을 부여하고 있는데(제34조), 인공지능은 법령상 자연인과 법인 모두에 포섭되지 않으므로[민법상 ‘본법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다.’고 하여 사람과 법인을 제외한 나머지를 포괄적으로 물건으로 보고 있는바(제98조), 소프트웨어와 하드웨어가 결합하는 형태의 인공지능 역시 민법상 유체물로서 물건에 해당할 여지가 높아 보인다], 현행 법령상으로 인공지능에게 권리능력을 인정할 수도 없다(원고는 인공지능이 출원서에 ‘발명자’로 기재되는 것이 권리능력 등과 별개로 허용될 수 있다는 취지로 주장하나, 이는 앞서 본 바와 같은 특허법상 발명자의 개념과 상치되는 것이고, 통일적 법해석에 전혀 부합하지 않는 주장이어서 받아들이기 어렵다).
- 나아가 원고는 인공지능을 발명자로 표시할 수 있도록 허용하는 것이 발명을 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적·취지에 더 부합한다고도 주장한다. 그러나 인공지능이 발명자로 표시될 수 있다 하더라도 그로 인하여 인공지능이나 인공지능의 개발자가 더 적극적으로 발명을 할 유인이 발생한다고 볼만한 합리적 근거는 부족한 반면, 인공지능을 발명자로 인정할 경우 향후 인간 지성의 위축을 초래하여 미래 인간의 혁신에 부정적인 영향을 미칠 우려, 연구 집약적인 산업 자체가 붕괴될 우려, 발명이나 그 결과물과 관련된 법적 분쟁이 발생할 경우 인공지능의 개발자인 인간이 책임을 회피함으로써 책임 소재가 불분명해질 우려 등이 엄존하고, 소수 거대 기업 등이 강력한 인공지능을 독점함으로써 특허법이 소수의 권익만을 보호하는 수단으로 전락할 위험성도 있는바, 인공지능을 발명자로 인정하는 것이 우리 사회의 기술 및 산업발전의 도모에 궁극적으로 기여할 것이라고 단정하기도 어렵다.
- 원고는 인공지능을 발명자로 표시할 수 없을 경우, 인공지능이 인간의 개입 없이 독자적으로 한 발명에 관하여 어느 누구도 적법하게 특허를 출원할 수 없는 문제가 발생할 수 있고, 이는 특허법의 목적이나 취지에도 반한다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 현 단계의 인공지능이 인간의 어떠한 개입 없이도 독자적으로 발명할 정도의 기술적 수준에 이르렀다고는 보이지 않을 뿐 아니라, 현행 법령상 인공지능을 활용하여 발명에 기여한 인간을 발명자로 표시하여 특허를 출원하는 것까지 금지된다고 보이지도 않고, 이를 영업비밀 등으로 보호하는 다른 수단도 존재하므로, 원고의 주장과 같은 문제는 현실적으로 발생할 것으로 보이지 않는다. 물론 미래에 강한 인공지능이 출현할 경우에 원고의 주장과 같은 문제가 현실화할 가능성까지 완전히 배제할 수는 없으나, 이는 기술적·정책적 판단을 거쳐 향후 제도 개선 등을 통해 해결할 과제로 보일 뿐이다.

[2] 추가판단

가. 원고는, 특허법상 발명자는 자연인으로 한정된다는 해석은 근거가 없고, 특허법 입법 당시 인공지능 발명자에 대한 고려가 없었을 것이라는 점에 비추어 입법적 공백은 규정의 합리적인 해석을 통하여 해결해야 한다고 주장한다. 특허법 제33조 및 제42조의 해석에 비추어 특허법상 발명자가 자연인을 의미하는 것이 분명한 것은 제1심판결에서 본 바와 같다. 인공지능의 출현 및 발전 정도, 현재까지의 기술 수준, 인공지능에 대한 사회의 인식 등에 비추어 현재의 특허법 규정만으로 인공지능을 발명자에 포함시키는 것은 정당한 법률해석의 한계를 벗어난다. 향후 인공지능의 발명으로 보호받아야 할 대상이 존재한다면 이는 사회적 논의를 거쳐 입법을 통해 보완해 나가야 할 것이다.

나. 원고는 인공지능이 권리능력을 갖지 못하더라도 특허법상 발명자로 인정될 수 있다고 하면서 인공지능이 생성한 결과물에 대한 권리 및 의무는 인공지능의 소유자 또는 관리운영자에게 귀속시키는 것이 가능하다고 주장한다. 특허법 제33조 제1항에서 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.’고 규정하여 발명자주의를 채택하고 있어 원고의 주장은 그 자체로 특허법에 맞지 않을 뿐 아니라, 관련 권리와 의무는 인공지능의 소유자 등에게 귀속시키는 것 또한 아무런 근거가 없고 현행 특허법의 체계와도 전혀 부합하지 않는다.



① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.

- 이전 : 양도 + 상속

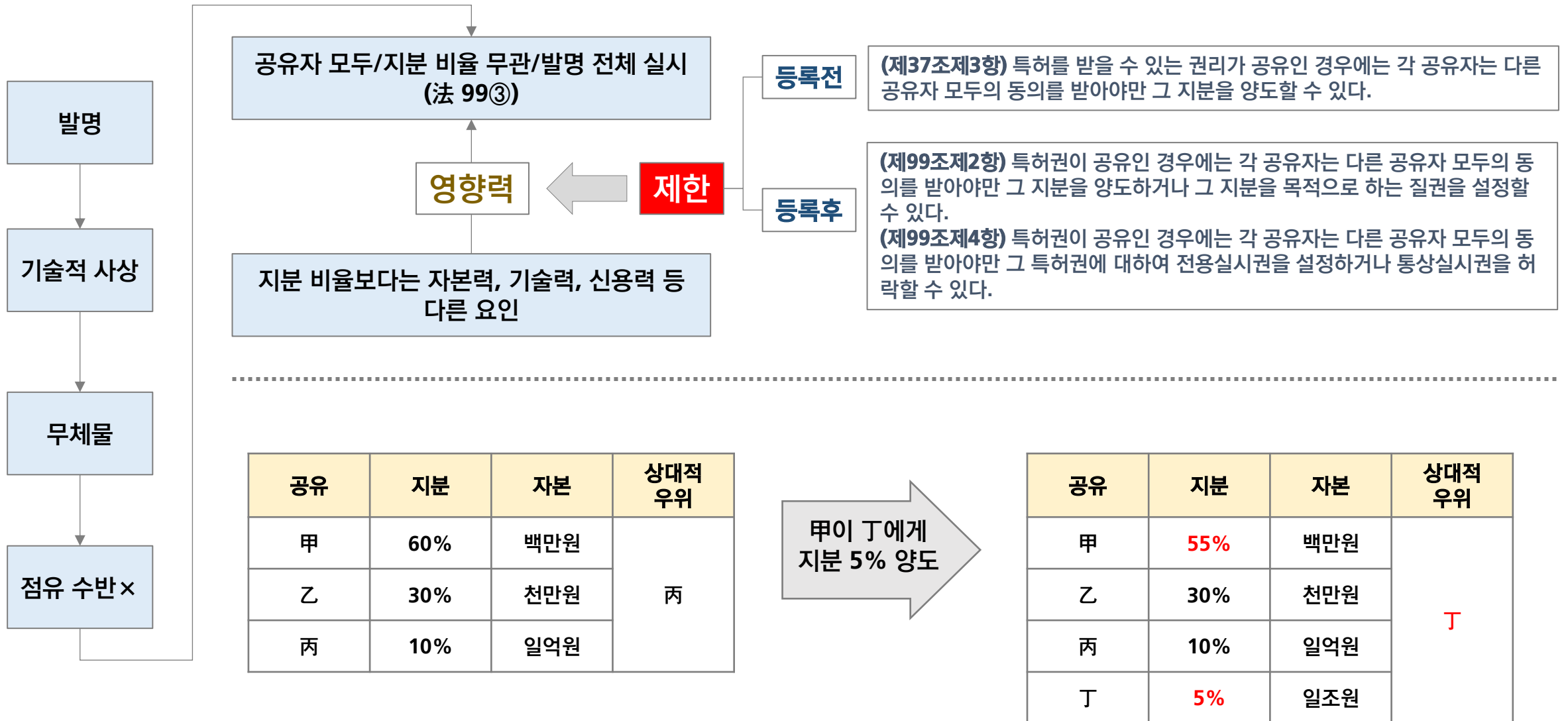
② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.

- 불안정한 상태

③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

- 새로이 공유자로 될 자의 자본력, 기술력, 신용력 여하에 따라 기존 공유자의 이해관계에 영향을 미치기 때문에 제한을 두고 있음(민법과 차이점)
- 다만, 지분의 상속은 다른 공유자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없기 때문에 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 할 수 있으며 공유자끼리의 지분양도는 공유자 사이의 지분 비율의 변동에 불과하기 때문에 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 가능하다.





등록 전 출원인과 등록 후 특허권자는 발명자의 추가, 정정을 할 수 있다. 등록 전 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자의 기재를 일부 누락하거나 잘못 적은 경우에는 발명자를 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 특허출원인은 법 제66조에 따른 특허결정이 있는 때부터 법 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받기 전까지는 발명자를 추가할 수 없고 발명자의 동일성이 유지되지 않는 경우 발명자를 정정할 수 없다. 특허출원인은 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 보정서에 i) 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서, ii) 특허출원인 및 추가 또는 정정의 대상이 되는 발명자가 서명 또는 날인한 확인서류(다만, 발명자의 사망 등으로 서명 또는 날인이 불가능한 특별한 사유가 있는 경우에는 그 사유를 확인서류에 기재하고 서명 또는 날인을 생략할 수 있다.)를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다. 다만, 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락되거나 발명자를 잘못 적은 것임이 명백한 경우에는 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다(施規 28①②). 등록 후 특허권자도 발명자의 추가, 정정을 할 수 있다. 특허권자가 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 정정발급신청서에 i) 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서, ii) 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다. 다만, i) 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락된 경우, ii) 발명자를 잘못 적은 것임이 명백한 경우, iii) 특허권자가 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자인 경우에는 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다(施規 28③④).

진실한 발명자가 발명자로 표시되지 않았으면 발명자는 특허증에 발명자로 기재된 권리를 제한받았기 때문에 특허권자에게 발명자 인격권의 침해에 대한 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 특허증에 발명자로 표시되는 것은 직무발명의 보상 등과 같은 개인적인 만족을 넘어서 입시, 인사 등에서 사회적으로 유의미한 이익을 누리도록 하는 기능이 있고, 수수료를 감면받거나 확대된 선출원을 회피할 목적으로 악용될 소지가 있으므로 제한하고 있다. 또한 감면 대상자를 발명자에 포함하여 부당하게 수수료를 감면받은 경우 감면받은 특허료 및 수수료의 2배를 추징하고 일정 기간 감면을 제한(法 83④)함으로써 제도의 악용을 방지하고 공정성을 제고하고 있다. 다만 인격권을 침해하였다고 하여 등록된 특허가 제한열거적인 무효사유(法 133①각호)에 해당하지 않는다.

* 확대된 선출원 위반 회피 악용 방지?

- 표시상 완전히 일치하지 않더라도 실질적으로 동일한 발명자로 판단되면 발명자가 동일한 것으로 인정된다(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525). 다만, 발명자가 동일하다는 것은 출원인이 증명하여야 한다. 한편, 출원인이 제 29조제3항 및 제4항에 위반된 것을 염려하여 발명자의 추가나 정정신청을 한 경우 심사관은 진정한 발명자인지 여부를 증명할 수 있는 서류를 출원인에게 요구할 수 있다.

* 甲으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 乙이 발명자, 출원인을 乙로 기재하여 특허출원한 경우?

- 등록 전 심사과정에서 발명자 기재에 대한 방식 흠결을 이유로 보정명령 후, 진정한 발명자임을 증명하지 못하거나 발명자 정정을 하지 않은 경우 출원을 무효로 할 수 있으나, 제한열거적인 거절이유에 해당하지 않음
- 등록 후에는 제한열거적인 무효사유(法 133①각호)에 해당하지 않음(대법원 2018. 7. 20. 선고 2015후1669)
- 발명자 인격권 침해에 대한 손해배상청구가능(서울행정법원 2011. 11. 4 선고 2011구합21942)
- 부당 수수료 감면자에 대하여 감면받은 특허료 및 수수료의 2배를 추징하고 일정기간 감면을 제한(法 83④)

***발명자만을 허위 기재한 경우**

甲으로부터 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 乙이 발명자, 출원인을 乙로 기재하여 특허출원

- 진정한 발명자인지 여부는 실질에 의하여 판단
- 등록 전 심사과정에서 발명자 기재에 대한 방식 위반으로 절차보정사유(法 46)이므로 보정명령 후, 진정한 발명자임을 증명하지 못하거나 발명자 정정을 하지 않은 경우 출원을 무효(法 16)로 할 수 있으나, 제한열거적인 거절이유(法 62)에 해당하지 않음
- 착오로 등록된 경우에는 제한열거적인 특허무효사유(法 133①)에 해당하지 않으므로 하자 치유 간주
- 발명자 인격권 침해에 대한 손해배상청구를 할 수 있고, 발명자를 잘못 적은 것임이 명백한 경우나 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부한 경우에 해당하기 때문에 발명자 정정 가능
- 수수료 면탈 목적인 경우 감면받은 특허료 및 수수료의 2배를 추징하고 일정기간 감면을 제한(法 83④)

***발명자, 출원인 모두를 허위 기재한 경우**

甲으로부터 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받지 못한(甲의 발명을 모인한) 乙이 발명자, 출원인을 乙로 기재하여 특허출원

- 진정한 발명자인지 여부는 실질에 의하여 판단
- 발명자 허위 기재는 방식 위반으로 절차보정사유(法 46)이고, 출원인 흠결은 제33조제1항본문 위반으로 제한열거적인 거절이유(法 62), 특허무효사유(法 133①)에 해당하나, 제34조, 제35조, 제99조의2에 의한 정당한 권리자 보호를 위해 제33조제1항본문 위반으로 처리가 적절함

제38조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계) ① 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.

② 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.

③ 동일한 자로부터 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있으면 특허출원인 및 실용신안등록출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.

④ 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.

⑤ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.

⑥ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다.

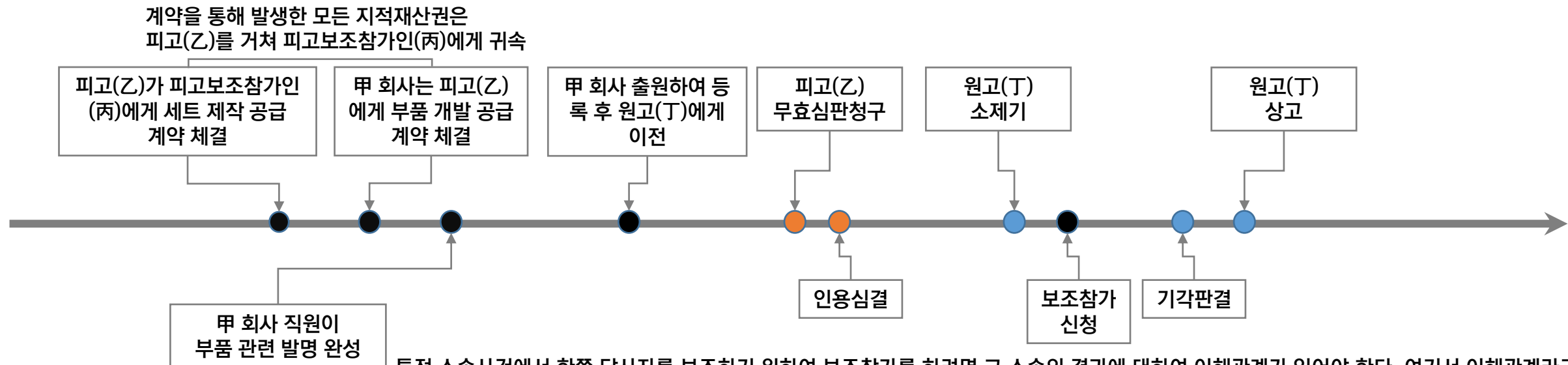
⑦ 제2항·제3항 또는 제6항의 경우에는 제36조제6항을 준용한다.

이전시기 \ 이전형식	일반승계	특정승계
출원 전	1. 사유발생시 효력발생 2. 승계인이 특허출원 → 제3자 대항요건(法 38①) 3. 동일자 출원 ① 협의제, 협의명령(法 38②③⑦) → 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력발생 ② 협의가 성립되지 아니하면 승계의 효력 불발생 → 무권리자 출원으로 간주	
출원 후	1. 사유발생시 효력 발생(·권리의 단절 막기 위해) 2. 승계인이 지식재산처장에 신고 要(法 38⑤)	1. 승계인의 출원인변경신고 → 효력발생요건 2. 동일자 출원인변경신고 ① 협의제, 협의명령(法 38⑥⑦) → 협의하여 정한 자에게만 출원인변경신고 효력발생 ② 협의가 성립되지 아니하면 출원인변경신고의 효력 불발생 → 피승계인이 출원인인 상태로 출원절차 진행

대법원 2020. 5. 14 선고 2020후10087 판결 [등록무효(특)]

[1] 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.

[2] 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.



현재는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 丙만이 무효심판 청구 가능

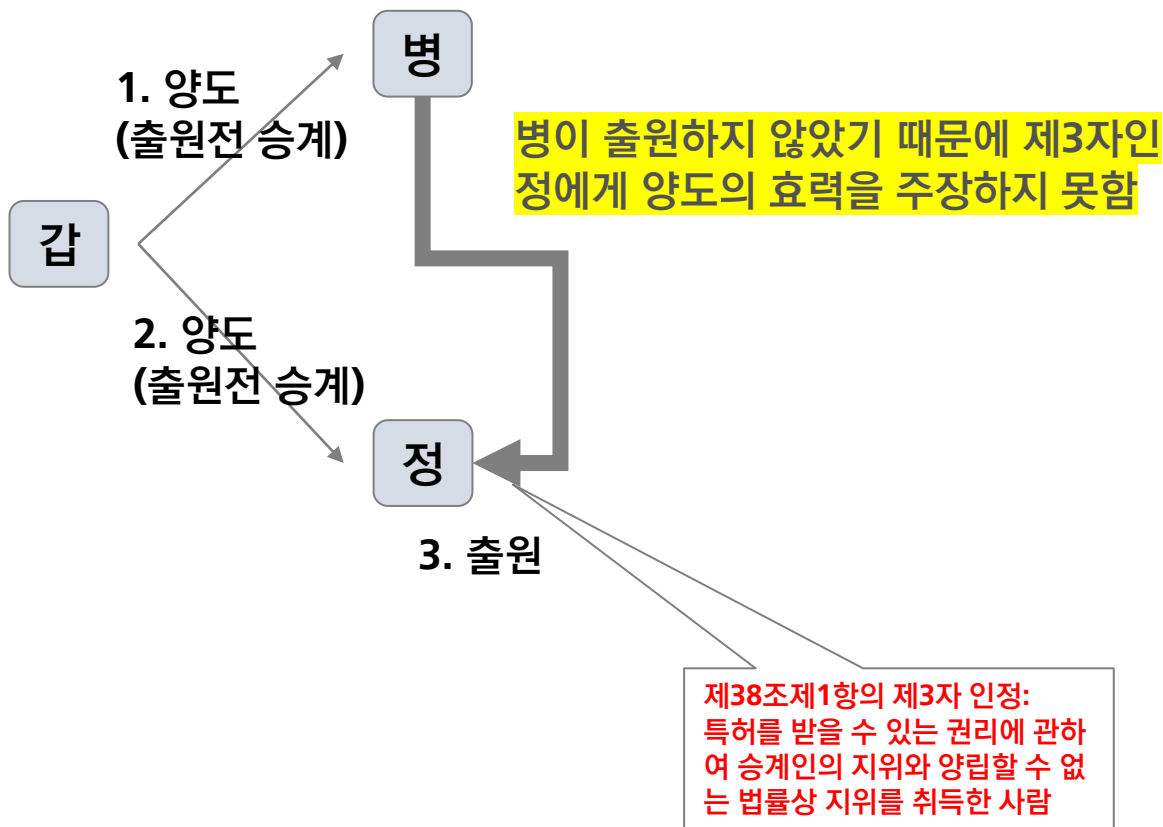
특정 소송사건에서 한쪽 당사자를 보조하기 위하여 보조참가를 하려면 그 소송의 결과에 대하여 이해관계가 있어야 한다. 여기서 이해관계라고 함은 사실상·경제상 또는 감정상의 이해관계가 아니라 법률상의 이해관계를 말하는 것으로, 그 소송의 판결의 기판력이나 집행력을 당연히 받는 경우 또는 적어도 그 판결을 전제로 하여 보조참가를 하려는 자의 법률상의 지위가 결정되는 관계에 있는 경우를 의미한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결, 대법원 2007. 4. 26. 선고 2005다19156 판결 등 참조).

살피건대, 뒤에서 보는 바와 같이 피고보조참가인은 이 사건 특허발명에 관한 특허를 출원할 권리를 적법하게 승계한 자로서 이 사건 소송에서 이 사건 특허발명이 무권리자에 의한 출원으로 인정되어 그 특허가 무효가 될 경우 자신 명의로 이 사건 특허발명을 출원하여 특허를 등록받을 수 있는 지위에 있다고 인정되므로, 이 사건 소송의 결과에 대하여 법률상 이해관계가 있다고 할 것이다.

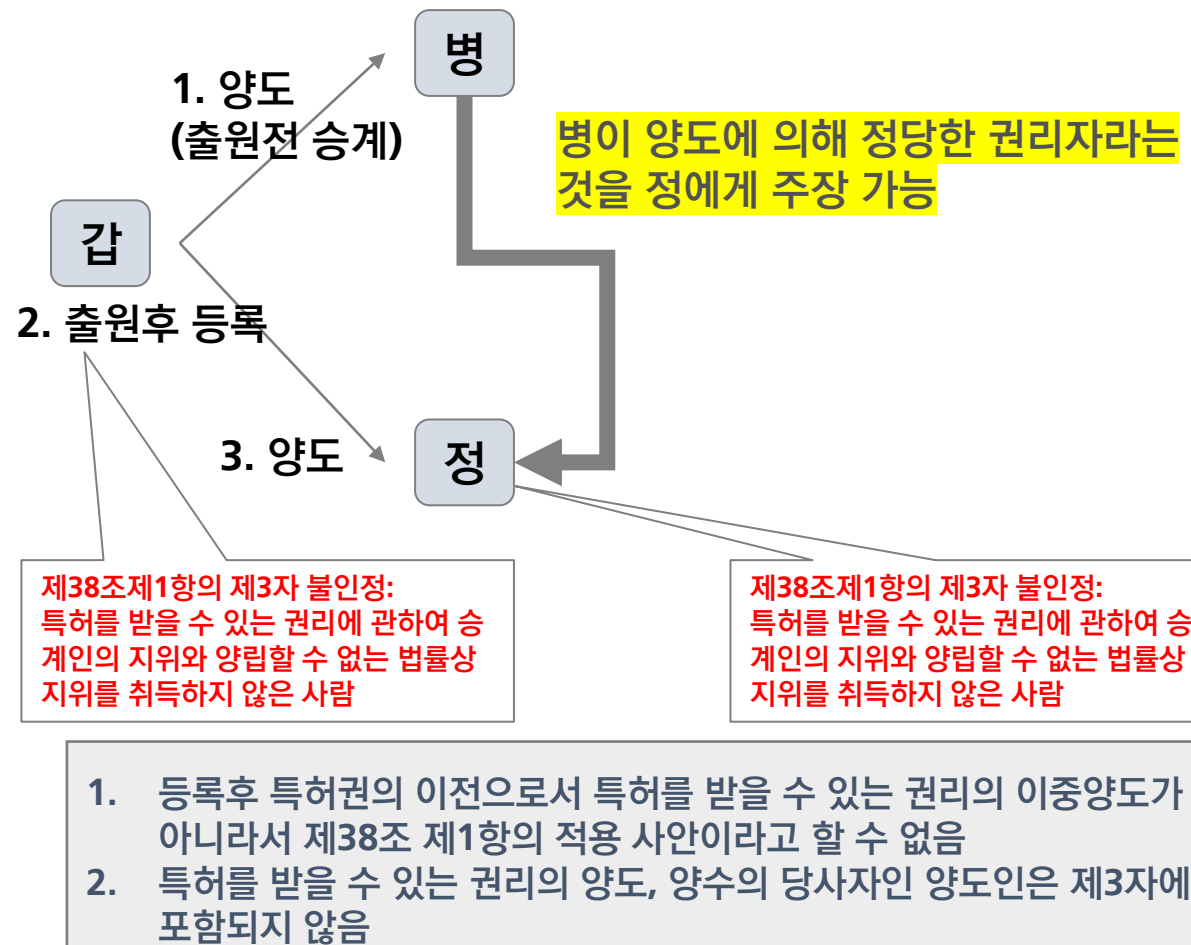
특허법 제38조 제1항 적용 CASE

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 **대항**할 수 있다.

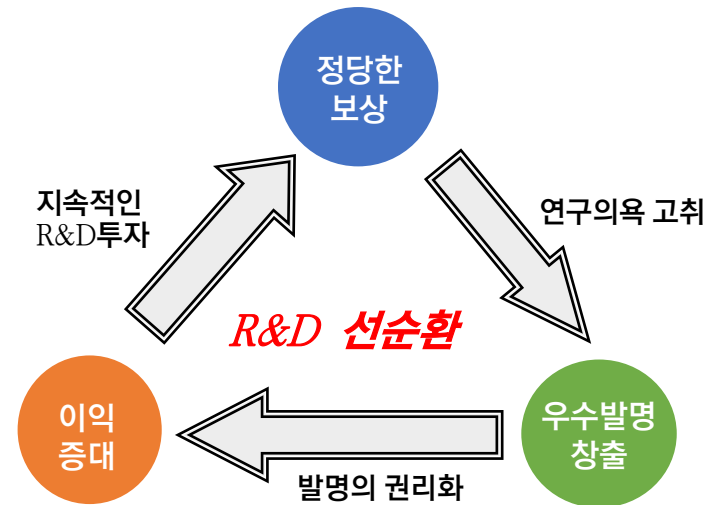
특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람 사이에서 우열을 결정하는 의미



대법원 2020. 5. 14 선고 2020후10087 판결 [등록무효(특)]



연구개발투자와 시설 등을 제공한 사용자와 창조적인 노력으로 발명을 완성한 종업원의 합리적인 이익 조정으로 상호 Win-Win할 수 있는 구도가 직무발명제도의 기본 전제이자 작동원리



기술이 고도로 복잡화 및 다양화됨에 따라 기존의 기술 (prior art)을 뛰어 넘는 새로운 기술의 개발은 대규모 연구시설과 인력 및 막대한 연구비의 지원없이 사실상 불가능하게 됨. 그 결과 기업체, 연구소 및 대학 등에 의한 직무발명의 비중이 갈수록 높아지고 있음

구분 \ 연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
개인발명(건)	41,972	40,878	41,671	42,487	44,552	44,696	42,043	36,049
직무발명(건)	171,722	167,952	163,104	167,505	174,423	182,063	195,955	201,584
합계(건)	213,694	208,830	204,775	209,992	218,975	226,759	237,998	237,633
직무발명 비중(%)	80.36%	80.43%	79.65%	79.77%	79.65%	80.29%	82.33%	84.83%

* 특허출원건수를 기준으로 하였으며, 개인발명(건)은 개인출원, 직무발명(건)은 법인출원 건수를 의미함

직무발명제도 도입 기업에게는 직무발명보상금 지출비용에 대하여 세액공제 혜택이 주어지고, 정부지원사업 대상자 선정 시에 인센티브가 부여됨

항목	내용
권리확보	- 직무발명에 대한 합리적이고 안정적인 권리를 확보
세액공제	- 사용자: 직무발명 보상금으로 지출한 금액에 대해서 연구개발비용으로 소득세 또는 법인세에서 세액공제 (조세특례제한법 제9조, 제10조, 동법 시행령 제8조) - 발명자: 사용자로부터 받는 보상금에 대하여 500만원까지 비과세 혜택 (소득세법 제12조 제5호 라목)
지식재산처*	- 민간 IP-R&D 연계전략 지원사업 - 특허기술의 전략적 사업화 지원사업 - 지역지식재산 창출 지원사업 - 특허, 실용신안, 디자인 우선심사대상 - 특허, 실용신안, 디자인 4~6년차 등록료 20% 추가감면(2026년 2월말까지)**
중소벤처기업부*	- 중소기업 기술혁신 개발사업 - 융·복합기술 개발사업 - 상용화기술 개발사업 - 창업성장기술 개발사업 - 제품·공정개선 기술개발
과학기술정부통신부*	- SW 공학기술 현장적용 지원사업 - 모바일 융합 제품화 기술개발 및 R&D역량강화사업 - IT중소기업 공통 애로 해소지원사업

* 직무발명 보상 우수기업으로 인증된 경우에 한함

** 청구항 10항의 등록특허 1건의 4~6년차 등록료 감면금액 370,500원(등록특허 100건은 37,050,000원 절감)

종업원 발명

(제655조) 고용은 당사자 일방이 상대방에 대하여 노무를 제공할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

민법의 고용관계

특허법

(제33조제1항본문) 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.

사용자에게 귀속 vs 종업원에게 귀속

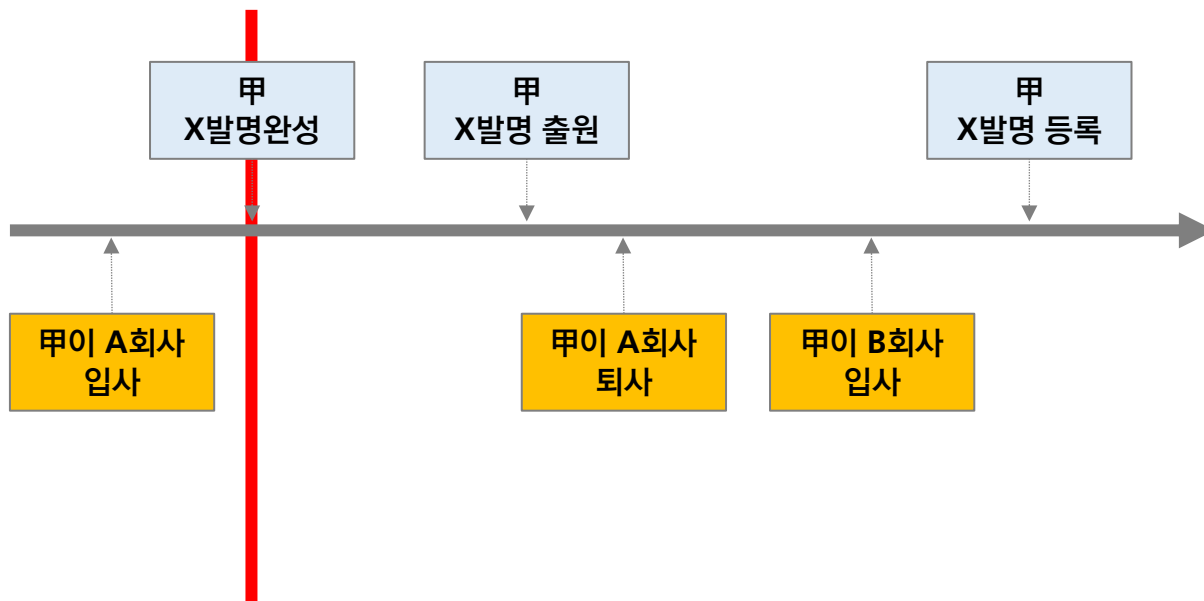
발명진흥법에서 양자간의 관계를 조절

구 분	종업원 등의 권리 및 의무	사용자 등의 권리 및 의무
직무발명	▪ 특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 취득 ▪ 발명완성사실통지의무 ▪ 비밀유지의무	▪ 법정실시권 (단, 대기업의 경우 예약승계 계약의 체결 또는 근무규정의 작성에 있는 경우에 한함) ▪ 예약승계 - 예약승계계약이나 근무규정에 근거한 승계취득 - 승계한 경우 정당한 보상 의무
자유발명	▪ 특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 취득	▪ 승계한 경우 정당한 보상 의무

대법원 1997. 6. 27. 선고 97도516 판결 【실용신안법위반】

구특허법 제17조 제1항이나 특허법 제39조 제1항에 의하면, 직무발명에 관한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 그 피용자나 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.

→ 이는 발명완성 당시에 고용관계에 있는 사용자 등을 기준으로 직무발명인지 여부를 판단하기 때문이다.



발명 완성 당시

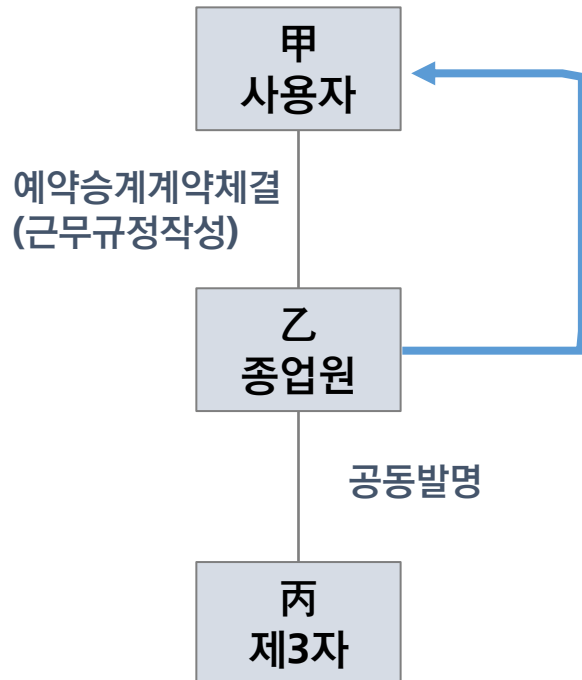
X발명에 대하여 통상실시권을 취득하는 사용자는?
= X발명은 A/B 회사 中 어느 회사의 직무발명인가?

- 종업원 등이 발명하였을 것
- 사용자 등의 업무범위에 속할 것
- 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

① 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 ② 미리 ③ 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 ④ 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다(發振法 10③).

구분		2 발명 완성 전(예약승계)	발명 완성 후
직무 발명	특허를 받을 수 있는 권리 승계계약	가능	가능
	특허권 승계계약	가능	
	전용실시권 설정계약	가능	
	통상실시권 허락계약	종업원 등 또는 승계인이 특허를 받은 경우 법정실시권 발생하기 때문에 불필요 (단, 대기업의 경우 예약승계계약의 체결 또는 근무규정의 작성이 된 경우에 한함)	
1 자유 발명	3 특허를 받을 수 있는 권리 승계계약	4 불가능	가능
	특허권 승계계약	불가능	
	전용실시권 설정계약	불가능	
	통상실시권 허락계약	가능	

종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다(發振法 14). 이 경우 지분의 이전에 대하여 특허법 제37조제3항에 의하여 제3자인 다른 공유자의 동의를 받아야 하는지와 관련하여, 대법원(2012도6676)은 이미 공동개발을 할 때 다른 공유자의 묵시적 동의가 있는 것으로 간주하여 별도의 동의절차를 밟을 필요가 없는 것으로 해석하고 있다.



乙의 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 지분을 甲이 丙의 동의없이 취득할 수 있는가?

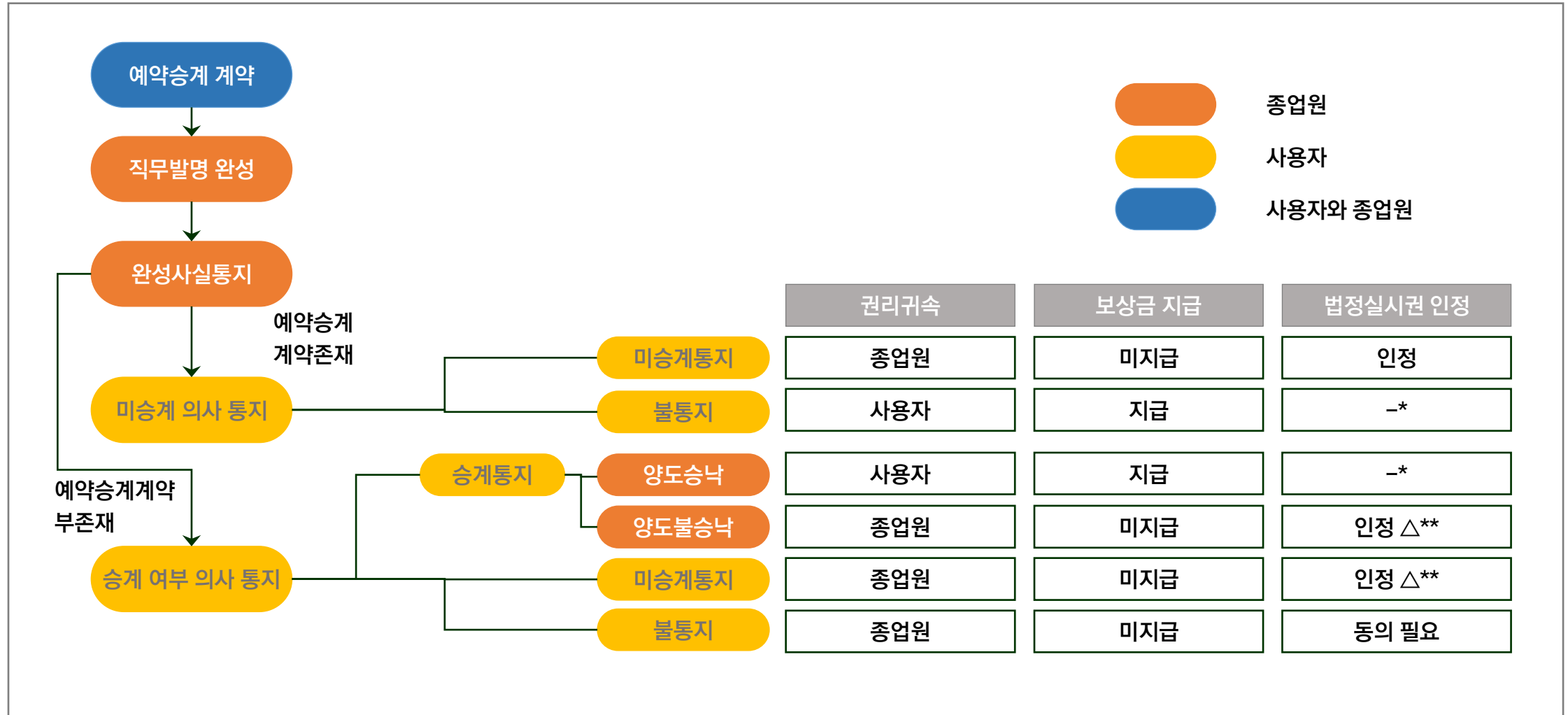
특허법 제37조제3항

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

발명진흥법 제14조

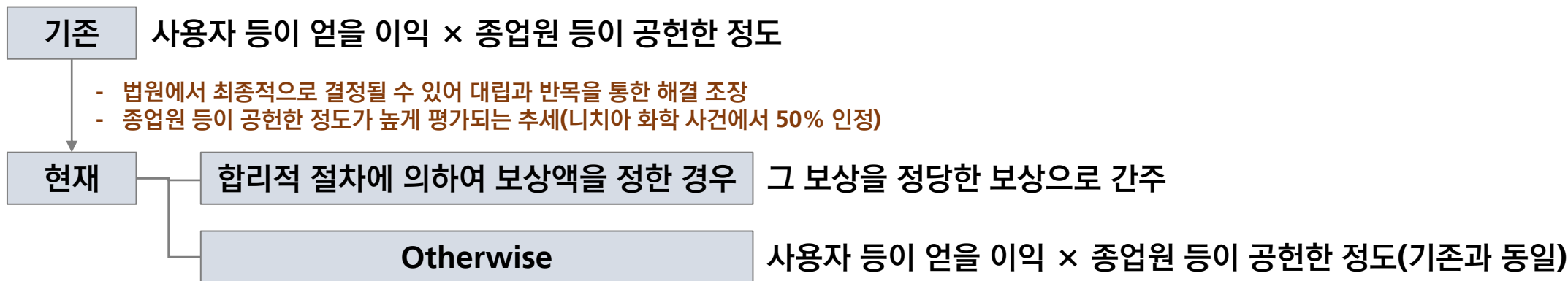
종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

대법원(2012도6676) : 별도의 추가적인 동의절차 不要



* 법정실시권은 혼동에 의해 소멸

** 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업은 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 예약승계에 관한 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 않았다면 통상실시권 불인정

보상규정의
작성 및 변경

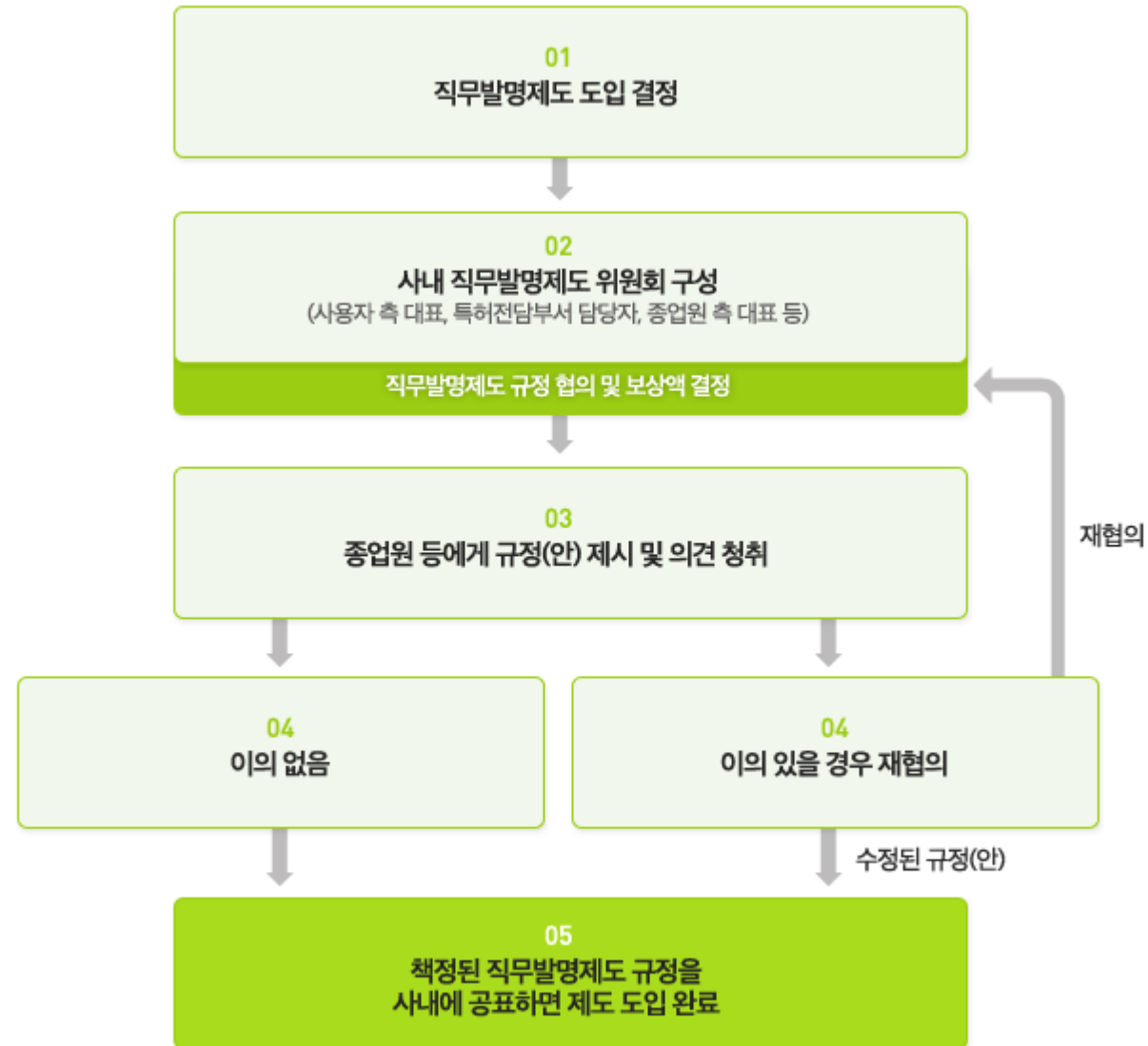
- 사용자 등은 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다(發振法 15②).
- 사용자 등 등은 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원 등과 협의하여야 한다(發振法 15③).
- 다만, 보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다(發振法 15③).

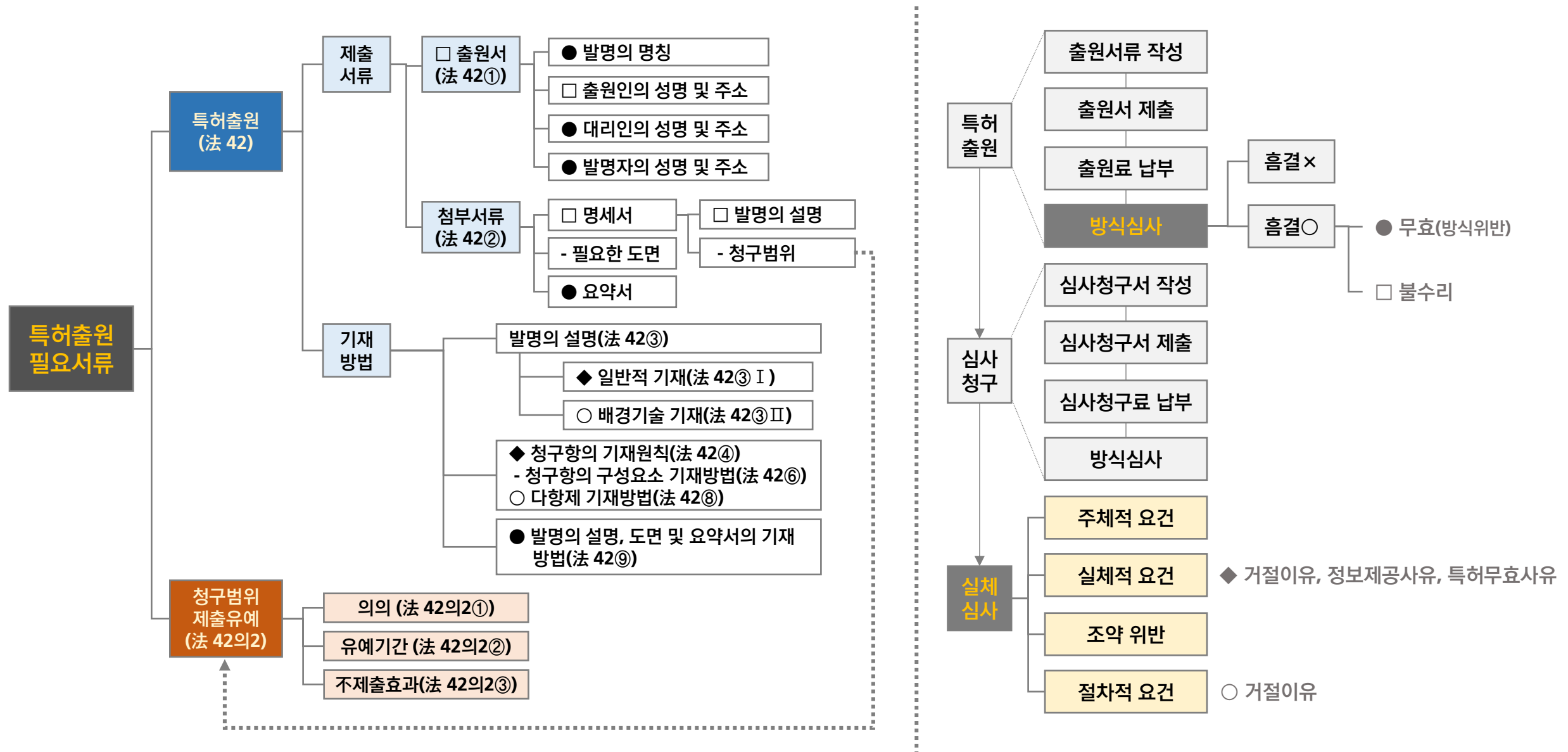
보상사항의
통지

- 사용자 등은 보상을 받을 종업원 등에게 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 서면으로 알려야 한다(發振法 15④).

보상의 효력

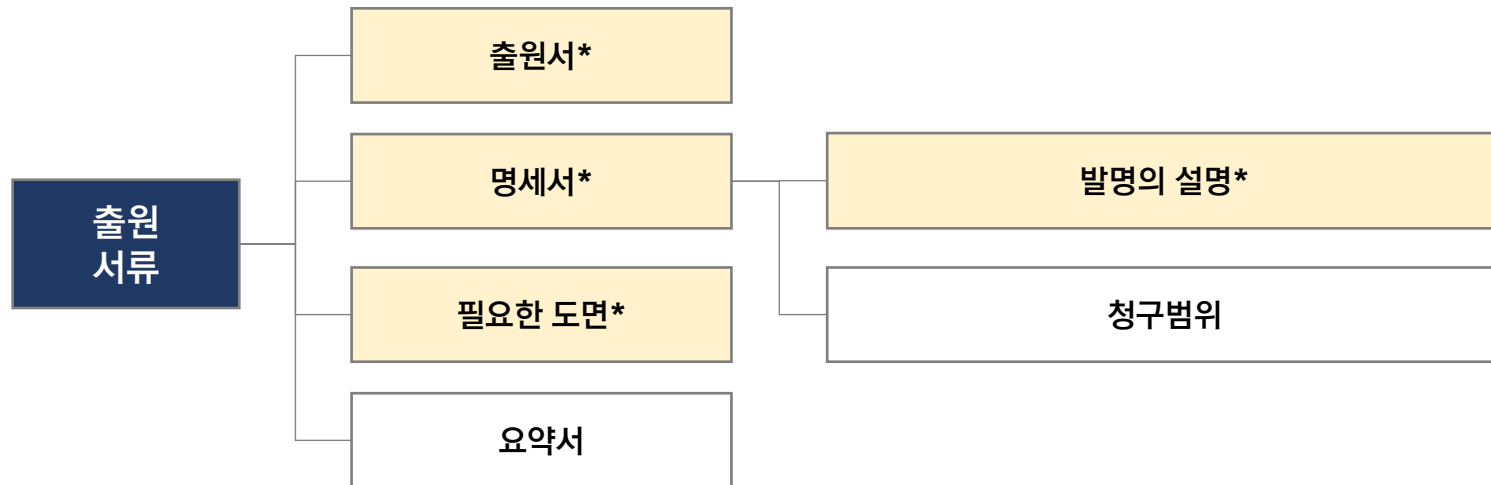
- 사용자 등이 발명진흥법 제15조 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다.
- 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 「사용자 등이 얻을 이익」 과 「그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도」 를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(發振法 15⑥).





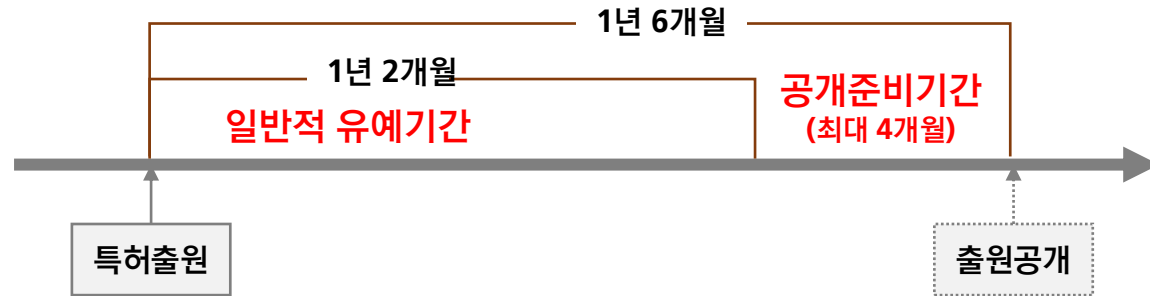
제출서류		역할	기재방법		위반 취급
제42조 제1항	출원서	출원과 관련된 각종 취지를 적은 서면	제42조제1항각호 + @		무효, 불수리
	발명의 설명	발명의 공개	실시가능요건 (제42조제3항)	일반적 (제42조제3항제1호)	거절이유(실체적 요건 위반)
				배경기술 (제42조제3항제2호)	거절이유(절차적 요건 위반)
			기재방법요건 (제42조제9항)		무효
	명세서	발명의 보호	기재원칙 (제42조제4항)	뒷받침 요건 (제42조제4항제1호)	거절이유(실체적 요건 위반)
				명확성 요건 (제42조제4항제2호)	거절이유(실체적 요건 위반)
			구성요소의 기재 (제42조제6항)		-
			다항제의 기재 (제42조제8항)		거절이유(절차적 요건 위반)
	필요한 도면	명세서의 보조수단	제42조제9항		무효
	요약서	기술정보(제43조)	제42조제9항		무효
제42조 제2항	청구범위	발명의 보호	구성요소의 기재 (제42조제6항)		-
			다항제의 기재 (제42조제8항)		거절이유(절차적 요건 위반)

- 제42조의2(특허출원일 등)** ① 특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 지식재산처장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다.
- ② 특허출원인은 제1항 후단에 따라 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다.
- ③ 특허출원인이 제2항에 따른 보정을 하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.



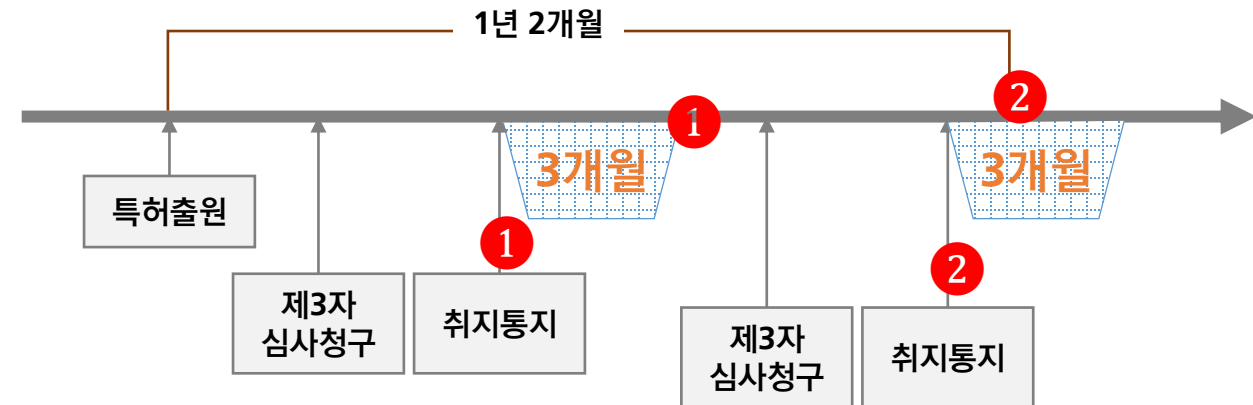
원칙적 유예기간

(제42조의2제2항본문)



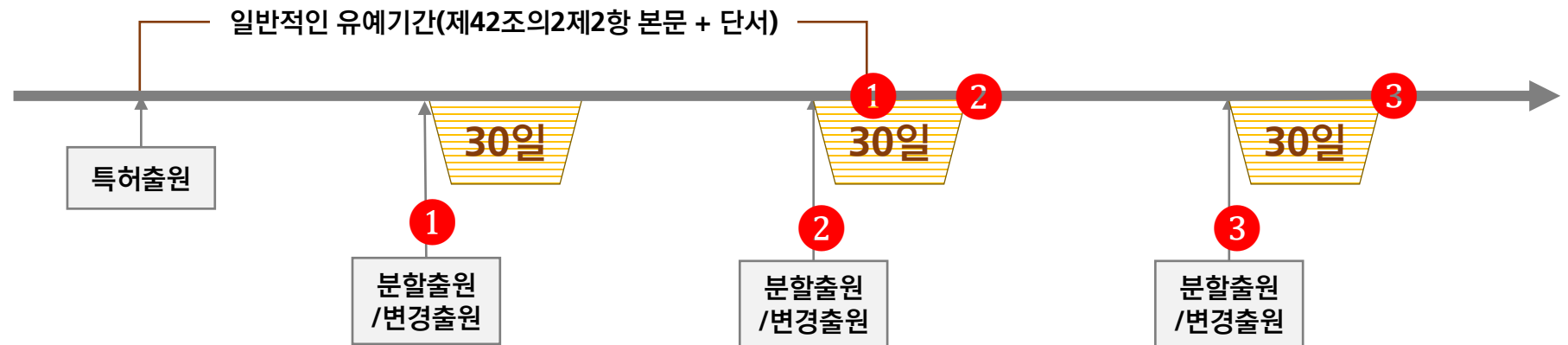
제3자의 심사청구

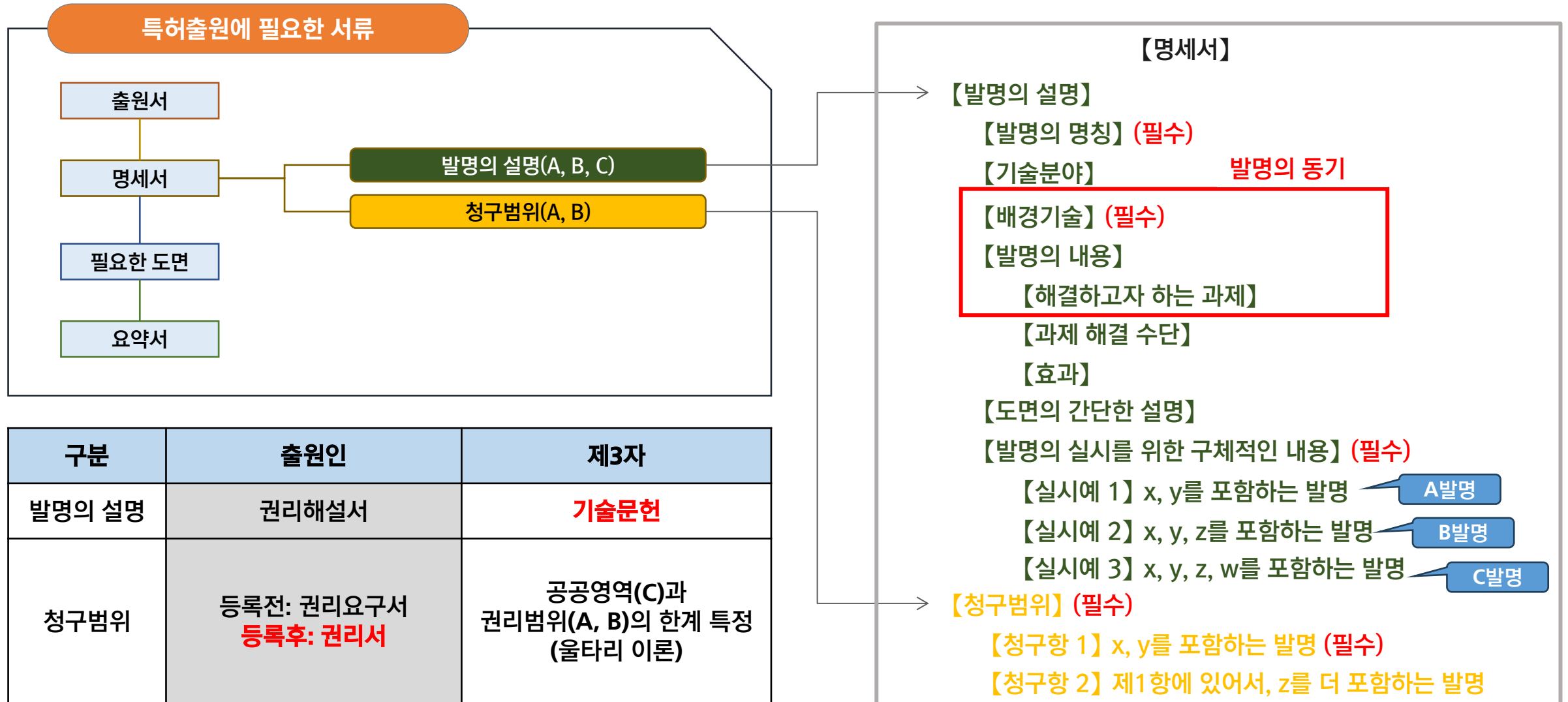
(제42조의2제2항단서)



분할출원, 변경출원

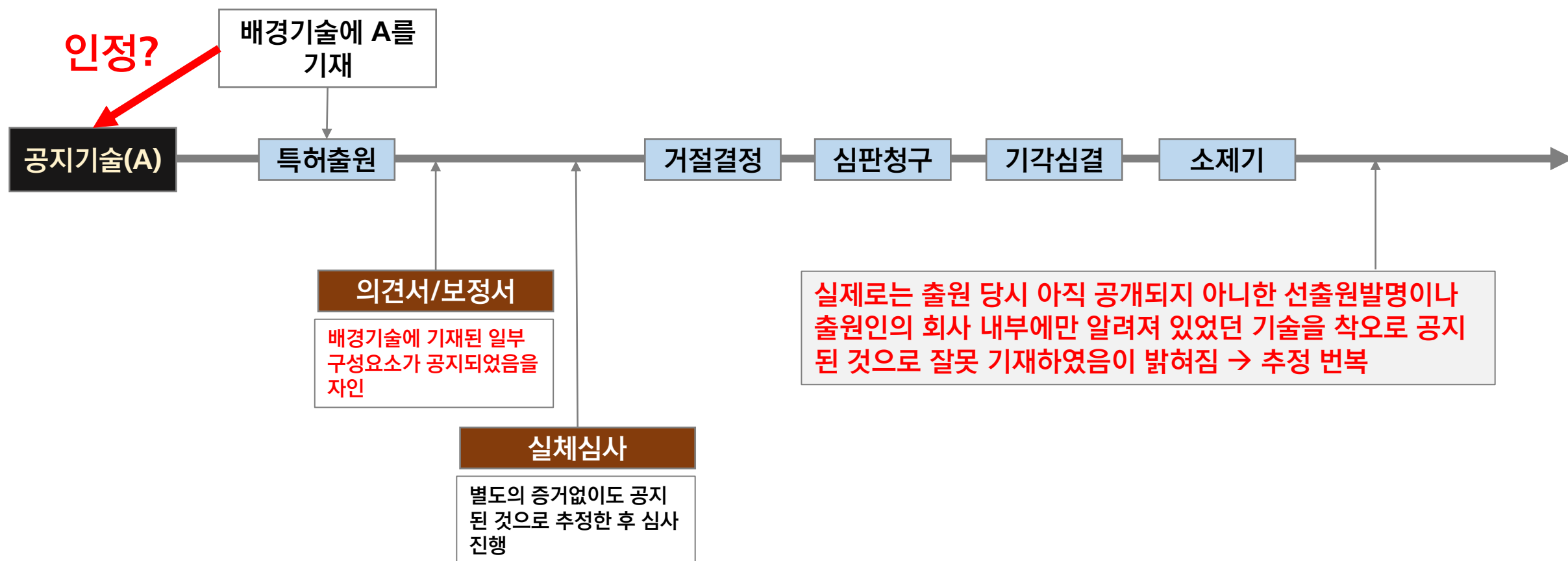
(제52조제8항, 제53조제8항)



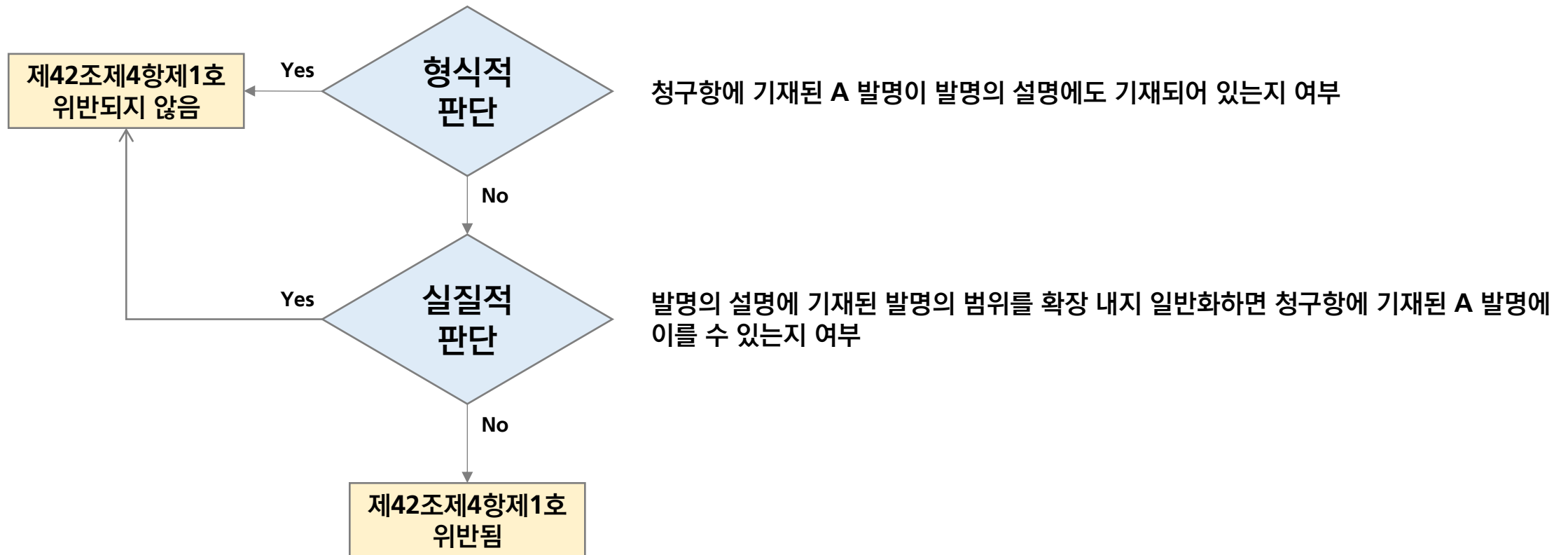


* 심사관은 청구범위의 청구항별로 거절이유를 판단하지만, 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 출원 전체를 거절결정하며, 이를 출원일체의 원칙(All or Nothing Rule)이라고 한다.

문제가 되는 것은 배경기술에 기재된 경우 이를 신규성, 진보성을 부정하는 공지기술로 볼 수 있느냐는 것이다. 기존 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결 등은 특별한 사정이 없는 한 공지기술로 보아야 한다는 입장이었으나, 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결은 이러한 종래의 판결을 변경하면서 명세서에 배경기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수 없다고 판시하였다. 이는 출원 전 공지된 것인지는 사실인정의 문제인데 배경기술이라는 항목(명세서의 기재형식)에 기재했다는 것에 근거하여 공지기술로 간주하는 태도는 객관적 진실에 반하는 결과를 낳을 수 있고, 더욱이 배경기술이란 공개 여부는 묻지 않고 출원 전 존재한 기술을 말하는 것이기 때문이다. 예를 들어, 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 배경기술에 기재할 수 있는데, 이를 공지기술이라고 단정할 수는 없는 것이다.



발명의 설명에 뒷받침되고 있는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구항에 적혀 있는 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 적혀 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.



판단대상:
발명의 설명청구범위: A
발명의 설명: A, B

해결수단

제42조제3항
제1호 위반제42조제4항
제1호 위반청구범위: A, B
발명의 설명: A판단대상:
청구범위

- 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재에 의하여 청구범위에 기재된 A 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되지 않은 경우
- B는 발명의 설명 기재에 오류가 있더라도 무관

- 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 봤을 때 발명의 설명에 기재된 A로부터 청구범위에 기재된 B까지 확장 내지 일반화 될 수 없는 경우

발명의 명칭, 기술분야, 배경기술, 발명의 내용(해결과제, 해결수단, 효과), 도면의 간단한 설명, 실시예

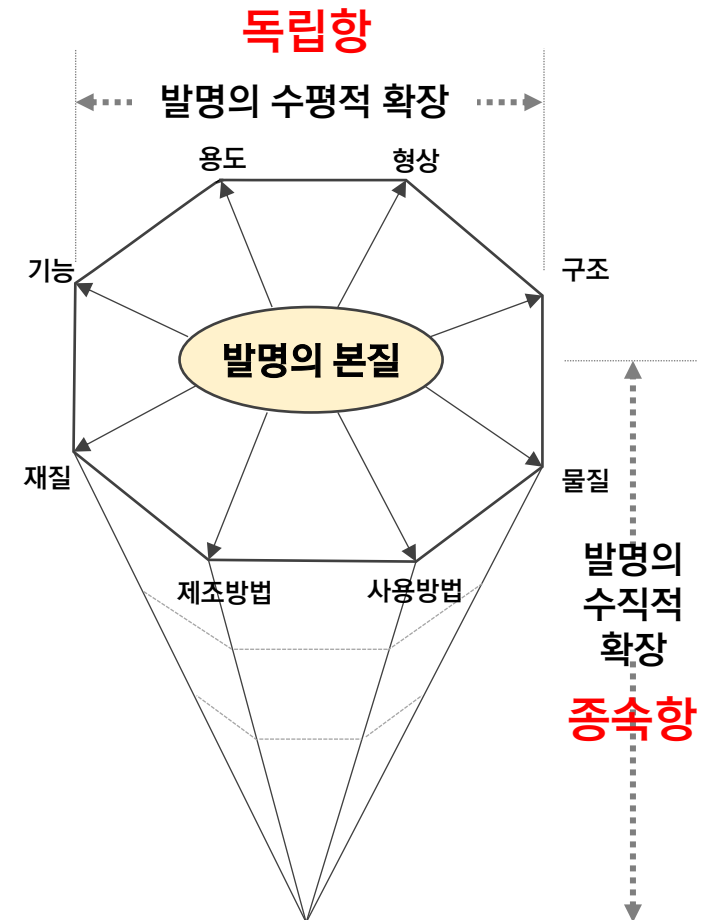
기재요건	취지	판단
제42조제3항제1호 (실시가능요건)	특허출원된 발명의 내용을 제3자가 발명의 설명만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것	통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명의 기재에 의하여 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되었는지 여부
제42조제4항제1호 (뒷받침요건)	발명의 설명에 적지 아니함에 따라 공개하지 아니한 사항을 청구범위에 청구항으로 적어 특허권이 부여되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 결과를 초래	통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 봤을 때 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 있는지 여부
제42조제4항제2호 (명확성요건)	청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 아니한 발명은 특허요건 판단 등이 불가능하며 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정할 수 없기 때문	통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단

보드마카를 발명한 경우 출원인은 다양한 방법에 의하여 보드마카의 구성요소를 특정하여 청구항에 적을 수 있다. 예를 들어, 보드마카의 **구조(structure)** A, B를 알고 있는 경우에는 「A의 일측에 B가 결합된 보드마카」와 같이 청구항을 적을 수 있다. 구조를 알고 있지 아니한 경우에는 구조가 갖는 **기능(function)**(A는 필기하는 기능, B는 지지하는 기능)을 특정하여 「필기수단의 일측에 지지수단이 결합된 보드마카」와 같이 청구항을 적을 수 있다. 또한, 구조(structure) 또는 기능(function)을 알지 못하더라도 **제조방법**을 알고 있는 경우에는 「X공정후 Y공정을 거치는 방법에 의하여 제조된 보드마카」와 같이 청구항을 적을 수 있다. 출원인은 이와 같은 기재방법 중 발명을 보호할 수 있는 가장 적절한 수단을 선택하여 청구항을 작성할 수 있다.



청구항
기재?

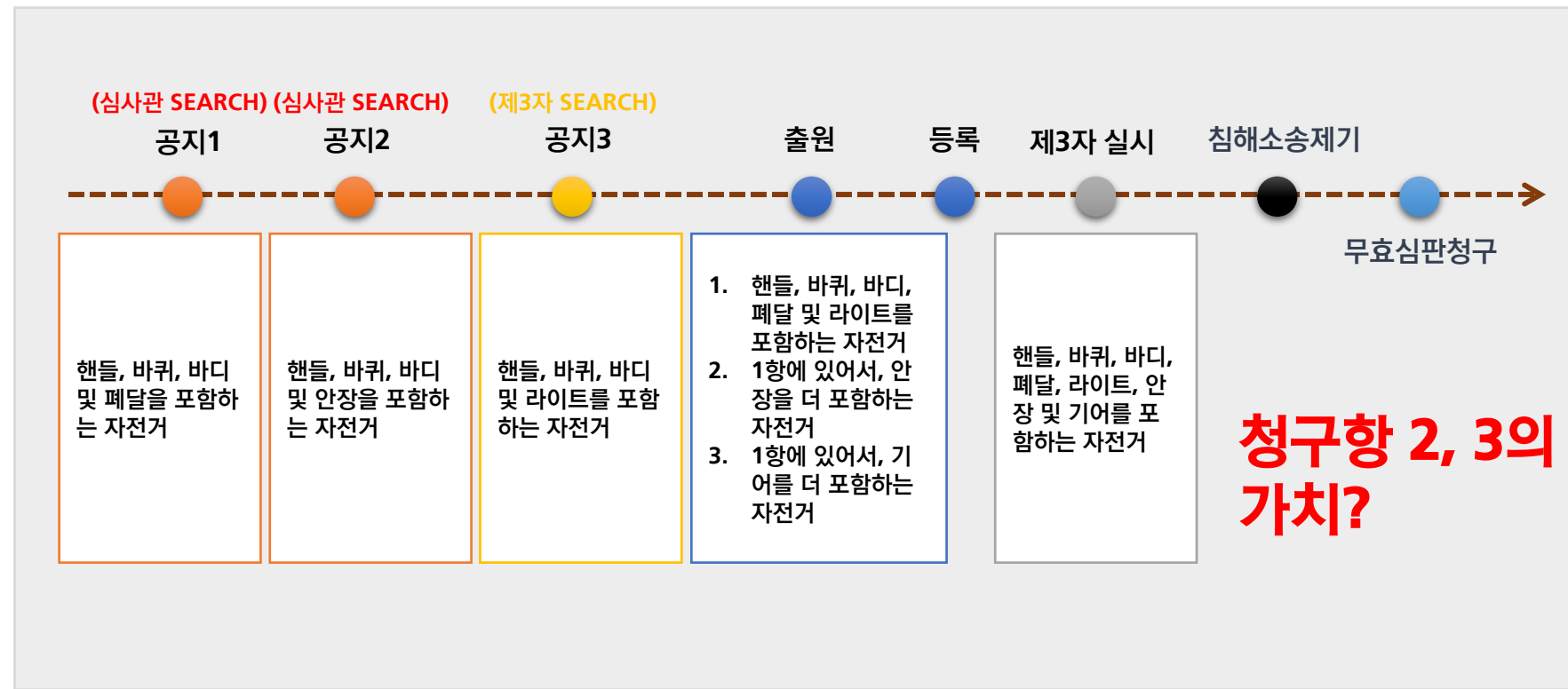
Element	Structure (구조)	Function (기능)	Method (방법)
청구항	A의 일측에 B가 결합된 보드마카	필기수단의 일측에 지지수단이 결합된 보드마카	X공정후 Y공정을 거치는 방법에 의하여 제조된 보드마카
비고	-	Means plus function Claim (기능식 청구항)	Product by Process Claim (PBP 청구항)



- ① 법 제42조제8항에 따른 청구범위의 청구항(이하 "청구항"이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 "독립항"이라 한다)을 **기재하여야 하며**, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 **구체화**하는 종속청구항(이하 "종속항"이라 한다)을 **기재할 수 있다**. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 **구체화**하는 다른 종속항을 **기재할 수 있다**.
- ② 청구항은 발명의 성질에 따라 **적정한 수**로 기재하여야 한다.
- ③ 종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는데 **필요한 수**로 기재하여야 한다.
- ④ 다른 청구항을 **인용하는 청구항**은 인용되는 **항의 번호**를 적어야 한다.
- ⑤ **2 이상의 항을 인용하는 청구항**은 인용되는 항의 번호를 **택일적**으로 기재하여야 한다.
- ⑥ **2 이상의 항을 인용한 청구항**에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. **2 이상의 항을 인용한 청구항**에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.
- ⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 **먼저 기재**하여야 한다.
- ⑧ 각 청구항은 항마다 **행을 바꾸어 기재**하고, 그 기재하는 순서에 따라 **아라비아숫자로 일련번호**를 붙여야 한다.

- 독립항은 필수, 종속항은 임의
- 독립항은 넓이를 표현하는 것으로서, 모든 실시유형 포섭될 수 있도록 넓게 기재(다기재협범위의 원칙)
- 종속항은 깊이를 표현하는 것으로서, 독자적으로 신규성, 진보성 위반을 극복할 수 있는 구성요소를 기재
- 종속항은 구체화한 청구항으로서, 한정하여 구체화와 부가하여 구체화로 구분됨
- 하나의 청구항에 카테고리나 다른 2 이상의 발명을 기재하거나 청구하는 대상이 2 이상인 경우와 같이 법 제2조제3호에 따라 하나의 실시유형으로 포섭할 수 **없는** 기재를 하는 경우 시행령 제5조제2항 적용
- 발명이 중복기재되어 있다고 할지라도 적법하다는 판결(94후1558)이 나온 후 1999.6.30. 삭제됨
- 현재 중복기재(**문언적 동일의 경우만**)된 경우 시행령 제5조제2항 위반 적용
- 인용형식이 없으면 독립항, 인용형식이 있으면, 구체화 여부에 따라 독립항/종속항 구별
- 항의 번호를 구체적으로 적지 않고, "전술한, 상술한" 등과 같이 적은 경우 위반
- 청구항은 택일적(OR) 기재를 하여야 하나, 구성요소는 택일적(병렬적)(OR) 기재, 직렬적(AND) 기재 모두 가능
- "또는(OR)"는 택일적 기재 만족하나, "및(AND)", "내지(THROUGH)"는 "중 어느 하나"와 결합된 경우 택일적 기재 만족
- ",(COMMA)"는 마지막 구분이 "또는(OR)", "및(AND)"인지 여부에 따라 성질 결정
- 다중청구항을 다중청구항으로 인용 불가
- 2 이상의 항을 인용하지 아니한 청구항은 시행령 제5조제6항 위반 아님

청구범위의 청구항은 상호 독립되어 있기 때문에 독립항, 종속항 상관없이 청구항별로 특허요건을 판단하고, 등록후에는 청구항별로 침해여부를 판단하는 것이 원칙이다. 그러나 종속항의 보호범위는 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화한 청구항이기 때문에 독립항의 보호범위보다 상대적으로 좁다. 따라서 독립항이 특허요건판단에 있어서 신규성, 진보성 위반이 아니면, 종속항도 신규성, 진보성 위반이 아니다. 등록후 침해여부판단에 있어서도 독립항의 침해가 아니면 종속항의 침해도 되지 아니한다(물론 독립항의 보호범위가 인정되지 아니하고, 종속항의 보호범위만 인정되면 독립항의 침해가 아닐지라도 종속항의 침해가 될 수도 있다). 이와 같은 논리라면 표면적으로 살펴보면 종속항의 존재 의의가 없는 것으로 보일 수도 있다. 종속항의 가장 중요한 존재 의의는 **등록 후 특허의 취소나 무효 가능성을 대비**할 수 있다는 것이다. 제3자가 실시하는 발명이 독립항과 그 종속항의 침해인 경우 독립항이 특허취소신청에 의하여 취소나 특허무효심판에 의하여 무효가 되더라도 종속항이 있다면 권리행사를 할 수 있게 된다. 종속항에 의하여 권리행사를 하기 위해서는 종속항에는 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화해서 **별개의 새로운 발명이라고 부를 수 있는 정도의 구성요소**를 적어야 한다. 즉, 심사관이 독립항의 구성요소와 결합하였을 때 신규성, 진보성 등의 특허요건 위반이 아니라고 판단할 만한 구성요소를 종속항에 적어야 한다. 그렇지 아니한 경우 **독립항의 특허요건 위반이 있으면, 종속항도 같이 특허요건 위반이 된다.** 이와 같은 종속항을 적는 것은 출원인에게 심사청구료, 특허료 등 청구항 수에 따라 달라지는 비용 부담만 가중시키는 결과를 초래한다.



출원발명	공지1	공지2	심사 (1&2)	공지3	심판 (1&2&3)
1 핸들	O	O	O	O	O
바퀴	O	O	O	O	O
바디	O	O	O	O	O
페달	O	X	O	X	O
라이트	X	X	X	O	O
2 핸들	O	O	O	O	O
바퀴	O	O	O	O	O
바디	O	O	O	O	O
페달	O	X	O	X	O
라이트	X	X	X	O	O
안장	X	O	O	X	O
3 핸들	O	O	O	O	O
바퀴	O	O	O	O	O
바디	O	O	O	O	O
페달	O	X	O	X	O
라이트	X	X	X	O	O
기어	X	X	X	X	X

청구항의 구조(Claim Structure)

[청구항 1]

젯슨 청구항
(Jepson Claim)

.... 에 있어서,

전제부

(function).... A 수단;

(function).... B 수단; 및

특징부

(function).... C, D 및 E 중 어느 한 수단;

을 포함하는 것을 특징으로 하는

연결부

X

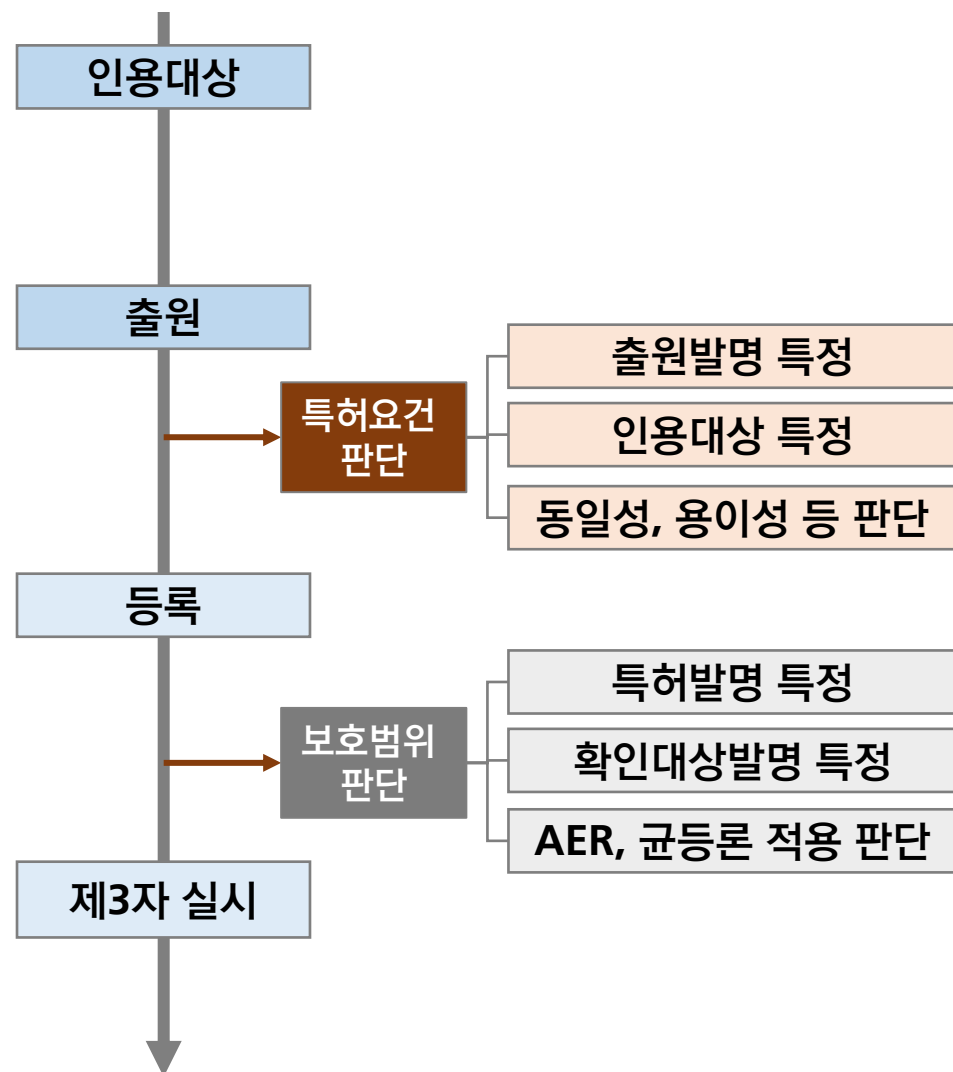
종결부

기능적 표현으로 기재된
청구항

마쿠쉬 청구항
(Markush Claim)

형식	작성내용
전제부	- 기술분야 한정 - 기술이 적용되는 대상물품(용도)의 한정 - 선행기술로 생각하여 기재
특징부 (본체부)	- 발명의 핵심적 구성요소 기재 - 보호받으려고 하는 실질적인 구성요소 기재
연결부	- 연결용어 - 을 포함하는 것을 특징으로 하는(개방형) - 로 구성된 것(이루어진 것)을 특징으로 하는(폐쇄형) - 로 필수적으로 구성된 것(이루어진 것)을 특징으로 하는(반폐쇄형)
종결부	- 발명의 카테고리 기재 - 주로 발명(고안)의 명칭과 동일한 용어 사용 - 종속항은 독립항과 일치

구분	젯슨 청구항	PBP 청구항	기능적표현 청구항
형태	에 있어서, ~를 특징으로 하는 ○○발명	X 단계 후 Y 단계를 거치는 방법에 의해 제조되는 화합물 Z	구성요소의 일부 또는 전부가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 기능적 표현으로 기재된 청구항
필요성	소위 개량발명에 있어서 선행기술을 청구항의 전문에 기재하고 선행기술에 대하여 그 발명이 특징으로 하는 개량부분을 특징부에 명확하게 지적하여 독점권이 허여될 발명의 기술영역을 명백히 하는데 공헌함	물건(product)의 구조적 특성을 규명하지 못하여 그것을 제조하는 제법(process)을 특정하지 않으면 그 물건도 한정할 수 없는 경우에 이용됨	발명의 구성요소로 통상적인 구조, 방법, 물질 등을 명확하게 구체화하는 것이 불필요하거나 그에 대한 적합한 발명 명칭이 존재하지 않은 경우에 이용됨
특허 요건 판단	전제부의 구성요소와 특징부의 구성요소의 결합에 의한 전체에 의하여 출원발명을 특정함(다만, 명세서의 전체적인 기재와 출원 경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우(공지 자인)에는 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함)	물건(제조방법의 기재가 물건의 구조나 성질에 영향을 준 경우 그 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건)으로 출원발명을 특정함 → 제조방법에 특허성이 있는지 여부와는 무관	기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명으로 출원발명을 특정함
침해 여부 판단	특허요건 판단과 마찬가지로 전제부의 구성요소와 특징부의 구성요소의 결합에 의한 전체에 의하여 특허발명을 특정함. 다만 출원인이 출원과정에서 선행기술과의 관계에서 신규성 및 진보성 결여의 거절이유를 극복하기 위하여, 구성요소 중 일부를 전제부로 돌리면서 전제부에 대해서는 권리의 보호범위로 주장하지 않겠다는 의사를 분명히 한 때에는, 등록 후에 특징부에는 해당하지 않고 전제부에만 해당하는 균등한 구성요소를 포함하는 기술의 실시 대해서는 자신의 권리를 주장하지 않겠다는 의사로 파악함	특허요건 판단과 마찬가지로 물건(제조방법의 기재가 물건의 구조나 성질에 영향을 준 경우 그 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건)으로 특허발명을 특정함. 다만, 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정해석함	청구항 그 자체만으로 특허발명의 기술적 구성의 내용을 알 수 없으므로 기능적 표현에 상응되는 발명의 설명과 도면에 기재된 실시예로 제한하여 특허발명을 특정함

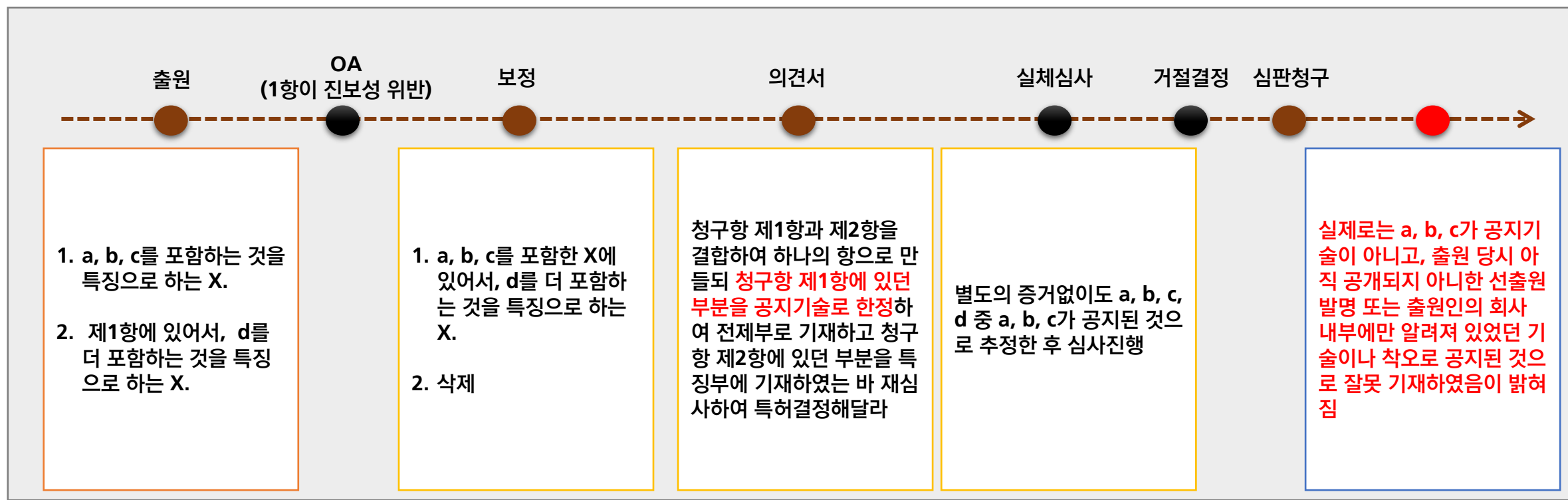


출원인의 입장만 고려: 출원인의 표시한 의사를 심사관이 임의로 변경하는 것은 타당하지 않음

특별사정
출원인의 입장뿐만 아니라 제3자의 입장 고려: 보호할 가치가 없는 사항이나 진실로 발명하지 아니한 부분까지 그 권리를 인정하는 것은 곤란

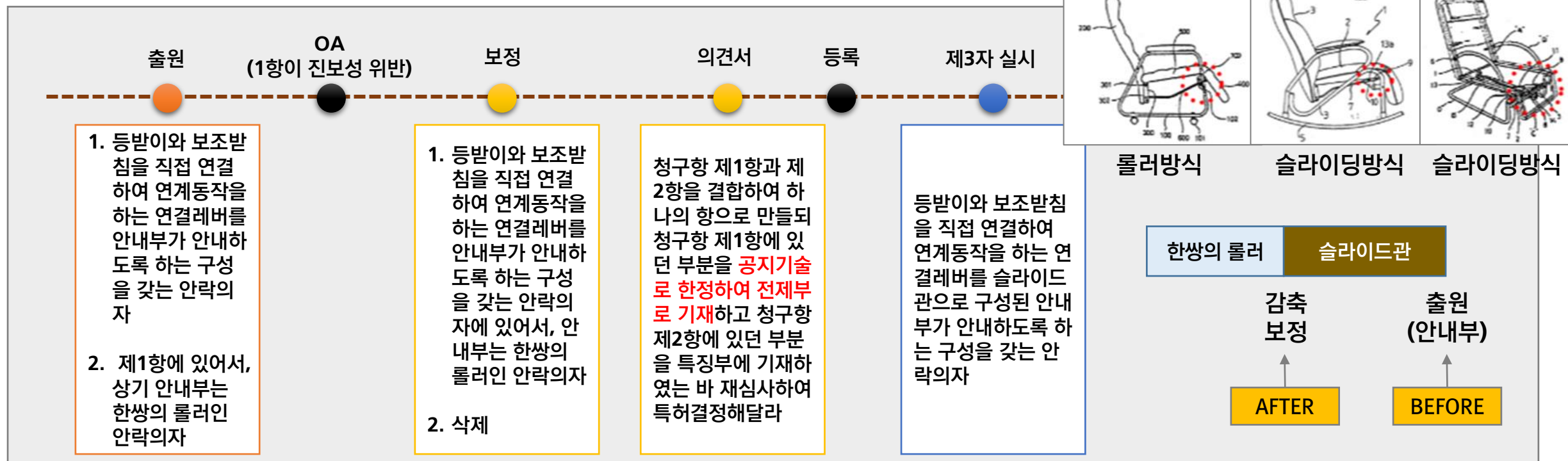
발명의 특정	특허요건 판단	보호범위 판단
청구범위 중심의 원칙	적용	적용
발명의 설명 참작의 원칙	적용	적용 (제한해석 가능)
공지기술 참작의 원칙	부적용 (발명의 특정 후 신규성, 진보성 등 판단으로 같음)	적용 (제한해석)
출원경과 참작의 원칙	부적용 (다만, 출원인이 공지되었음을 자인하는 경우 공지된 것으로 추정)	적용 (제한해석)
특허권하자 참작의 원칙	부적용 (발명의 특정 후 특허요건 판단으로 같음)	적용 (제한해석) 특별사정

특허요건을 판단할 때 명세서의 전체적인 기재와 출원 경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우(공지 자인)에는 **별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정**할 수 있다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 **잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다.**



대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결【권리범위확인(실)】: 안락의자 사건

지식재산처 심사관으로부터 실용신안공고 제95-4971호 고안 등에 의하여 통상의 기술자가 극히 용이하게 고안할 수 있다는 이유로 거절이유통지를 받고, 1998. 7. 22. 의견서 및 보정서를 제출하면서 **인용발명에 저촉되는 부분을 공지의 기술로 하여 청구범위를 대폭 축소 한정한다고 주장함**과 아울러 청구항 제1항과 제2항을 결합하여 하나의 항으로 만들되 청구항 제1항에 있던 부분을 전제부로 기재하고 청구항 제2항에 있던 부분을 특징부에 기재하였는바, **그렇다면 출원인 스스로 전제부의 기재사항인 「등받이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 안내부가 안내하도록 하는 구성」을 공지의 기술로 한정한 것이라 하겠고, 나아가 다시 특징부에서 위 안내부를 「한 쌍의 롤러」로 한정한 것은 출원인이 이와 균등관계에 있는 구성에 대해서는 그 권리범위를 주장하지 않겠다는 취지로 볼 것이므로, 결국 출원경과금반언의 원칙상 등받이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 안내부가 안내하도록 함에 있어서, 그 안내부를 {확인대상 고안과 같은} 슬라이드관으로 구성하는 것은 이 사건 등록고안의 출원인이 의식적으로 그 보호범위로부터 제외한 것으로 봄이 상당하여, 확인대상 고안의 슬라이드관은 이 사건 등록고안 제1항의 롤러의 균등론이 될 수 없다.**



대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결【등록무효(특)】

[1] 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. **물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.**

[2] 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 **제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.**

[3] 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

[4] 이와 달리, 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결, 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결, 대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다.

원심은, 이 사건 제6항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 ‘편광필름’을 그 청구범위로 하여 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명을 비교대상발명들과 대비함에 있어서, 이 사건 **제6항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음 곧바로 그에 따라 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였다.** 앞서 본 법리에 비추어 볼 때, **제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성 유무를 판단하였어야 함에도,** 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

공지기술

물건발명: 흑연연필심과 상기 흑연연필심을 둘러싸도록 목재로 구성된 외각부로 구성된 연필
 방법발명: a 공정후, b 공정후, c공정을 거치는 방법에 의해, 흑연연필심과 상기 흑연연필심을 둘러싸도록 목재로 구성된 외각부로 구성된 연필을 제조하는 방법

출원1

청구항1: a 공정후, c2 공정후, b1공정을 거치는 방법에 의해, 흑연연필심과 상기 흑연연필심을 둘러싸도록 목재로 구성된 외각부로 구성된 연필을 제조하는 방법
 청구항2: 제1항의 방법에 의해 제조된 연필

판단

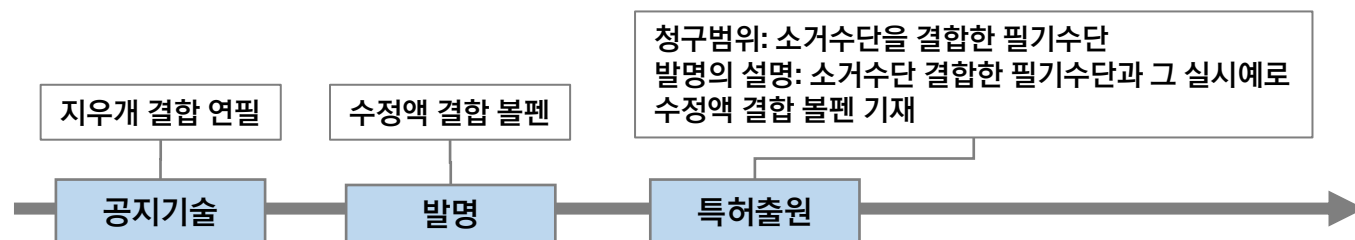
청구항1: $a \rightarrow c2 \rightarrow b1$ 을 구성으로 하며, 공지기술인 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 와 비교하여 동일성(신규성), 용이성(진보성) 판단
 청구항2: 흑연연필심과 목재외각부를 구성으로 하며, 공지기술인 흑연연필심과 목재외각부와 동일성이 있어 신규성 위반

출원2

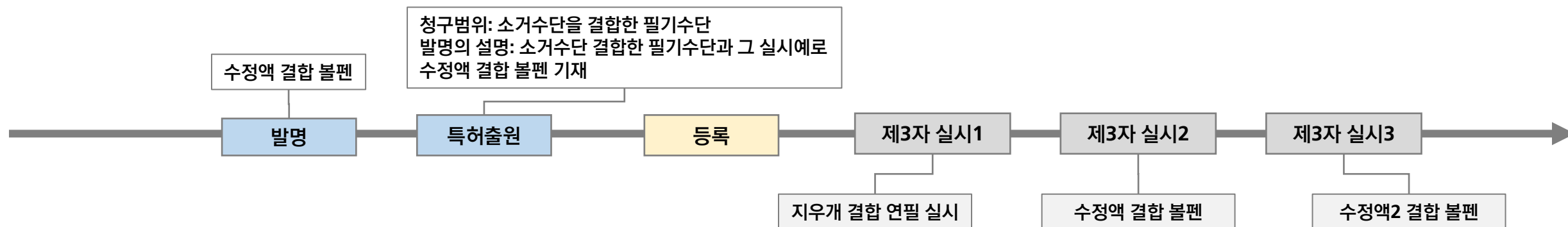
청구항1: a1 공정후, c3 공정후, b2공정을 거치는 방법에 의해, 흑연연필심과 상기 흑연연필심을 둘러싸도록 목재로 구성되고, 형상이 다각형인 외각부로 구성된 연필을 제조하는 방법
 청구항2: 제1항의 방법에 의해 제조된 연필

판단

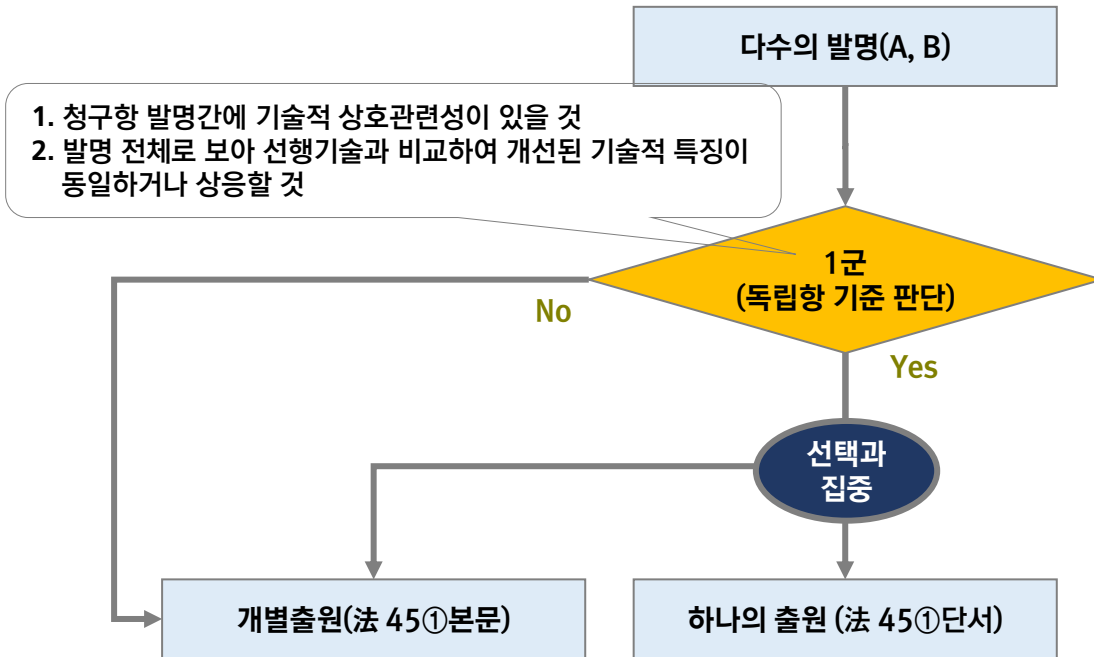
청구항1: $a1 \rightarrow c3 \rightarrow b2$ 를 구성으로 하며, 공지기술인 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 와 비교하여 동일성(신규성), 용이성(진보성) 판단
 청구항2: 흑연연필심과 다각형 목재외각부를 구성으로 하며, 공지기술인 흑연연필심과 목재외각부와 동일성(신규성), 용이성(진보성) 판단



구 분	1 발명특정	2 비교대상특정	3 판단
특허요건 판단	소거수단 결합 한 필기수단	지우개 결합 연필	발명이 상위개념이기 때문 에 신규성 위반*



구 분	1 발명특정	2 비교대상특정	3 판단
보호범위 판단	수정액 결합한 볼펜	지우개 결합 연필	AER, 균등론 의하여 비침해
		수정액 결합 볼펜	AER에 의한 침해
		수정액2 결합 볼펜	균등론에 의한 침해△



구 분	단일성(1군 발명)을 만족하는 경우	단일성을 만족하지 아니한 경우
개별 특허출원	가능(法 45①본문)	가능(法 45①본문)
하나의 특허출원	가능(法 45①단서)	불가능
비 고	단일성을 만족하는 발명에 대해서는 비용, 등록가능성 및 권리행사 측면을 고려하여 개별 특허출원할 것인지 아니면 하나의 특허출원을 할 것인지 선택하여야 한다.	

독립항 추출

▪ N개

판단횟수
결정▪ $N \times C_2$ 번 판단시행령 제6조
판단

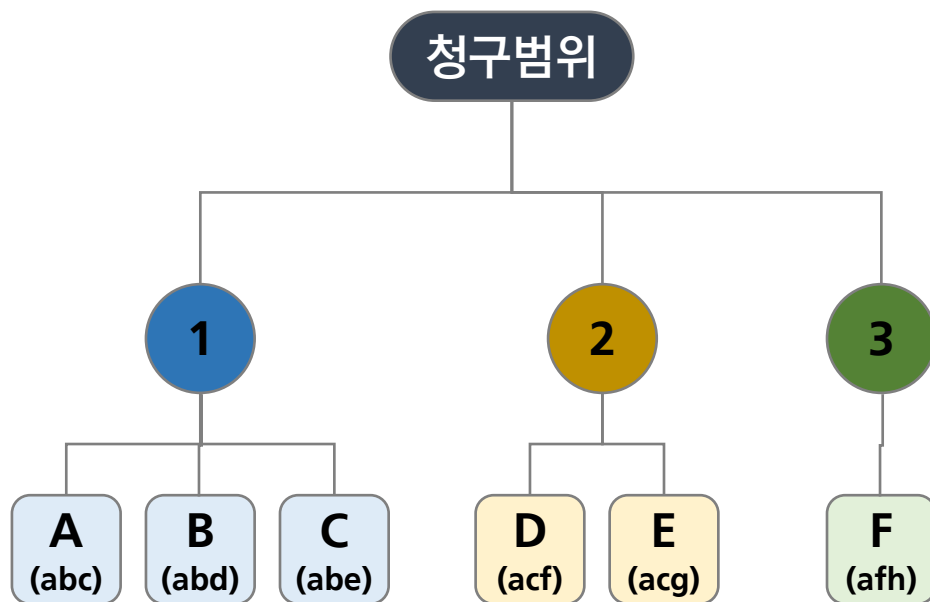
▪ 청구항(발명) 단위로 판단

모두 만족
여부

- 모두 만족: 제45조제1항본문/단서 선택
- 그렇지 아니한 경우: 제45조제1항본문

[청구범위]

1. ab와 (c, d 및 e 중 어느 하나) 로 구성된 X
2. ac와 (f 및 g 중 어느 하나) 로 구성된 X
3. afh로 구성된 X



등록 전
처리단위

- 일부 청구항이라도 거절이유가 있으면 출원전체가 거절결정(출원일체의 원칙)

예를 들어, 청구항 1에 흠결이 있는 경우 청구항 2, 3에 흠결이 없더라도 출원 전체를 거절결정

등록 후
처리단위

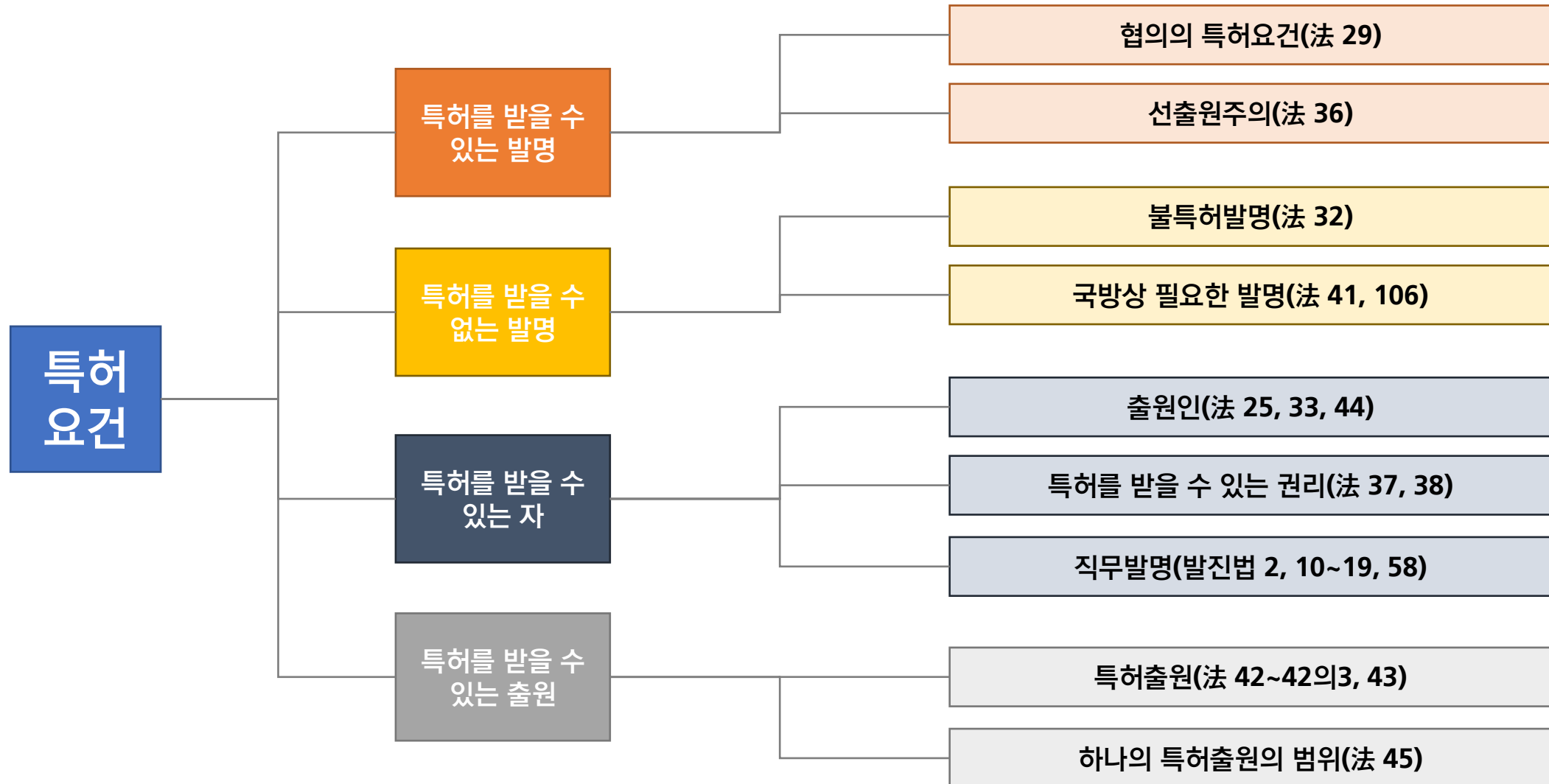
- 하자 있는 청구항 단위로 일부무효/일부취소

예를 들어, 청구항 1에 흠결이 있고, 청구항 2, 3에 흠결이 없는 경우 청구항 1만 무효, 취소

심사(심리)
단위

- 발명 단위로 심사(심리) 진행
- 일부 발명에 흠결이 있으면 청구항 전체에 흠결이 있는 것으로 처리

예를 들어, A 발명에 흠결이 있는 경우 B, C 발명에 흠결이 없더라도 청구항 1에 흠결이 있는 것으로 처리



요건			발명의 성립성 (法 29①본문)	산업상 이용가능성 (法 29①본문)	신규성 (法 29①각호)	진보성 (法 29②)	확대된 선출원 (法 29③④)	선출원주의 (法 36)	
의의			자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것	산업에서 실제 실시될 수 있는 발명	발명의 내용이 사회일반에 아직 알려지지 않은 것으로서 객관적 창작성이 있는 것	통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 없는 것	특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원하여 그 특허출원 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 다른 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일성이 있는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 선출원의 지위를 부여하는 것	동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있는 경우 가장 먼저 출원한 자에게 발명을 허용하는 주의	
내용			1.자연법칙 이용 2.기술적 사상 3.창작 4.고도	1.산업 2.이용가능성	1.공지 2.공연실시 3.반포된 간행물에 게재 4.전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능			1.이일출원(法36①③) 2.동일출원(法36②③⑥) 3.선출원지위의 인정여부(法36④⑤)	
판단	주체적 기준		심사관, 심판관, 법관			1.심사관, 심판관, 법관 2.통상의 기술자 입장에서 판단		심사관, 심판관, 법관	
	객체적 기준	대상	청구범위 중심으로 명세서 · 도면을 창작			공지기술(1개) vs 청구범위		다른 출원 최 · 명 · 도 vs 그 출원의 청구범위	선출원 청구범위 vs 후출원 청구범위
		범위	청구항마다(단, 특허여부결정은 출원단위)						
	시기적 기준	원칙	법규정×(실무상 출원시)			특허출원전		1.그 특허출원일전 다른 출원-역일주의(단,동일자 적용×) 2.그 특허출원후 다른 출원의 공개-(시각주의)	출원일
		예외	1.소급-정당한 권리자출원(法34. 35), 분할출원(法52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法53③), 조약우선권주장출원(法54①), 국내우선권주장출원(法55③) 2.국제특허출원-우선일						
	지역적 기준					국제주의		국내주의(속지주의 원칙)	
	판단방법		1.비발명 2.미완성발명			1.의료업 2.경제성 3.불성립발명 4.타법과 관계 5.결과물과 관계	동일성	용이성	동일성
위반의 효과			실체적 요건 위반						
기타			발명의 성립성이 문제되는 경우		신규성 상실의 예외	1.진보성 상실의 예외 2.고안의 진보성과 관계	1.적용의 예외 2.다른 출원이 국제특허출원인 경우	1.선출원주의의 보완 2.선출원주의의 예외	

요건		불특허발명 (法 32)	출원인 (法 25, 33, 44)	특허출원에 필요한 서류 (法 42-42의3)	하나의 특허출원의 범위 (法 45)
의의		공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없도록 규정	출원인이 되기 위해서는 i)일반적인 권리의 주체가 될 수 있는 능력인 권리능력이 있어야 하며, ii)권리능력이 있는 자라 하더라도 당해발명에 대한 권리의 주체가 될 수 있는 권리적격이 있어야 함	특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명의 공개를 전제로 하여 지식재산처에 대하여 특허를 받고자 하는 의사를 객관적으로 표시하는 행위를 말하며, 특허절차는 출원으로부터 시작된다.	하나의 특허출원으로 할 수 있는 발명의 범위를 말하는 것으로서, 하나의 발명마다 하나의 특허출원을 원칙으로 하나, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.
내용		1.공서양속에 위반된 발명 2.공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명	1.권리능력자 ①내국인 ②외국인(法25) 2.권리적격자 ①발명자 ②승계인 ③지식재산처직원 ④특허를 받을 수 있는 권리의 공유	1.종류 2.역할 3.기재방법	1.하나의 발명 하나의 출원 원칙 2.일 군의 발명 하나의 출원 보완
판단	주체적 기준		심사관, 심판관, 법관		
	객체적 기준	대상	청구범위		독립항을 기준
		범위	청구항마다(단, 특허여부결정은 출원단위)		
	시기적 기준	원칙	특허여부 결정시		
		예외			
	지역적 기준				
	판단방법		1.심사절차내에서 판단 2.합리적 의심이 드는 경우의 판단		
위반의 효과		1.출원공개의 예외 2.실체적 요건 위반	주체적 요건 위반	1.실체적 요건 위반 (法 42③Ⅰ,④) 2.절차적 요건 위반 (法 42③Ⅱ,⑧)	절차적 요건 위반
기타				1.청구범위제출 유예(法 42의2) 2.외국어특허출원(法 42의3)	1.최소한의 판단 2.보정에 의한 청구항 변경의 경우

총칙/
보칙

특허
요건

이익
제도

심사
(제도)

특허권

심판/
소송

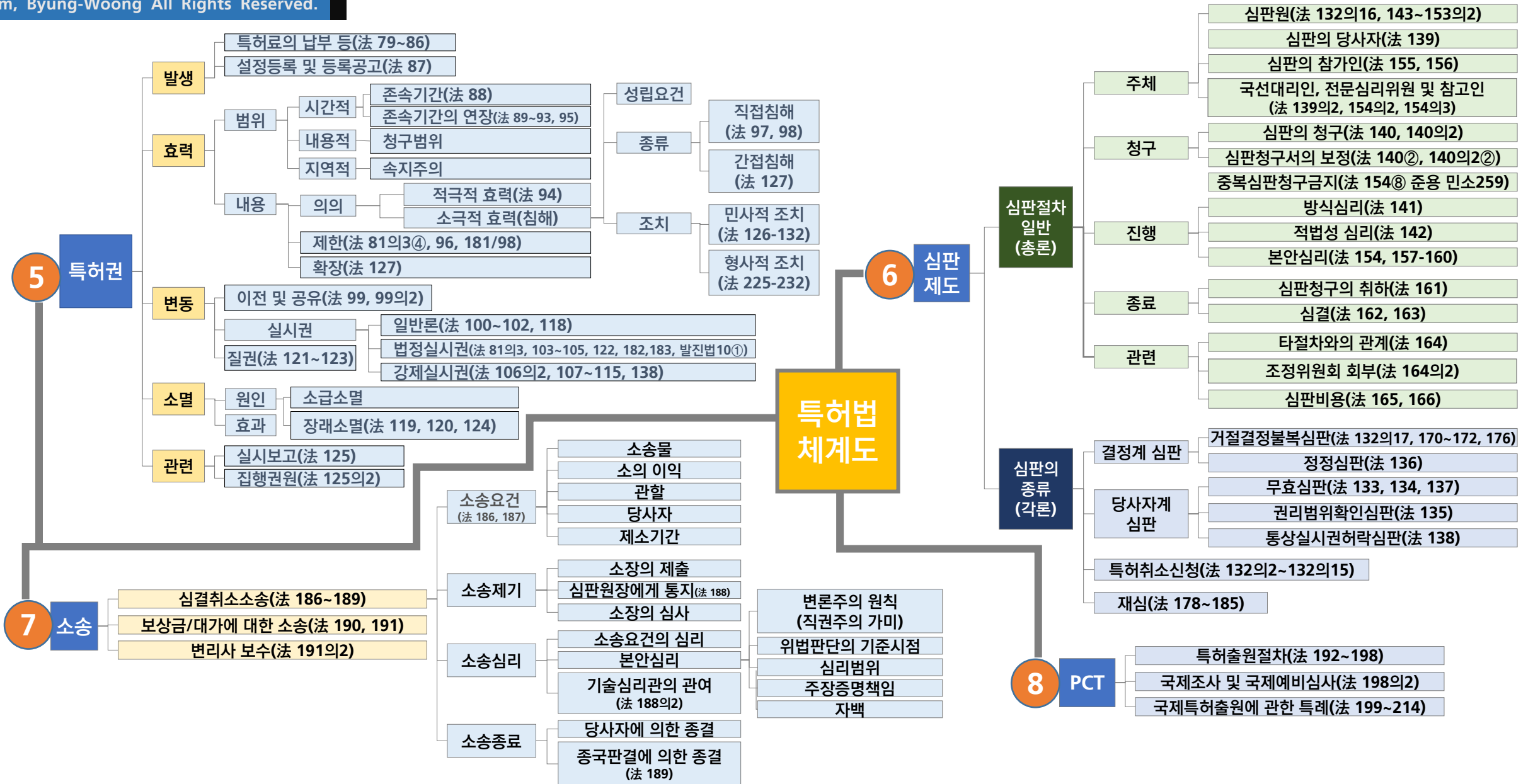
PCT

특허법 강의노트

Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

2026





제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공개된 경우는 제외한다.

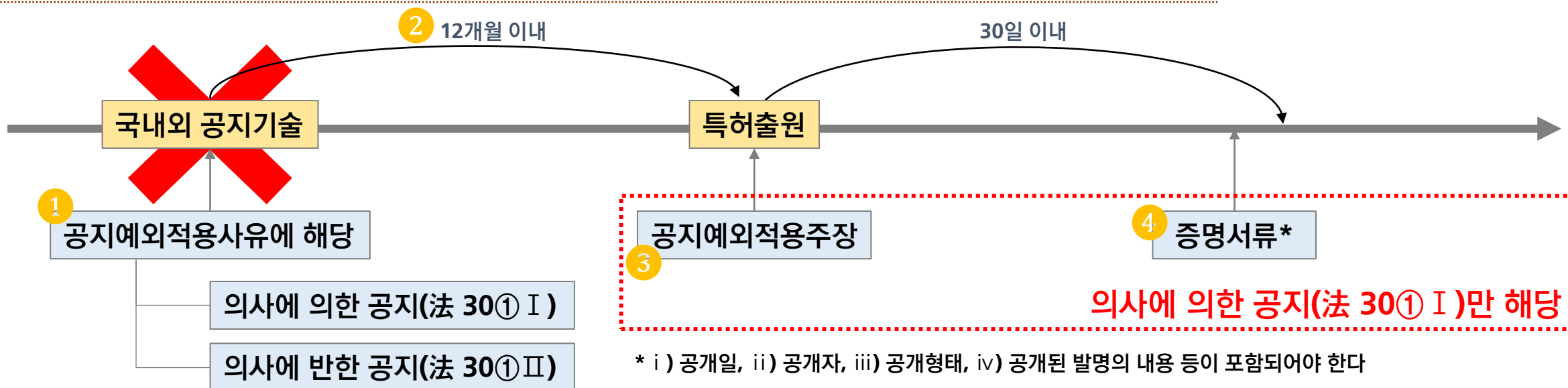
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 총리령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일로부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

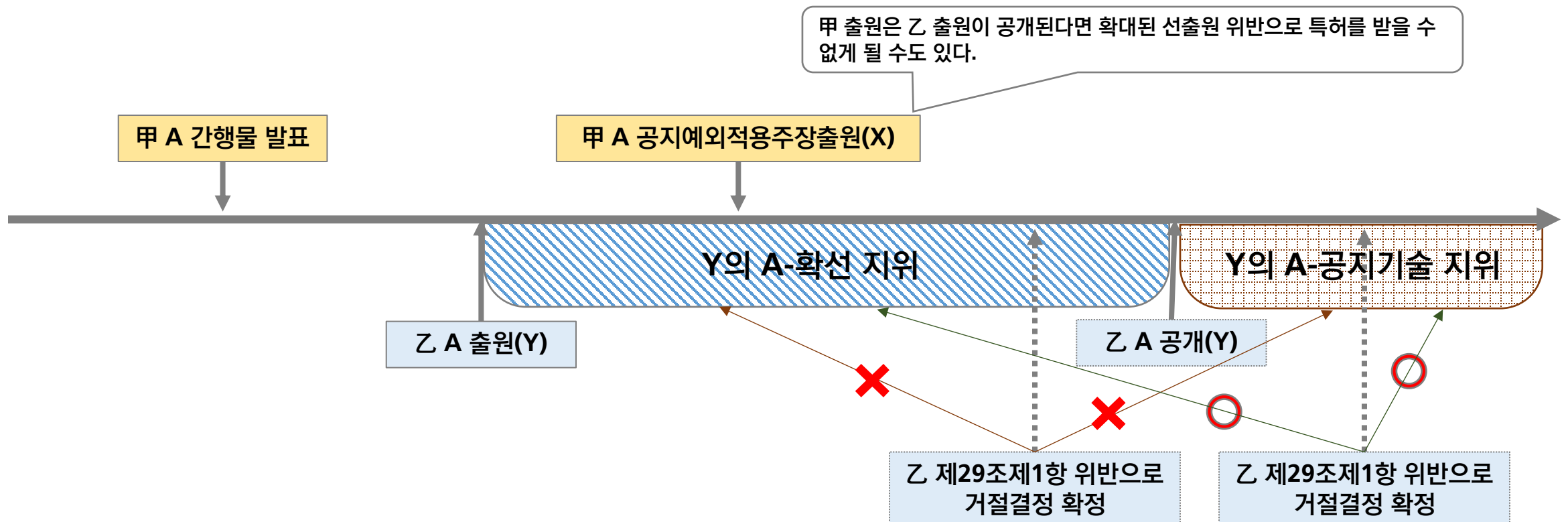
③ 제2항에도 불구하고 총리령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다

1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간

2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

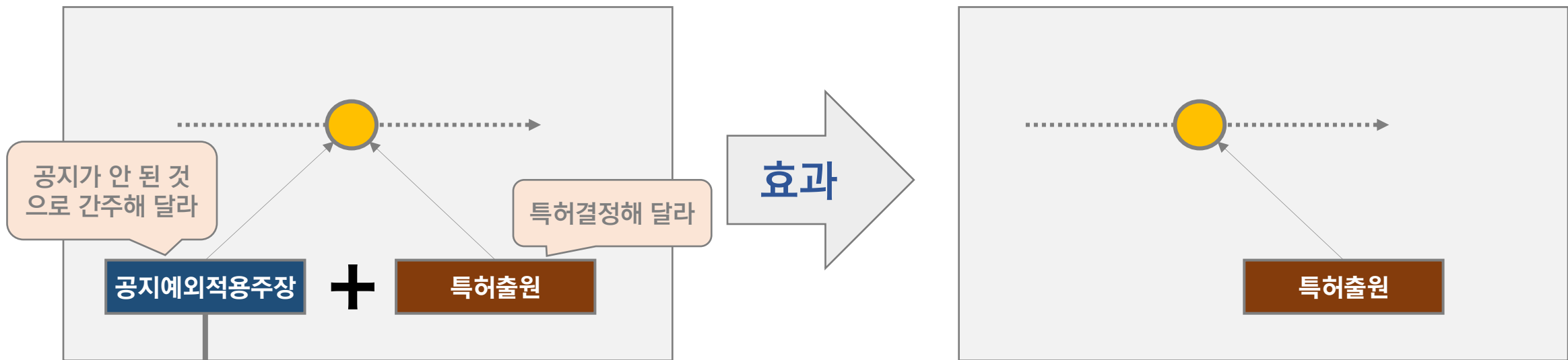


공지에외적용주장출원의 경우 출원일이 소급되는 것은 아니므로 12개월의 유예기간이 있더라도 될 수 있으면 빨리 출원해야 한다. 예를 들어, 공지일과 공지에외적용을 주장한 특허출원(이하 “甲 출원”라 함)일 사이에 타인의 특허출원(이하 “乙 출원”이라 함)이 있으면, 甲 출원은 乙 출원이 공개된다면 확대된 선출원 위반으로 특허를 받을 수 없게 될 수도 있다. 다만, 乙 출원이 공개 전에 무효, 취하, 포기 또는 거절결정이 확정된다면 甲 출원은 특허를 받을 수 있을 것이다. 한편 乙 출원은 신규성 위반으로 특허를 받을 수 없다.



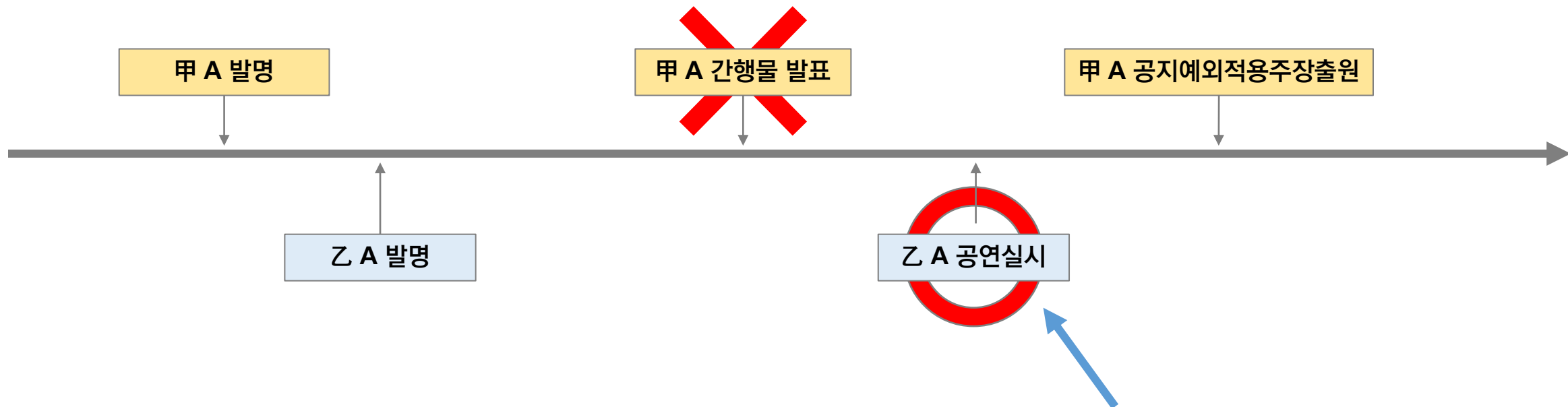
* 乙 출원의 심사청구시기, 심사청구순서에 따라 공개 전후에 거절결정확정가능

출원인이 공지에외적용주장출원을 하였으나, 공지에외적용주장이 방식에 위반된 경우 지식재산처장은 그 흠결을 지적하여 보정명령을 하고 보정명령에도 불구하고 보정하지 않거나 보정에 의하여 흠결이 치유되지 아니한 경우 그 보정명령을 한 절차인 **공지에외적용주장**을 무효로 할 수 있다. **출원**은 공지에외적용주장을 하지 아니한 출원이 되기 때문에 심사관은 공지에외적용을 주장한 공지기술에 의하여 출원된 발명의 신규성 또는 진보성을 판단하여야 한다.



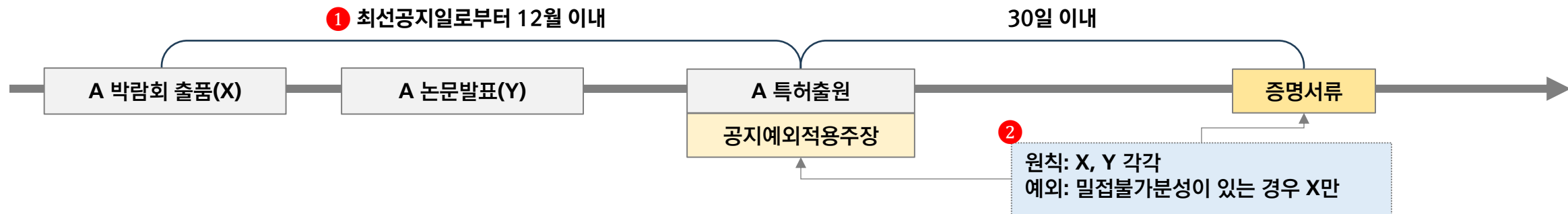
- 부적법한 경우 방식위반으로 처리하여 보정명령후 **공지에외적용주장**을 무효 처분
- 무효가 된 경우 공지에외적용주장은 처음부터 없었던 것으로 간주

공지예외적용사유(法 30①각호)가 아닌 다른 사유로 공지된 경우에는 다른 공지에 의하여 특허출원된 발명의 신규성 또는 진보성을 판단하여야 한다. 예를 들어, 공지예외적용사유에 해당하는 공지가 있는 날과 특허출원일 사이에 출원발명과 동일한 발명에 대하여 공지예외적용사유가 아닌 공지가 있는 경우 그 특허출원된 발명은 신규성이 없는 것으로 하여 특허거절결정된다.



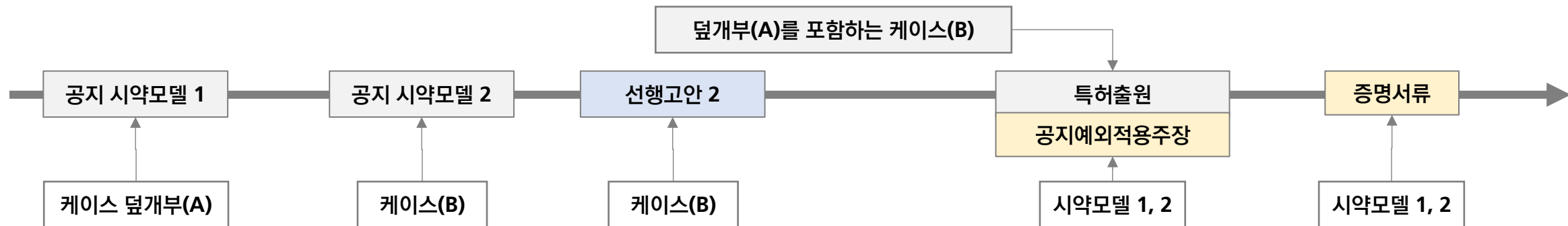
특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자(甲)의 발명이 아니기 때문에 공지예외적용주장 不可

복수의 공지행위가 모두 공지에외적용사유(法 30①각호)에 해당하는 경우에는 모든 공지행위에 대하여 각각 공지에외적용주장을 할 수 있다. 이 경우 출원인은 **최선의 공지일로부터 12개월 이내** 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 총리령으로 정하는 방법에 따라 출원일로부터 30일 이내 각각 제출하여야 한다. 다만 특정한 어느 하나의 공지와 **밀접불가분의 관계에 있는 복수회에 걸친 공지일** 경우에는 출원인의 편의를 위해 2번째 이후의 공지에 대해서는 **취지기재 및 증명서류의 제출을 생략**할 수 있다.



대법원 2025. 5. 29. 선고 2023후10712 판결 【등록무효(실)】

신규성 또는 진보성 요건에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 특허법의 취지에 맞지 않게 되는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 발명은 공지 등이 되지 않은 것으로 취급하기 위하여 공지에외 규정을 둔 것이다. 이러한 공지에외 규정의 문언과 취지에 비추어 보면, **특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제30조 제1항에서 정한 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지에외 주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지된 나머지 발명들에까지 공지에외의 효과가 미친다고 보아야 한다.**



공지에외적용사유나 시기가 국가별로 차이가 있기 때문에, 특허출원이 공지보다 선행되어야 한다. 특히 논문발표를 한 경우 중국이나 유럽은 특허를 받을 수 없기 때문에 유의해야 한다.

공지에외적용시기

구 분	국 가 명
6개월	유럽(EPO), 중국, 러시아, 대만, 리투아니아, 북한
12개월	미국, 호주, 캐나다, 멕시코, 브라질, 불가리아, 포르투갈, 루마니아, 터키, 벨라루스, 슬로베니아, 아르헨티나, 아르메니아, 엘살바도르, 에스토니아, 카자흐스탄, 말레이시아, 페루, 사우디아라비아, 싱가포르, 스리랑카, 트리니다드토바고, 몰도바, 바르바도스, 한국, 일본
무제한	남아공

공지에외적용사유

국가	의사에 의한 공지				의사에 반한 공지	박람회 출품
	시험	간행물 게재	전기통신회선을 통해 공지	학술단체가 개최하는 연구집회에서 서면발표		
일본	○	○	○	○	○	○ (박람회종류 제한)
중국	X	X	X	○	○	○ (박람회종류 제한)
EPO	X	X	X	X	○ (요건 엄격)	○ (박람회종류 제한)
미국	○ (적용대상을 열거하지 않고 넓게 허용)					

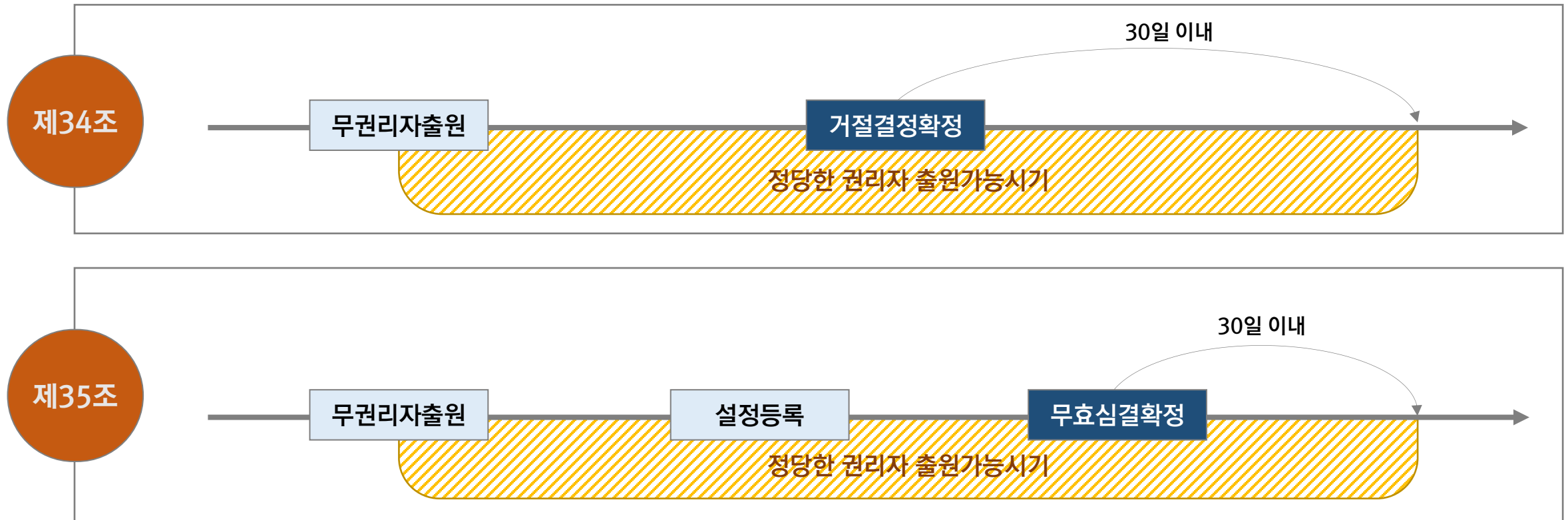
특허법은 i) 무권리자의 출원이나 특허를 배척하는 한편(法 33①본문 위반) 일정요건 하에 정당한 권리자의 출원을 무권리자의 출원일로 소급시키거나(法 34, 35), ii) 특허권의 이전청구(法 99의2)를 통해 정당한 권리자를 보호해 주고 있다. 즉, 정당한 권리자가 i)과 ii)의 방법 중에서 각각 소요되는 비용과 시간 등을 상호 비교하여 선택할 수 있도록 함으로써 편의를 제고하고 있다. 이는 선출원주의하에서 선발명주의적 요소의 가미라고 할 수 있다.

구분	출원일의 소급효		특허권(특허출원)의 이전청구 (제33조제1항본문, 제44조 위반)
	제33조제1항본문 위반	제44조 위반	
출원	○(法 34)	×	○(해석상)
	- 거절이유(法 62①Ⅱ) - 거절결정확정된 날로부터 30일까지	- 거절이유(法 62Ⅰ)	- 출원계속중 - 거절이유에서 제외(해석상)
특허	○(法 35)	×	○(法 99의2)
	- 무효사유(法 133①Ⅱ본문) - 무효심결확정된 날로부터 30일까지 - 선의의 무권리자에게 중용권(法 104) 인정가능	- 무효사유(法 133①Ⅱ본문) - 지분에 대한 무효심판청구불가	- 무효심결확정전 - 무효사유에서 제외(法 133①Ⅱ단서) - 선의의 무권리자에게 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 103의2) 인정가능

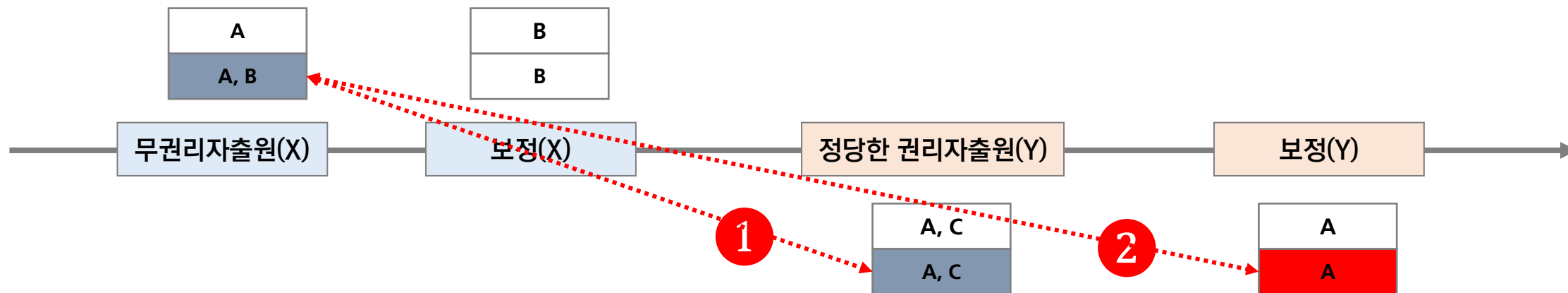
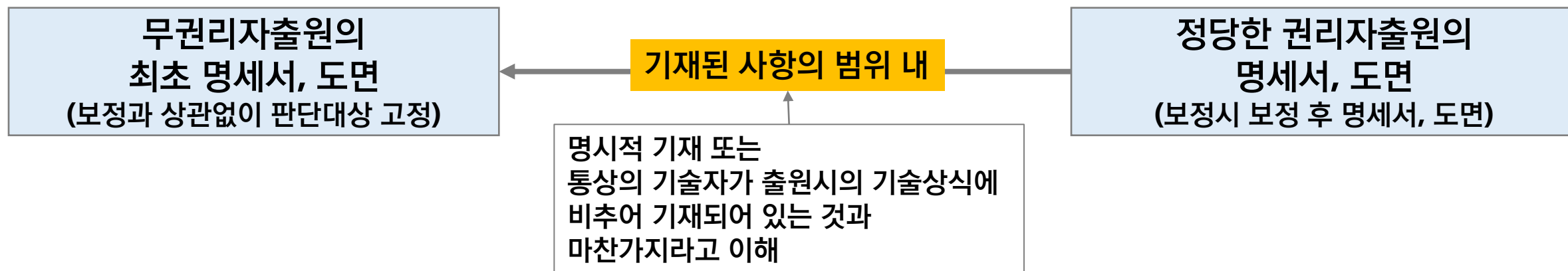
권리범위 재설계 기회의 확보 vs 절차의 신속성, 경제성

제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 **그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.**

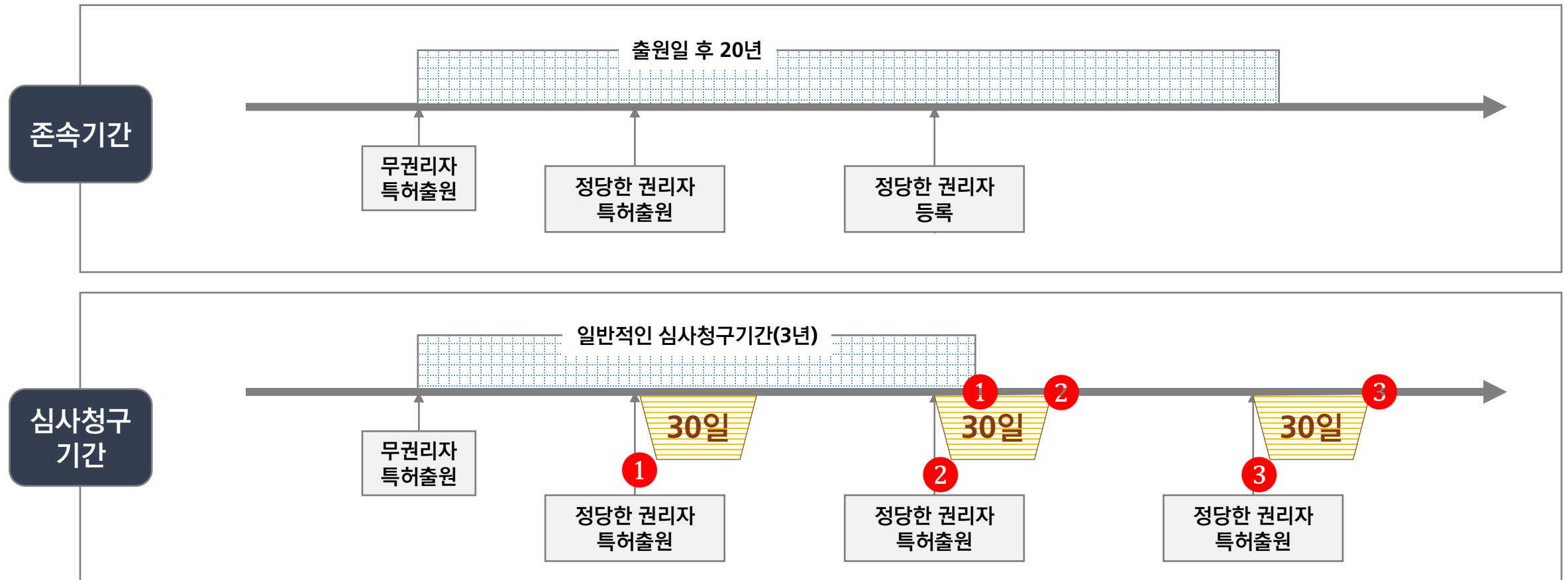
제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 **그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.**



정당한 권리자 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 무권리자 출원의 발명 범위에 포함되어 있어야 한다. 「무권리자 출원의 발명 범위」란 무권리자의 보정 여부에 따라 발명 범위가 달라지는 것은 타당하지 않기 때문에 무권리자가 출원할 때 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위로 해석함이 타당하다. 「최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항」은 최초 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다.



정당한 권리자의 특허출원에 대하여 법 제34조 및 제35조에 따라 특허된 경우에는 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음날부터 기산한다(法 88②). 즉, **존속기간은 정당한 권리자 출원의 특허권을 설정등록한 날로부터 무권리자의 출원일 후 20년이 되는 날까지이다.** 무권리자의 특허출원·특허에 대한 정당한 권리자의 특허출원의 경우 심사청구기간은 무권리자의 출원일의 다음날부터 기산한다(法 34, 35). 다만, 정당한 권리자의 특허출원이 무권리자의 출원일로부터 3년의 기간이 지난 후라도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다(法 59③). 즉, **정당한 권리자 특허출원의 심사청구기간은 무권리자 출원일로부터 3년과 정당한 권리자 출원일로부터 30일 중 늦은 날까지이다.**

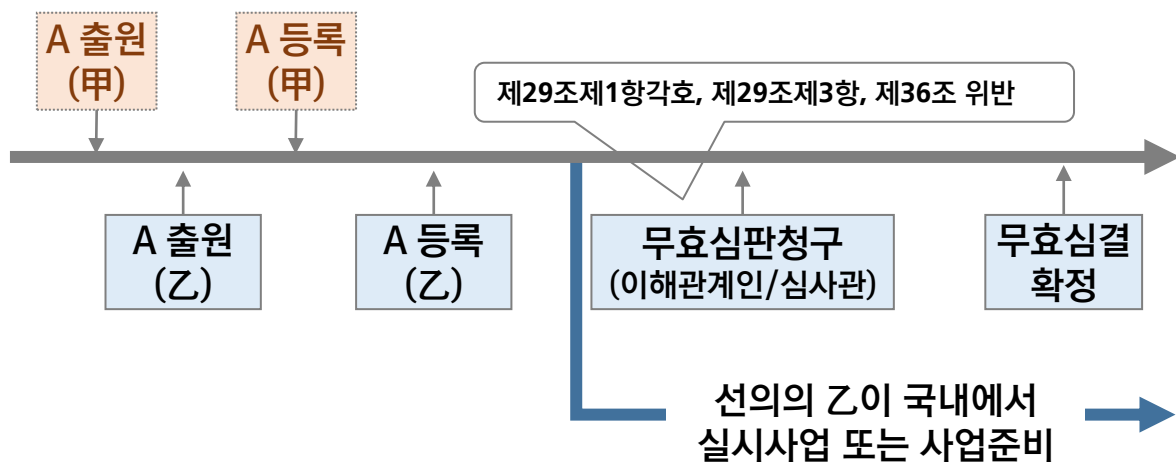


제104조(무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

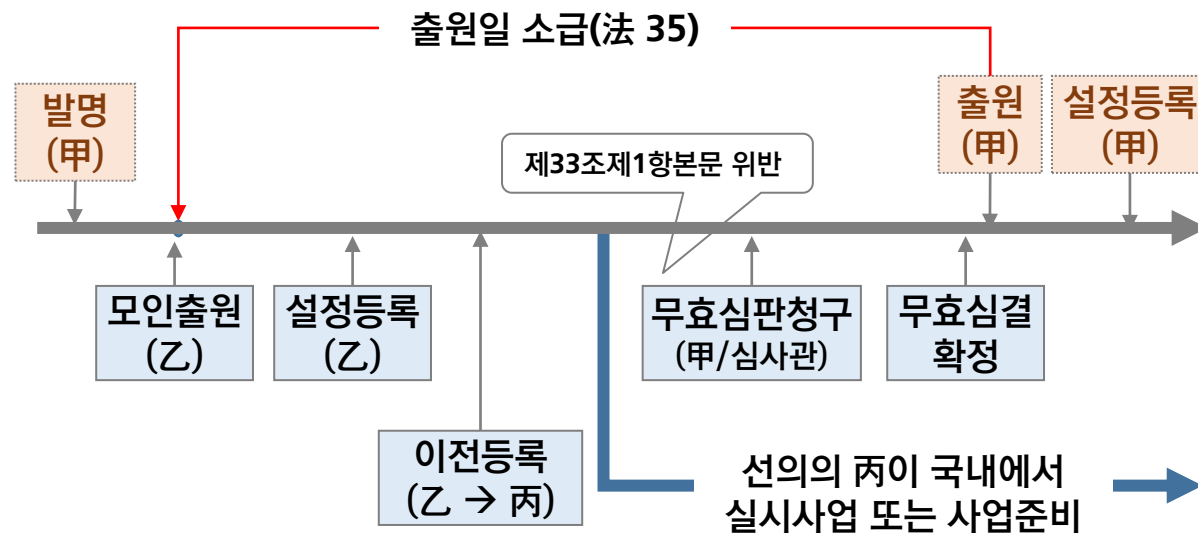
1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자
3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자
5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제29조제1항각호, 제29조제3항, 제36조 위반

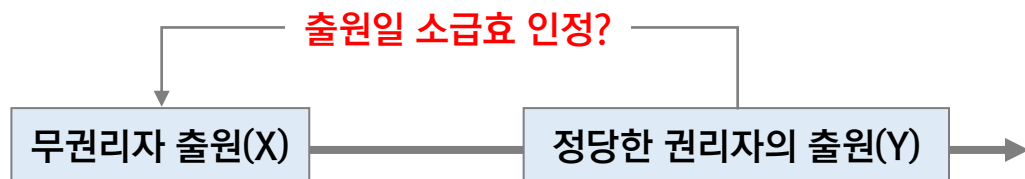


제33조제1항본문 위반

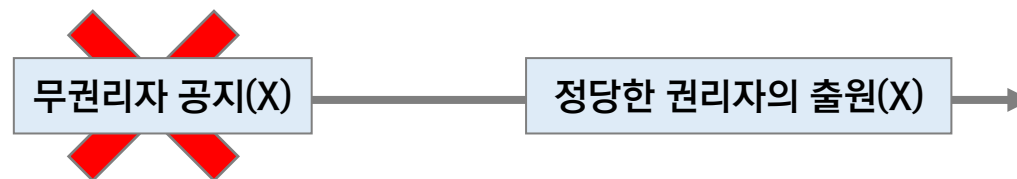


무권리자의 출원의 공개가 있는 후에 소급효가 인정되지 아니한 정당한 권리자의 출원이 있는 경우, 무권리자의 공개는 법 제30조제1항제2호의 의사에 반한 공지에 해당하기 때문에 공개된 날로부터 1년 이내 정당한 권리자가 출원했다면 공지가 되지 아니한 것으로 보아서 신규성, 진보성 위반을 판단하지 않게 된다. 그러나 공개된 날로부터 1년을 지나서 정당한 권리자가 출원했다면 정당한 권리자의 출원이 그 공개에 의하여 신규성, 진보성에 위반되었는지 여부를 판단해야 한다.

제34조, 제35조에 의한 출원일 소급효 인정여부 판단



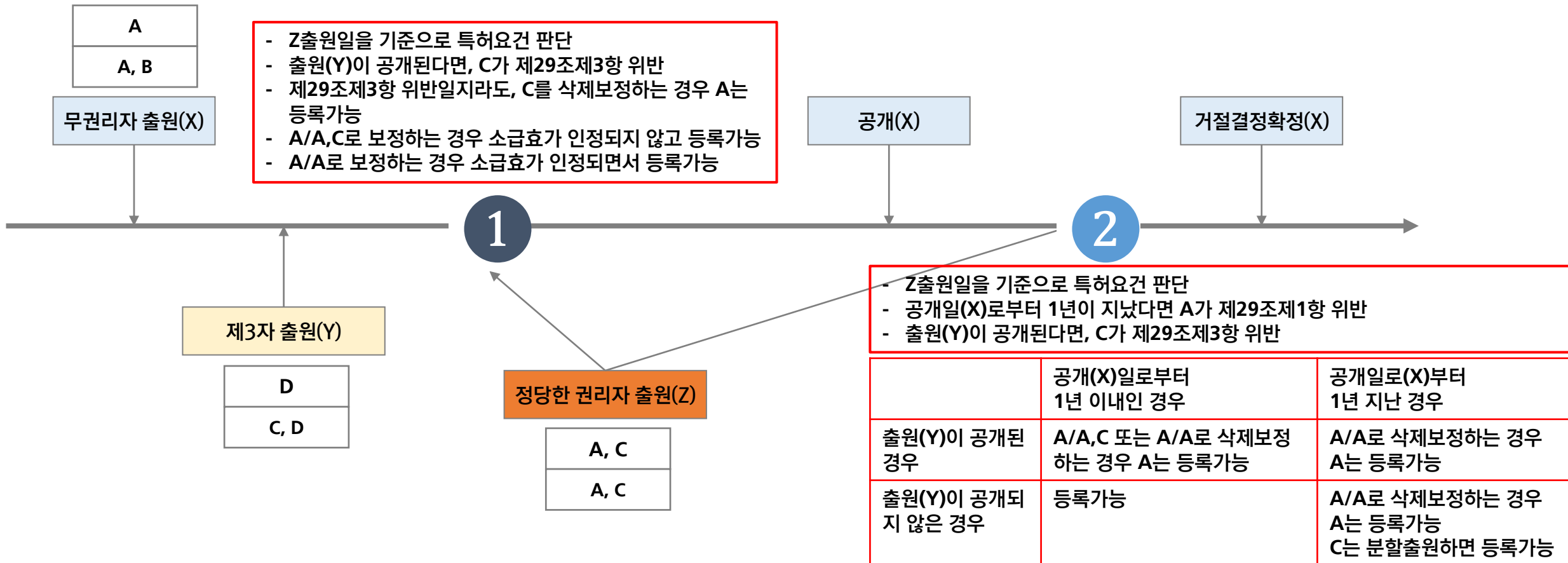
제30조제1항제2호의 의사에 반한 공지 주장 여부 판단



1차적으로 제34조, 제35조에 의한 출원일 소급효 인정여부 판단한 후,
2차적으로 제30조제1항제2호의 의사에 반한 공지 주장 여부 판단



정당한 권리자 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 무권리자 출원에 기재된 발명과 다른 발명이 있는 경우(정당한 권리자 출원에 다수의 발명이 포함되어 있고 그 발명 중 일부의 발명만이 무권리자에 의하여 출원된 발명에 해당하는 경우) 정당한 권리자 출원의 출원일은 소급되지 아니한다. 심사관은 출원일 소급을 인정할 수 없을 때 i) 다른 거절이유가 있는 경우에는 거절이유통지서에 출원일을 소급할 수 없다는 취지를 적어 함께 통지함으로써, 출원을 분할하거나 보정할 수 있도록 기회를 부여하고, ii) 다른 거절이유가 없는 경우에는 출원일을 소급할 수 없는 취지만을 통지한 후 특허결정한다. 즉, **정당한 권리자의 특허출원은 출원일이 소급되지 않더라도 무권리자의 선출원에 의하여 특허거절결정되지 아니한다.** 무권리자의 선출원은 선출원의 지위가 없으며(法 36⑤), 발명자가 동일하여 정당한 권리자의 출원에 대하여 확대된 선출원의 지위도 인정되지 않기 때문이다(法 29③④단서).



제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

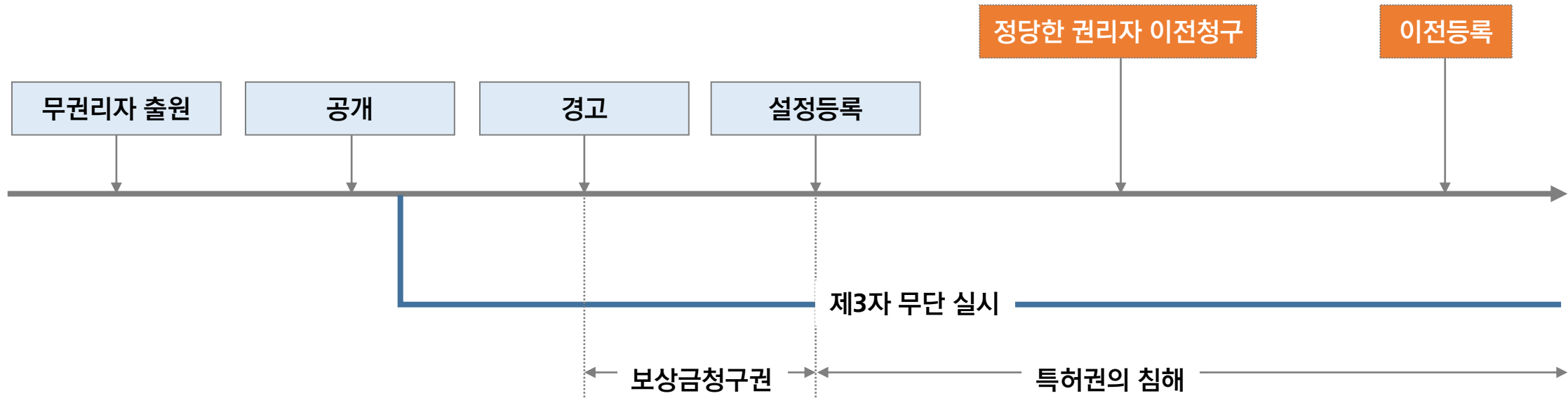
② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.

1. 해당 특허권

2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권

3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권

③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.



제103조의2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

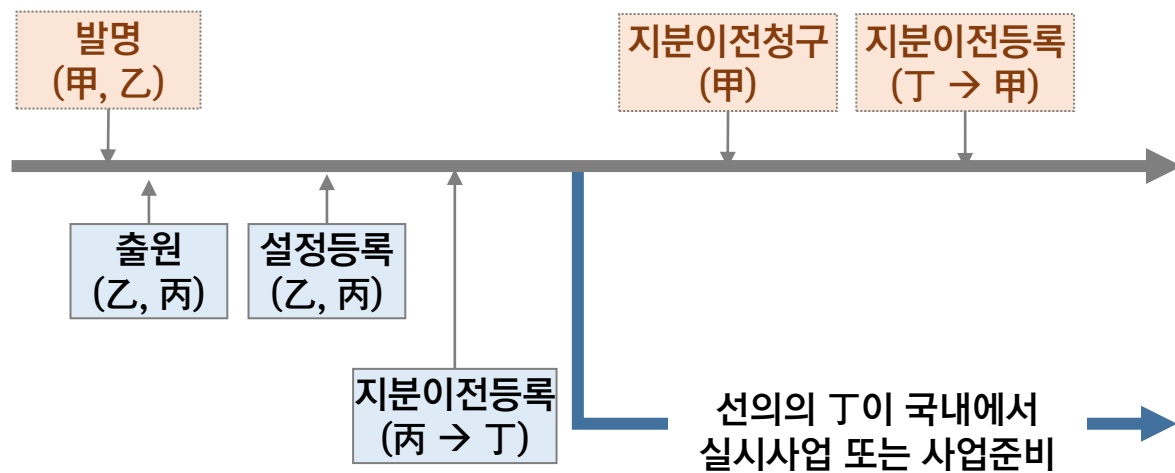
1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자

2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

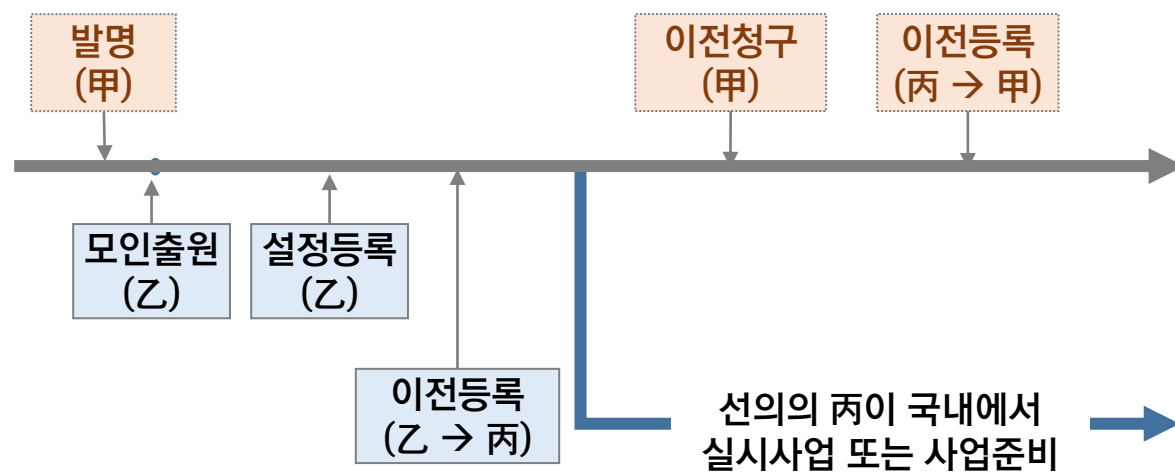
② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제44조 위반

제44조 위반	출원일의소급효	특허권(특허출원)의이전청구
출원	×	○(해석상)
	×	○(法 99의2)
특허	-지분에 대한 무효심판청구불가	-무효사유에서 제외(133①Ⅱ단서) -특허권의이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 103의2) 인정가능



제33조제1항본문 위반



제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 “무권리자”라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 신격이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우
2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

제104조(무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
 2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자
 3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
 4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자
 5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.
- ② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.

1. 해당 특허권
 2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
 3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권
- ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

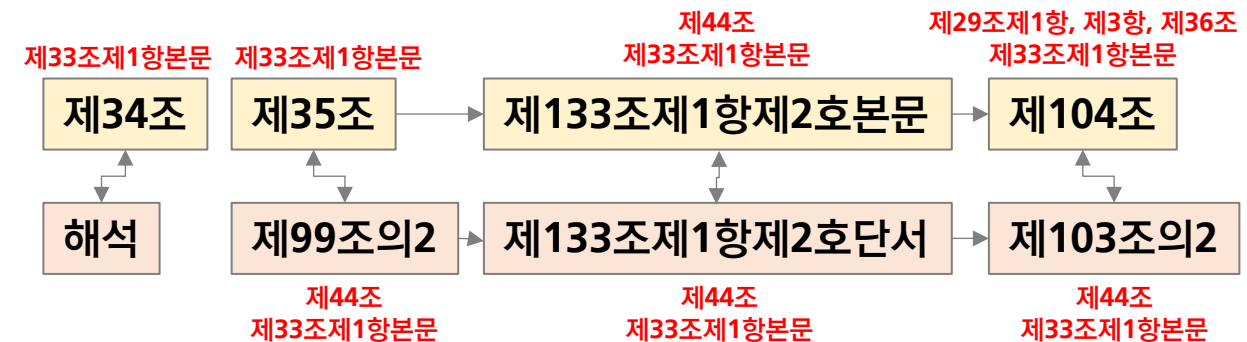
제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우
2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

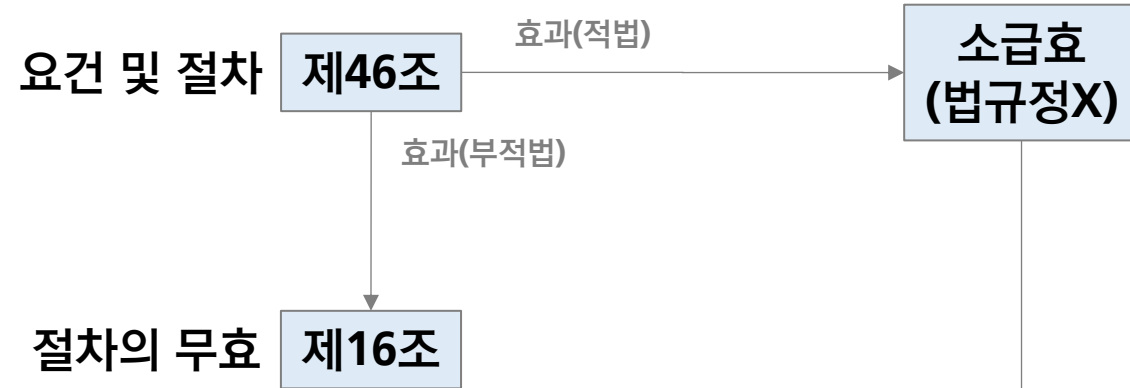
제103조의2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자
2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

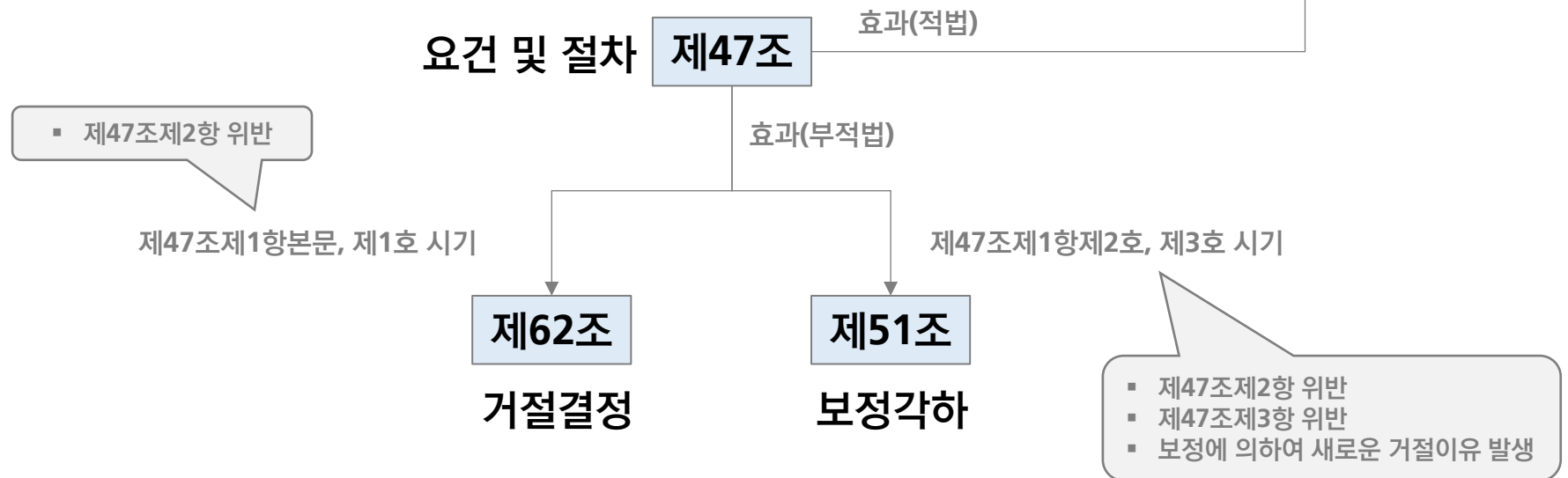
② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.



절차보정



실체보정



제47조(특허출원의 보정) ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.

1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때

② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.

③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

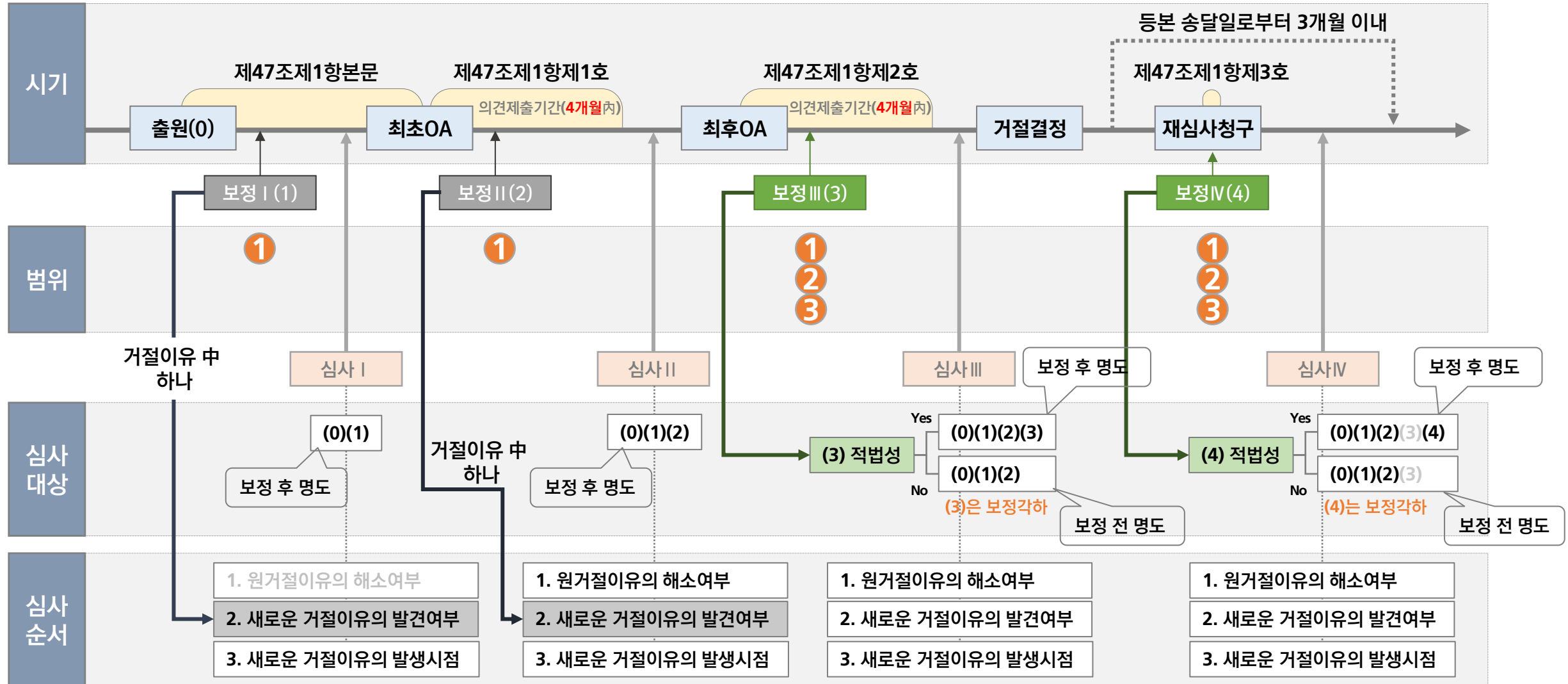
1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우
 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
 4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우
- ④ 제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다.
- ⑤ 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

제51조(보정각하) ① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우: 그 직권보정 전에 한 보정
2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허결정 전에 한 보정
3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정

② 제1항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

③ 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.

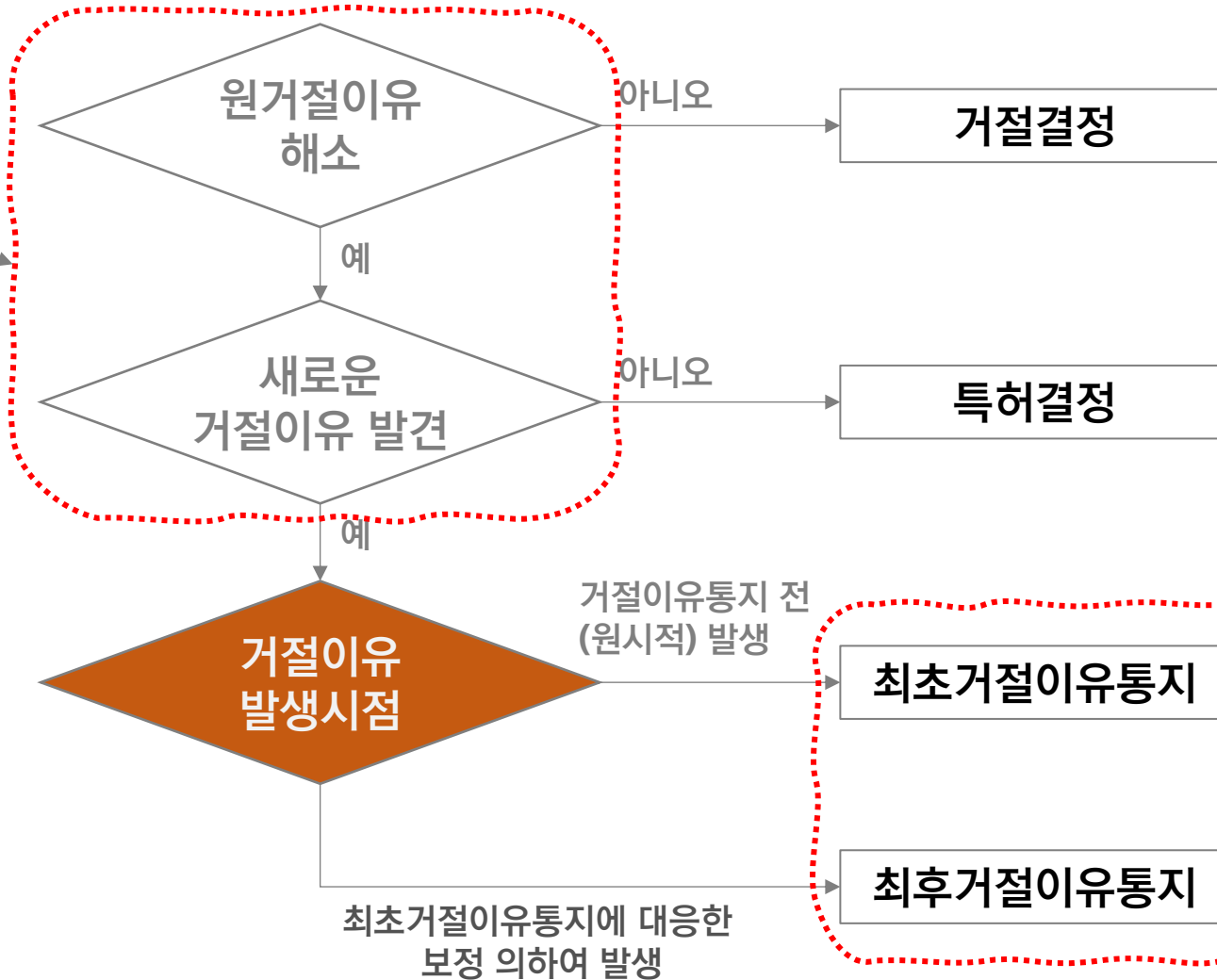


① 신규사항추가금지(제47조제2항)

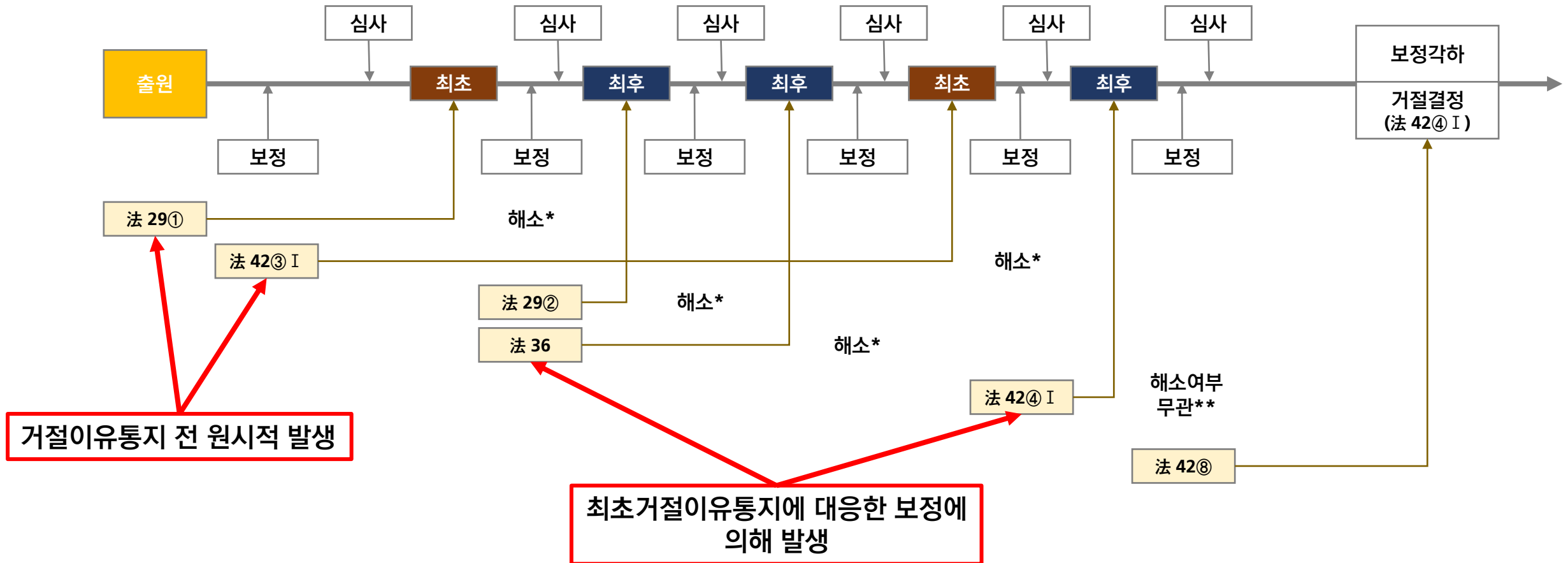
② 청구범위 보정범위 제한(제47조제3항)

③ 보정에 따라 새로운 거절이유 발생 ×

심사관이
모든 거절이유에 대하여
거절이유통지한 후
거절결정해야 하는 것은
아니다.



둘 다 발견된 경우에는
출원인의 절차적 이익을 위해
최초거절이유통지를
한다.



* 원거절이유가 해소되지 않은 경우 바로 거절결정됨

** 보정이 부적법하여 보정각하되기 때문에 보정된 명세서 또는 도면에 의하여 원거절이유가 해소되었는지 여부는 무관함

*** 거절이유통지전 발생한 거절이유와 **거절이유통지에 대응한** 의견제출기간 내 보정에 의하여 발생한 거절이유를 동시에 발견한 경우에는 최초거절이유통지

제47조(특허출원의 보정) ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다.

1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때

제47조제1항본문



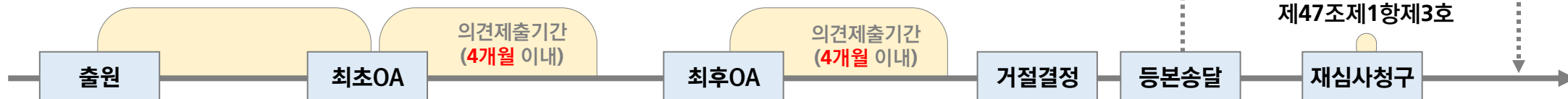
제47조제1항본문

제47조제1항제1호

제47조제1항제2호

3개월 이내

제47조제1항제3호



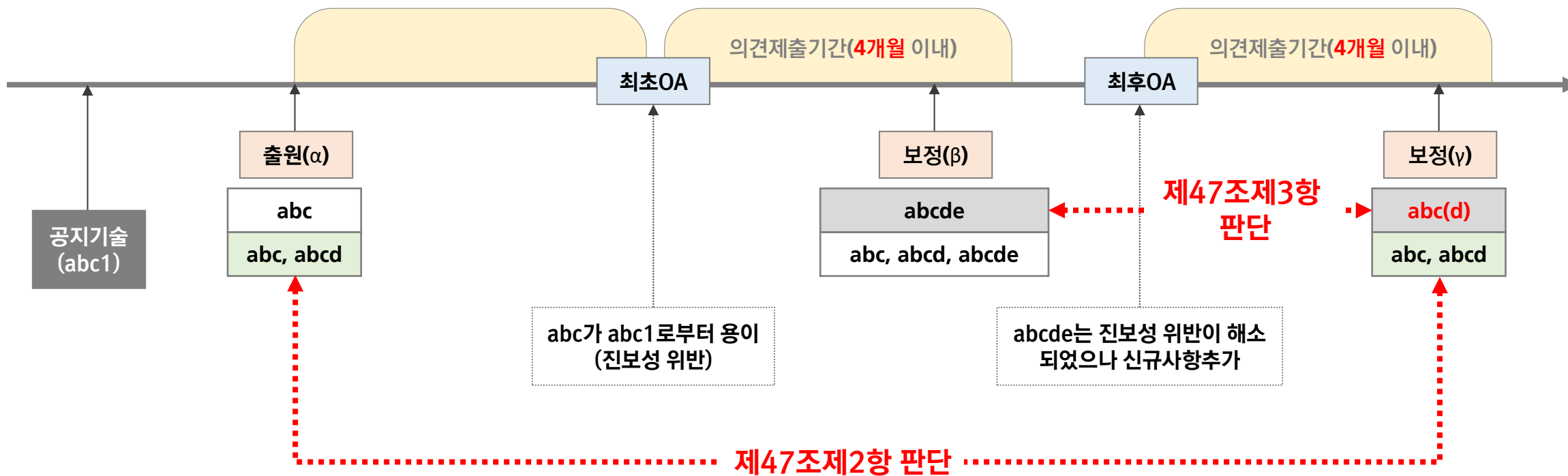
- ① **우선권주장의 기초가 된 제1국 출원 또는 선출원**은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 해당되지 않으므로 신규사항의 추가 여부 판단의 기초로 사용할 수 없다.
- ② **요약서**는 명세서 또는 도면에 해당하지 않으므로 신규사항 추가 여부를 판단하는 기준이 되는 최초 명세서 등에 포함되지 아니한다.
- ③ **미완성발명을 완성시키는 보정**을 한 경우 그 보정은 신규사항을 추가한 것으로 된다.
- ④ **상위개념을 하위개념으로 보정**하여 범위를 축소하였더라도(재질이나 용도한정의 경우 포함), 최초 명세서 등에 그 하위개념이 개시되어 있거나, 출원 시의 기술상식을 참작하여 통상의 기술자에게 그러한 상위개념이라고 하면 보정된 하위개념으로 바로 인식될 정도가 아니면 신규사항 추가에 해당한다.
- ⑤ **하위개념을 상위개념으로 보정**하는 경우, 그 상위개념 중에 최초 명세서 등의 하위개념과 비교하여 발명의 효과 또는 과제해결 여부가 달라지는 부분이 포함되면 신규사항의 추가에 해당한다. 일부 구성을 삭제하는 경우에도 그 삭제되는 구성이 최초 명세서 등에서 과제해결을 위하여 필수적인 것으로 기재된 것이라면 신규사항추가에 해당한다. 다만, 과제해결과 관계없이 임의로 부가된 사항을 삭제하여 상위개념이 되는 경우라면 최초 명세서 등 범위 내의 보정으로 볼 수 있다.
- ⑥ **수치범위를 추가하거나 변경 또는 감축하는 보정**의 경우에, 새로운 수치범위가 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고, 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하지 않은 경우에는 신규사항 추가에 해당한다.
- ⑦ **청구항에서 일정한 사항을 제외하는 보정(이른바 ‘제외 클레임’ 보정)**은, 그러한 제외하는 한정이 최초 명세서 등에 기재된 것으로 볼 수 없는 새로운 기술적 사항이 도입되는 것이 아니라면 허용된다. 특히 의료방법 관련 발명의 대상이 사람인지 동물인지가 명시되어 있지 아니한 경우, 그 발명이 특정 동물만을 대상으로 하는 것은 아닌 것이 자명할 때 사람에게 해당하는 부분을 삭제하기 위하여 한정하는 보정은 신규사항이 추가된 것으로 보지 않는다.
- ⑧ **최초 명세서 등에 독립적으로 기재된 개별구성이나 실시예들을 하나의 발명으로 결합하는 보정**을 하는 경우, 그러한 결합이 최초 명세서 등에 언급되어 있거나 통상의 기술자가 출원시의 기술상식에 비추어 당연히 상정할 수 있는 정도가 아니면 신규사항 추가에 해당한다.
- ⑨ **일반적으로 실시예 또는 시험예를 추가하는 보정**은 신규사항 추가에 해당한다. 다만, 최초 명세서 등의 기재 범위 내로 볼 수 있는 경우에는 신규사항 추가에 해당하지 않는다.
- ⑩ **일반적으로 발명의 새로운 효과를 추가하는 보정**은 신규사항 추가에 해당한다. 다만, 최초 명세서 등에 기재된 발명의 구성 등으로부터 통상의 기술자가 당연히 예측할 수 있는 정도이거나 최초 명세서 등에 기재된 발명의 구성이 그러한 효과를 나타낸다는 것이 해당 기술분야에서 잘 알려진 사실인 경우에는 신규사항 추가에 해당되지 않는다.
- ⑪ **선행기술 문헌명을 명세서에 단순히 추가하는 보정과 선행기술 문헌명과 함께 그 문헌 내용의 간략한 요약만을 추가하는 보정**은 신규사항 추가로 보지 않는다. 다만, 미완성 발명이 완성되도록 하거나 발명의 실시 등에 관한 발명의 설명 기재요건 미비를 해소하기 위하여 선행기술문헌의 내용을 추가하는 보정, 또는 출원발명의 이점을 제시하기 위하여 출원발명과 선행기술을 비교하는 내용을 추가하는 보정은 일반적으로 신규사항 추가에 해당한다.
- ⑫ 통상의 기술자가 최초 명세서 또는 도면에 오기가 있음을 인식할 수 있고, 그러한 오기가 무엇으로 정정되어야 하는지도 명확히 알 수 있다면, 그와 같은 오기의 정정은 신규사항 추가로 보지 않는다. 또한 명세서 또는 도면 중에 상충하는 2개 이상의 기재 중 어느 것이 올바른 지가 최초 명세서 등의 기재로부터 통상의 기술자에게 자명한 경우, 그 올바른 기재로 일치시키는 보정은 신규사항 추가가 아니다.
- ⑬ **보정된 사항이 주지관용기술**이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아닌 경우 신규사항추가이다.

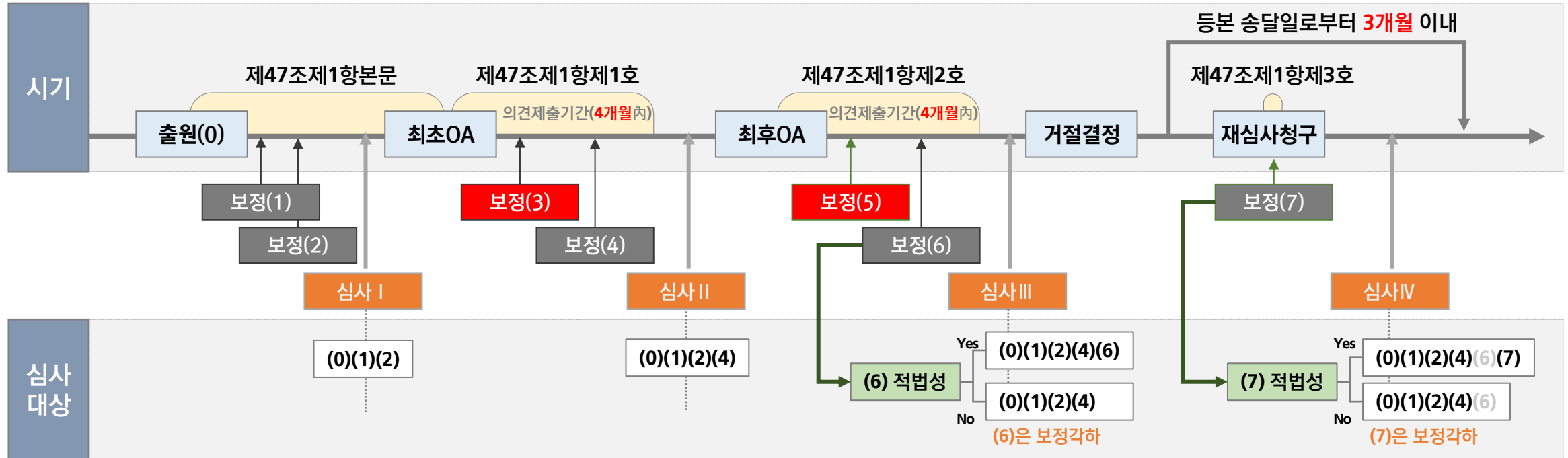
청구범위의 감축이란 **청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가**하는 것을 말한다. 여기서, 「청구항을 한정」 하는 경우는 i) 택일적으로 기재된 요소의 삭제, ii) 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경, 또는 iii) 수치범위의 축소 등을 말한다. 「청구항을 삭제」 하는 경우는 청구항을 직접 삭제하는 경우뿐만 아니라 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항수를 감소하는 것도 포함된다. 한편, 「청구항에 부가」 하는 경우는 청구항의 구성요소를 직렬적으로 부가하는 것을 의미한다.

구성요소 보정	직렬적 요소 (AND)	병렬(택일)적 요소 (OR)
부가	청구범위의 감축	청구범위의 확장
삭제	청구범위의 확장	청구범위의 감축

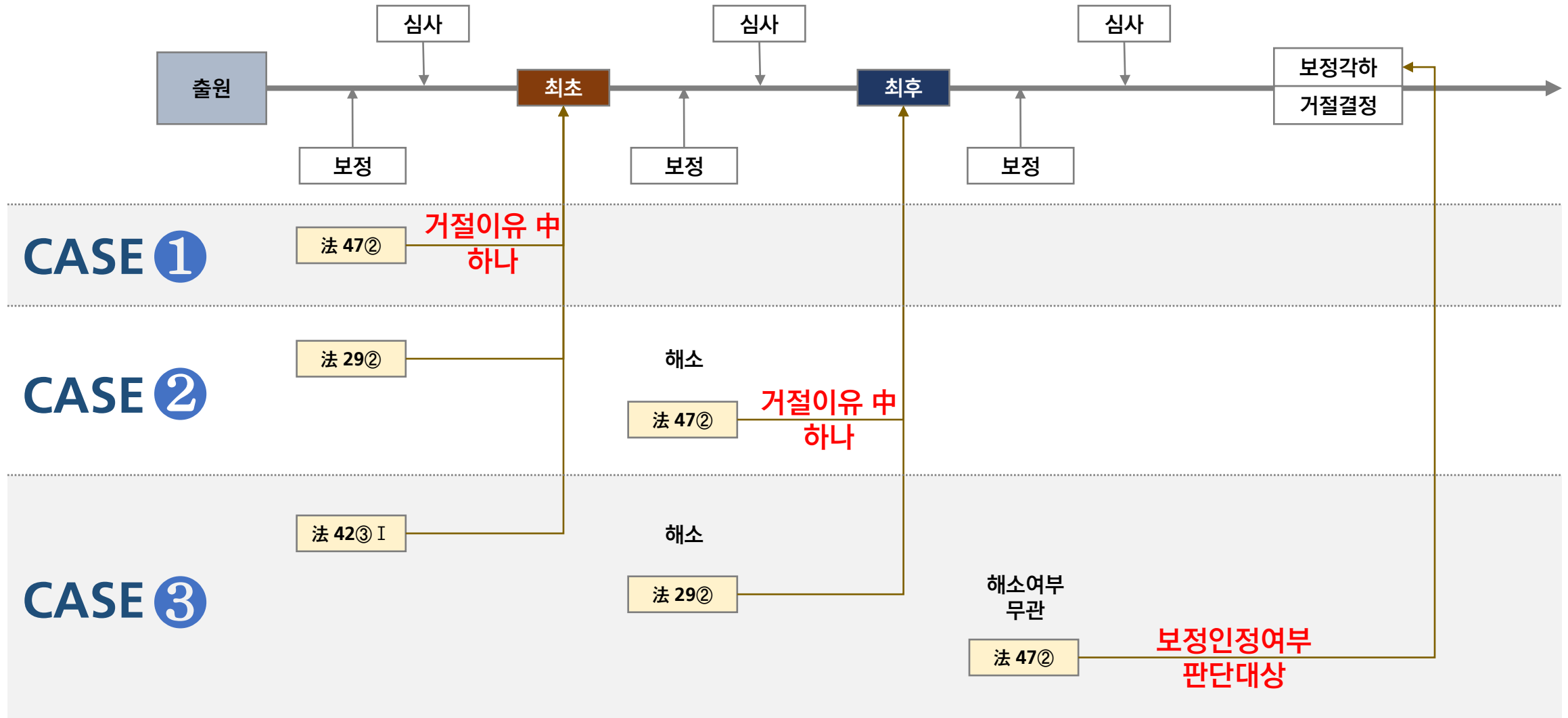
구 분	구체적 예
상위개념의 기재로의 변경	당초: ...스프링으로 지지되는..... →탄성체로 지지되는...
직렬적 구성요소의 삭제	당초: A, B, C, D로 구성된 자동차 → A, B, C로 구성된 자동차
직렬적 구성요소의 가감	당초: A, B, C로 구성된 장치 → B, C, D, E로 구성된 장치
수치범위의 확장	당초: 10 ~ 50° C의 온도에서... → 10 ~ 70° C의 온도에서....
구성요소의 치환	당초: 볼트로 결합시킨... → 리벳으로 결합시킨....
수치범위의 변경	당초: 10 ~ 20° C의 온도에서... → 30 ~ 50° C의 온도에서....
택일적 요소의 추가	Fe 또는 Al로...→ Fe, Al 또는 Cu로....
인용항의 추가	청구항1에 있어서...→ 청구항1 또는 청구항2에 있어서....
항 정리 차원에서 청구항의 신설 (청구범위의 감축)	(보정 전) 【청구항 1】 구성요소 A, B, C 로 이루어진 물건 【청구항2】 청구항 1에 있어서, 구성요소 A 는 a1, a2, a3 중 하나로 이루어진 물건 (보정후) 【청구항 1】 삭제 【청구항 2】 (정정) 구성요소 a1, B, C 로 이루어진 물건 【청구항 3】 (청구항 2 정정) 구성요소 a2, B, C 로 이루어진 물건 【청구항 4】 (청구항 2 정정) 구성요소 a3, B, C 로 이루어진 물건

보정(β)된 명세서 또는 도면이 출원(α)의 명세서 또는 도면과 비교하여 신규사항추가라는 이유로 최후거절이유가 통지된 경우 보정(γ)이 적법하기 위해서는 i) 신규사항추가가 아닐 것(法 47②), ii) 청구범위 보정범위의 제한을 만족할 것(法 47③), iii) 보정에 따라 새로운 거절이유가 생기지 않을 것을 만족하여야 한다. 그런데, 신규사항추가인지 여부(法 47②)는 출원(α)의 명세서 또는 도면과 보정(γ)된 명세서 또는 도면을 비교하여 판단하고, 청구범위 보정범위의 제한을 만족하는지 여부(法 47③)는 보정(β)된 청구범위와 보정(γ)된 청구범위를 비교하여 판단한다. 이 경우 최후거절이유를 해소하기 위해 신규사항추가한 사항을 삭제하는 보정을 하려고 하는 경우 청구범위의 확장으로 제47조제3항제1호 위반의 문제가 될 수 있기 때문에, 제47조제3항제4호에서 그 예외를 인정하고 있다.

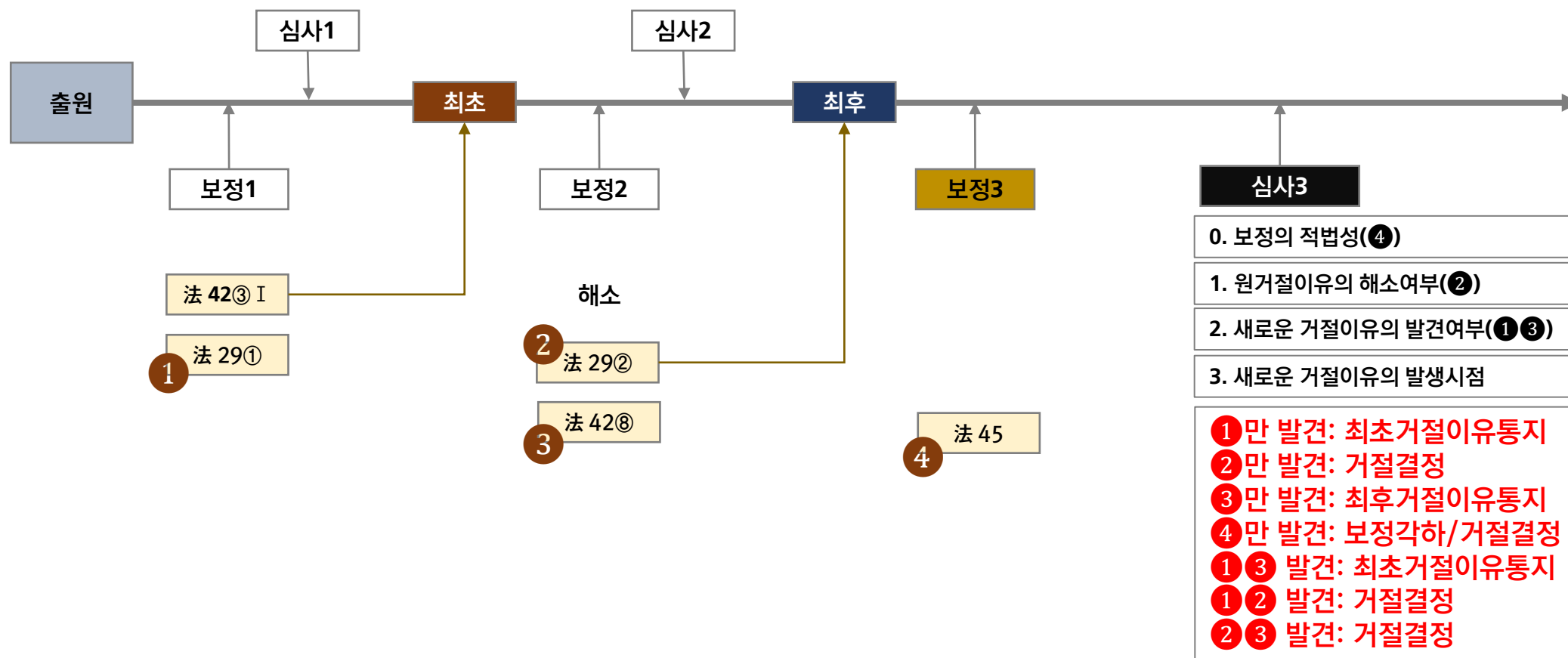




보정대상항목	최초출원 (0)	최초거절이유통지 전(法 47①본문)		심사대상 명세서 또는 도면 (0)(1)(2)	최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① I)		심사대상 명세서 또는 도면 (0)(1)(2)(4)
		제1차 보정서 (1)	제2차 보정서 (2)		제3차 보정서 (3)	제4차 보정서 (4)	
발명의 설명	◇	◇1	◇2	◇2			◇2
제1항	○		○2	○2	○3		○2
제2항	□	□1		□1	□3	□4	□4
제3항	△			△	△3		△
-							
제10항	☆			☆	☆3	☆4	☆4
도면	♠	♠1		♠1	♠3		♠1



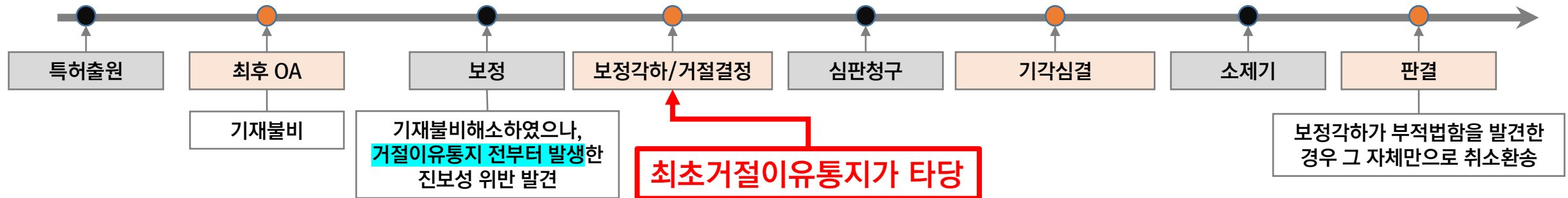
「그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우」란 그 보정서의 제출로 인해 전에 없던 거절이유가 발생한 것을 의미한다. 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우라면 심사관이 다시 거절이유를 통지하지 않고 보정각하를 한 후 최후거절이유통지 당시의 심사대상 명세서로 특허거절결정을 할 수 있도록 하여 심사의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다. 다만, 최후거절이유통지에 대한 보정을 하였으나 여전히 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 보정은 적법하나 거절이유가 동일하여 특허거절결정된다.



대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121 판결 【거절결정(특)】

【1】 2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 구 특허법 제174조에 의하여 구 특허법 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 위 규정에서 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 그 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 보면, 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.

【2】 특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 ‘보정 전의 특허출원’에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 그 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.



청구항을 삭제하는 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우

구체적 예	설명
청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C를 부가한 장치 【최후거절이유통지】 청구항 1은 진보성 없음. 【최후보정 후의 명세서】 청구항 1 : 삭제 청구항 2 : 청구항 1 에 있어서, C를 부가한 장치	【보정인정】 청구항 1을 삭제하는 보정은 청구범위의 감축에 해당함. 청구항 1의 삭제로 청구항 2에 기재불비라는 새로운 거절이유가 발생하였으나 제51조제1항 괄호 규정에 의하여 보정은 인정함 【최후거절이유통지】 청구항을 삭제하면서 제42조제4항제2호 위반의 새로운 거절이유가 생긴 경우 다시 최후거절이유통지를 함.
청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : A+E로 이루어진 장치 청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, C를 부가한 장치 【최후거절이유통지】 청구항 1은 진보성 없음. 【최후보정 후의 명세서】 청구항 1 : 삭제 청구항 2 : A+E로 이루어진 장치 청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, C를 부가한 장치	【보정인정】 청구항 1을 삭제하는 보정은 청구범위의 감축에 해당함. 한편, 청구항 3은 삭제된 청구항 1을 인용하고 있지만 삭제된 청구항 1의 인용을 제외하고 해석하여 청구항의 발명이 A+E+C로 명확하게 파악되기 때문에 오기임이 명백한 경우로 취급하여 보정을 인정함 【특허결정】 특허결정하면서 명백한 오기에 대해서는 직권보정함

청구항을 삭제하는 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우

대법원 2014. 7. 10 선고 2013후2101

1

단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사 때 다른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우’에 포함된다고 할 것이다.

청구항	보정전	보정후
22	C	C1
23	제22항에 있어서, C는 C1	삭제
24	제23항에 있어서, C1은 C2	제22항에 있어서, C1은 C2
25	제24항에 있어서, C2는 C3	제22항에 있어서, C2는 C3

대법원 2018. 6. 28 선고 2014후553

3

청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에는 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서, 그 인용번호를 잘못 변경하거나, 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재 누락함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’도 포함된다고 보아야 한다.

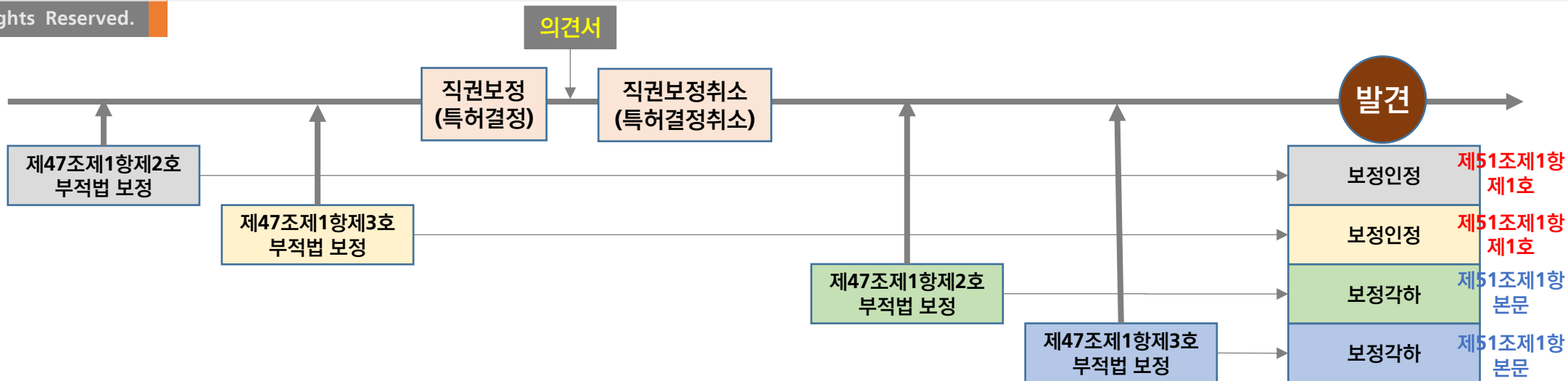
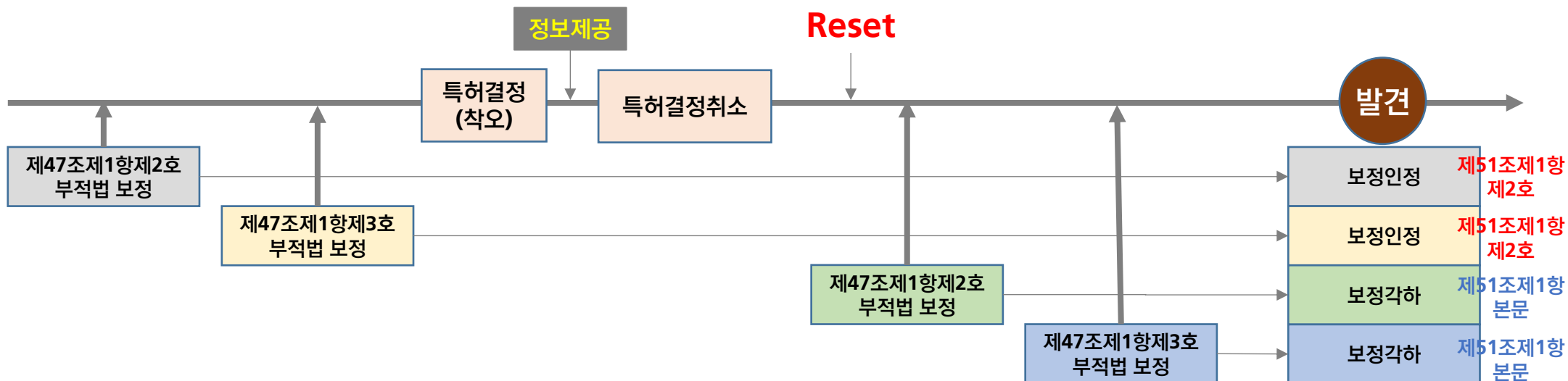
보정전	보정후
상기 제1항, 제2항, 제3항, 제4항 또는 제8항의 인 함유 구리 애노드	상기 제1항, 제2항, 제3항의 인 함유 구리 애노드

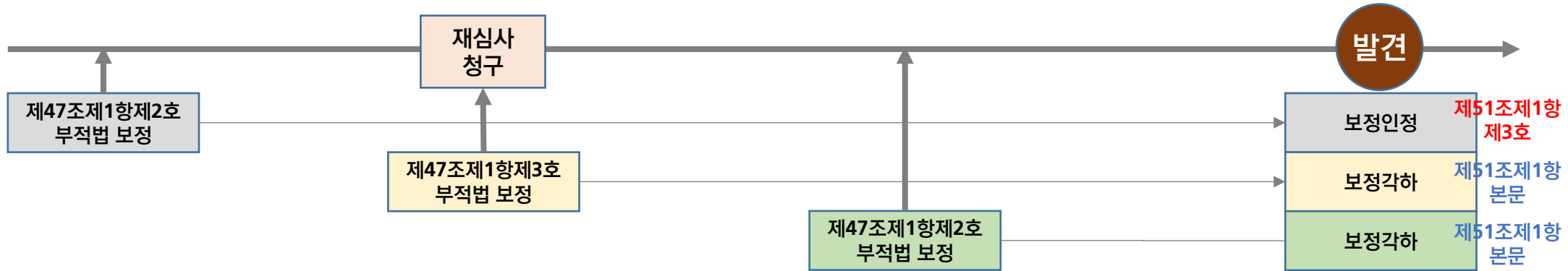
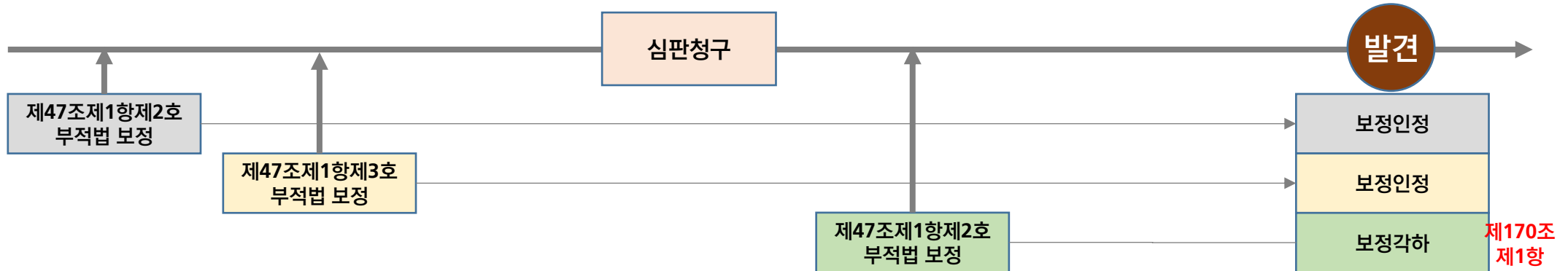
대법원 2018. 7. 12 선고 2015후2259

4

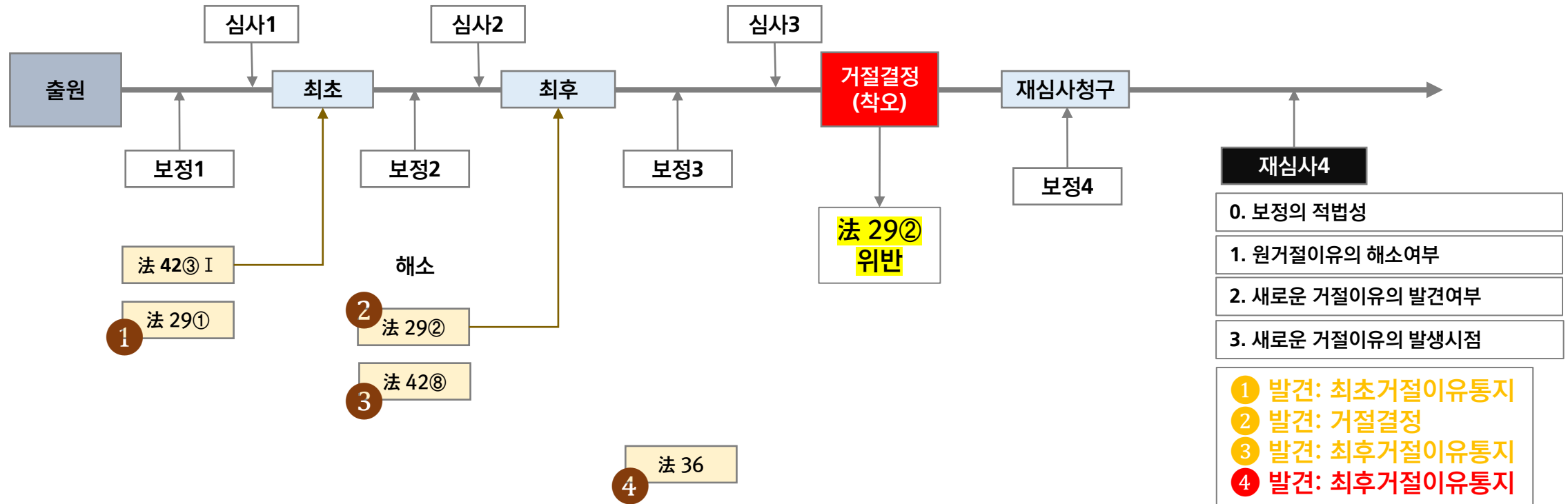
이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사 때 다른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다.

보정전	보정후
적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지는 것을 특징으로 하는 방법	적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지고

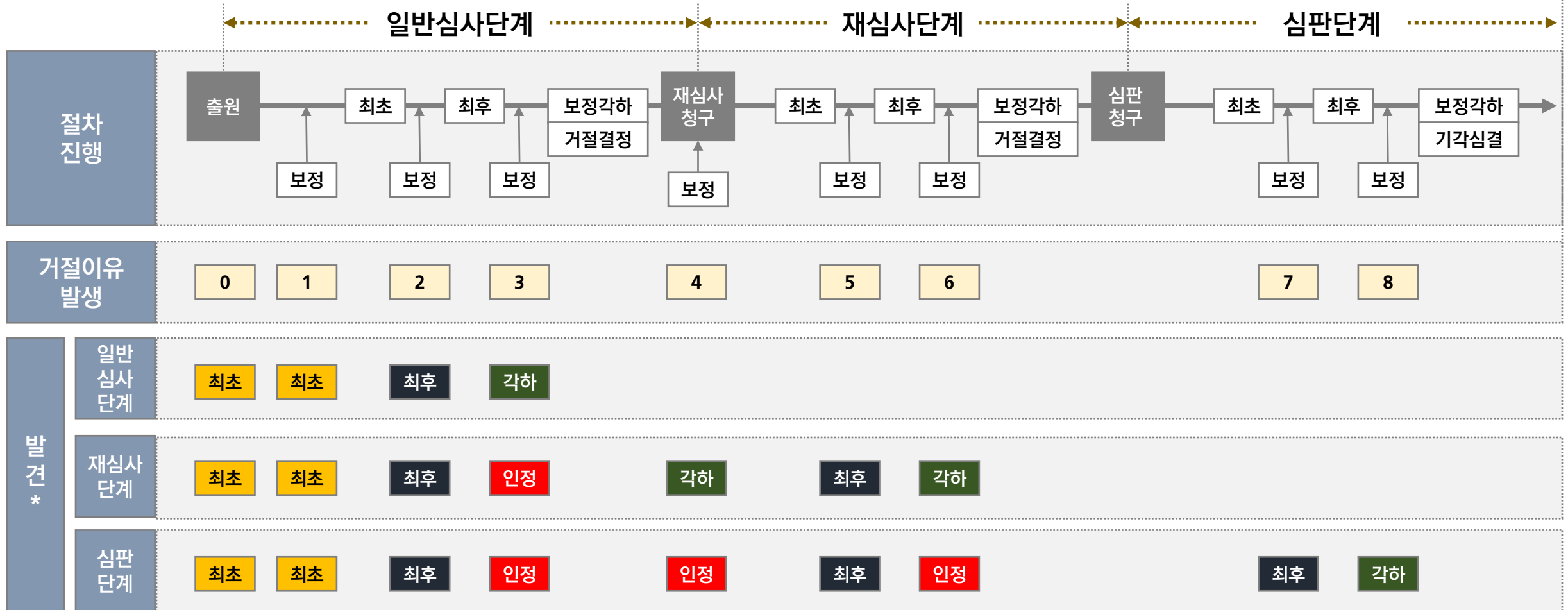
제51조
제1항
제1호제51조
제1항
제2호

제51조
제1항
제3호제170조
제1항

재심사의 청구 전에 한 부적법한 보정이 재심사 청구 발견된 경우



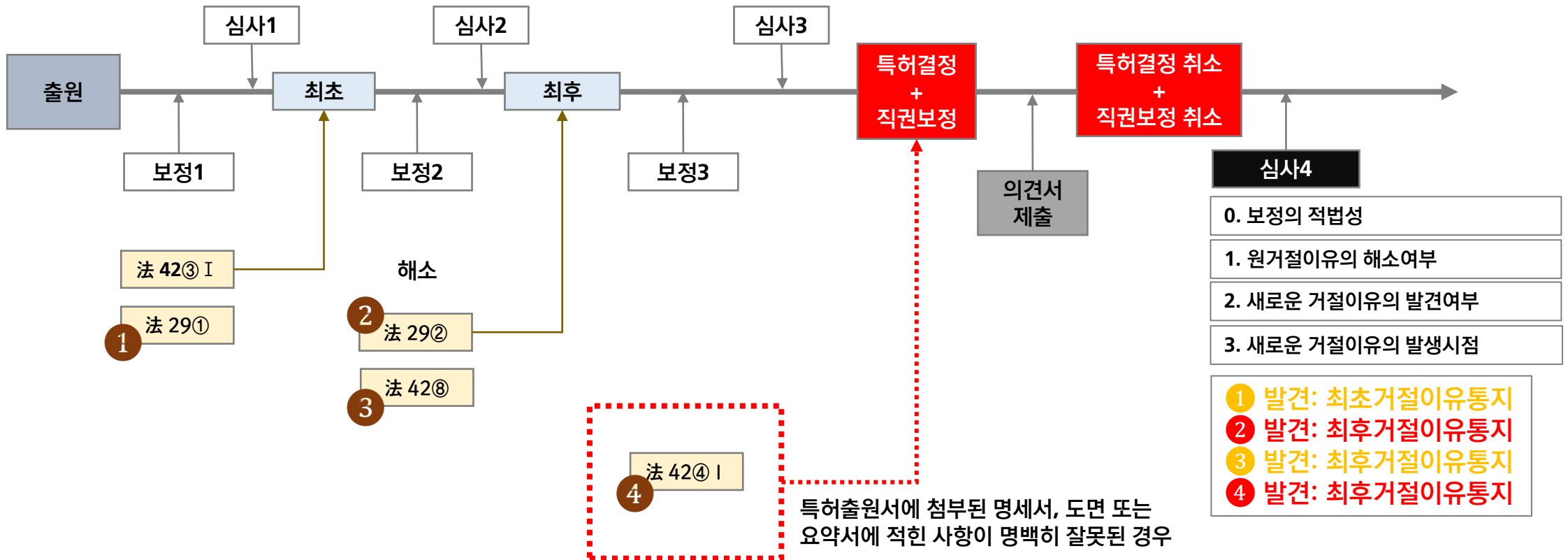
심판청구 전 부적법한 보정이 심판청구 후 발견된 경우



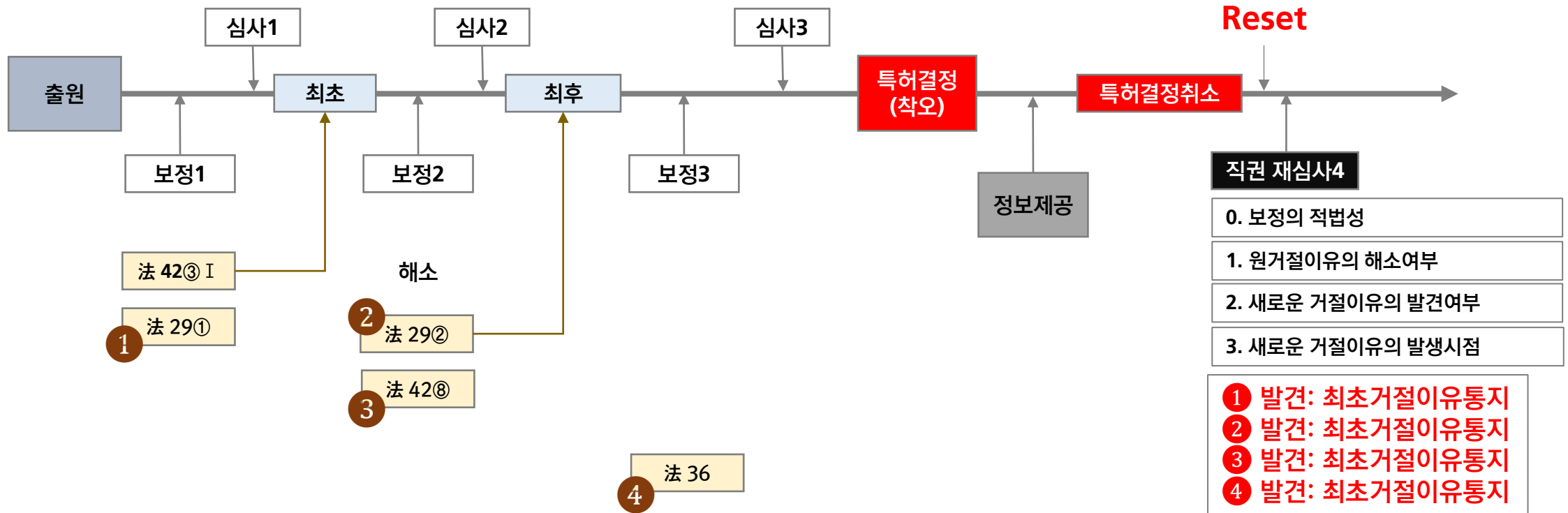
* 2, 5, 7은 원거절이유가 해소됨을 전제로, 3, 4, 6, 8은 원거절이유 해소 여부와 무관하게 적용

직권보정 전에 한 부적법한 보정이 특허결정이 취소된 후 발견된 경우

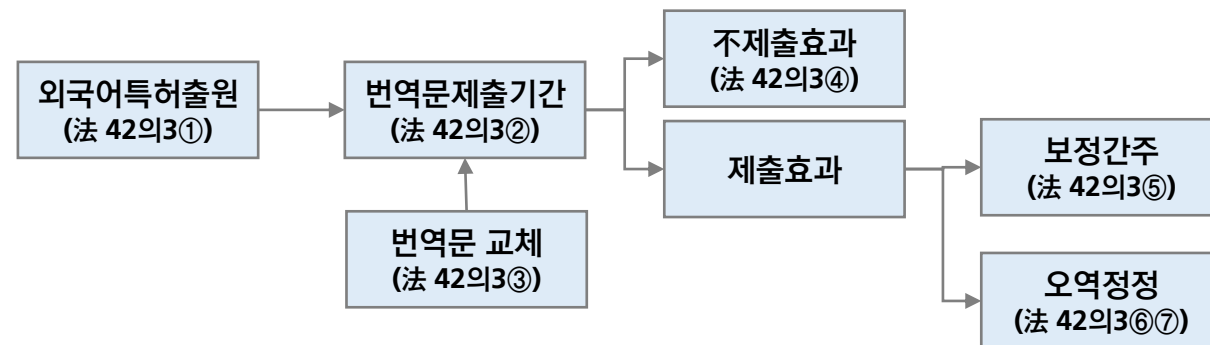
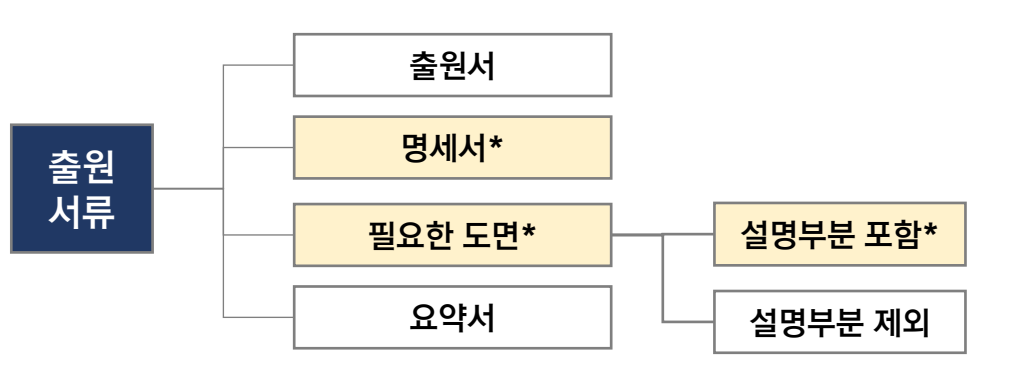
발생한 새로운 거절이유가 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 경우



취소된 특허결정 전에 한 부적법한 보정이 직권 재심사 후 발견된 경우

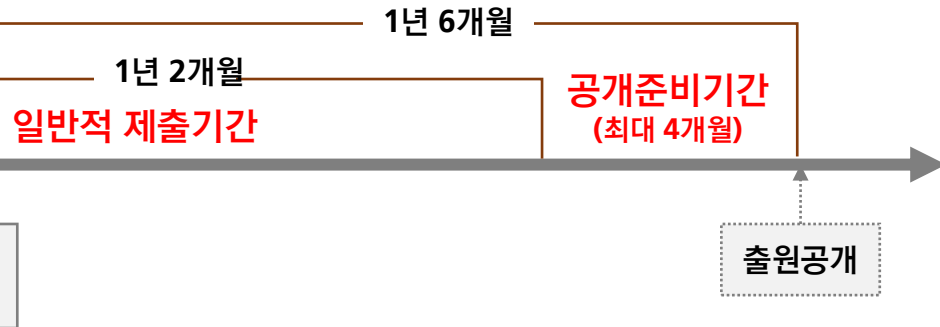


- 제42조의3(외국어특허출원 등)** ① 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 총리령으로 정하는 언어로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다.
- ② 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 특허출원인은 제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우
 2. 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우
- ④ 특허출원인이 제2항에 따른 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.
- ⑤ 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ⑥ 특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.
- ⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.



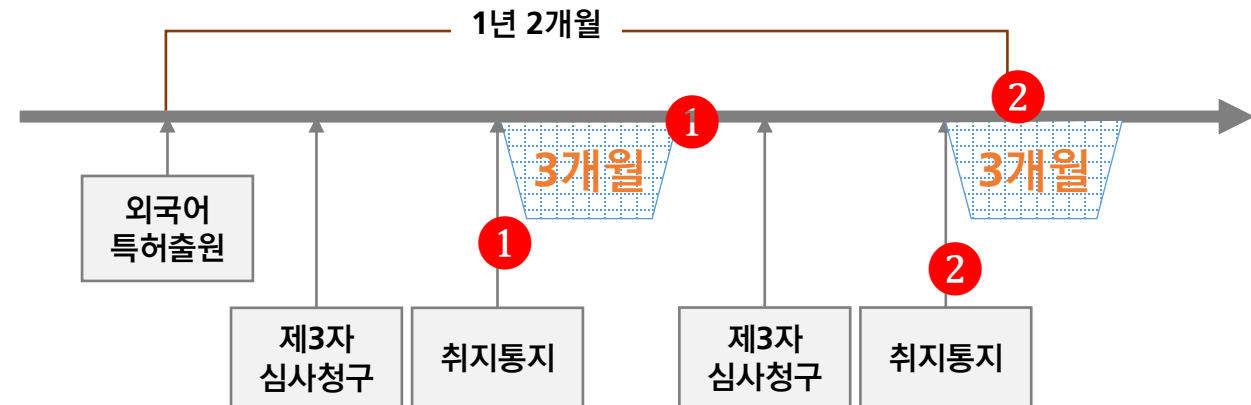
원칙적 제출기간

(제42조의3제2항본문)



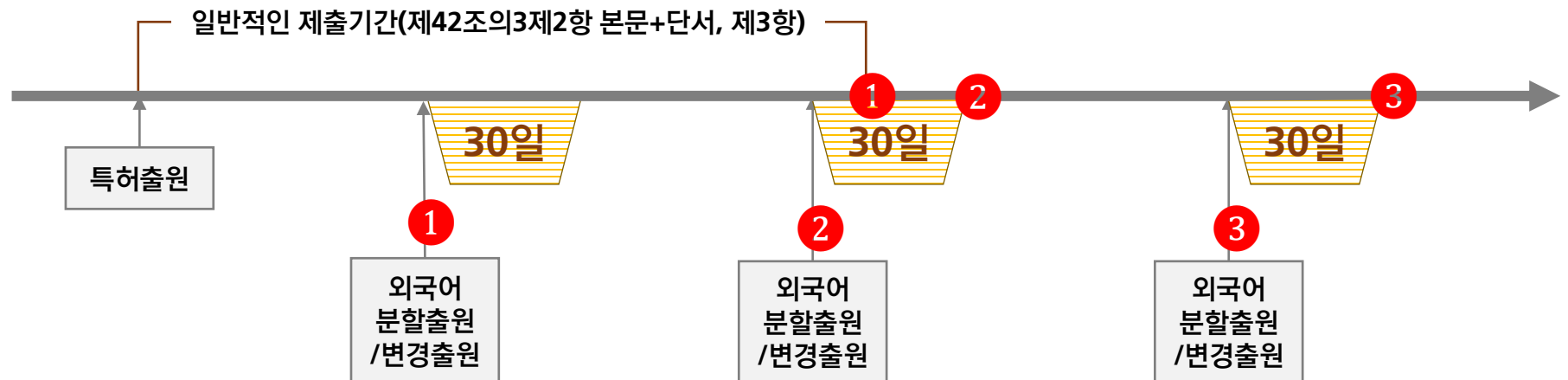
제3자의 심사청구

(제42조의3제2항단서)



분할출원, 변경출원

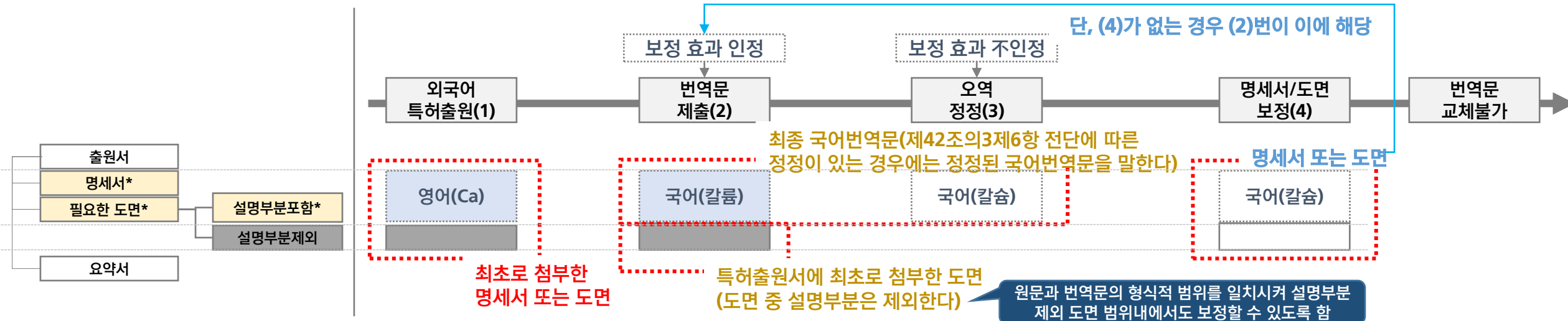
(제52조제7항, 제53조제7항)



* 분리출원의 경우 외국어특허출원 불가

제47조(특허출원의 보정) ② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 **최초로 첨부한 명세서 또는 도면**에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 **최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)**에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.

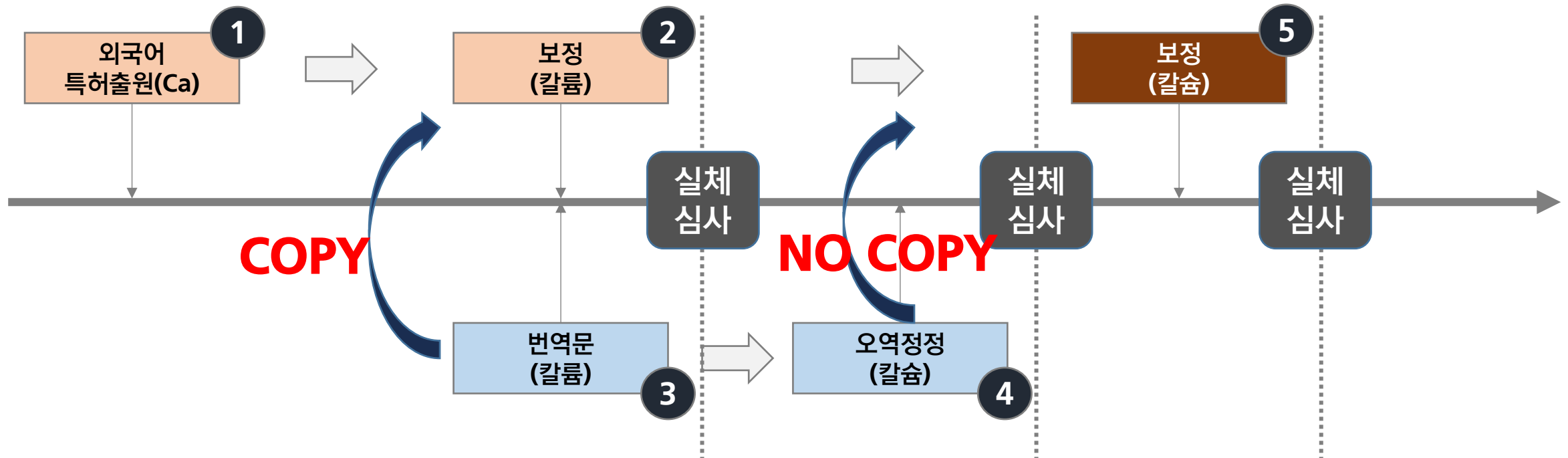
⑤ 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.



원문 (Ca)(1)	국어번역문 (칼름)(2)	오역정정 (칼숨)(3)	명세서보정 (칼숨)(4)	신규사항추가의 판단
○	○	-	-	(2)가 (1)(法 47②전단)과 (2)(法 47②후단)의 기재된 사항의 범위를 만족했는지 여부에 의하여 판단 → 제47조제2항 전단에 위반됨
○	○	○	-	(2)가 (1)(法 47②전단)과 (3)(法 47②후단)의 기재된 사항의 범위를 만족했는지 여부에 의하여 판단 → 제47조제2항 전단과 후단에 위반됨
○	○	-	○	(4)가 (1)(法 47②전단)과 (2)(法 47②후단)의 기재된 사항의 범위를 만족했는지 여부에 의하여 판단 → 제47조제2항 후단에 위반됨
○	○	○	○	(4)가 (1)(法 47②전단)과 (3)(法 47②후단)의 기재된 사항의 범위를 만족했는지 여부에 의하여 판단 → 제47조제2항 후단에 위반되지 않음

오역 정정은 명세서를 보정한 것이 아니라 국어번역문만을 정정한 것이기 때문에 국어번역문에 오역이 있는 경우에는 국어번역문에 대한 오역정정과 별도로 심사대상 명세서 등에 대하여 보정해야 함

오역 정정은 명세서를 보정한 것이 아니라 국어번역문만을 정정한 것이기 때문에 국어번역문에 오역이 있는 경우에는 국어번역문에 대한 오역정정과 별도로 심사대상 명세서 등에 대하여 보정해야 함



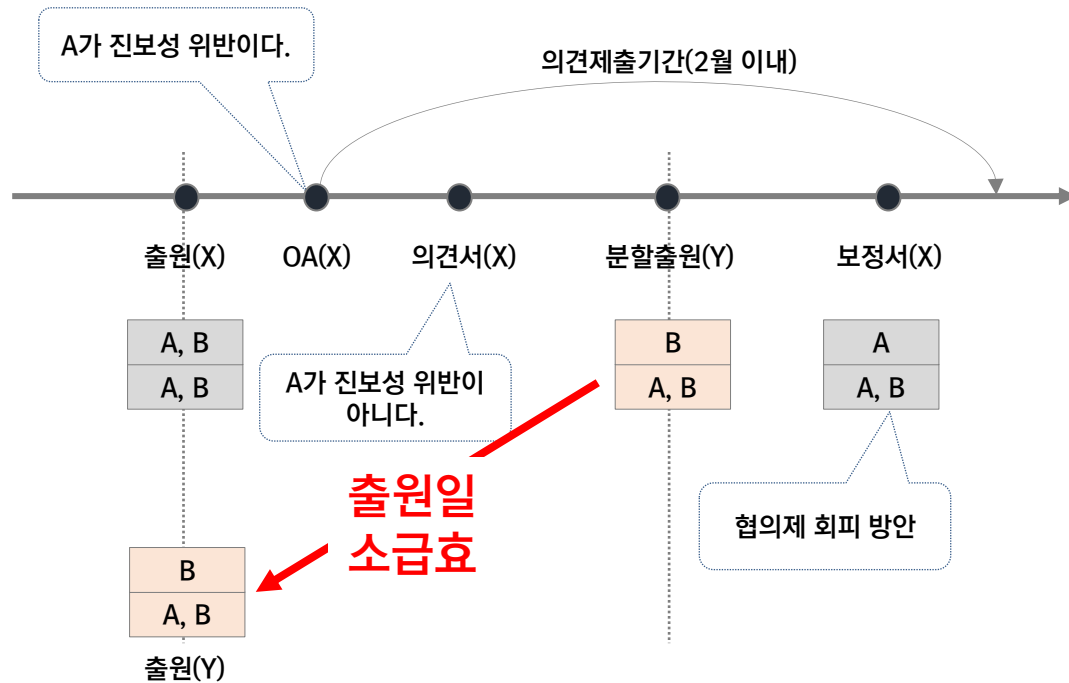
보정된 명도(2)가 원문(1)과 번역문(3)의 범위를 만족하는지 여부

보정된 명도(2)가 원문(1)과 번역문(4)의 범위를 만족하는지 여부

보정된 명도(5)가 원문(1)과 번역문(4)의 범위를 만족하는지 여부

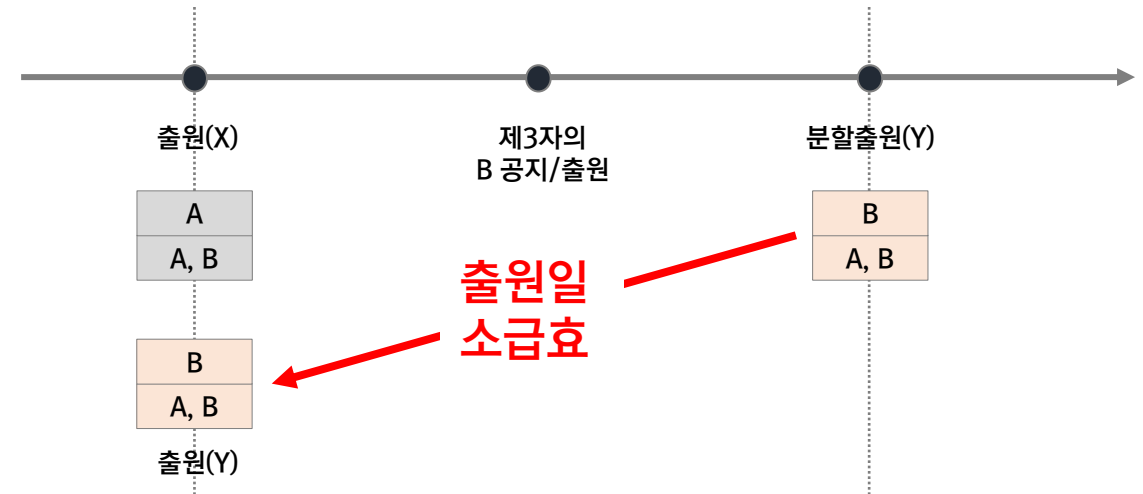
거절이유 대응형

- 심사관은 출원된 발명의 청구항별로 거절이유를 판단하지만, 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 출원전체를 거절결정함
- 따라서, 일부 청구항에 거절이유가 있는 경우 거절이유가 있는 청구항은 분할출원하여 대응방안을 모색하고, 거절이유가 없는 청구항은 먼저 등록받는 것이 바람직함
- 이때 분할출원의 심사청구시기와 청구항 수를 조절하여 비용을 절감함



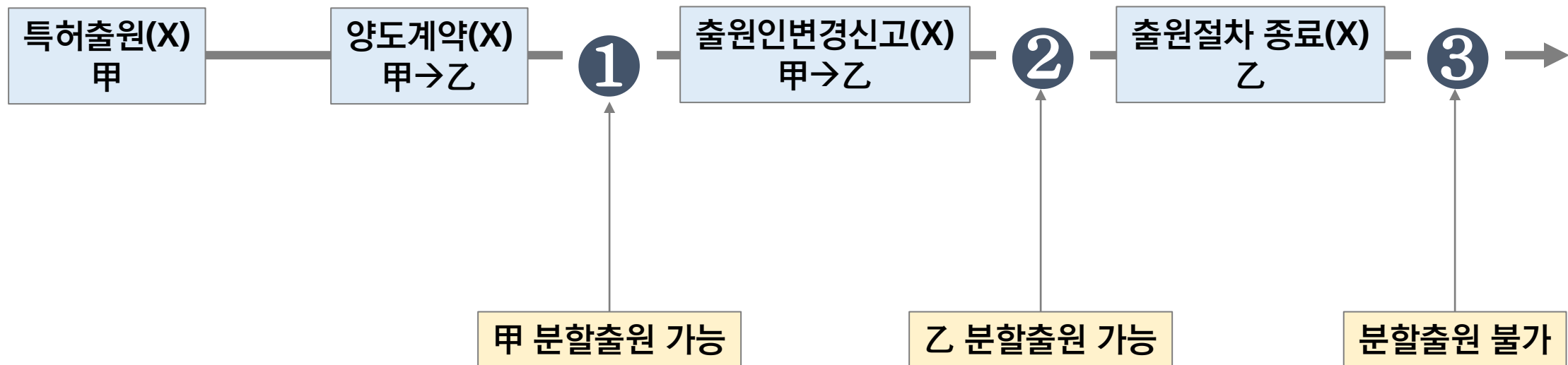
권리범위 재설계형

- 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 보호받고자 할 경우 분할출원을 이용함
- 특허결정등본이 송달된 후라도 시장에서 사용가능성이 있는 중요한 특허의 경우에는 권리범위를 재설계하여 특허 포트폴리오를 구축하기 위하여 분할출원을 이용함
- 이때 분할출원의 심사청구시기와 청구항 수를 조절하여 비용을 절감함

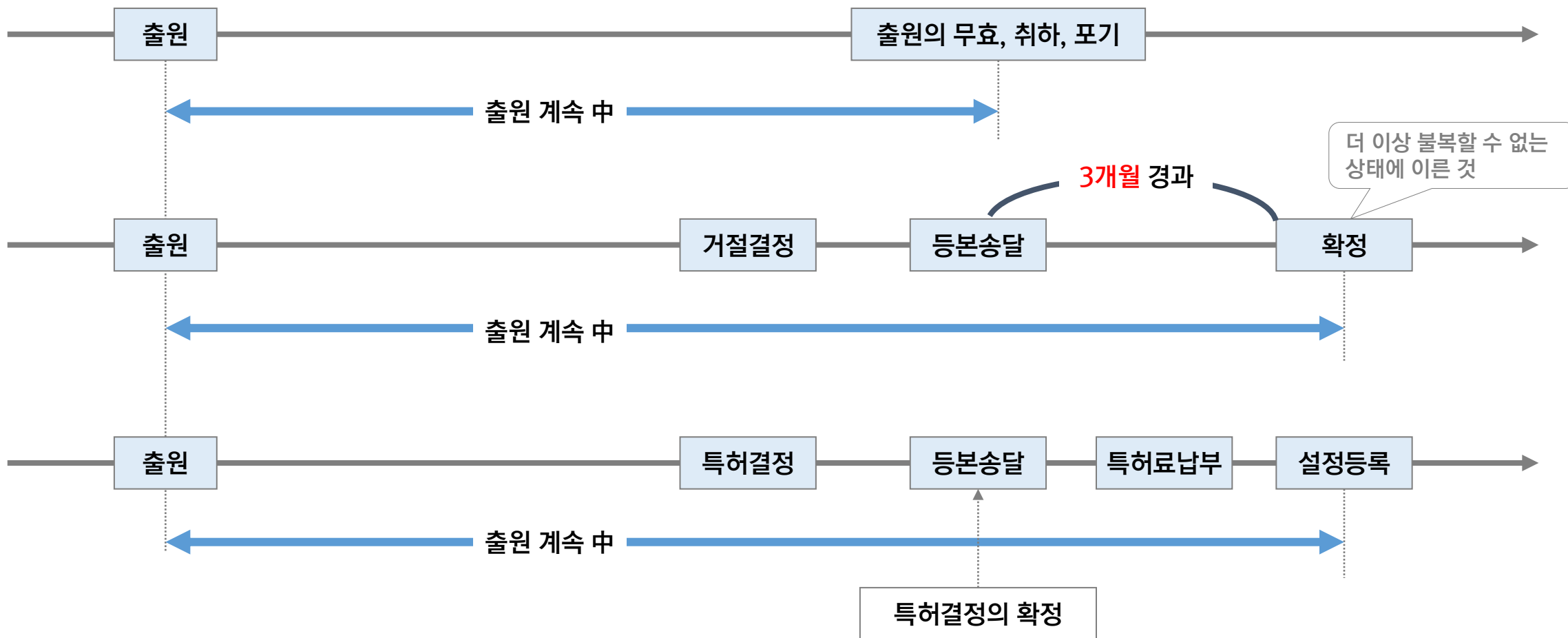


발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 보호받기 위한 조치로는 별도 출원, 보정, 분할출원, 우선권주장출원 등이 있으며, 각 제도의 장단점을 분석하여 대응방안을 모색함

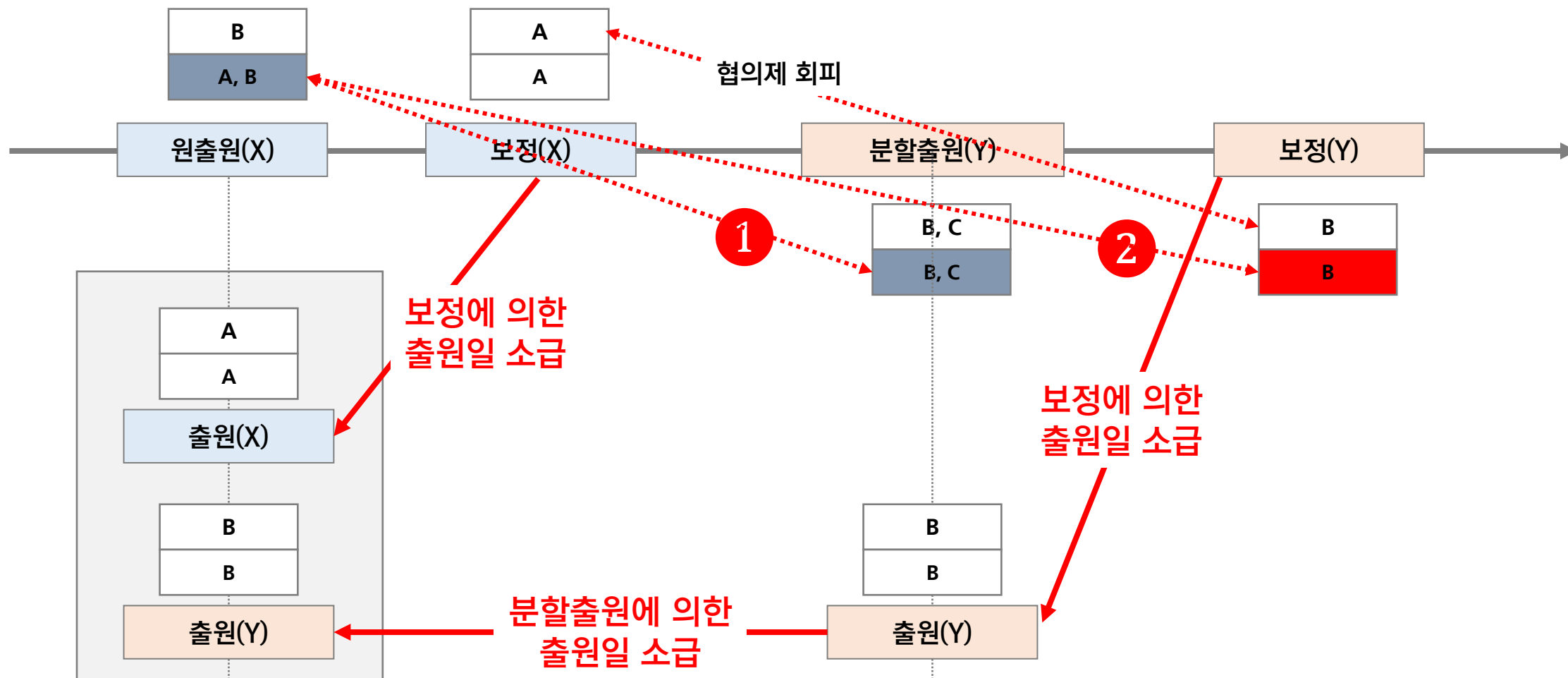
원특허출원의 「특허출원인」이 분할출원을 할 수 있다. 즉, **분할출원 당시 분할출원인은 원출원의 출원인 또는 그 승계인과 동일인**이어야 한다. 한편, 「분할출원 당시」 원출원이 적법하게 출원계속 중이어야 한다. 이미 출원절차가 종료된 출원에 관하여 분할출원을 인정해 준다면 행정절차가 복잡해지고 영속적으로 분할출원할 수 있는 권리를 인정하게 되어 절차의 안정성을 해치는 결과를 초래하기 때문이다. 따라서 분할출원 시에 원출원이 취하, 포기, 무효되거나 특허거절결정이 확정되어 원출원의 절차가 종료된 때에는 분할출원을 할 수 없다.



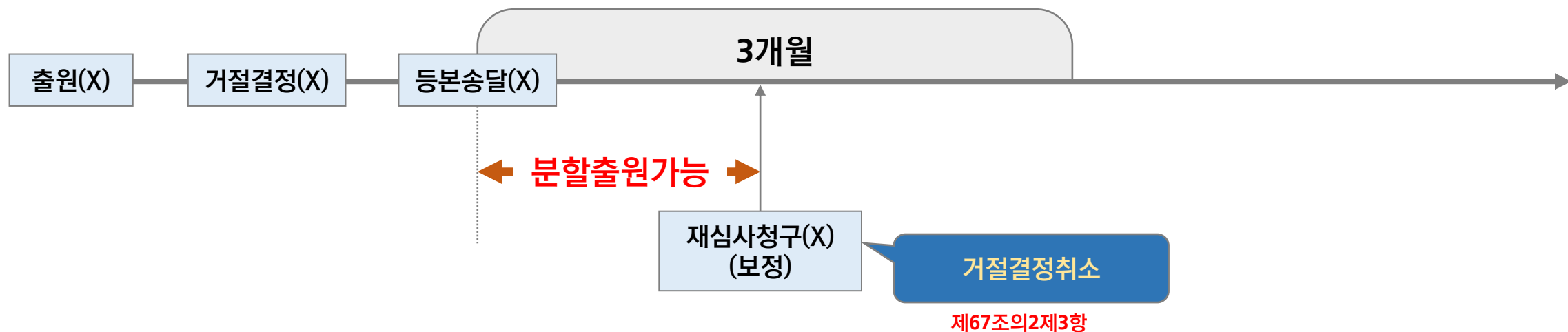
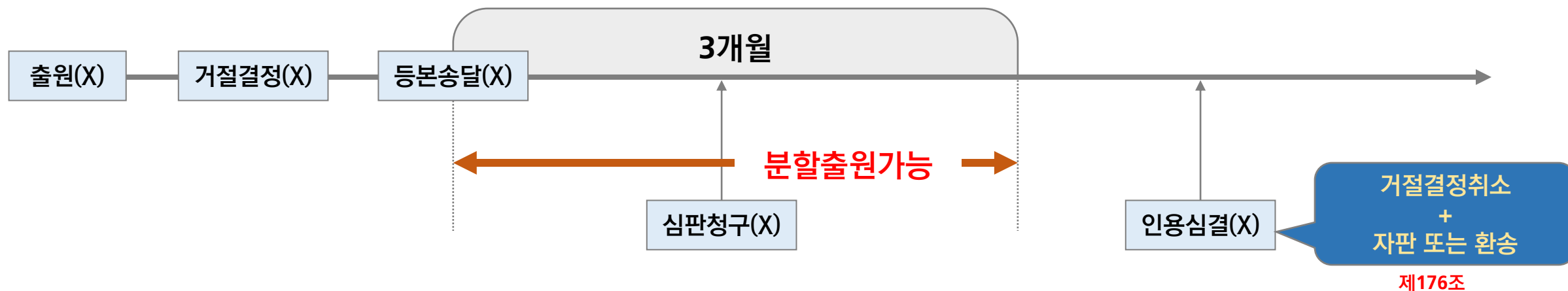
특허출원이 지식재산처에 출원계속 중인 경우란 출원에 대하여 지식재산처가 특허를 허여(제87조제2항에 따른 설정등록을 말한다)하는데 필요한 행정행위를 할 수 있는 상태를 말하는 것으로, **출원이 무효, 취하, 포기 또는 특허거절결정이 확정되기 전이나 설정등록되기 전**을 말한다.



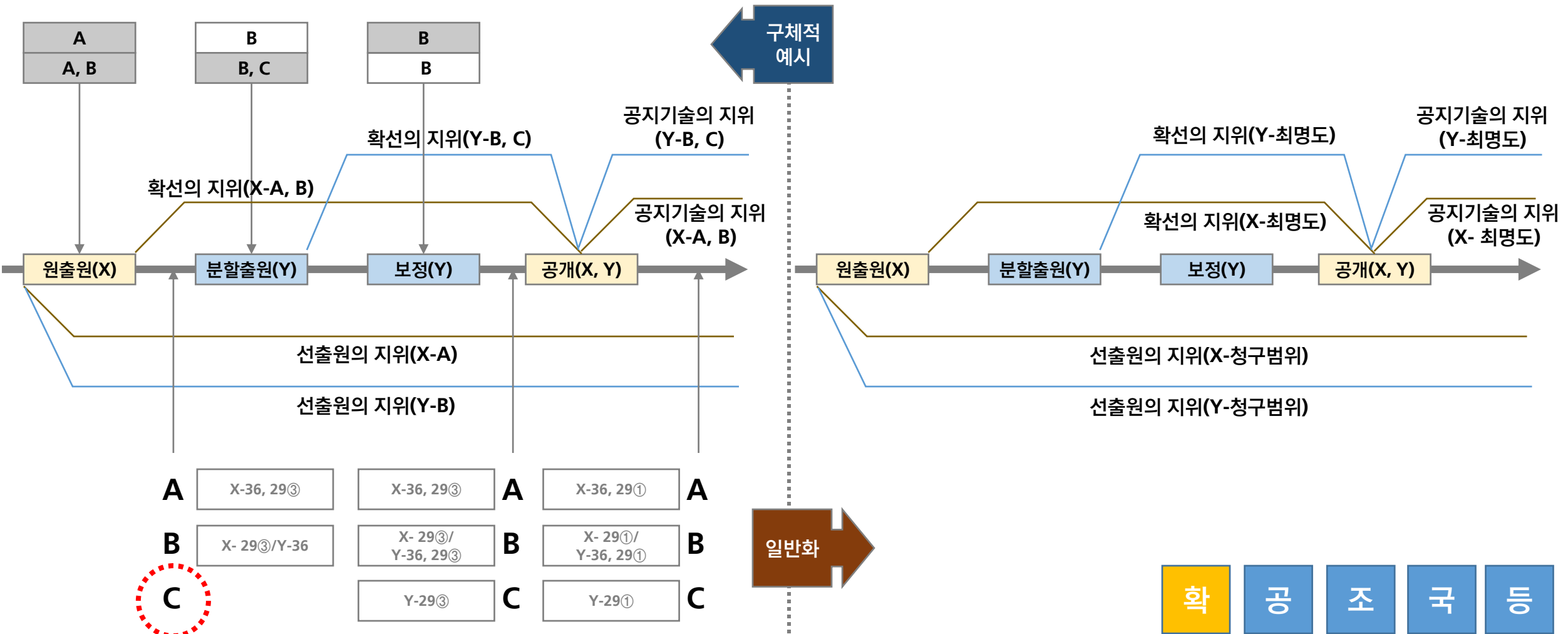
분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다. 「최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항」이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 말한다. 분할출원에 포함된 발명 중 일부라도 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에 있지 아니하면 거절이유에 해당한다(法 52①, 62).



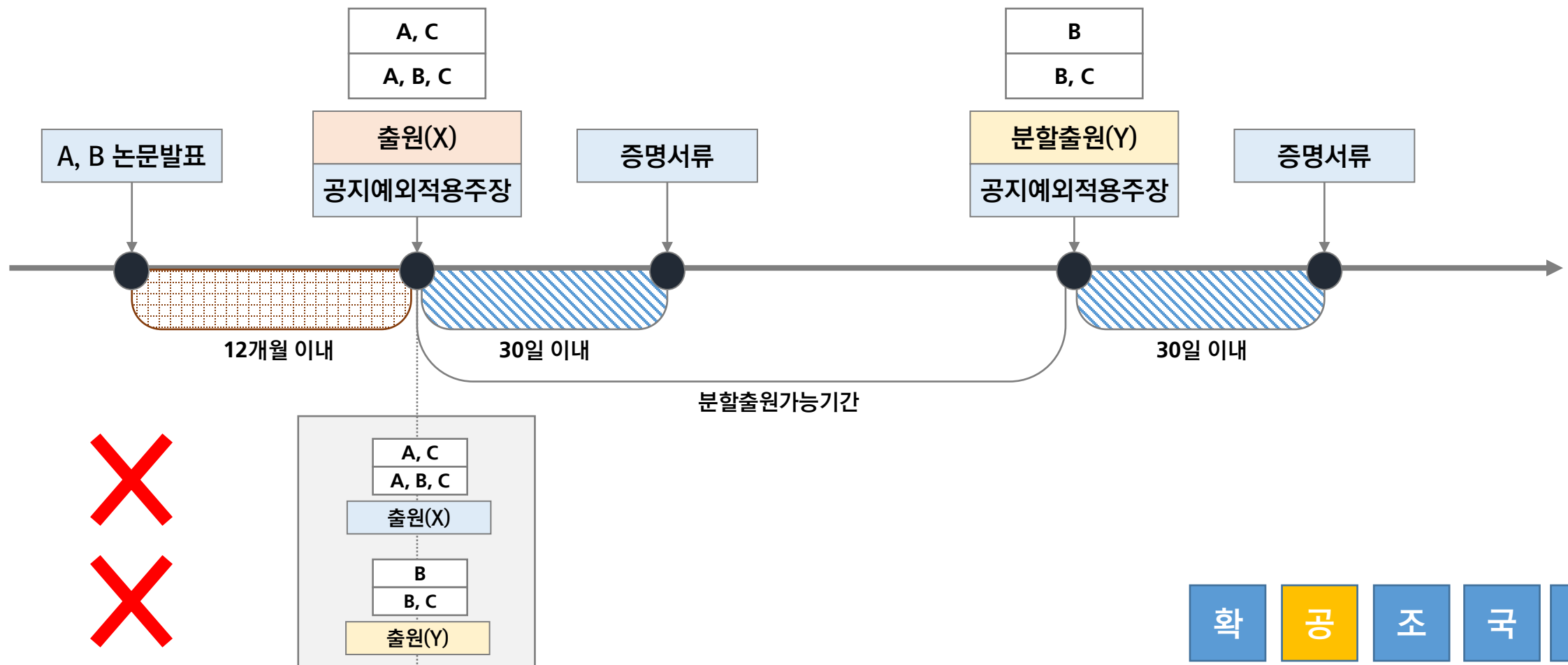
특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다)에는 거절결정불복심판을 청구하였더라도 분할출원을 할 수 있다. 다만, **재심사청구가 있는 경우에는 특허거절결정은 취소된 것으로 보므로 분할출원을 할 수 없다.** 물론, 재심사청구와 동시에 분할출원하거나 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 다시 분할출원을 할 수는 있다.



확대된 선출원에 관한 규정(法 29③④)에서의 다른 출원에 해당하는 경우 원출원의 최초 명세서 또는 도면에는 포함되어 있지 아니하지만 분할출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함된 발명에 의하여 원출원과 분할출원 사이의 제3자의 출원을 거절시키는 것은 먼저 출원하여 공개시킨 자에게 독점·배타적인 특허권을 부여한다는 특허법의 목적에 반하기 때문에 확대된 선출원을 적용할 때 소급효가 인정되지 않고 현실의 분할출원일을 기준으로 한다.

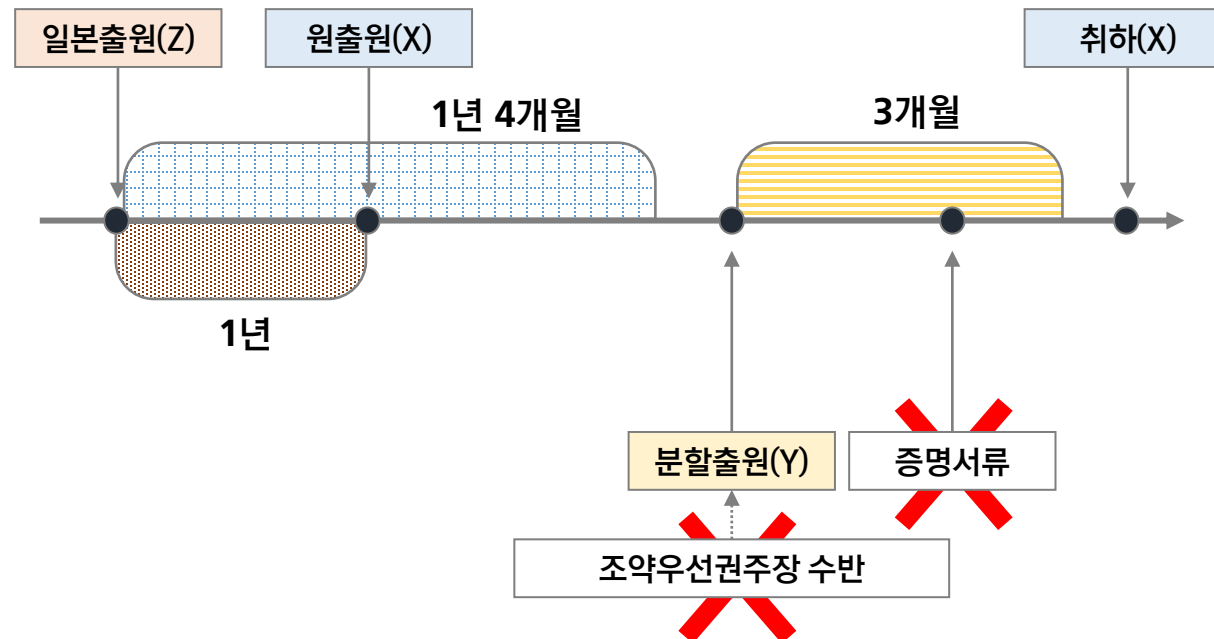


분할출원(Y)은 원출원(X)의 출원일로 소급효가 인정되는 것을 제외하고는 원출원(X)과는 별개의 특허출원이다. 따라서 원출원(X)이 공지에외적용주장을 하였다고 하여 분할출원(Y)이 그 효과를 누릴 수 있는 것은 아니며, 분할출원(Y)이 그 효과를 적용받기 위해서는 분할출원 역시 공지에외적용주장을 하여야 한다. 한편, 공지에외적용주장을 하기 위해서는 공지된 날로부터 12개월 이내에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 그 출원일로부터 30일 이내 증명서류를 제출하여야 한다. 그런데, 분할출원이 이와 같은 공지에외적용주장을 수반하는 경우에는 출원인의 이익을 위해서 12개월의 판단은 X출원일을 기준으로, 취지 및 증명서류에 대한 것은 Y출원일을 기준으로 판단하게 된다.

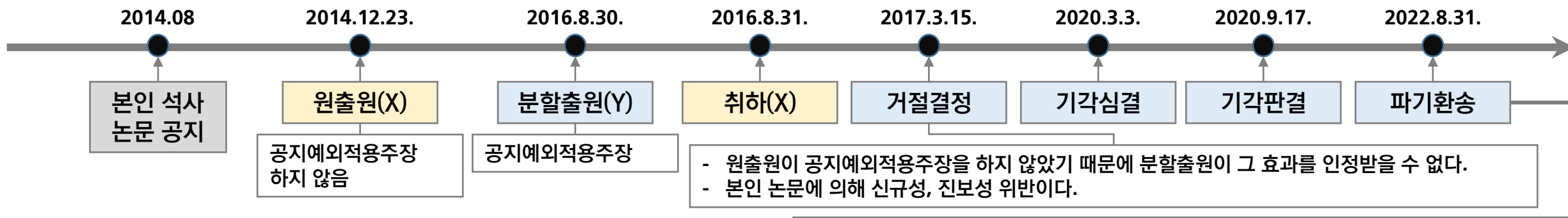


분할출원은 원출원과 전혀 별개의 새로운 출원이다. 따라서 분할출원은 원출원에 대하여 생긴 절차상의 효력을 그대로 승계할 수 없다. 즉 분할출원에 대한 심사청구, 출원공개, 특허여부결정도 원특허출원과 독립하여 행하여진다. 예를 들어, 분할출원은 원출원일부터 1년 6개월이 지나기 전에 분할된 경우에는 원출원일부터 1년 6개월이 지난 후에, 원출원일부터 1년 6개월이 지난 후에 분할된 경우에는 즉시 출원공개된다. 다만, 분할출원의 심사는 지식재산처장이 정하는 바*에 따른다(施規 38②). 이는 심사순서를 탄력적으로 운영하여 변동하는 심사환경에 대응하기 위함이다. 이는 원출원과 분할출원에 기재된 발명이 관련기술인 경우가 많이 있기 때문에 원출원과 분할출원을 같이 심사하여 심사의 효율성을 높이기 위함이다. 한편, 상술한 바와 같이 원출원이 우선권주장절차를 밟았다고 하더라도 분할출원이 이들 절차의 효력을 누리기 위해서는 다시 절차를 밟아야 한다. 다만, 원출원이 우선권주장을 하지 아니한 경우 실무상 분할출원 역시 상기 주장을 할 수 없다. 이는 원출원과 동시에 우선권주장을 하지 아니하여 그 효과가 발생하지 아니한 경우 이를 회피하기 위한 수단으로서 분할출원을 이용하는 것을 방지하기 위해서이다.

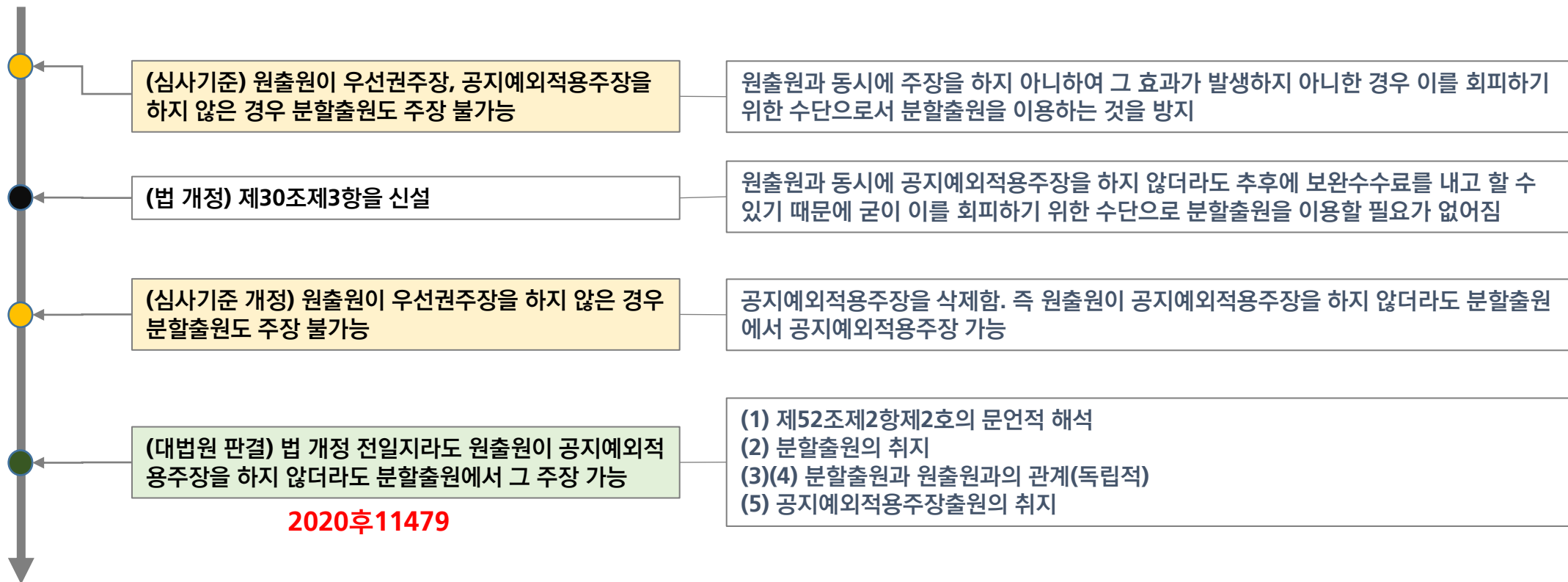
* 분할출원의 심사청구순서



대법원 2022. 08. 31. 선고 2020후11479 판결 【거절결정(특)】



- (제52조제2항의 문언적 해석)** 특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다. 결국 위 **규정들의 문언상**으로는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.
- (분할출원의 취지)** 분할출원은 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다. 따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, **분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어** 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.
- (원출원과의 관계: 제30조제2항의 해석)** 분할출원은 보정과 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 **독립된 출원**이다. 따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.
- (원출원과의 관계: 제30조제3항의 신설)** 위 2010후2353 판결 이후 출원인의 권리 보호를 강화하기 위하여 특허법 제30조 제3항을 신설하였으나(2015. 1. 28. 법률 제13096호로 개정된 것), 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 그 요건과 취지를 달리하는 **별개의 제도**라는 점에서, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장으로 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과를 인정받을 수 있는지의 문제는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석함이 타당하다.
- (공지예외적용주장의 취지)** 공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 **특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로** 자리 잡고 있다는 점까지 더하여 보면, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 원출원일을 기준으로 한 공지예외 효과를 인정받는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

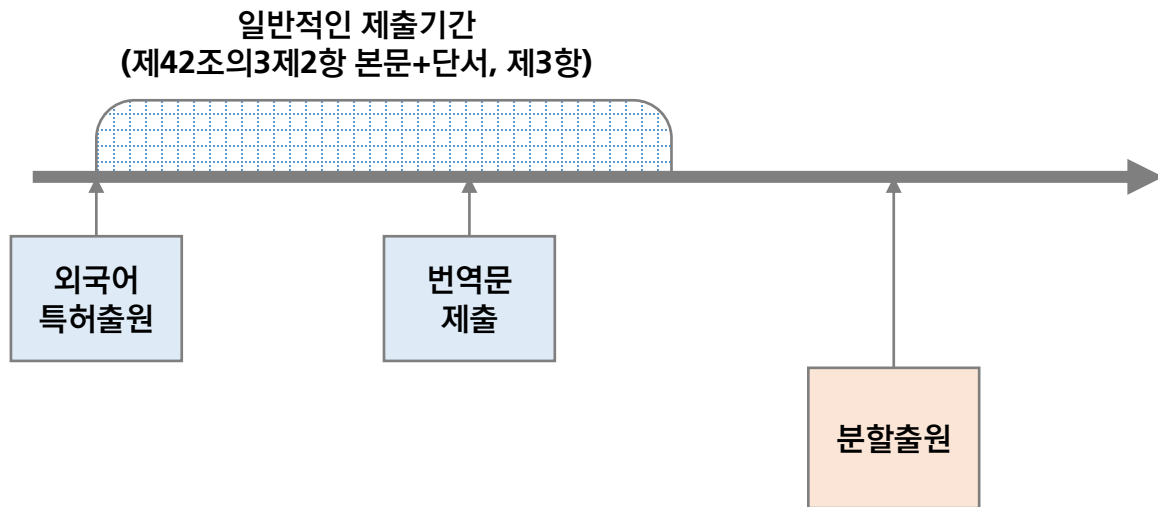


- 판례의 근거에 의하면, 원출원이 우선권주장을 하지 않더라도 분할출원에서 우선권주장 가능
- 이는 출원과 동시에 주장을 해야 한다는 제54조제3항, 제55조제2항의 취지를 분할출원을 통해 몰각시킬 수 있음
- 따라서, 제52조제2항제3호, 제4호의 개정이 필요함

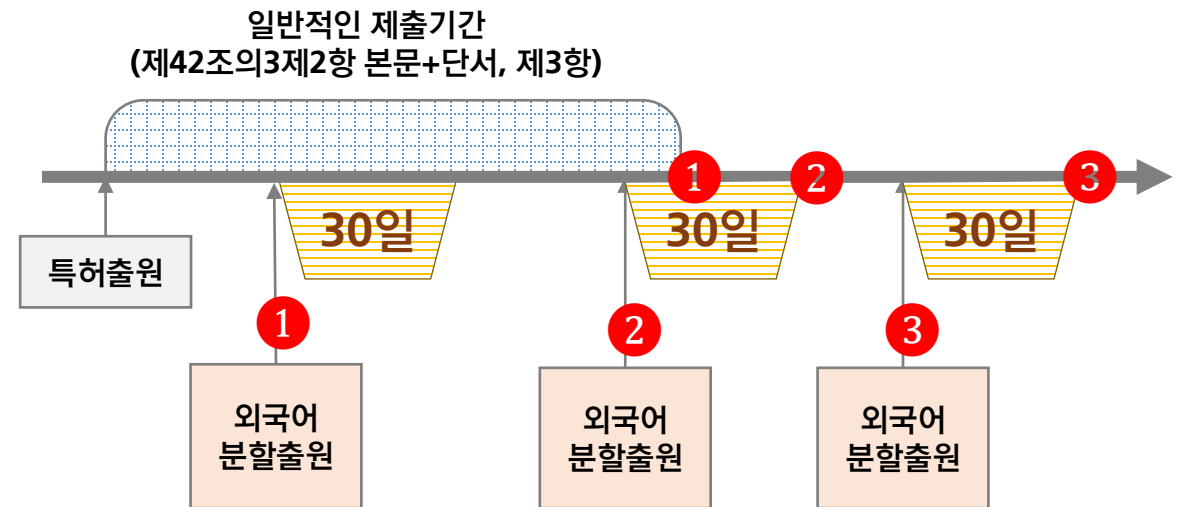
원출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 국어번역문(法 42의3②)이 제출된 경우에만 분할출원할 수 있다(法 52①단서).

분할출원이 외국어특허출원인 경우에 특허출원인은 국어번역문(法 42의3②) 또는 새로운 국어번역문(法 42의3③본문)을 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만, 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다(法 52⑤본문). 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(法 52⑤단서).

- i) 명세서 또는 도면을 보정(제42조의3제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우
- ii) 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우

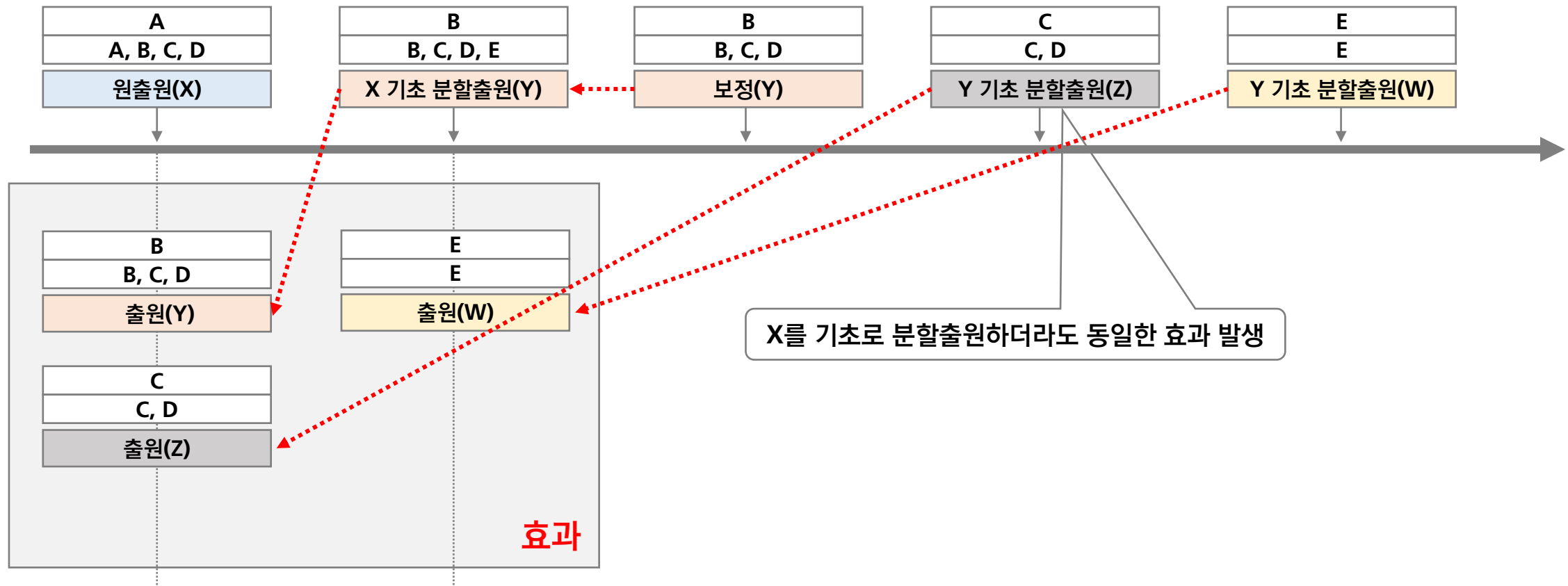


보 분 변 심 공

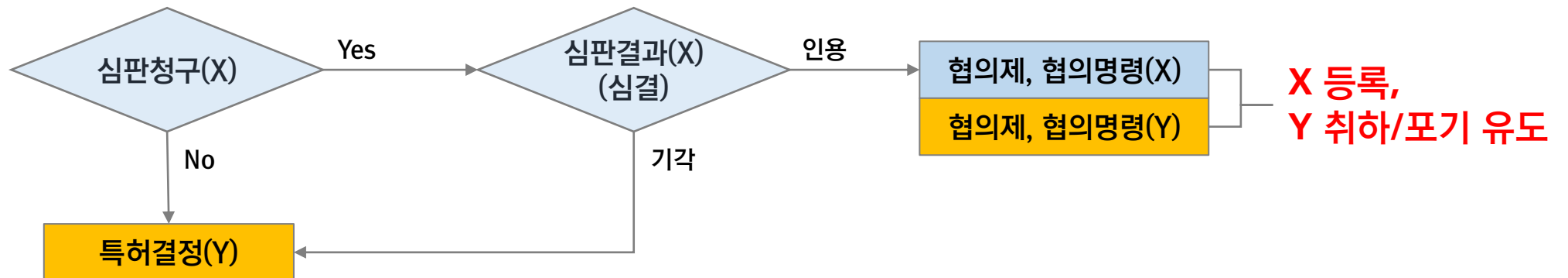
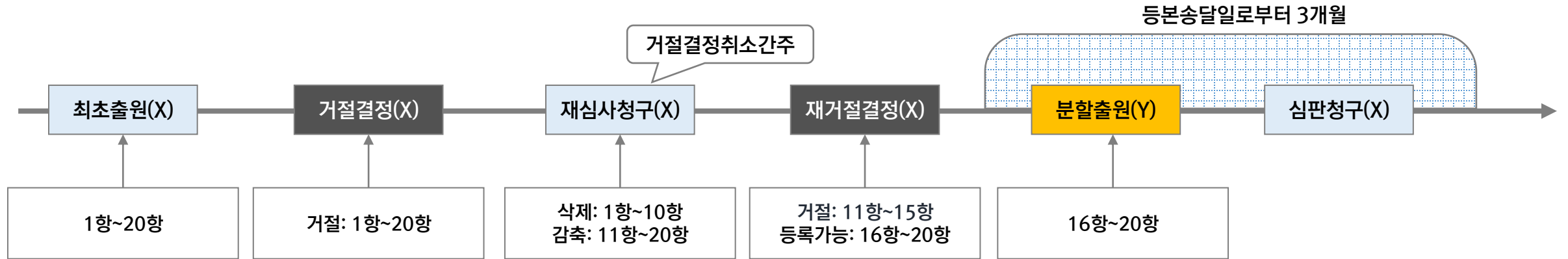


청 (30일) 번 (30일) 조 (3개월) 우 (30일) 심 (30일)

원출원(이하 “父출원”이라 한다)으로부터 분할출원(이하 “子출원”이라 한다)하고, 다시 子출원을 원출원으로 하여 분할출원(이하 “孫子출원”이라 한다)하였을 때 i) 孫子출원이 子출원에 대하여 분할출원의 요건을 충족할 것, ii) 子출원이 父출원에 대하여 분할출원의 요건을 충족할 것, iii) 孫子출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 父출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 범위 이내일 것을 만족하는 경우 孫子출원의 출원일은 父출원의 출원일로 소급한다. 이는 출원인이 父출원을 기초로 분할출원을 할 수 없는 경우(예컨대 분할출원의 시기적 제한 때문에 父출원으로부터 출원의 분할을 할 수는 없으나, 子출원으로부터 출원의 분할이 가능한 경우 등)에 실효성이 있다할 것이다.



심판청구없이 분할출원(16항~20항)하는 경우에는 즉시 특허결정이 가능하다. 한편, 분할출원(16항~20항)과 심판청구를 같이 하는 경우에는 심판결과가 확정된 후에 분할출원에 대한 특허여부를 결정한다(심판결과 인용되어 원출원에 대한 거절결정이 취소되면 협의제, 협의명령에 의함).



대법원 2009.9.24. 선고 2007후2827 판결 【권리범위확인(특)】

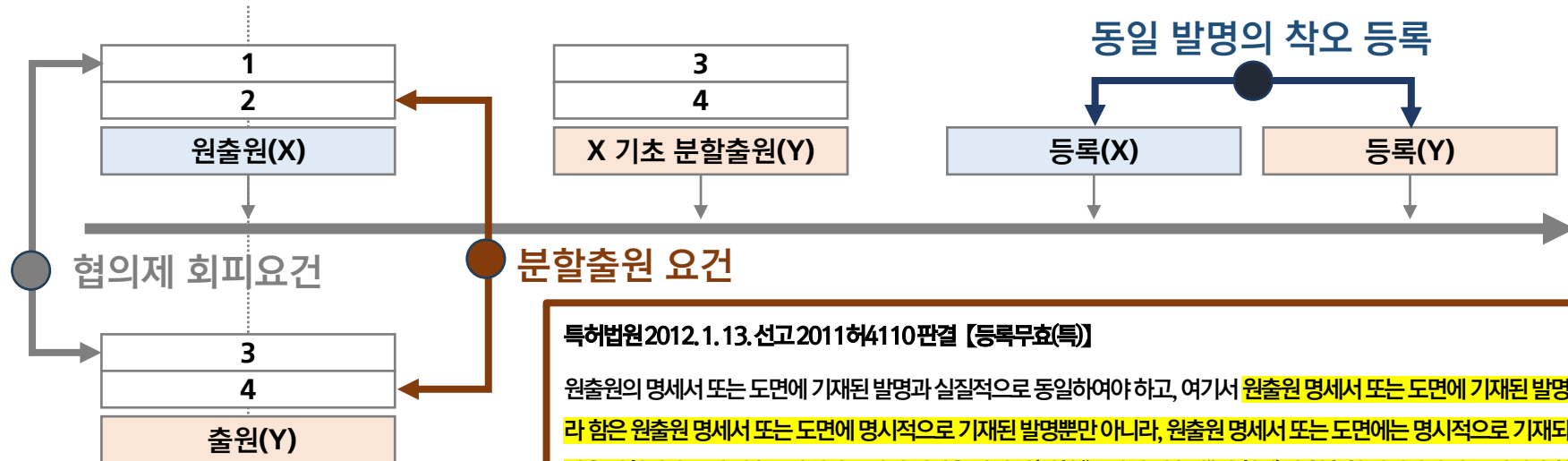
구 특허법(1990.1.13. 법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것) 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선출원주의를 채택하고 있다. 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, **비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용 효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는** 양 발명은 역시 동일한 발명이다.

특허법원 2017.10.12. 선고 2017허1021 판결 【등록무효(특)】

분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일하면 구 특허법 제36조 제2항의 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 경우에 해당한다. 분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일하지 여부는 청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 실질적으로 동일한지 여부를 기준으로 하여야 하며, 청구범위의 기재가 문언적으로 일치하지 **않더라도 그 차이가 동일한 기술적 구성에 대해 기능·성질·효과 등으로 표현을 달리한 것에 불과하거나 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 수단에서 주지관용기술을 부가·삭제·변경한 것 또는 단순히 수치 범위를 달리한 것에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면** 양 발명은 실질적으로 동일한 발명에 해당한다.

실질적 동일성 인정

대법원 1990.8.14. 선고 89후1103 판결 【실용신안등록무효】 동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록이 된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니다. 위법 제7조 제3항에서 동일한 내용의 실용신안등록출원이 경합하거나 실용신안등록출원과 특허출원이 경합한 경우에 그 어느 하나가 무효 또는 취하되었거나 포기된 때에는 그 실용신안등록출원 또는 특허출원은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정한 취지에 미루어 보더라도 위와 같이 해석하는 것이 타당하다.



대법원 1995.9.26. 선고 94후1558 판결 【거절사정】

동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다.

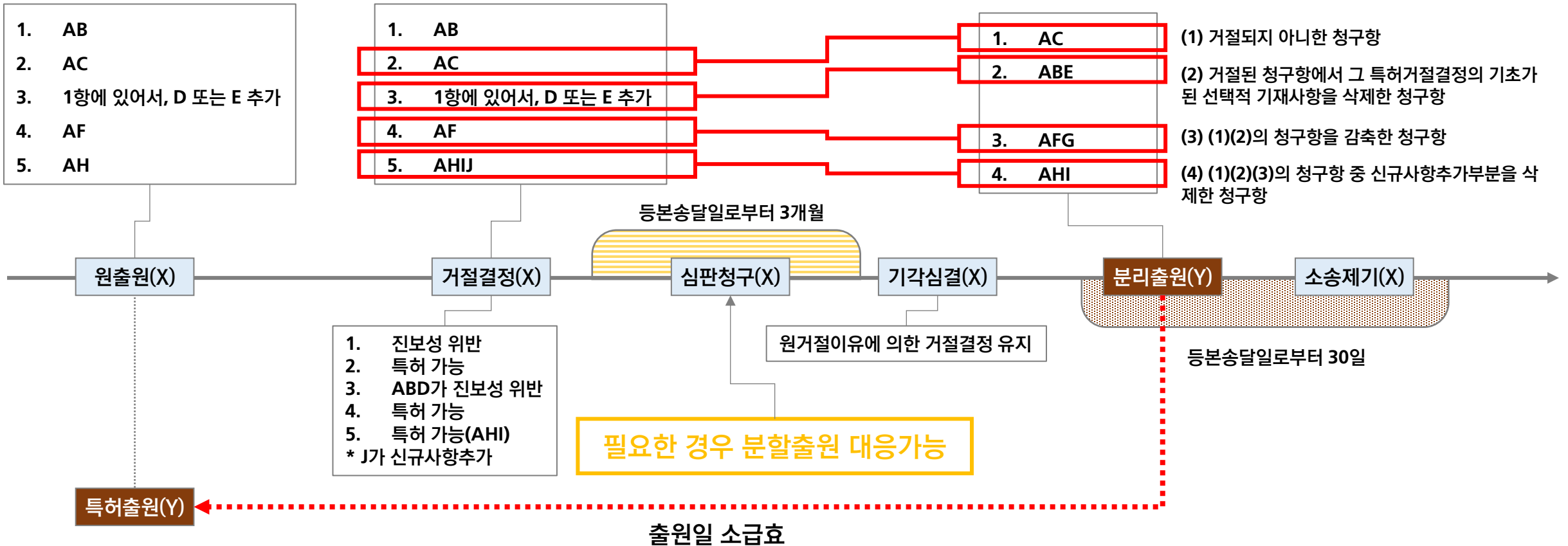
동일자 출원 모두 등록된 것의 처리에 대한 비판

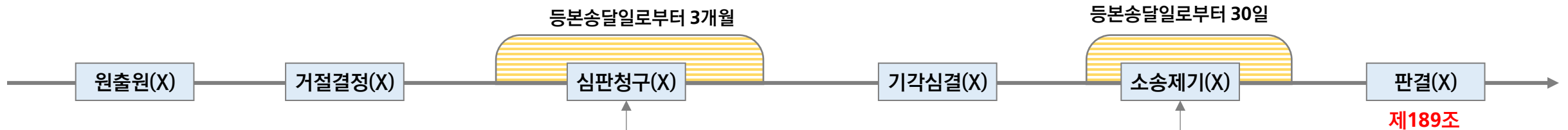
특허법원 2012.1.13. 선고 2011허4110 판결 【등록무효(특)】

원출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일하여야 하고, 여기서 **원출원 명세서 또는 도면에 기재된 발명이라 함은 원출원 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재된 발명뿐만 아니라, 원출원 명세서 또는 도면에는 명시적으로 기재되지 않은 사항이라도 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 "통상의 기술자"라 한다)가 원출원 명세서의 다른 기재나 최초 출원 당시의 기술상식에 비추어 일의적이고 명확하게 인식할 수 있는 사항도 포함될 수 있지만, 원출원 명세서에 화합물이 상 위개념으로서의 일반 화학식으로 기재되어 있는 발명 중 일부를 하위개념으로 새롭게 정의하여 분할출원하는 경우에 있어서, 이는 선택발명의 영역에 있는 것을 분할출원하는 것으로서 이러한 분할출원을 인정한다면 원출원에 기초한 다른 제3자의 선택발명을 극히 제한하게 되고, 원출원 발명 당시에 개시되지 않았던 사항에 대하여 사후에 분할출원에 의하여 그 기술적 의의를 인정해 주게 되어 특허출원은 1 발명을 1 특허출원으로 한다는 규정에 의하여 특허를 받을 수 없게 되는 발명들을 따로 분할하여 별도로 분할출원할 수 있도록 함과 동시에 이들 발명의 특허출원시점을 당초의 원출원의 출원시점으로 소급시켜주는 것은 분할출원 제도의 취지에 어긋나게 되므로, 분할출원으로서의 하위개념 발명이 원출원 명세서에 기재된 상위개념 발명에 개념적으로 포함된다는 점만으로는 분할출원된 발명이 원출원 명세서에 기재된 사항이라고 할 수는 없고, 원출원 명세서 전체의 기재와 최초 출원 당시의 기술상식을 종합적으로 고려하여 분할출원된 발명이 원출원 명세서에 기재된 것인지 또는 기재된 것과 동일하게 볼 수 있는 것인지 여부를 실질적으로 판단해야 한다.**

거절결정불복심판의 심결후 특허가능한 청구항에 대한 권리획득 기회 제공

특허거절결정불복심판에서 기각심결이 있는 후에는 분할출원을 할 수 없기 때문에 거절결정 대상이 되지 않은 청구항(즉, 청구범위 중 특허가능한 청구항)을 포함하는 특허출원이 구제받지 못하는 경우가 발생하는 문제점이 있었다. 이에 2022. 4. 20. 시행되는 개정법(法律 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 심결취소의 소 제기 전까지 그 청구항을 새로운 특허출원으로 분리하여 신속하게 추가적인 권리획득할 수 있는 기회를 제공하고 있다.





분할출원(Y)한 경우 원출원(X)과 협의제 회피방안

- 원출원(X)의 심판결과가 확정될 때까지 분할출원(Y)의 심사절차 중지 O
- 심판결과 원출원(X)에 대한 거절한다는 취지의 심결이 확정되면 선출원의 지위가 없어지기 때문에(法 36④) 분할출원(Y)은 협의제(法 36②) 회피 가능
- 원출원(X)에 대한 인용심결이 확정되어 거절결정이 취소되면 원출원(X)과 분할출원(Y)은 협의제(法 36②) 적용

분리출원(Z)한 경우 원출원(X)과 협의제 회피방안

- 분리출원(Z)의 심사절차 중지 X
- 원출원(X)의 특허결정 전이고 원출원을 인용발명으로 하는 선출원주의 위반(法 36②)의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 분리출원(Z)에 대해 특허결정(먼저 등록가능)
- 분리출원(Z)의 특허결정 후에 원출원(X)의 기각심결이 취소되어 특허심판원으로 환송된다면, 특허심판원에서는 원거절결정의 이유와 다른 거절이유인 협의제(法 36②) 위반으로 원출원(X)에 대하여 거절이유통지
(분리출원(Z)이 먼저 등록된 경우 협의제 위반의 특허취소사유, 특허무효사유 존재)

제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 대하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
 2. 제30조제2항을 적용하는 경우
 3. 제54조제3항을 적용하는 경우
 4. 제55조제2항을 적용하는 경우
- ③ 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.
- ④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.
- ⑤ 제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취할 수 있다

⑥ 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다

⑦ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

⑧ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.

제52조의2(분리출원) ① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.

1. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
2. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
3. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항
4. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항

② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 “분리출원”이라 한다)에 관하여는 제52조제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “분할”은 “분리”로, “분할출원”은 “분리출원”으로 본다.



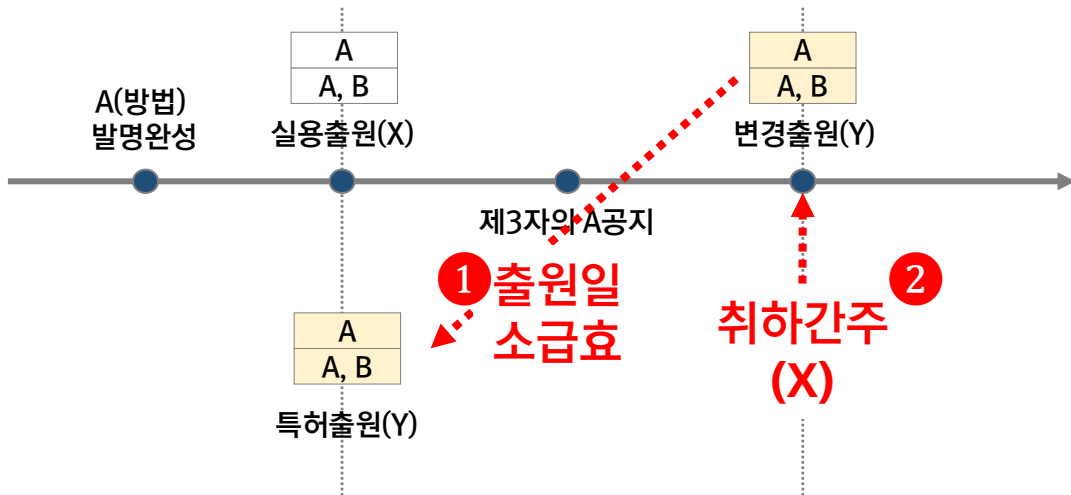
③ 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단 또는 제42조의3제1항에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적을 수 없다.

④ 분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원의 기초가 될 수 없다.

출원형식선택의 과오 치유

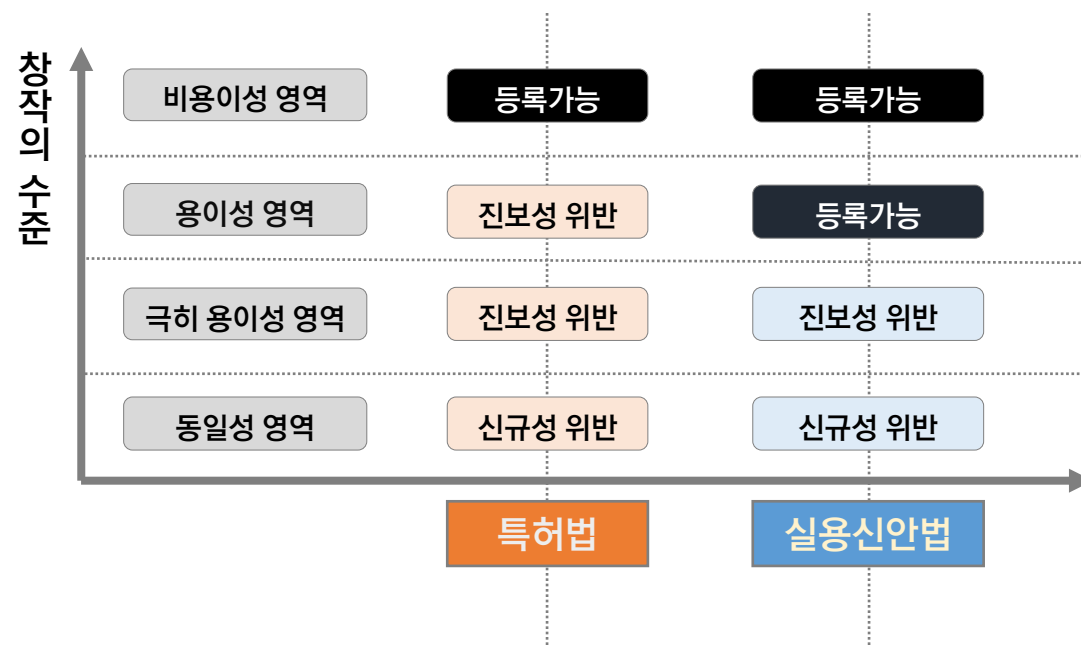
특허로서 보호받기 위해서는 단순히 발명일 것을 요하나 실용신안으로서 보호받기 위해서는 **물품의 형상·구조·조합에 관한 고안**이어야 한다. 그런데, 출원인이 착오로 물질이나 방법발명을 실용신안등록출원으로 하는 경우가 있다. 이와 같은 단순한 출원형식 선택의 과오를 이유로 거절하고 재출원하게 한다면, 우리 법제가 선출원주의를 채용하고 있음을 감안할 때 출원인에게 가혹하다할 것이다.

구분		특허법 보호대상	실용신안법 보호대상
물건 발명	협의를 물건발명	○	○
	물질발명	○	×
방법 발명	통상방법발명	○	×
	제법발명	○	×

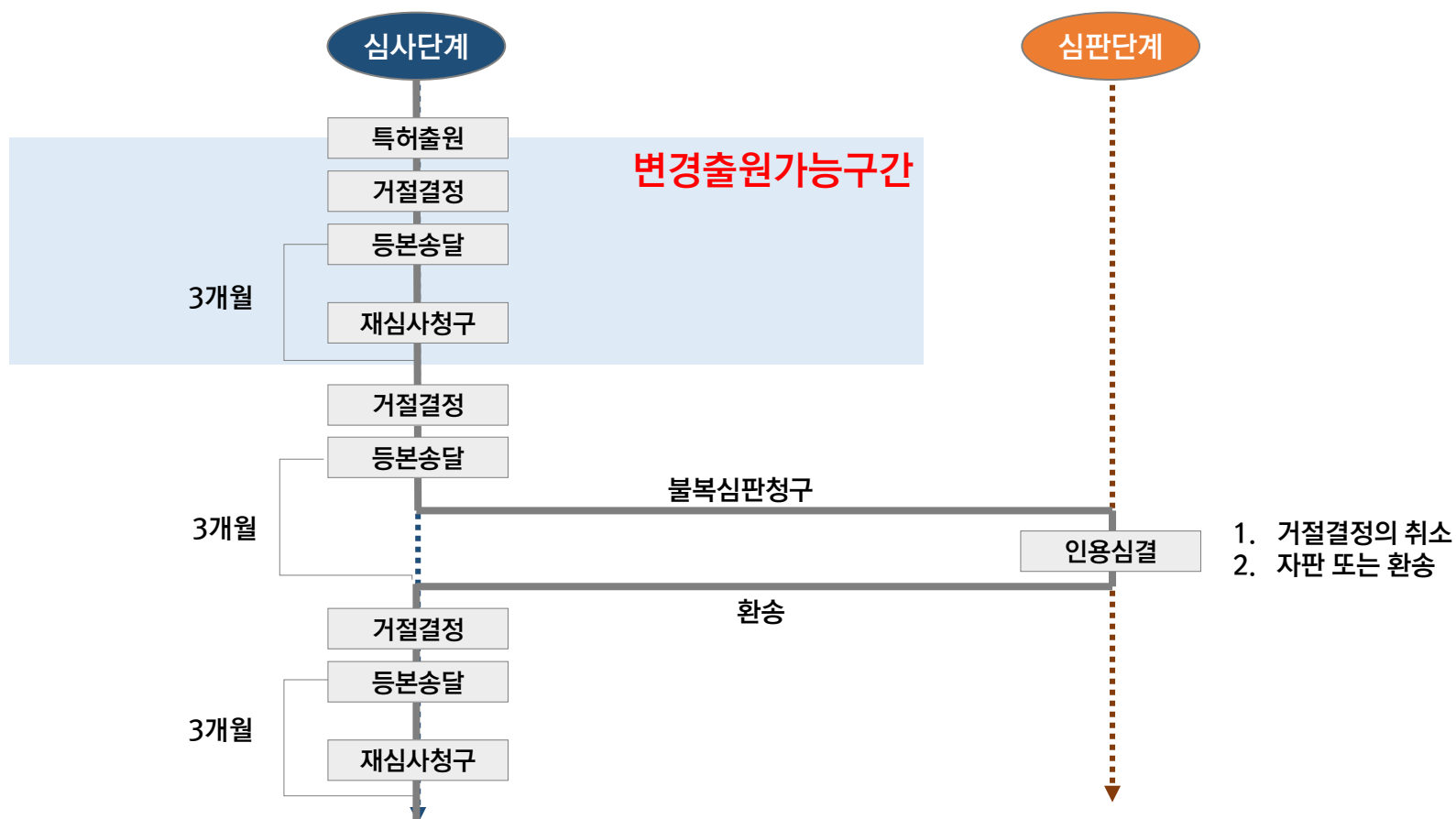


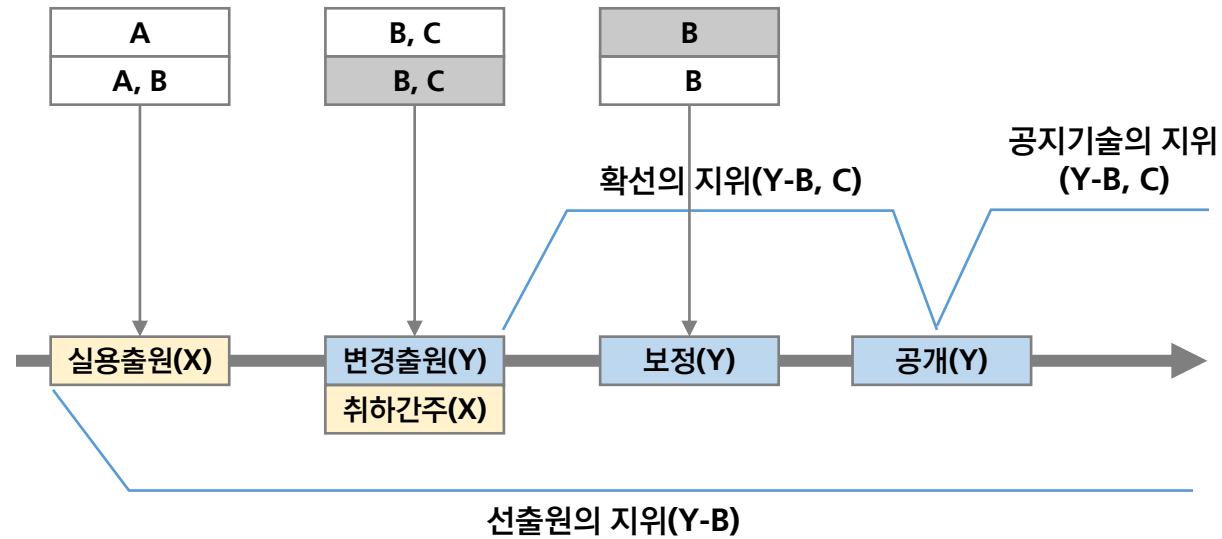
진보성 위반 극복 위한 방안

변경출원제도는 물품성이 있는 물건발명에 대한 특허출원이 진보성이 없다는 이유로 거절결정이 확정될 가능성이 있는 경우 이를 극복하기 위한 방안으로서 의미가 있다고 할 것이다. 이는 진보성을 판단할 때 **실용신안법은 특허법보다 낮은 수준인 「극히 용이성」**을 요구하고 있기 때문이다.

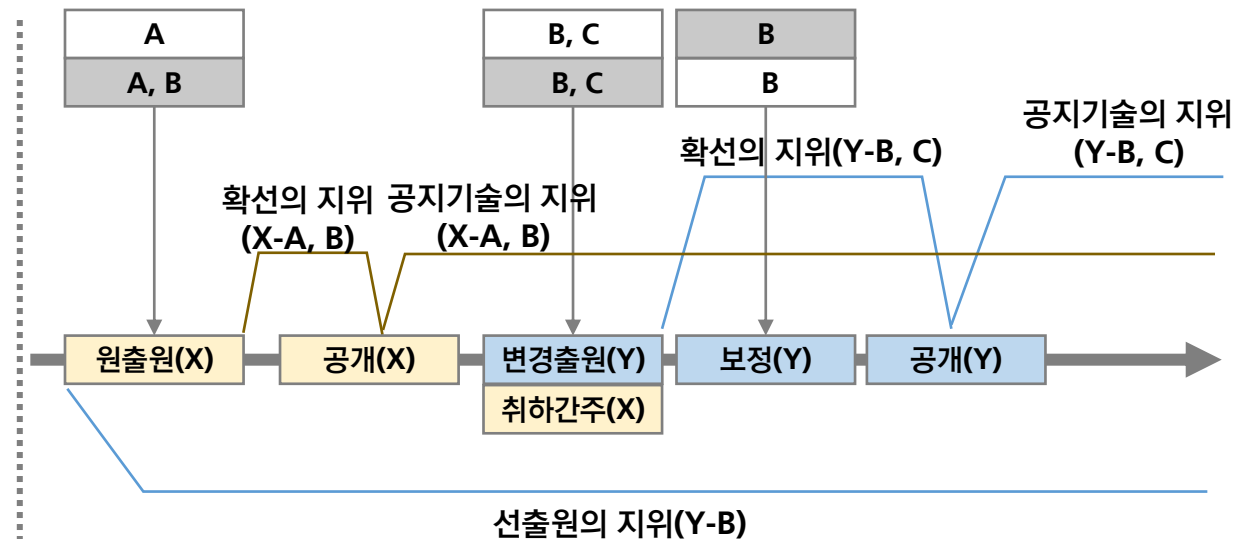
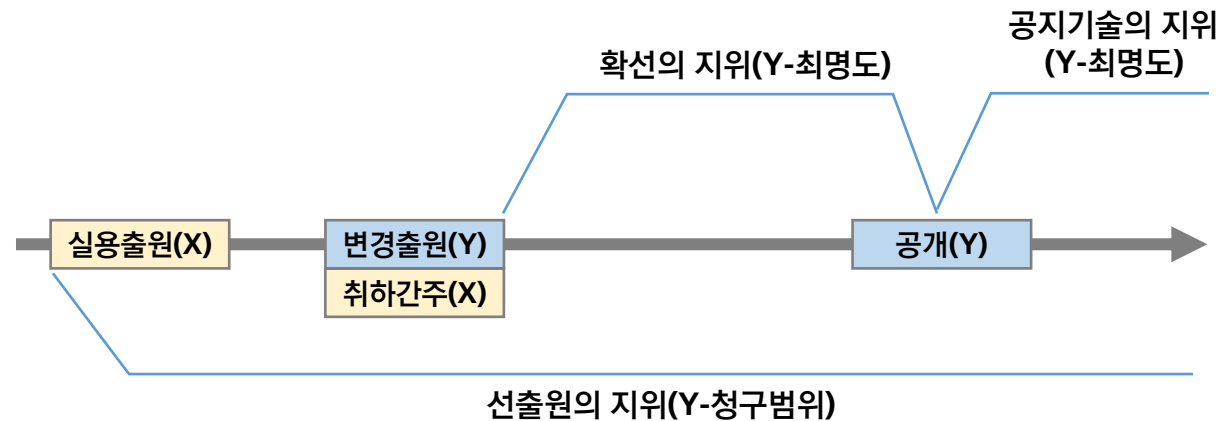


원출원이 있는 후 변경출원을 할 수 있으나 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다)이 지난 후에는 변경출원을 할 수 없다(法 53① I). 이는 변경출원이 특허거절결정에 대한 일방책(一方策)임을 감안하여 출원인에게 변경출원, 거절결정불복심판의 청구와 재심사 청구 중 택일적으로 조치를 취할 수 있는 기회를 주기 위함이다. 한편, 「최초」 특허거절결정등본을 받은 경우에 한정되므로 거절결정불복심판 또는 재심사를 청구하여 원특허거절결정이 취소되었다거나 그에 따라 특허거절결정등본을 다시 송달받아 3개월 이내라고 하더라도 변경출원할 수 없다.

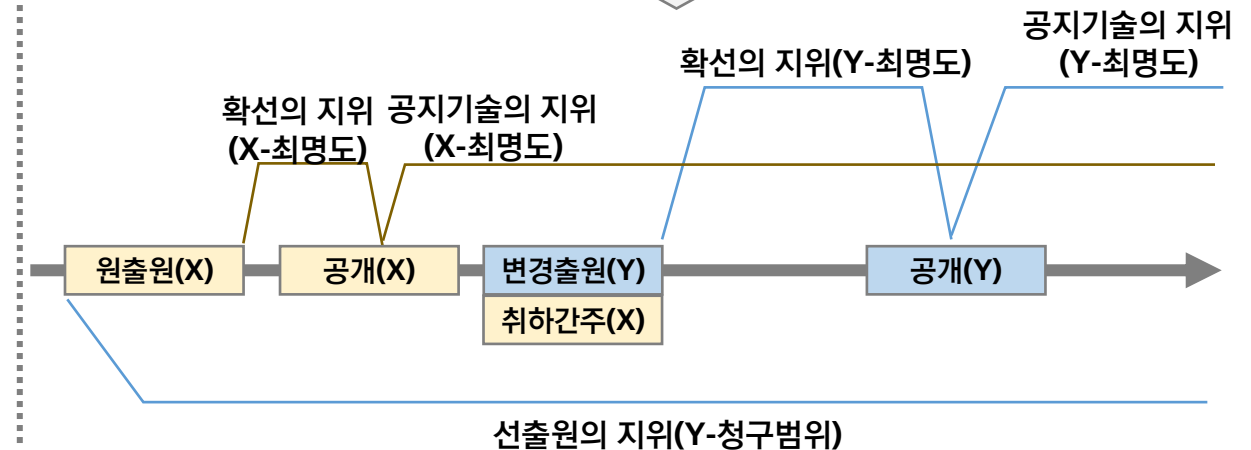




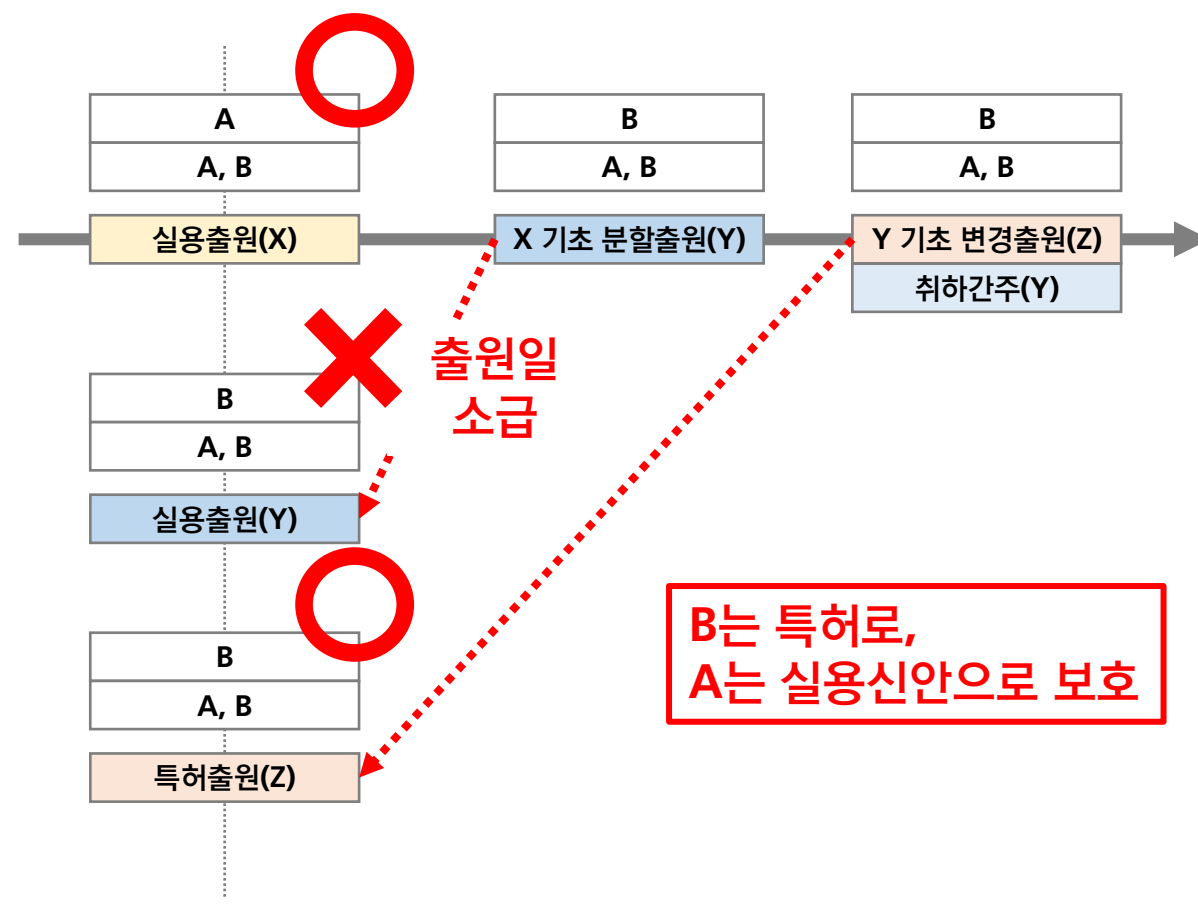
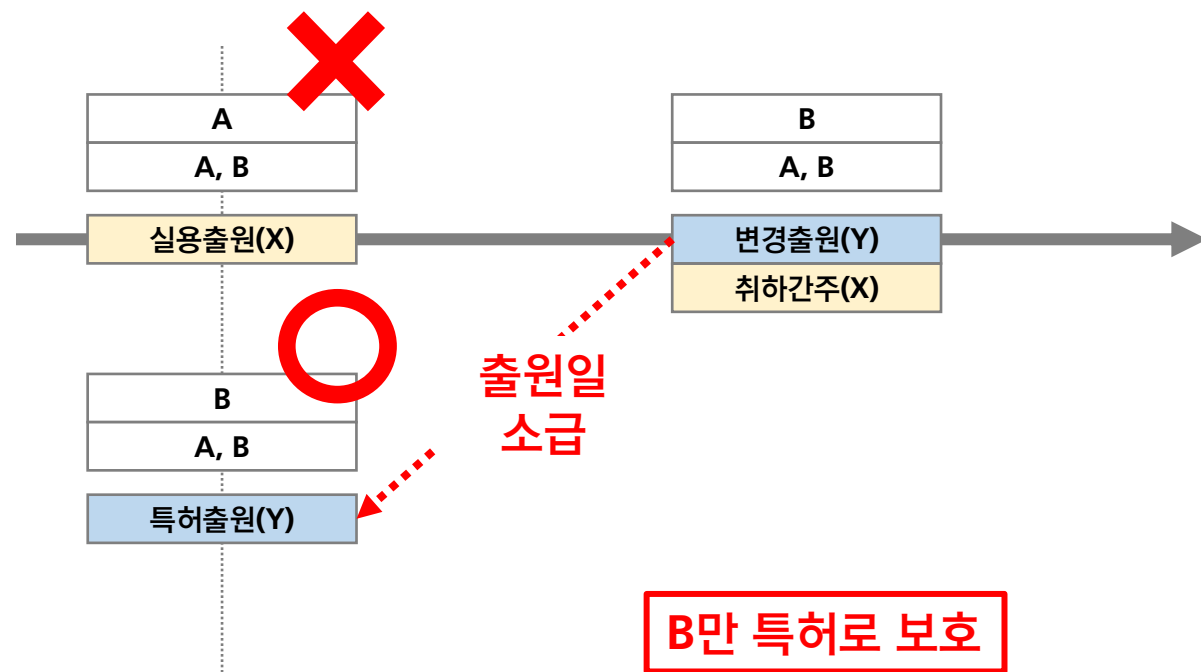
일반화



일반화



분할출원을 한 후 그 분할출원을 원출원으로 하여 변경출원을 할 수 있다. 다만 분할출원과 변경출원이 하나의 절차에 의하여 이루어질 수는 없으므로 특허출원 발명(A, B) 중 일부(A)를 특허로 보호받고, 일부(B)를 실용신안으로 보호받고자 할 때에는 일단 그 발명(B)을 동일한 출원형식으로 분할출원을 하고 그 분할출원을 다시 변경출원하여야 한다. 그 발명(B)을 분할출원하지 않고 특허출원(A, B)을 바로 변경출원하는 경우에는 특허출원이 취하간주되어(法 53④) 변경출원한 일부 발명(B)에 대해서만 실용신안으로 보호를 받을 수 있게 된다.



제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.

1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.

1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
 2. 제30조제2항을 적용하는 경우
 3. 제54조제3항을 적용하는 경우
 4. 제55조제2항을 적용하는 경우
- ③ 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.



④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.

⑤ 제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취할 수 있다.

⑥ 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다.

⑦ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

⑧ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.

제53조(변경출원) ① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(「실용신안법」 제3조에 따라 준용되는 이 법 제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다)이 지난 경우
2. 그 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제8조의3제2항에 따른 외국어실용신안등록출원인 경우로서 변경하여 출원할 때 같은 항에 따른 국어번역문이 제출되지 아니한 경우

② 제1항에 따라 변경된 특허출원(이하 "변경출원"이라 한다)이 있는 경우에 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 변경출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
 2. 제30조제2항을 적용하는 경우
 3. 제54조제3항을 적용하는 경우
 4. 제55조제2항을 적용하는 경우
- ③ 제1항에 따라 변경출원을 하려는 자는 변경출원을 할 때 특허출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다.

④ 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다.

⑤ 삭제



⑥ 변경출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다.

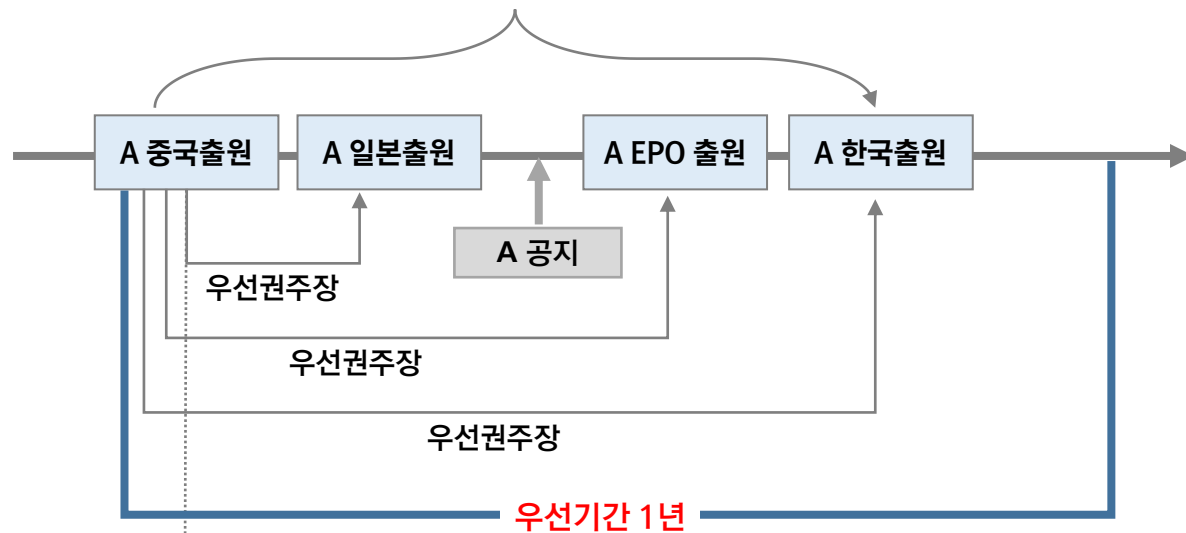
⑦ 특허출원인은 변경출원이 외국어특허출원인 경우에는 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

⑧ 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 변경출원의 경우 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.

구분		분할출원(제52조)	분리출원(제52조의2)	변경출원(제53조)
요건		제52조제1항	제52조의2제1항	제53조제1항
효과		제52조제2항	제52조의2제2항	제53조제2항
절차		제52조제3항	제52조의2제2항	제53조제3항
협약제 회피		-	-	제53조제4항
자동주장/증명서류		제52조제4항	제52조의2제2항	-
기간 특례	우선권주장취하	제52조제5항	제52조의2제2항	-
	조약우선권증명서류	제52조제6항	-	제53조제6항
	번역문제출	제52조제7항	제52조의2제3항	제53조제7항
	청구범위제출유예	제52조제8항	제52조의2제3항	제53조제8항
	심사청구	제59조제3항	제59조제3항	제59조제3항

A 발명을 중국, 일본, 유럽특허청(EPO) 또는 한국에 특허출원하려는 경우 시간, 거리, 언어 또는 법제상의 차이 등으로 인해 동일자에 출원하지 못하고 시간적 간격이 존재할 수밖에 없다. 이 경우 우선권주장을 수반하지 아니한다면 유럽특허청(EPO) 출원과 한국 출원은 A 공지로 인해 신규성 상실로 특허를 받을 수 없게 된다. 그러나 중국출원일로부터 1년 이내 우선권주장을 수반한다면 유럽특허청(EPO) 출원과 한국 출원 모두 중국 출원일로 특허요건 판단시점이 소급하기 때문에 A 공지로 인해 신규성이 상실되지 아니하여 특허를 받을 수 있게 된다. 이와 같이 특허법은 진정한 선출원자의 지위를 보장하고 발명의 국제적 보호를 위해 조약우선권제도를 두고 있다. 이러한 조약에 의한 우선권제도는 파리조약상의 우선권제도가 기본적으로 적용이 되고 그 밖에 파리조약의 비동맹국이라고 하더라도 우리나라와 조약에 따라 상호 우선권을 인정하기로 한 국가의 경우에도 적용이 된다.

시간적 간격



일본의 A

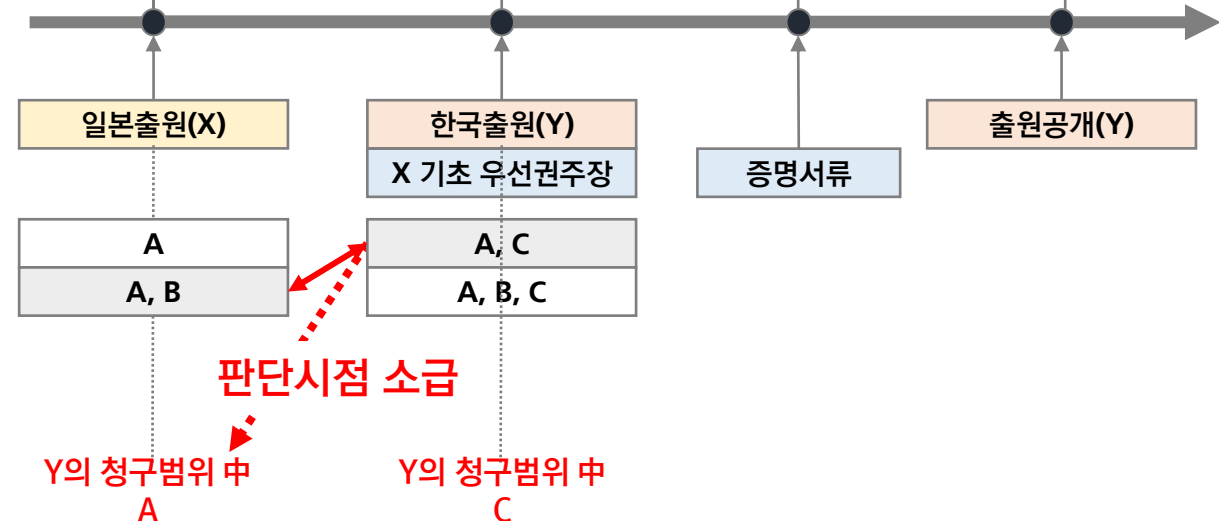
EPO의 A

한국의 A

1년 6개월

1년 4개월

1년



판단시점 소급

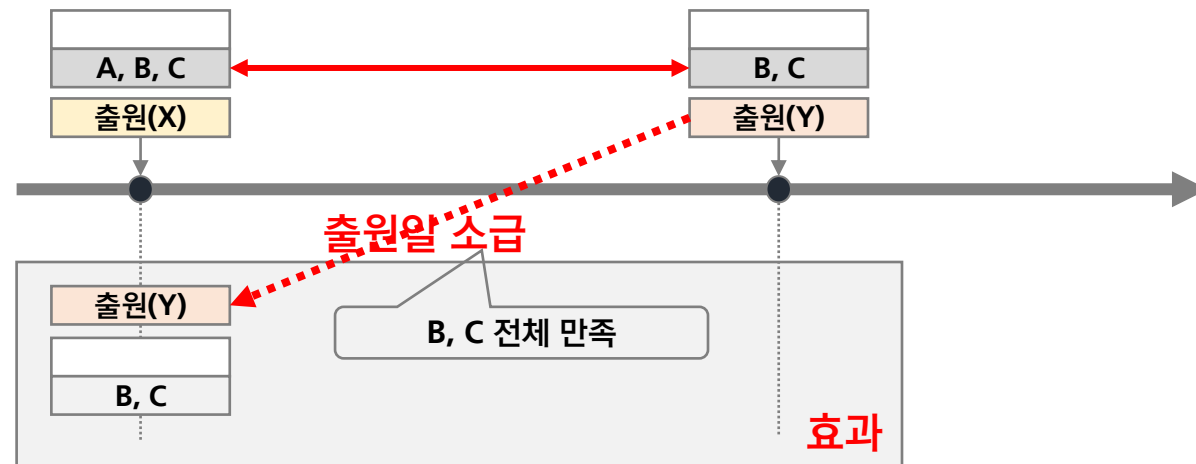
Y의 청구범위 중
AY의 청구범위 중
C

용어 정리

구 분	FRONT APPLICATION	BACK APPLICATION
제52조	원출원	분할출원
제52조의2	원출원	분리출원
제53조	원출원	변경출원
제54조	제1국출원 선출원 우선권기초출원 (우선권주장일)	제2국출원 후출원 우선권주장출원 (우선권주장출원일)
제55조	선출원 우선권기초출원 (우선권주장일)	후출원 우선권주장출원 (우선권주장출원일)

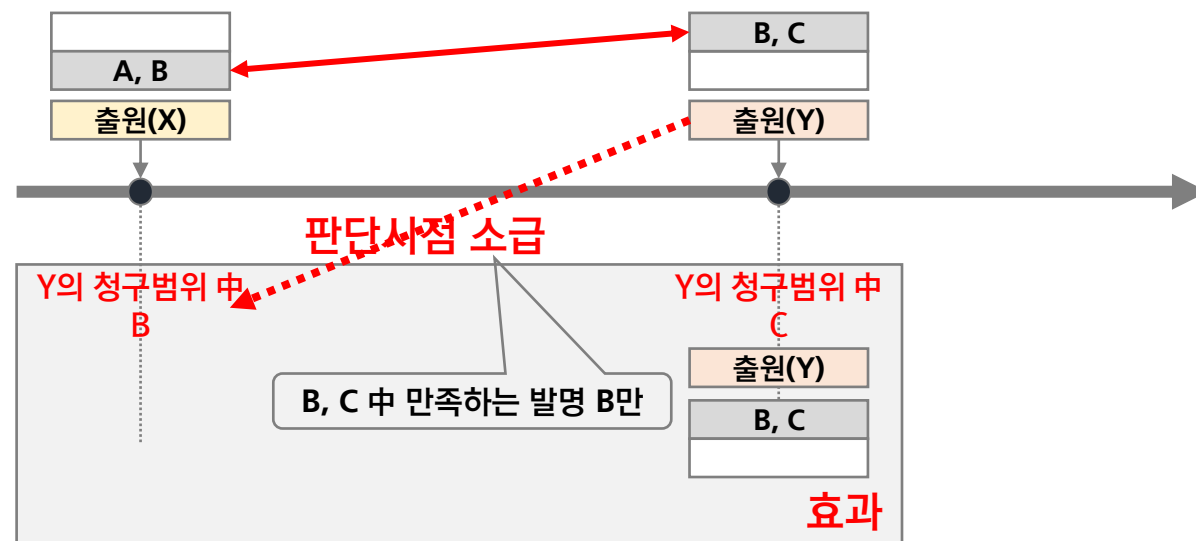
출원일 소급제도

출원(Y)는 출원(X)한 때에 출원한 것으로 본다.

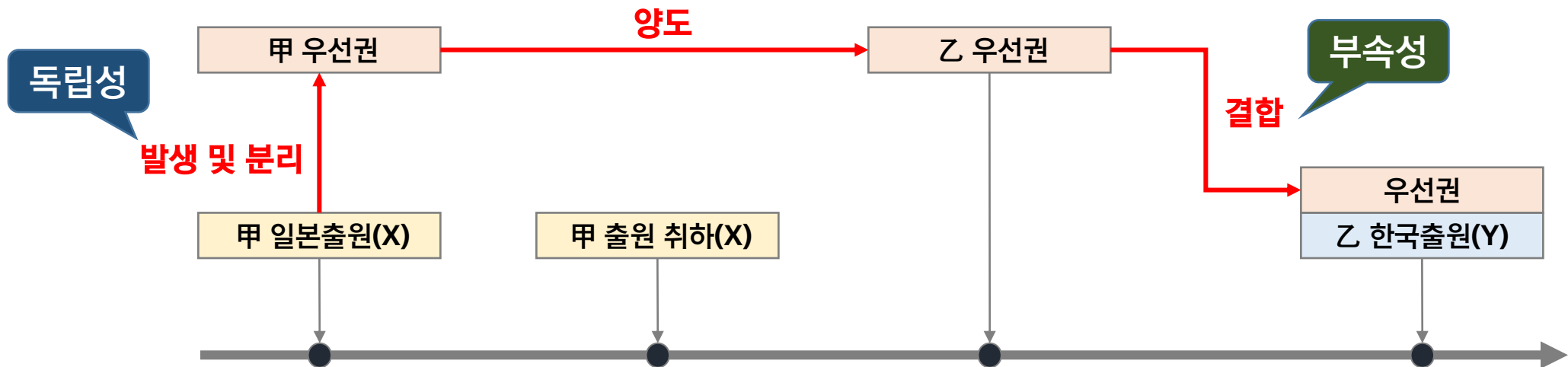


판단시점 소급제도

OO 규정을 적용할 때 출원(Y)는 출원(X)한 때에 출원한 것으로 본다.

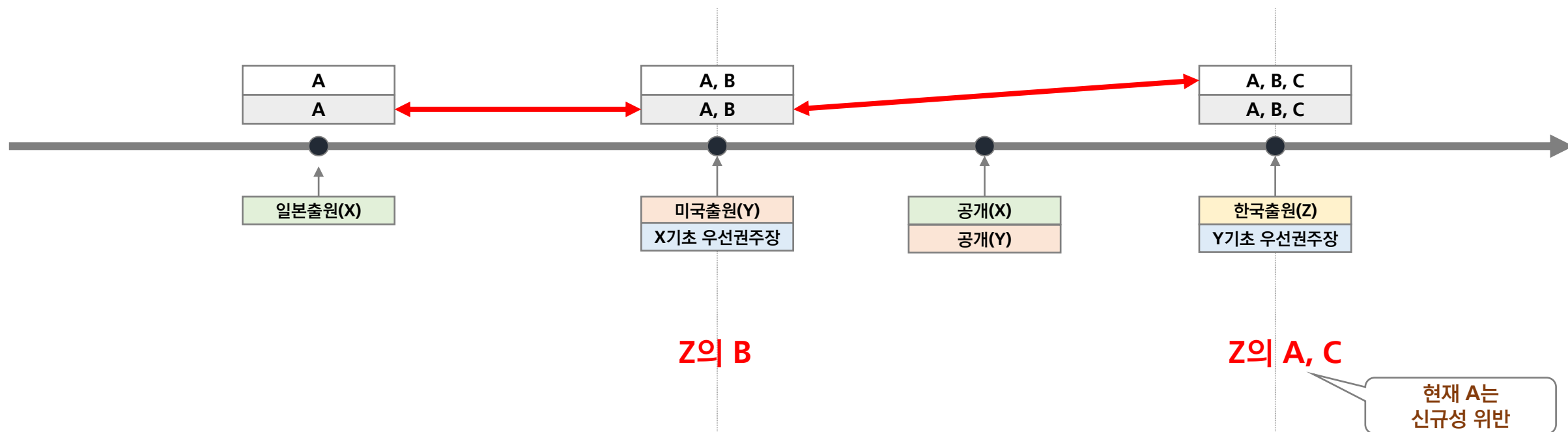


우선권은 최초 출원행위로부터 발생되지만 **그 발생과 함께 그 최초출원으로부터 분리되어 독립적**이 된다. 이를 우선권의 「독립성」이라 하는데, 이러한 독립성 때문에 **우선권만의 양도가 가능**하므로 제1국 출원의 승계인은 우선권을 별도로 승계하여야 우선권주장출원을 할 수 있다. 또한, 우선권의 독립성으로 말미암아 **제1국 출원은 정규성만 인정**되면 된다. 한편, 우선권은 동맹국의 최초 정규출원으로부터 독립된 것이라고 하더라도 그 독립성은 어디까지나 제2국 출원의 기초로서 사용될 때까지 성립되는 것이다. 따라서 제2국 출원의 기초로서 일단 행사된 때에는 독립성을 잃는 것이며, **그 후에는 제2국 출원의 부속물로서 제2국 출원국의 특허법에서의 출원과 그 운명을 함께** 한다. 이를 우선권의 「부속성」이라고 한다.

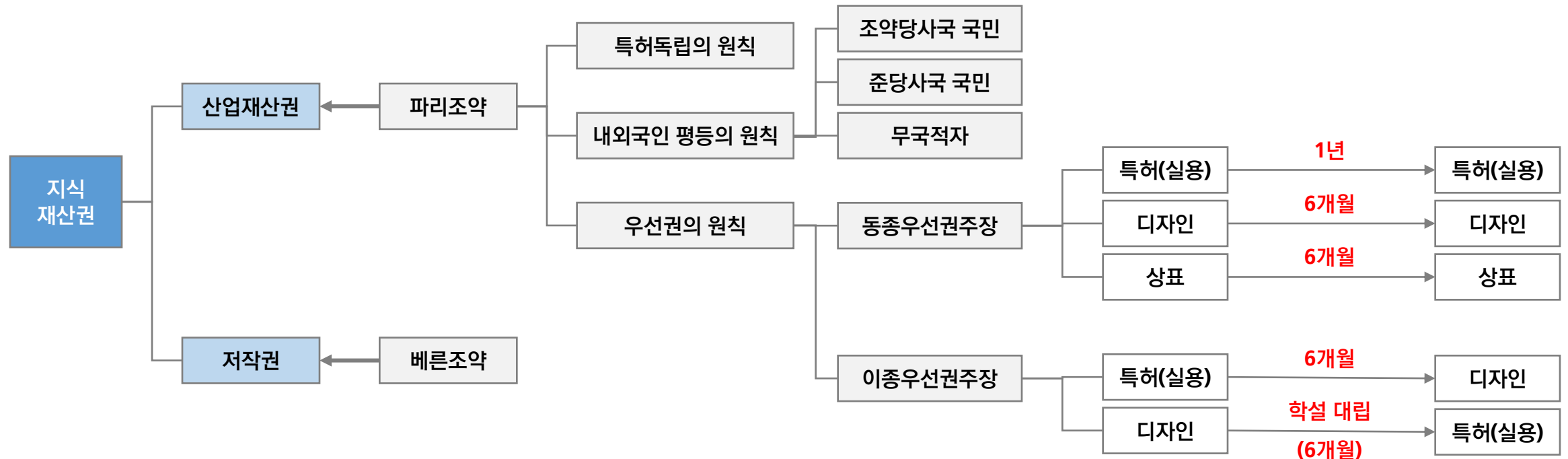


특허법원 2006. 2. 9. 선고 2004허8749 판결 【등록무효】

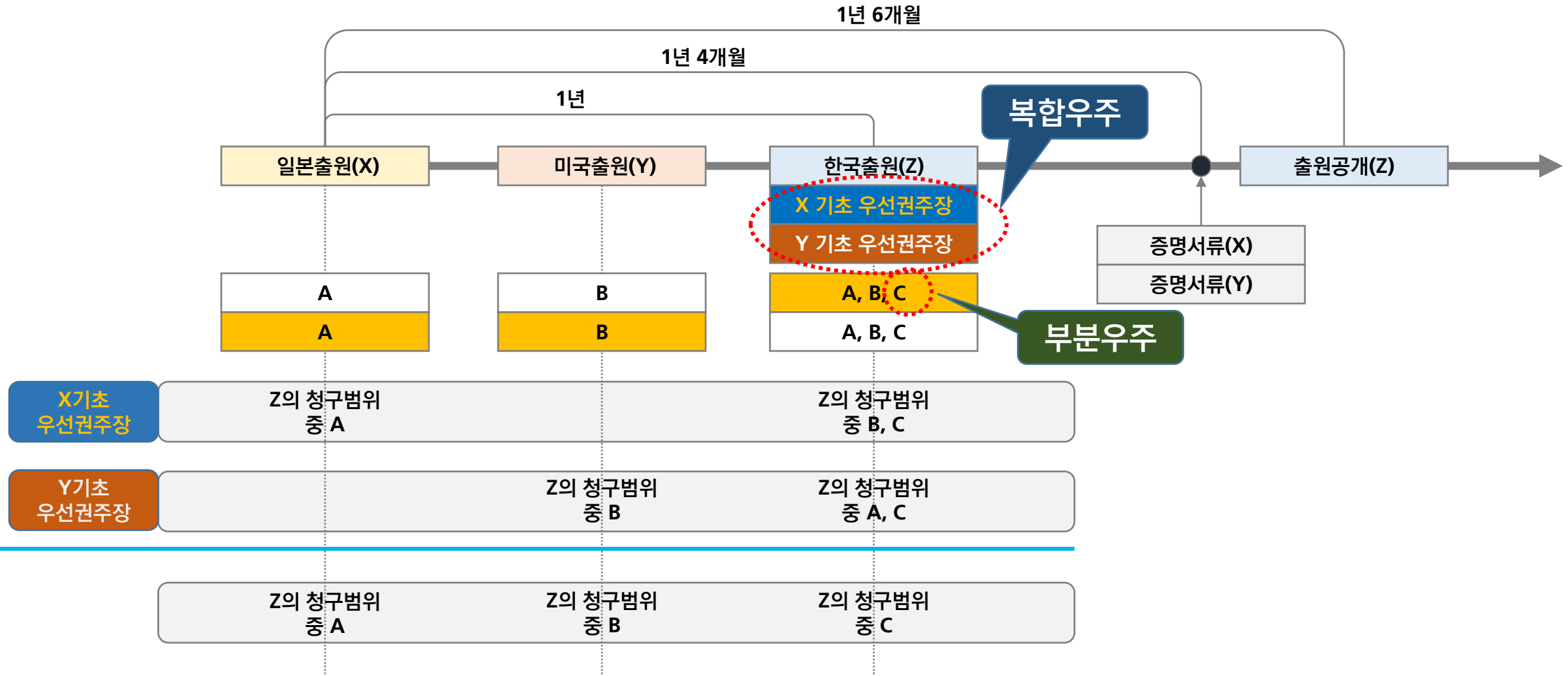
조약에 의한 우선권 주장을 인정받기 위해서는 ① 제1국 출원이 정규의 최초의 출원이어야 할 것, ② 제1국 출원과 제2국 출원이 동일한 발명이어야 할 것, ③ 제2국 출원이 제1국 출원일로부터 1년 이내에 이루어져야 할 것 등의 요건을 모두 충족시켜야 하므로, 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 제2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 출원이 아니거나(즉, 제1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고) 그 제2국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1년)을 지나서 이루어진 경우에는, 제2국 출원에 기재된 발명 중에 전출원과 제1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 아니한데, 이는 제2국 출원이 제1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선권의 소급 효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다. 따라서 제2국 출원의 우선권 주장이 인정받지 못하고 그 우선권 주장의 기초가 된 제1국 출원이 제2국 출원일 이전에 공개되었을 경우에는, 제2국 출원은 제1국 출원에 기재된 내용에 의하여 신규성을 상실하게 된다.



우선권을 주장하기 위해서는 우선기간(period of priority)내에 출원하여야 한다. 이러한 우선기간에 대해서는 출원인의 이익과 일반 제3자의 이익과의 조화라는 점에서 **특허 및 실용신안에 대해서는 12개월, 디자인 및 상표에 대해서는 각각 6개월**로 규정하고 있다(파리조약 4C(1)). 한편, 실용신안등록출원을 기초로 디자인등록출원으로 우선권주장을 하는 경우 우선기간은 6개월이며, 특허출원을 기초로 실용신안등록출원으로 우선권주장을 하는 경우 우선기간은 12개월이다(파리조약 4E(1)(2)). 문제가 디자인등록출원을 기초로 실용신안등록출원으로 우선권주장을 하는 경우인데 이 경우 파리조약에 직접적인 규정이 없기 때문에 디자인등록출원을 기준으로 6개월로 하여야 한다는 제1국설과 실용신안등록출원을 기준으로 12개월로 하여야 한다는 제2국설이 있으나, 심사실무는 제1국설을 지지한다.

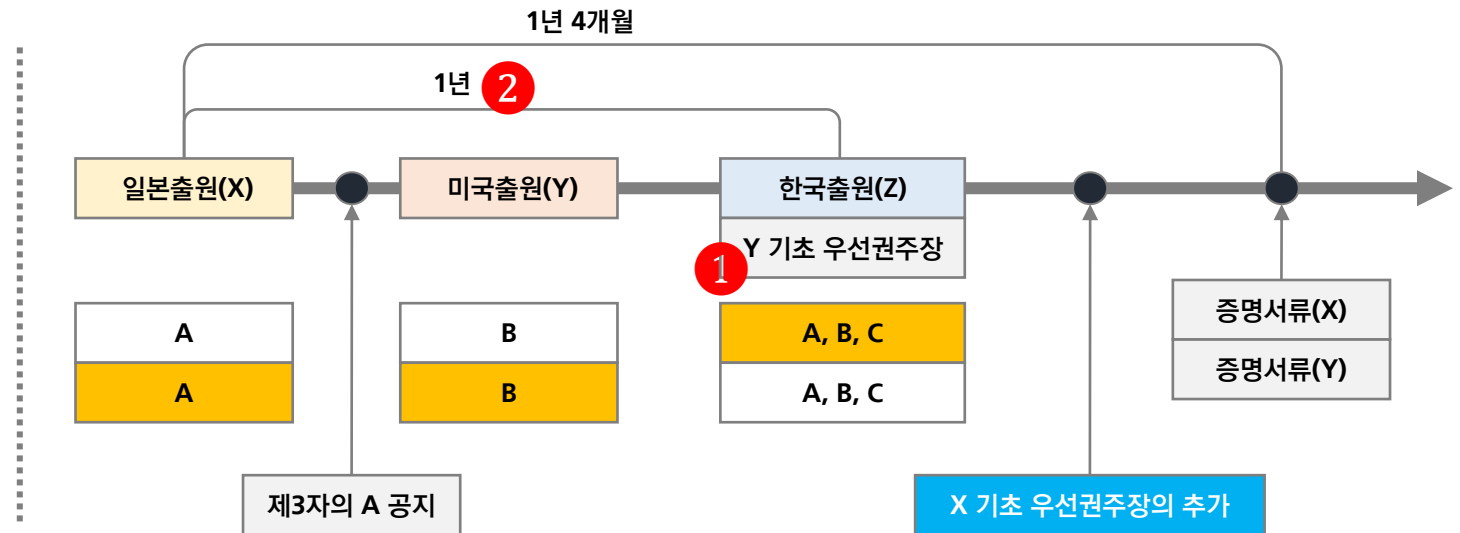


i) 「복합우선」이란 하나의 출원에 관하여 복수의 우선권(둘 이상의 국가에서 한 출원에 기한 것을 포함한다)을 주장하는 것을 말하며, ii) 「부분우선」이란 1 또는 그 이상의 우선권을 주장하는 출원이 그 우선권이 주장되는 출원에 포함되지 아니한 일 또는 그 이상의 발명을 포함하는 것을 말한다. 우선권이 주장되는 선출원에 포함되지 않았던 구성요소에 대해서는 후출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단하게 한다(파리조약 4F).



파리조약에서는 제2국에 출원할 수 있는 기간인 우선기간은 1년이라고 규정하고 있지만(파리조약 4C(1)), 제2국에 출원한 후 우선권주장을 할 수 있는 기간인 우선권주장기간은 동맹국의 자국법에 일임하고 있다(파리조약 4D(1)). 그 결과 우선권주장기간은 각국에 따라 다르나, 우리나라 특허법은 예측가능성을 높이기 위해 제54조제3항에서 “우선권주장을 하려는 자는 특허출원을 할 때 출원서에 그 취지, 최초 출원국가명 및 출원연월일을 적어야 한다.”고 하여 출원을 할 때에 우선권주장을 하도록 하고 있다. 한편, 다른 동맹국에 비해 우선권주장출원을 하는 출원인에게 불이익한 점을 보완하여 우선기간은 만족하지만 우선권주장기간은 만족하지 못한 출원인을 보호하기 위하여 제54조제7항에서 우선권주장의 보정 또는 추가를 인정하고 있다.

구 분	우선기간	우선권주장기간
의 의	제2국에 출원할 수 있는 기간	제2국에 출원한 후 우선권주장을 할 수 있는 기간
파리조약	1년	동맹국의 자국법에 일임
특허법 태도	1. 출원과 동시에 우선권주장을 하도록 함(法 54③) 2. 단점(출원인에게 불이익)의 보완 ○ 우선권주장의 보정 또는 추가(法 54⑦)의 인정 ○ 요건 - 조약우선권주장을 한 자 & 우선기간 만족 ○ 효과 - 최우선일로부터 1년 4개월 이내 - 우선권주장의 보정 또는 추가 - 최우선일로부터 1년 4개월 이후 - 명백한 오기의 정정 또는 우선권주장의 취하	

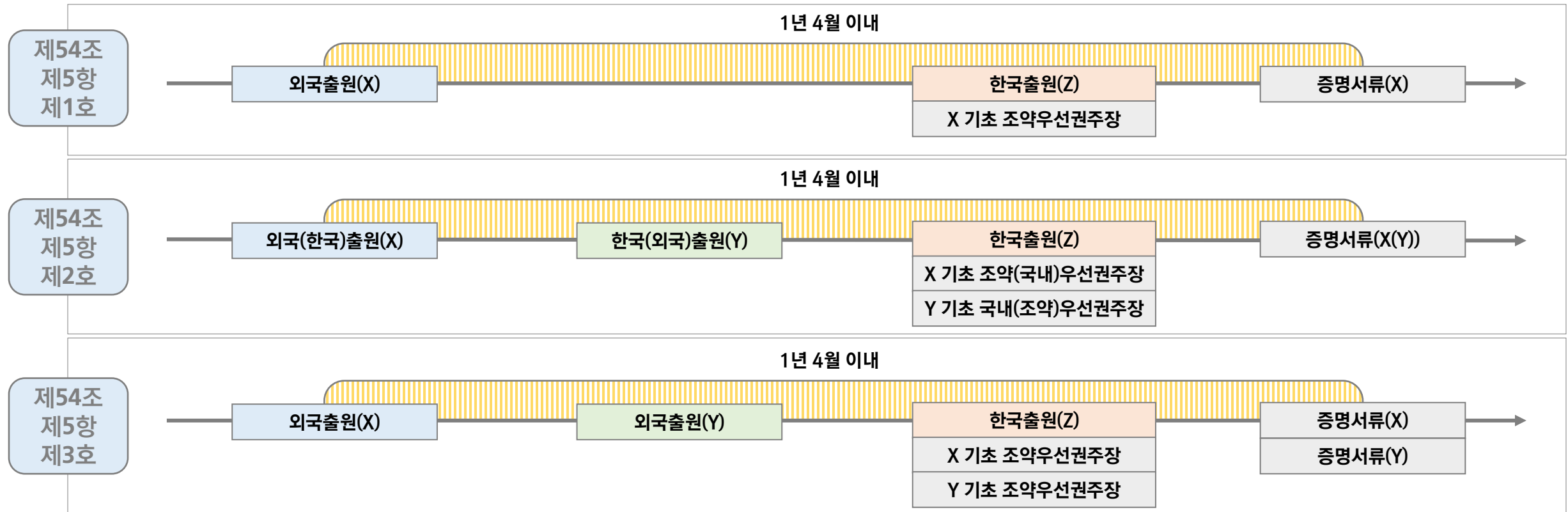


제54조(조약에 의한 우선권 주장) ④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 총리령으로 정하는 국가의 경우만 해당한다.

1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본
2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 총리령으로 정하는 사항을 적은 서면

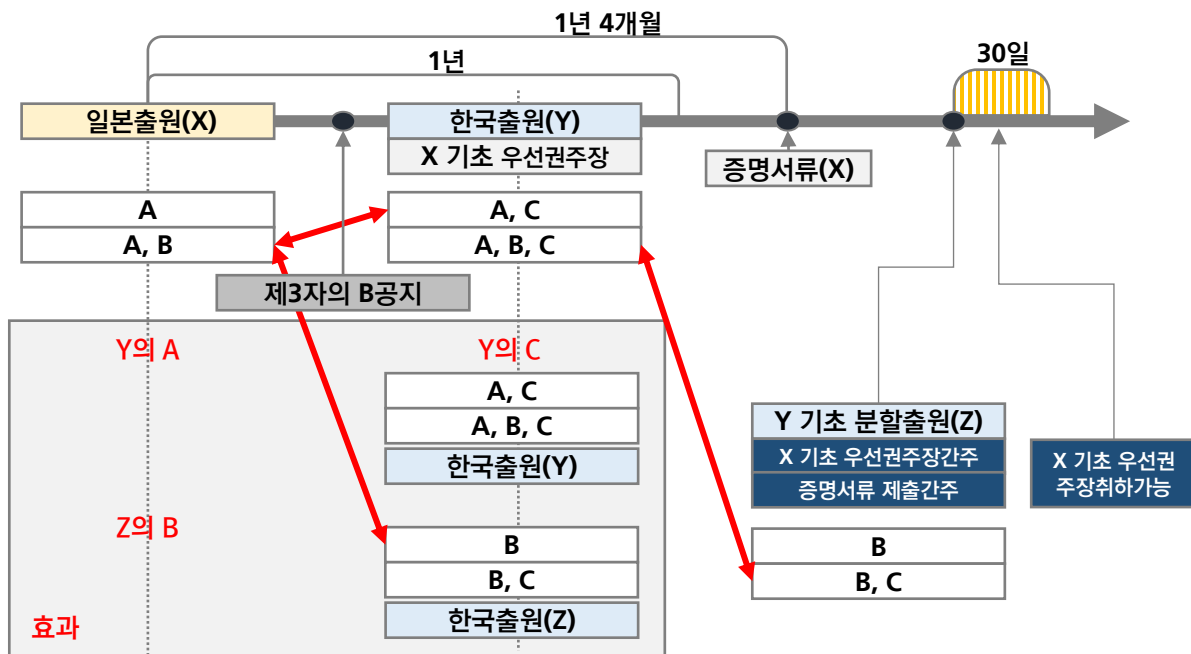
⑤ 제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다.

1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
 2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
 3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
- ⑥ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간에 제4항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다.



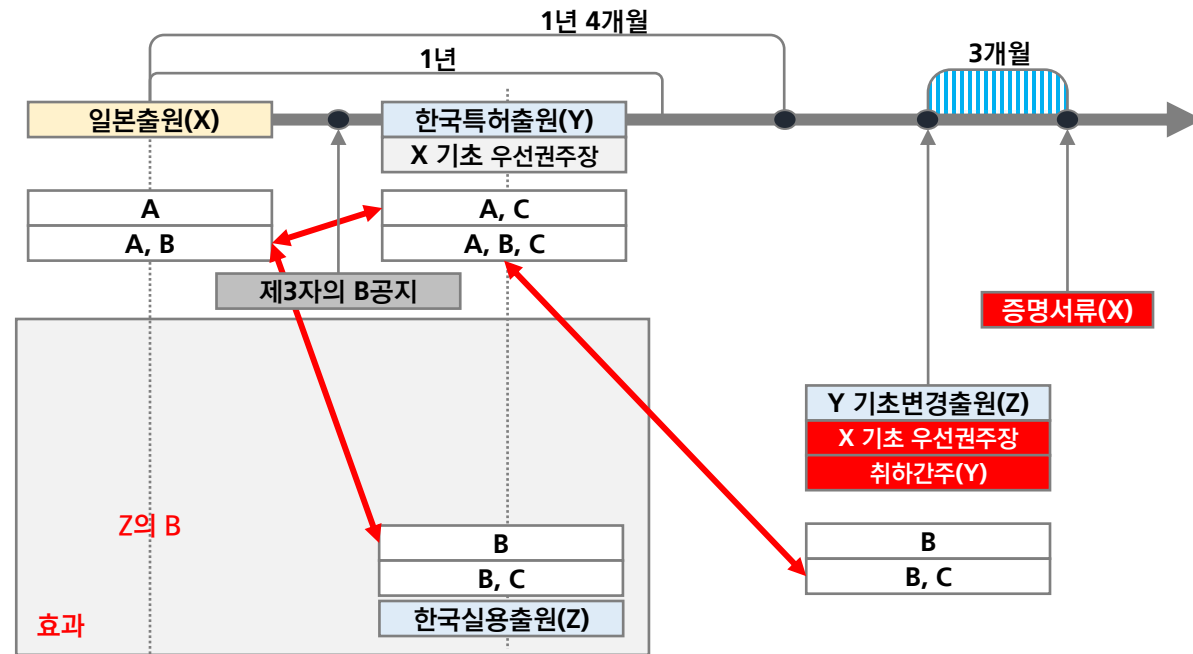
분할출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우

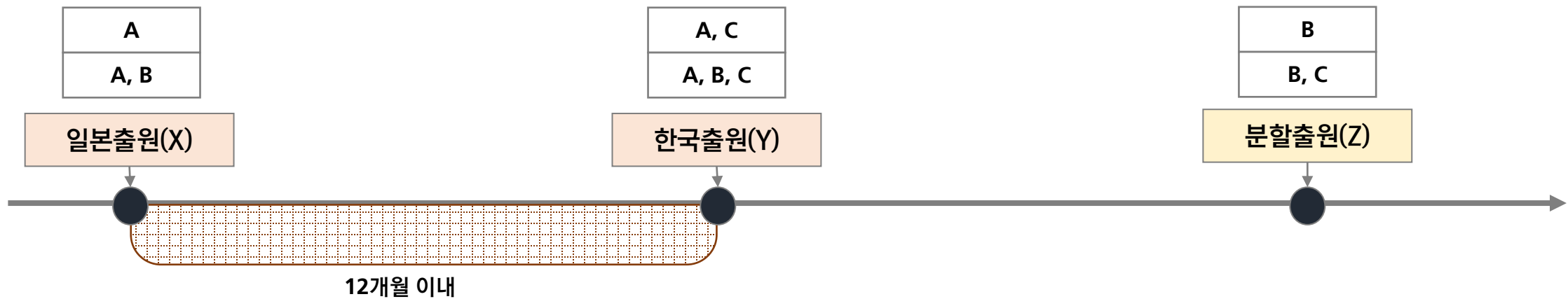
분할출원(Z)은 원출원(Y)의 출원일로 소급효가 인정되는 것을 제외하고는 원출원(Y)과는 별개의 특허출원이다. 따라서 원출원(Y)이 조약우선권주장을 수반하였다고 할지라도 분할출원(Z)이 그 효과를 적용받기 위해서는 분할출원(Z) 역시 우선기간인 1년 이내 출원, 출원할 때 주장(취지 기재) 및 최우선일로부터 1년 4개월 이내 증명서류를 제출하여야 한다. 그런데, 분할출원(Z)이 이와 같은 조약우선권주장을 수반하는 경우에는 출원인의 이익을 위해서 1년의 판단은 Y 출원일을 기준으로 판단하고, 원출원이 조약우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며(자동 주장 간주), 원출원에 대하여 조약우선권주장의 증명서류 제출기간 내 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(자동 증명서류 제출 간주). 다만, 원출원(X)이 최우선일(X)로부터 1년 4개월까지 원출원(Y)에 대한 조약우선권주장의 증명서류를 제출하지 아니한 경우 최우선일(X)로부터 1년 4개월과 분할출원(Z)을 한 날부터 3개월 중 늦은 날까지 분할출원(Z)에 대한 조약우선권주장의 증명서류를 제출할 수 있다.



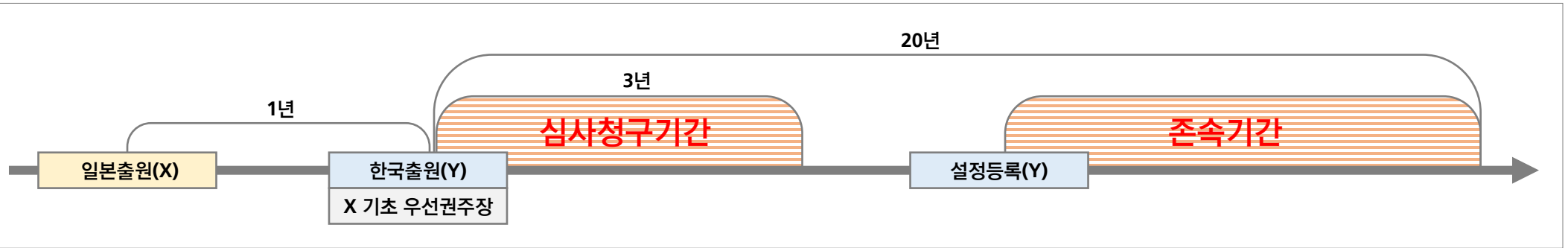
변경출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우

변경출원(Z)은 원출원(Y)의 출원일로 소급효가 인정되는 것을 제외하고는 원출원(Y)과는 별개의 출원이다. 따라서 원출원(Y)이 조약우선권주장을 수반하였다고 할지라도 변경출원(Z)이 그 효과를 적용받기 위해서는 변경출원(Z) 역시 우선기간인 1년 이내 출원, 출원할 때 주장(취지 기재) 및 최우선일로부터 1년 4개월 이내 증명서류를 제출하여야 한다. 그런데, 변경출원(Z)이 이와 같은 조약우선권주장을 수반하는 경우에는 출원인의 이익을 위해서 1년의 판단은 Y 출원일을 기준으로, 취지 기재에 대한 것은 Z 출원일을 기준으로 판단하게 된다. 또한, 증명서류는 최우선일(X)로부터 1년 4개월의 기간이 지난 후에도 변경출원(Z)을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다. 이 경우 변경출원(Z)은 Y 출원일로 출원일의 소급효가 인정되고, 변경출원(Z)의 청구범위에 기재된 B 발명은 X 출원일로 판단시점이 소급하게 된다. 한편, 변경출원(Z)과 동시에 원출원(Y)은 취하간주된다.

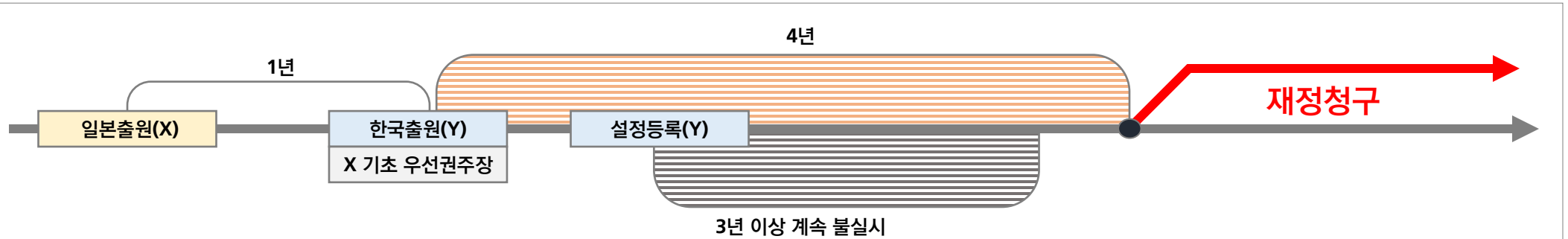
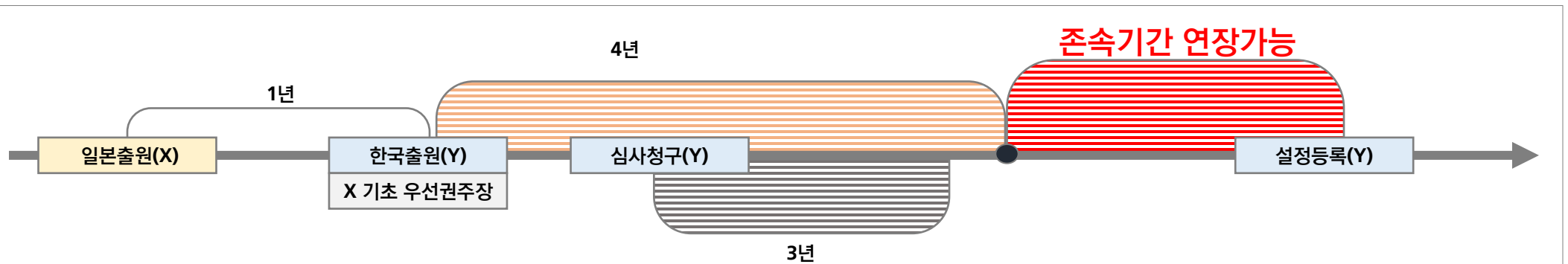




Y출원		Z출원	
조약우선권주장	증명서류제출	조약우선권주장	증명서류제출
×		×(실무상 불인정)	
○	○	자동주장간주 (제2항제3호, 제4항) 우선권주장의 취하 (제5항)	자동제출간주 (제4항)
○	×	자동주장간주 (제2항제3호, 제4항) 우선권주장의 취하 (제5항)	기간의 특례 (제6항)

심사청구
존속기간

재정

등록지연에 따른
존속기간 연장

심

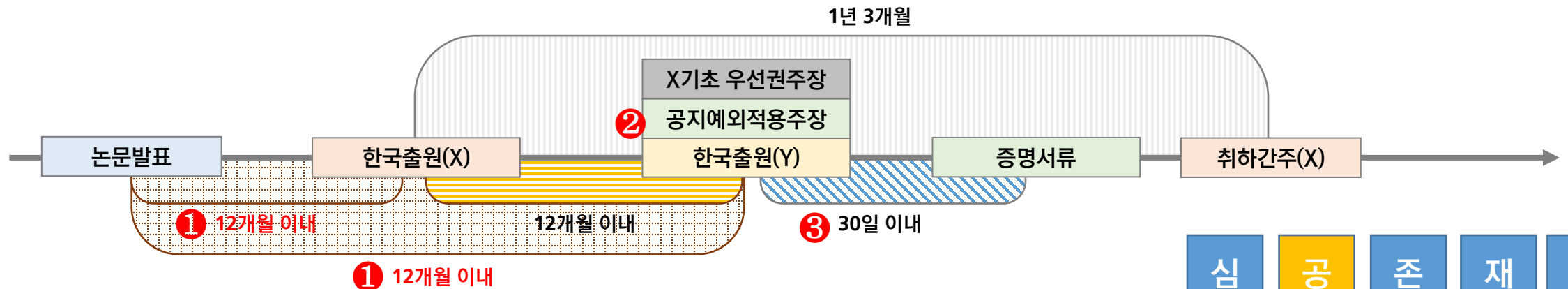
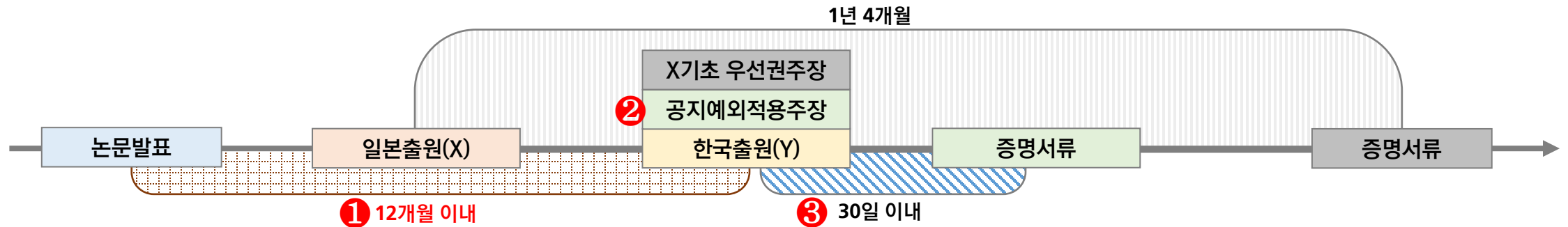
공

존

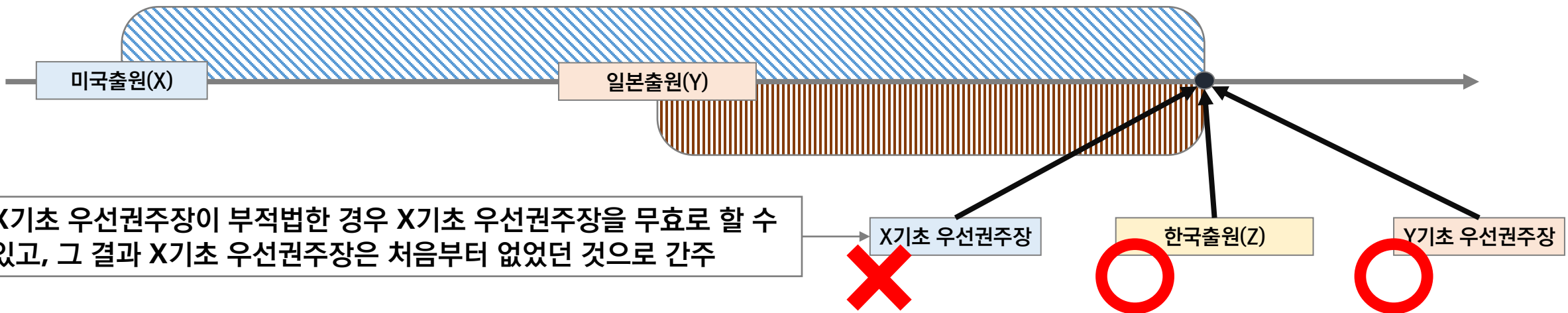
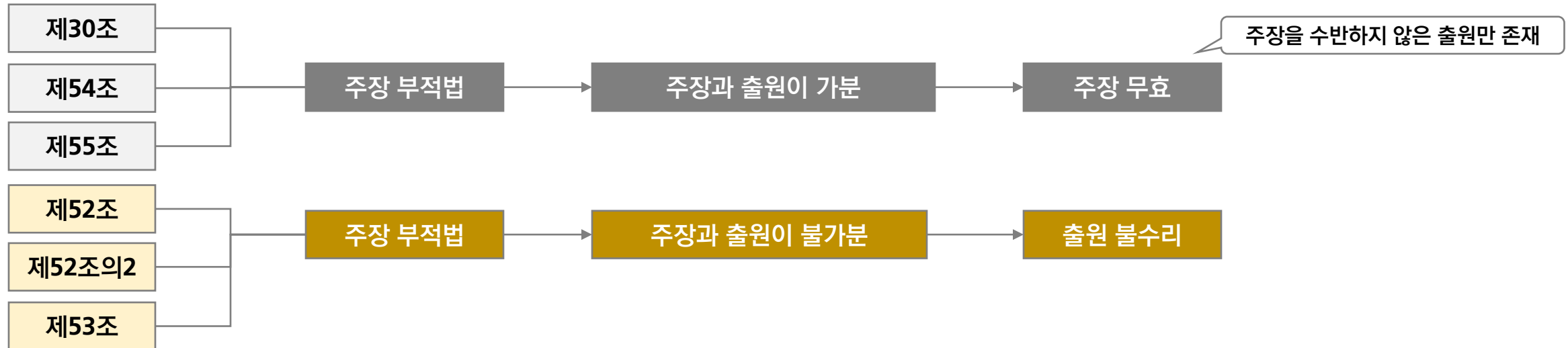
재

등

구 분	① 12개월(法 30①)	②③ 취지기재서면 및 증명서류(法 30②)
분할출원 (法 52②)	소급효 ○	소급효 ×
분리출원 (法 52의2②)	소급효 ○	소급효 ×
변경출원 (法 53②)	소급효 ○	소급효 ×
조약우선권주장출원 (法 54③)	소급효 × (제30조제1항의 "특허출원" 을 국내출원으로 제한해석)	소급효 ×
국내우선권주장출원 (法 55①)	소급효 ○ (단, 판단시점의 소급효가 인정된 발명으로 제한)	소급효 ×

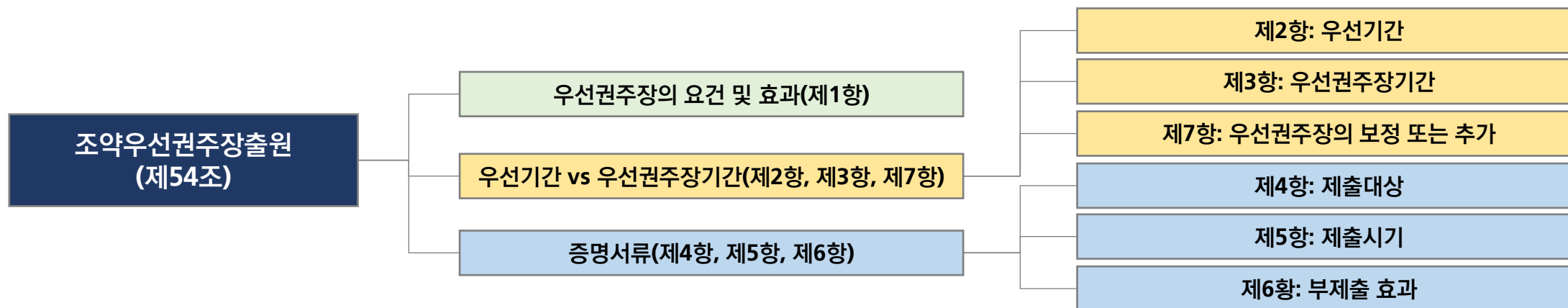


출원인이 공지에외적용주장/우선권주장출원을 하였으나, 공지에외적용주장/우선권주장이 방식에 위반된 경우 지식재산처장은 그 흠결을 지적하여 보정명령을 하고 보정명령에도 불구하고 보정하지 않거나 보정에 의하여 흠결이 치유되지 아니한 경우 그 보정명령을 한 절차인 「공지에외적용주장/우선권주장」을 무효로 할 수 있다. **출원**은 공지에외적용주장/우선권주장을 하지 아니한 출원이 된다.

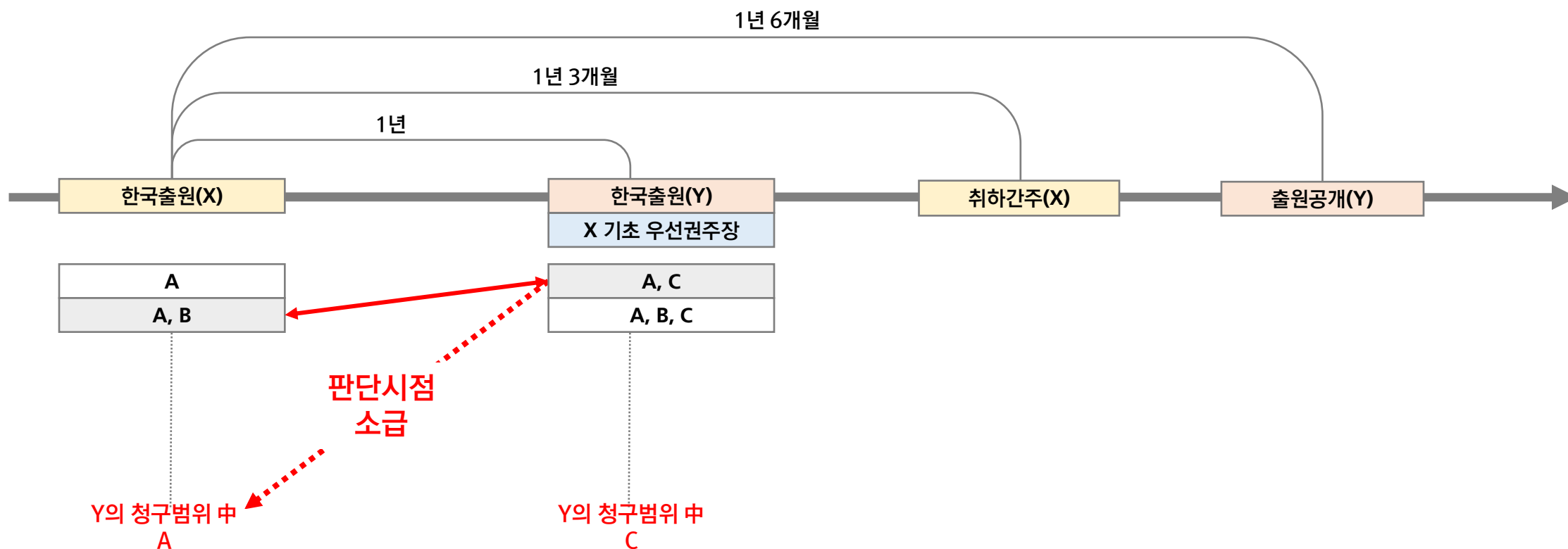


제54조(조약에 의한 우선권 주장) ① 조약에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다.

1. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우
2. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대한민국 국민이 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우
- ② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.
- ③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적어야 한다.
- ④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 총리령으로 정하는 국가의 경우만 해당한다.
 1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본
 2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 총리령으로 정하는 사항을 적은 서면
- ⑤ 제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다.
 1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
 2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
 3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
- ⑥ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간에 제4항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다.
- ⑦ 제1항에 따라 우선권 주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항에 따른 최우선일부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.



국내우선권주장제도를 이용하는 경우 선출원에 포함된 기본발명을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 하였을 때 기본발명과 개량발명을 하나의 출원으로 보 함으로써 기술개발의 진전이 현저한 현 실정에 비추어 포괄적이고 누락없이 발명을 보호할 수 있으며, 출원절차의 간편 및 출원비용의 절감을 통한 출원인의 발명 의욕을 고취시킬 수 있다. 또한, 기본발명의 출원심사청구기간 또는 특허권의 존속기간을 우선기간만큼 연장할 수 있다.

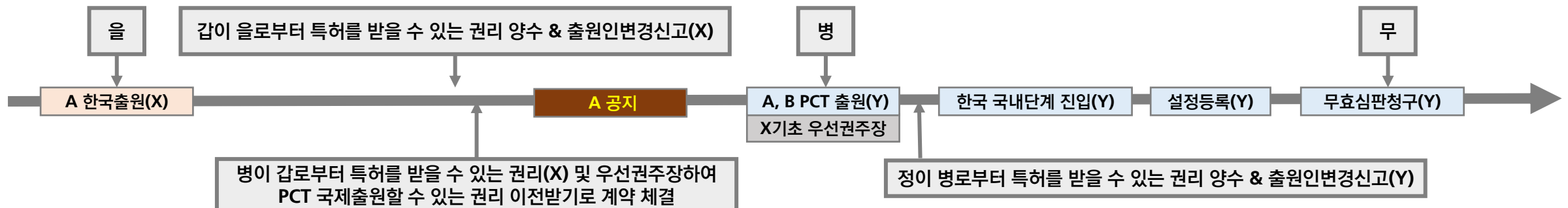


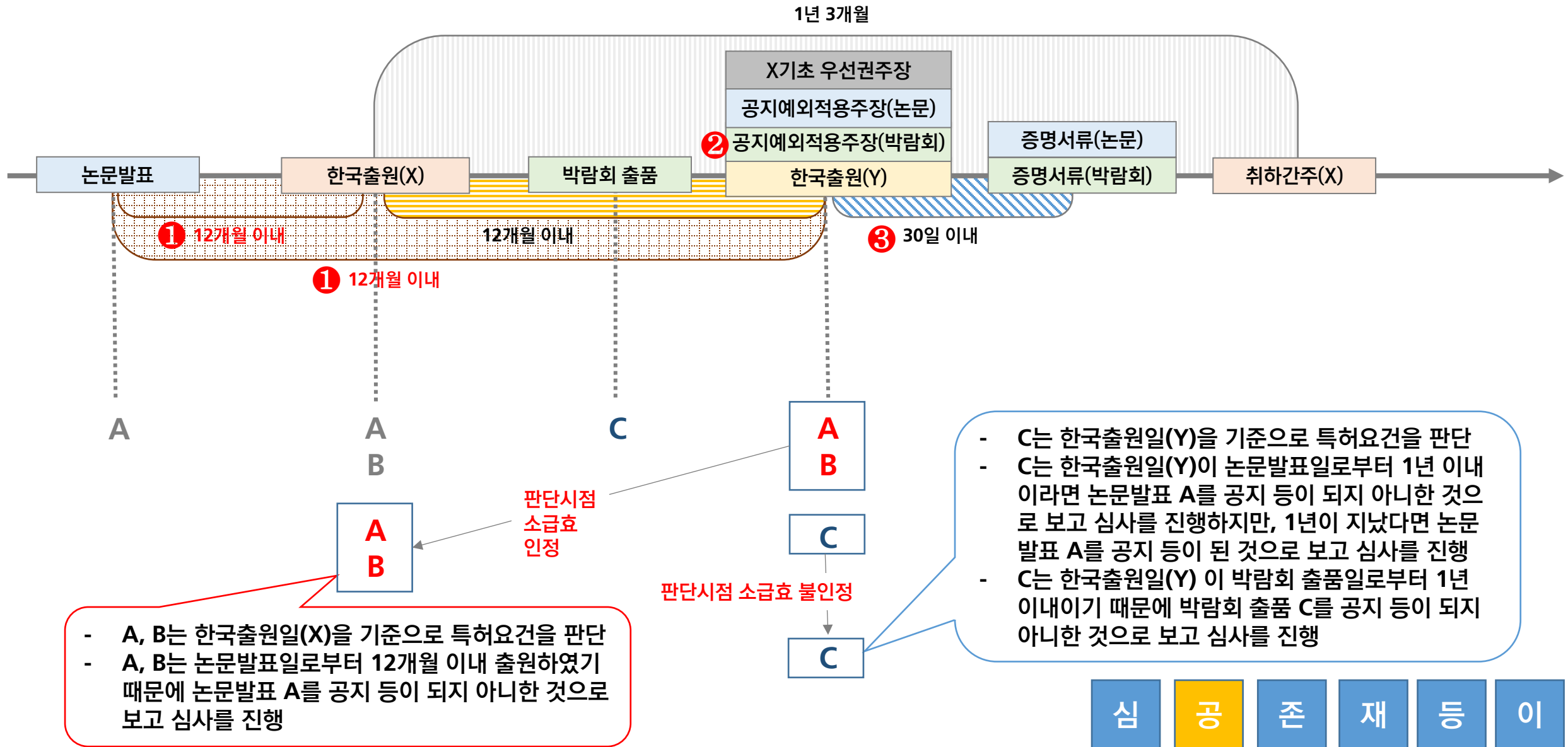
대법원 2019. 10. 17. 선고 2017후1274 판결 【등록무효(특)】

...(중략)...이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다. 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. 고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

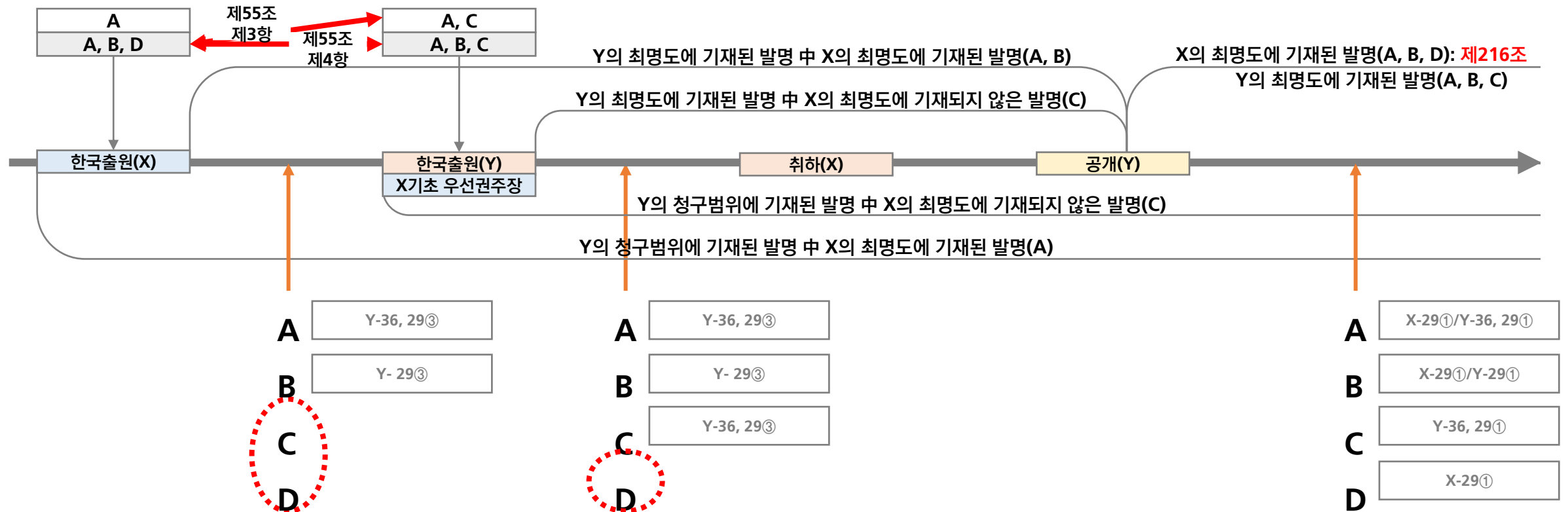
① PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제8조 (2)(b)에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 한다. 지식재산처장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로(특허법 시행규칙 제7조 제1항), 필요한 경우 보완을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있다. 그리고 특허법 제38조 제4항을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없다. 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 된다. 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 된다.

② 특허법 제55조 제1항은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 ‘특허를 받으려는 자’라고 규정하고 있을 뿐이다. 이는 특허법이 분할출원(제52조)과 실용신안등록출원의 변경출원(제53조)을 할 수 있는 자는 ‘출원인’이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비된다. 발명을 한 자의 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로(특허법 제33조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 특허법 제55조 제1항의 ‘특허를 받으려는 자’ 및 ‘자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당한다고 봄이 문리해석에 부합한다. 특허출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정한 특허법 시행규칙 제26조 제1항도 이러한 해석을 뒷받침한다.





국내우선권주장을 수반하는 특허출원(후특허출원)의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 **그 특허출원(후특허출원)이 출원공개되거나 등록공고된 때에 그 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고** 확대된 선출원(法 29③④각 호 외의 부분 본문 또는 實用 4③각 호 외의 부분 본문)의 규정을 적용한다(法 55④). 한편, 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되지 아니한 발명은 우선권주장 출원일의 다음날로부터 우선권주장출원의 출원공개 또는 등록공고 전에 출원된 제3자의 발명에 대하여 확대된 선출원을 적용한다. 국내우선권주장출원의 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월을 지난 때에 일반적으로 출원공개되지 않고 취하간주되기 때문에 선출원의 지위, 확대된 선출원의 지위가 인정되지 아니한다. 다만, 후출원이 출원공개 또는 설정등록된 때에는 국내우선권주장출원의 적법성을 판단하기 위해서 선출원의 열람을 허가하고 있기 때문에(法 216) 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명의 공지기술의 지위가 인정된다.

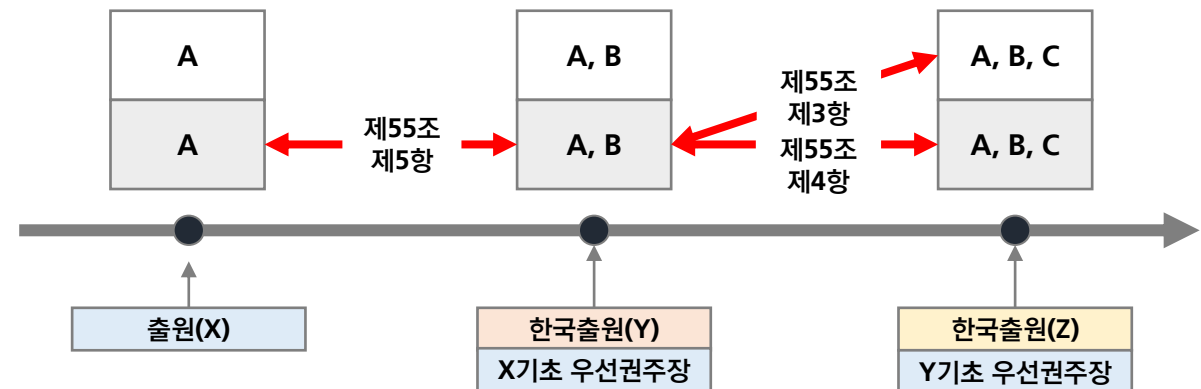
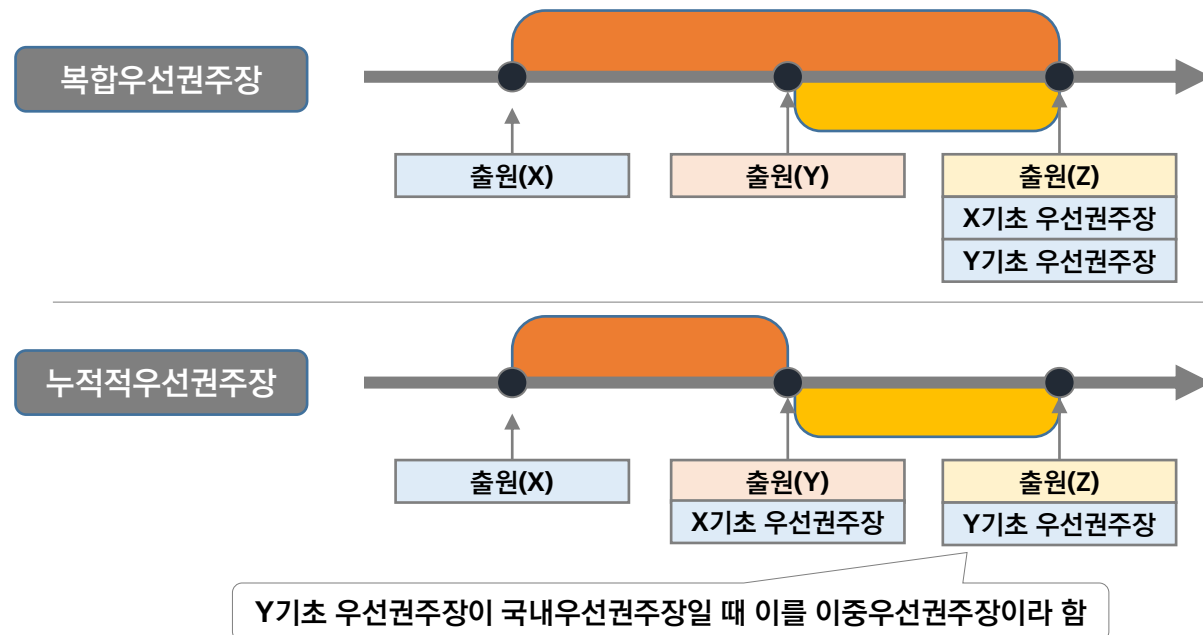


제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 및 제136조제5항(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다.

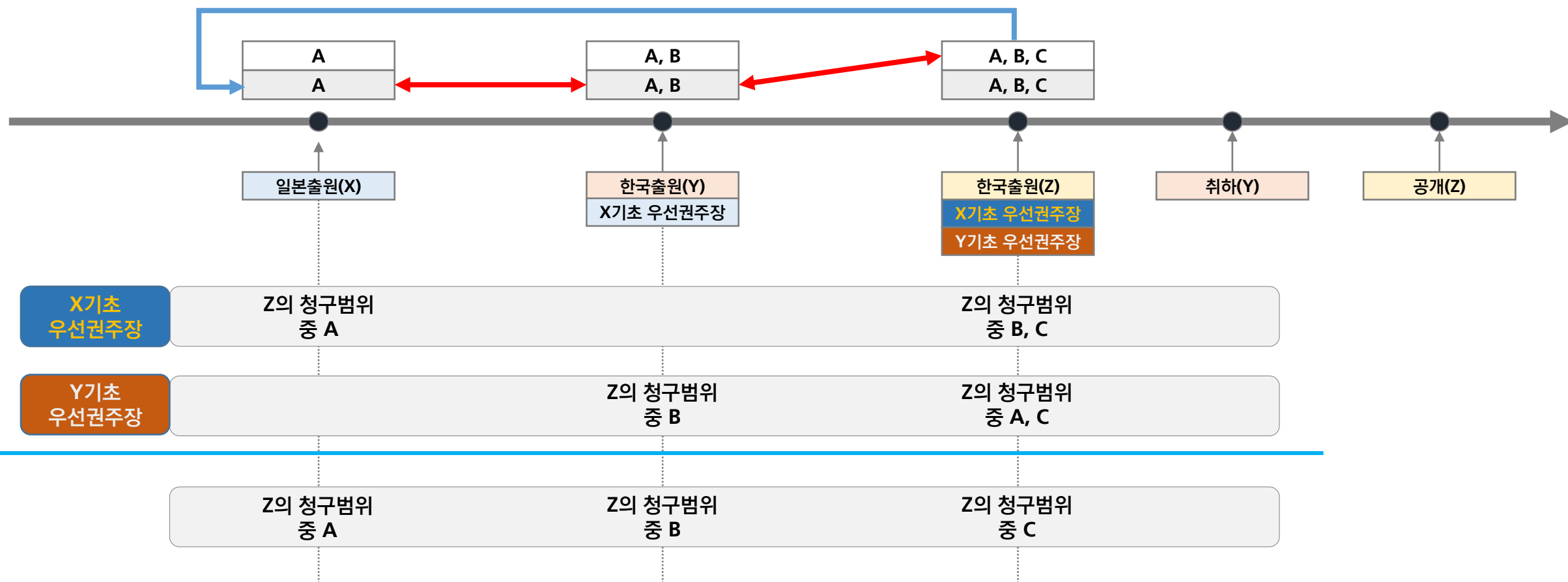
④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다.

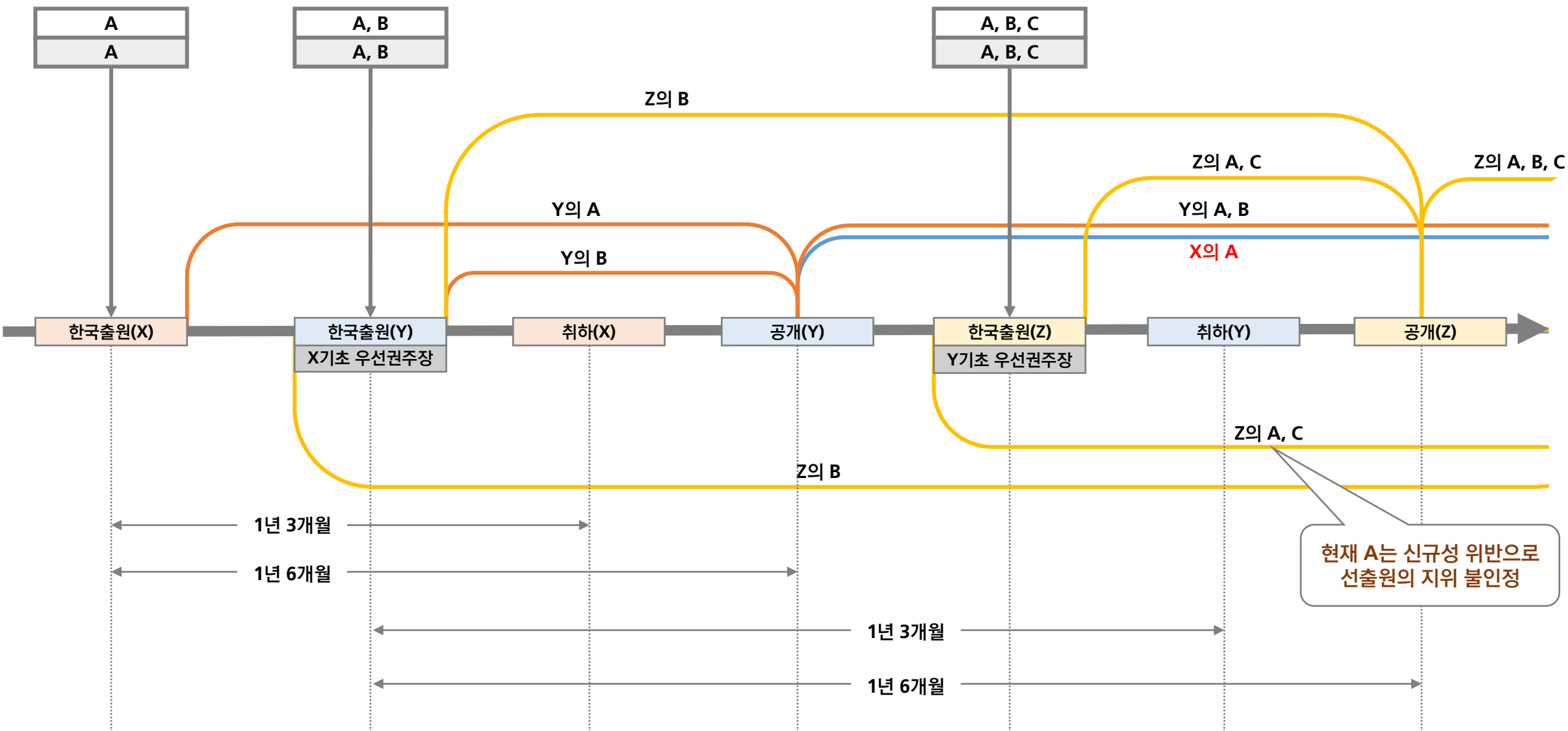
⑤ 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다.

1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
2. 선출원이 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우



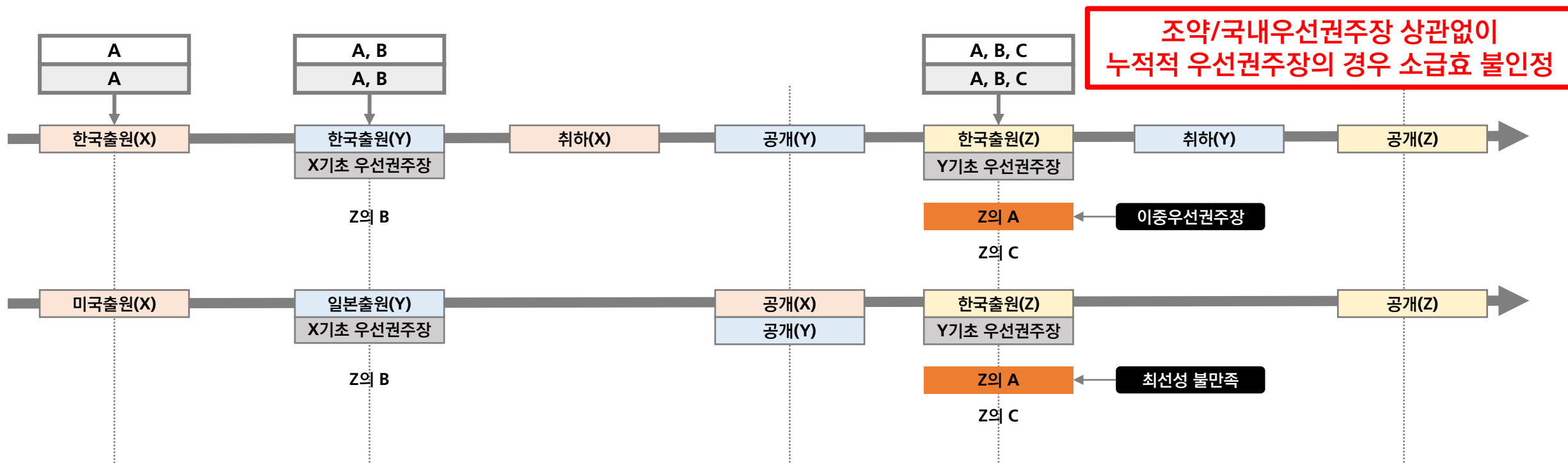
Z 출원은 X 기초와 Y 기초의 복합우선으로서 우선권주장에 의한 소급효 여부는 X 기초에 의한 우선권주장과 Y 기초에 의한 우선권주장을 각각 별도로 판단한 후 출원인에게 유리하게 해석하여야 한다. 먼저, X 기초의 우선권주장은 Z출원의 청구범위에 기재된 A, B, C 발명 중 X출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 A 발명만 X 출원일로 판단시점이 소급되고, 그렇지 아니한 B, C 발명은 판단시점이 소급되지 아니한다. 다음으로, Y 기초의 우선권주장은 Z출원의 청구범위에 기재된 A, B, C 발명 중 Y출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 B 발명만, Y 출원일로 판단시점이 소급되고 그렇지 아니한 C 발명은 판단시점이 소급되지 아니한다. 한편, A 발명은 Y 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있으나 제55조제5항의 이중우선으로 판단시점이 소급되지 아니한다. 따라서 **Z출원 발명의 특허요건은 A 발명은 X 출원일을 기준으로, B 발명은 Y 출원일을 기준으로, C 발명은 Z 출원일을 기준으로 판단**하게 된다.





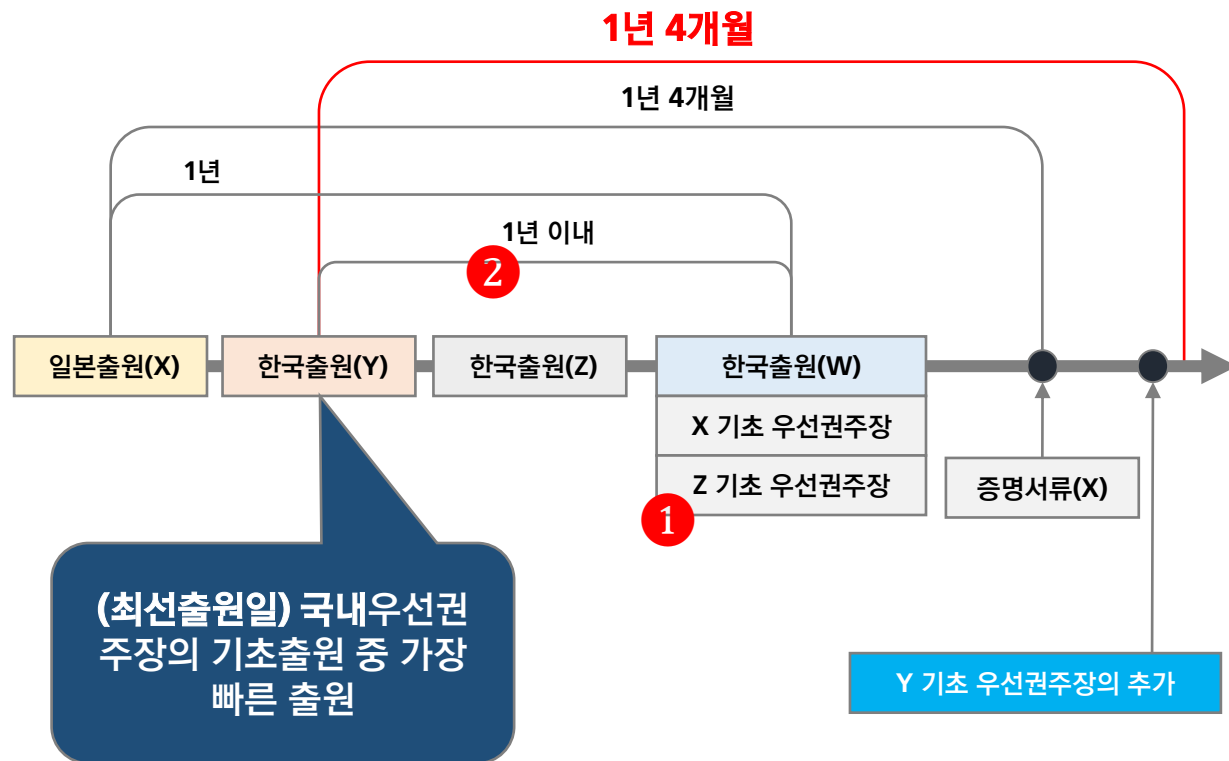
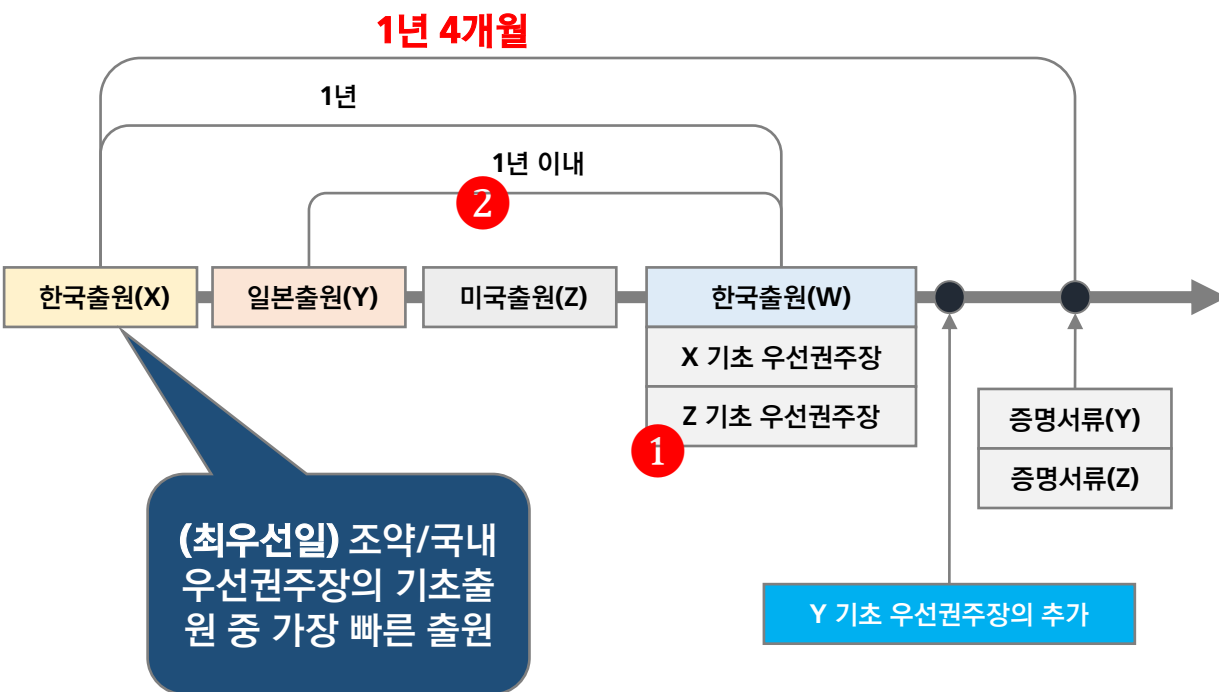
특허법원 2006. 2. 9. 선고 2004허8749 판결 【등록무효】

특허법 제54조는 ‘① 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. ② 제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 1년 이내에 특허출원하지 않으면 이를 주장할 수 없다’고 규정하고 있다. 이러한 특허법의 관련 규정에 비추어 보면, 조약에 의한 우선권 주장을 인정받기 위해서는 ① 제1국 출원이 정규의 최초의 출원이어야 할 것, ② 제1국 출원과 제2국 출원이 동일한 발명이어야 할 것, ③ 제2국 출원이 제1국 출원일로부터 1년 이내에 이루어져야 할 것 등의 요건을 모두 충족시켜야 하므로, 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 제2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 출원이 아니거나(즉, 제1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고) 그 제2국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1년)을 경과하여 이루어진 경우에는, 제2국 출원에 기재된 발명 중에 전출원과 제1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 않는데, 이는 제2국 출원이 제1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선일의 소급 효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다. 따라서, 제2국 출원의 우선권 주장이 인정받지 못하고 그 우선권 주장의 기초가 된 제1국 출원이 제2국 출원일 이전에 공개되었을 경우에는, 제2국 출원은 제1국 출원에 기재된 내용에 의하여 신규성을 상실하게 된다.

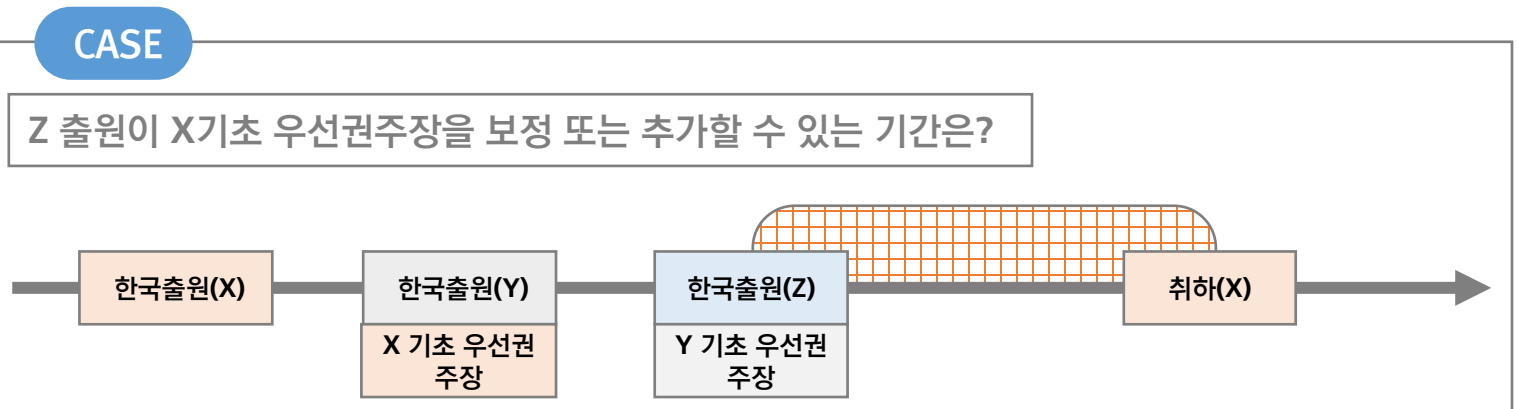
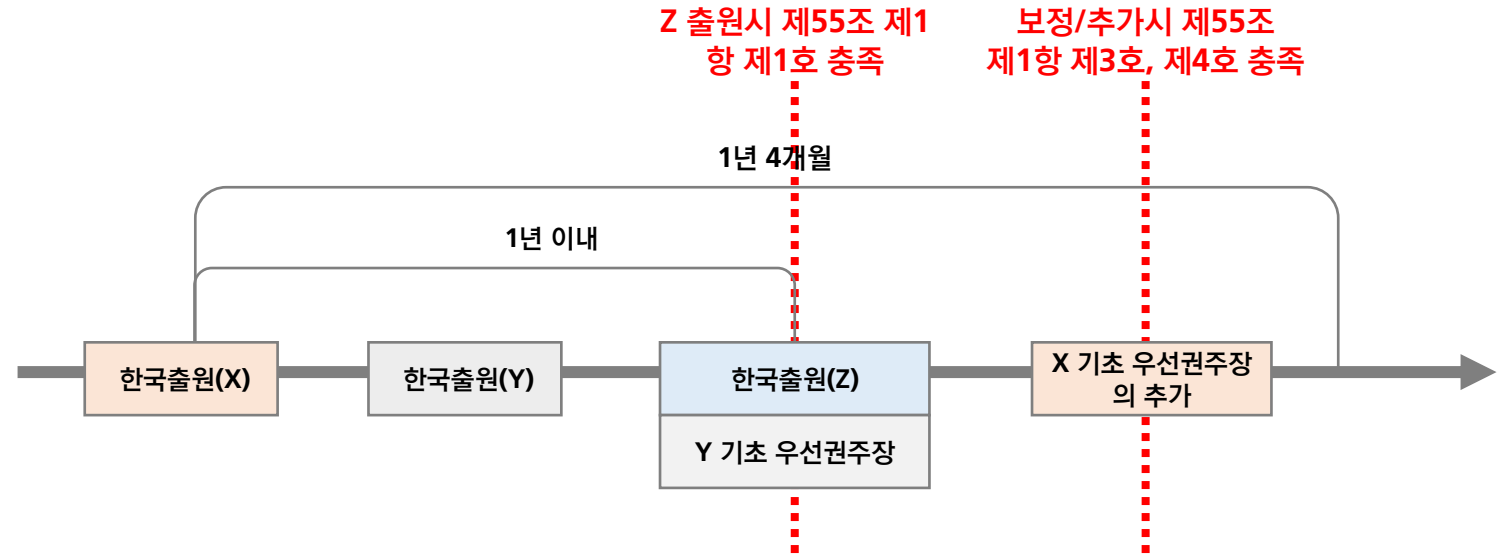
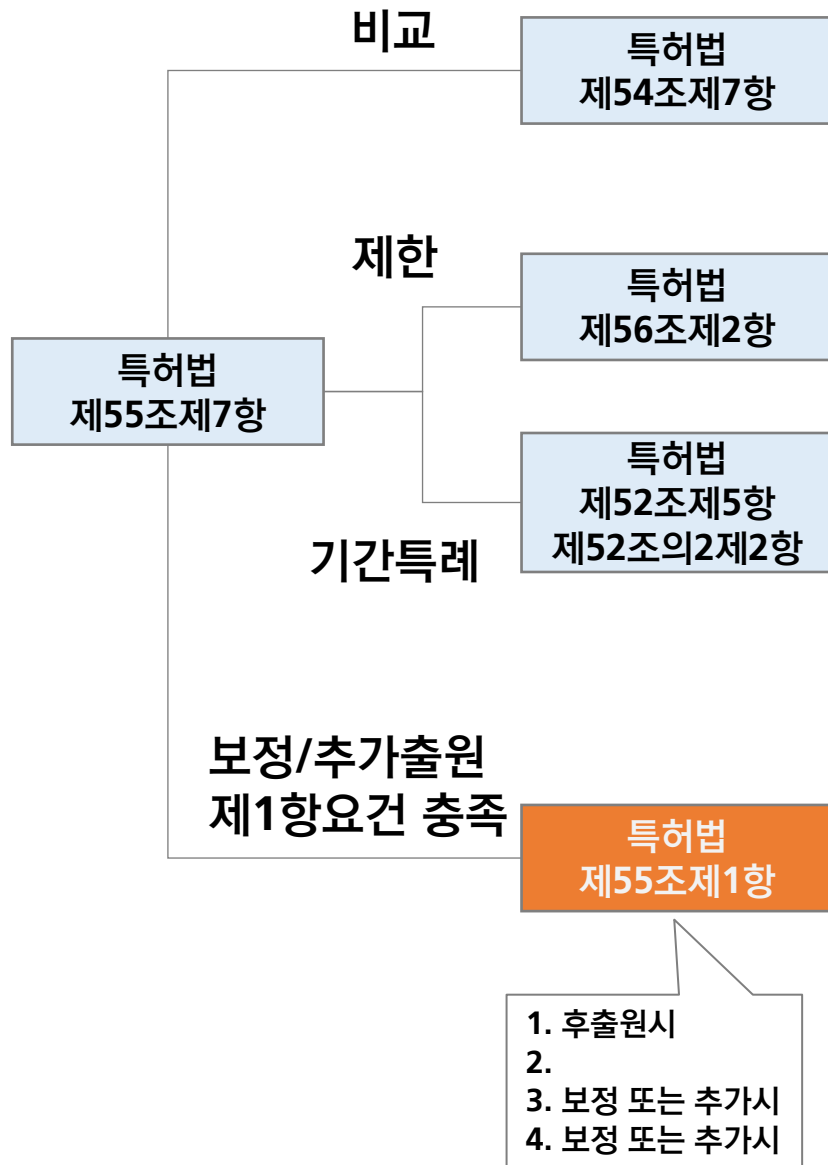


제54조(조약에 의한 우선권 주장) ⑦ 제1항에 따라 우선권 주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항에 따른 **최우선일**부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ⑦ 제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원이 둘 이상인 경우에는 **최선출원일**을 말한다)부터 1년 4개월 이내에 그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

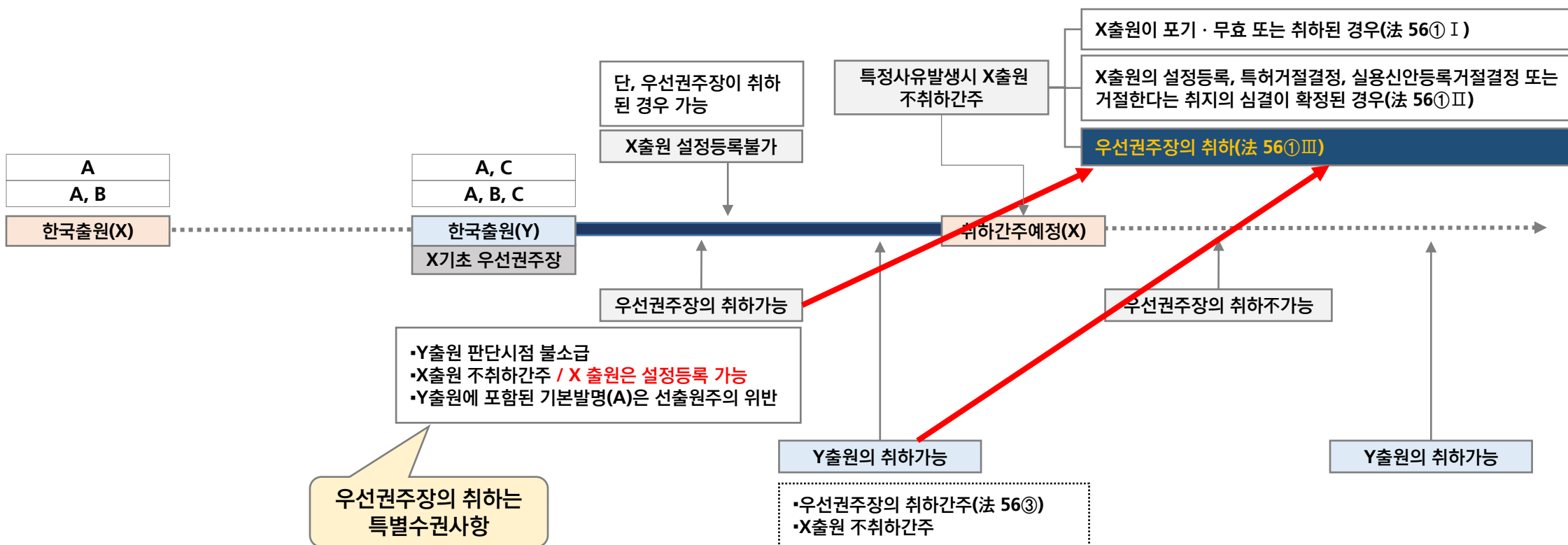


제55조제1항의 요건 중 **우선기간 1년**의 판단시점은 후출원(W) 시이고, **우선권 주장출원할 때에 선출원이 무효, 취하 또는 포기되거나 설정등록, 거절결정이 확정되지 아니하였을 것**은 국내우선권주장의 보정 또는 추가시를 기준으로 판단한다



제56조(선출원의 취하 등) ① 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
 2. 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
 3. 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우
- ② 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다.
- ③ 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다.



제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

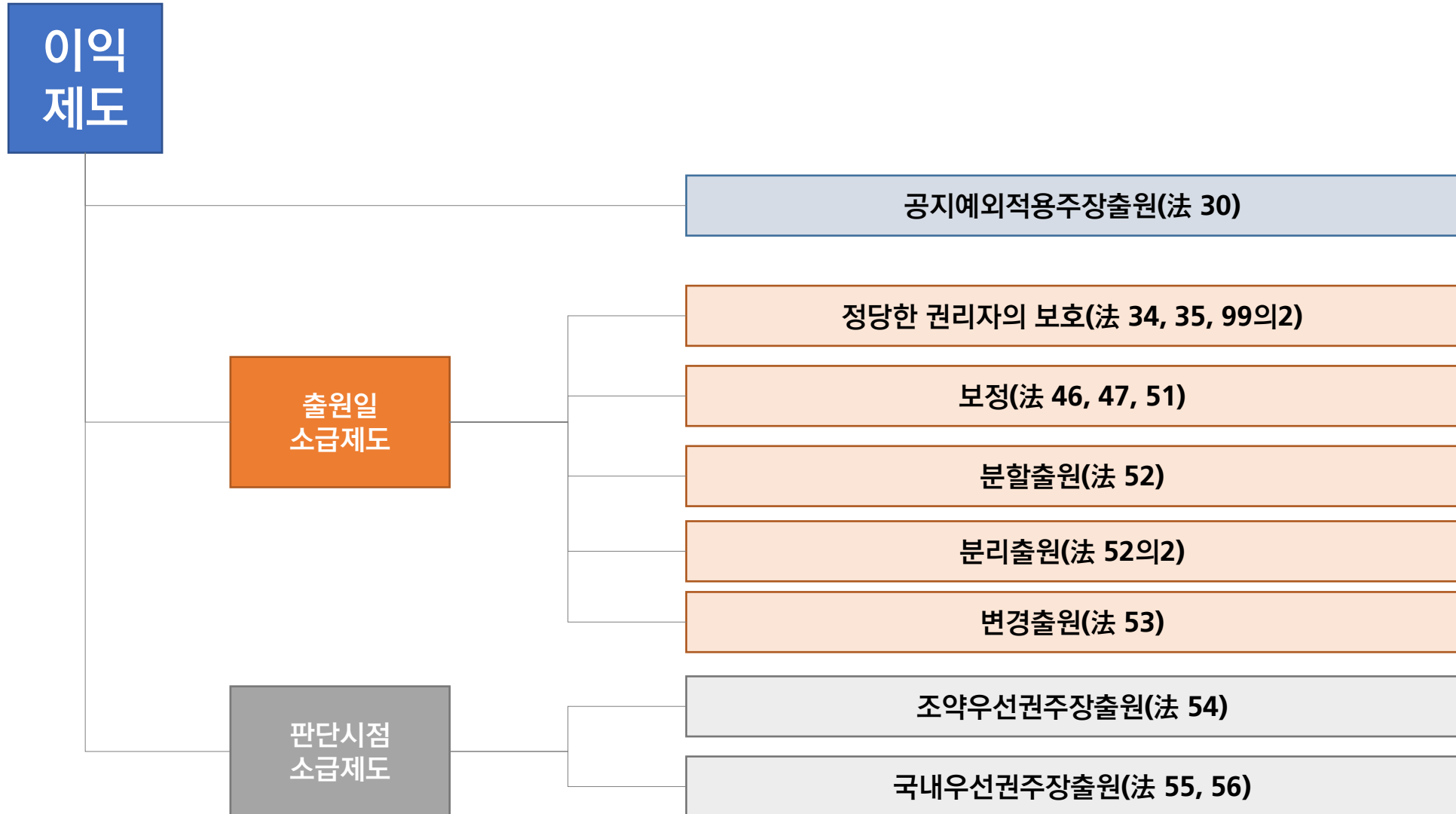
1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우
 2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원 또는 **제52조의2제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분리출원이거나** 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우
 3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
 4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
- ② 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, **같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문, 제30조제1항**, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 및 제136조제5항(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다.
- ④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공개되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문, **같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문**을 적용한다.
- ⑤ 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다.
1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
 2. 선출원이 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
- ⑥ 제4항을 적용할 때 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하더라도 제29조제7항을 적용하지 아니한다.
1. 선출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원인 경우
 2. 선출원이 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원인 경우
- ⑦ 제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원이 둘 이상인 경우에는 최선출원일을 말한다)부터 1년 4개월 이내에 그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.
- ⑧ 제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다.

소급효의 예외	제34조, 제35조	제52조	제52조의2	제53조	제54조	제55조	기간의 특례	제34조, 제35조	제52조	제52조의2	제53조
확 대된 선출원에서 다른 출원의 지위	X	○	○	○			청 구범위 제출 유예기간의 특례(30일)	X	○	X	○
공 지에외적용주장을 수반하는 경우 그 취지 및 증명서류	X	○ (1년은 인정)	○ (1년은 인정)	○ (1년은 인정)			변 역문 제출기간의 특례(30일)	X	○	X	○
조 약우선권주장을 수반하는 경우 그 취지	X	○ (1년은 인정) (자동간주)	○ (1년은 인정) (자동간주)	○ (1년은 인정)			조 약우선권주장 증명서류 제출기간의 특례(3월)	X	○ (단, 자동 간주)	X (단, 자동 간주)	○
국 내우선권주장을 수반하는 경우 그 취지	X	○ (1년은 인정) (자동간주)	○ (1년은 인정) (자동간주)	○ (1년은 인정)			우 선권주장취하기간의 특례(30일)	X	○	○	X
등 록지연에 따른 존속기간연장의 경우 출원일의 기산	○	○	○	○			심 사청구기간의 특례(30일)	○	○	○	○
심 사청구할 때 출원일의 기산					○	○					
공 지에외적용주장을 수반하는 경우 그 취지 및 증명서류					○ (1년도 불인정)	○ (1년은 발명단위로 인정)					
존 속기간 만료일의 기산					○	○					
재 정에 있어서 불실시, 불충분실시의 경우 출원일의 기산					○	○					
등 록지연에 따른 존속기간연장의 경우 출원일의 기산					○	○					
이 중우선권주장된 발명의 소급효 및 확대 된 선출원에서 다른 출원의 지위					X (최선성)	○					

출원(X) → 출원(Y) → 출원(Z) →					
Y 출원 \ Z 출원	분할출원	분리출원	변경출원	조약우선권주장출원	국내우선권주장출원
분할출원	가능*	가능*	가능*	외국법이 국내법과 동일하지 아니하기 때문에 논의 실익 ×	불가능(∵요건 불만족하여 무효처분)
분리출원	불가능(불수리)	불가능(불수리)	불가능(불수리)		
변경출원	가능*	가능*	가능*		
조약우선권 주장출원	가능(우선기간(1년) - 소급효 ○, 취지 - 소급효 ×)			최선성 요건 불만족하여 무효처분 (∵ 우선기간의 실질적 연장을 방지)**	요건 만족하지만 이중우선으로 소급효의 예외 인정 (∵ 우선기간의 실질적 연장을 방지)
	자동주장간주	자동주장간주	출원과 동시에 주장		
	자동증명서류제출간주/ 증명서류제출기간 특례	자동증명서류제출간주	증명서류제출기간 특례		
국내우선권 주장출원	가능(우선기간(1년) - 소급효 ○, 취지 - 소급효 ×)				
	자동주장간주	자동주장간주	출원과 동시에 주장		

* X 출원과 Y 출원 사이에 분할(분리, 변경)출원의 요건을 만족하고 Y 출원과 Z 출원 사이에 분할(분리, 변경)출원의 요건을 만족하며, Z 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 X 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 범위내이면, Z 출원이 X 출원의 출원일로 소급

** 다만, Z 출원에 포함된 발명 중 X 출원에 기재되어 있지 않지만, Y 출원에 새로이 추가된 발명이 있는 경우에는 그 추가된 발명은 최선성이 있기 때문에 우선권주장을 무효처분하는 것이 아니라 그 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정(2004허8749).



제 도		法 30	法 34, 35	法 47, 51	法 54	法 55, 56
요건	주체	특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 공지가 되었을 것	무권리자의 출원/특허	1.공동출원의 경우 각자 2.임의대리인은 특별히 권한 위임 不要	1.대한민국 국민, 조약당사국 국민, 준당사국 국민 2.특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있다면 출원인의 동일성 불필요(승계인은 우선권 별도 승계)	1.특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있다면 출원인의 동일성 불필요 2.임의대리인은 특별히 권한 위임 要
	객체	공지가 법 제30조 제1항 각호에 해당 ①의사에 의한 공지(단, 출원공개/등록공고제외) ②의사1. 2에 반한 공지	정·명·도가 무·최·명·도에 기재된 범위내일 것	1.법47①본, I -신규사항추가금지(法 47②) 2.법47①IIⅢ ①신규사항추가금지(法 47②) ②청구범위 보정범위 제한(法 47③) ③보정에 의하여 새로운 거절이유 발생 X	1.선출원의 요건 ①최선성 ②정규성 ③형식제한 x-디자인○ 2.우선권출원의 요건 후·청구범위가 선·최·명·도에 기재된 범위내일 것	1.선출원의 요건 ①후출원당시 선출원이 출원계속중일 것 ②분할·분리·변경출원이 아닐 것 ③형식 제한 ○-디자인 x 2.우선권출원의 요건 후·청구범위가 선·최·명·도에 기재된 범위내일 것
	시기	최선의 공지일로부터 12월 이내 출원	1.특허를 받지 못한 경우(法34)-무권리자의 출원 후 거절결정이 확정된 날로부터 30일 이내 2.착오로 특허를 받은 경우(法35)-무권리자의 출원 후 무효심결 확정일로부터 30일 이내	1.원칙→특허결정등본 송달 받기전 2.예외 ①최초거절이유통지받은 경우 의견서제출기간 ②최후거절이유통지받은 경우 의견서제출기간 ③재심사를 청구할 때	1.동종우선-제1국 출원일로부터 1년 이내 2.이종우선-제1국 출원일로부터 6개월 이내	선출원의 출원일로부터 1년 이내
절차		법30① I의 경우 출원서에 취지 기재하고 출원일로부터 30일 이내 증명서류 제출(다만, 보완수수료를 납부한 경우 보정기간 또는 특허결정등본송달일로부터 3개월이나 설정등록일까지)	정당한 권리자임을 증명하는 서류 첨부	1.보정서 제출+수수료 납부 2.최초/최후거절이유통지에 대응한 의견서 제출기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하	1.출원과 동시에 취지, 출원국가명, 출원연월일 기재(法54③) 2.우선권주장의 보정 또는 추가(法54⑦) 3.우선권증명서류를 최우선일로부터 1년 4월 이내 제출(法54④⑤⑥)	1.출원과 동시에 취지, 선출원의 표시(法55②) 2.우선권주장의 보정 또는 추가(法55⑦)-단, 1년 3월 지난 후에는 우선권주장의 취하 不可 3.증명서류제출 불요
효과	적법	공지 등이 되지 아니한 것으로 간주	1.무권리자 출원일로 소급 2.단, 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장 시 특허출원일의 기산일은 불소급 3.심사청구기간의 특례-무권리자 출원일로부터 3년 지난 경우 정당한 권리자출원일로부터 30일 이내	소급효	1.판단시점의 소급효(심공존재등) 2.확대된 선출원의 적용은 국내우선권주장출원과 동일	1.판단시점의 소급효(심공존재등이) 2.확대된 선출원 3.우선권주장의 취하금지 및 간주
	부적법	1.공지예외적용주장의 무효 2.출원은 공지기술에 의하여 신규성, 진보성 판단	1.소급효 불인정(단, 무권리자의 출원에 의하여 거절결정되지 않음) 2.청구범위제출유예기간 지난 경우 불수리	1.기간경과-불수리 2.법47①본, I 시기 범위 위반-거절이유 3.법47①IIⅢ시기 범위 위반-보정각하(단, 예외 존재)	1.우선권주장의 무효 2.출원은 실제출원일을 기준으로 판단	
협의제 회피			무권리자 출원의 선출원 지위 불인정		선출원이 외국출원이므로 협의제 회피 不要	선출원일로부터 1년 3월 지난 후 선출원의 취하간주(단, 예외 존재) / 선출원등록불가
외국어 출원						
특례		기준일 지난 후 30일 이내 취지 및 증명서류 제출		1.시기-수수료납부+변역문제출+기준일 후 2.범위-원문&번역문(오역정정이 있는 정정된 국어번역문) 또는 도면(설명X)	PCT 제8조 (1),(2)(a)를 적용(法 199②)	PCT 제8조 (1),(2)(b)를 적용(法 55, 56, 202)

제 도		法 52	法 52의2	法 53
요 건	주체	분할출원당시 원출원인 또는 그 승계인과 분할출원인이 동일인	분리출원당시 원출원인 또는 그 승계인과 분리출원인이 동일인	1.변경출원당시 원출원인 또는 그 승계인과 변경출원인이 동일인 2.임의대리인은 특별수권 要
	객체	1.원출원의 요건 ①분할출원당시 지식재산처에 적법하게 계속중 ②분리출원이 아닐 것 ③원출원의 최·명·도에 2이상의 발명 포함 2.분할출원의 요건 분·명·도가 원·최·명·도에 기재된 범위에내일 것	1.원출원의 요건 ①분리출원당시 지식재산처에 적법하게 계속중 ②분리출원이 아닐 것 2.분리출원의 요건 ①분·명·도가 원·최·명·도에 기재된 범위에내일 것 ②분리출원의 경우 청구범위에 기재된 청구항이 다음의 i) 내지 iv) 어느 하나에 해당할 것 i) 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항, ii) 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항, iii) i) 또는 ii)에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항, iv) i)부터 iii)까지 중 어느 하나의 청구항에서 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항	1.원출원의 요건 ①변경출원당시 지식재산처에 적법하게 계속중 ②분리출원이 아닐 것 2.변경출원의 요건 변·명·도가 원·최·명·도에 기재된 범위에내일 것
	시기	1.법47①에 의하여 보정할 수 있는 기간 2.거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(연장된 경우에는 연장된 기간) 이내 3.특허결정등본을 송달받은 날부터 3개월 기간(다만, 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)	거절결정불복심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간)	실용신안등록출원후 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(연장된 경우에는 연장된 기간)
절차		그 취지 및 원출원 표시를 한 분할·분리·변경출원서와 명세서, 필요한 도면 및 요약서 제출		
		원출원이 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 자동 주장 간주하며, 원출원에 대하여 조약우선권주장증명서류 제출기간 내 증명서류 제출이 있는 자동 제출간주. 이 경우 우선권주장의 보정 또는 추가기간이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내 우선권 주장의 전부 또는 일부 취하가능		변경출원과 동시에 우선권주장을 하고 증명서류를 별도로 제출
효 과	적법	1.출원일의 소급효(확공조국등) 2. 원출원과의 독립성. 단 심사순서는 지식재산처장이 정하는 바에 의함 / 원출원이 우선권주장하지 않은 경우 분할·분리·변경출원도 불가 3. 심사청구기간의 특례 - 원출원일로부터 3년 지난 후라도 분할출원, 분리출원, 변경출원일로부터 30일 이내 4. 국내우선권주장출원과의 관계 - 분할출원, 분리출원, 변경출원은 국내우선권주장출원의 선출원 불가 5.분할출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우에는 최우선일로부터 1년 4개월의 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 증명서류 제출 6.청구범위제출유예기간이 지난 후라도 분할출원일로부터 30일 이내 제출		
	부적법	1.일반요건 불만족-불수리 2.명도가 원출원의 최명도에 기재된 범위 이내일 것 위반-거절이유, 정보제공사유, 무효사유 (분리출원의 경우 청구범위의 요건을 만족하지 않은 경우 거절이유, 정보제공사유)		5.변경출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우에는 최우선일로부터 1년 4개월의 기간이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 증명서류 제출 6.청구범위제출유예기간이 지난 후라도 변경출원일로부터 30일 이내 제출
협의제 회피		원출원과 청구범위가 동일한 경우 회피 필요		변경출원과 동시에 원출원의 취하간주
외국어 출원	1.원출원이 외국어출원인 경우에는 국어번역문이 제출된 경우에만 분할·변경출원 가능(분리출원도 마찬가지)			
	2.분할출원이 외국어출원인 경우에는 국어번역문 제출기간이 지난 후라도 분할출원일로부터 30일 이내(다만, 보정하거나 출원인이 심사청구한 경우 새로운 국어번역문 제출 불가)		2.분리출원은 외국어 출원 불가	2.변경출원이 외국어출원인 경우에는 국어번역문 제출기간이 지난 후라도 변경출원일로부터 30일 이내(다만, 보정하거나 출원인이 심사청구한 경우 새로운 국어번역문 제출 불가)
특례		수수료 납부 + 번역문 제출 + 기준일 지난 후		수수료 납부+번역문 제출 후

총칙/
보칙

특허
요건

이익
제도

심사
(제도)

특허권

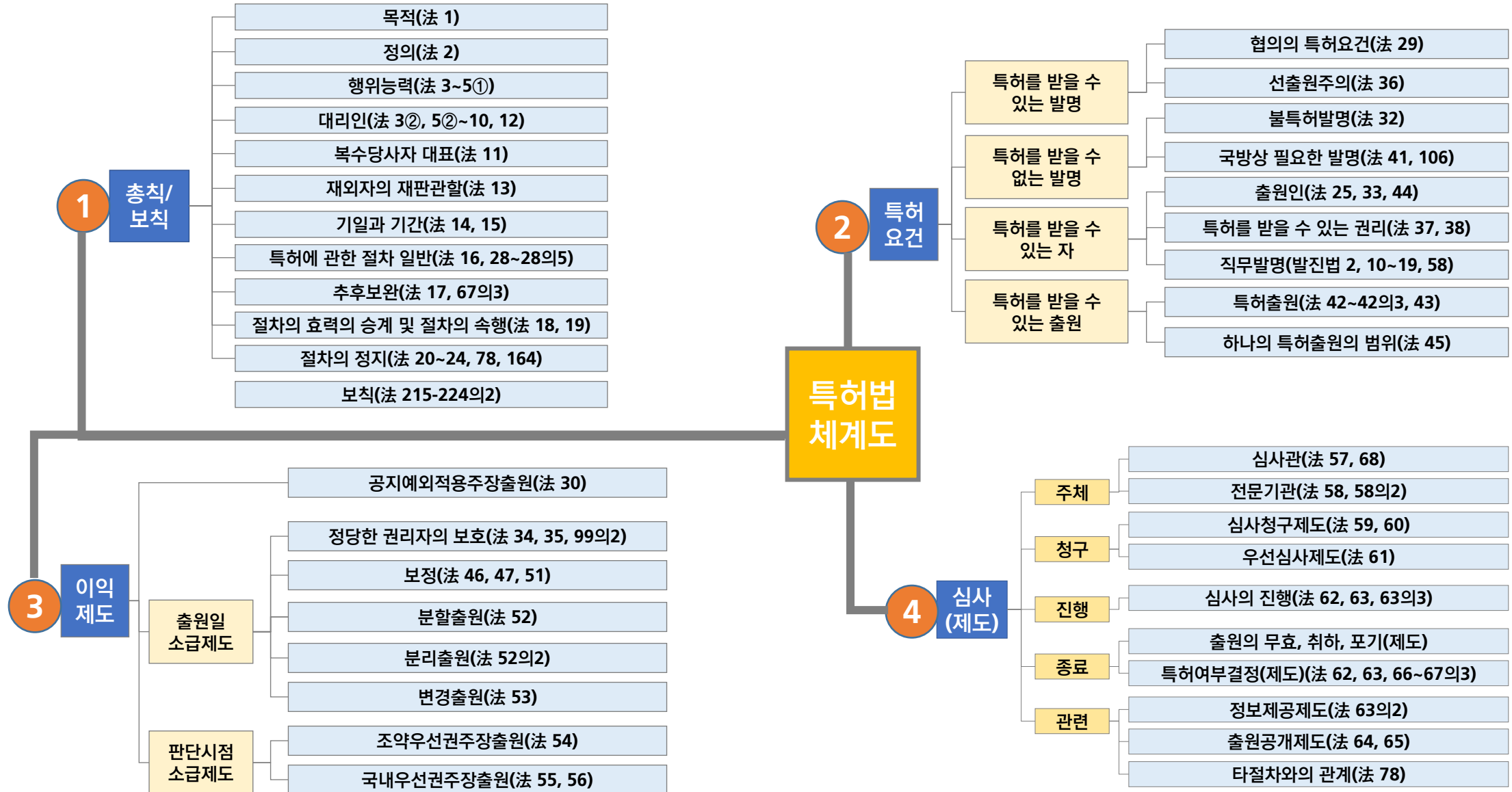
심판/
소송

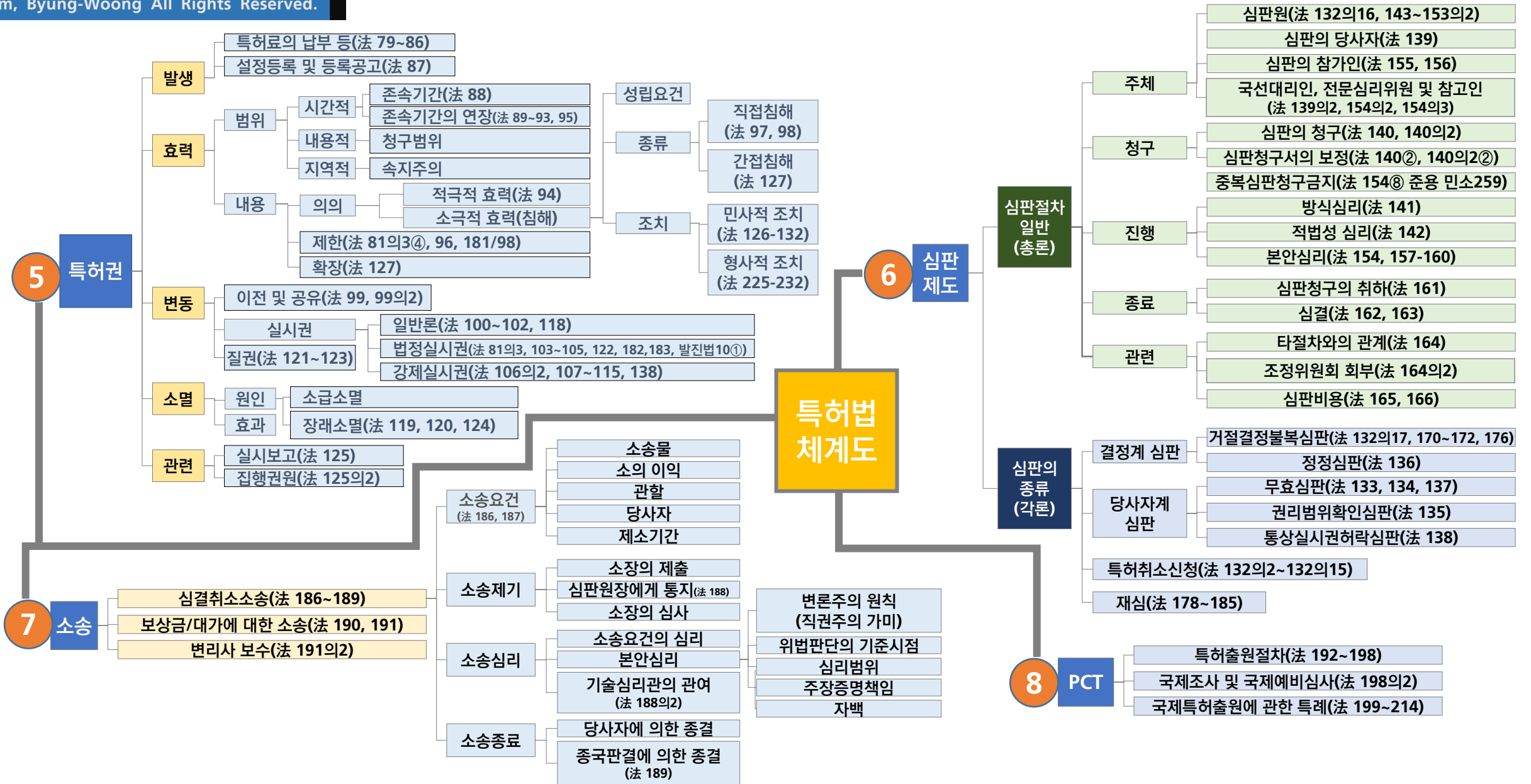
PCT

특허법 강의노트

Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

2026

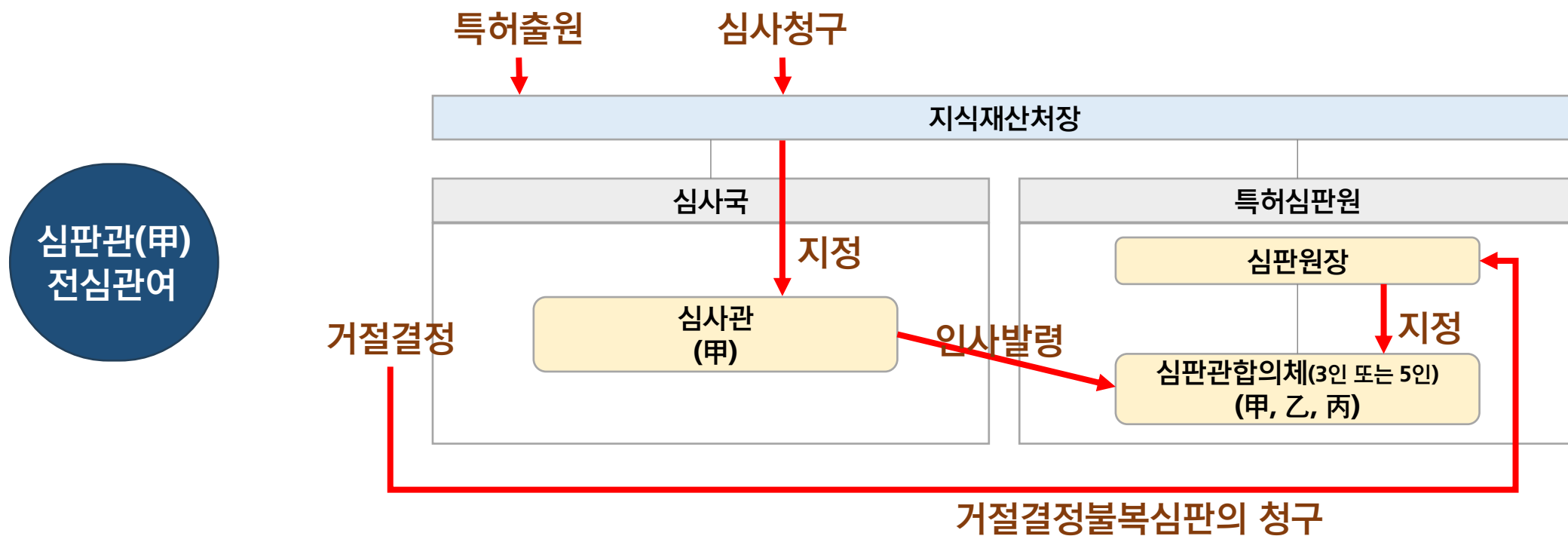




제68조(심판규정의 심사예외 준용) 특허출원의 심사에 관하여는 제148조제1호부터 제5호까지 및 제7호를 준용한다.

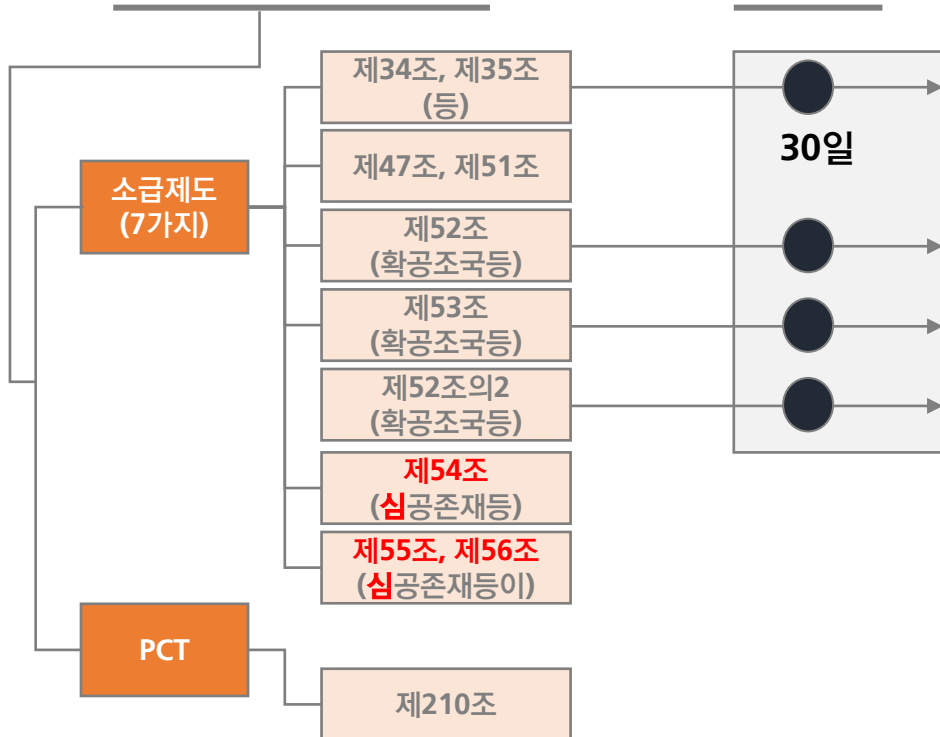
제148조(심판관의 제척) 심판관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심판에서 제척된다.

1. 심판관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인 경우
2. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 친족이거나 친족이었던 경우
3. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우
4. 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인이거나 감정인이었던 경우
5. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우
6. 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우
7. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

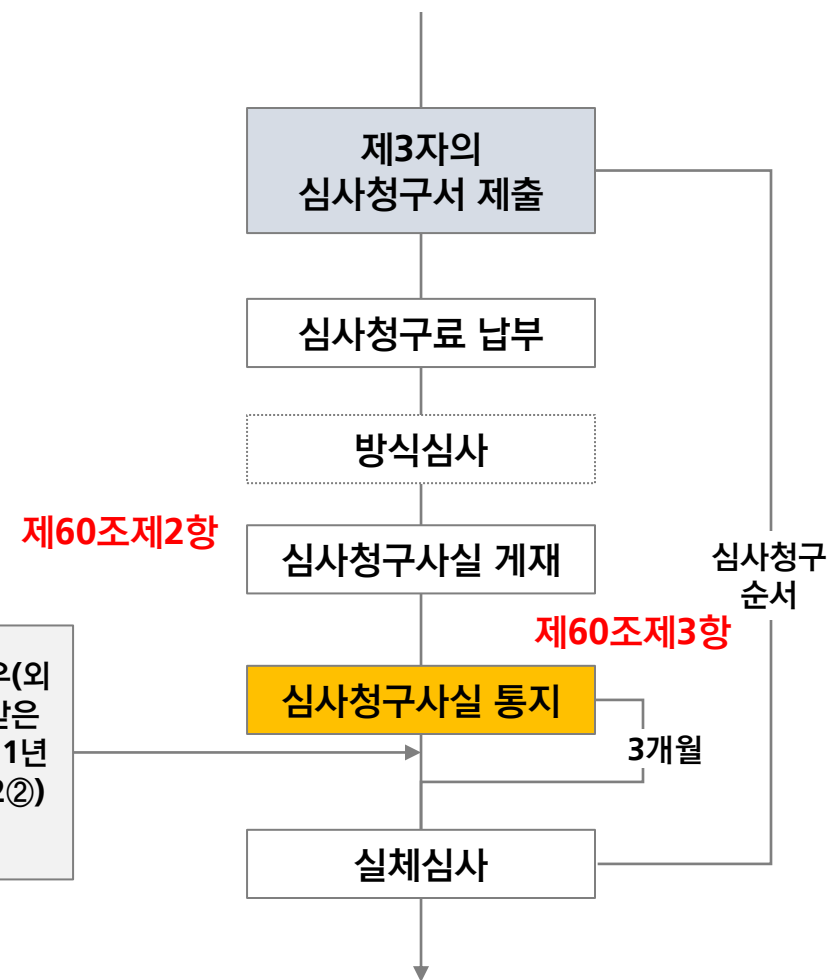
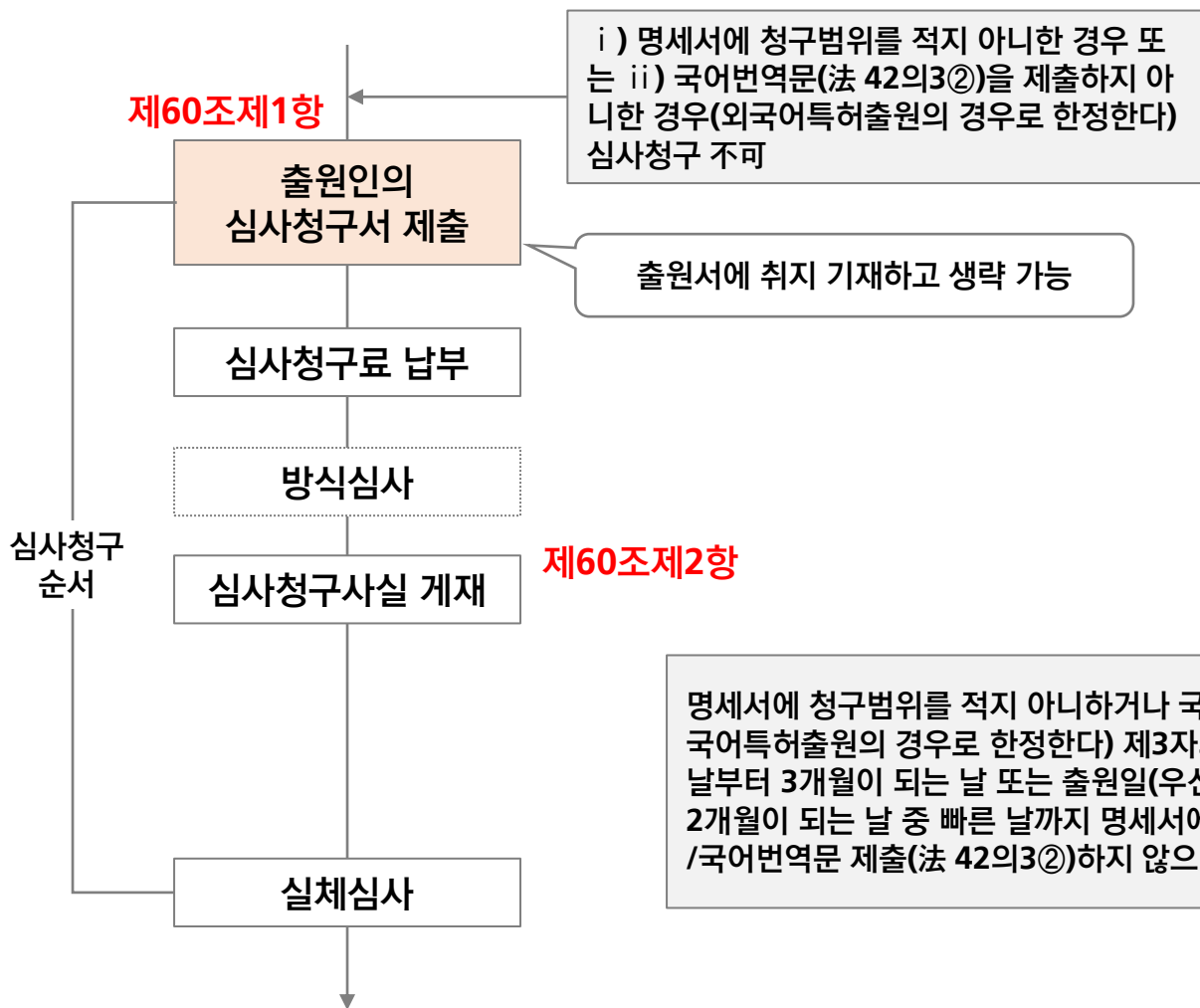


특허출원에 관한 심사의 청구는 **특허출원일로부터 3년** 이내에 할 수 있다. 출원인의 입장에서 보면 기술적·경제적으로 무가치한 출원의 심사청구를 억제할 수 있도록 충분한 고려기간이 필요하다. 그러나 그 심사청구기간을 너무 장기로 하게 되면 출원발명의 권리화 여부가 불확실해지게 되어 산업계의 불안정한 상태가 장기간 계속되는 문제점이 있기 때문에 출원일로부터 3년으로 규정하고 있다. 출원인은 라이프 사이클이 짧은 기술과 관련된 발명에 대해서는 심사청구를 하여 조기에 특허권을 확보해야 하겠지만, 중장기적인 사업과 관련된 발명에 대해서는 심사청구시기를 늦출 필요가 있다. **시간의 경과에 따라 자사·타사의 연구개발 상황이나 그 기술 분야 전체의 장래성 등의 정보가 갱신되기 때문이다.** 또한, 심사청구를 하여 실체심사 결과 특허등록이 되면 청구범위가 확정되어 보정하여 **권리범위를 재설계할 수 있는 기회를 상실하게 되고, 특허료 등의 특허비용이 증가할 수 있다**는 것을 고려해야 한다.

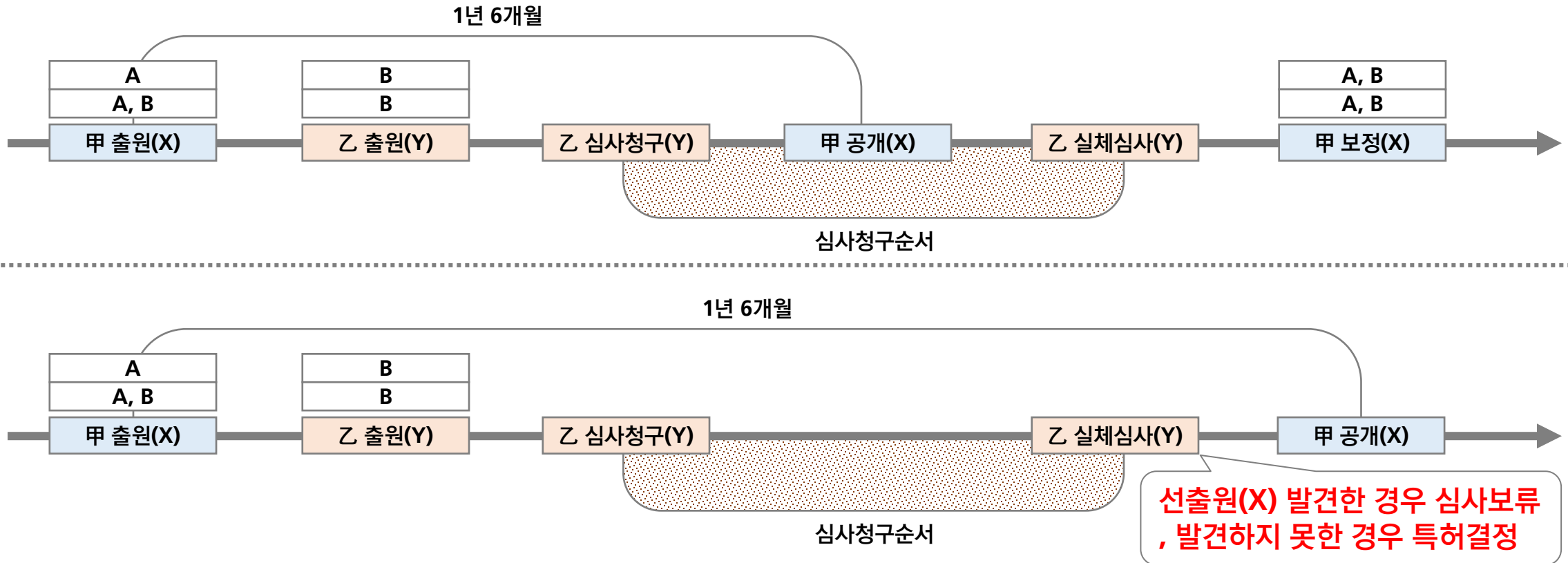
특허출원일로부터 3년



연도	출원건수	심사청구								출원연도별 심사청구	
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	건수	비율
2022	237,633								144,049	144,049	60.62%
2021	237,998							147,536	17,448	164,984	69.32%
2020	226,759						140,508	16,393	12,542	169,443	74.72%
2019	218,975					133,263	16,150	12,037	25,783	187,233	85.50%
2018	209,992				129,951	5,688	10,721	32,615	1,182	180,157	85.79%
2017	204,775			127,442	5,084	5,279	29,193	6,011	1,504	174,513	85.22%
2016	208,830		130,962	4,525	4,859	10,828	8,365	18,463		178,002	85.24%
2015	213,694	132,625	4,499	3,676	11,830	9,122	18,905			180,657	84.54%



甲 출원(X)의 보정유무에 따라 乙 출원(Y)이 선출원주의에 위반되는지 상관없이 甲 출원(X)의 공개를 요건으로 甲 출원(X)의 출원일의 다음날부터 출원공개 전 사이에서 선출원의 범위를 청구범위(A)로부터 최초 명세서 또는 도면(A, B)의 범위로 확대하여 먼저 심사청구한 후출원인 乙 출원(Y)을 확대된 선출원 위반으로 거절시킴으로써 심사청구순서에 따라 실체심사를 진행한다는 **심사청구제도를 효율적으로 운용**할 수 있다. 다만, 출원일로부터 1년이 되기 전 특허결정을 하는 경우 심사관은 특허결정을 하되, 조약우선권주장출원의 우선기간(1년)을 고려하여 선출원주의 위반 여부를 판단할 수 없다는 단서를 붙이고 있다. 또한 1년 6개월이 되기 전 특허결정을 하는 경우에는 심사관은 선출원의 공개 여부가 불명확하기 때문에 확대된 선출원 위반을 판단할 수 없다는 단서를 붙이고 있다. 즉, **i) 출원일로부터 1년이 지나기 전 특허결정을 할 때는 선출원주의, 확대된 선출원 위반 여부를 판단할 수 없다는, ii) 출원일로부터 1년이 지난 후 1년 6개월이 지나기 전 특허결정을 할 때는 확대된 선출원 위반 여부를 판단할 수 없다는 단서**를 붙이고 있다. 한편, 심사관이 선출원(X)이 있음을 발견한 경우에는 선출원이 출원공개 또는 등록공고될 때까지 심사를 보류하게 된다(施規 40본문).



특허법 제61조(우선심사) 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
2. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우
3. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우

시행령 제9조(우선심사의 대상) ① 법 제61조제2호에서 "대통령령으로 정하는 특허출원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하는 특허출원을 말한다.

1. 방위산업분야의 특허출원
2. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따른 녹색기술과 직접 관련된 특허출원
 - 2의2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원
 - 2의3. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)
3. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원
4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 특허출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함한다)
5. 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원
 - 5의2. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원
 - 5의3. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 인증된 기업의 특허출원
 - 5의4. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원
6. 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원
7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다)
 - 7의2. 법 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원
8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원
9. 삭제<2019. 7. 9.>
10. 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원
11. 삭제<2023. 12. 19.>
12. 삭제<2023. 12. 19.>

② 법 제61조제3호에서 "대통령령으로 정하는 특허출원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원을 말한다. <신설 2021. 6. 22.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하여 고시하는 특허출원
 - 가. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 특허출원
 - 나. 「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따라 인증을 받은 재난안전제품과 직접 관련된 특허출원
2. 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 지식재산처장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 특허출원

실용법 제15조(「특허법」의 준용) 실용신안등록출원의 심사·결정에 관하여는 「특허법」 제57조, 제58조, 제58조의2, 제60조, 제61조, 제63조의2, 제63조의3, 제64조부터 제66조까지, 제66조의2, 제66조의3, 제67조, 제67조의2, 제67조의3, 제68조 및 제78조를 준용한다.

시행령 제5조(우선심사의 대상) 법 제15조에서 준용하는 「특허법」 제61조제2호에서 "대통령령으로 정하는 특허출원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하는 실용신안등록출원을 말한다.

1. 방위산업분야의 실용신안등록출원
2. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원
3. 수출촉진에 직접 관련된 실용신안등록출원
4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 실용신안등록출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 실용신안등록출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 실용신안등록출원을 포함한다)
5. 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 실용신안등록출원
6. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 실용신안등록출원
 - 6의2. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 인증된 기업의 실용신안등록출원
 - 6의3. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 실용신안등록출원
7. 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 실용신안등록출원
8. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 실용신안등록출원(그 실용신안등록출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허출원 또는 실용신안등록출원에 관한 절차가 진행 중인 것에 한정한다)
9. 실용신안등록출원인이 실용신안등록출원된 고안을 실시하고 있거나 실시준비 중인 실용신안등록출원
10. 삭제<2019. 7. 9.>
11. 삭제<2019. 7. 9.>
12. 삭제<2023. 12. 19.>
13. 삭제<2023. 12. 19.>

타법에 의한 특허법의 우선심사신청사유

1. 첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 내 의료연구개발과 관련한 특허출원
2. 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 대한 규제특례법 제36조의8에 따라 규제특례가 적용된 특화사업과 직접 관련된 특허출원

시행규칙 제38조(심사의 순위) ① 특허출원에 대한 심사는 법 제59조제1항에 따른 출원심사의 청구순위에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 **지식재산처장이 정하는 바***에 따라 심사한다.

1. 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우
2. 심사청구된 특허출원을 법 제52조의2에 따라 분리출원하여 심사청구한 경우
3. 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우

시행규칙 제40조(동일출원의 심사) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공개 될 때까지 후출원의 심사를 보류하여야 한다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 아니하다.

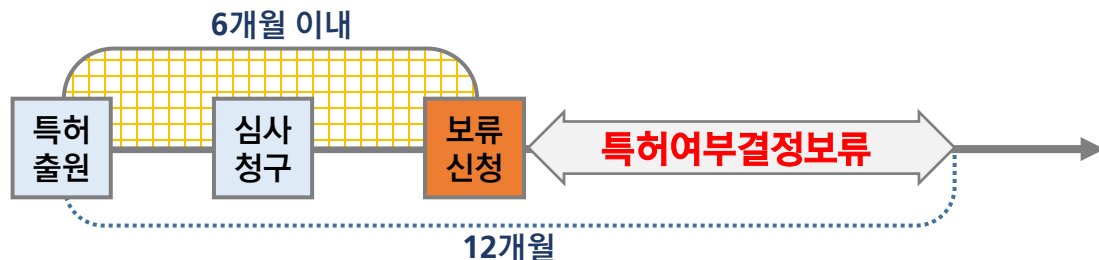
② 심사관이 제1항에 따라 심사를 보류하려는 경우에는 지식재산처장이 지정한 심사장의 확인을 받아야 한다

시행규칙 제40조의2(특허여부결정의 보류) ① 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월 이내에 별지 제22호의2서식의 결정 보류신청서를 지식재산처장에게 제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원이 분리출원 또는 변경출원인 경우
2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우
3. 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우

② 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

* 분할출원은 분할출원의 심사청구순서, 분리출원과 변경출원은 원출원의 심사청구순서에 의하여 심사(특허·실용신안 심사사무취급규정 제20조)



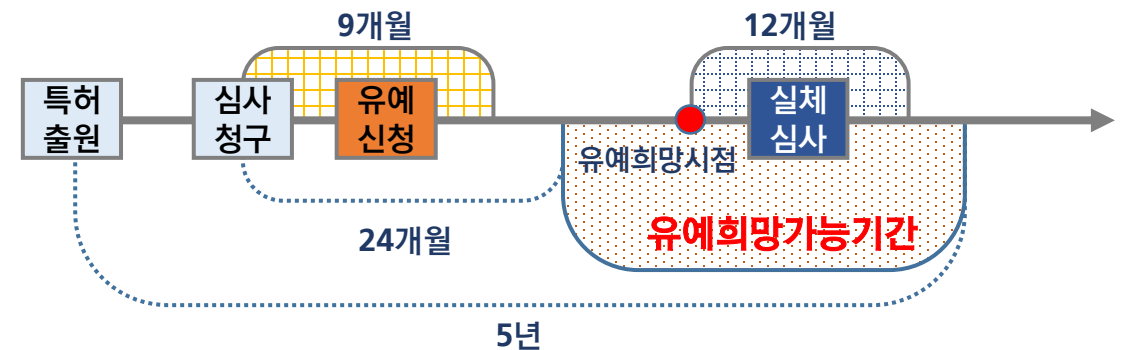
시행규칙 제40조의3(특허출원심사의 유예) ① 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서 출원심사의 청구일부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일부터 5년 이내에 한정하며, 이하 "유예희망시점"이라 한다)을 적은 별지 제22호의2서식의 심사유예신청서를 지식재산처장에게 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 따른 특허출원서 또는 심사청구서에 그 취지 및 유예희망시점을 적음으로써 그 신청서를 갈음할 수 있다.

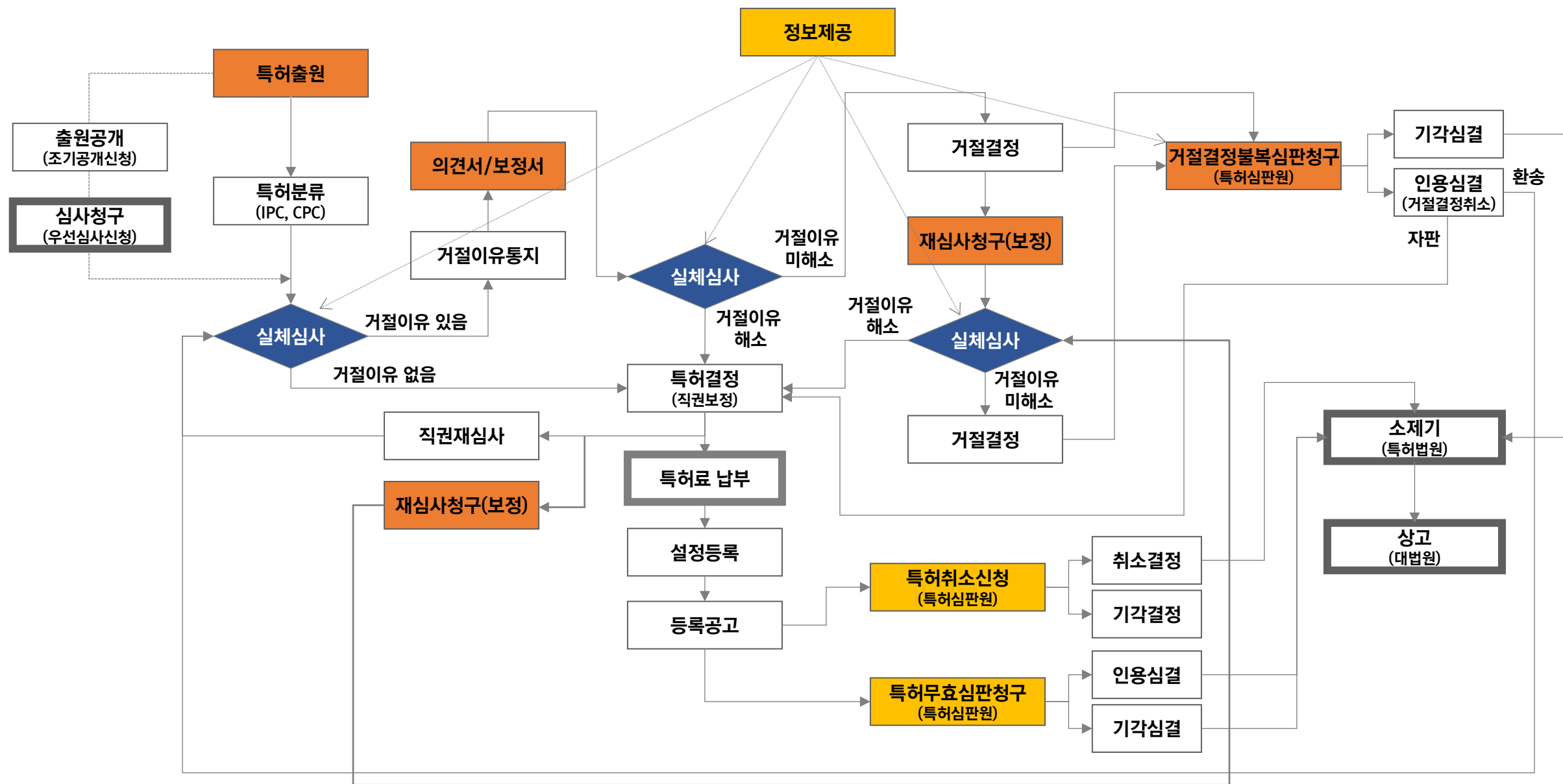
1. 제37조제1항 단서에 따라 특허출원과 동시에 심사청구를 하면서 심사유예신청도 같이 하는 경우에는 별지 제14호서식의 특허출원서
2. 심사청구와 동시에 심사유예신청을 하는 경우(제1호의 경우는 제외한다)에는 별지 제22호서식의 심사청구서

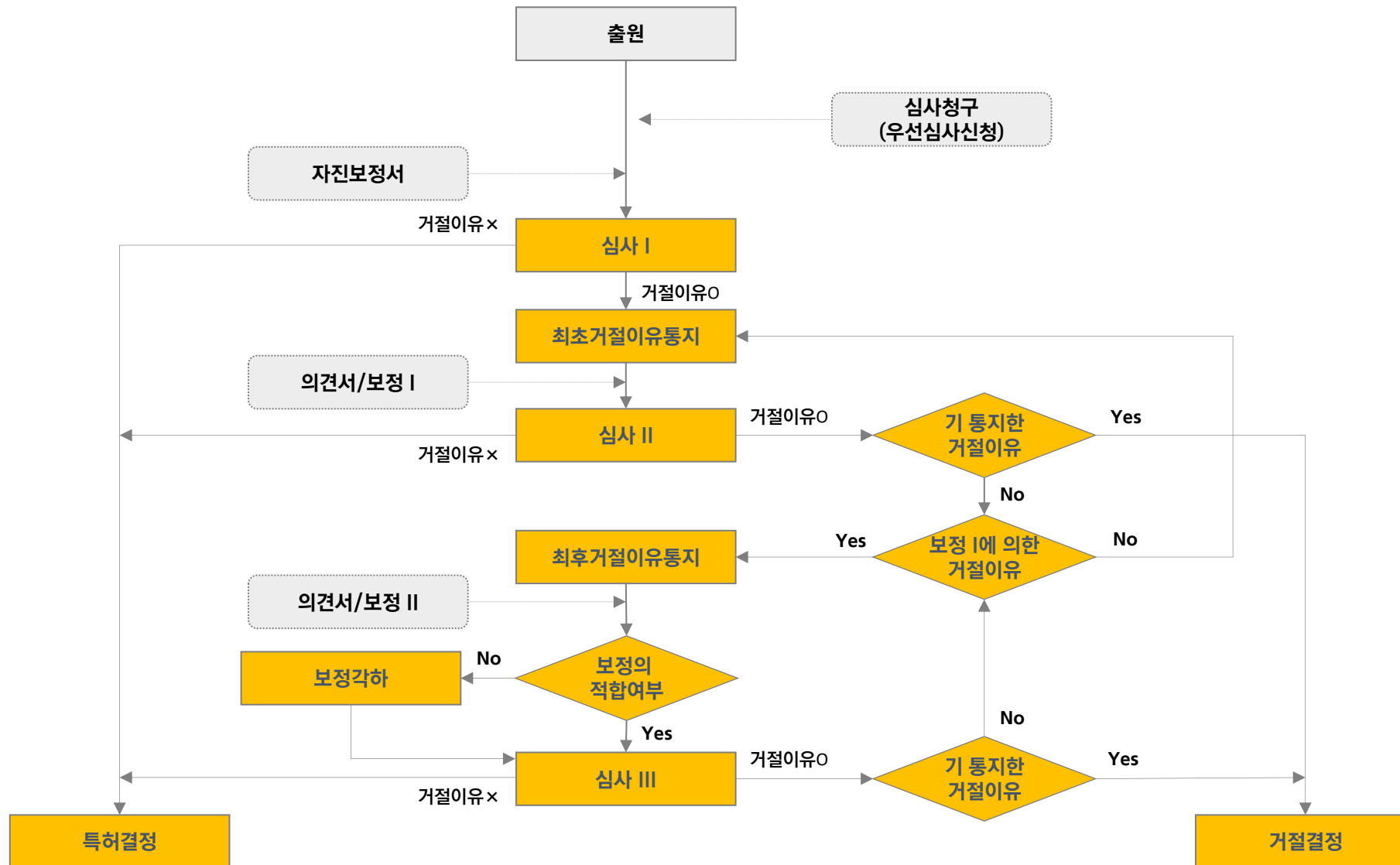
② 특허출원인이 제1항에 따른 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을 변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 별지 제12호서식의 취하서 또는 별지 제9호서식의 보정서를 제출하여야 한다.

③ 심사관은 제1항에 따른 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원이 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우
2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우
3. 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우
- ④ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.







「최초거절이유통지」란 제63조에 따라 거절이유통지를 최초로 받거나 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 말한다. 「최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지」란 i) 특허출원한 발명에 원시적으로 거절이유가 존재하였는데 심사관이 간과한 후 나중에 이를 발견한 경우에 그 거절이유에 대한 거절이유통지, ii) 심사관이 직권 재심사를 하려고 특허출원인에게 특허결정을 취소한다는 사실을 통지한 경우에(法 66의3②) 그 통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지 또는 iii) 거절결정불복심판에서 취소환송되었는데 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지를 말한다.

자진보정이 있었는지 여부에 관계없이 심사가 착수된 이후 첫 번째의 거절이유통지인 경우

보정되지 아니한 보정식별항목(특허법 시행규칙 별지 제9호서식 기재요령의 식별항목으로서 식별번호 등을 말한다. 이하 같다)에 거절이유가 있는 경우

거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라고 하더라도 그 거절이유가 보정에 의하여 발생된 것이 아니라 최초거절이유통지시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유인 경우

보정 외적인 요인에 의하여 거절이유가 발생한 경우

직권 재심사를 하려고 특허출원인에게 특허결정을 취소한다는 사실을 통지한 후 그 통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유를 발견한 경우

거절결정불복심판에서 취소환송된 출원은 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유를 발견한 경우

【예1】 아래의 사례에서 심사관이 최초거절이유를 통지한 후 경미한 기재불비(명세서 등을 참고 할 때 A' 은 A가 되어야 할 것으로 인정)를 보정한 청구항에 대하여 다시 심사한 결과 구성요소 A+C로 된 장치에 관한 선행기술을 발견하여 거절이유를 통지하려는 경우, 이는 보정 전 청구항에 기재된 발명에도 존재했던 신규성 또는 진보성의 거절이유이므로 최초거절이유를 통지한다.

보정 전	보정 후
청구항 1: 구성요소 A' 또는 B에 C를 부가한 장치	청구항 1: 구성요소 A 또는 B에 C를 부가한 장치

【예2】하나의 청구항에 기재된 둘 이상의 발명 중 일부에 대하여만 거절이유를 통지하였다가 나머지 발명에 대하여 거절이유를 통지하는 경우 그 청구항이 거절이유통지에 따라 보정되었더라도 최초거절이유를 통지하여야 한다.

심사에 착수하여 최초거절이유를 통지할 때에는 외국인으로서 권리능력에 관한 흠결이 없었으나 보정 이후 제25조에 따라 특허에 관한 권리를 누릴 수 없게 된 경우, 해당 거절이유는 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유가 아니므로 최초거절이유를 통지한다.

「최후거절이유통지」란 최초거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지를 말한다.

명세서 또는 도면을 보정하여 신규사항이 추가된 경우, 기재불비가 새롭게 발생한 경우, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원의 범위를 벗어나게 된 경우

심사가 이루어진 청구항을 보정하여 새롭게 신규성, 진보성 등에 관한 거절이유를 통지하게 된 경우(다만, 보정된 청구항의 발명이 그 청구항 외의 다른 청구항에 원래부터 기재되어 있던 발명이었음에도 해당 거절이유를 통지하지 않았던 경우에는 최초거절이유를 통지한다.)

신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 바뀐 청구항에 신규성, 진보성의 거절이유가 있는 경우(다만, 그 청구항이 거절이유를 통지받지 아니한 청구항의 발명으로 보정된 경우에는 최초거절이유를 통지한다.)

청구항 기재의 현저한 기재불비 또는 신규사항의 추가 등으로 신규성 또는 진보성 등과 관련된 심사가 불가능했던 청구항을 보정한 후 다시 심사한 결과 신규성이나 진보성에 관한 거절이유를 발견한 경우

【예1】 아래 사례에서 신규성 또는 진보성을 위반으로 거절이유를 통지한 청구항 1을 보정하여 종전의 신규성이나 진보성 거절이유를 해소하였으나, 구성 D를 부가함으로써 D를 포함하는 선행기술을 추가로 인용할 필요가 생겼다면 이는 보정에 의하여 발생한 거절이유이므로 최후거절이유를 통지한다. 만일 'A 및 B'라는 표현이 구성요소를 선택적으로 적지 아니하여 발명의 구성이 불분명하다는 거절이유가 있었다면, 이는 구성 D를 부가한 것과 관계없이 보정 전 청구항에 존재하던 거절이유로서 보정에 의하여 발생한 거절이유가 아니므로 최후거절이유통지 대상이 아니다.

보정 전	보정 후
청구항 1: 구성요소 A 및 B에 C를 부가한 장치	청구항 1: 구성요소 A 및 B에 D를 부가한 장치

【예2】 기재불비만으로 통지한 거절이유에 대한 보정으로 청구항이 확장됨으로써 신규성 또는 진보성의 거절이유가 발생한 경우 보정에 의하여 선행기술을 다시 찾아 심사하여야 하기 때문에 그 거절이유가 같은 청구항 번호에 존재하는 거절이유라도 최후거절이유를 통지하여야 한다.

심사관은 거절이유통지에 따라 제출된 의견서·보정서에 의해서도 이미 통지한 거절이유가 해소되지 아니하고 동일한 경우에는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 아니하고 특허거절결정을 한다. 「거절이유가 이미 통지한 거절이유와 동일한 경우」란 해당 거절이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지(主旨)에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되어서는 아니 되고 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가되어야 한다.

거절이유통지

거절이유

주지가 부합
(출원인에게 실질적 대응기회 부여)

거절결정

거절결정의 이유

1

다른 거절이유통지하고 거절결정해서는 안 된다.

(우선 법조문을 달리 한다면 거절이유를 달리하며, 법조문을 같이 하더라도 사실을 달리 한다면 거절이유를 달리한다.)

2

거절이유통지가 어느 정도 추상적이나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재되어 있으면 충분하다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 등)

3

출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 **우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성**하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유를 거절이유통지서에 포함하여야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371).

4

기통지한 거절이유에서 선행기술로 인용된 자료가 특허공보와 같이 하나의 기술에 관한 것이거나 여러 실시태양을 개시하고 있지만 동일 또는 밀접한 기술사상에 대한 문헌인 경우에는 **그 문헌 전체**에 대하여 거절이유통지가 있었다고 봄이 상당하므로, 추가적인 거절이유통지 없이 기통지한 거절이유에서 위 문헌 중 직접 인용하지 않았던 부분을 들어 바로 거절결정할 수 있다. 다만, 그 인용된 자료가 서적 등과 같이 방대하거나 여러 개의 기술에 관한 기재가 있는 것인데, 거절이유통지에서는 그 중 일부 기술만을 사본하여 첨부하거나 적시한 경우라면 인용되지 않은 부분을 새로운 거절이유로 볼 여지가 있으므로, 가급적 다시 거절이유를 통지하여 출원인에게 의견제출할 기회를 부여하도록 한다(특허법원 2011. 4. 27. 선고 2010허2612; 2012. 6. 20. 선고 2011허10306).

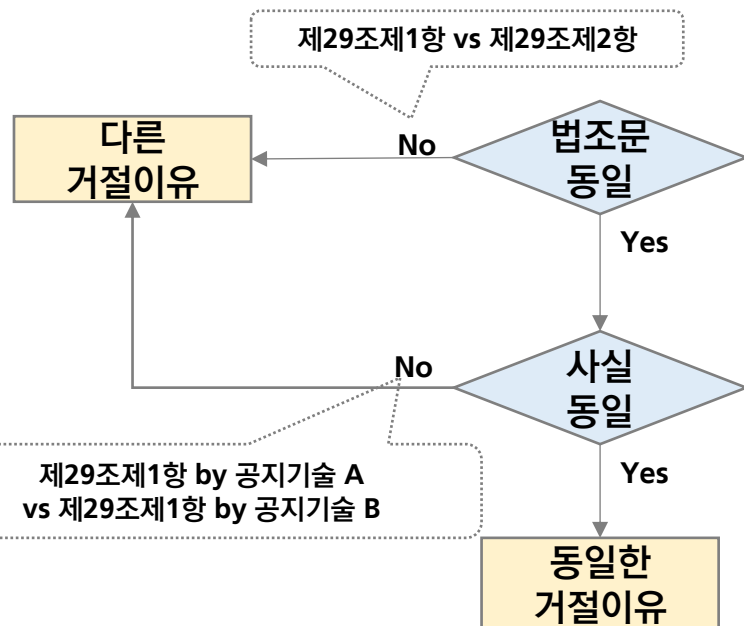
5

진보성 위반을 이유로 한 거절이유에 기재된 **주선행발명을 다른 선행발명으로 변경**하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다(대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341).

심사관은 거절이유통지에 따라 제출된 의견서·보정서에 의해서도 이미 통지한 거절이유가 해소되지 아니하고 동일한 경우에는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 아니하고 특허거절결정을 한다. 「이미 통지한 거절이유와 동일한 경우」란 해당 거절결정의 이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지(主旨)에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되어서는 아니 되고 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가되어야 한다. 구체적으로 **우선 법조문을 달리 한다면 거절이유를 달리 하며, 법조문을 같이 하더라도 사실을 달리 한다면 거절이유를 달리 한다.**

기통지한 거절이유에서 선행기술로 인용된 자료가 특허공보와 같이 하나의 기술에 관한 것이거나 여러 실시태양을 개시하고 있지만 동일 또는 밀접한 기술사상에 대한 문헌인 경우에는 **그 문헌 전체에 대하여 거절이유통지가 있었다고 봄이 상당하므로**, 추가적인 거절이유통지 없이 기통지한 거절이유에서 위 문헌 중 직접 인용하지 않았던 부분을 들어 바로 거절결정할 수 있다. 다만, 그 인용된 자료가 서적 등과 같이 반대하거나 여러 개의 기술에 관한 기재가 있는 것인데, 거절이유통지에서는 그 중 일부 기술만을 사본하여 첨부하거나 적시한 경우라면 인용되지 않은 부분을 새로운 거절이유로 볼 여지가 있으므로, 가급적 다시 거절이유를 통지하여 출원인에게 의견제출할 기회를 부여하도록 한다(특허법원 2011. 4. 27. 선고 2010허2612; 2012. 6. 20. 선고 2011허10306).

제29조제1항 vs 제29조제2항



구체적 예

설명

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치

【최후거절이유통지】 청구항 1이 인용대상 1에 의하여 진보성 없음.

【최후보정 후의 명세서】

청구항 1 : A+B+C로 이루어진 장치(인용대상 1에 대해서는 진보성이 인정되나 인용대상 1 및 인용대상 2에 의하여 진보성 없음. 인용대상 2는 C의 부가로 인해 추가로 필요)

【보정각하】 청구항 1의 보정에 따라 보정 전에 없던 새로운 거절이유가 발생하였기 때문에 보정각하함.

【특허거절결정】 청구항 1(A+B)은 인용대상 1에 의하여 진보성이 없으므로 특허거절결정함.

청구항 1 : A로 이루어진 장치

【최후거절이유통지】 청구항 1이 **인용대상 1**에 의하여 진보성 없음.

【최후보정 후의 명세서】

청구항 1 : A+B로 이루어진 장치(**인용대상 1에 B도 개시되어 있어 여전히 진보성이 부정됨**)

【보정인정】 청구항 1에 기재된 발명이 인용대상 1로부터 진보성이 부정된다는 거절이유는 기 통지되었던 거절이유이므로 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하지 아니하여 보정 인정함.

【특허거절결정】 청구항 1(A+B)은 인용대상 1에 의하여 진보성이 없으므로 특허거절결정함.

제63조 본문에 의하면, 심사관은 제62조에 따라 특허거절결정을 하려면 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데, 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 **우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로**, 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 아니한 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지는 **출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여**하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371).

특허법원 2009. 7. 1. 선고 2008허7706 판결

(국내우선권주장출원의 패들타입 교반기 사건)

교반기1

하위개념

공지기술

패들교반기

한국출원(X)

취하간주(X)

동일성
불인정

한국출원(Y)

X 기초 우선권주장

교반기

상위개념

출원인에게 실질적
대응기회가 주어졌는가?

거절이유:
우선권주장 불인정
불포함

주지 부합X

거절결정의 이유:
우선권주장 불인정
포함

출원공개(Y)

거절이유통지(Y)

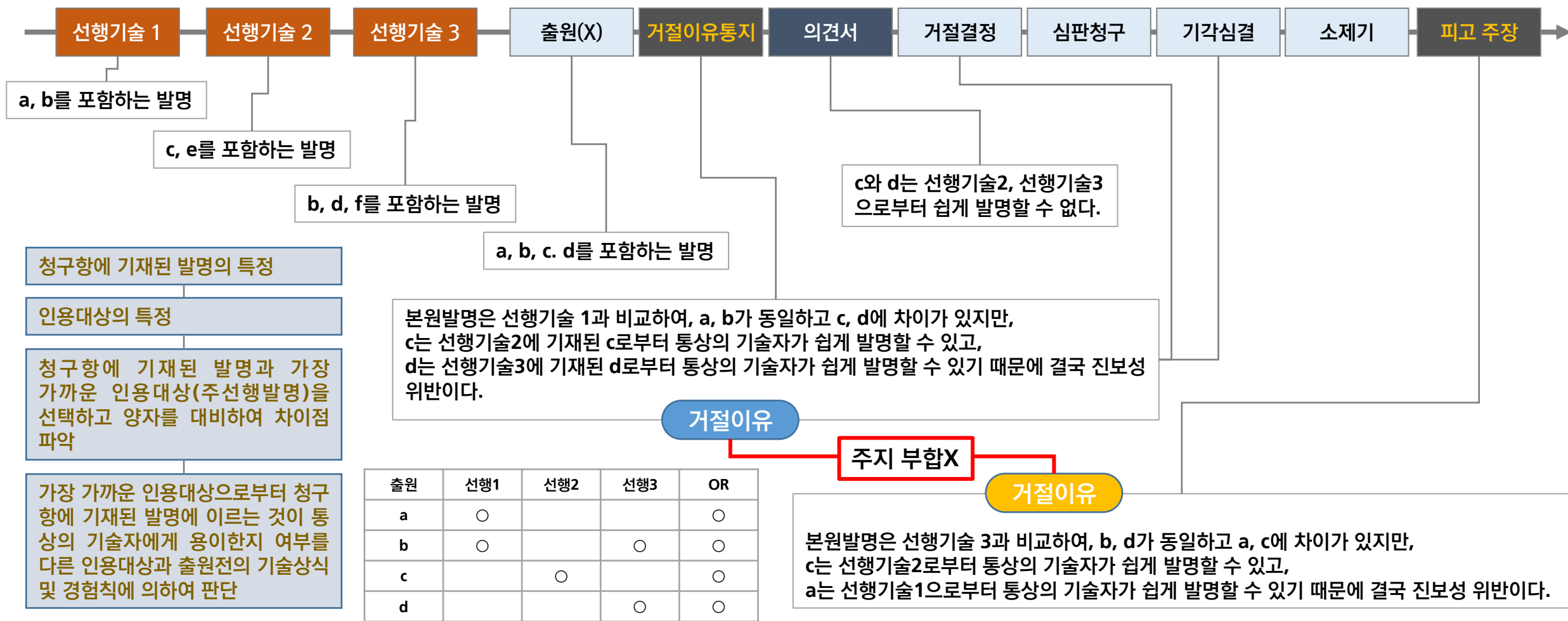
의견서(Y)

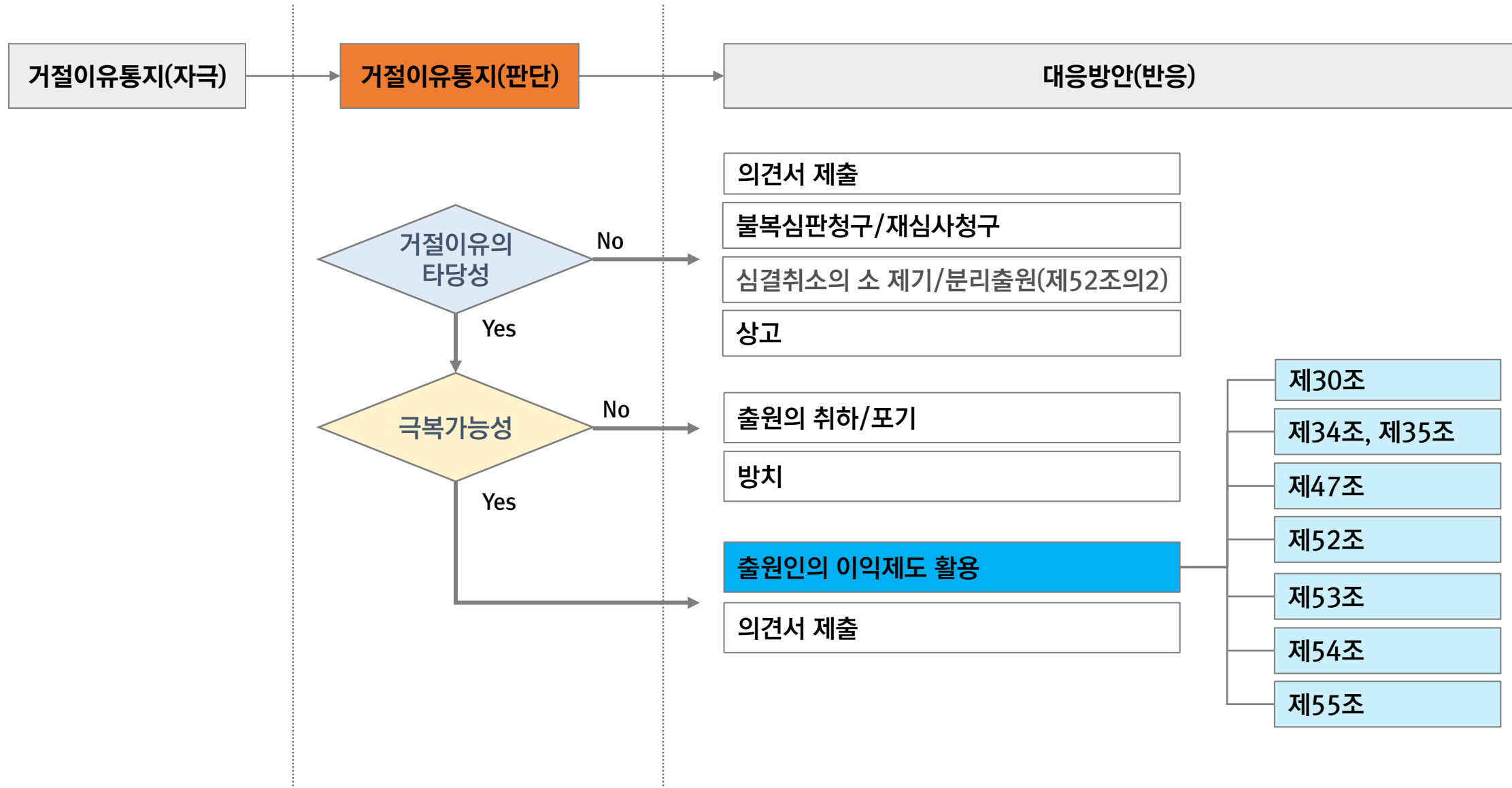
거절결정(Y)

공지기술에 의하여
진보성 위반

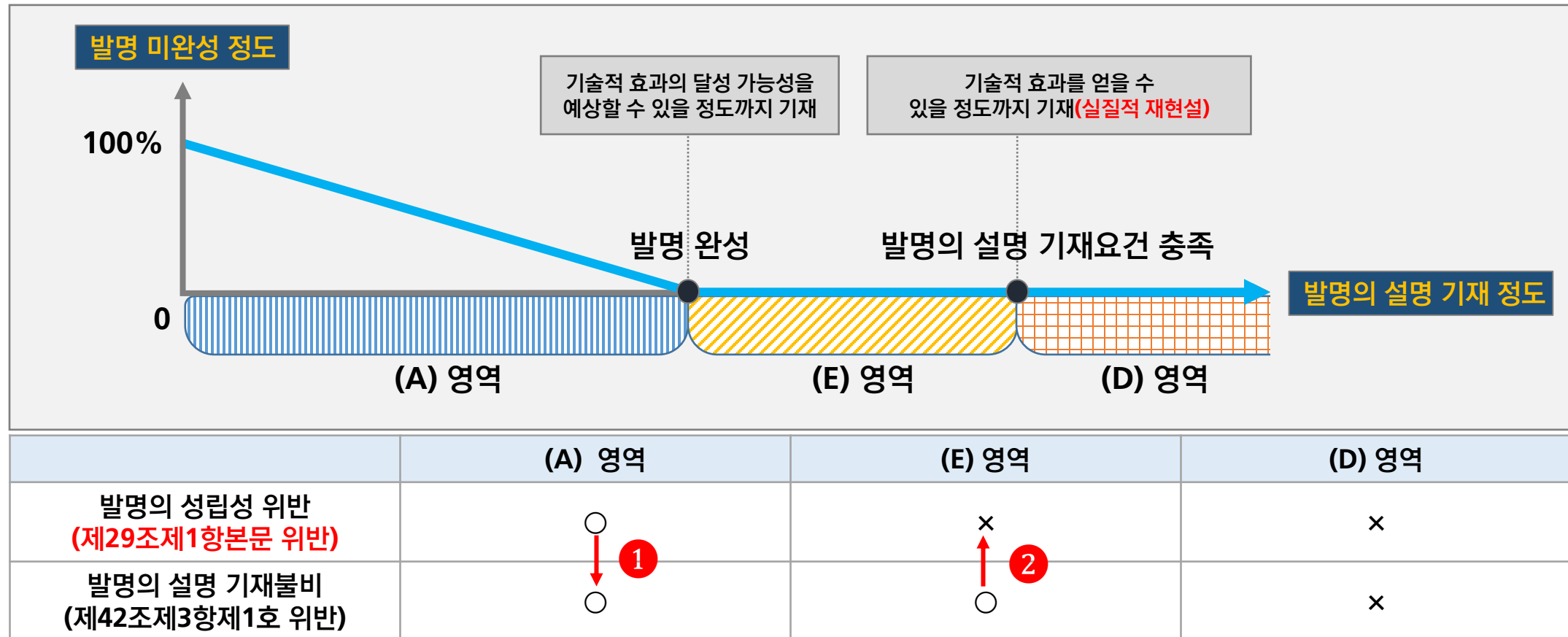
한국출원(X)의 출원일로 판단시점이
소급하여 진보성 위반이 아님

진보성 위반을 이유로 한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다(대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341).



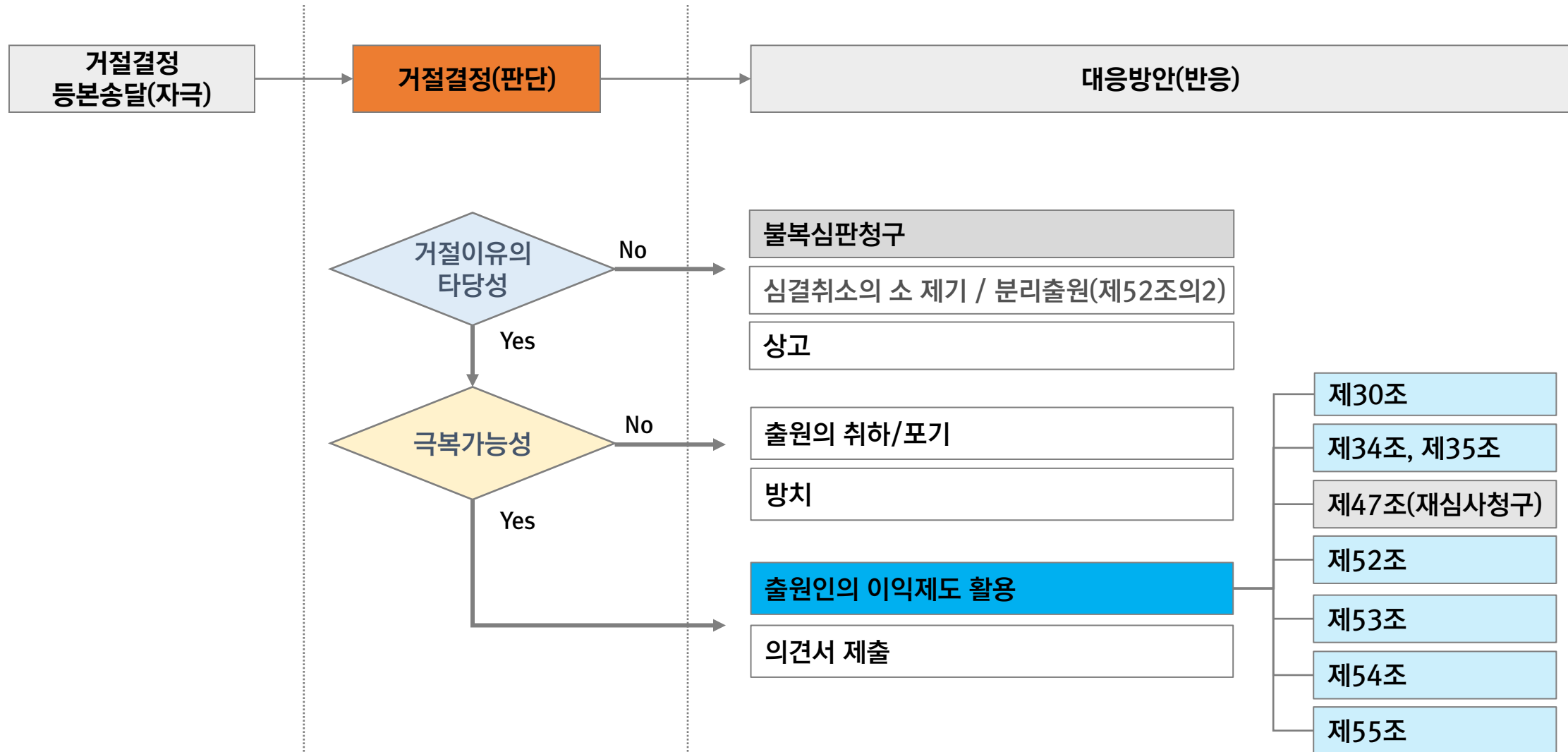


거절이유는 제한열거적이기 때문에 심사관은 제62조 각 호의 거절이유에 명시되지 아니한 사항을 이유로 특허거절결정을 할 수 없으며, 특허출원이 거절이유에 해당 될 때에는 반드시 특허거절결정을 하여야 하며, 심사관의 재량은 인정되지 아니한다. 그 결과, 심사관은 발명의 성립성이 결여되어 있는 경우에 발명의 정의 규정(法 21)이 제62조의 거절이유에 명시되지 있지 않기 때문에 우회적으로 제29조제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명 또는 제42조제3항제1호의 발명의 설명 기재의 위반으로 특허거절결정하고 있다.

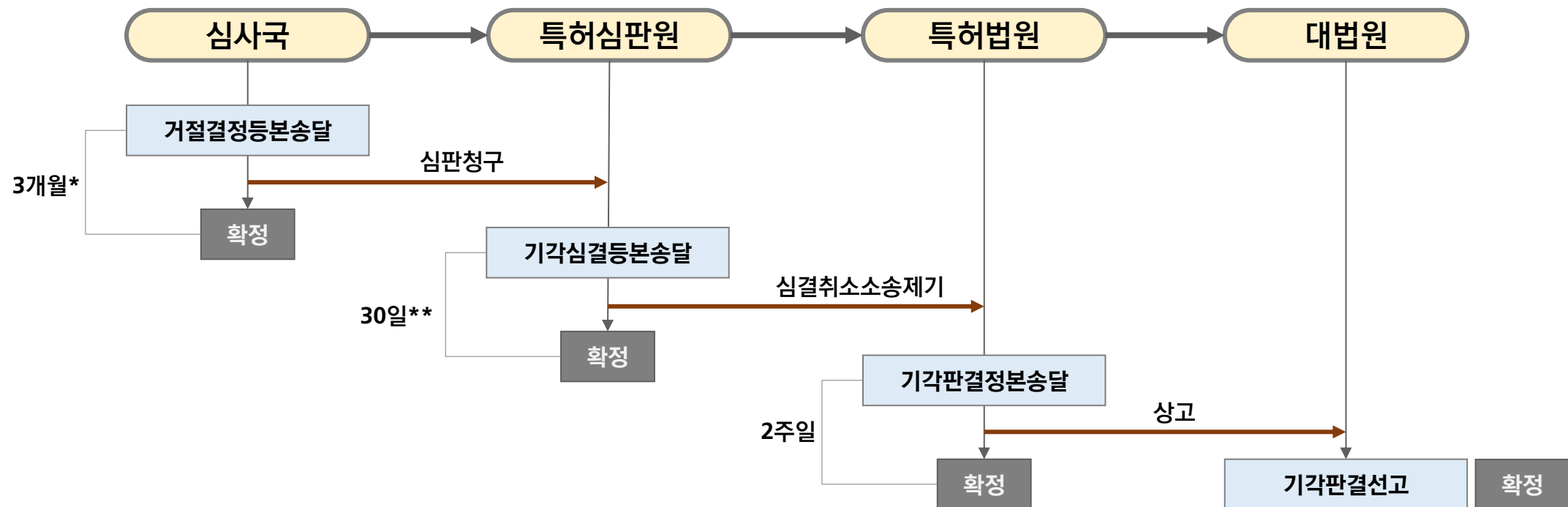


- ① 발명의 성립성 위반은 기재불비이기도 하다.
- ② 기재불비라고 하여, 반드시 발명의 성립성 위반은 아니다.

거절이유에 따라 확신 위반 여부가 달라져서 구분해야 함
(발명의 성립성 위반이 타당)



확정이란 통상적인 불복방법으로는 더 이상 불복할 수 없는 상태에 이른 것을 말한다. 특허거절결정은 심사국은 물론 심판원, 특허법원 또는 대법원에서도 확정될 수 있으며, 심판원 이후 특허거절결정이 확정된 경우에 이를 거절한다는 취지의 심결이 확정되었다고 표현한다.



* 연장, 추후보완 가능
** 부가기간 가능

제66조의2(직권보정 등) ① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 "직권보정"이라 한다)할 수 있다. **이 경우 직권보정은 제47조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다.**

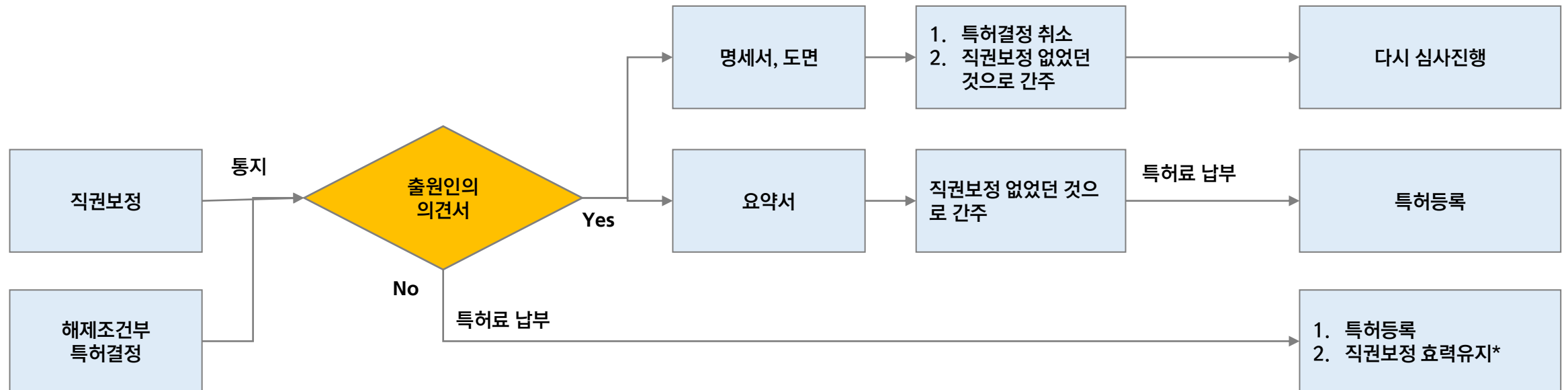
② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.

③ 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 **일부**를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다. 다만, 특허출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다.

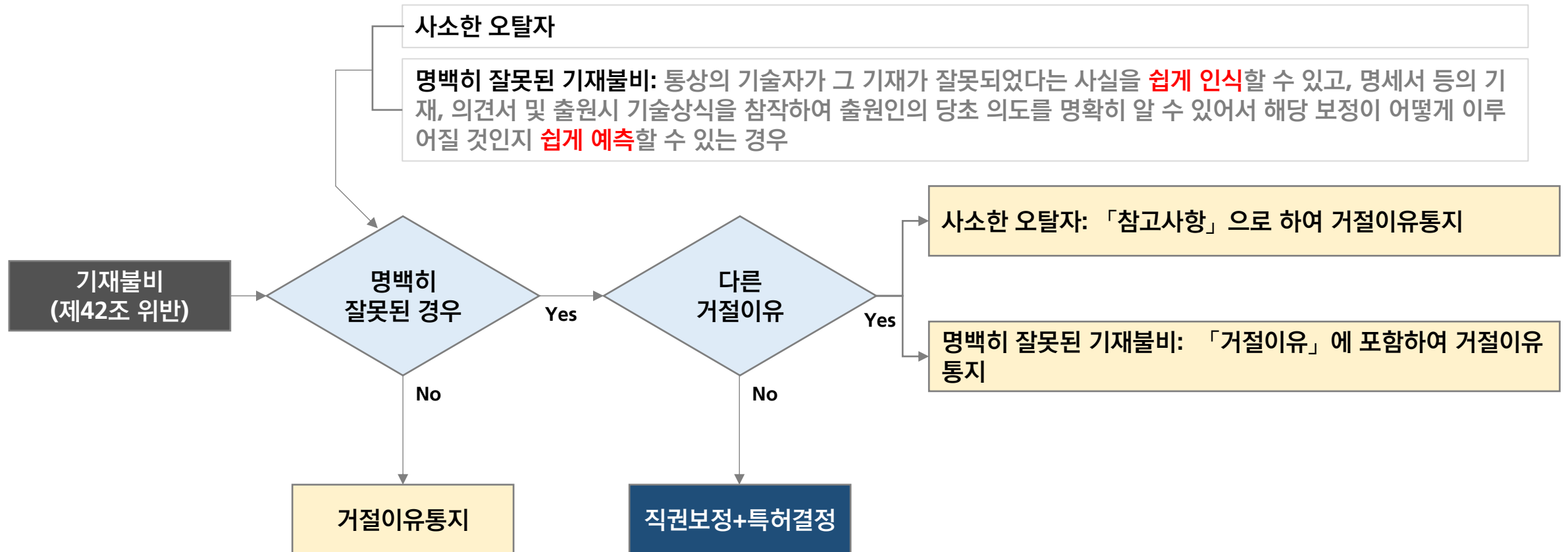
⑤ 삭제

⑥ **직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.**



* 직권보정이 신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 간주

심사관은 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우이고 다른 거절이유가 없다면 직권보정(法 66의2)하면서 특허결정할 수 있다. 「명백히 잘못된 경우」란 사소한 오타자 이외에 명백히 잘못 기재된 기재불비가 있는 경우를 말하고, 여기서 명백히 잘못 기재된 기재불비란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 의견서 및 출원시 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 경우를 말한다. 한편, 심사관은 다른 거절이유가 있다면 명백히 잘못된 경우 중 사소한 오타자인 것은 「참고사항」으로, 명백한 잘못된 기재불비에 해당하는 것은 「거절이유」에 포함하여 거절이유를 통지한다.



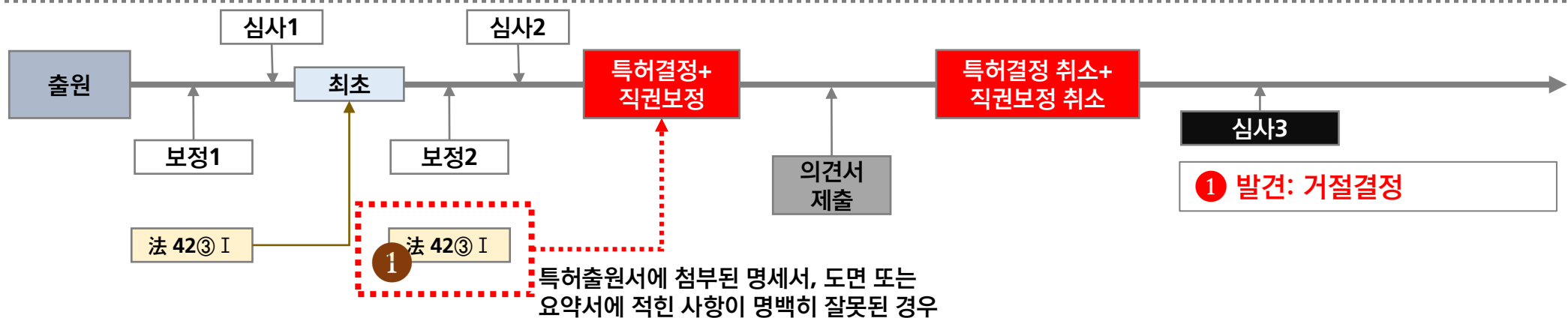
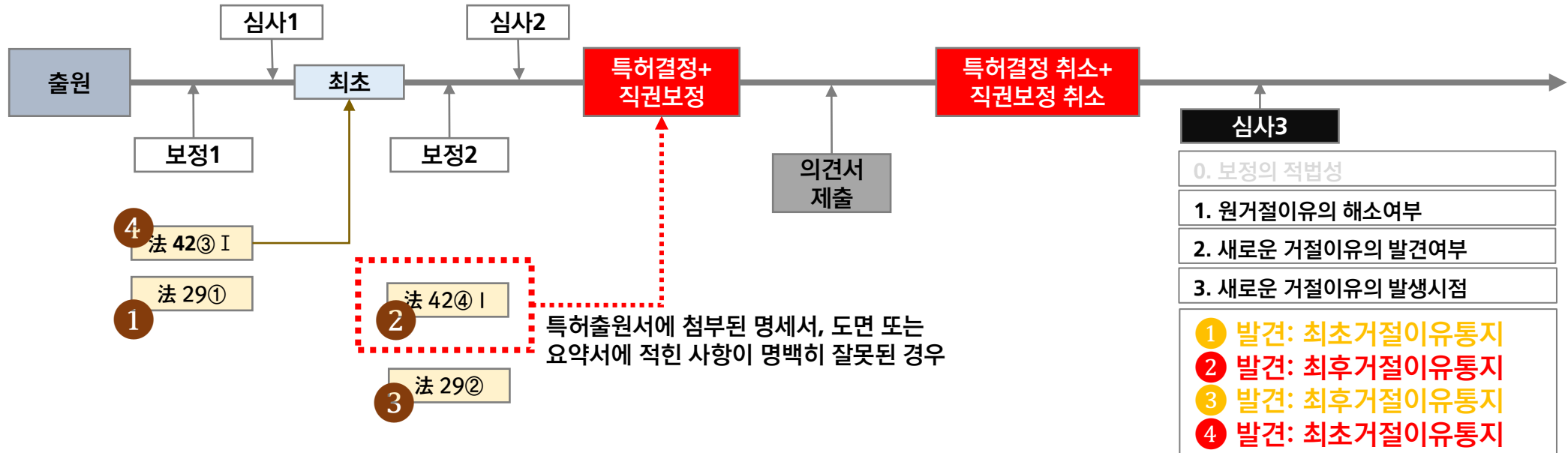
사소한 오타자

구 분		예시 및 설명
국문법에 어긋난 오자		(a) 반도테 → 반도체 (b) 기판은 → 기판은
국문법상 해석이 분명한 탈자		(a) 라인에 전달하○신호 → 라인에 전달하는 신호 (b) 리니어 터 → 리니어 모터
참조부호의 불일치		명세서 중 [도2] 버퍼부(115) vs 도면 [도2] 버퍼부(15)
반복된 기재		지식재산처 지식재산처는 → 지식재산처는
도면의 간단한 설명의 오류	도면번호오기	도 1은 재생기기의 단면도 도 1은 재생기기의 측면도 → 도 2는 재생기기의 측면도 도 3은 재생기기의 사시도
	도면부호오기	3...치차 3...모터 → 3...치차 4...모터
대표도의 오기		명세서로 파악해 본바 명백히 잘못 기재된 대표도
명세서상의 발명의 명칭이 출원서와 일치하지 아니한 경우		명세서의 발명의 명칭을 출원서에 기재된 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다. 만약, 출원서에 기재된 발명의 명칭이 명세서의 발명의 명칭 기재요건을 충족하지 못하는 경우에는 출원서와 명세서 모두를 적절하다고 인정되는 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다.

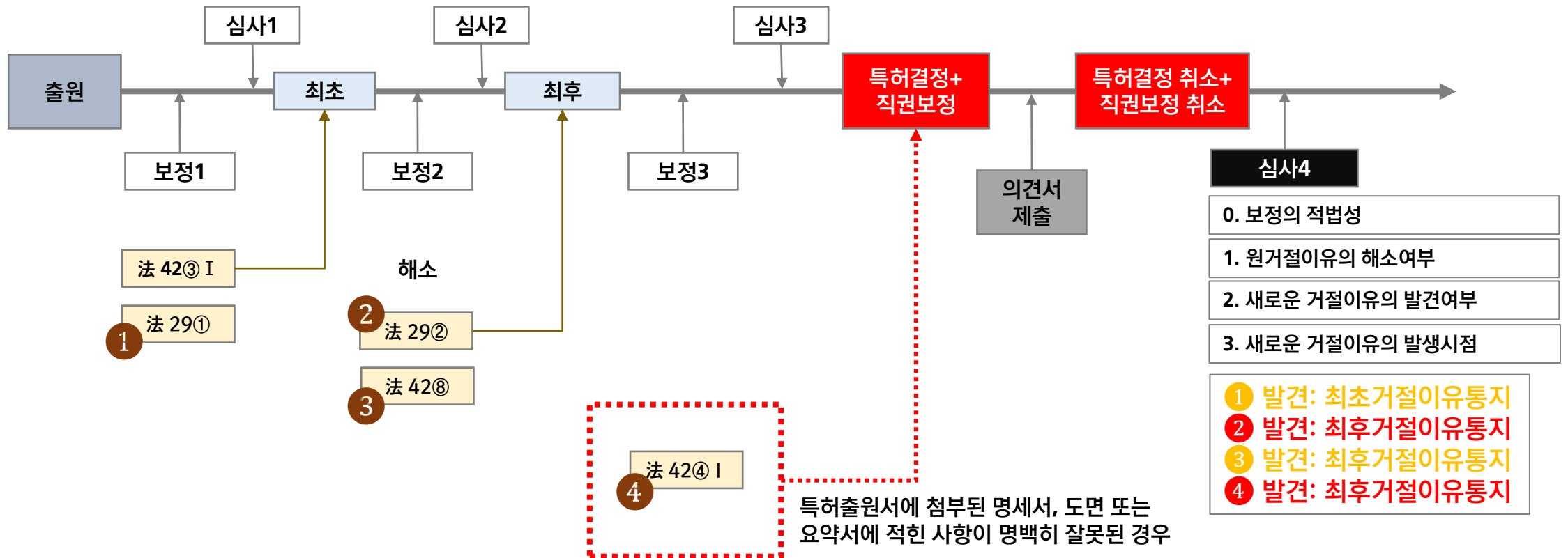
명백히 잘못된 기재불비

구 분		예시 및 설명
삭제된 청구항을 인용하는 경우	삭제된 청구항만을 인용하며, 선행 청구항이 1개인 경우	청구항 1. A와 B를 포함하는 장치 청구항 2. 삭제 청구항 3. 청구항 2에 있어서, C를 더 포함하는 장치 → 청구항 1에 있어서, C를 더 포함하는 장치
	삭제되지 않은 청구항도 인용하는 경우	청구항 1. A와 B를 포함하는 장치 청구항 2. 삭제 청구항 3. 청구항 1 또는 2에 있어서, C를 더 포함하는 장치 → 청구항 1에 있어서, C를 더 포함하는 장치
종속항임에도 인용하는 청구항과 말미가 다른 경우		청구항 1. A를 포함하는 장치 청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 방법 → 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치
보정으로 종속항이 인용하는 청구항에 병합되었음에도 종속항을 삭제하지 않은 경우		[보정 전] 청구항 1. A를 포함하는 장치 청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치 [보정 후] 청구항 1. A와 B를 포함하는 장치 청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치 → 삭제
동일한 구성을 두 개 이상의 용어를 사용하여 지칭하는 경우		청구항 1. 핵 형성층을 형성하는 단계와 상기 핵 생성층 위에 실리콘 층을 형성하는 단계를 포함하는 반도체층 형성 방법 → 청구항 1. 핵 형성층을 형성하는 단계와 상기 핵 형성층 위에 실리콘 층을 형성하는 단계를 포함하는 반도체층 형성 방법
청구항을 잘못 인용한 것이 명백한 경우		청구항 1. A를 포함하는 장치 청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치 청구항 3. 청구항 1에 있어서, 상기 B는 C인 장치 → 청구항 2에 있어서, 상기 B는 C인 장치
문언적으로 동일한 청구항을 중복하여 기재하는 경우		청구항 1. A와 B를 포함하는 장치 청구항 2. A와 B를 포함하는 장치 → 삭제
인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않은 경우		(a) 청구항 1 및 2에 있어서, → 청구항 1 또는 2에 있어서, (b) 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 중 적어도 어느 한 항에 있어서, → 청구항 1 내지 3 중 어느 한 항에 있어서,

특허결정이 취소된 것으로 보는 경우 심사관은 직권보정 전 명세서 또는 도면에 의하여 다시 심사를 진행한다. 이 때 심사관이 직권보정 전에 이미 통지된 거절이유가 발견되더라도 다시 거절이유를 통지하여야 한다. 다만, 그 거절이유가 출원인이 받아들이지 아니한 직권보정사항에 해당하고, 이미 통지된 거절이유라면 바로 거절결정할 수 있다.

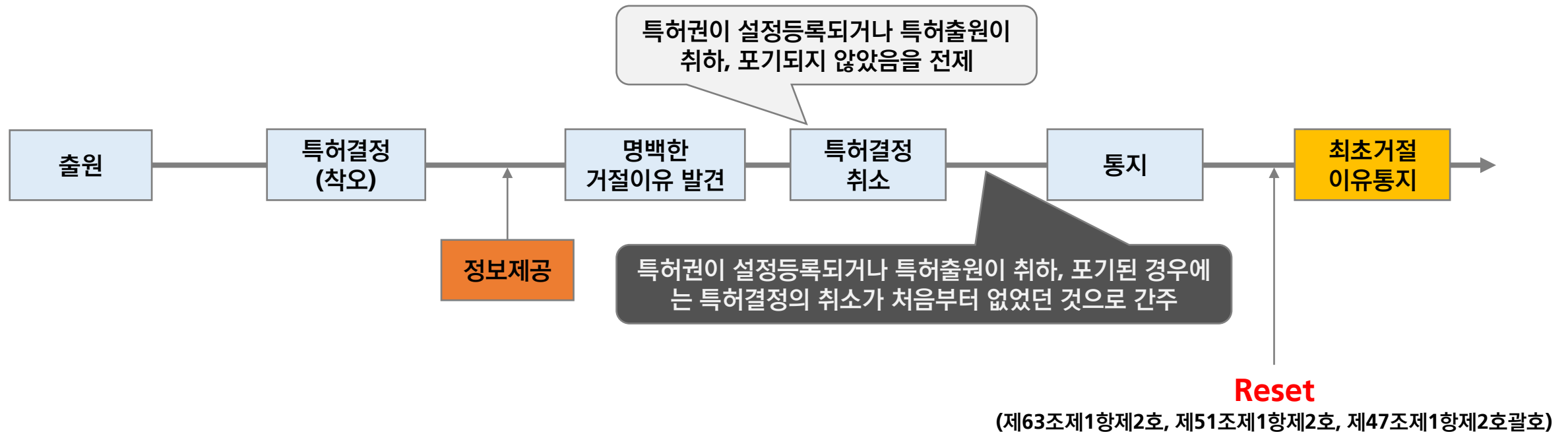


심사관은 직권보정 전에 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 한 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 보정각하결정을 하지 아니하고 특허결정한 것을 특허결정을 취소한 후에 발견한 경우에는, 보정각하를 하지 아니하고 **최후거절이유통지**를 한다(法 51① I). 이는 보정이 인정됨을 전제로 특허결정을 받았다는 것을 신뢰한 출원인의 이익을 보호하기 위함이다.

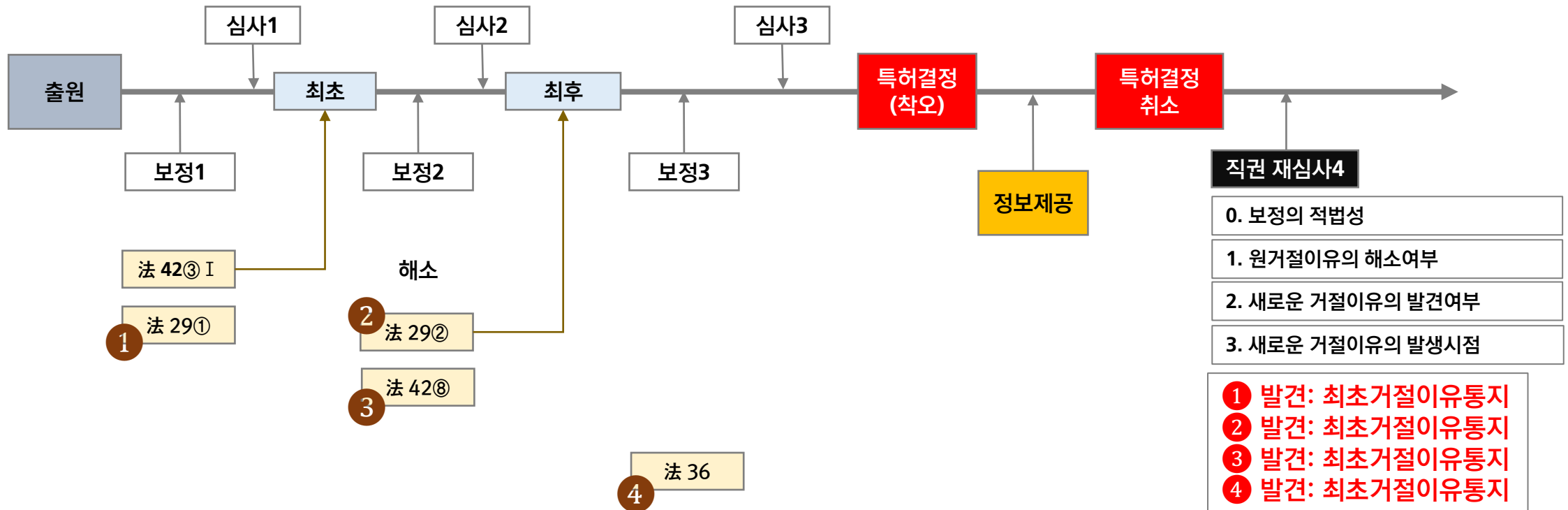


제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 "직권 재심사"라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우
 2. 그 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우
 3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우
- ② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다.
- ③ 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

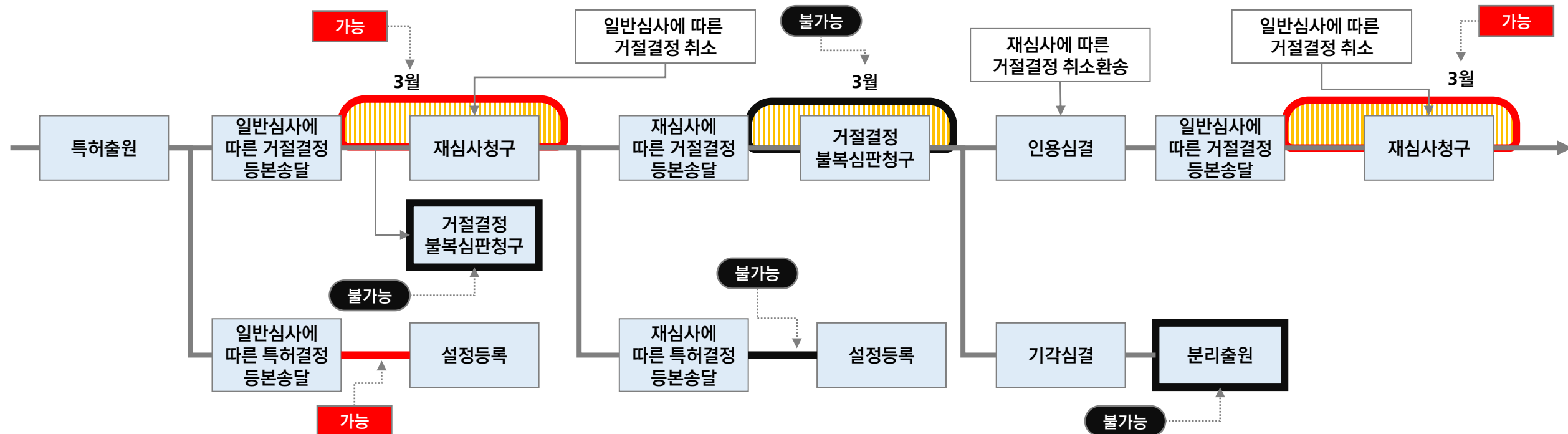


심사관은 특허결정을 취소한 경우에는 다시 심사를 진행한다. 심사관은 직권 재심사에 이르게 된 명백한 거절이유에 대해서는 특허출원인에게 최초거절이유를 통지하여 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 47①Ⅱ괄호). 즉, 심사관이 특허결정을 취소한 경우에는 다시 최초거절이유통지를 하여, 출원인에게 청구범위를 확장, 변경할 수 있는 보정기회를 주고 있다(法 47②). 심사관은 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우에도 특허출원인에게 최초거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 63①Ⅱ). 이는 심사관이 특허출원에 관하여 명백한 거절이유가 있음에도 불구하고 특허결정을 한 후 이를 취소하여 다시 심사를 진행할 때 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유를 이유로 곧바로 거절결정하는 것은 출원인에게 가혹하기 때문이다. 심사관은 취소된 특허결정 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 한 보정이 신규 사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 보정각하결정을 하지 아니하고 특허결정한 것을 특허결정을 취소한 후에 직권 재심사단계에서 발견한 경우에는, 보정각하를 하지 아니하고 최초거절이유통지를 한다(法 51①Ⅱ, 47①Ⅱ). 이는 보정이 인정됨을 전제로 특허결정을 받았다는 것을 신뢰한 출원인의 이익을 보호하기 위함이다.

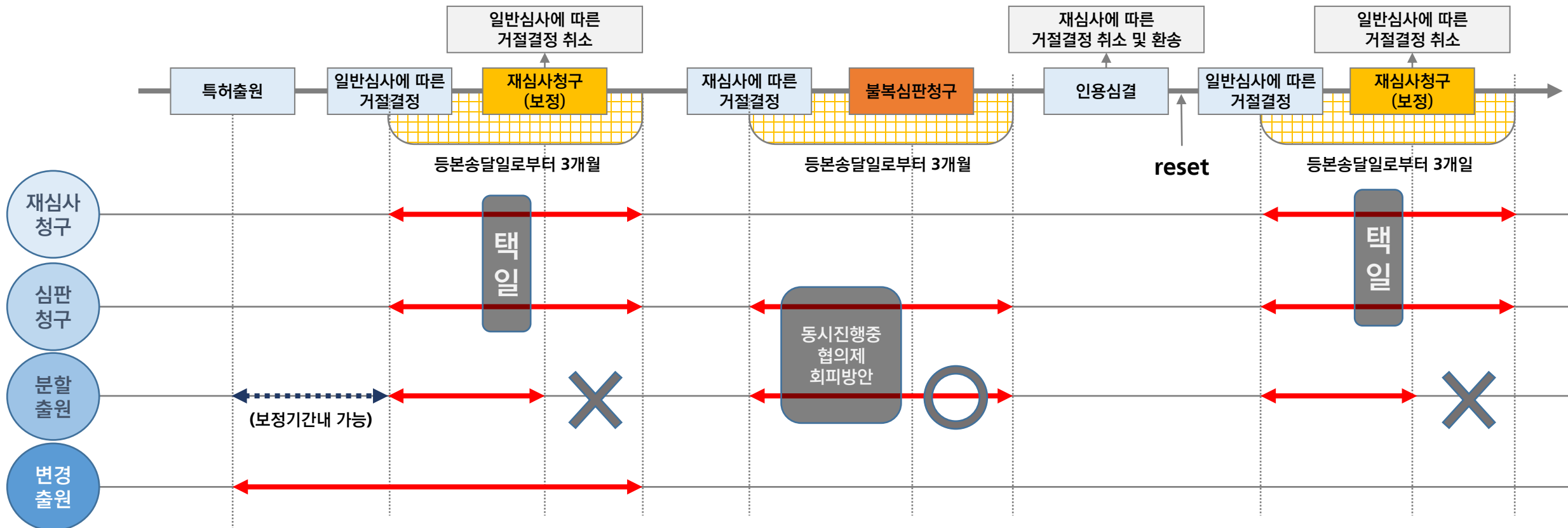


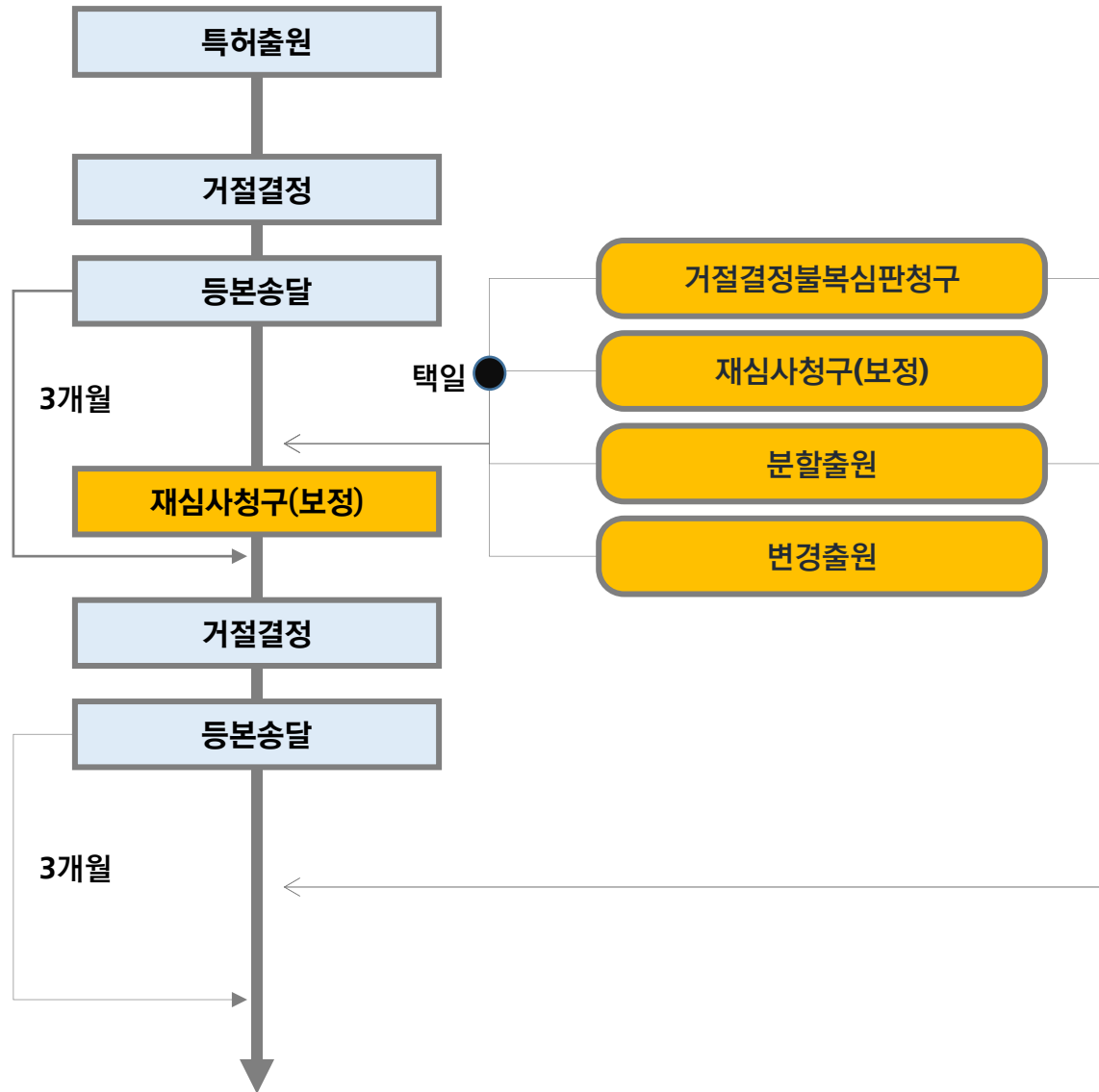
제67조의2(재심사의 청구) ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 **특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간** 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 "재심사"라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우
 2. 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다)
 3. 그 특허출원이 분리출원인 경우
- ② 특허출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.



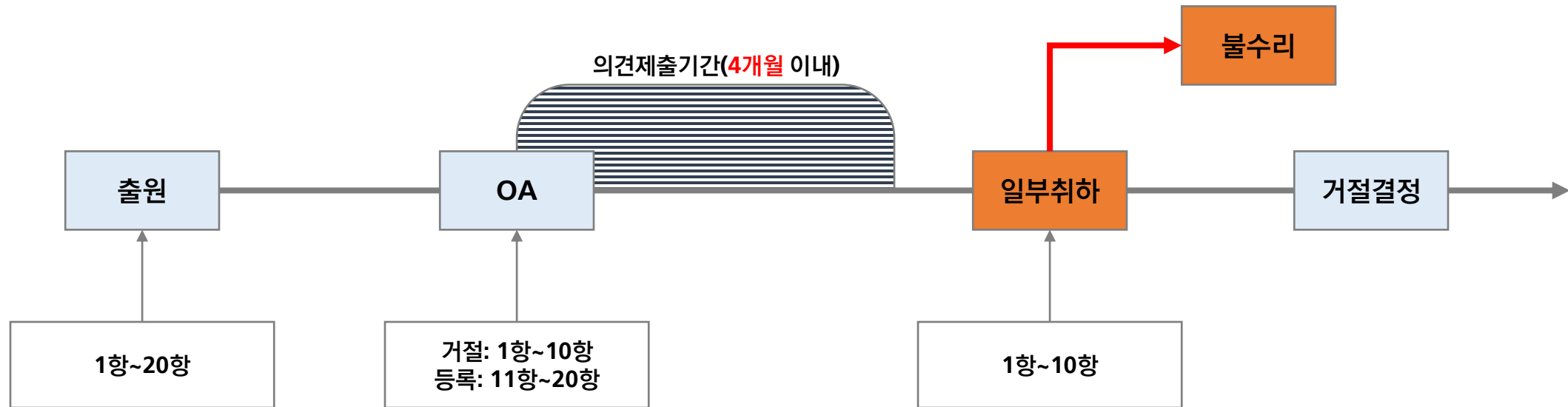
그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조 제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 “재심사”라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 1) 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우, 2) 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다), 3) 그 특허출원이 분리출원인 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다(法 67의2①). 즉, 이미 재심사 청구를 하여 다시 특허거절결정이 된 경우에는 재심사 절차의 반복으로 인해 심사가 지연되는 것을 방지하기 위해 다시 재심사 청구를 할 수 없고, 거절결정불복심판만 가능하다. 물론, 거절결정불복심판에서 재심사에 따른 특허거절결정이 취소되고, 심사국으로 환송된 이후 특허거절결정등본이 송달된 경우에는 재심사에 따른 특허거절결정은 아니기 때문에 다시 재심사 청구를 할 수 있다. 또한, 거절결정불복심판청구와 재심사청구는 선택적 사항으로서 출원인은 특허거절결정등본송달일로부터 **3개월**(연장된 경우에는 그 연장된 기간) 이내 둘 중에 하나를 선택하여 특허거절결정에 대하여 다룰 수 있다.





구 분	취 급
심판청구서를 제출한 후 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 경우	제67조의2제1항제2호에서 재심사를 청구할 때에 이미 거절결정불복심판이 청구된 경우에는 재심사를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바, 보정서 제출 시점을 기준으로 심판청구가 계속 중인 경우에는 특허법 시행규칙 제11조제1항제19호를 이유로 소명 기회를 부여하고 보정서를 반려 한다. 이때 보정서를 반려 받은 출원인은 제67조의2 제1항의 기간이 지나지 않았다면 심판청구를 취하하고 보정하면서 재심사를 다시 청구할 수 있다.
재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우	보정서 제출에 따른 보정 및 재심사청구 절차는 적법하므로 거절결정이 취소된 것으로 보고 재심사절차를 진행한다. 이 경우 심판절차는 심결각하 된다.
심판청구서와 재심사청구 취지를 기재한 보정서가 동일자로 제출된 경우	심판청구서와 보정서의 제출 시점을 확정할 수 없는바, 출원인의 선택을 유도하기 위해 보정서가 늦게 제출된 것으로 보고 보정서에 대하여 반려이유를 즉시 통지한다. 반려이유통지서에서는 출원인이 거절결정 불복심판이나 재심사 중 어느 하나를 선택할 수 있음을 상세히 설명 하여야 한다. 출원인이 심판청구를 취하하는 경우에는 재심사청구가 유효한 것으로 보고 재심사절차를 진행하고, 반려 요청하는 경우에는 보정서를 즉시 반려한다.
심판청구서와 재심사청구 취지가 기재되지 않은 보정서를 동일자에 제출한 경우	보정서에 재심사청구의 취지가 기재되지 않은바, 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 것으로 볼 수 없으므로 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 취급하여 소명 기회를 부여한 후 보정서를 반려 한다.

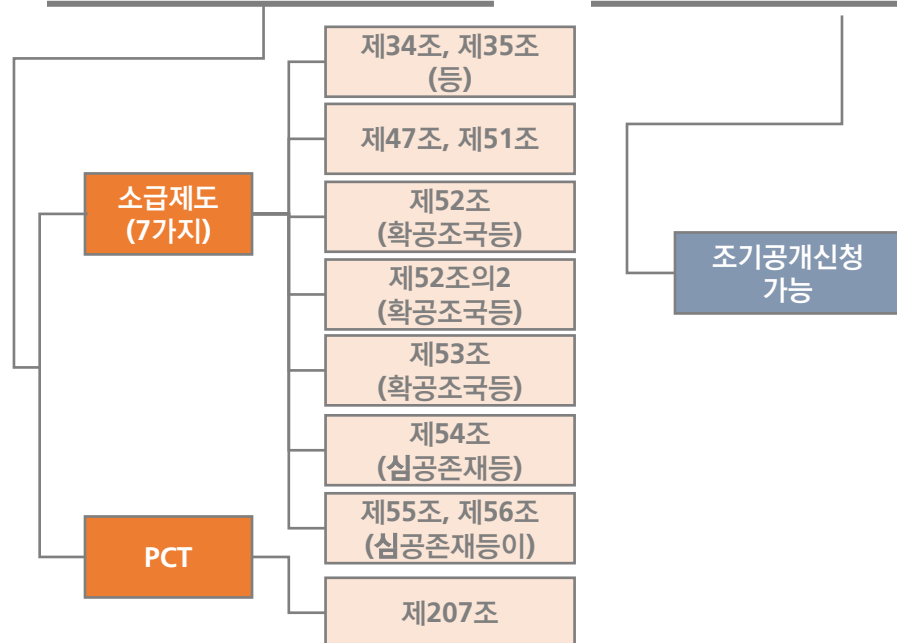
문제가 되는 것은 청구항별 일부 취하가 허용되는지 여부이다. 이에 대하여 대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결은 “출원서에 첨부된 명세서와 도면의 보정이라는 제도 및 그 보정의 시기와 범위를 제한하는 규정을 두고 있을 뿐 특허결정이 되기 전에 특허출원의 일부를 취하할 수 있다고 규정해 놓은 바 없으며, 특허법에 정해진 보정기간이 지난 후에도 특허출원의 일부 취하를 허용하는 것은 특허출원의 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법의 취지에도 반하므로 원칙적으로 청구항별 일부 취하는 허용되지 아니한다.”고 하여 일부 취하서를 삭제보정서와 동일시하고 있다. 즉, **청구항별 일부 취하를 하는 경우 보정기간의 제한을 가하여, 보정기간을 지난 일부 취하서를 불수리하는 한편, 특허출원을 거절결정하였다.**



제64조(출원공개) ① 지식재산처장은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후 또는 그 전이라도 특허출원인이 신청한 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다.

1. 제54조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일
2. 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 선출원의 출원일
3. 제54조제1항 또는 제55조제1항에 따른 둘 이상의 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일
4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 특허출원의 경우: 그 특허출원일

특허출원일로부터 1년 6개월

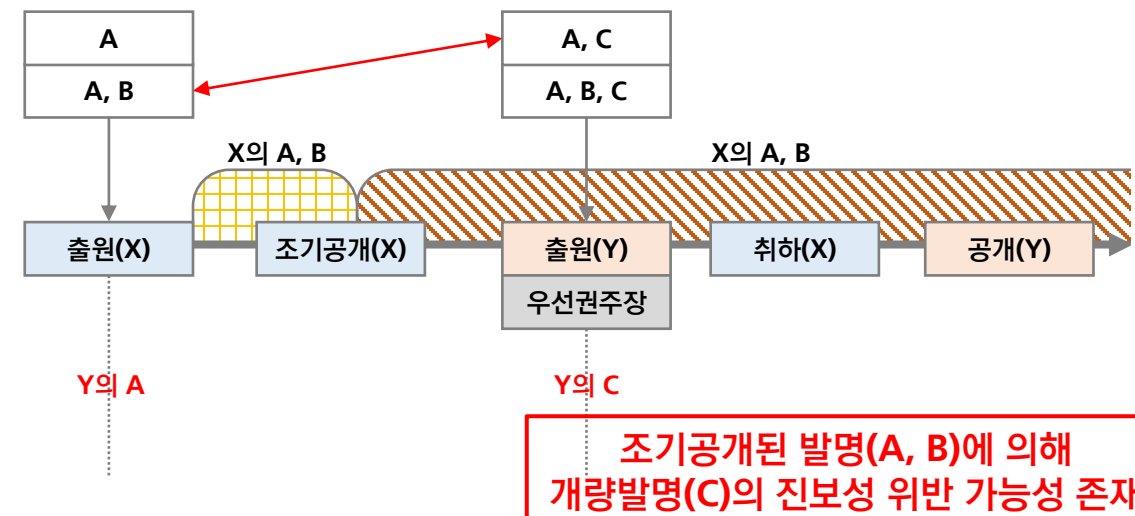


시행규칙 제44조(조기공개 등의 신청) ① 법 제64조제1항에 따라 특허출원일부터 1년 6개월이 경과하기 전에 특허출원의 공개를 신청하려는 자는 별지 제25호서식의 조기공개신청서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 특허출원과 동시에 공개를 신청하려는 경우(청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 경우만 해당한다)에는 출원서에 그 취지를 기재함으로써 신청서의 제출에 갈음할 수 있다.

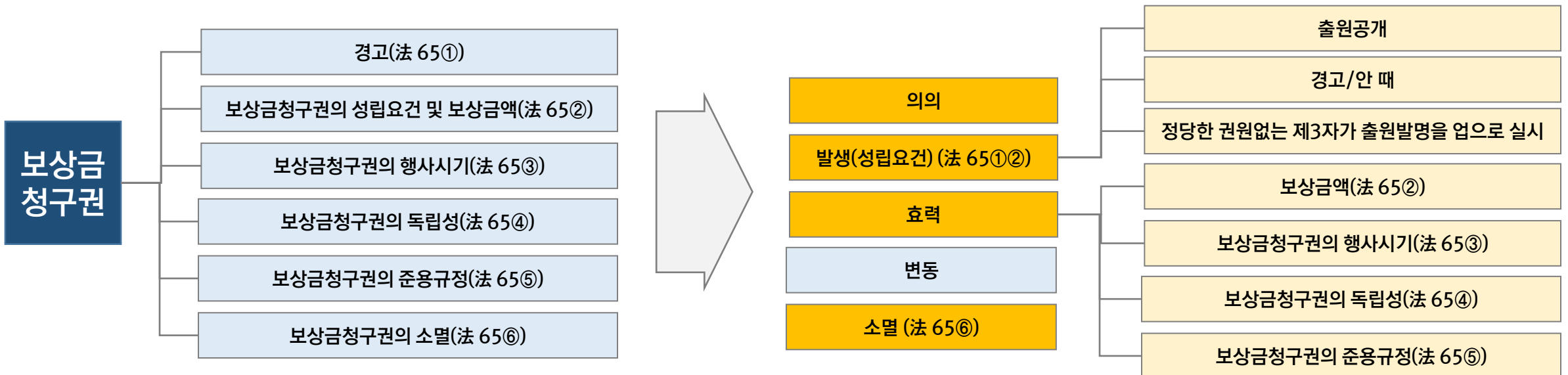
② 외국어특허출원 또는 국제특허출원의 경우에는 법 제42조의3제2항 또는 법 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 후가 아니면 조기공개의 신청을 할 수 없다.

③ 특허에 관한 절차를 밟는 자가 제1항의 규정에 의한 조기공개의 신청을 취하하고자 하는 경우에는 **조기공개신청서를 제출한 날부터 10일 이내에** 별지 제12호서식의 취하서를 제출하여야 한다.

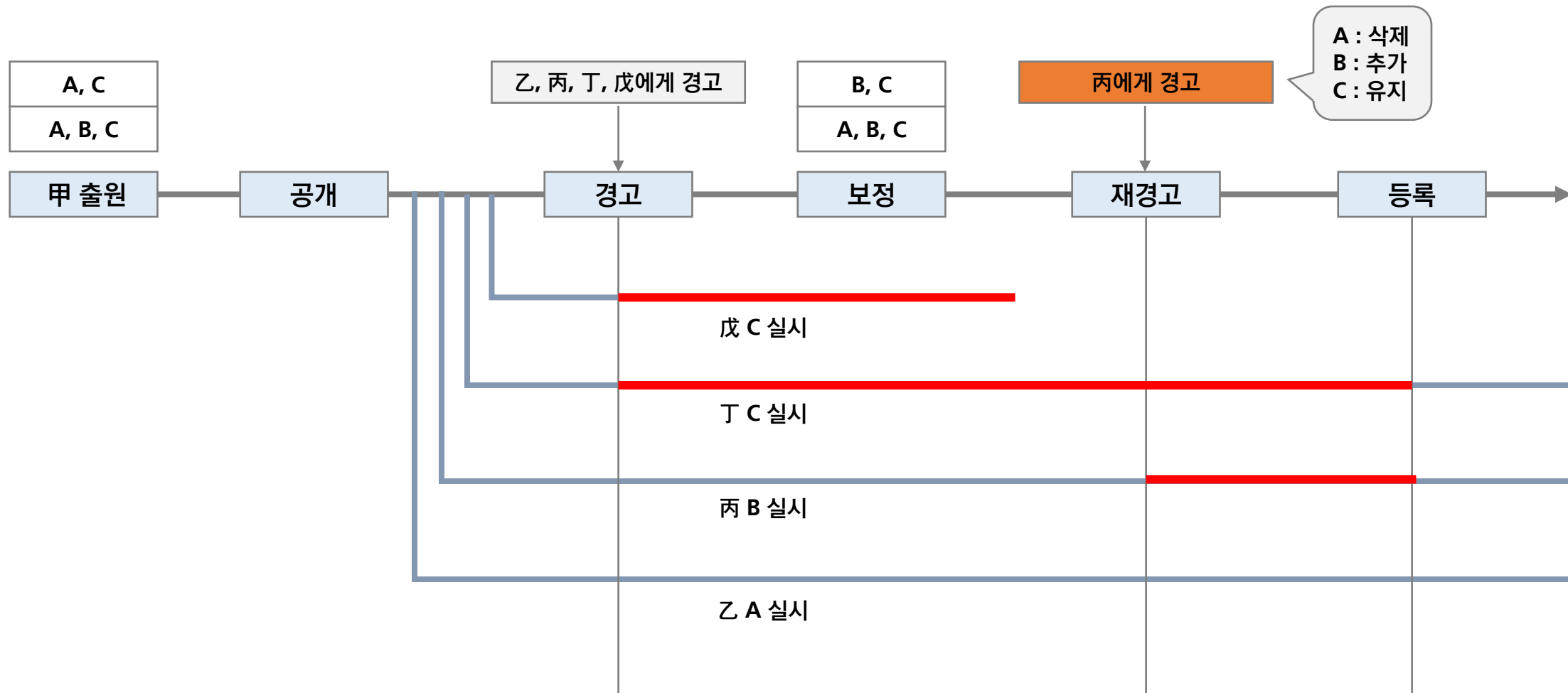
④ 대리인이 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.



- 제65조(출원공개의 효과)** ① 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다.
- ② 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 **합리적으로** 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.
- ③ 제2항에 따른 청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.
- ④ 제2항에 따른 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.
- ⑤ 제2항에 따른 청구권을 행사하는 경우에는 제127조·제129조·제132조 및 「민법」 제760조·제766조를 준용한다. 이 경우 「민법」 제766조제1항 중 "피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날"은 "해당 특허권의 설정등록일"로 본다.
- ⑥ 제64조에 따른 출원공개 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.
1. 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
 2. 특허출원에 대하여 제62조에 따른 특허거절결정이 확정된 경우
 3. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이 확정된 경우
 4. 제133조에 따른 특허를 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항제4호에 따른 경우는 제외한다)이 확정된 경우



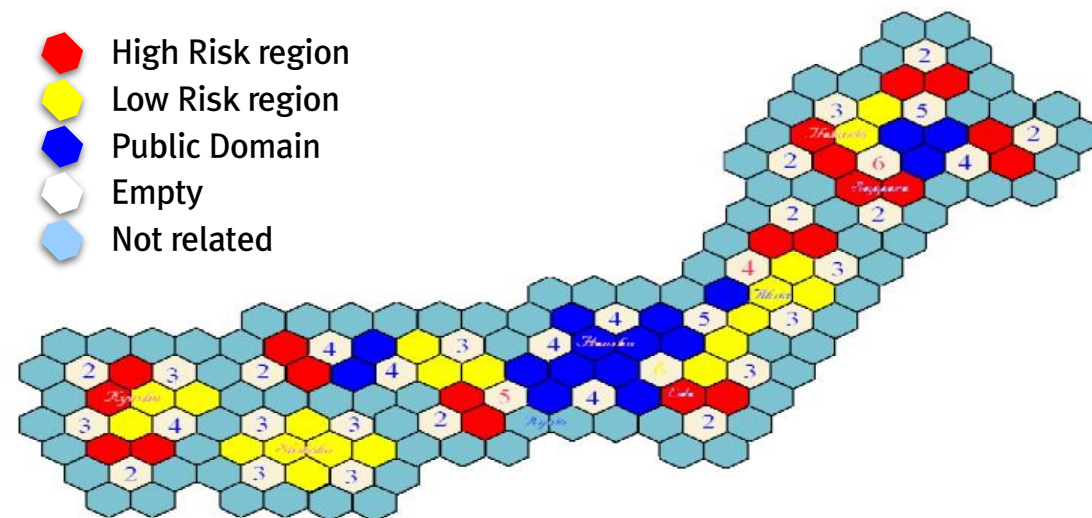
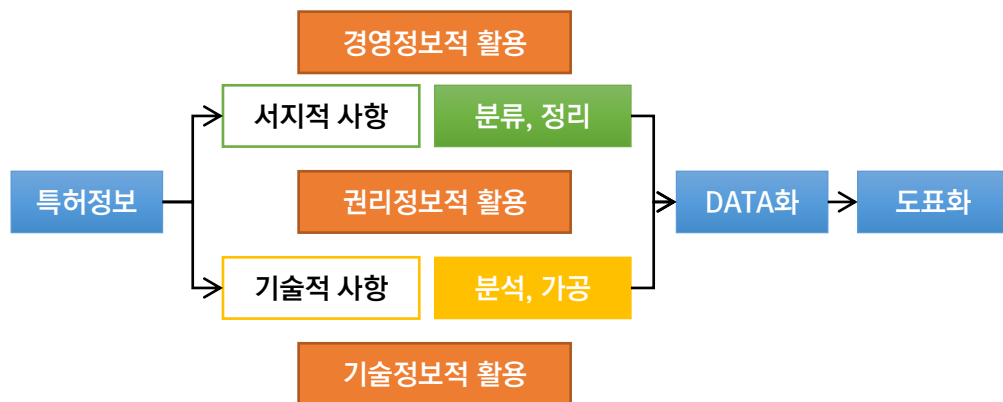
출원인이 출원발명임을 경고한 후 청구범위 보정을 한 경우에 재경고를 하여야 하는지 여부가 문제된다. **보정에 의하여 청구범위가 확장 또는 변경된 경우에는 그 확장 또는 변경된 내용에 대하여 보상금청구권을 행사하기 위해서는 다시 경고를 하여야 하나** **보정에 의하여 청구범위가 감축 또는 삭제된 경우에는 재경고를 할 필요가 없다.**

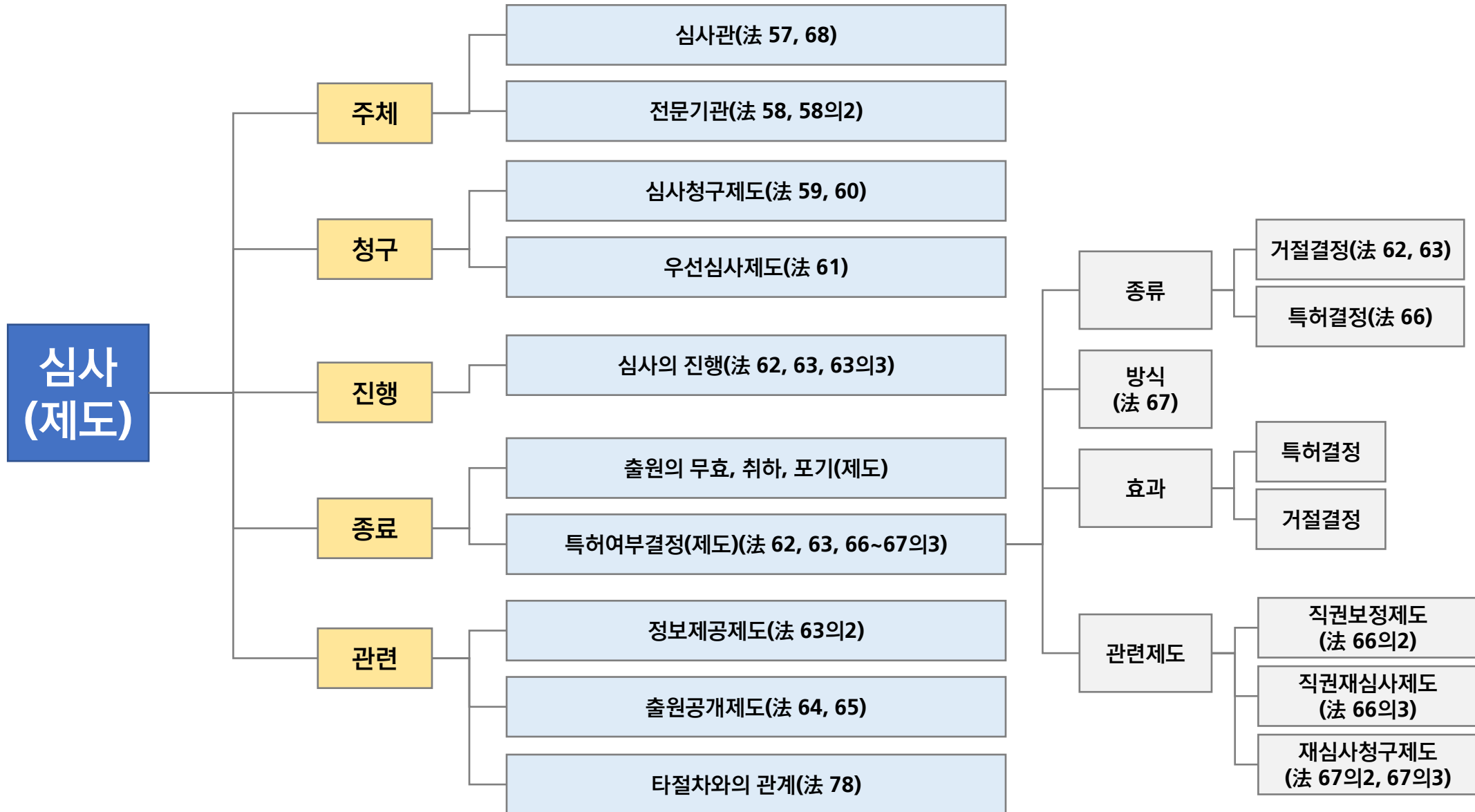


목적	주요 내용	검색 전략
신기술 개발을 위한 조사	▪ 관련 기술분야의 개발흐름을 파악 ▪ 연구개발 테마를 선정하거나 미래기술 예측 ▪ 선행기술조사로 중복투자 및 중복투자 방지 ▪ 기술개발시 문제점 해결을 위한 아이디어 입수 ▪ 타사의 기술개발 동향 파악	▪ 관련성 있는 기술범위를 넓게 설정하여 조사 ▪ 해결하고자 하는 과제를 중심으로 조사
특허등록 가능성/특허권 존 재 여부 조사	▪ 특허출원전 선행기술조사 ▪ 특허등록 가능성 판단 및 권리범위 가능 영역의 확인 ▪ 무용한 특허출원의 지양 ▪ 특허등록 가능성이 높아지도록 명세서 작성	▪ 신규성, 진보성의 판단 기준을 고려하여 조사 ▪ 기술의 구성요소를 특정하고, 이에 상응하는 구성요소들이 공지되어 있는지를 중점적으로 조사
특허분쟁 대응 자료 조사	▪ 시장출시 예정 제품에 대한 특허침해 가능성 있는 특허 검색 ▪ 특허분쟁 가능성 사전 예방 ▪ 회피설계 타진 또는 해당 권리의 무효화 추진 ▪ 문제 특허에 대한 정보제공 또는 무효자료 조사	▪ 침해이론(All Elements Rule, 균등론)에 입각하여 침해 문제가 있는 선행기술을 중점적으로 조사 ▪ 경쟁사의 포트폴리오를 분석 ▪ 회피설계방안을 고려하여 공지기술 조사 ▪ 등록되지 않은 특허의 경우에는 지속적인 모니터링 방안 제시 ▪ 인용도(Forward, Backward Citation)를 활용하여 심도 있는 조사

특허맵이란 특허정보를 분석하여 서지사항의 분류, 정리하고, 기술적 사항을 분석, 가공하여 특허정보만이 가지고 있는 경영정보, 권리정보 및 기술정보를 도표화한 것을 말한다.

경영정보분석 (경영전략 수립)	경쟁사의 동향 파악, 시장동향 및 상품의 변형과 흐름파악
	신규 사업방향 및 가능성 파악
	자사 기술 매각, 해외진출, 기술도입
	사업화시 주의를 요하는 권리 파악
기술정보분석 (연구개발전략 수립)	R&D 동향 파악, 공백 기술 분야 파악, 선행 프로젝트의 현존기술 파악, 중요 특허 파악, 타깃제품의 시장조사
	기술 분야의 체계 파악, 자사의 위치 설정
권리정보분석 (특허전략 수립)	정보제공, 취소신청 및 무효심판 등의 자료
	특허 관리망 형성
	강력한 특허권 취득을 위한 명세서 파악

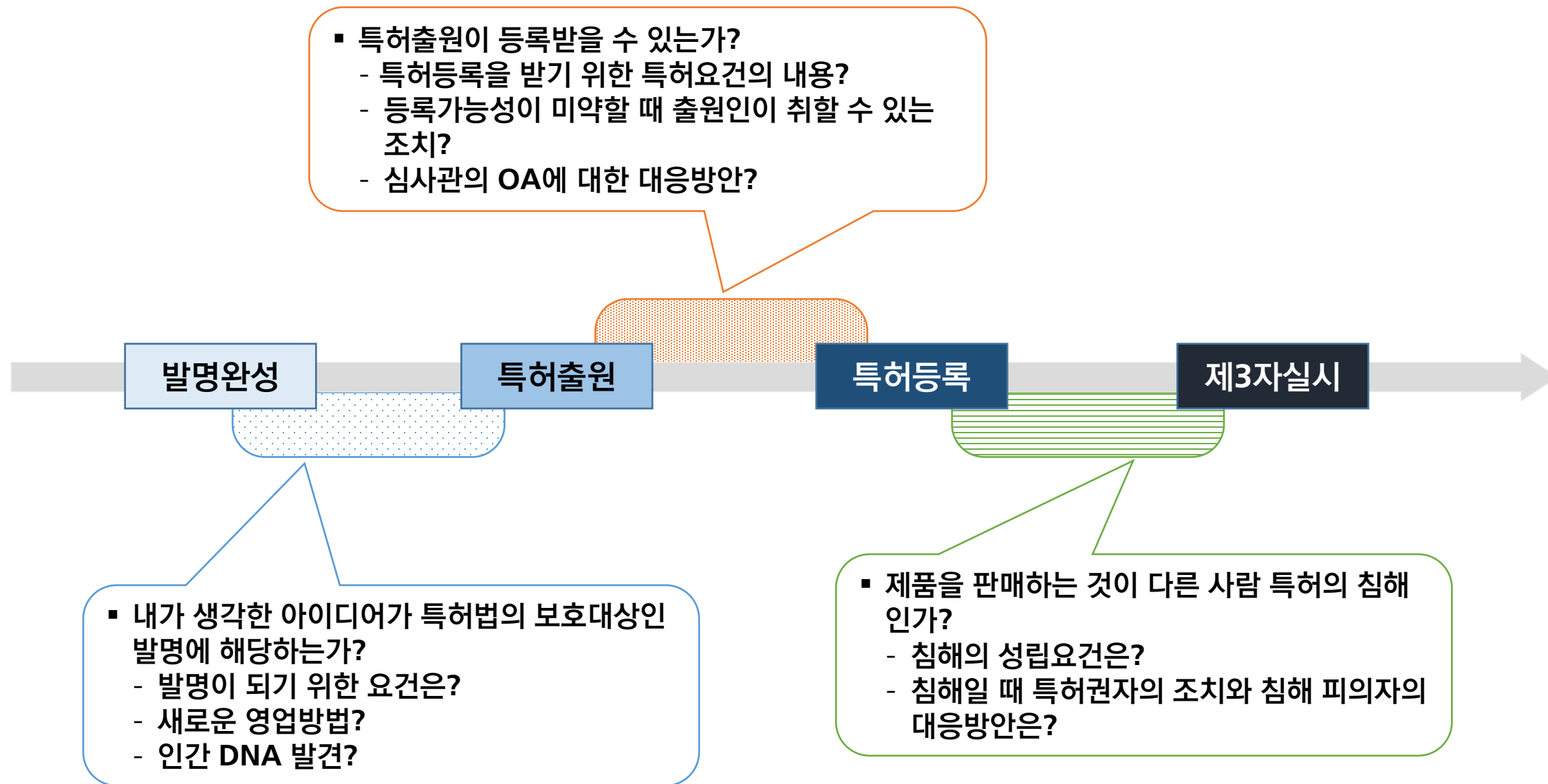


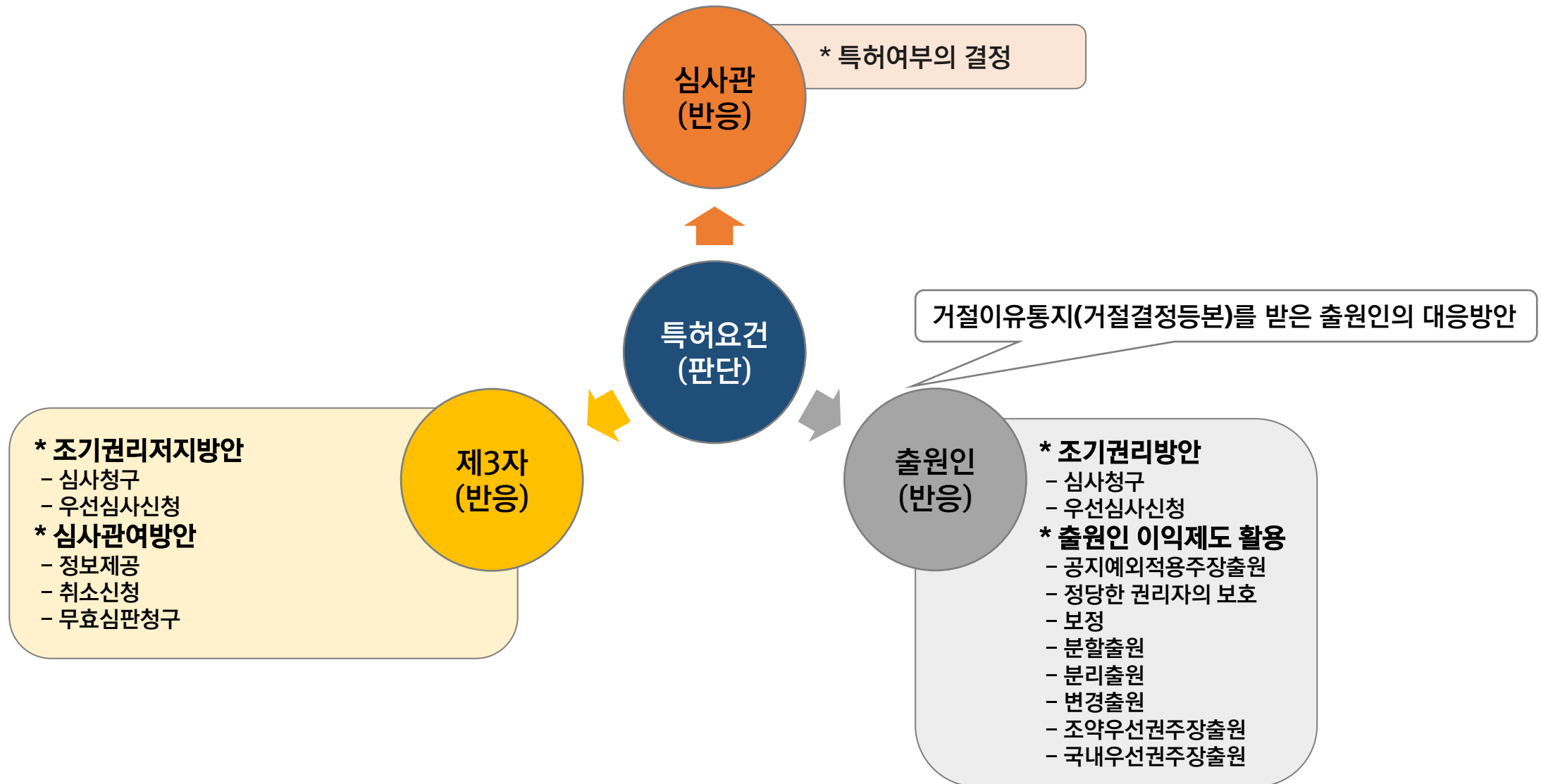


제도			심사청구제도	우선심사제도	특허여부결정제도	재심사청구제도
요건	주체적		1.누구든지, 비법인사단·재단(法4) 2.출원인은 1)명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우, 2)외국어특허출원인데 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 심사청구 不可	1.누구든지 2.단, 국가·지방자치단체의 직무에 관한 특허출원의 경우는 국가 또는 지방자치단체(전담조직도 포함)만	심사관	출원인 또는 그 승계인
	객체적	대상	적법하게 출원계속중인 발명	1.출원공개후 제3자의 무단실시의 경우(法 61Ⅰ) 2.긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우(法 61Ⅱ) 3.재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우(法 61Ⅲ) 4.타법에서 규정하고 있는 경우-의지	1.심사청구된 출원 2.보정된 경우 ①法47①본,Ⅰ-보정된 내용 반영한 명세서 또는 도면 ②法47①Ⅱ,Ⅲ-보정적법성을 판단 3.외국어특허출원-번역문	특허여부결정등본을 송달받은 출원으로서 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정
		범위	청구항별 불가	하나의 청구항이라도 대상인 경우 가능		
	시기적	원칙	출원일로부터 3년 이내	1.출원공개후 제3자의 무단실시의 경우-심사청구+출원공개후 2.그밖의 사유-심사청구	1.거절결정 ①거절이유통지 ②의견서/보정서제출 ③거절결정 2.특허결정	그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제 79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다)
		예외	1.조약우선권주장출원(法54①),국내우선권주장출원(法55②)의 경우 소급효× 2.분할·분리·변경출원·정당한권리자출원의 특례(法59③) 3.국제특허출원(法 210)			1.재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우 2.거절결정불복심판청구(法 132의17)가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다) 3.그 특허출원이 분리출원인 경우
절차			1.심사청구서 제출(法60①) 2.심사청구사실의 게재(法60②) 3.심사청구사실의 통지(法60③) – 法 42의2, 42의3 4.심사청구료 납부(法82②, 16①단서)	1.우선심사의 신청 2.우선심사여부의 결정-우선심사 각하 불복X	1.서면+이유 2.지식재산처장이 등본 송달	1.명세서등의 보정서에 그 취지를 병기하여 제출 2.출원인은 재심사청구와 함께 의견서 제출 가능
효과	적법	1.심사의 개시(法59①) ①원칙 - 심사청구순위 ②예외 - 분할/분리/변경출원, 우선심사 2.취하금지(法59④)	우선심사 - 신속한 권리구제 및 권리이용	1.특허료납부 2.직권보정 3.직권재심사 4.재심사청구 5.공지예외적용주장, 분할출원 또는 변경출원	1.특허여부결정은 취소된 것으로 보고(法67의2③), 재심사를 진행 2.출원인은 재심사에 따른 거절결정등본송달후 3개월 이내에 거절결정불복심판(法 132의2)을 청구하거나 분할출원(法 52)可 3.보정각하의 예외(法 51①단서). 4.재심사의 청구는 취하 不可(法 67의2④).	
	부적법	출원 취하간주(法 59⑤)	1.심사청구순서에 따라 심사 2.수수료의 반환	1.거절결정의 불복 2.거절결정의 확정 3.재심사청구	1.재심사의 청구절차가 무효로 된 경우 특허여부결정은 취소되지 아니한 것으로 간주(法 67의2③단서) 2.① 보정서가 제출되지 아니한 경우 ② 시기에 위반된 재심사 청구의 경우 재심사 청구서는 반려	

제도		직권보정제도	직권재심사제도	출원취하/포기제도	정보제공제도	출원공개제도	
요건	주체적	심사관	심사관	1.공동출원의 경우 전원 2.임의대리인은 특별수권 3.법정대리인 중 후견인은 후견감독인의 동의	누구든지	지식재산처장에 의한 강제공개, 출원인의 신청에 의한 조기공개	
	객체적	대상	특허결정된 특허출원에 관하여 배경기술 기재(法 42③Ⅱ), 다항제 기재방법(法 42⑧) 및 하나의 특허출원의 범위(法 45) 위반을 제외한 명백한 거절이유를 발견한 경우	1.의사에 의한 경우 ①출원전체 ②단,등록료 납부시 청구항별 포기 가능(法 215) 2.법률에 의한 경우	거절이유(法 62)(단, 절차적 요건(발명의 설명 중 배경기술 기재(法 42③Ⅱ), 다항제 기재방법(法 42⑧) + 1특허출원의 범위(法 45) 제외)	1.원칙-출원 계속 중인 모든 특허출원 2.예외 ①명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우(法 64②Ⅰ) ②국어번역문을 제출하지 아니한 경우(法 64②Ⅱ) ③등록공고를 한 특허의 경우(法 64②Ⅲ) ④국방상 필요한 발명으로서 비밀취급이 필요한 경우(法 64③) ⑤공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우	
		범위				청구항별로 가능	
	시기적	원칙	특허결정할 때	특허권이 설정등록되기 전이나 특허출원이 취하/포기되기 전	출원계속중	1.당해 출원이 지식재산처에 계속중인 경우 2.거절결정불복심판단계에서 가능(단, 심판원장에게 제출)	출원일로부터 1년6월 지난 후
		예외					1.출원일/판단시점은 모두 소급효 2.1년6월전이라도 출원인의 신청에 의하여 조기공개가 가능
절차		특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 통지	1.특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지(法 66의3②) 2.통지 받기 전 특허권이 설정등록된 경우나 특허출원이 취하/포기된 경우에는 특허결정의 취소는 없었던 것으로 간주(法 66의3③)	취하/포기서 제출	1.정보제공 2.심사에 참고 3.활용여부 및 특허여부결정 통보	1.전문공개,CD-ROM 2.조기공개신청의경우 ①신청서의 제출 ②외국어출원, 국제특허출원의 경우 번역문 제출 후에 신청가능 ③신청일로부터 10일 이내 취하	
효과	적법	출원인이 의견서를 제출하지 아니한 경우 의사에 의한 보정과 같이 취급(法 66의2③). 단, 직권보정이 신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 간주(法 66의2⑤)	1.특허결정취소 후 최초거절이유통지(法 63①Ⅱ+51①Ⅱ+47①Ⅱ괄호) 2.보정각하의 예외(法 51①Ⅱ)	1.절차의 종료 2.등록금지적 효력 3.보상금청구권의 소멸 4.출원료등의 반환	심사의 신속성 및 정확성 향상	1.보상금청구권의 발생(法65) 2.우선심사의 신청(法61Ⅰ) 3.특허출원에 관한 서류의 열람신청(法216) 4.기탁된 미생물의 분양 5.공지기술로 활용 6.확대된 선출원 인정	
	부적법	1.특허료를 낼 때까지 의견서를 지식재산처장에게 제출하면 특허결정과 직권보정 취소간주(단, 요약서에 대한 의견서는 직권보정만 취소간주)(法 66의2④) 2.직권보정 전 명세서, 도면에 의하여 심사(직권보정사항이 아닌 거절이유에 대해서는 다시 거절이유통지) 3.보정각하의 예외(法 51①Ⅰ)					

권리		특허를 받을 수 있는 권리	보상금청구권
서	의의	발명의 완성에 의하여 발생하고, 특허출원에 대한 거절결정확정이나 설정등록이 있기 전까지 인정되는 권리	출원공개가 있는 후 경고받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 경고받거나 알았을 때부터 설정등록을 한 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있는 권리
	취지	특허권 발생이전에 발명자 또는 출원인 보호	공개로 인해 상실된 이익의 보전
	성질	사권(재산권)과 공권(특허부여요구권)을 병합	1.해제조건부 권리 2.채권적 권리 3.특허권의 독립적인 권리
발생		발명의 완성에 의하여 발생	1.출원공개가 있을 것 2.경고받거나 알고 있을 것 3.정당한 권원없는 제3자가 업으로서 출원발명을 실시할 것
효력	범위	1.특허부여요구권 ①특허부여의 요구(法42) ②타인의 등록금지	1.보상금액(法65②)-경고받거나 알았을 때부터 설정등록을 한 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구
	내용	2.발명자권 ①인격권 ②재산권	2.행사시기(法65③)-등록 후 3.독립성(法65④)-특허권과 별개 4.준용규정(法65⑤) ①특허법상-간(法 127), 생(法 129), 자(法 132) ②민법상-공(民法 760), 소(民法 766)
변동	이전	1.이전가능(法 37①) 2.특발권의 승계(法 38)	
	실시권		
	질권	불가(法 37②)	
소멸	원인	1.권리능력 상실(상속인 부존재도 포함) 2.출원계속의 소멸	1.특허등록이 되지 않은 경우 2.특허등록이 되더라도 소급 소멸하는 경우
	효과	1.공개전 소멸-등록금지적 효력X 2.공개후 소멸-法29①②③	1.고의과실○-손배청구 2.고의과실×-부당이득반환청구
공유		다른 공유자 동의 받아야만 지분양도 可(法 37③)	특허등록후 소급 소멸한 경우만 해당





총칙/
보칙

특허
요건

이익
제도

심사
(제도)

특허권

심판/
소송

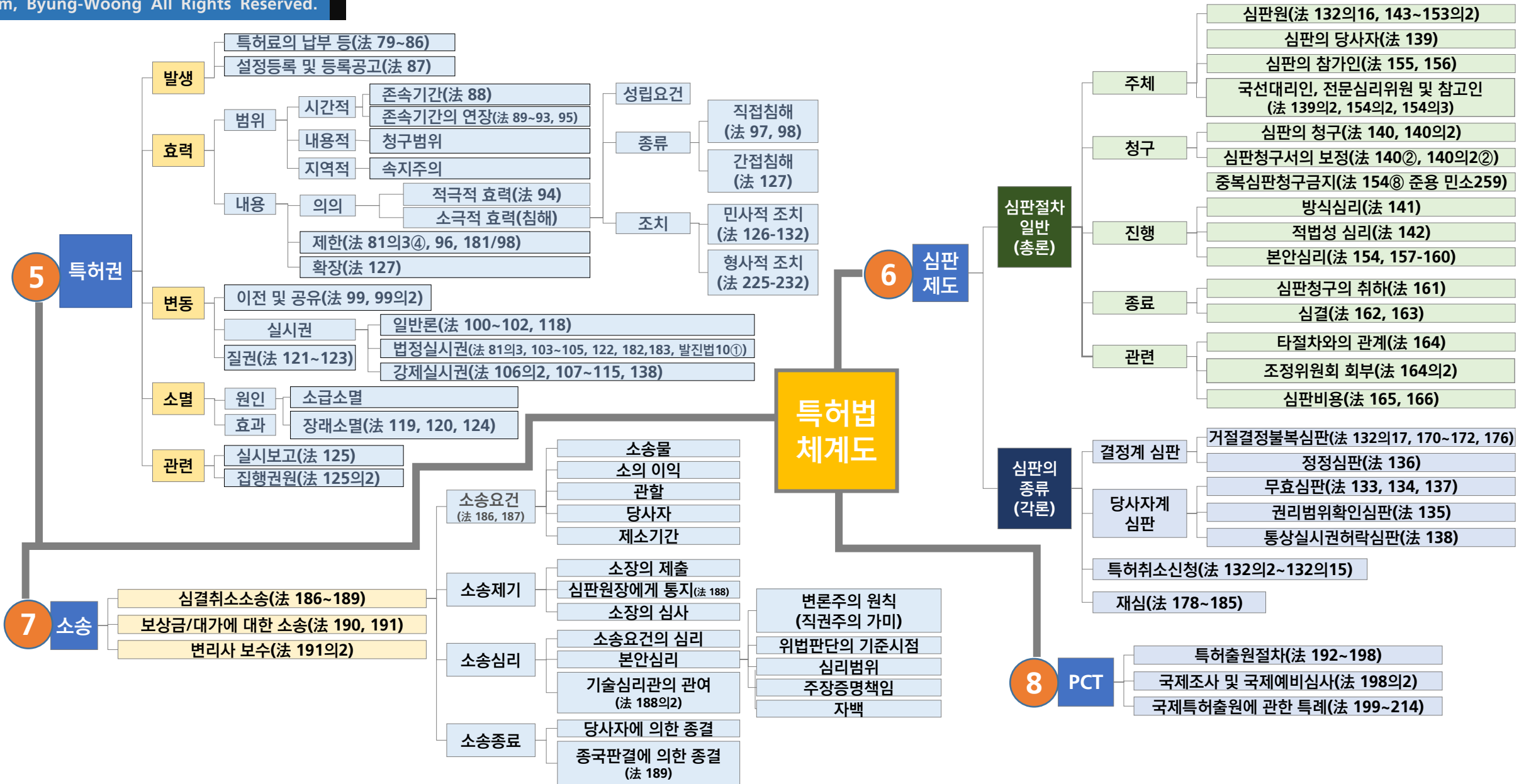
PCT

특허법 강의노트

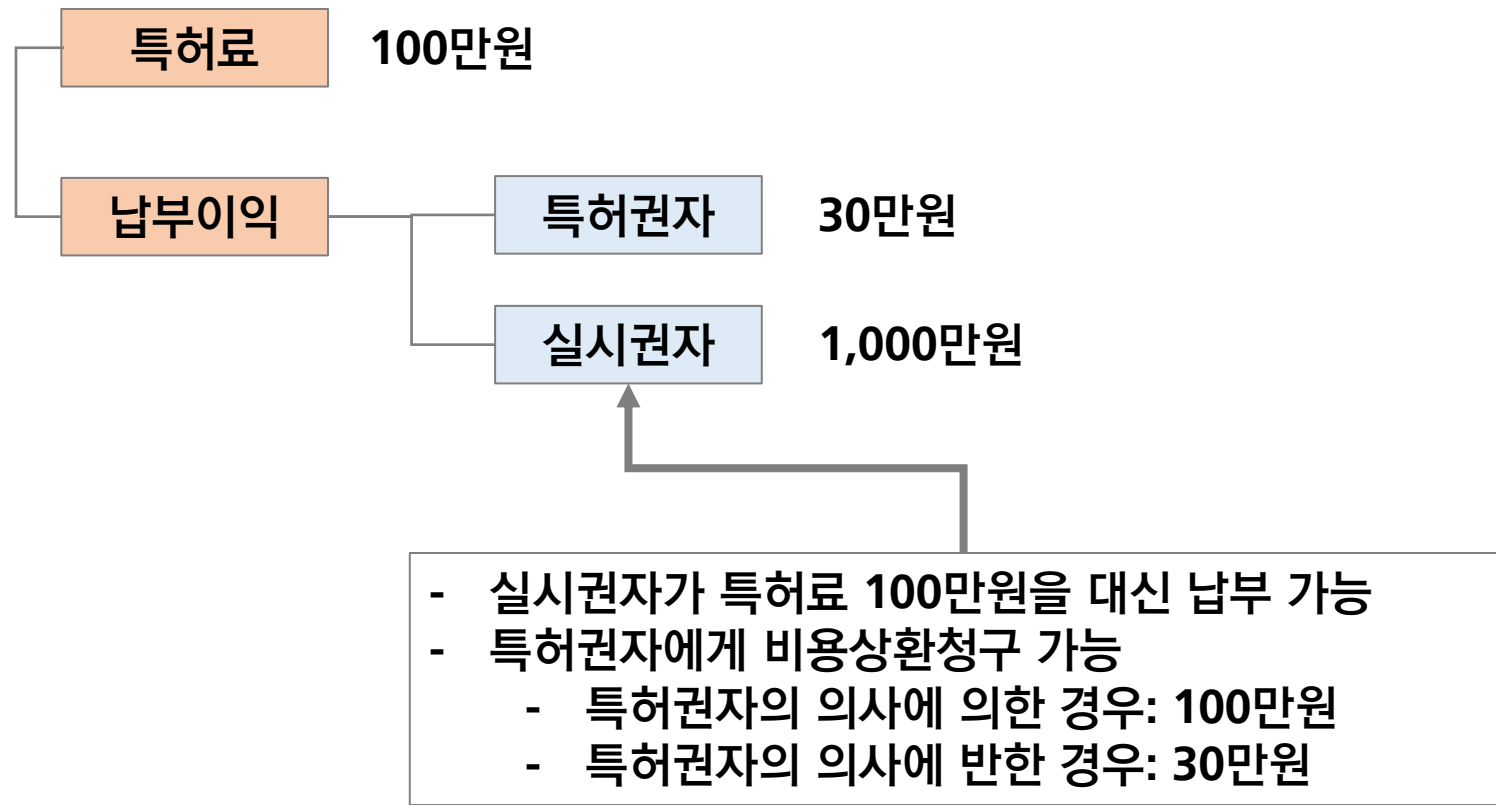
Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

2026

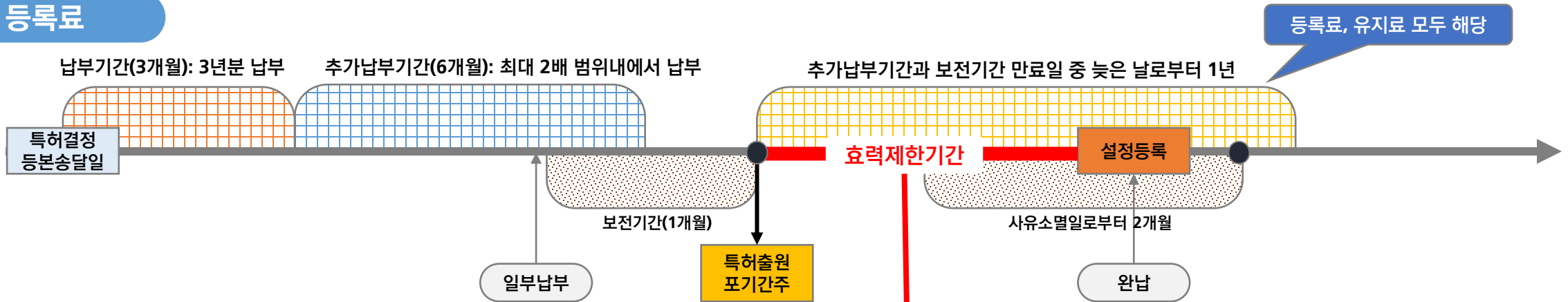




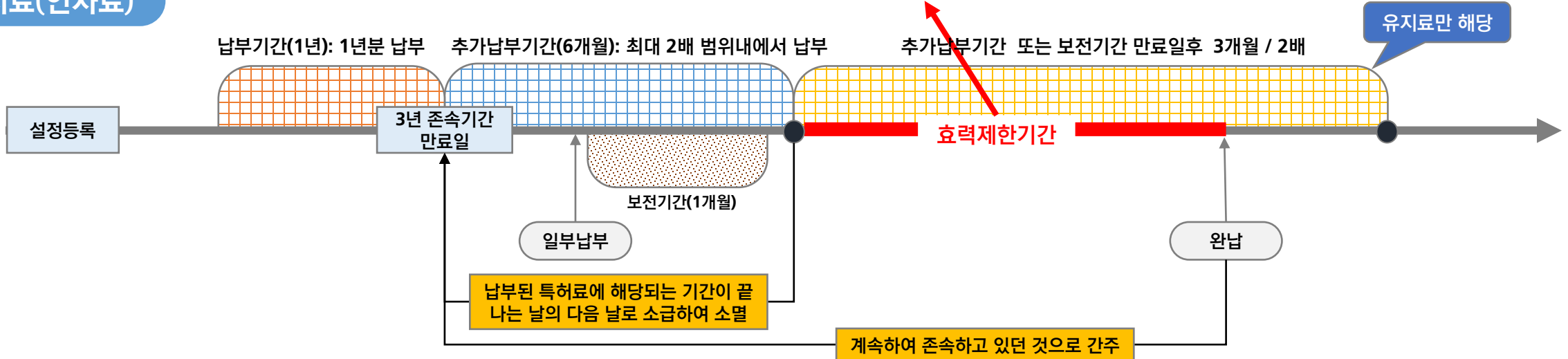
제80조(이해관계인에 의한 특허료의 납부) ① 이해관계인은 특허료를 내야 할 자의 의사와 관계없이 특허료를 낼 수 있다.
 ② 이해관계인은 **제1항에 따라 특허료를 낸 경우에는** 내야 할 자가 현재 이익을 얻는 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다.



등록료



유지료(연차료)



구 분	출원료	심사청구료	등록료	유지료(4-9년)	유지료(9년-)	무효심판	권리범위확인심판청구료	우선심사신청료
100%	- 국가 - 의료급여 수급자* - 국가유공자 등* - 장애인* - 학생(초, 중, 고 / 만 6세 이상 18세 이하 포함)* - 군인*					심사관		첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법에 따른 출원으로서 출원료 등 면제받은 자와 동일
85%	개인(만 19세 이상 29세 이하 또는 만 65세 이상, 발명자와 출원인 일치) **							첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법에 따른 출원으로서 출원료 등 감면 받은 자와 동일
70%	- 개인(발명자와 출원인 일치) * - 중소기업						- 개인(발명자와 출원인 일치) - 중소기업	- 첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법에 따른 출원으로서 출원료 등 감면 받은 자와 동일 - 중소기업이 사업개시일로부터 3년 이내 출원***
50%	- 중소기업이 중소기업이 아닌 자와 계약에 따라 공동연구를 수행하고, 그 연구결과물에 대하여 공동출원 - 공공연구기관 - 전담조직 - 지방자치단체	- 개인 - 중소기업 - 공공연구기관 - 전담조직 - 지방자치단체 - 은행이전****					전담조직	첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법에 따른 출원으로서 출원료 등 감면 받은 자와 동일(단, 지방자치단체는 제외)
30%	중견기업		중견기업					첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법에 따른 출원으로서 출원료 등 감면 받은 자와 동일

* 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따른 출원·심사청구 또는 권리설정등록을 하는 경우에는 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」 별로 각각 연간 10건(무효·반려되거나 1개월 이내에 취하 또는 포기된 것은 제외한다. 이 경우 1출원에 특허심사청구료 또는 실용신안심사청구료를 면제받을 수 있는 청구항은 30개 이하로 하고, 「디자인보호법」 제41조에 따른 복수디자인등록출원은 1출원에 면제받을 수 있는 디자인은 3개 이하로 한다)에 한하여 면제

** 개인이 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따른 출원을 하는 경우에는 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」 별로 각각 연간 20건(무효·반려되거나 1개월 이내에 취하 또는 포기된 것은 제외한다)을 초과하는 경우에는 출원료의 30%

*** 다만, 감면받을 수 있는 특허출원 우선심사신청은 연간 10건(무효·반려되거나 1개월 이내에 취하 또는 포기된 것은 제외한다) 이하

**** 「은행법」 제2조제2호에 따른 은행이 다음의 어느 하나에 해당하는 방식에 따라 개인, 중소기업, 공공연구기관 또는 전담조직의 특허권·실용신안권 또는 디자인권을 2024년 12월 31일까지 이전받는 경우
- 질권의 행사, - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제80조제1항 본문에 따른 투자대상자산의 취득, - 신탁의 설정

***** 직무발명보상우수기업선정 또는 지식재산경영인증 받은 기업은 중소기업 또는 중견기업에 대해서는 2026년 2월 말일까지 4년분부터 6년분까지의 특허료 등을 20% 추가 감면

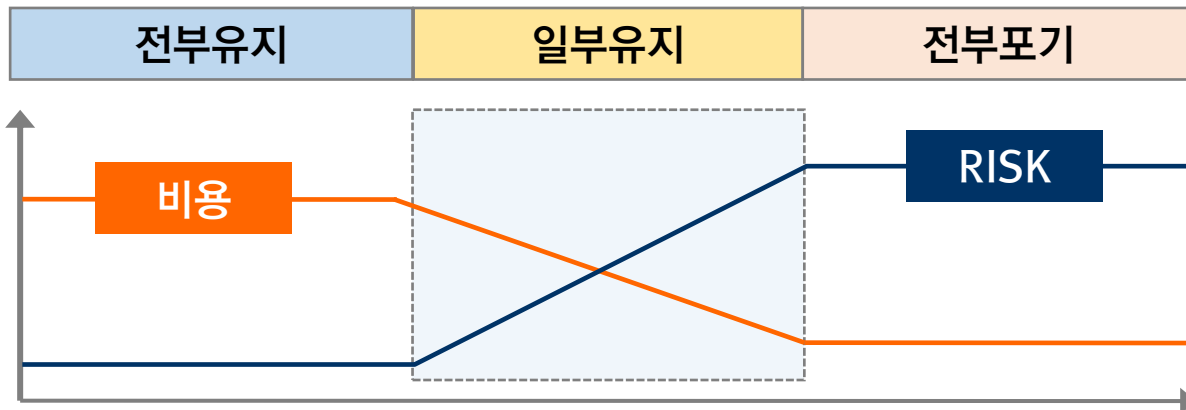
특허료는 청구항별 가산료가 산정되기 때문에 청구항이 많을수록 많은 특허료를 납부해야 한다. 따라서 **청구항별 일부 포기 제도를 활용**하여 점차적으로 특허료를 줄여 나가면서, 특허권을 그 동안 유지존속시키는 전략이 필요하다.

특허료의 체계

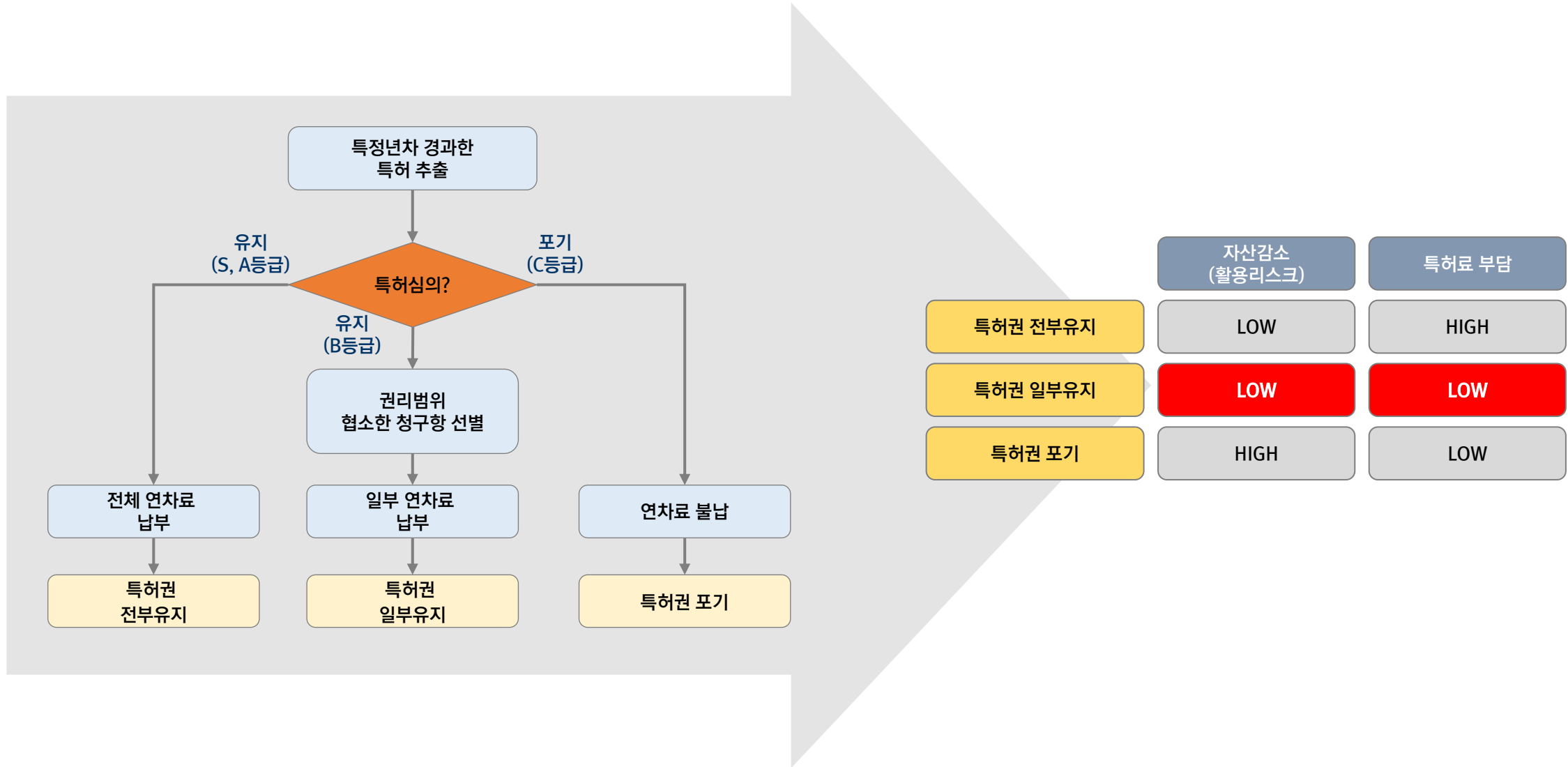
특허료	등록료	연차료			
	1-3년	4-6년	7-9년	10-12년	13-25년
기본료	13,000 원/년	36,000 원/년	90,000 원/년	216,000 원/년	324,000 원/년
가산료 (청구항별)	12,000 원/년	20,000 원/년	34,000 원/년	49,000 원/년	49,000 원/년

- 특허료는 특허에 부과되는 세금으로서 처음 3년분을 일괄납부 후, 4년차 이후에는 1년분 또는 일괄 납부 가능함
- 특허료는 청구항 수에 따라 가산됨(예를 들어, 청구항 15항의 특허료인 경우 설정등록료 39,000+15x36,000=579,000원)
- 특허료는 존속기간이 지날수록 증가함(예를 들어, **7년차의 기본료는 4-6년차 기본료의 250%로 증가함**)
- 한정된 예산 내에서 권리유지비용과 출원 및 등록에 관련된 비용을 적절하게 조절해야 함
- 따라서 일정기간 경과한 경우에는 유지비절감을 위해 등록 포기/유지 여부를 결정할 필요가 있음

일부유지전략



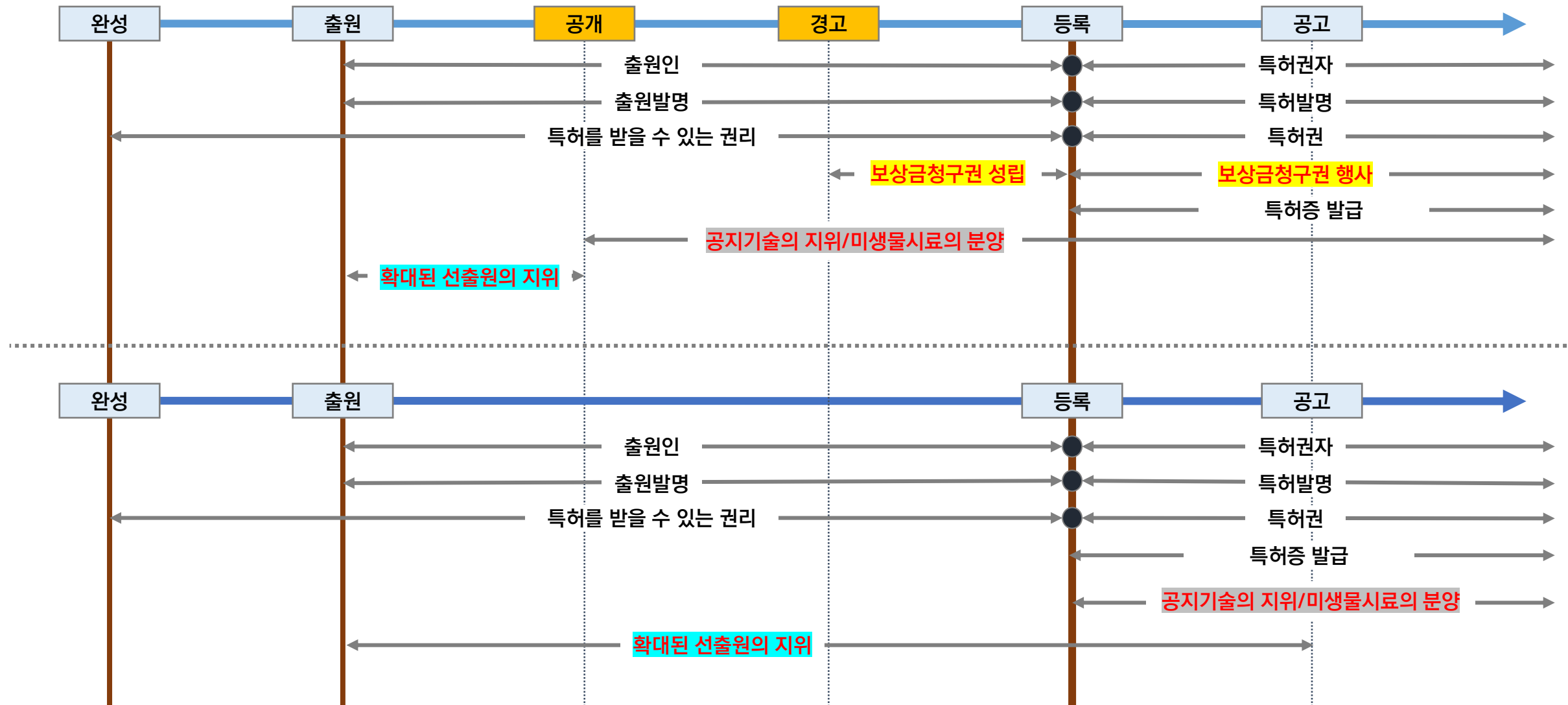
- 시장은 예측 불가능하기 때문에 특허가 포기된 후 특허와 관련된 시장이 형성될 가능성이 항상 존재함
- 그렇다고 하여 특허를 계속 유지하고 있기에는 특허료가 누진세이다 보니 예산적인 측면에서 상당한 부담감이 됨
- 일정기간 경과된 특허에 대하여 일부포기/일부유지를 한다면 특허료를 줄일 수 있고, 특허권도 그 동안 유지시킬 수 있는 장점이 있음



- 제87조(특허권의 설정등록 및 등록공고)** ① 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.
- 제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.
1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한
 2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한
 3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한
- ② 제1항 각 호에 따른 특허권·전용실시권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.
- 제118조(통상실시권의 등록의 효력)** ① 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.
- ② 제81조의3제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.
- ③ 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

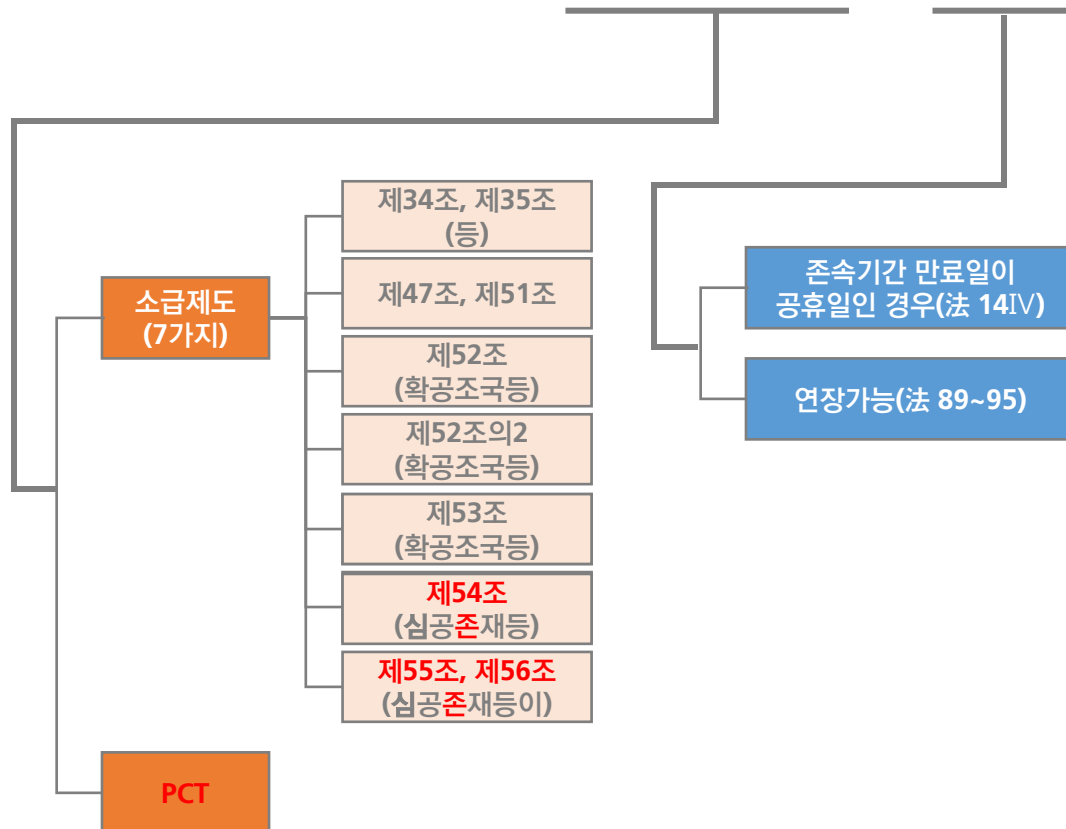
권리		특허권	전용실시권	통상실시권
등록 사항	설정	○ 제87조제1항	○	○ 제118조제1항 (법정실시권 제외)
	이전	○ (상속 그 밖의 일반승계 제외)	○ (상속 그 밖의 일반승계 제외)	○
	변경	○ 제101조제1항 제1호 (∴ 전면적 지배성)	○ 제101조제1항 제2호 (∴ 일면적 지배성)	○ 제118조제3항
	소멸	○ (포기에 한함)	○ (혼동 제외)	○
	처분의 제한	○	○	○
효력		효력발생요건		대항요건

- 장래효: 특허료 불납, 존속기간 만료, **특허권의 포기**, 상속인 부존재
- 소급효: 취소결정확정, 무효심결확정(단, 후발적 사유는 제외)

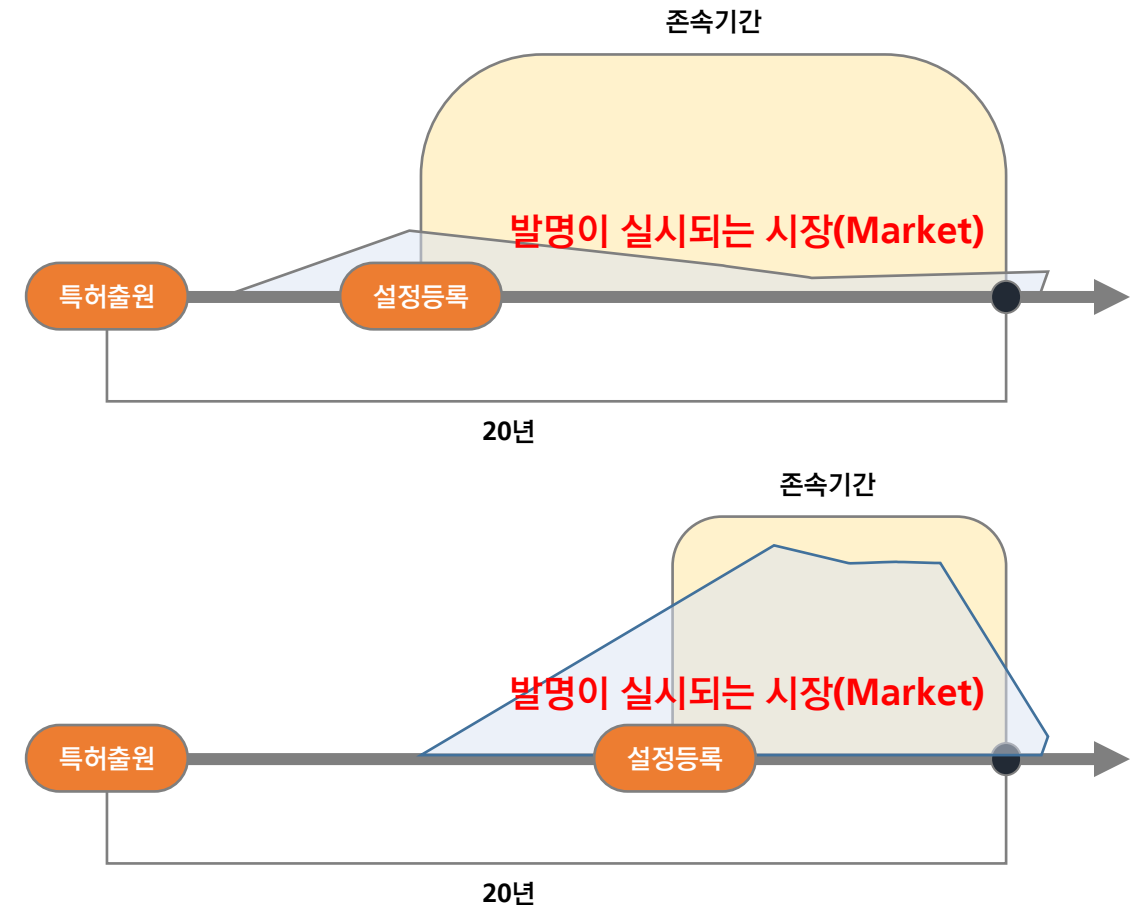


- 제88조(특허권의 존속기간)** ① 특허권의 존속기간은 제87조제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.
 ② 정당한 권리자의 특허출원이 제34조 또는 제35조에 따라 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다.

설정등록한 날로부터 특허출원일후 20년



* Market Maker가 될 수 있는가?



이미 허가(등록)된 의약품(농약)에 의하여 확인된 신물질을 유효성분으로 하여 제조된 의약품(농약)이면서 용도, 제형 등만을 변경한 경우에는 이미 허가(등록)된 의약품(농약)과 동일한 물질로 볼 수 있기 때문에 존속기간 연장 대상이 될 수 없다. 그러나 이미 허가(등록)된 의약품(농약)의 염, 에스테르, 구조 이성질체, 광학이성질체 등이 달라 새로운 신물질을 유효성분으로 한 것이라면 존속기간 연장의 대상이 될 수 있다.

연장가능한 대통령령이 정하는 발명

1. 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질 **약효를 나타내는 유효성분**의 화학구조가 새로운 물질]을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 **최초로 품목허가를 받은 의약품**으로 한정한다)의 발명 또는 「마약류 관리에 관한 법률」 제18조제2항 또는 제21조제2항에 따라 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 마약 또는 향정신성의약품으로서 **최초로 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품**으로 한정한다)의 발명,
2. 특허발명을 실시하기 위하여 「농약관리법」 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로 한정한다)의 발명

대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결 【거절결정(특)】

당해 법령 자체에 그 법령에서 사용하는 용어의 정의나 포섭의 구체적인 범위가 명확히 규정되어 있지 아니한 경우 법령상 용어의 해석은 가능한 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 그 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 당해 조항의 규정형식과 내용 및 관련 법령을 종합적으로 고려하여 해석하여야 한다(대법원 2010. 6. 24. 선고 2010두3978 판결, 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결, 대법원 2018. 6. 21. 선고 2011다112391 전원합의체 판결 참조). 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도를 규정한 특허법 제89조 제1항과 이 사건 시행령 조항의 전반적인 체계와 취지·목적, 이 사건 시행령 조항의 규정형식과 내용, 관련 약사법령 등을 종합하면, 이 사건 시행령 조항에서 **‘약효를 나타내는 활성(유효성) 부분’**은 **‘의약품의 유효성분 중 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 나타내는 부분’**을 의미한다. 한편 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 기존에 품목허가된 의약품의 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도 이는 의약품의 효능·효과로서의 ‘약효’를 나타내는 부분이 아니므로, 이러한 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 있다는 사정만으로 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

기허가된 의약품: 인터페론베타-1a를 유효성분으로 하는 의약품

약리기전: 인터페론베타-1a이 체내 유효성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 나타냄

이 사건 의약품: 페그인터페론베타-1a(인터페론베타-1a + 폴리에틸렌글리콜)를 유효성분으로 하는 의약품

약리기전:

- 인터페론베타-1a 부분이 체내 유효성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 나타냄
- 폴리에틸렌글리콜 부분은 체내 유효성이나 위와 같은 치료효과를 가지지 않으면서 인터페론베타-1a 부분이 혈액 중에 오래 체류하도록 하거나 인터페론베타-1a의 단백질 수용체에 대한 결합력을 낮추는 등으로 인터페론베타-1a의 유효성 정도에 영향을 미치는 부분에 불과

**약효를 나타내는 유효성 부분인
인터페론베타-1a가 동일**

객체: 연장기간(제89조, 제91조제3호)

연장기간: 특허발명을 실시할 수 없었던 기간 (최대 5년) / 단, 허가 등을 받은 날로부터 14년 초과 연장 불가

설정등록일 이후의 기간 중

시험기간



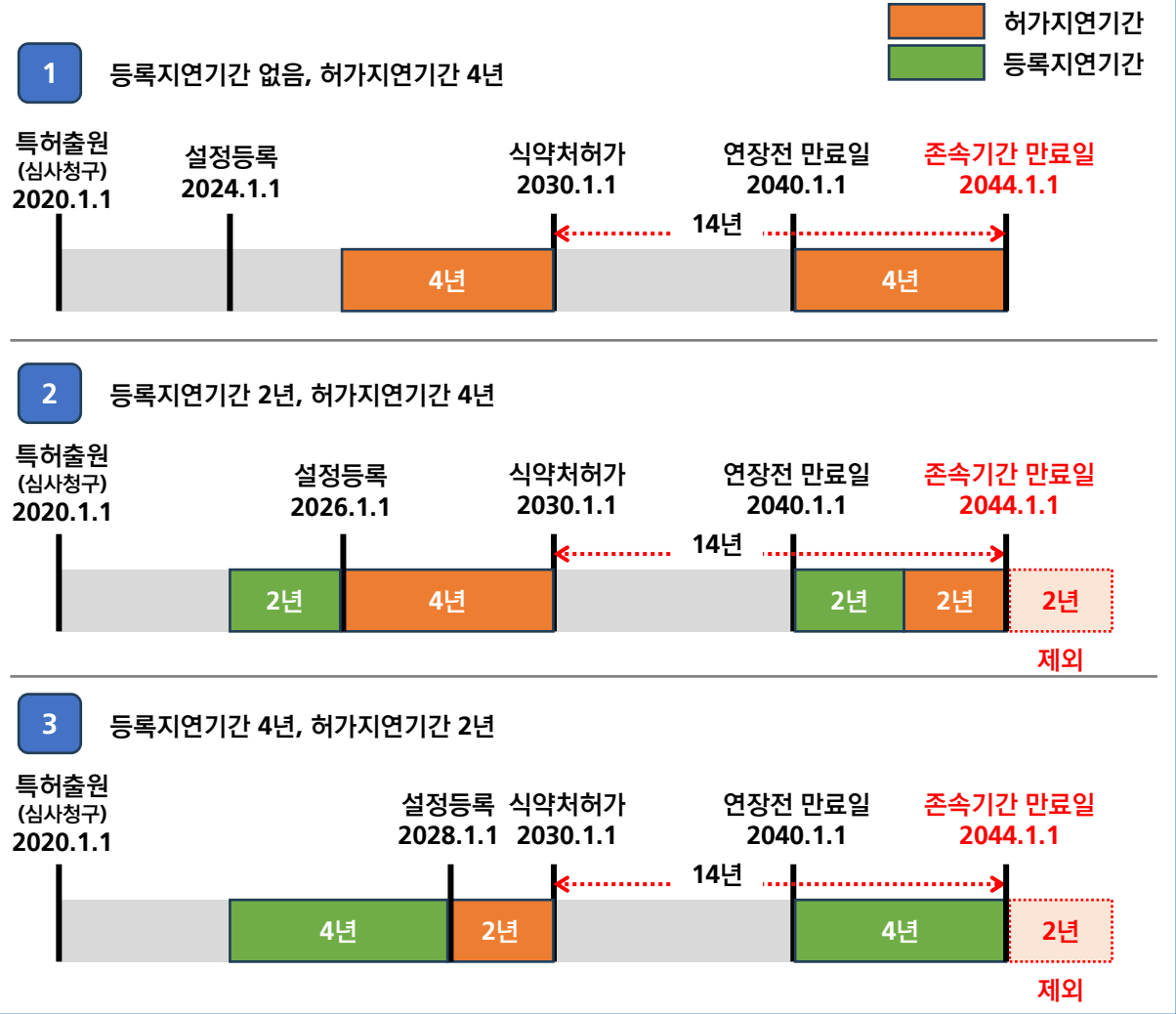
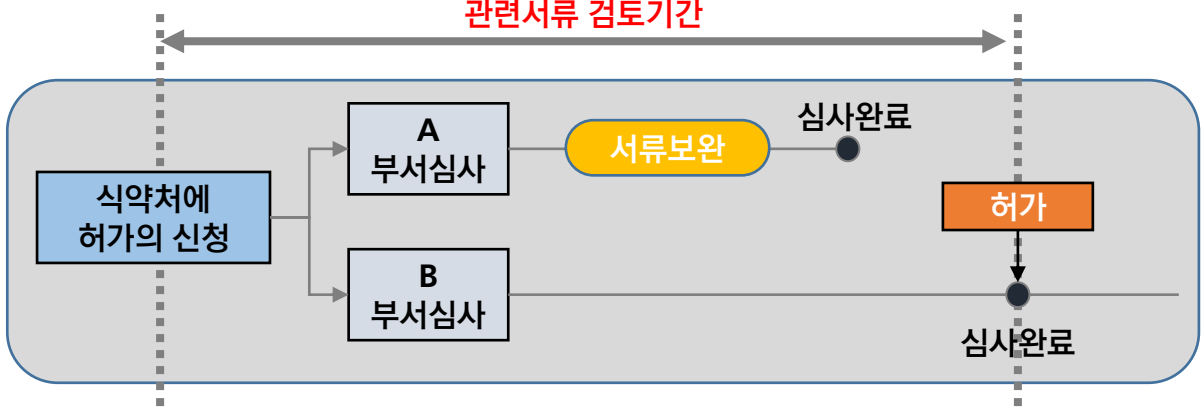
관련서류 검토기간



책임있는 사유로 소요기간

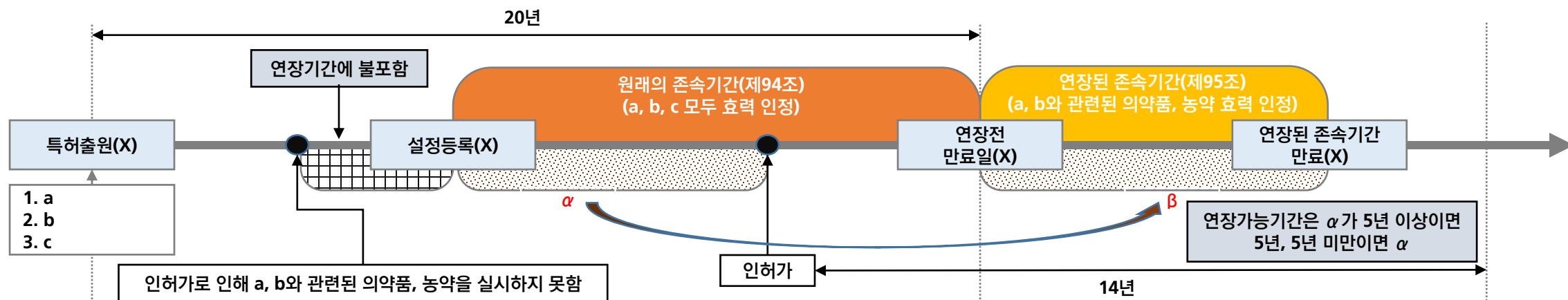
원고들이 피고를 상대로 피고의 특허발명에 대하여 이루어진 존속기간 연장등록은 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 무효로 되어야 한다고 주장한 사건에서, **식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다 하더라도, 그 동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없으므로, 이 사건 특허발명을 실시할 수 없었던 기간 중에서 식품의약품안전처의 심사가 전혀 진행되지 아니한 기간은 없고 달리 ‘허가 등을 받은 자의 책임 있는 사유’로 제외되어야 할 기간을 인정할 자료가 없으므로, 이 사건 연장등록에 구 특허법 제134조 제1항 제3호의 무효사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844, 851, 868, 875).**

관련서류 검토기간



* 이정석(법무법인 율우), “의약품 특허권 존속기간 연장등록제도 관련 특허법 개정안 연구”, 지식재산처(2023), 34면 참조

1. 존속기간을 연장등록할 수 있는 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간으로서 최대 5년 내이다. 「특허발명」은 특허를 받은 발명을 의미하기 때문에 등록 전부터 a, b에 대하여 인허가를 받지 못해서 실시하지 못했다고 하더라도 연장가능기간은 등록 후 인허가를 받은 날까지이다. 다만, 허가 등을 받은 날로부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다.
2. 허가 등에 따른 특허권의 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시 행위에만 미치게 된다. 따라서 a, b, c 발명 중 인허가를 받지 못해서 실시하지 못했던 a, b와 관련된 대상물건에 대해서만 연장된 특허권의 효력이 미치게 된다.



특허법은 이와 같이 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 **‘품목(하급심 판결)’**의 실시로 제한하지는 않았다. 이러한 법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 **약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다.** 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품(이하 ‘침해제품’이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 i) 통상의 기술자라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, ii) 인체에 흡수되는 유효성분(**솔리페나신**)의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다(대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245789).

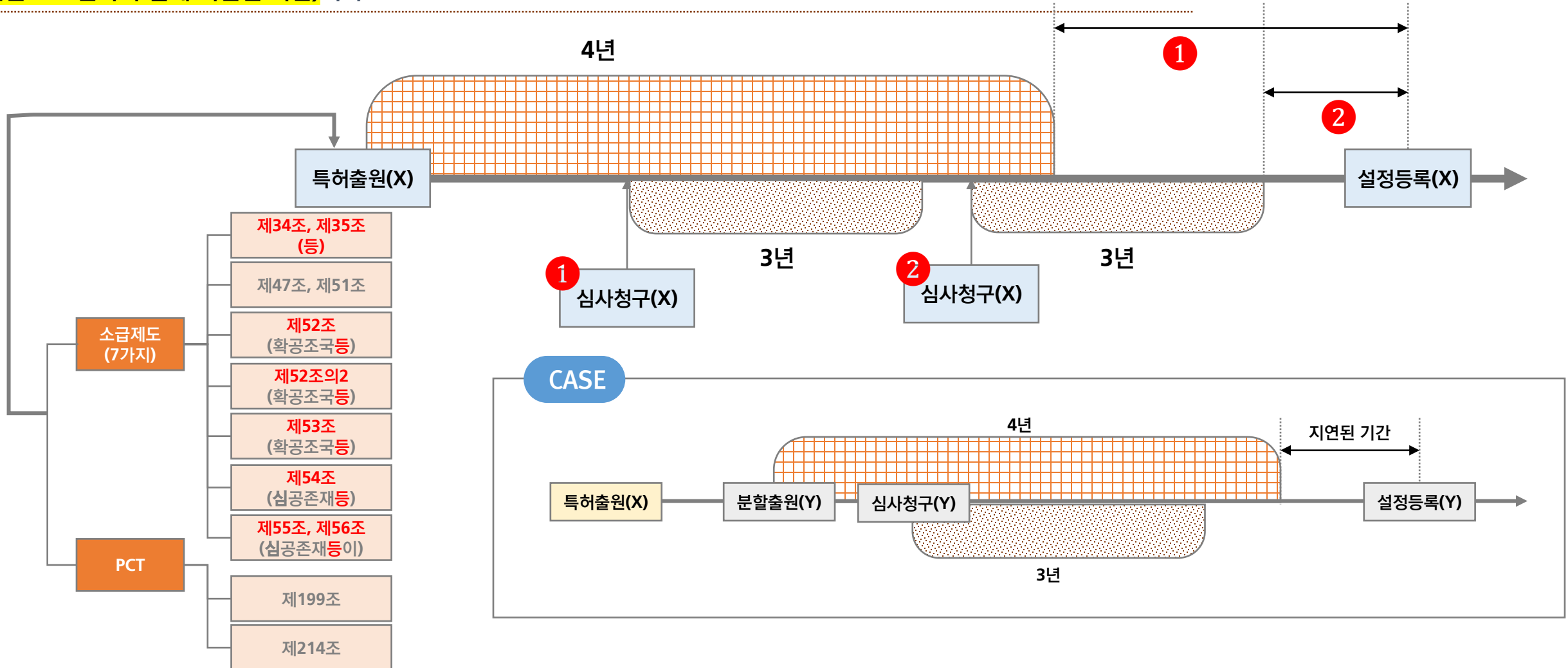
특허발명: 과민성 방광증상 등에 치료효과를 가지는 특정 기본골격을 갖는 화합물’을 특징으로 하는 물질특허인데, 그 유리염기 형태의 특정 화합물은 숙신산이나 푸마르산을 비롯한 다양한 산과 염 화합물을 형성

연장등록출원서 기재(허가 등의 내용): 일반명(품목명) **숙신산** 솔리페나신, 제품명(상표명) 베시케어정, 효능 및 효과(용도) 과민성 방광 증상의 치료

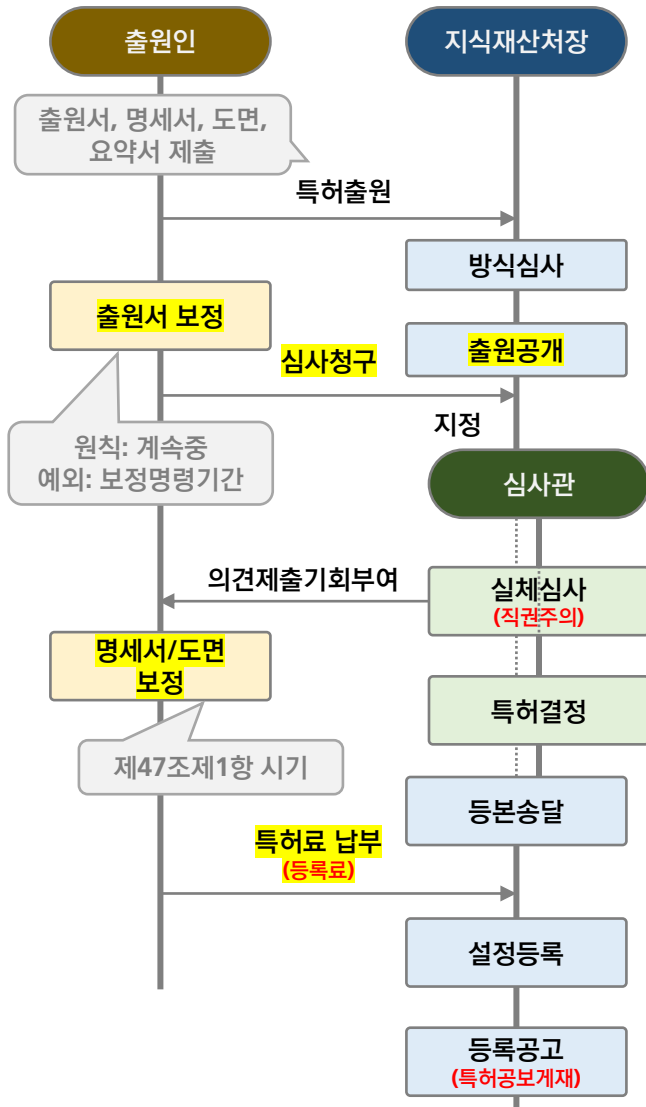
피고제품: ‘**푸마르산** 솔리페나신’ 외 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제, 코팅제 등으로 이루어지고, 신경성 빈뇨, 불안정 방광, 만성 방광염에서의 요실금과 빈뇨의 비뇨기 질환의 예방 또는 치료를 의약품으로 하는 약제학적 조성물

약리기전: 품목허가를 받은 솔리페나신 숙신산염은 솔리페나신과 숙신산이 이온결합에 의해 약하게 결합된 상태의 화합물이고, 체내에 경구투여되어 위장에 들어가면 강산이 위액에 의해 이온결합이 끊어져 솔리페나신과 숙신산으로 분리되게 된다. 이렇게 분리된 숙신산은 체내 대사를 거쳐 체외로 배출되고 솔리페나신만 소장의 상피세포에서 흡수된 후 혈액을 통하여 방광에 도달하여 사람의 M 무스카린 수용체와 반응하여 약리효과를 발휘하게 된다.

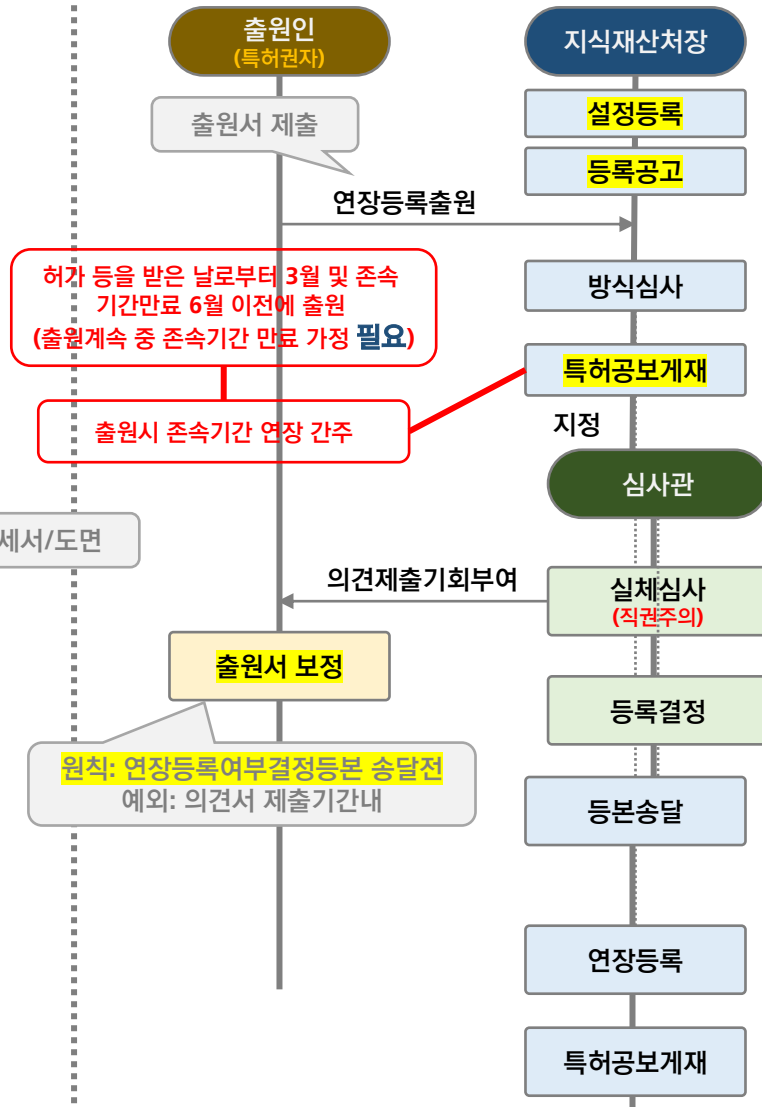
존속기간을 연장등록할 수 있는 기간은 지연된 기간(연장기준일로부터 설정등록일까지의 기간) 이내이어야 한다(法 92의2①, 92의4 I). 다만, 대통령령으로 정하는 출원인으로 인하여 지연된 기간은 특허권의 존속기간의 연장에서 제외된다. 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니 된다(法 92의2②③). 결국 **연장가능한 기간은 (연장기준일로부터 설정등록일까지의 기간 - 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간)이다.**



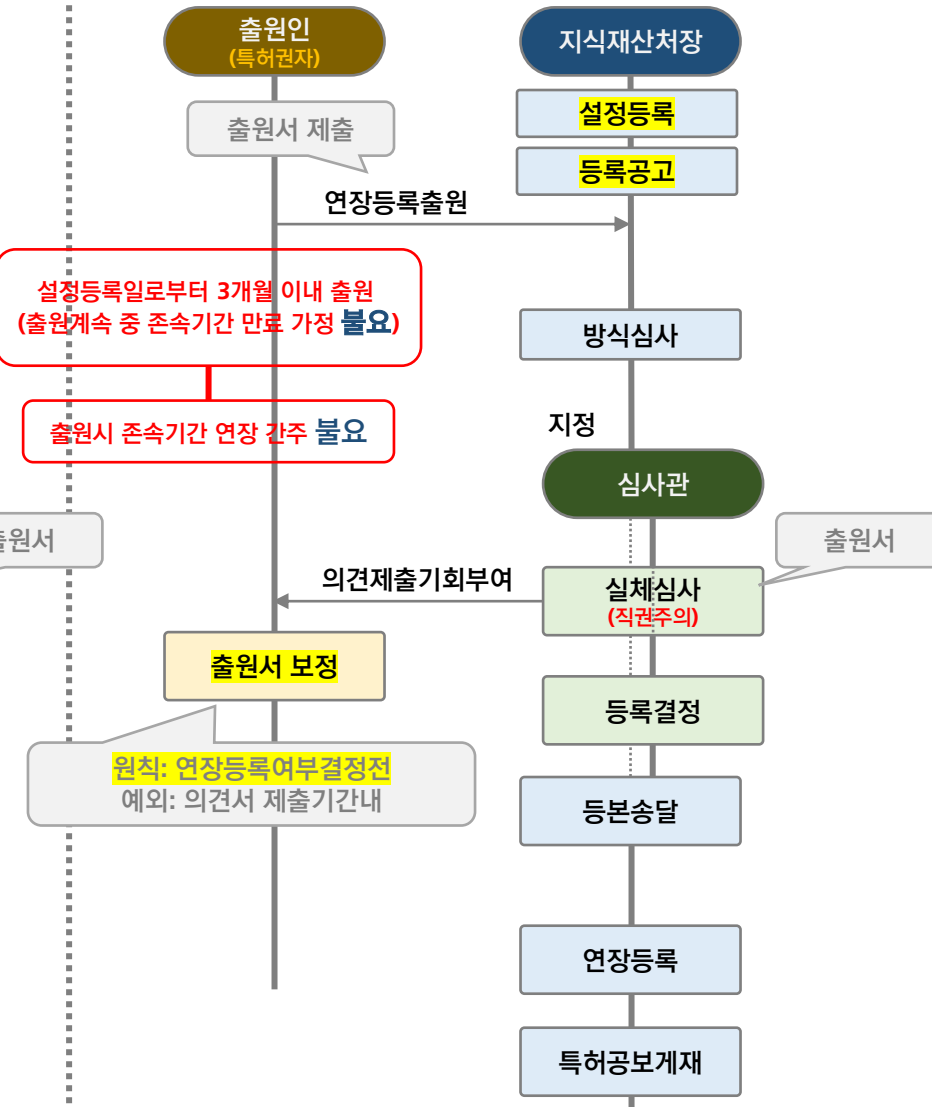
특허출원



허가 등에 따른 연장등록출원



등록지연에 따른 연장등록출원



구 분	허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장	등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장
의 의	제89조	제92조의2
연장등록 출원	제90조	제92조의3
거절결정	제91조	제92조의4
등록결정등	제92조	제92조의5
준용규정	제93조	
특허권의 효력	제95조	제94조

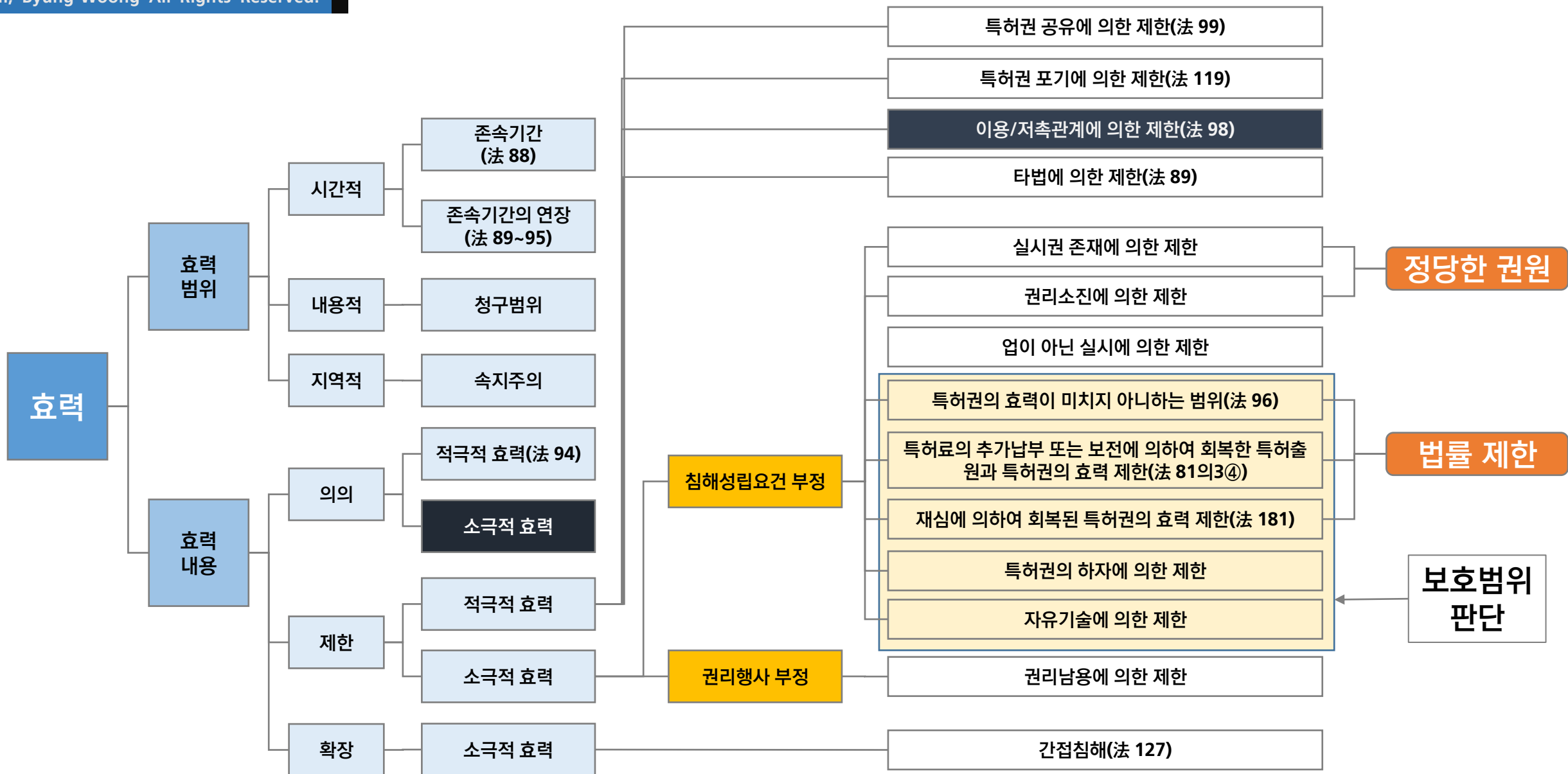
구분	허가 등에 따른 존속기간 연장	등록지연에 따른 존속기간 연장
의의	제89조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장】 ① (의의) 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가 등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다. ② (연장기간) 제1항을 적용할 때 허가 등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 "실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.	제92조의2 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장】 ① (의의) 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다. ② (연장기간: 일반) 제1항의 규정을 적용할 때 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장에서 제외된다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다. ③ (연장기간: 지연기간) 제2항에서 "출원인으로 인하여 지연된 기간"에 관한 사항은 대통령령으로 정한다. ④ (연장기간: 출원일 기산) 제1항에 따라 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 날을 특허출원일로 본다. 1. 제34조 또는 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원의 경우에는 정당한 권리자가 출원을 한 날 2. 제52조에 따른 분할출원의 경우에는 분할출원을 한 날 2의2. 제52조의2에 따른 분리출원의 경우에는 분리출원을 한 날 3. 제53조에 따른 변경출원의 경우에는 변경출원을 한 날 4. 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 제203조제1항 각 호의 사항을 기재한 서면을 제출한 날 5. 제214조에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날 6. 제1호부터 제5호까지의 규정 중 어느 하나에 해당되지 아니하는 특허출원에 대하여는 그 특허출원일

구분	허가 등에 따른 존속기간 연장	등록지연에 따른 존속기간 연장
출원	제90조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원】 ① (출원서 제출) 제89조제1항에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제91조에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명] 3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상청구범위의 표시 4. 연장신청의 기간 5. 제89조제1항에 따른 허가 등의 내용 6. 총리령으로 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다) ② (시기적 요건) 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조제1항에 따른 허가 등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에 따른 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 없다. ③ (주체적 요건) 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다. ④ (출원의 효과) 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. ⑤ (특허공보 게재) 지식재산처장은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 제1항 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.	제92조의3 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원】 ① (출원서 제출) 제92조의2에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제92조의4에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) 3. 연장 대상 특허권의 특허번호 4. 연장신청의 기간 5. 총리령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다) ② (시기적 요건) 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. ③ (주체적 요건) 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.
	⑥ (출원서의 보정) 연장등록출원인은 지식재산처장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 제1항제3호부터 제6호까지의 사항(제3호 중 연장대상특허권의 특허번호는 제외한다)에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다. ⑦ (객체적 요건) 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 하고, 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우에는 어느 특허권의 존속기간도 연장할 수 없다. ⑧ (객체적 요건) 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 출원은 제7항을 적용할 때는 처음부터 없었던 것으로 본다. 1. 포기, 무효 또는 취하된 경우 2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우	④ (출원서의 보정) 연장등록출원인은 심사관이 특허권의 존속기간의 연장등록 여부결정 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항 중 제1항제4호 및 제5호의 사항에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.

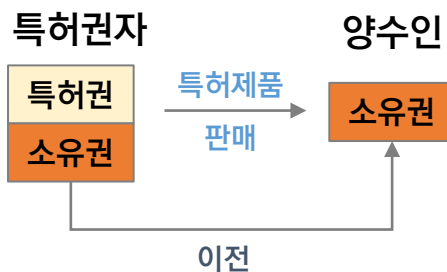


등록일로부터 3개월 이내 출원하므로, 출원계속 중 존속기간이 만료되는 경우를 가정하지 않아도 됨

구분	허가 등에 따른 존속기간 연장	등록지연에 따른 존속기간 연장
거절 결정	제91조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정】 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다. 1. (객체: 허가 등의 필요성) 그 특허발명의 실시가 제89조제1항에 따른 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우 2. (객체: 허가 등의 취득) 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조제1항에 따른 허가 등을 받지 아니한 경우 3. (객체: 연장기간) 연장신청의 기간이 제90조에 따라 인정되는 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우 4. (주체) 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우 5. (주체) 제90조제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우 6. (객체: 연장횟수) 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우	제92조의4 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정】 심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다. 1. (객체: 연장기간) 연장신청의 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우 2. (주체) 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우 3. (주체) 제92조의3제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우
등록 결정	제92조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등】 ① (등록결정) 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 한다. ② (특허원부 등록) 지식재산처장은 제1항에 따른 연장등록결정을 한 경우에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다. ③ (특허공보 게재) 지식재산처장은 제2항에 따른 등록을 한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다. 1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2. 특허번호 3. 연장등록의 연월일 4. 연장기간 5. 제89조제1항에 따른 허가 등의 내용	제92조의5 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등】 ① (등록결정) 심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제92조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없는 경우에는 연장등록결정을 하여야 한다. ② (특허원부 등록) 지식재산처장은 제1항의 연장등록결정이 있으면 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다. ③ (특허공보 게재) 제2항에 따른 등록이 있으면 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다. 1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2. 특허번호 3. 연장등록 연월일 4. 연장 기간
준용 규정	제93조 【준용규정】 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여는 제57조제1항, 제63조, 제67조, 제78조제1항·제3항, 제148조제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호를 준용한다. 이 경우 제78조제1항 중 “특허취소신청에 대한 결정”은 “제92조의4 및 제92조의5에 따른 연장등록거절결정 또는 연장등록결정”으로, “그 심사절차”는 “허가등에 따른 연장등록출원 심사 절차”로 본다.	
효력	제95조 【허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력】 제90조제4항에 따라 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.	제94조 【특허권의 효력】 ① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항[전용실시권의 효력]에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.







- 권리자 이중이득 불필요
- 유통과정 보호
- 양수인 또는 전득자 보호

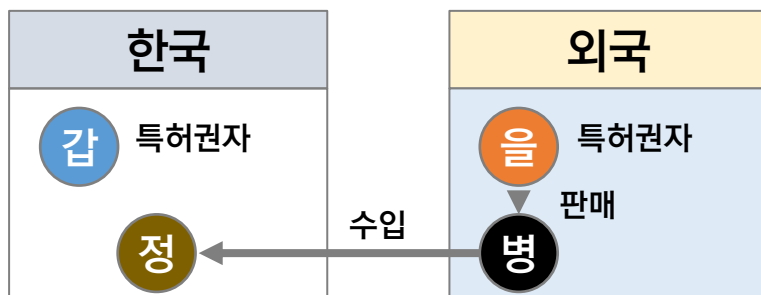
권리소진

1) 특허권자 또는 제조·판매권을 갖는 실시권자(이하 “특허권자 등”이라 함)가 2) 특허발명을 실질적으로 구현한 제품(이하 “특허제품”이라 함)을 3) 적법하게 판매한 경우, 4) 판매할 때 권리가 소진되어 동일물에 대해서는 특허권의 침해를 주장할 수 없게 되는 것을 말한다.

1	실시권자의 계약조건 위반	실시권자가 실시권의 제한조건을 벗어나서 판매한 경우에는 실시권의 제한조건이 위법하다거나 무효인 경우를 제외하고는, 권리소진의 효과가 발생하지 않아서 특허권의 침해가 된다. 다만, 계약상 부수적인 제한조건을 위반하여 판매한 경우에는 일률적으로 특허권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, i) 계약의 구체적인 내용, ii) 특허권자가 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 iii) 특허제품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 권리소진 여부를 판단하여야 한다.
2	방법발명 특허	방법발명에 대한 특허권자로부터 방법의 실시에만 사용되는 물건을 양도받은 제3자가 해당 물건을 양도, 대여, 수출, 수입 또는 대여의 청약뿐만 아니라 사용하는 행위를 하더라도 특허권이 소진된다(대가 확보 기회 부여, 제품판매시 소진 회피 악용 방지). 다만, 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서는, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되지 아니한다(제99조제4항의 무력화 방지)
3	조건부 판매	권리소진은 특허권자가 특허제품의 판매를 적법하게 한 경우에 적용되기 때문에 특허제품을 판매할 때 조건을 부과하여 권리소진을 배제할 수 있는지 문제이다. 특허권자가 특허제품을 판매할 때 특허권자의 권한 양도를 추정하는 것이 아니라 특허권자의 권리범위를 제한하기 때문에 배제불가라는 것이 일반적이다. 우리나라는 이에 관한 사례가 아직 존재하지 않으나, 만약 조건부 판매에 의하여 권리소진을 제한할 수 있다면 i) 조건부 판매가 계약법적으로 유효한지 여부, ii) 계약법적으로 유효하더라도 특허권의 남용이나 독점금지법 등의 법률에 위반되는지 여부와 함께 검토되어야 할 것이다.
3	외국에서 판매	1. 국내와 외국 특허권의 특허권자가 각기 다른 경우 외국 특허권자가 판매한 특허제품(진정상품)을 제3자가 구매하여 국내에 병행수입하는 경우: 외국에서 특허권의 경우 권리소진이 발생하지만, 국내에서 특허권의 경우 특허권자가 달라 국내의 특허권자가 특허제품의 판매를 통해 이득을 취한 것도 아니고 특허독립의 원칙 및 속지주의에 의하여 국내에서 권리소진이 발생하지 않아서, 국내 특허권의 침해라고 볼 것이다. 2. 국내와 외국 특허권의 특허권자가 동일한 경우 특허권자가 외국에서 판매한 특허제품을 제3자가 구매한 후 국내에 병행수입하는 경우: 외국에서 특허제품의 판매를 통해 외국과 국내에서 특허권의 권리소진이 발생하였고, 특허권자가 이득을 취하였기 때문에 국내 특허권의 침해가 아니라고 볼 것이다. 3. 국내 특허권자가 특허권이 없는 외국에서 특허제품을 판매하거나 국내에서 판매하여 외국에 수출하였는데, 제3자가 이를 그대로 또는 가공하여 국내에 수입할 경우: 국내외 특허제품의 판매를 통해 국내 특허권의 권리소진이 발생하였고, 특허권자가 이득을 취하였기 때문에 국내 특허권의 침해가 아니라고 볼 것이다.
4	부품교환	1. 부품이 비소모품인 경우에는 발명의 기술적 사상과 관련된 본질적인 구성요소라면 부품의 교체가 생산에 해당한다(서울중앙지방법원 2006. 8. 23. 선고 2005가합48548). 2. 부품이 소모품인 경우에는 i) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 ii) 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 iii) 해당 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, iv) 특허권자 측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면 생산에 해당한다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580). 3. 다만, 특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001 판결에서는 부품을 교체하는 것이 원래 특허제품과의 동일성을 해할 정도에 이르게 된 경우에는 재생산으로 특허권을 침해하는 것으로, 동일성을 유지되는 경우에는 수리로서 특허권을 침해하지 않은 것으로 판단하고 있다. 이는 본질적 부분의 교체라면 생산이 된다는 기존의 판례보다 수리의 범위를 조금 더 넓게 인정해 주려는 경향으로 파악된다.

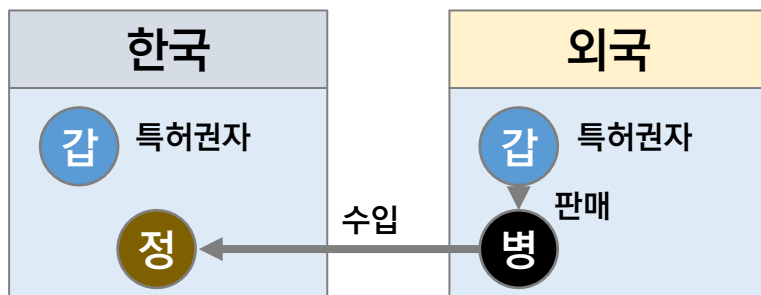
권리소진의 요건으로서 판매는 국내외를 불문하고, 권리소진이 적용되는 범위는 특허독립의 원칙 및 속지주의 원칙에 따라 국내로 한정되는 것으로 이해

1



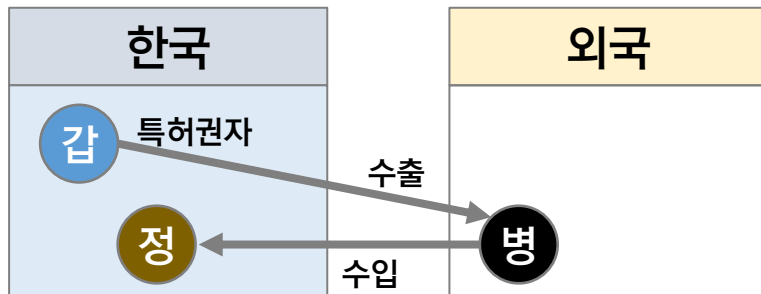
외국에서 특허권의 경우 권리소진이 발생하지만, 국내에서 특허권의 경우 특허권자가 달라 국내의 특허권자가 특허제품의 판매를 통해 이득을 취한 것도 아니고 특허독립의 원칙 및 속지주의에 의하여 국내에서 권리소진이 발생하지 않아서, 정의 수입은 **국내 갑의 특허권의 침해라고 볼 것이다.**

2

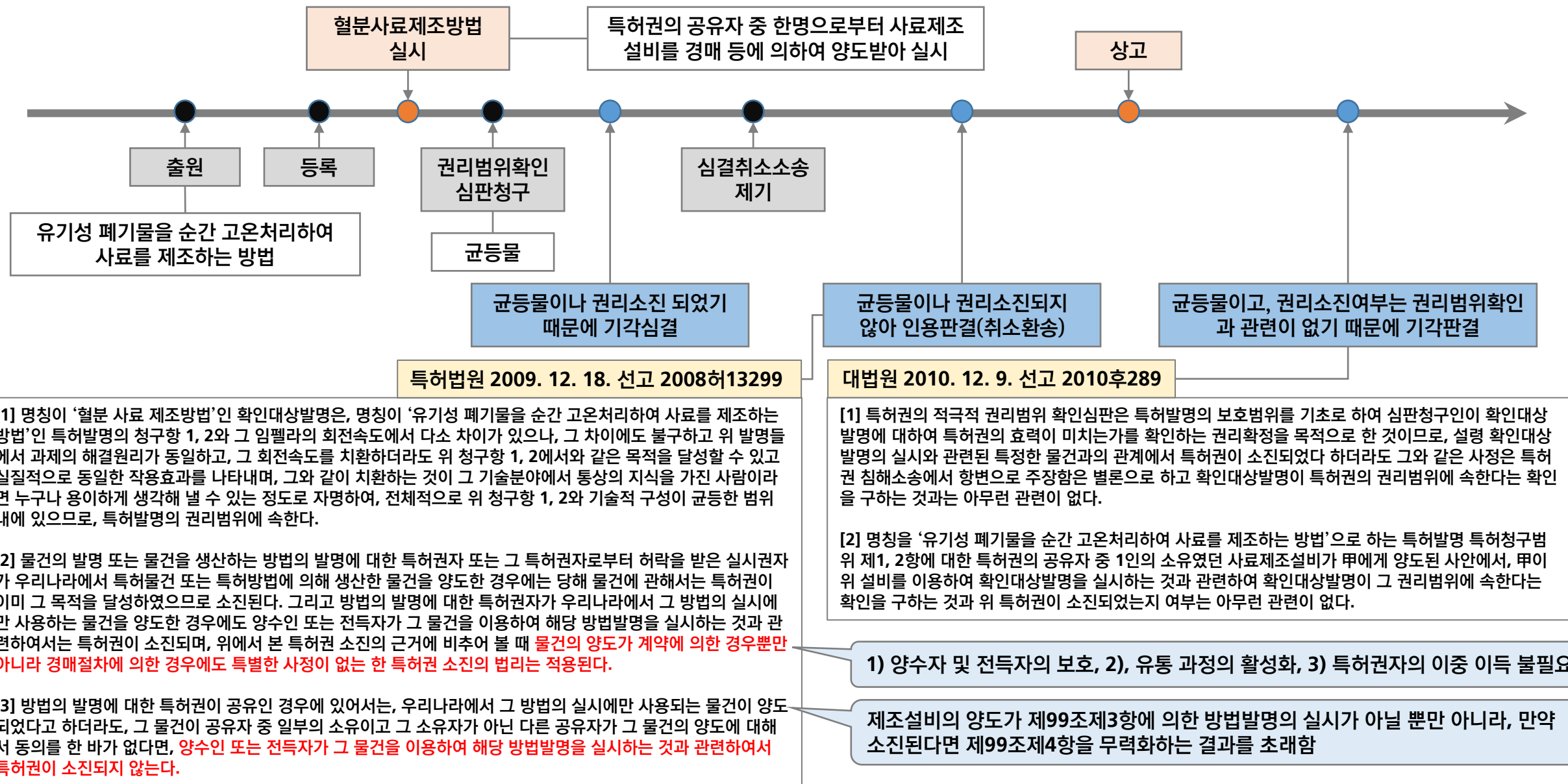


외국에서 특허제품의 판매를 통해 외국과 국내에서 특허권의 권리소진이 발생하였고, 특허권자가 이득을 취하였기 때문에 정의 수입은 국내 갑의 **특허권의 침해가 아니라고 볼 것이다.**

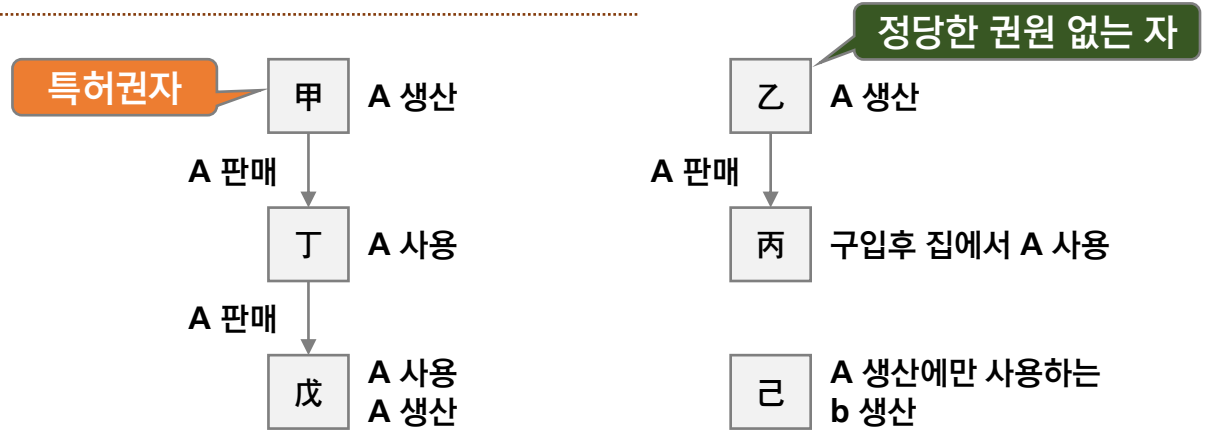
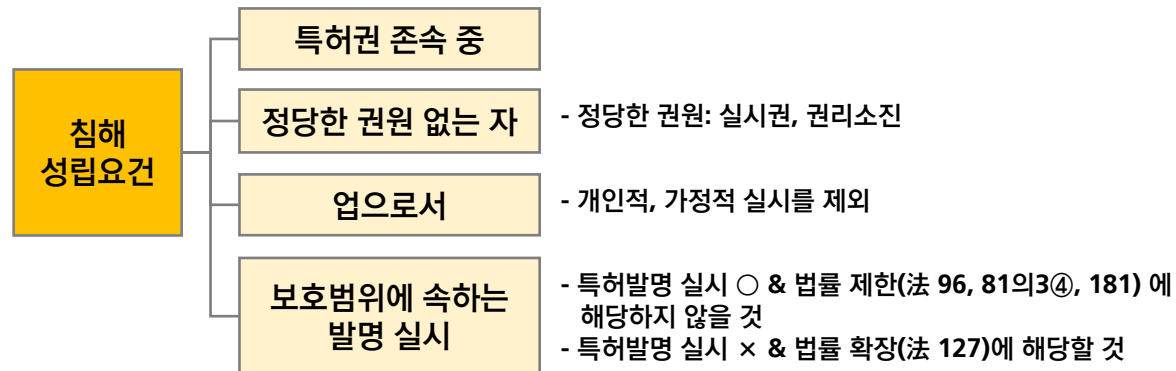
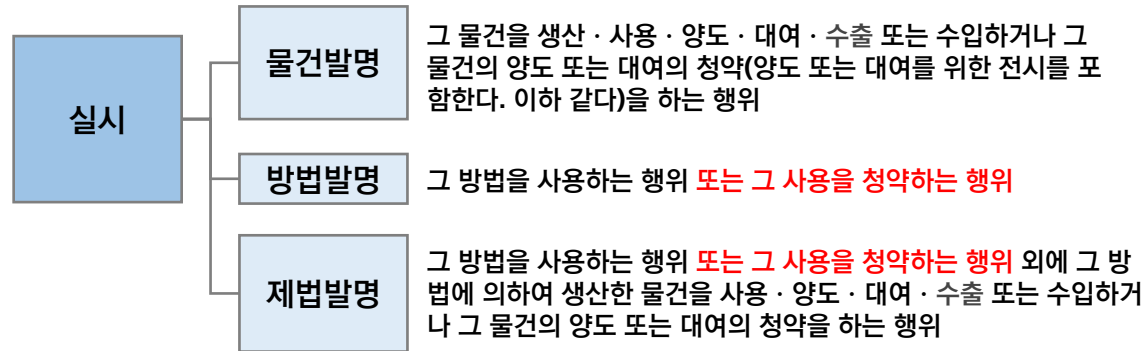
3



국내외 특허제품의 판매를 통해 국내 특허권의 권리소진이 발생하였고, 특허권자가 이득을 취하였기 때문에 정의 수입은 **국내 갑의 특허권의 침해가 아니라고 볼 것이다.**



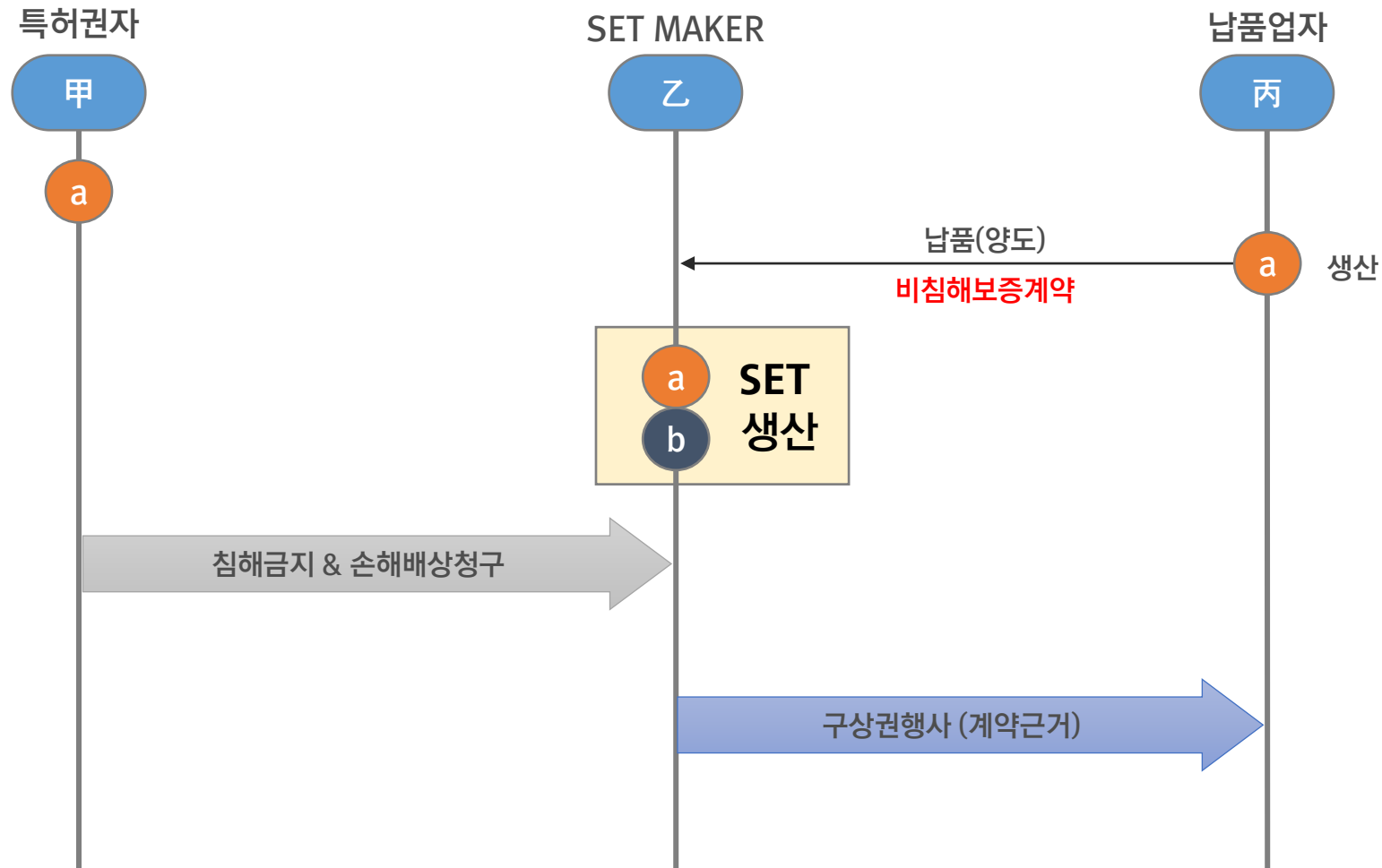
「실시행위의 독립성」이란 각각의 실시행위는 서로 독립적이므로 침해 여부 역시 각각 독립적으로 판단하여야 한다는 것을 말한다. 즉, 제2조제3호에서 규정한 각각의 실시행위는 특허권의 효력상 독립적이며 어느 하나의 실시행위는 다른 실시행위에 영향을 미치지 아니하기 때문에 한 단계의 실시행위가 적법하다고 하여 다른 단계의 행위까지도 적법하게 되는 것은 아니다. 예컨대, 甲이 위법하게 특허발명을 생산한 경우에는 그것을 판매하지 않더라도 특허권의 침해가 되며, 乙이 침해자인 甲으로부터 특허발명을 선의로 적법하게 구입하였다고 하더라도 乙이 특허발명을 사용 또는 판매하는 경우에는 독립적인 별개의 실시행위에 해당되므로 특허권의 효력은 여전히 거기에까지 미치게 되어 별개의 특허권의 침해가 된다.



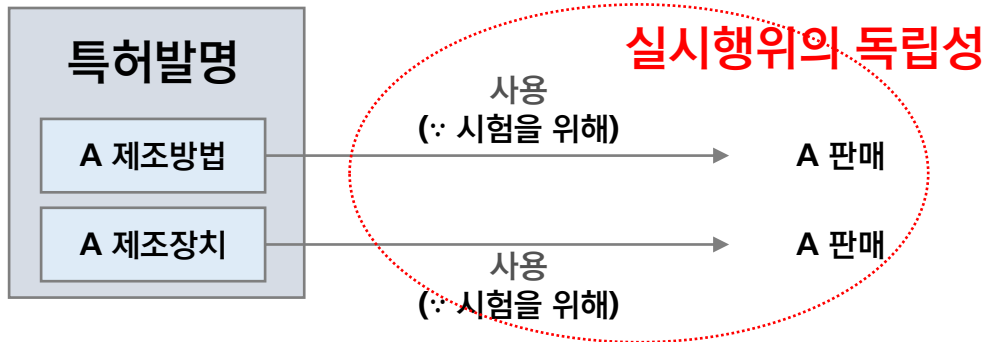
주체	행위	실시여부	침해여부
乙	A 생산 A 판매	실시 실시	침해 침해
丙	A 구입 A 사용	비실시 실시	비침해 비침해(∵업이 아님)
丁	A 사용	실시	비침해(∵권리소진)
戊	A 사용 A 생산	실시 실시	비침해(∵권리소진) 침해
己	b 생산	비실시	침해(∵간접침해)
비고	각각의 실시행위별로 침해인지 여부를 판단(실시행위의 독립성)		

특허권자는 왜 SET MAKER를 공격하는 것일까?

- 손해배상액의 결정
- 침해금지의 영향력



각각의 실시행위별로 특허권의 침해인지를 판단하므로, 연구 또는 시험을 위한 실시는 침해가 아니나 그 결과 제작된 것을 업으로서 연구 또는 시험 이외의 것에 실시했을 때는 특허권의 침해가 된다. 예를 들면 물건을 생산하는 방법에 관한 특허발명을 시험하여 생산된 물건을 타인에게 양도하는 것은 특허권의 침해가 된다. 그러나 **물건제조장치에 관한 특허발명을 시험하여 생산된 물건을 타인에게 양도하는 것은 물건의 양도가 물건제조장치의 실시(法 2Ⅲ가)가 아니므로 특허권의 침해가 되지 아니한다.**



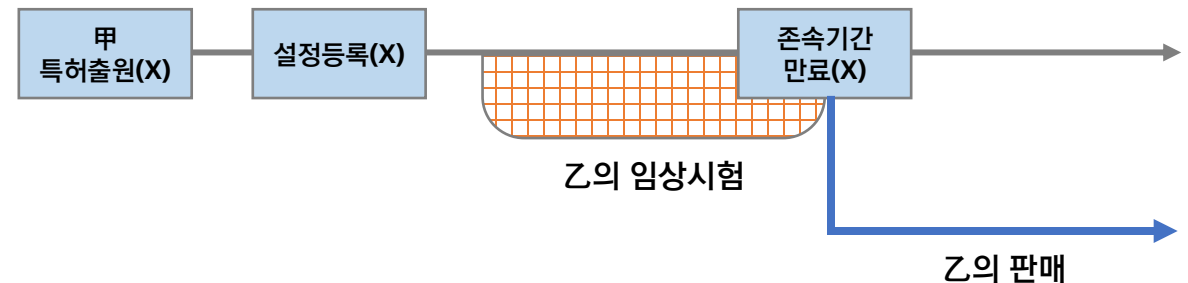
특허발명	제3자의 실시	침해 여부	비고
A 제조방법 (方1)	A 제조방법 사용(∴ 시험을 위해)	×	제96조제1항제1호 해당
	제조방법(方1)의 사용에 의하여 생산된 A 판매	○	제2조제3호(다)목의 실시에 해당 (실행행위의 독립성)*
A 제조장치 (裝1)	A 제조장치 사용(∴ 시험을 위해)	×	제96조제1항제1호 해당
	제조장치(裝1)의 사용에 의하여 생산된 A 판매	×	제2조제3호(가)목의 실시에 해당하지 않음**

* A 제조방법의 실시: 제조방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 **생산한 물건(A)**을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약하는 행위

** A 제조장치의 실시: 제조장치를 생산·**사용(A 생산)**·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

기존에 논란이 되었던 부분은 특허발명인 의약품의 존속기간이 만료된 후 상업화할 목적으로 특허권의 존속기간 중 약사법의 허가를 얻기 위한 시험을 한 경우 (통상적으로 시험결과를 얻어내기 위해서는 2~3년의 시간이 소요됨) 특허권의 침해가 되는지 여부이다. 이에 대하여 판례는 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에 해당하기 때문에 침해가 아니라고 판시하였다. **허가를 얻기 위한 시험이 침해가 된다면 의약품의 존속기간이 만료된 후에도 시험결과를 얻어내기까지 특허권자를 부당하게 보호하는 결과가 되므로 제96조제1항제1호에 해당하여 침해가 아니라고 하였다.** 2010년 1월 27일 개정(법률 제9985호, 2010. 7. 28. 시행)된 특허법에서는 제96조제1항제1호의 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에 “「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다.”라고 하여 이를 명확히 하고 있다.

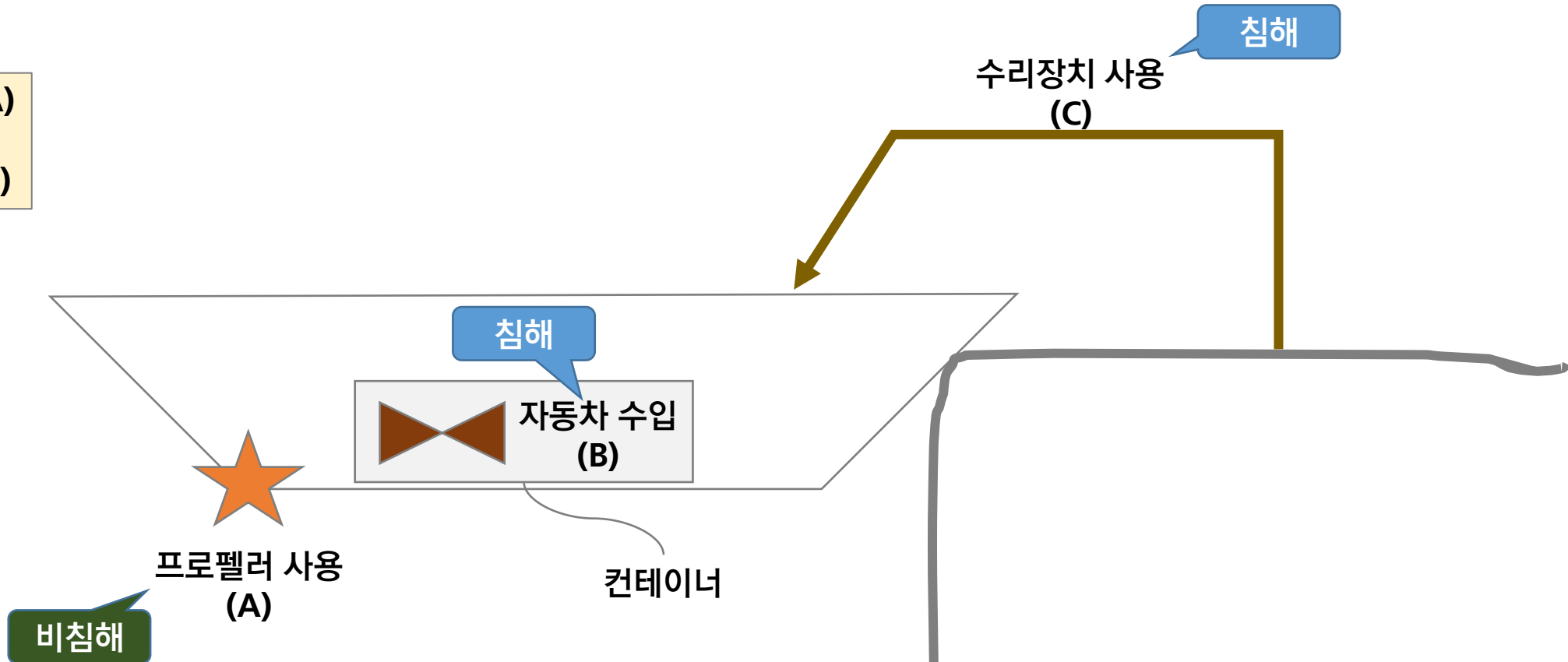
乙이 약사법의 허가를 얻기 위한 임상시험을 한 경우 甲의 특허권의 침해인가?



「국내」란 영토뿐만 아니라 영해 및 영공 등을 포함하며, 「국내를 통과하는데 불과한」이란 주유를 하거나 하역을 위하여 일시 정박하거나 착륙한 교통기관을 말한다. 한편, 「기계·기구·장치, 그 밖의 물건」은 직접 항공기 등의 운행에 필요한 것뿐만 아니라 여객의 생활에 필요한 일체의 설비물도 포함하는 것으로 넓게 해석하는 것이 타당하다고 본다. 다만 물건 이외의 「방법」은 포함되지 아니함을 유의하여야 한다. 또한, 일시적 또는 우발적으로 선박·항공기·차량 또는 이들에서 사용하는 기계·기구 등을 육상에서 수리 등을 하는 경우에 수리장치 또는 방법이 특허에 해당되거나 선박 또는 항공기에 적재된 특허물이 수입을 목적으로 하는 경우에는 이들에 대하여 특허권의 효력이 미친다는 것은 당연하다.

특허발명

프로펠러(A)
자동차(B)
수리장치(C)



1

권리의 유효성

특허권의 하자가 있더라도 하자를 이유로 특허취소신청의 취소결정이나 무효심판의 인용심결확정에 의한 소멸되기 전까지는 권리가 유효

행정처분의 공정력이 부정되어 당연무효가 되기 위해서는 그 하자가 법규의 중요한 부분을 위반한 **중대한** 것으로서 객관적으로 **명백**하여야 하나, 지식재산처 심사관이 특허결정을 할 때에는 엄격한 선행기술의 조사, 거절이유의 통지 등의 절차를 거쳐 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에 한하여 이루어지는 점, 특허무효사유 가운데는 신규성 또는 진보성 결여와 같이 단순한 사실확정의 문제에서 나아가 법적 평가의 성격을 지니는 것들이 적지 않은데다가 대체로 그 판단이 반드시 자명하지는 아니한 점 등에 비추어 보면, 특허법 소정의 특허무효사유는 원칙적으로 행정법상의 당연무효사유에 해당한다고 보기는 어렵고 단순한 취소사유에 불과하다.

원칙: 권리범위 인정

2

예외: 권리범위 불인정

- 신규성 위반인데 착오로 등록된 경우
- 선출원 위반인데 착오로 등록된 경우
- 확대된 선출원 위반인데 착오로 등록된 경우
- 실시불가능한 경우
- 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우

3

원칙: 권리행사가능

- 권리행사 후 취소결정이나 무효심결의 확정에 의하여 특허권이 소급하여 소멸한 경우, 권리침해소송 등의 민사소송의 확정판결 혹은 침해죄의 확정판결에 대하여 재심의 소를 제기가능
- 특허권자가 무효심결의 확정 전에 특허권을 행사하여 고의 또는 과실로 타인에게 손해를 입힌 경우 그 손해를 배상해야 하며, 고의 또는 과실에 없더라도 부당이득은 반환해야 함

4

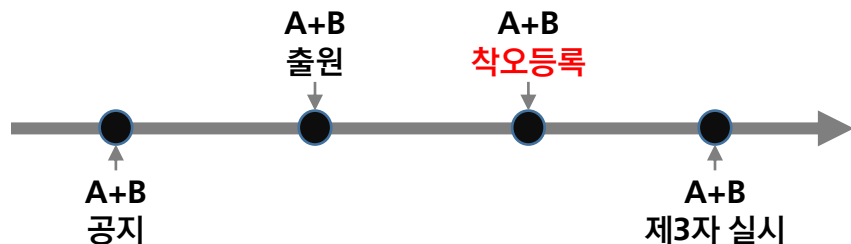
예외: 권리행사불가능

특허발명에 대한 취소결정이나 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 취소결정이나 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 불허

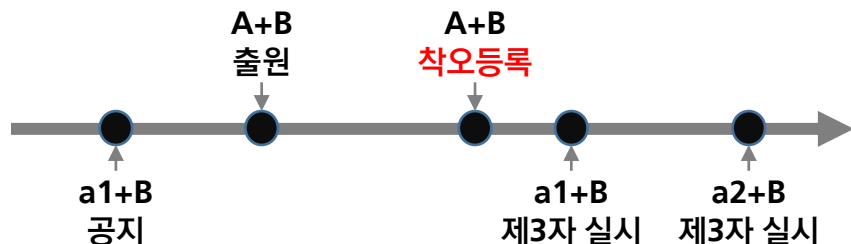
- 권리범위 불인정하는 것을 이유로 실시자가 항변하는 것은 **특허권 하자의 항변**, 권리행사불가능을 이유로 실시자가 항변하는 것은 **권리남용의 항변**이라 함
- 특허권 하자의 항변은 침해소송뿐만 아니라 권리범위확인심판에서 가능하나, 권리남용의 항변은 침해소송에서만 가능함

유형

(유형1) 특허발명이 공지기술과 내재적 동일성(문언적 동일)이 있는 경우

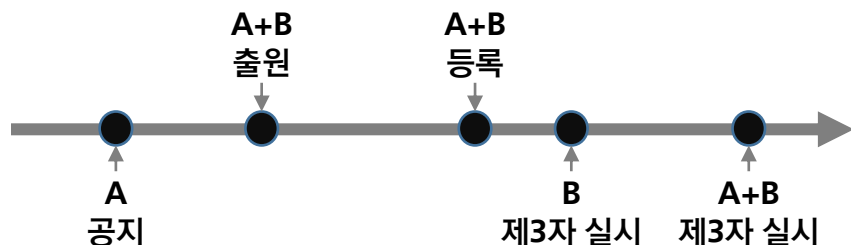


(유형2) 특허발명이 공지기술과 실질적 동일성이 있는 경우



* A는 a1과 a2를 포괄하는 개념임

(유형3) 특허발명의 구성요소 일부가 공지기술인 경우



특허요건의 판단

공지 A+B와 출원된 발명 A+B는 동일하기 때문에 신규성 위반임에도 불구하고 착오로 등록

공지 a1+B와 출원된 발명 A+B는 동일하기 때문에 신규성 위반임에도 불구하고 착오로 등록

공지 A와 출원된 발명 A+B는 동일하지 않기 때문에 신규성 위반이 아니고, 만약 A+B가 A로부터 용이하지 않다면 등록가능함

침해의 판단

특허취소신청이나 특허무효심판과 관계없이 제3자의 A+B 실시에 대해서 권리범위를 불인정

특허취소신청이나 특허무효심판과 관계없이 제3자의 a1+B 실시에 대해서 권리범위를 불인정. a2+B 실시에 대해서는 **권리범위를 불인정하되, 특허권자가 정정(심판)청구를 통해 취소사유, 무효사유를 극복한 경우에 권리범위를 인정하는 것이 타당**

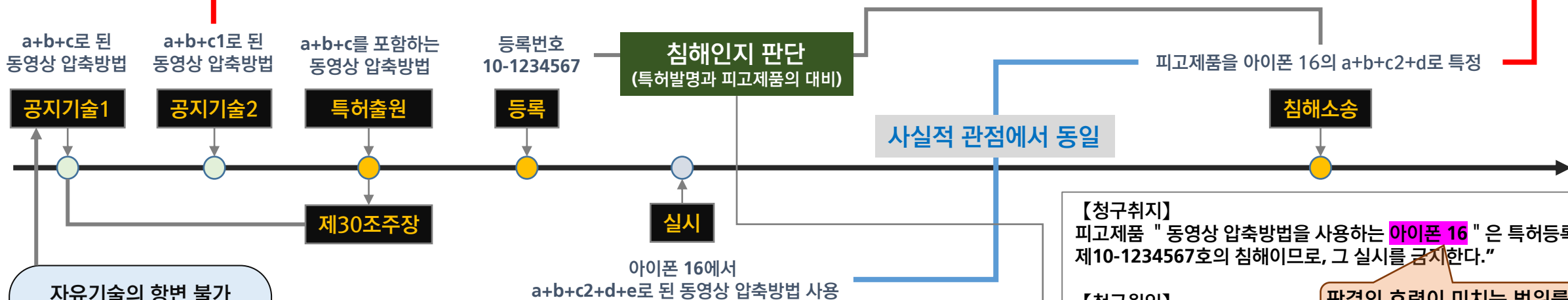
구성요소완비의 원칙에 따라 제3자의 B 실시는 권리범위에 속하지 않으나, A+B 실시는 권리범위에 속함

cf) 대응구성설 - $a + b + c2$

특허권자가 특정한 구성 전체(2008후64) - 전체구성설

피고 제품($a+b+c2+d$)이 공지기술2($a+b+c1$)와 동일하거나 통상의 기술자가 공지기술2($a+b+c1$)로부터 용이하게 실시할 수 있어 자유기술영역(=공공영역)에 속하므로 특허발명(10-1234567)과 대비할 필요도 없이 침해가 아니다(99후710).

특허발명과 대비하여 문언침해, 균등침해인지 상관없이 적용(2016후366)



자유기술의 항변 불가
(2022후10012)

1. 자유기술의 항변을 인정한다면 공지에외적용주장을 하여 등록된 특허는 실질적으로 권리 행사를 할 수 없게 되어 공지에외적용주장제도의 취지를 몰각시키고 제도를 형해화
2. 자유기술의 항변은 애당초 특허를 받을 수 없는 공공영역에 대해서 권리범위를 인정하지 않겠다는 것인데, 시기적, 절차적 요건 등을 지키면서 공지에외적용주장을 하였다면 입법적 결단을 통해 공공영역이 독점배타적인 특허를 받을 수 있는 영역에 편입되어 더 이상 공공영역이 아님
3. 공지된 발명에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 특허권자와의 형평을 도모하기 위하여 인정되는 선사용에 의한 통상실시권(法 103)을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여하는 것은 온당치 않음

【청구취지】
피고제품 " 동영상 압축방법을 사용하는 아이폰 16 " 은 특허등록 제10-1234567호의 침해이므로, 그 실시를 금지한다."

- 【청구원인】
1. 이 사건 특허의 요지($a+b+c$)
 2. 피고제품의 요지($a+b+c2$)
 3. 침해인지 판단 (특허발명과 피고제품의 대비)
 4. 결론

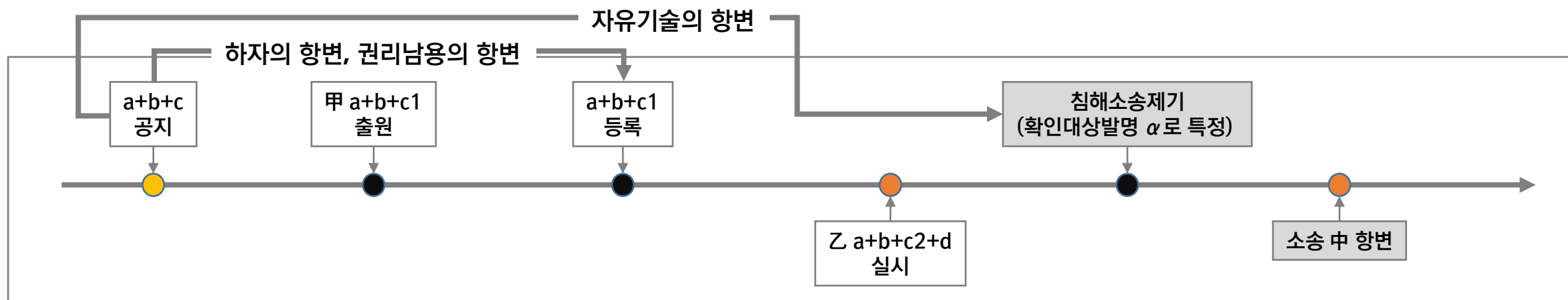
판결의 효력이 미치는 범위를 명확히 하기 위하여 다른 것과 구별

청구항 대비표(Claim-chart)

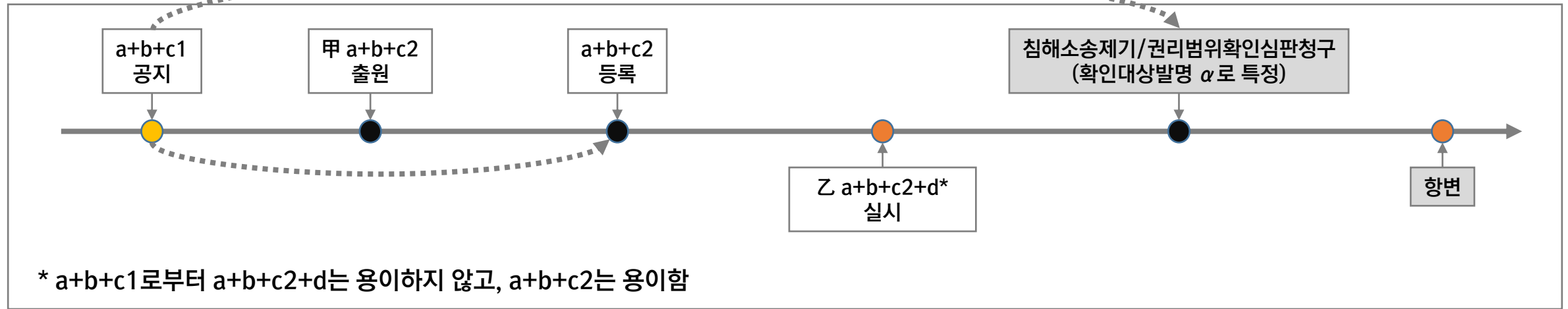
특허발명의 특징	피고제품의 특징	판단(○/×/△)
a	a	○
b	b	○
c	c2	△

특허발명과 대비하기 위하여 특허발명과 대응되는 구성 (대응되지 않은 구성 d는 대비함에 있어서 영향 X)

- 특허권자(甲)가 제기한 특허권 침해소송에서 실시자(乙)는 「 i) 특허권자의 등록발명 $a+b+c1$ 이 공지기술인 $a+b+c$ 와 동일하기 때문에 특허무효심판여부와 관련 없이 특허권의 권리범위를 인정할 수 없어 침해가 아니다 또는 ii) 확인대상발명 α 가 공지기술인 $a+b+c$ 와 동일하거나 $a+b+c$ 로부터 용이하게 실시할 수 있기 때문에 특허발명과 대비할 필요없이 침해가 아니다.」 라고 항변할 수 있다. 강학상 전자를 특허권 하자의 항변(무효의 항변), 후자를 자유기술의 항변이라 한다.
- 한편, 확인대상발명 α 는 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위해서는 **대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재**하면 되는 것이나 다만, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 한다. 즉, 특허권자는 확인대상발명 α 를 $a+b+c2$ 또는 $a+b+c2+d$ 로 특정할 수 있다. 다만, **특허권자가 확인대상발명 α 를 $a+b+c2+d$ 로 특정하는 것이 $a+b+c2$ 로 특정하는 것보다 실시자의 자유기술의 항변을 어렵게 만들기 때문에(예를 들어, $a+b+c2$ 는 $a+b+c$ 로부터 용이하나, $a+b+c2+d$ 는 $a+b+c$ 로부터 용이하지 않은 경우) 특허권자에게 이익이 된다.**



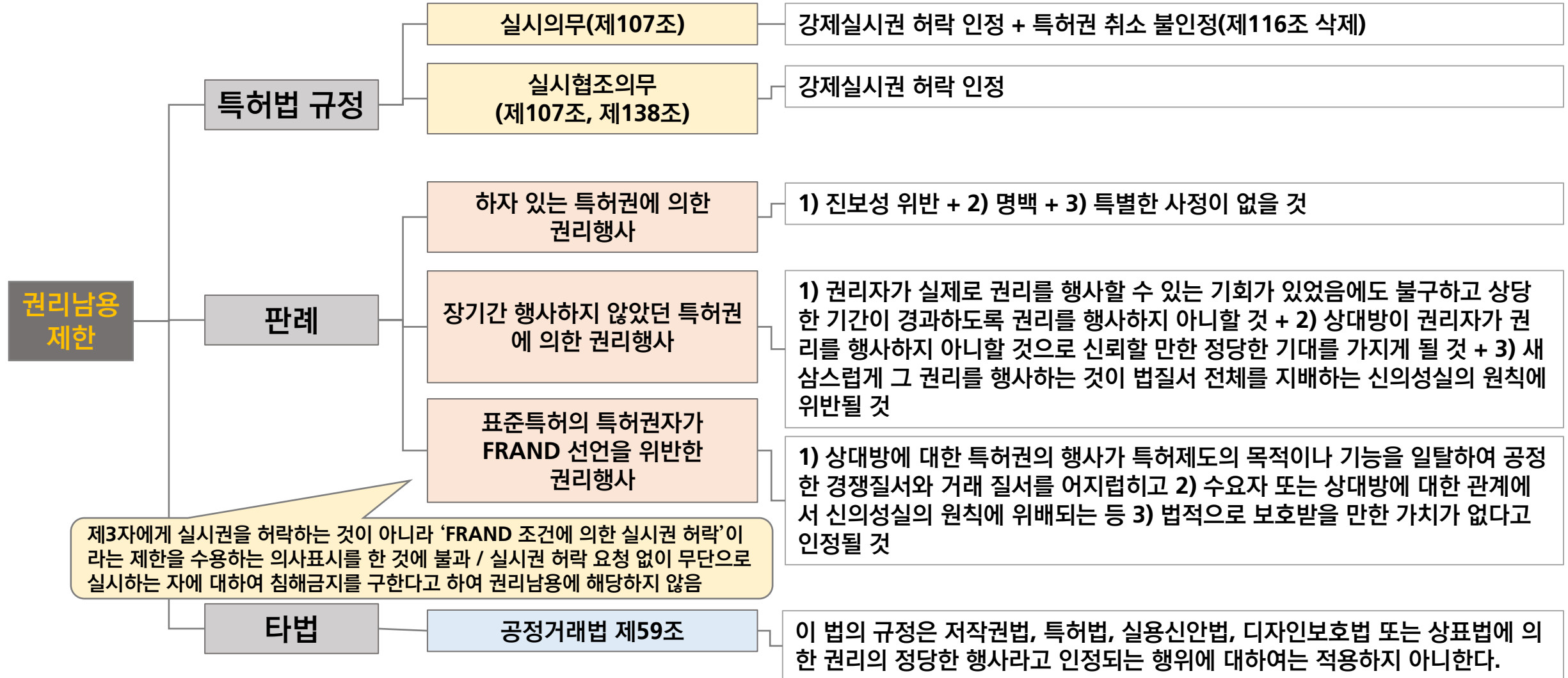
구 분		특허권 하자의 항변(무효의 항변)	자유기술의 항변
판단대상		공지기술 vs 특허발명	공지기술 vs 확인대상발명(α -전체구성설)
적용 범위	동일성	인정	인정
	용이성	부정(단, 최근의 판례가 일정한 경우 권리행사를 제한함)	인정
권리범위		부정	특허발명과 대비 필요성×(권리범위 언급×) - 문언침해, 균등침해 적용



확인대상발명(α)	권리범위확인심판		침해소송	
	자유기술의 항변*	권리남용의 항변**	자유기술의 항변*	권리남용의 항변**
a+b+c2	인정	불인정	인정	인정
a+b+c2+d	불인정	불인정	불인정	인정

* **확인대상발명(α)**이 공지기술로부터 유사하기 때문에 권리범위에 속하지 않는다.

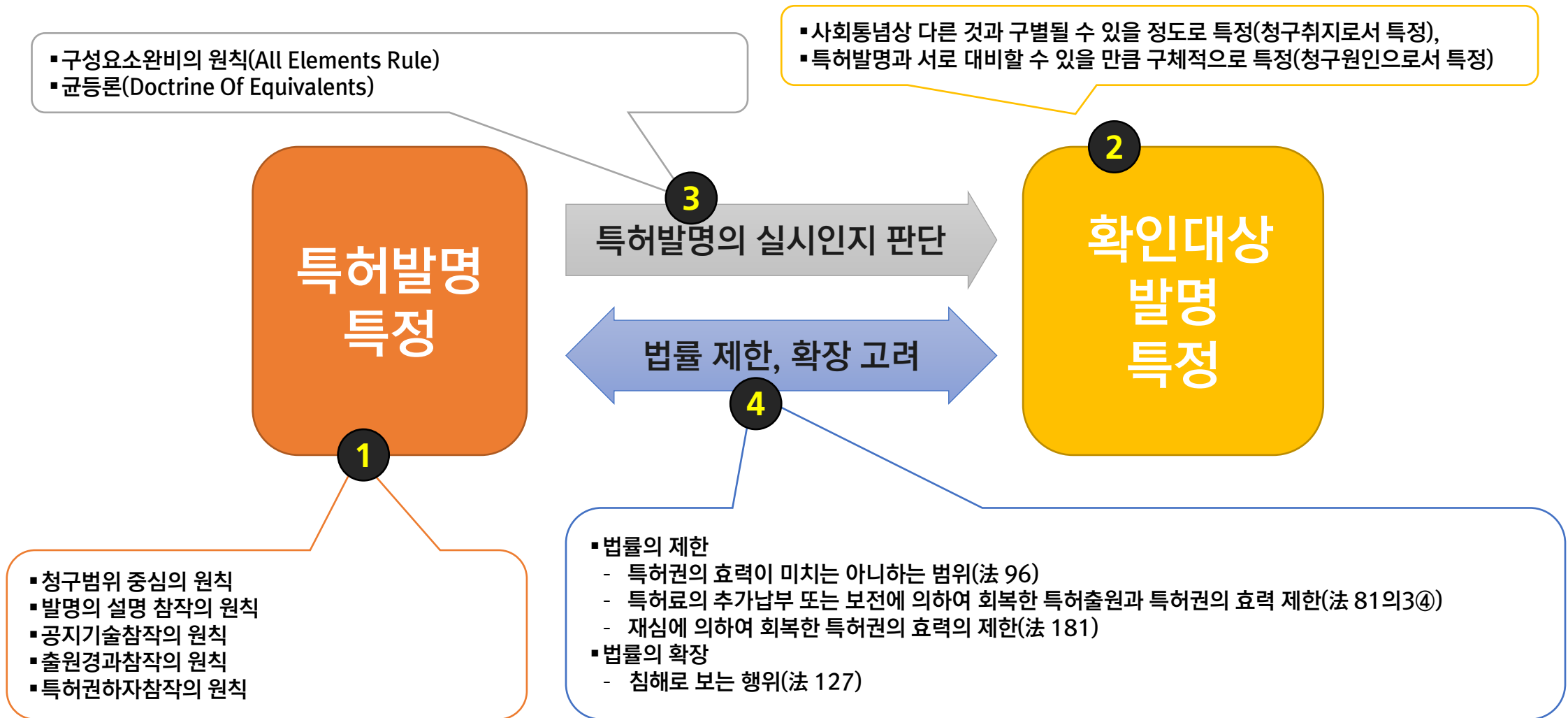
** **특허발명(a+b+c2)**이 공지기술로부터 용이함이 명백하고 특별한 사정이 없기 때문에 (권리범위에 속하더라도) 권리남용으로서, 침해가 아니다.



구 분	주변한정주의	중심한정주의
의 의	청구범위의 기재에 의해서 문언 그대로 해석	청구범위의 기재에서 발명의 핵심사상을 추출하여 확장 해석
판단의 용이성 (법적 안정성)	○	×
특허권자의 보호 (구체적 타당성)	×	○
판례 및 특허법의 태도	1. 판례의 태도 - 90년대 초반까지 중심한정주의 입장에 있었으나 90년대 후반 이후 주변한정주의 입장으로 변화 2. 주변한정주의의 보완(특허권자의 보호) ① 다항제(法 42④)* ② 간접침해(法 127) ③ 균등론(判例가 인정) ④ 생략침해, 불완전이용침해 이론(判例는 불인정)	

*다항제는 청구범위에 하나의 청구항만을 적을 수 있는 단항제(單項制)와 반대되는 개념으로서 보호범위의 해석원리로서 주변한정주의의 입장을 취할 때 발명의 다면적 보호를 위한 청구범위의 기재방법이라는 점에 그 의미가 있다. 우리 특허법은 종래(1961년 제정 특허법)에는 하나의 청구항만을 기재하도록 하는 단항제를 채택하고 있었으나, 1980년 법률 제 3325호부터 다항제를 도입하였다.

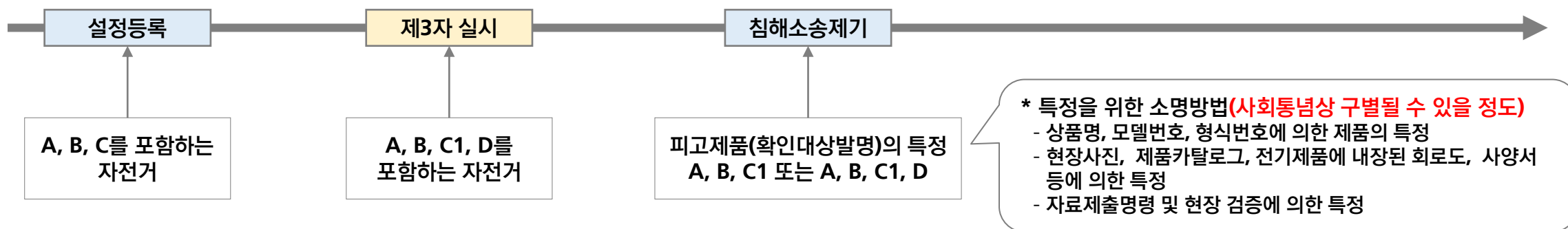
0 자유실시기술인지 판단



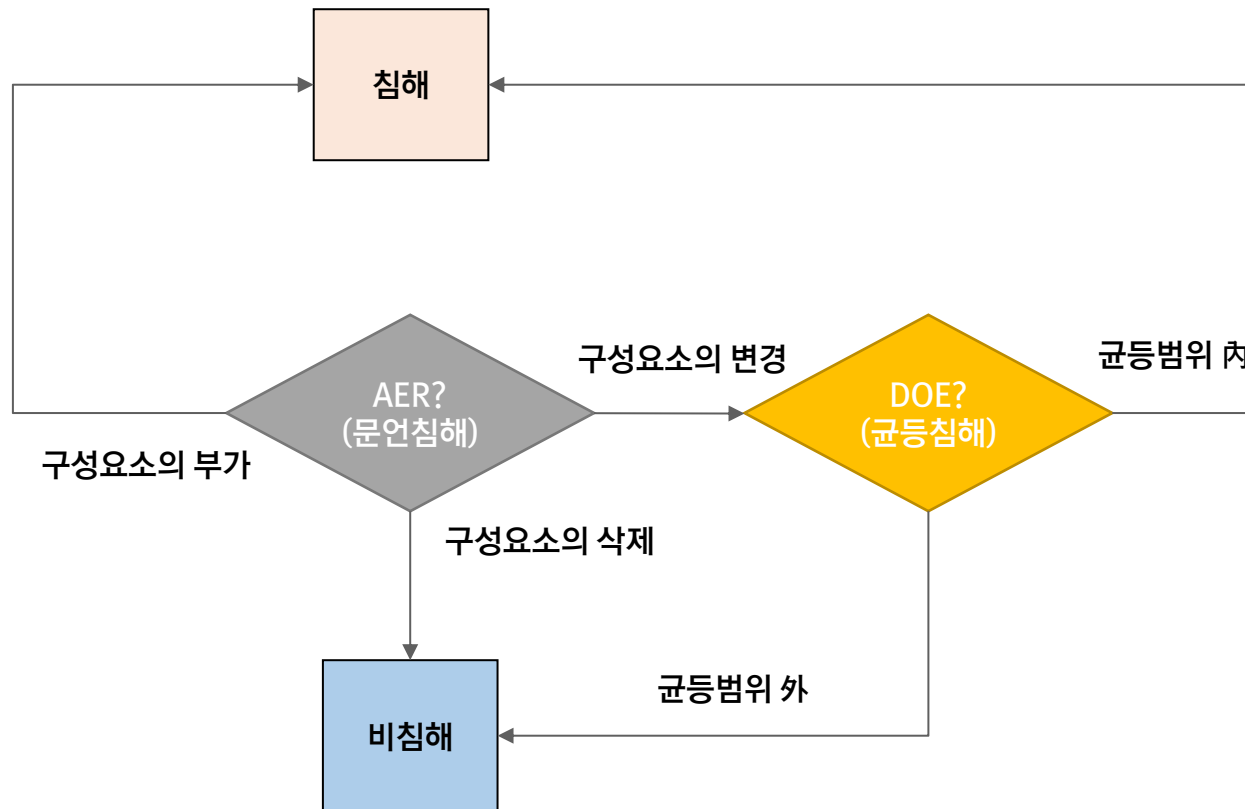
특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(法 97). 이는 특허발명의 보호범위가 청구범위에 기재된 그대로 정해진다는 의미는 아니며, 발명의 설명·도면의 참작과 함께 출원 당시의 기술수준, 출원의 경과 및 특허권의 하자 등을 참작하여 해석된 청구범위가 특허발명의 보호범위결정의 기준이 된다는 의미이다. 즉 특허발명을 특정할 때에는 청구범위 기준의 원칙, 발명의 설명 참작의 원칙, 공지기술 참작의 원칙, 출원 경과 참작의 원칙 및 특허권 하자 참작의 원칙 등이 고려된다.

청구범위 기준 원칙	- 발명의 설명에 적혀 있는 발명일지라도 청구범위에 포함되지 아니한 것은 특허발명의 보호범위에 속하지 않음 - 청구항별로 독립적으로 보호범위를 판단하고, 하나의 청구항의 보호범위에 포함된다면 그 특허발명의 보호범위에 속함
발명의 설명 참작 원칙	- 특별한 사정이 없는 한 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하려는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적, 합리적으로 하여야 한다. * 제한해석되는 특별한 사정(진실로 발명하지 않은 부분까지 보호범위를 인정하는 것은 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있음) - 기능적 표현으로 되어 있는 청구항 ① 문언 그대로 해석하는 것이 명백히 불합리한 경우 - ② 발명의 설명에 의하여 보충을 하더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 발명의 설명 또는 도면에 의하여 뒷받침되는 범위내로(단, 발명의 설명에 의하더라도 구성요소 일부가 추상적이거나 불분명하여 도저히 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없으면 보호범위 불인정) Cf) 확장해석되는 사례는 아직 없음
공지기술 참작 원칙	- 공지기술로부터 개량진보의 정도가 큰 발명의 보호범위는 넓게, 개량진보의 정도가 작은 발명의 보호범위는 좁게 인정(산업발전촉진에 대한 기여력의 측정이며, 균등범위에서 차이가 발생함) - 특허발명이 공지기술과 비교하여 개량·진보되지 아니한 경우, 즉 특허발명이 공지기술과 동일한 경우에는 보호범위를 인정할 수 없는데, 이를 특히 공지기술제외의 원칙이라 함
출원경과 참작 원칙	- 출원과정에서 확인대상발명의 치환된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등 특단의 사정을 참작해야 함 - 균등론의 적용에 따른 청구범위의 확장해석을 억제하기 위한 이론으로 발전
특허권 하자 참작 원칙	- 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 신규성이 없는 경우, 선행특허와 동일하여 선출원주의, 확대된 선출원에 위반된 경우, 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우는 권리범위를 불인정함

확인대상발명이란 권리범위확인심판에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단대상이 되는 구체적인 실시형태를 말하며, 침해소송에서는 대상 제품, 피고 제품, 피고 실시제품 등으로 표시된다. 확인대상발명은 대상물을 주관적으로 가공하여 설명서 또는 도면에 의하여 기재하는데, **사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.** 그리고, 해당 특허발명과 서로 **대비**할 수 있을 만큼 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부를 필요는 없고 특허발명의 구성요소에 **대응**하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나 다만, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 한다. 확인대상발명의 구성요소 중 **특허발명의 구성요소에 대응하지 아니한 구성요소**는 특허발명과 **대비**하여 구성요소 완비의 원칙, 균등론 등에 의한 특허발명의 실시인지 판단함에 있어서 자유기술의 항변의 경우를 제외하고는 일반적으로 영향을 미치지 아니한다. 다만, 확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하지 아니하면 종속항에 대응되는 부분의 구성이 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 특정된 것으로 보고 종속항의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단할 수 있다. 이는 **독립항의 권리범위가 인정되었을 때** 그 권리범위는 독립항을 구체화한 종속항의 권리범위보다 더 넓을 수밖에 없기 때문이다.



특허발명의 특징	피고제품의 특징	판단(○/×/△)
A	A	○
B	B	○
C	C1	△
결론	△(특허발명과 확인대상발명을 대비하여 특허발명에 대응되는 구성이 모두 동일하면 구성요소완비의 원칙을 적용하고, 대응되는 구성의 일부에 차이가 있다면 균등론의 적용 여부를 검토하여 침해 여부를 판단한다. 특허발명의 구성요소 중 일부라도 생략되어 있다면 비침해이다.)	



* 누가 특허를 침해 하였는가?

[청구항 1] a, b, c, d를 포함하는 재봉틀.

- 삼순이 : a, b, c 로 구성된 재봉틀?
- 향단이 : a, b, c, d, e 로 구성된 재봉틀?
- 간난이 : a, b, c, f로 구성된 재봉틀?

2. My patent



- 청구항 1.
받침대와;
상기 받침대의 일단에 결합되어 있는 등받이와;
상기 받침대 하부에 연결되어 상기 받침대를 지지하는
4개의 다리와;
상기 받침대 및 상기 등받이에 결합되어 있는 팔걸이
를 포함하는 의자.

1. My product



3. Other product



2. My patent



- 청구항 1.
받침대와;
상기 받침대의 일단에 결합되어 있는 등받이와;
상기 받침대 하부에 연결되어 상기 받침대를 지지하는
4개의 다리
를 포함하는 의자.

1. My product



3. Other product



2. My patent



- 청구항 1.
받침대와;
상기 받침대 하부에 연결되어 상기 받침대를 지지하는
4개의 다리
를 포함하는 의자.

1. My product



3. Other product



2. My patent



- 청구항 1.
받침대와;
상기 받침대에 결합되어 상기 받침대를 지지하는 복수의 다리
를 포함하는 의자.

1. My product

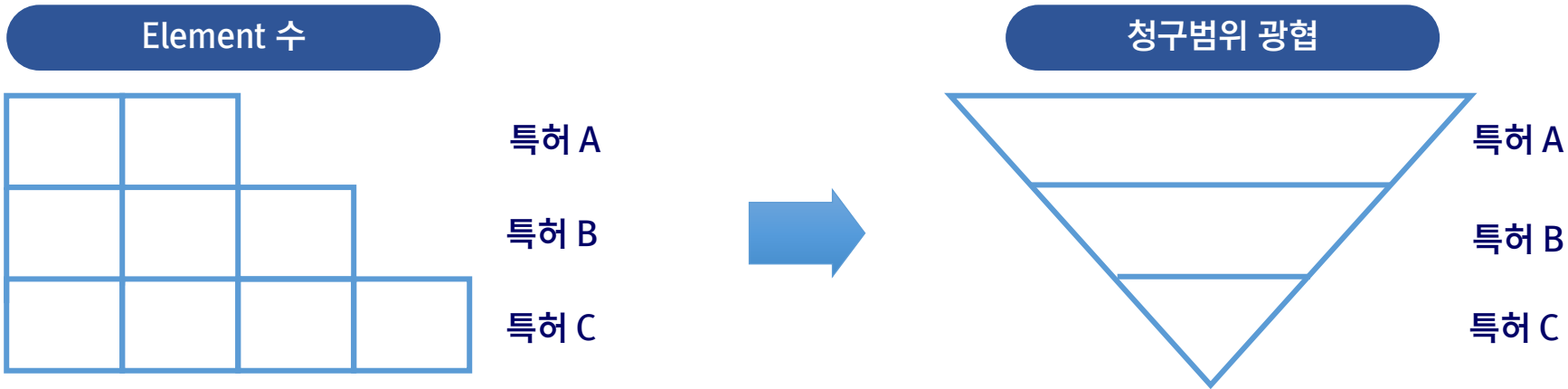


3. Other product

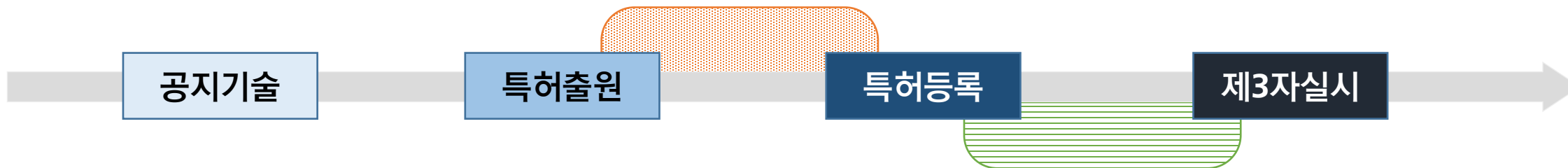


[illegible]

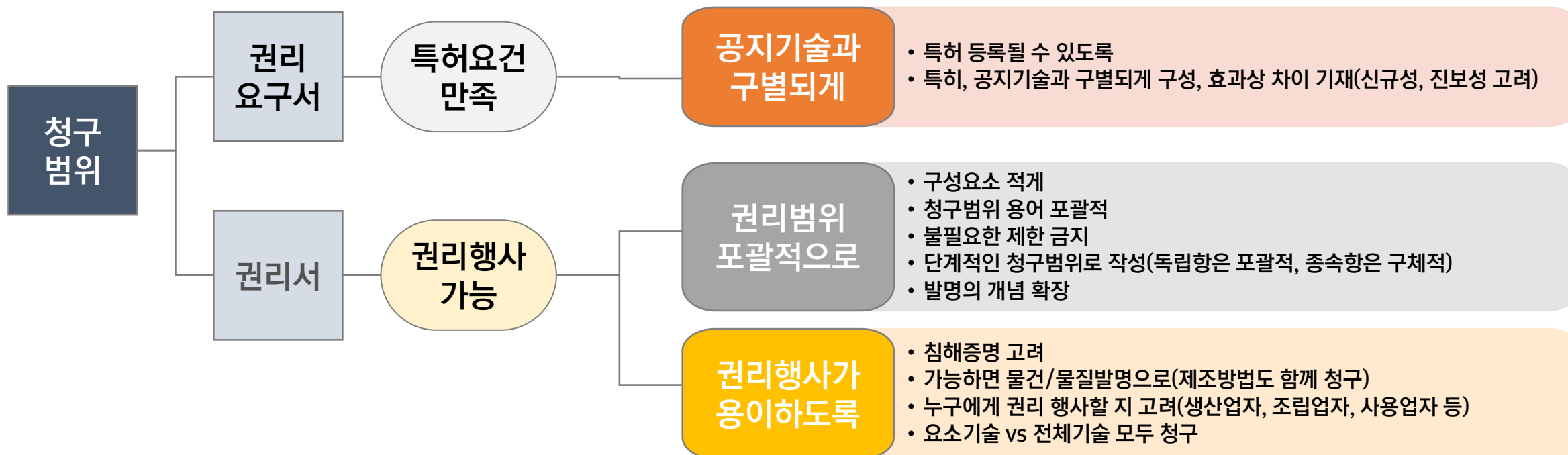
청구항에 구성요소를 많이 기재하면 등록가능성이 높아지지만, 상대적으로 권리범위는 좁아지게 된다. 따라서, 등록가능성을 만족할 정도의 구성요소만을 기재하는 것이 가장 바람직하다. 청구항 작성시 한정사항을 최소화하는 것도 중요하지만 그 보다 더 중요한 것은 구성요소가 생략 불가능한 필수요소인지에 대한 판단이다.



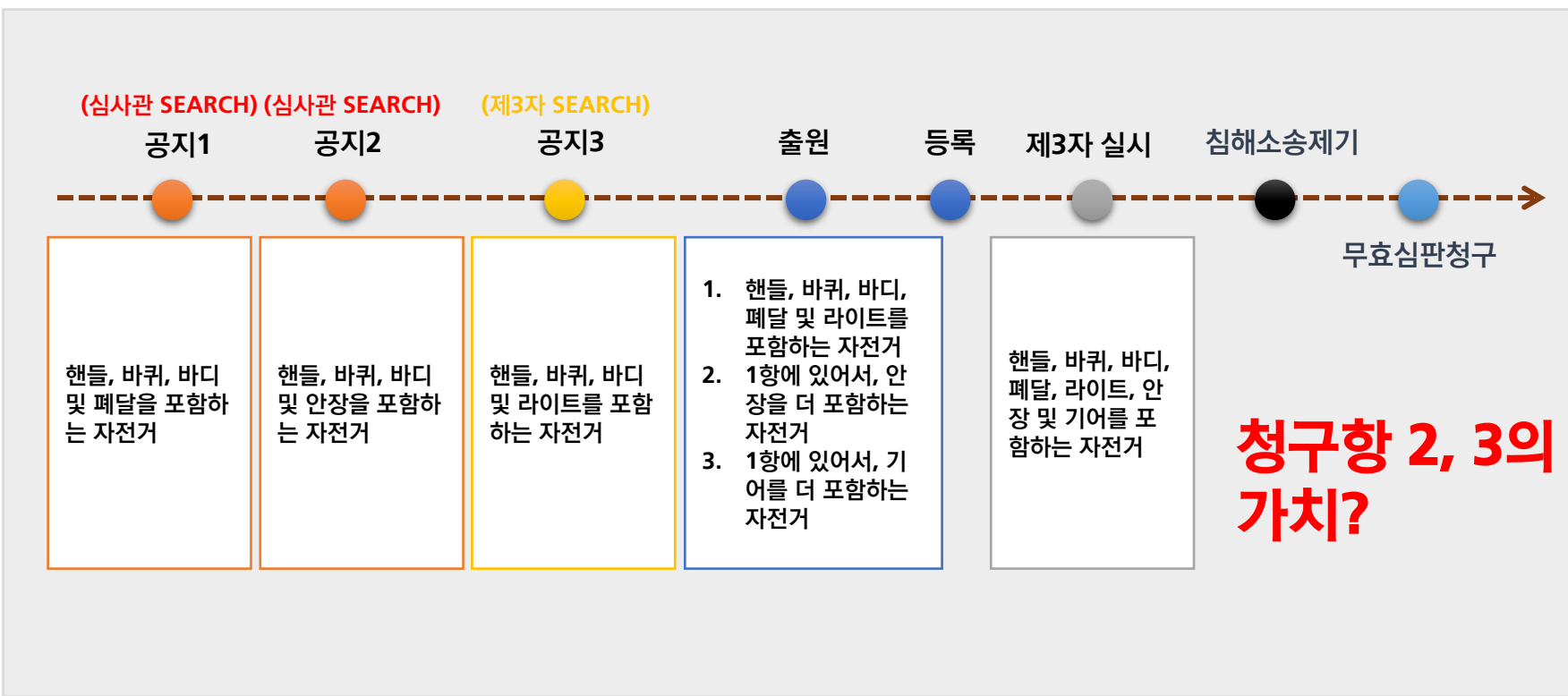
공지기술과 차별성을 확보하기 위하여
구성요소를 많이 기재하는 것이 유리



침해 주장을 하기 위하여
구성요소를 적게 기재하는 것이 유리



청구범위의 청구항은 상호 독립되어 있기 때문에 독립항, 종속항 상관없이 청구항별로 특허요건을 판단하고, 등록후에는 청구항별로 침해여부를 판단하는 것이 원칙이다. 그러나 종속항의 보호범위는 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화한 청구항이기 때문에 독립항의 보호범위보다 상대적으로 좁다. 따라서 독립항이 특허요건판단에 있어서 신규성, 진보성 위반이 아니면, 종속항도 신규성, 진보성 위반이 아니다. 등록후 침해여부판단에 있어서도 독립항의 침해가 아니면 종속항의 침해도 되지 아니한다(물론 독립항의 보호범위가 인정되지 아니하고, 종속항의 보호범위만 인정되면 독립항의 침해가 아닐지라도 종속항의 침해가 될 수도 있다). 이와 같은 논리라면 표면적으로 살펴보면 종속항의 존재 의의가 없는 것으로 보일 수도 있다. 종속항의 가장 중요한 존재 의의는 **등록 후 특허의 취소나 무효 가능성을 대비**할 수 있다는 것이다. 제3자가 실시하는 발명이 독립항과 그 종속항의 침해인 경우 독립항이 특허취소신청에 의하여 취소나 특허무효심판에 의하여 무효가 되더라도 종속항이 있다면 권리행사를 할 수 있게 된다. 종속항에 의하여 권리행사를 하기 위해서는 종속항에는 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화해서 **별개의 새로운 발명이라고 부를 수 있는 정도의 구성요소**를 적어야 한다. 즉, 심사관이 독립항의 구성요소와 결합하였을 때 신규성, 진보성 등의 특허요건 위반이 아니라고 판단할 만한 구성요소를 종속항에 적어야 한다. 그렇지 아니한 경우 **독립항의 특허요건 위반이 있으면, 종속항도 같이 특허요건 위반이 된다.** 이와 같은 종속항을 적는 것은 출원인에게 심사청구료, 특허료 등 청구항 수에 따라 달라지는 비용 부담만 가중시키는 결과를 초래한다.



출원발명	공지1	공지2	심사 (1&2)	공지3	심판 (1&2&3)
1					
핸들	O	O	O	O	O
바퀴	O	O	O	O	O
바디	O	O	O	O	O
페달	O	X	O	X	O
라이트	X	X	X	O	O
2					
핸들	O	O	O	O	O
바퀴	O	O	O	O	O
바디	O	O	O	O	O
페달	O	X	O	X	O
라이트	X	X	X	O	O
안장	X	O	O	X	O
3					
핸들	O	O	O	O	O
바퀴	O	O	O	O	O
바디	O	O	O	O	O
페달	O	X	O	X	O
라이트	X	X	X	O	O
기어	X	X	X	X	X

특허발명
(A+B)

VS

확인대상발명
(A+B1)

구성(전체)

과제의 해결원리가 동일

B와 B1의 변경된 부분이 있더라도 과제의 해결원리가
동일할 것

(invention as a whole)

효과

변경가능성이 있을 것(작용효과가 실질적 동일)

B와 B1이 작용효과가 실질적 동일한 것

(invention as a whole vs individual element)

구성(요소)

변경용이성이 있을 것
(침해시를 기준으로 판단)B로부터 B1를 쉽게 변경할 수 있을 것
(individual element)확인대상발명이 공지기술이 아닐 것
(자유기술의 항변)A+B1이 공지기술과 동일하거나 공지기술로부터 용이
하지 않을 것의식적으로 제외된 것이 아닐 것
(출원경과참작의 항변)A+B 출원절차를 통하여 A+B1이 의식적으로 제외된
것이 아닐 것적극적 요건
(특허권자 주장)

특별사정

소극적 요건
(실시자 항변)균등론
적용요건

과제의 해결원리가 동일한 지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 **기술사상의 핵심**이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단(대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361)

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른 없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252).

기술사상의 핵심
공지여부

No

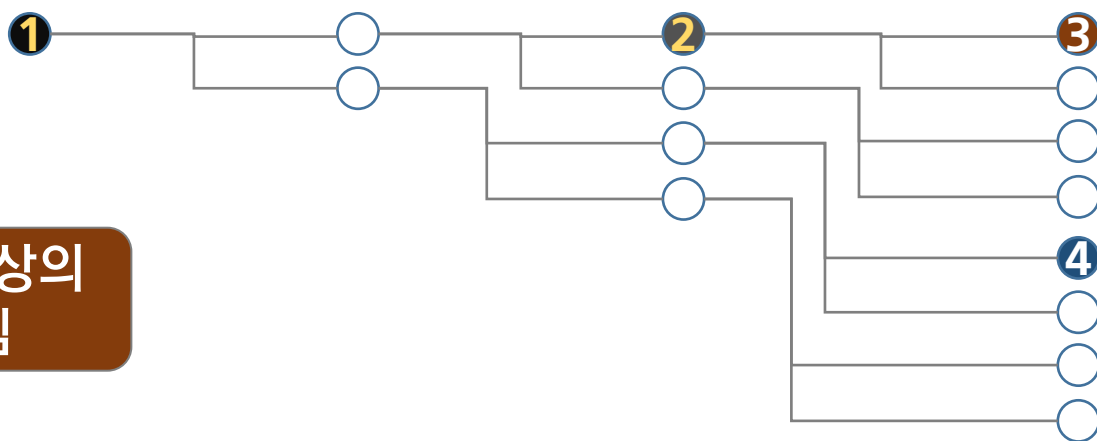
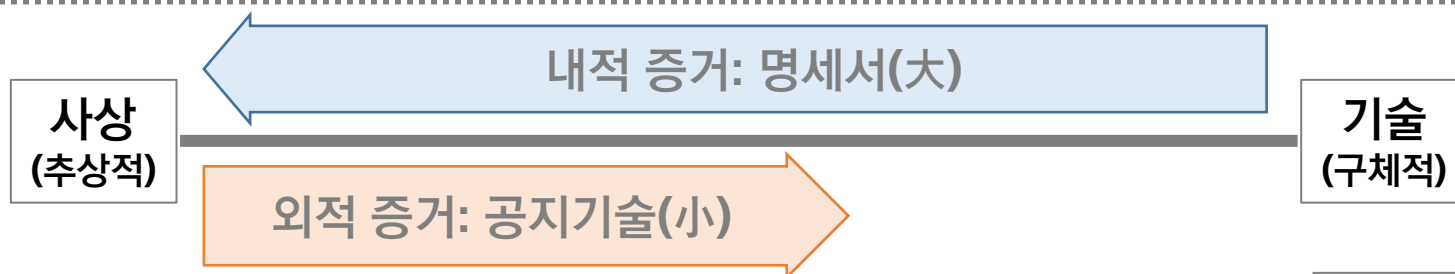
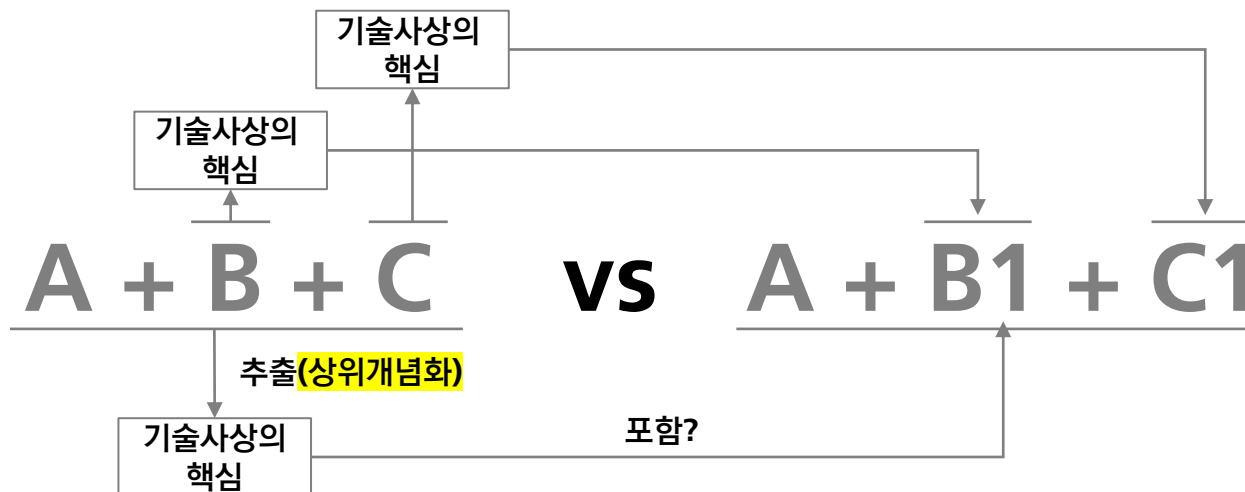
(발명 전체 판단) 실질적으로 작용 효과 동일 ○

Yes

(구성요소 판단) 실질적으로 작용 효과 동일 △

individual element

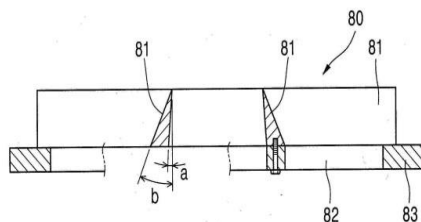
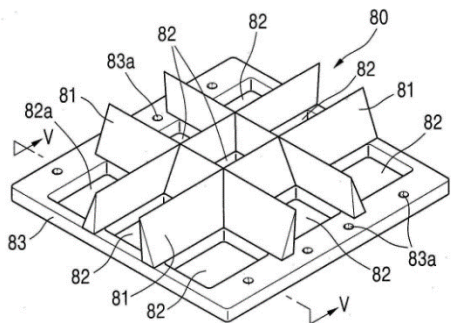
invention as a whole



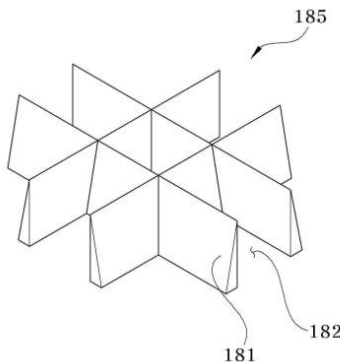
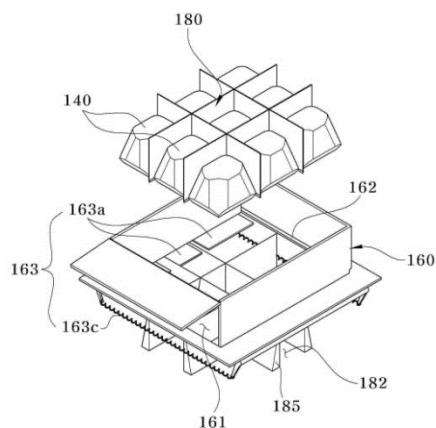
특허발명(3)의 기술사상의 핵심이 1번으로 파악되는 경우
 피고제품(4)은 과제의 해결원리가 동일한 반면,
 특허발명(3)의 기술사항의 핵심이 2번으로 파악되는 경우
 피고제품(4)은 과제의 해결원리가 동일하지 않음

기술사상의
핵심

특허발명



확인대상발명



(1) 이 사건 제1항 발명 중 원심 판시 구성 7은 ‘가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날(80)’로서, 이는 가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 ‘격자형 부재’와 그러한 격자형 부재와 같은 위치에 고정 배치되는 ‘격자형 칼날’이 일체로 형성된 것이다.

(2) 그런데 피고 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘격자형 부재’ 구성처럼 가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 구비한 ‘격자형 박스(185)’ 구성을 그대로 가지되, 다만 이 사건 제1항 발명의 ‘격자형 칼날’ 구성을 상하로 이동되는 절단용 실린더에 연동하고 각 가압절판에 인접하여 수직으로 형성되는 ‘격자형 절단날(180)’ 구성으로 변경한 것이다.

(3) 따라서, ‘격자형 부재’와 일체로 형성되어 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 이 사건 제1항 발명의 ‘격자형 칼날’과 달리, 피고 실시제품은 ‘격자형 절단날’이 ‘격자형 박스’와 분리되어 상하로 이동되도록 가이드케이스의 위쪽에 별도로 배치되는 점에서 차이가 있다.

(4) ‘종래에는 포장용기들의 각 수납공간 사이의 간격만큼 절단된 각각의 적층 김들의 사이를 벌려 놓는 구조를 제시하지 못했지만, 위 적층 김들을 누르는 가압절판들이 격자형 절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도함으로써 수납공정까지 자동화할 수 있다’는 취지가 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있다.

(5) 이러한 명세서의 기재와 출원 당시 공지기술 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하는 데에 있다. 그런데 피고 실시제품도 경사면을 구비한 ‘격자형 박스’ 구성에 의해 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’할 수 있다. 따라서 피고 실시제품은 위와 같은 구성의 변경에도 불구하고 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 없으므로, 과제의 해결원리가 동일하다.

(6) 그리고 피고 실시제품은 위와 같은 구성의 변경에 의하더라도 ‘절단된 각각의 적층 김들이 포장용기 내에 정확히 위치하도록 사이를 벌려 놓아 수납공정까지 자동화’한다는 점에서 이 사건 제1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다.

(7) 나아가 피고 실시제품처럼 상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 그 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하므로, 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 그와 같은 구성의 변경을 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다.

(8) 비록 피고 실시제품에서 ‘격자형 절단날’이 상하로 이동하기 위해 구조가 다소 복잡해지고 ‘가압절판’과의 관계에서 구체적인 절단방식이 달라지는 등의 차이가 생긴다고 하더라도, 이는 앞서 본 기술사상의 핵심과 관련 없는 관용적 기술수단을 채택함에 따른 부수적인 것에 불과하다고 보이므로 이러한 차이를 들어 실질적인 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다.

	특허발명	확인대상발명
구성6		
구성7		

(1) 과제 해결원리의 동일성 여부 (invention as a whole)

(가) 채무자의 원심 판시 이 사건 실시제품에는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 구성 6과 구성 7을 제외한 나머지 구성들인 ① 구성 1(프레임), ② 구성 2(절단용 실린더유닛), ③ 구성 3(승강판), ④ 구성 4(가압절판), ⑤ 구성 5(가압봉), ⑥ 구성 8(포장용기 이송유닛)과 동일한 구성들이 포함되어 있다.

(나) 이 사건 제1항 발명의 구성 6은 ‘적층 구이김을 내부로 수용하기 위한 투입구가 일측에 형성되고 그 내측에는 투입 중인 구이김을 정확한 절단위치까지 이송하기 위한 인입작동유닛이 구비되어 상기 구이김을 내부로 자동 인입할 수 있게 함과 아울러 **상기 가압절판의 승강 작동을 안정적으로 안내해주는 가이드케이스**’이다. 이 사건 실시제품은 “구이김을 이송하는 인입작동유닛이 구비되는 한편, 구이김이 투입되는 곳에 **회동이 가능한 회동푸셔가 형성되고 그 맞은편에는 4개의 수직봉 형상의 스톱퍼가 설치되며**, 위쪽 변의 길이가 아래쪽 변의 길이보다 짧은 사다리꼴 형상의 가압절판이 상사점(상사점: 왕복운동의 상승행정 중 가장 높은 위치)에서 중간판 내측에 형성된 **사각케이스 형상의 중공에 끼워져** 모이게 되는 기술 구성”(이하 ‘구성 6 대응구성’이라 한다)을 포함하고 있다.

(다) 이 사건 제1항 발명의 구성 7은 ‘**가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날**’이다. 이 사건 실시제품은 “**김의 절단위치 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 구비한 ‘격자형 박스’와, 상하로 이동되는 절단용 실린더에 연동하고 각 가압절판에 인접하여 수직으로 형성되는 ‘격자형 절단날’의 기술 구성**”(이하 ‘구성 7 대응구성’이라 한다)을 포함하고 있다.

(라) 이 사건 특허발명의 설명에는 ‘종래에는 포장용기들의 각 수납공간 사이의 간격만큼 절단된 각각의 적층 김들의 사이를 벌려 놓는 구조를 제시하지 못했지만, 위 적층 김들을 누르는 가압절판들이 격자형 절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도함으로써 수납공정까지 자동화할 수 있다’는 취지가 기재되어 있다.

(마) 이러한 발명의 설명의 기재가 통하여 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘**절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부품의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도**’하는 데에 있다. 원심 판시 선출원고안은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지된 기술이 아니고, 그 밖에 위와 같은 기술사상의 핵심이 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 볼 만한 사정은 보이지 않는다. 그리고 발명의 설명에 구성 6 가이드케이스가 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내한다고 기재되어 있으나, 이러한 기능은 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내하는 것을 통해 앞서 본 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하는 데 기여하는 정도에 그칠 뿐 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심으로 파악할 수는 없다.

(바) 이 사건 실시제품도 경사면을 구비한 ‘격자형 박스’ 구성에 의해 ‘**절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도**’하고 있다.

(사) 따라서 이 사건 실시제품은 위와 같은 구성의 차이에도 불구하고 기술사상의 핵심에서 이 사건 제1항 발명과 같으므로 과제 해결원리가 동일하다.

(2) 작용효과의 동일 여부 (invention as a whole vs individual element)

이 사건 실시제품은 구성 7이 구성 7 대응구성으로 변경되었더라도 ‘**절단된 각각의 적층 김들이 포장용기 내에 정확히 위치하도록 사이를 벌려 놓아 수납공정까지 자동화**’한다는 점에서 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현할 수 있는 정도로 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다. 구성 6 대응구성이 가압절판을 안내하는 효과가 구성 6 가이드케이스 구성보다 떨어진다고 해도 이 사건 실시제품에서 구성 6이 결여되었다고 볼 정도는 아니고, 이로 인하여 이 사건 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하지 못한다고 볼 수는 없어 구성 6과 그 효과는 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다.

(3) 구성 변경의 용이성 여부 (individual element)

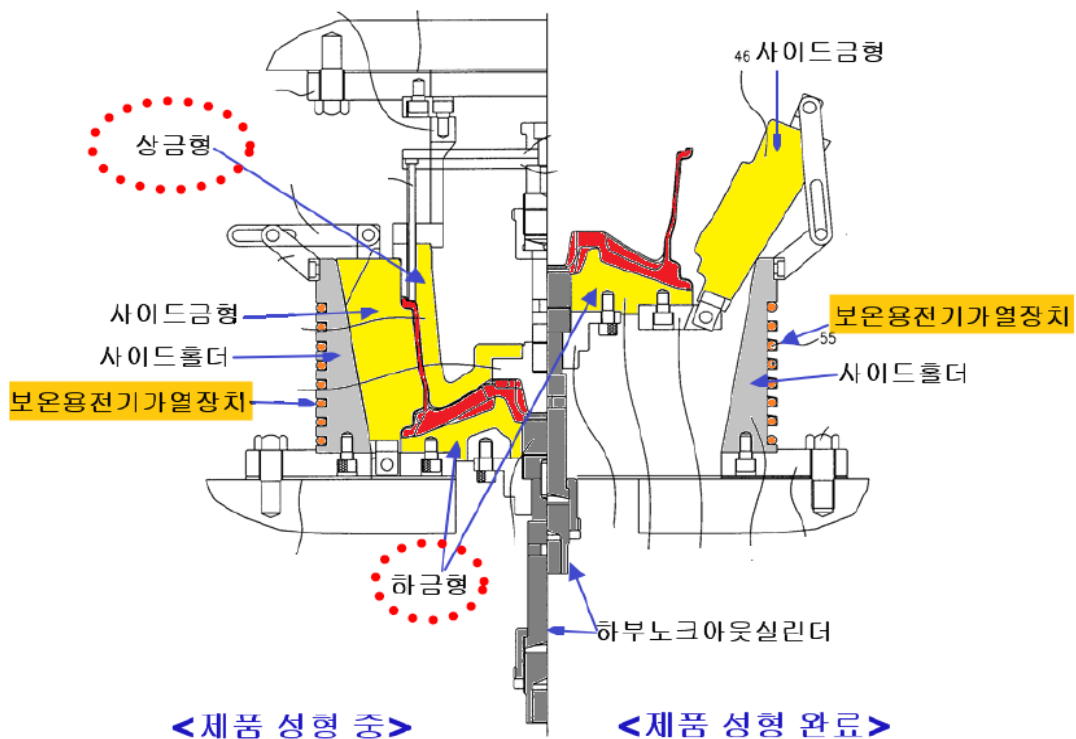
상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 이 사건 특허발명의 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하다. 따라서 구성 7을 구성 7 대응구성 과 같이 ‘격자형 절단날’이 ‘격자형 박스’와 분리되어 상하로 이동되도록 각 가압절판에 인접한 위쪽에 별도로 배치하는 구성으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다. 그리고 상자 형태의 구성 6을 그 중 두 면을 제거한 ‘회동푸셔와 스톱퍼’를 두고 그 위쪽에 ‘사각케이스 형상의 중공이 그 내측에 형성된 중간판’을 별도로 배치하는 구성 6 대응구성으로 변경하는 것도, 부품의 형태나 배치 관계 등을 고려하여 통상의 기술자가 별다른 기술적인 노력 없이 쉽게 생각해 낼 수 있을 것으로 볼 수 있다.

(4) 의식적 제외 여부

출원인이 출원 시에 균등 여부가 문제 되는 침해 제품 등의 구성을 용이하게 생각해 낼 수 있었음에도 그것을 청구범위에 기재하지 않은 경우라도, 그것만을 이유로 위 구성요소가 특허발명의 출원 절차에 있어서 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 존재한다고 할 수는 없다.

특허발명

(자동차 알루미늄 휠을 만들기 위해) 상금형과 하금형으로 용탕(붉은 색)을 가압하는 장치이다.



확인대상발명

침해제품도 위와 같은 가압 방식을 구현하는 기본적인 구성은 갖추고 있다. 다만 피고 제품은 '보온용 전기가열장치'를 갖는 사이드홀더 구성 대신, 사이드홀더(= 사이드 케이싱)의 외부에서 '가스 가열장치'를 이용하여 가압한다는 점에서 차이가 난다.

(1) 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 '직접 가압식 용탕 단조장치'라는 명칭의 발명이다.

(2) 회생채무자 주식회사 알로드가 실시하고 있는 원심 판시 피고 제품에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)의 '사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치(원심 판시 구성 5-5)'를 제외한 모든 구성들이 포함되어 있다.

(3) 피고 제품은 위 '보온용 전기 가열장치' 대신 사이드 케이싱 외부에 '가스 가열장치'를 두고 있다.

(4) 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 이 사건 제1항 발명과 관련하여, '본 발명의 직접 가압식 용탕 단조공정은 상부 금형이 하강하여 하부 금형에 주입된 용탕 전체 표면에 걸쳐 직접 강압, 예비성형 및 고압단조하고 재차 하부 금형에 의해 고압으로 가압함으로써 단순히 금형 온도에 크게 의존하는 종래 간접방식에 비해 단조효과가 월등히 우수할 뿐만 아니라, 응고에 따른 국부적인 체적변화에 대응하는 노크 아웃 실린더가 하부에 장착되어 고압으로 작동하기 때문에 그 단조효과를 더해 주며'라고 기재되어 있다.

(5) 그러나 위와 같이 발명의 상세한 설명에서 파악되는 '상·하부 양방향에서 가압하여 단조효과를 향상시킨다'는 기술사상은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시에 공지된 을 제7호증에 나타나 있다.

(6) 위 '상·하부 양방향에서 가압하여 단조효과를 향상시킨다'는 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 '보온용 전기 가열장치'와 피고 제품의 '가스 가열장치'의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다.

(7) 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 '보온용 전기 가열장치'와 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다. 원심의 이유 설시에 부적절한 점이 있으나, 피고 제품이 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 본 원심의 결론에 상고이유 주장과 같이 특허발명의 균등침해에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

	기술사상의 핵심이 공지되지 아니한 경우	기술사상의 핵심이 공지된 경우
본질적 구성의 차이가 있는 경우	2차 구이김 절단 및 수납장치 사건(2016마5698): 긍정 -선행기술과 비교하여 정해지는 특허발명의 실질적 가치를 기준으로 구성에서 과제해결원리가 어느 정도 상위개념화가 가능함 (균등범위가 넓어짐) -과제해결원리가 동일하다면, 이러한 해결원리를 구현하는지의 관점에서 효과가 동일한지를 판단하므로 제2요건도 만족되기 쉬움	경구 투여용 약제학적 제제(2022후10746): 부정 -과제해결원리가 청구범위의 구성에 근접한 것으로 파악되어야 함 (균등범위가 좁아짐)
비본질적 구성의 차이가 있는 경우	2차 구이김 절단 및 수납장치 사건(2016마5698): 긍정 -본질적 구성이 공통되므로 과제해결원리가 같음 -해결원리를 구현하는지의 관점에서 효과가 동일한지를 판단하므로 제2요건도 만족되기 쉬움	양방향 가압 장치 사건(2018다267252): 부정 LED 등기구 사건(2014후2788): 긍정 -본질적 구성이 공통되므로 과제해결원리가 같음 -그러나 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술 과제를 해결하였다고 할 수 없으므로 차이나는 구성의 기능이나 역할을 비교하여 양자의 작용효과가 동일하지 않다고 볼 수 있음

* 구민승, “특허 균등침해의 제1, 2요건”, 사법 48호, 사법발전재단, 2019 여름호, 97-99면

사실관계

- 원고(청[○]나이스)의 이 사건 특허발명의 명칭은 ‘자가세정 가능한 정수기’이다. 이 사건 특허발명의 출원인인 원고는, 자신이 원출원한 발명[출원일 2009. 2. 3., (출원번호 1 생략), 이하 ‘원출원 발명’이라 한다]의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 일부를 분할출원하고[출원일 2010. 10. 28., (출원번호 2 생략), 이하 ‘1세대 분할출원 발명’이라 한다], 1세대 분할출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 일부를 다시 분할출원하여[출원일 2011. 4. 4., (출원번호 3 생략)], 이 사건 특허발명으로 특허등록을 받았다.
- 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항에는 ‘여과부에서 여과된 물을 이용하여 저장탱크를 세정할 수 있도록 저장탱크에 연결되며, 세정수단을 구비하는 세정부’라는 사항이 적혀 있다(구성요소 3). 그 청구범위에 ‘세정수단’의 구체적인 기술적 구성은 적혀 있지 않다.
- 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는 ‘세정수단은 세정물질 또는 살균물질을 희석시켜 저장탱크에 공급할 수 있다. 세정수단에 유입된, 여과부에서 여과되는 물에, 세정수단에 포함된 세정물질 또는 살균물질이 희석된다. 세정물질 또는 살균물질이 희석된 여과된 물이, 저장탱크에 공급되면서, 저장탱크가 세정 또는 살균된다.’는 내용이 있다.
- 한편 원고는 원출원 발명의 출원 과정에서 2011. 1. 5. 지식재산처 심사관으로부터 ‘원출원 발명의 청구범위 제1항은 선행기술 문헌에 기재된 정수기 및 정수기 저수조 세척방법(이하 ‘비교대상 발명’이라 한다)과 실질적으로 동일하다. 원출원 제2항부터 제21항의 발명도 마찬가지이다. 원출원 발명은 특허를 받을 수 없다.’는 거절이유를 통지받았다.
- 그러자 원고는 2011. 3. 7. 지식재산처 심사관에게 ‘원출원 제1항 발명의 세정수단은 그 내부에 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있어, 세정, 살균을 위한 시간이 극히 짧고 별도의 전력이 소모되지 않는다. 반면 비교대상 발명은 살균물질을 미리 포함하지 않아, 세척을 위해서는 전기분해에 의하여 살균물질을 새롭게 생성해야 하는데, 전기분해에 많은 시간이 소요되고 전력도 소모된다. 이처럼 원출원 제1항 발명과 비교대상 발명은 구성과 효과에 차이가 있어, 실질적으로 동일하지 않다.’는 의견을 제출하였다. 그러면서 원고는 원출원 제1항 발명의 세정수단을 ‘세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고 있는 필터 또는 세정살균제 도징시스템을 포함하여 구성되는 세정수단’으로 한정하는 등으로 원출원 발명의 청구범위 등을 보정하였다.
- 원고는 위와 같이 원출원 발명을 보정한 이후인 2011. 4. 4. 이 사건 특허발명을 출원하여 특허로 등록받았다.
- 피고(코[○]이)는, 원고의 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제10항 발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허심판원에 원고를 상대로, 확인대상 발명이 제1항, 제10항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 확인대상발명의 설명서에는 ‘확인대상 발명은 여과된 물을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기를 포함한다. 전극 살균기는 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있지 않고, 물을 전기분해함으로써 전기분해수를 생성한다.’는 내용 등이 기재되어 있다. 확인대상 발명의 도면에는 전극 살균기 구성이 도示되어 있다.

구성요소	이 사건 제1항 발명	확인대상발명
1	물을 여과하기 위한 다수 개 필터를 구비하는 여과부(200)	선타본필터, RO멤브레인필터, 후카본필터를 순차적으로 포함하는 여과부
2	여과부(200)에서 여과된 물을 저장할 수 있도록 여과부(200)와 연결된 저장탱크(300)	여과부에서 여과된 물을 저장할 수 있도록 여과부와 연결된 정수탱크
3	여과부(200)에서 여과된 물을 이용하여 저장탱크(300)를 세정할 수 있도록 저장탱크(300)에 연결되고 세정부(400)를 구비하는 세정부(400)	여과부 필터 중 선타본필터만 통해 여과된 물을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기는 ‘여과부의 모든 필터를 통해서 여과된 물이 흐르는 유로’를 통해 정수탱크와 연결되며 전극 살균기에서 생성된 전기분해수는 위 유로와 정수탱크 살균
4	세정부(400)는 여과부(200)의 다수 개 필터 중 선타본필터(220)를 포함하여 구성되는 일부 필터만 통하여 여과된 물이 그 일부 필터 제외된 나머지 필터를 통과하지 않고 저장탱크(300)에 유입되도록 구성	전극 살균기에는 RO멤브레인필터 전단에 구비된 선타본필터만을 통해 여과된 물이 유입되고 전극 살균기를 통과한 물은 RO멤브레인필터와 후카본필터를 포함한 어느 한 필터도 통과하지 않고 정수탱크로 공급
5	세정수단(410)은 세정수단(410)에서 배출된 물이, 위 일부 필터 후단에 위치하며 RO멤브레인필터(230) 및 후카본필터(240)를 포함하여 구성되는 나머지 필터를 통과하지 않고 저장탱크(300)로 공급되도록 설치	
6	세정부(400)는 일부 필터만 통하여 여과된 물이 나머지 필터를 거치지 않고 저장탱크(300)로 유입되도록 유로를 전환하는 유로 전환밸브(420) 추가로 구비	선타본필터와 전극 살균기 사이 유로 및 선타본필터와 RO멤브레인필터 사이 유로 상에 제1 및 제2 개폐밸브 구비하여 선타본필터 통과한 물이 전극 살균기 또는 RO멤브레인필터로 유입되도록 조절

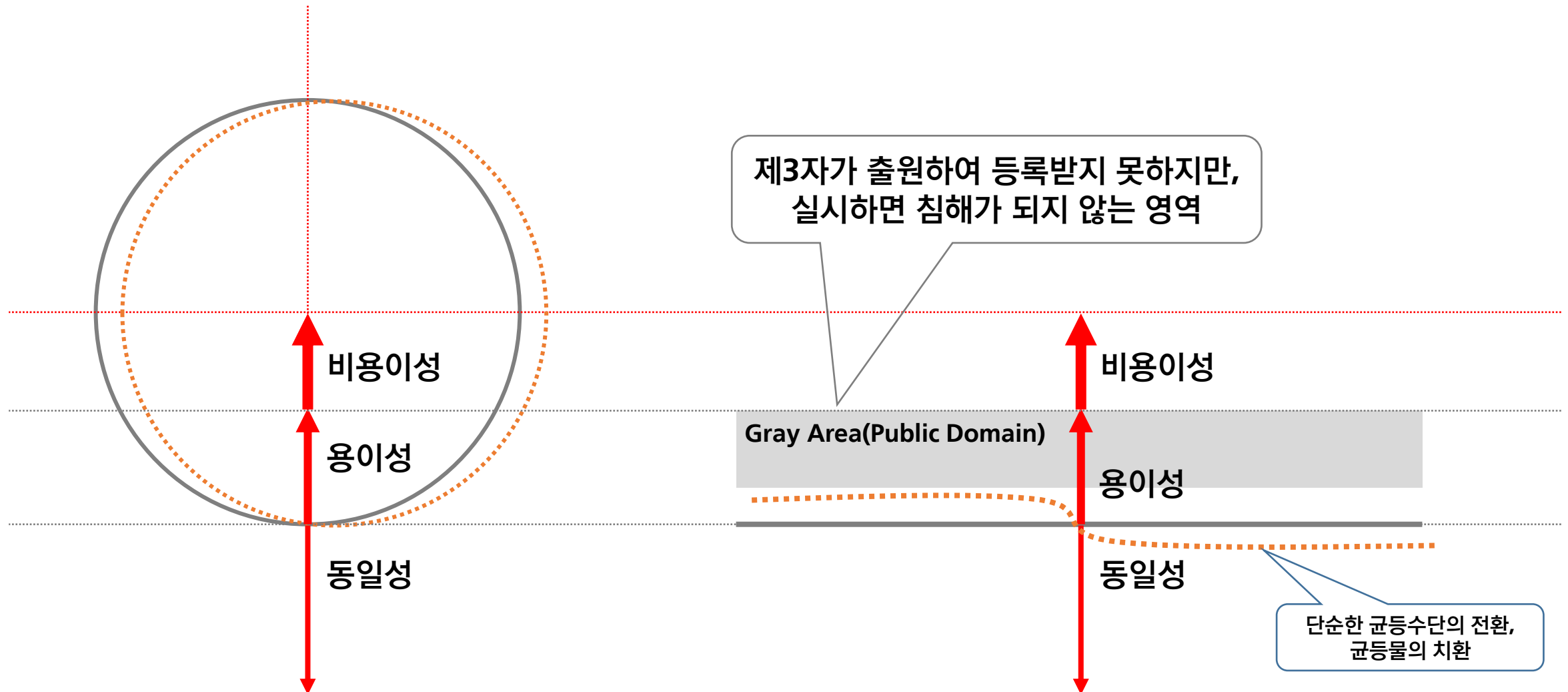
(청구범위의 제한해석) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다. 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.

- 1) 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 적혀 있는 ‘세정수단’이라는 용어는 ‘세정 기능을 하는 수단’이라는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없다.
- 2) 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는 ‘세정수단’에 대한 설명으로 ‘여과부에서 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석한 것을 가지고 저장탱크를 세정하는 수단’이라는 내용이 기재되어 있다. 그러나 이러한 내용 외에 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’에 관한 내용은 기재되어 있지 않고, ‘세정수단’의 구성을 구체적으로 개시하거나 시사하는 내용도 나타나 있지 않다.
- 3) 원고는 원출원 발명의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 원출원 제1항 발명의 ‘세정수단’에는 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출하였다. 원출원 발명과 이 사건 특허발명의 출원인은 모두 원고로 동일하다. 이 사건 특허발명은 원출원 발명을 기초로 하는 1세대 분할출원 발명으로부터 분할출원된 발명으로서 원출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있는 발명이다. 원고는 원출원 발명에 관한 위와 같은 의견제출 이후에 이 사건 특허발명을 출원하였다. 이러한 사정을 고려하면, 원출원 발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다. 이를 참작하면, 원고는 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’ 중 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’을 의식적으로 제외하였다고 보인다.
- 4) 따라서 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’은 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않고, 출원인인 원고가 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외한 부분에도 해당한다. 그러므로 그 ‘세정수단’을 문언 그대로 해석하는 것은 명백히 불합리하다.
- 5) 결국 출원된 기술사상의 내용, 발명에 관한 설명의 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하면, 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’은 ‘세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단’으로 해석하는 것이 타당하다. 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위가 이 사건 제1항 발명의 구성 중 ‘세정수단’을 구체적으로 한정된 종속항인 이 사건 제5항 발명 특허권이나 그 종속항인 이 사건 제6항 발명 특허권의 권리범위와 실질적으로 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.

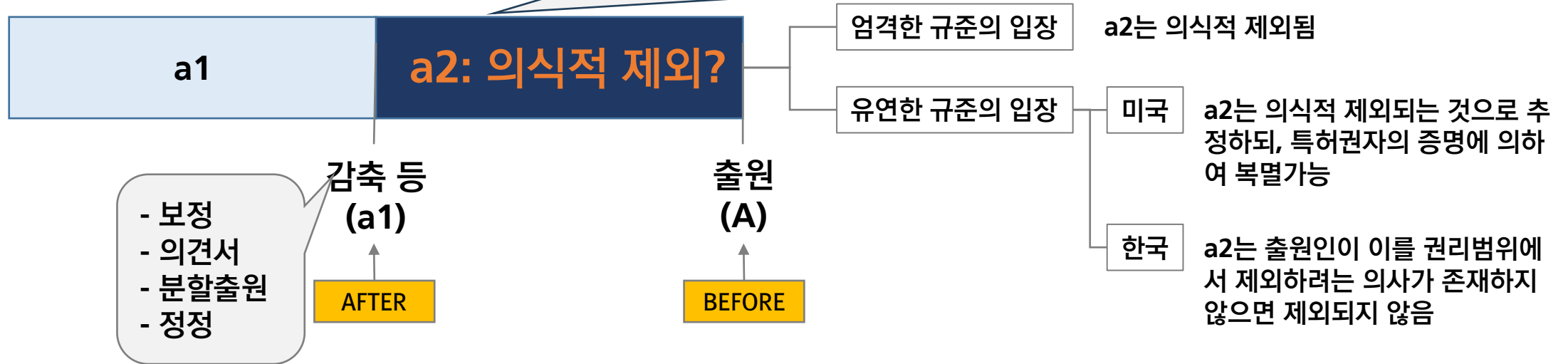
(균등론의 적용) 확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다

- 1) 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’은 ‘세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단’이다. 이에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소는 ‘여과부에서 여과된 물(선카본필터만 통과한 것)을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기로, 전극 살균기에서 생성된 전기분해수로 유로와 정수탱크를 살균하는 것’으로 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’과 차이가 있다.
- 2) 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에 따르면, 이 사건 제1항 발명이 해결하려는 과제는 정수기의 저장탱크를 정수기에서 분리할 필요 없이 자가 세정할 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해 이 사건 제1항 발명은, 자가 세정을 위해 정수기의 여과부에서 여과되는 물을 사용하되, 여과부에 구비된 다수 개의 필터 중 일부 필터만을 통과하여 여과된 물[알오(RO)멤브레인 필터 등은 통과하지 않는다]를 사용하고, 세정수단에 포함된 세정물질 또는 살균물질을 그와 같이 여과된 물에 희석시켜 저장탱크에 공급하는 해결수단을 채택하고 있다.
- 3) 그런데 이 사건 특허발명의 출원 당시 공지된 선행기술 문헌에는, 정수기의 여과부에서 여과되는 물을 활용하여 저수조를 자동으로 살균 또는 소독하는 기술, 정수기의 수조 등을 소독하기 위해 염소수나 살균수를 생성할 때 살균장치에 공급되는 물은 일부의 필터만을 거치고 나머지 필터는 거치지 않도록 하여 필터의 수명 단축을 방지하는 기술 등이 개시되어 있다.
- 4) 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명은 출원 당시 이미 공지된 ‘정수기의 여과부에서 여과되는 물을 정수기의 자가 세정에 사용하되, 여과부에 구비된 필터 중 일부 필터만을 통과하여 여과된 물을 사용한다.’는 기술사상에다가 세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하는 ‘세정수단’ 구성을 결합한 것이어서 선행기술과의 관계에서 기술발전에 기여한 정도가 크다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다.
- 5) 그런데 확인대상 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물로 전극 살균기를 통해 전기분해수를 생성하여 정수탱크를 자가 세정하는 반면, 이 사건 제1항 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석하여 저장탱크를 자가 세정하므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.
- 6) 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제10항 발명 특허권의 권리범위에도 속하지 않는다.

균등론의 변경용이성 vs 진보성의 용이성



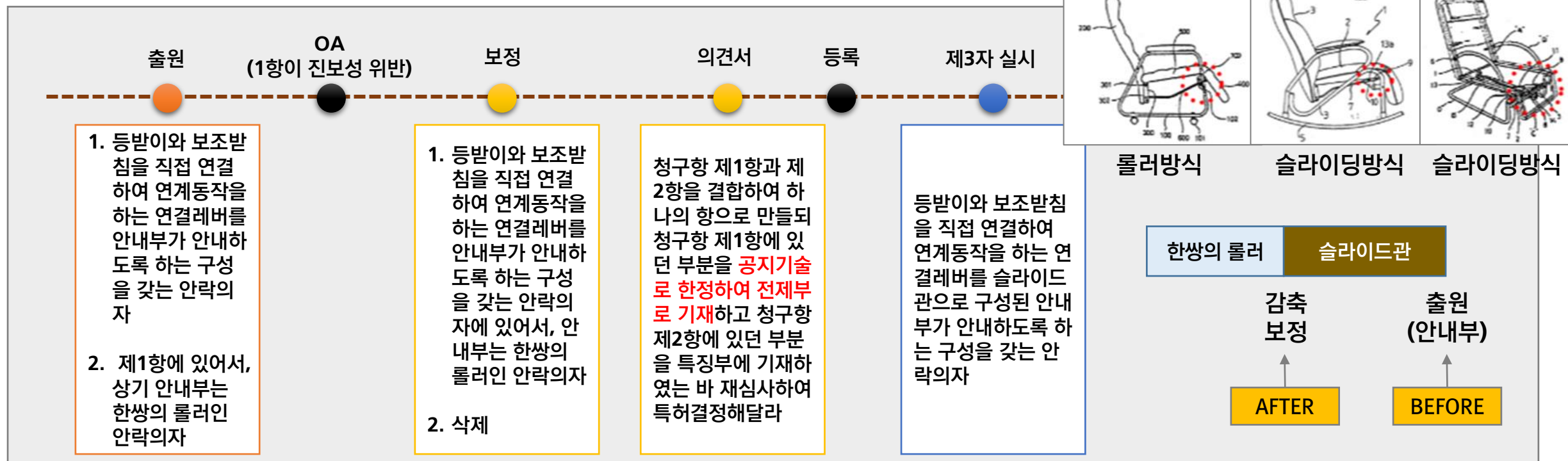
청구범위의 변경인 경우 변경 전 권리범위에 대해서 금반언의 적용이 비교적 명확하나, 청구범위의 감축인 경우 변경 전 권리범위에 대해서 금반언이 적용되는지 문제임



구분	엄격한 기준의 입장	유연한 기준의 입장(미국)	유연한 기준의 입장(한국)
의식적 제외 여부	a2는 의식적 제외○	a2는 의식적 제외○ (단, 특허권자가 추정 복멸)	a2는 의식적 제외×

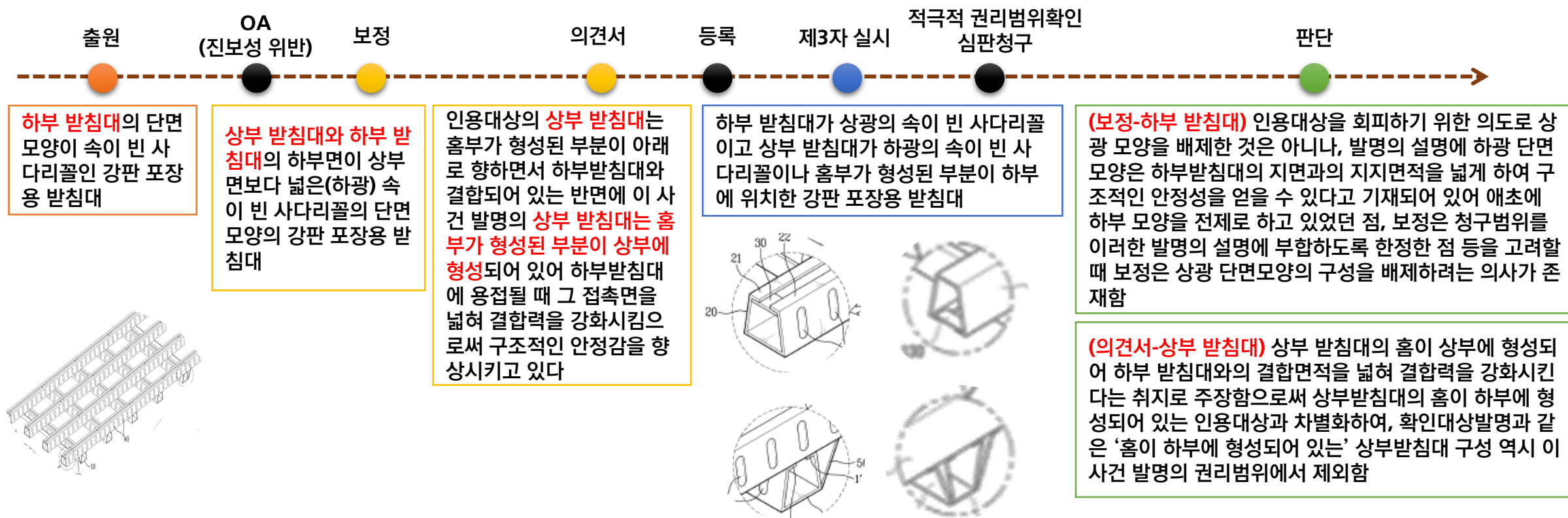
대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결【권리범위확인(실)】: 안락의자 사건

지식재산처 심사관으로부터 실용신안공고 제95-4971호 고안 등에 의하여 통상의 기술자가 극히 용이하게 고안할 수 있다는 이유로 거절이유통지를 받고, 1998. 7. 22. 의견서 및 보정서를 제출하면서 **인용발명에 저촉되는 부분을 공지의 기술로 하여 청구범위를 대폭 축소 한정한다고 주장함**과 아울러 청구항 제1항과 제2항을 결합하여 하나의 항으로 만들되 청구항 제1항에 있던 부분을 전제부로 기재하고 청구항 제2항에 있던 부분을 특징부에 기재하였는바, **그렇다면 출원인 스스로 전제부의 기재사항인 「등받이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 안내부가 안내하도록 하는 구성」을 공지의 기술로 한정한 것이라 하겠고, 나아가 다시 특징부에서 위 안내부를 「한 쌍의 롤러」로 한정한 것은 출원인이 이와 균등관계에 있는 구성에 대해서는 그 권리범위를 주장하지 않겠다는 취지로 볼 것이므로, 결국 출원경과금반언의 원칙상 등받이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 안내부가 안내하도록 함에 있어서, 그 안내부를 {확인대상 고안과 같은} 슬라이드관으로 구성하는 것은 이 사건 등록고안의 출원인이 의식적으로 그 보호범위로부터 제외한 것으로 봄이 상당하여, 확인대상 고안의 슬라이드관은 이 사건 등록고안 제1항의 롤러의 균등론이 될 수 없다.**



대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 【권리범위확인(특)】 강판 포장용 받침대 사건

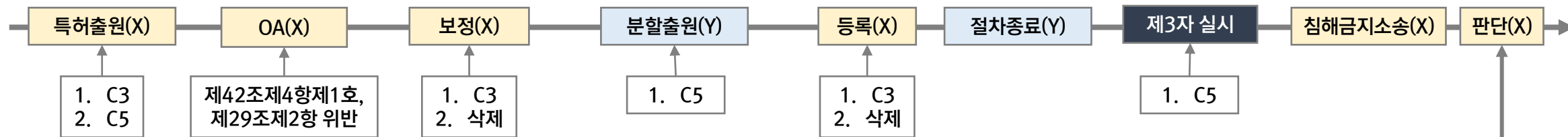
특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 지식재산처 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조). 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.



대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결 【특허권침해금지】

원출원 CASE

특허출원인이 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 이 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외한 것이라고 보아야 한다.

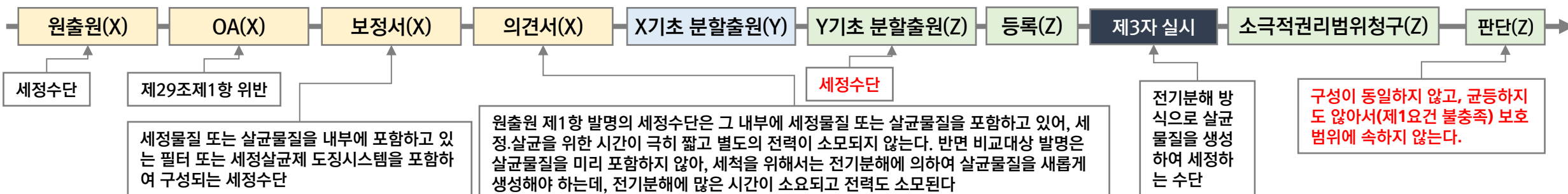


이 사건 특허발명(특허번호 제361255호)에 대한 출원과정에서 지식재산처 심사관의 거절이유통지의 내용, 원고의 이에 대응한 보정서와 의견서의 내용, 원고가 이 사건 출원발명으로부터 이 사건 화합물을 제외한 나머지 화합물에 대한 부분을 분할출원을 한 경우 등을 참작하면, 원고는 심사관으로부터 거절이유통지를 받고서 선행기술을 회피하고 명세서 기재요건을 충족시키기 위하여 이 사건 출원발명의 화합물을 이 사건 화합물로 감축보정하면서 이 (C3)를 제외한 나머지 화합물(C5)들을 별개의 발명으로 분할출원함으로써 이들을 이 사건 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 봄이 상당하므로, 위 분할출원된 화합물에 속하는 피고의 오르토-크레졸프탈레인 헥사노일 에스테르(C5)는 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다.

대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결 【권리범위확인(특)】

분할출원 CASE

원고는 원출원 발명의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 원출원 제1항 발명의 '세정수단'에는 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출하였다. 원출원 발명과 이 사건 특허발명의 출원인은 모두 원고로 동일하다. 이 사건 특허발명은 원출원 발명을 기초로 하는 1세대 분할출원 발명으로부터 분할출원된 발명으로서 원출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있는 발명이다. 원고는 원출원 발명에 관한 위와 같은 의견제출 이후에 이 사건 특허발명을 출원하였다. 이러한 사정을 고려하면, 원출원 발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다. 이를 참작하면, 원고는 이 사건 제1항 발명의 '세정수단' 중 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'을 의식적으로 제외하였다고 보인다.



청구항의 구성요소(elements of claim)는 청구항을 복수개의 구성요소(element)로 나누어 청구항을 해석하기 위한 기술적 용어(technical term)이다. 이 때 구성요소 단위를 작게 보는 경우 구성요소의 생략이지만 구성요소 단위를 크게 보는 경우 구성요소의 생략이 아닌 치환으로 평가할 수 있는 경우도 있기 때문에 어느 정도 기능을 수행하는 단위를 구성요소로 볼 것인지는 중요한 문제이다. 보통 실무적으로는 청구항의 문구를 임의적으로 한 단위씩 끊어 하나의 구성요소로 보고 있으나 각 구성요소의 단위는 발명 전체의 작용효과에 기여하기 위해 독자적인 기능을 보유할 정도는 되어야 할 것이다.

- 청구항
 - a, b, c로 된 X
 - d, e, f로 된 Y
 를 포함하는 것을 특징으로 하는 자전거

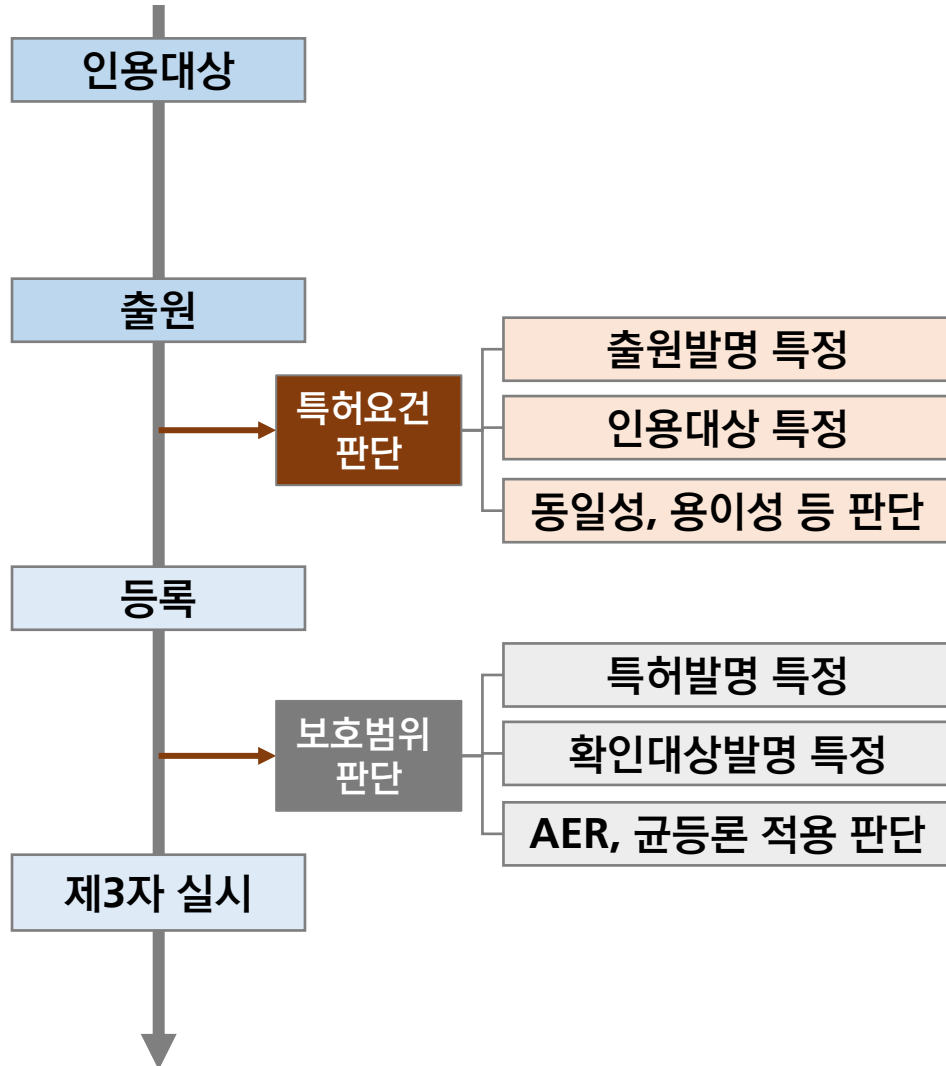
- 제3자의 실시발명
 - a, b, c로 된 X
 - d, e로 된 Y
 를 포함하는 것을 특징으로 하는 자전거

X, Y를 구성요소로 보는 경우

특허발명 구성요소	확인대상발명	판단(○/×/△)
abc로 된 X	abc로 된 X	○
def로 된 Y	de로 된 Y	△
종합 의견	AER이 적용되지 않으나, 구성요소의 치환으로 균등론이 적용될 여지가 존재함	

a, b, c, d, e를 구성요소로 보는 경우

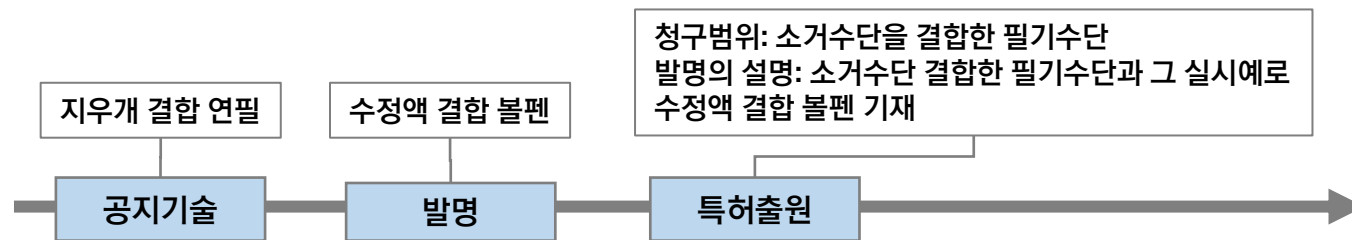
특허발명 구성요소	확인대상발명	판단(○/×/△)
a	a	○
b	b	○
c	c	○
d	d	○
e	e	○
f	-	X
종합 의견	구성요소의 삭제이므로 AER, 균등론이 적용될 여지가 없음	



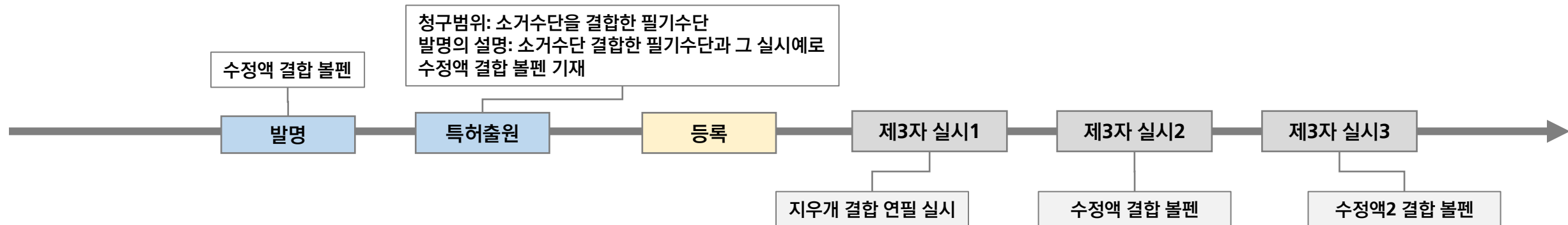
출원인의 입장만 고려: 출원인의 표시한 의사를 심사관이 임의로 변경하는 것은 타당하지 않음

특별사정
출원인의 입장뿐만 아니라 제3자의 입장 고려: 보호할 가치가 없는 사항이나 진실로 발명하지 아니한 부분까지 그 권리를 인정하는 것은 곤란

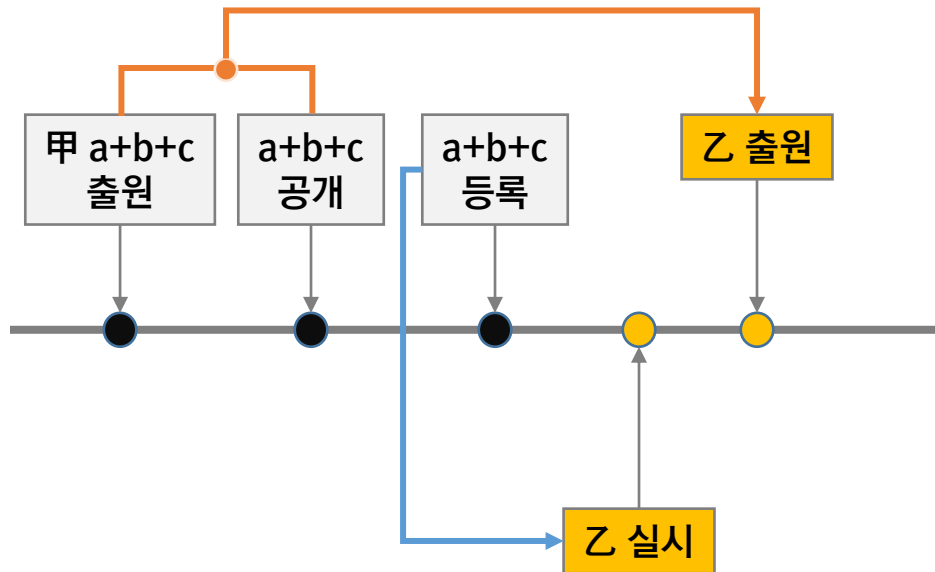
발명의 특정	특허요건 판단	보호범위 판단
청구범위 중심의 원칙	적용	적용
발명의 설명 참작의 원칙	적용	적용 (제한해석 가능)
공지기술 참작의 원칙	부적용 (발명의 특정 후 신규성, 진보성 등 판단으로 같음)	적용 (제한해석)
출원경과 참작의 원칙	부적용 (다만, 출원인이 공지되었음을 자인하는 경우 공지된 것으로 추정)	적용 (제한해석)
특허권하자 참작의 원칙	부적용 (발명의 특정 후 특허요건 판단으로 같음)	적용 (제한해석) 특별사정



구 분	1 발명특정	2 비교대상특정	3 판단
특허요건 판단	소거수단 결합 한 필기수단	지우개 결합 연필	발명이 상위개념이기 때문 에 신규성 위반*

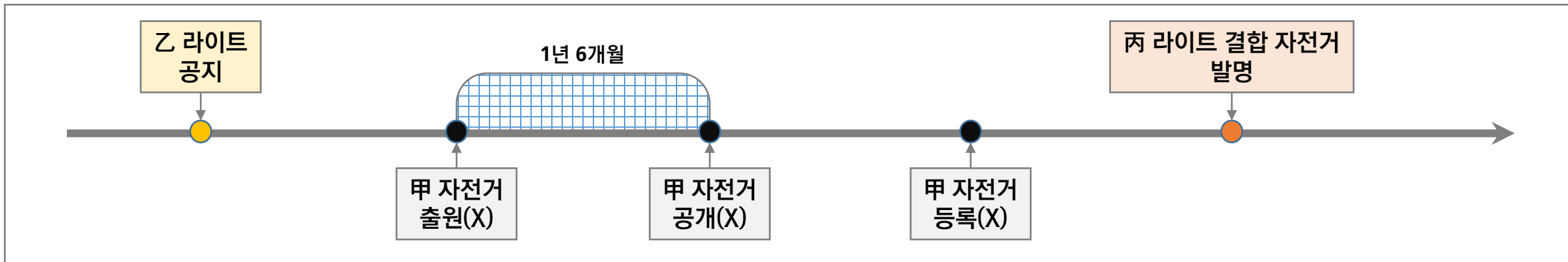


구 분	1 발명특정	2 비교대상특정	3 판단
보호범위 판단	수정액 결합한 볼펜	지우개 결합 연필	AER, 균등론 의하여 비침해
		수정액 결합 볼펜	AER에 의한 침해
		수정액2 결합 볼펜	균등론에 의한 침해△



구 분		특허발명 (甲 발명)	인용대상 (乙 발명)	乙 실시	乙 출원
AER	부가 법칙	a+b+c	a+b+c	침해	동일성이 있어 등록불가 (法 29① · 36 위반)
			a+b+c+d	침해	진보성이 있는 경우 등록가능 (등록된 경우 이를 이용관계라 함)
	생략 법칙	a+b+c	a+b	1. 원칙 → 비침해 2. 예외 → 간접침해	동일성이 있어 등록불가 (法 29① · 36 위반)
균등론		a+b+c	a+b+c'	1. 침해 (1) 과제해결원리동일○ (2) 변경가능성○ (3) 변경용이성○ (4) 특별사정 × 2. 그렇지 아니하면 비침해	1. 구성의 차이가 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경에 불과하고 새 로운 효과도 발생하지 아니한 경 우라면(선출원주의에서는 그 차 이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용 효 과에 특별한 차이를 일으키지 아 니하는 경우라면) 실질적 동일성 이 있어 등록불가(法 29① · 36 위반) 2. 구성의 곤란성이 없고 효과의 현 저성이 없어서 용이하다면 진보 성 위반으로 등록불가 3. 그렇지 아니하면 등록가능

- 개량발명은 특허등록을 받을 수 있으나, 실시하면 원천발명에 대한 특허의 침해가 된다. 즉, 나의 특허가 있다고 하더라도 나의 사업이나 제품을 보호할 수 있는 것은 아니다.
- 과연 丙의 출원은 잘한 것일까?



- 丙의 라이트 결합한 자전거의 출원은 특허등록을 받을 수 있는가?
- 丙이 라이트 결합한 자전거를 판매하는 것은 甲의 특허권의 침해인가?
- 丙이 자전거를 판매하는 것은 甲의 특허권의 침해인가?
- 甲이 라이트 결합한 자전거를 판매하는 것은 丙의 특허권의 침해인가?
- 甲이 자전거를 판매하는 것은 丙의 특허권의 침해인가?

구성요소	선행 기술1	선행 기술2	분석
라이트	O	X	O
결합	O/X		
자전거	X	O	O
소결	신규성 있음, 진보성 논란*		

카테고리	학 설	유 형		인정여부	
				통설	판례
동일 카테고리	그대로설	사상상의 이용	외적부가 (결합발명)	○	90'초: × 2000'초 :○
			내적부가 (선택발명)	○	90'초: × 최근 : ?
다른 카테고리	실시불가피설	실시상의 이용		○	?

甲이 A+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중이고, 乙이 A+B+C+D로 구성된 발명을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부(촉매부가발명 判例)

선출원여부	후출원의 등록가능성	후출원의 실시가 선출원의 침해인지 여부
甲 > 乙	1. 甲의 공개 전 → 등록가능 2. 甲의 공개 후 → A+B+C로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 法 29② 위반*	1. 乙의 실시는 甲의 특허권의 침해** 2. 정당한 권원획득 후 실시 ① 허락 ② 통상실시권허락심판(乙이 등록된 경우) (甲으로부터 A+B+C를 구매한 후 D를 부가하여 실시하는 것도 가능)
甲 < 乙	1. 乙의 공개 전 → 法 29③④, 36 위반 2. 乙의 공개 후 → 法 29①, 36 위반	1. 甲의 실시는 AER에 의하여 乙의 특허권의 직접침해 × 2. 단, 乙의 특허권의 간접침해일 수는 있음
甲 = 乙	실질적 동일성이 없는 경우 양자 모두 등록가능	양자 모두 등록된 경우 자유롭게 실시(∴ 法 제98조의 “특허출원일 전”의 해석결과 동일자 출원의 부적용)

* 결합발명은 선행발명에 구성요소를 더 부가한 것으로 일반적으로 선행발명과 동일성이 없기 때문에 신규성은 인정되나, 진보성에 위반되는지 여부가 문제이다. 결합발명의 진보성을 판단과 관련하여, 청구항에 기재된 발명은 전체로서 고려되어야 하며 구성요소 각각이 공지 또는 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정할 수 없다. 즉, 청구항에 기재된 발명의 과제해결원리를 배제한 채 청구항에 기재된 구성을 하나하나 분해한 후 선행기술의 대응 구성요소로부터 도출이 곤란한지만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제해결원리에 기초하여 그 발명에 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 진보성을 살펴봐야 한다(대법원 2010. 9. 9. 선고 2009후1897)

결합발명은 진보성 여부에 따라 공지기술의 단순한 집합인 「주합발명(Aggregation)」과 공지기술의 새로운 결합인 「조합발명(Combination)」으로 구별될 수 있다. 주합발명(Aggregation)은 조합발명(Combination)과 달리 진보성이 없어서 등록될 수 없다는 점에서 차이가 있다. 구체적으로, 여러 공지기술을 인용하여 특허의 진보성을 판단할 때 그 인용되는 공지기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 교시(teaching), 암시(suggesting), 동기(motivation) 등이 공지기술에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 특허 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 조합 또는 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 주합발명으로서 진보성이 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277; 2009. 7. 9. 선고 2008후3377 참조).

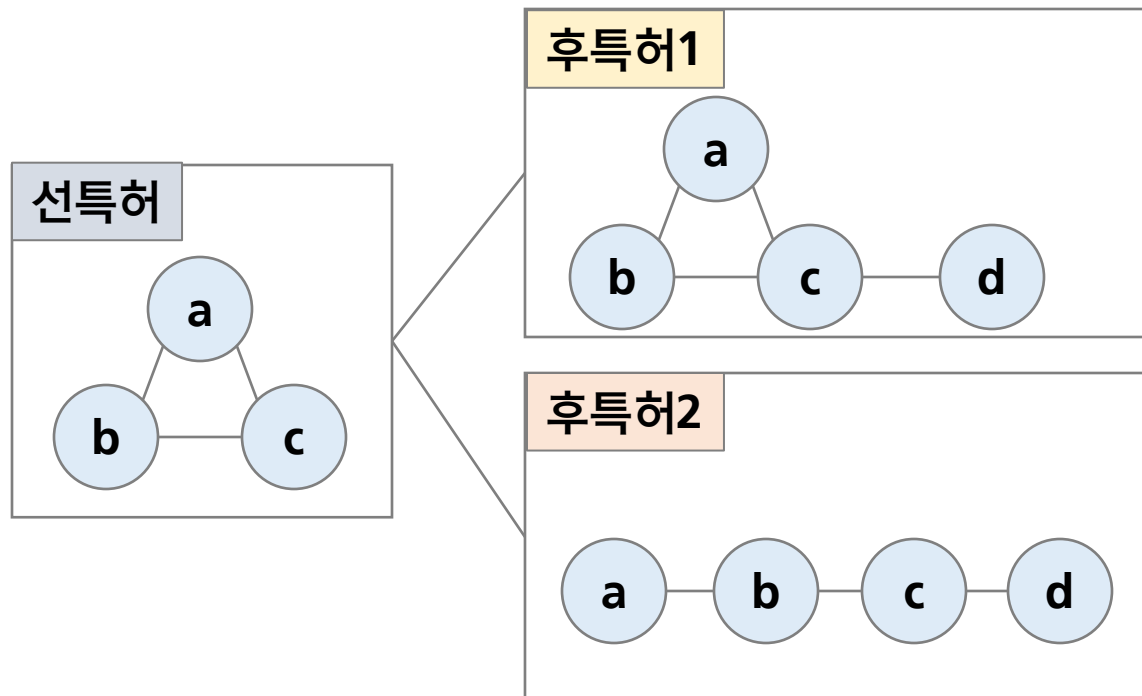
** 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결

[1] 선 등록고안과 후 고안 사이의 이용관계의 성립요건 및 등록고안의 균등고안을 이용하는 경우에도 이용관계가 성립하는지 여부(적극): 선 등록고안과 후 고안이 이용관계에 있는 경우에는 후 고안은 선 등록고안의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 고안이 선 등록고안의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 고안이 선 등록고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 고안 내에 선 등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 선 등록고안과 동일한 고안뿐만 아니라 균등한 고안을 이용하는 경우도 마찬가지이다.

▶ 1) 이용발명은 권리범위에 속한다는 점, 2) 그대로설을 지지한다는 점, 3) 일체성이 유지되어야 한다는 점, 4) 균등물을 이용하는 경우에도 이용관계를 긍정한다는 점을 판시하고 있다.

[2] 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승이 있는 경우에도 이용발명에 해당하는지 여부(적극): 화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다.

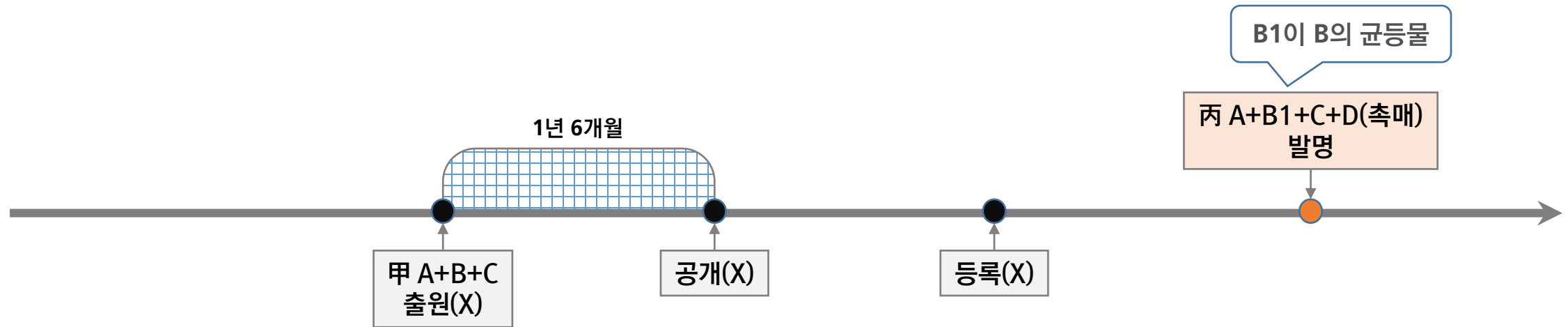
▶ 종래의 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결에서는 “선행발명과 후발명이 이용관계에 있다고 인정되는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되는 것이라 할 것인데 이러한 이용관계는 기계, 장치 등에 관한 발명의 경우에 있어서는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다 할 것이나, 방법의 발명, 특히 화학물질의 제법에 관한 발명에 있어서는 기계, 장치 등의 발명과 달라서 중간물질이나 촉매 등 어느 물질의 부가가 상호의 반응을 주목적으로 하는 경우가 많아 과정의 일시점을 잡아 선행방법에서 사용하는 물질이 상호반응 후에도 그대로의 형태로 존재하는 것을 증명하기가 극히 곤란하여 기계, 장치 등에 관한 발명에 적용될 위 법리를 제법발명에 적용할 수는 없다 할 것이고, 특히 화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리 하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 반응물질, 생성물질이 같다고 하더라도 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 후발명이 선행발명을 이용하고 있다고 볼 수 없고, 따라서 후발명은 선행발명의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이다.”고 하여 촉매의 부가로 인해 작용효과상의 우월성이 있다면 후출원 특허발명이 선행발명을 이용하지 않는다고 판시하였다. 그러나 이는 특허요건의 판단과 침해여부판단을 혼동하는 것으로서 현저한 효과로 인해 진보성(法 29②)에 위반되지 않아 등록되더라도 일체성을 상실하지 않았다면 침해, 즉 이용발명으로 봄이 타당하고, 본 판결에서는 이를 바로 잡고 있다.



1. 후특허 1은 d를 부가하면서 선택어 a, b, c의 결합관계(즉, 선택어와의 구성요소의 일체성)를 유지하였다. 따라서 구성요소완비의 원칙에 의하여 후특허 1을 실시하는 것은 선택어의 침해가 되고, 이를 이용발명이라 한다.
2. 후특허 2는 d를 부가하면서 선택어 a, b, c의 결합관계(즉, 선택어와의 구성요소의 일체성)를 상실하였다. 따라서 구성요소완비의 원칙이 적용되지 아니하여 후특허 2를 실시하는 것은 선택어의 침해가 아니며, 이를 이용발명이라 하지 아니한다.

대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결

일체성을 상실한 경우 이용관계가 아니기 때문에 후 출원에 의하여 특허 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다는 사례: 제30항 발명은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대 등의 효과를 위하여 선재를 한 방향으로만 형성한 것인 데 비하여, 확인대상발명은 하나의 석쇠틀에서 가로, 세로 방향으로 선재가 교차되는 양방향 구성을 채택하고 있었다. 심결과 원심은 이용관계에 있다고 판단하여 일단 본안판단으로 나아간 후 막상 권리범위 속부 실체 판단에서는 확인대상발명의 구성이 제30항 발명의 권리범위에서 의식적 제외된 구성이라고 보아 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 그러나 대법원은, 이용관계 해당 여부에 관한 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결의 판단기준을 인용한 다음, 하나의 석쇠틀에서 가로, 세로 방향으로 선재가 교차되는 확인대상발명의 양방향 구성은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대와 같은 한 방향 구성의 효과를 나타낼 수 없어 제30항 발명과 상이한 구성이라고 할 것이고, 확인대상발명 내에서 제30항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수도 없어 두 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 권리범위확인심판 청구는 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다고 판시하였다.



- 丙의 A+B1+C+D의 출원은 특허등록을 받을 수 있는가?
- 丙이 A+B1+C+D를 판매하는 것은 甲의 특허권의 침해인가?

甲이 A+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중이고, 乙이 a1(A의 하위구성요소)+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부(선택발명 判例)

선출원여부	후출원의 등록가능성	후출원의 실시가 선출원의 침해인지 여부
甲 > 乙	1. 甲의 공개 전 → 등록가능 2. 甲의 공개 후 → A+B+C로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 法 29② 위반*	1. 乙의 실시는 甲의 특허권의 침해로 보는 것이 타당 2. 단, 판례는 현저한 효과가 있어 등록된 경우 침해가 아니라고 판시**
甲 < 乙	1. 乙의 공개 전 → 法 29③④, 36 위반 2. 乙의 공개 후 → 法 29①, 36 위반	1. 甲이 a1+b+c를 실시하는 경우 침해 2. 그렇지 않으면 비침해
甲 = 乙	실질적 동일성이 없는 경우 양자 모두 등록가능	양자 모두 등록된 경우 자유롭게 실시(∵ 法 제98조의 “특허출원일 전”의 해석결과 동일자 출원 부적용)

* 먼저 신규성에 위반되지 않기 위해서는, 선행발명이 선택발명을 구성하는 그 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있어야 하고, 「개시」에는 선행발명을 적은 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736; 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 등).

다음으로 진보성에 위반되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 공지된 상위개념인 선행발명과 비교하여 구성의 곤란성이 인정되어야 한다. 구성의 곤란성이 인정되는지 여부와 관련해서는 i) 상위개념의 크기, ii) 선행발명이 선택발명을 선택할 동기를 제공하거나 선행발명에 암시가 있는지 여부, iii) 선행발명에 기재된 하위개념발명과 선택발명이 구조적으로 유사한지 여부 등이 고려되어야 한다. 예를 들어, 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 **선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 다만, 구성의 곤란성을 따져 보지 않고 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단해서는 안 된다**(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609).

* 선택발명의 진보성을 판단할 때에는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의학 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. **나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609).**

하나의 청구항에 여러 개의 하위개념을 포함하는 선택발명이 있는 경우 효과의 현저성이 인정되기 위해서는 선택발명에 포함되는 **하위개념들 모두가** 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다. 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명과 비교하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 **그 중 일부라도 선행발명과 비교하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면** 충분하다(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424).

선택발명에 포함되는 **하위개념의 실시형태 중 가장 열등한 것의 효과가 선행발명에 개시된 실시형태 중 가장 우수한 것의 효과와 비교하여** 현저하다는 관계가 인정되지 않는다면, 선택발명에 포함되는 하위개념의 실시형태 중 일부의 효과가 선행발명에 개시된 실시형태 중 일부의 효과보다 뛰어나 보인다고 하여 선택발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 볼 수는 없다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2013후1887).

**** 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960 판결**

선택침해 부정 사례: 확인대상발명의 출발물질에 작용하는 아실화제가 특허발명의 청구범위에 기재된 아실화제의 반응성유도체의 하나라 하더라도 **확인대상발명이 특허발명에 비하여 아실화수율 등에 있어서 현저히 향상된 작용효과가 있어 확인대상발명이 특허발명과 다른 발명이다.**

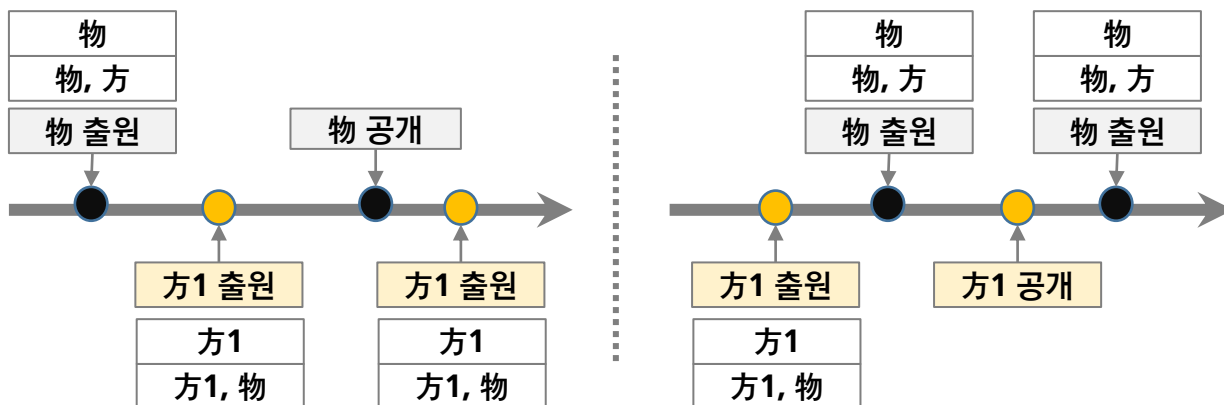
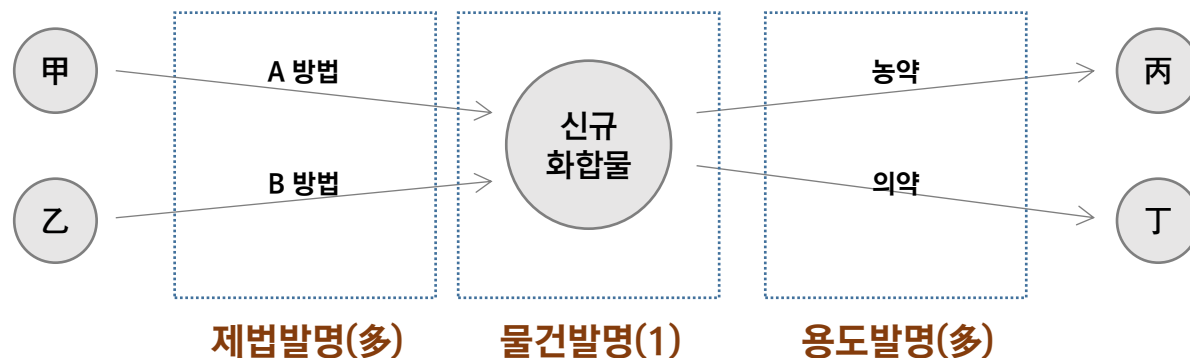
▶ 다만, 특허요건판단과 침해판단은 별개의 문제로서, 기술적 구성의 일체성이 상실되지 않았다면 침해로 보는 것이 타당하다.

甲이 물건발명(物)을 출원 후 실시중이고, 乙이 물건을 제조하는 방법(方1)을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부

선출원여부	후출원의 등록가능성	후출원의 실시가 선출원의 침해인지 여부
甲 > 乙	1. 物의 최·명·도에 기재된 方이 方1인 경우 ① 物의 공개 전 출원 → 法29③ 위반 ② 物의 공개 후 출원 → 法 29① 위반 2. 物의 최·명·도에 기재된 方이 方1이 아닌 경우 ① 物의 공개 전 출원 → 등록가능 ② 物의 공개 후 출원 → 物의 최·명·도에 기재된 方으로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 法 29② 위반	1. 方1의 실시는 物의 침해 ○(∵ 法 제2조제3호가목의 실시의 유형 - 물건생산을 청약하는 행위는 제외) 2. 정당한 권원획득 후 실시 ① 허락 ② 통상실시권허락심판(乙이 등록된 경우)
甲 < 乙	1. 方1의 공개 전 출원 → 法 29③④, 36 위반 2. 方1의 공개 후 출원 → 法 29①, 36 위반	1. 物의 실시가 方1의 실시에 의한 경우 - 方1의 침해 ○ 2. 物의 실시가 方1의 실시가 아닌 경우 ① 方1의 침해 × ② 단, 方1의 출원전 物이 공지되지 않았다면 方1의 실시에 의하여 物을 생산한 것으로 추정(法 129)
甲 = 乙	실질적 동일성이 없는 경우 양자 모두 등록가능	양자 모두 등록된 경우 자유롭게 실시(∵ 法 제98조의 “특허출원일 전”의 해석결과 동일자 출원의 부적용)

물건발명(物) : 제법발명(方) = 1 : 多

물건발명이 신규성 또는 진보성이 있는 경우 제법발명 또는 용도발명은 당연히 신규성 또는 진보성이 있다. 반면 물건발명이 신규성 또는 진보성이 없는 경우 제법발명 또는 용도발명은 개별적으로 신규성 또는 진보성 여부를 판단하여야 한다.



실시 : 물건발명(物) ⊃ 제법발명(方)

물 실시

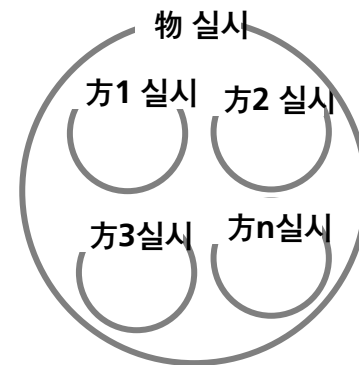
그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

方 실시

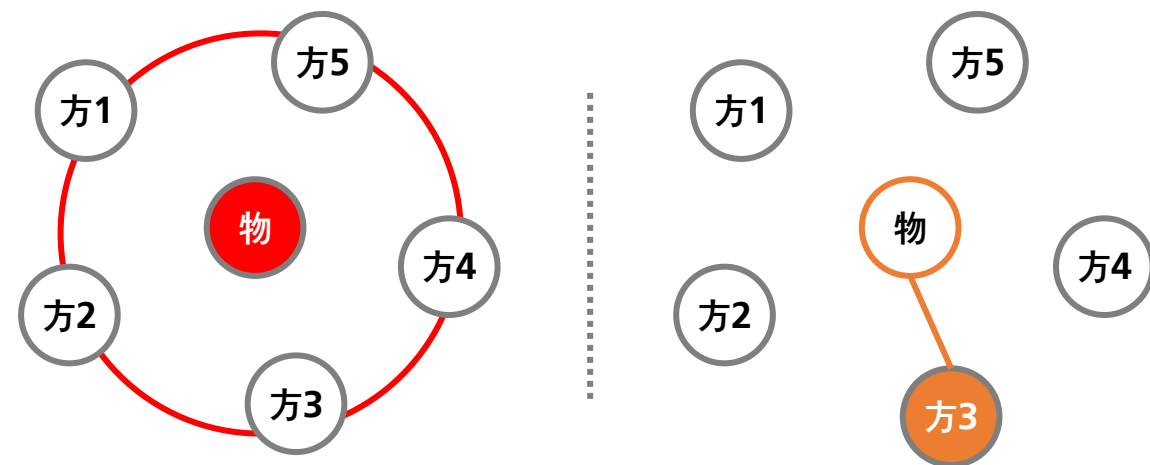
그 방법을 사용하는 행위(물건의 생산)

그 방법의 사용을 청약하는 행위
(물건생산의 청약)*

그 방법에 의하여 생산한 물건을
사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그
물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위



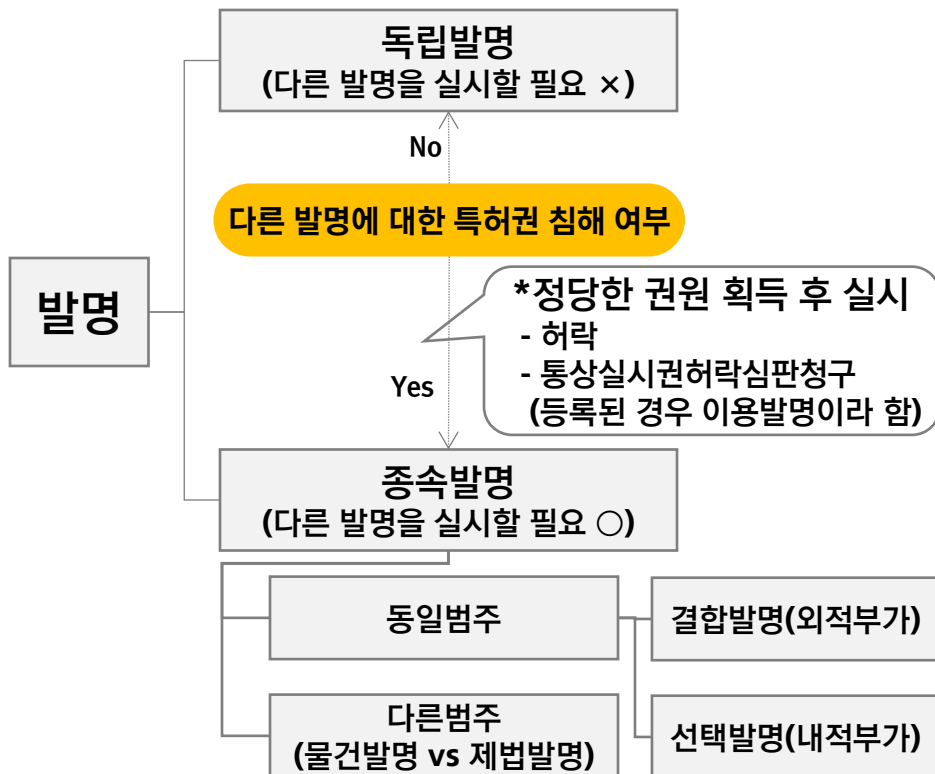
특허권의 효력 : 물건발명(物) ⊃ 제법발명(方)



* 물건생산의 청약은 물건발명의 실시(물건발명에 대한 특허권 침해)에 해당하지 않음

종속발명에 대한 특허권자는 독립발명에 대한 특허권자와는 달리 선행발명에 대한 특허권의 침해가 되지 않으려면 원칙적으로 선행발명에 대한 특허권자의 허락을 받거나(法 98), 통상실시권허락심판(法 138)을 청구하여 정당한 권원을 획득하여야 한다. 다만, 통상실시권허락심판(法 138)의 청구는 종속발명이 특허등록되어 이 용관계가 성립되는 경우에만 가능하다.

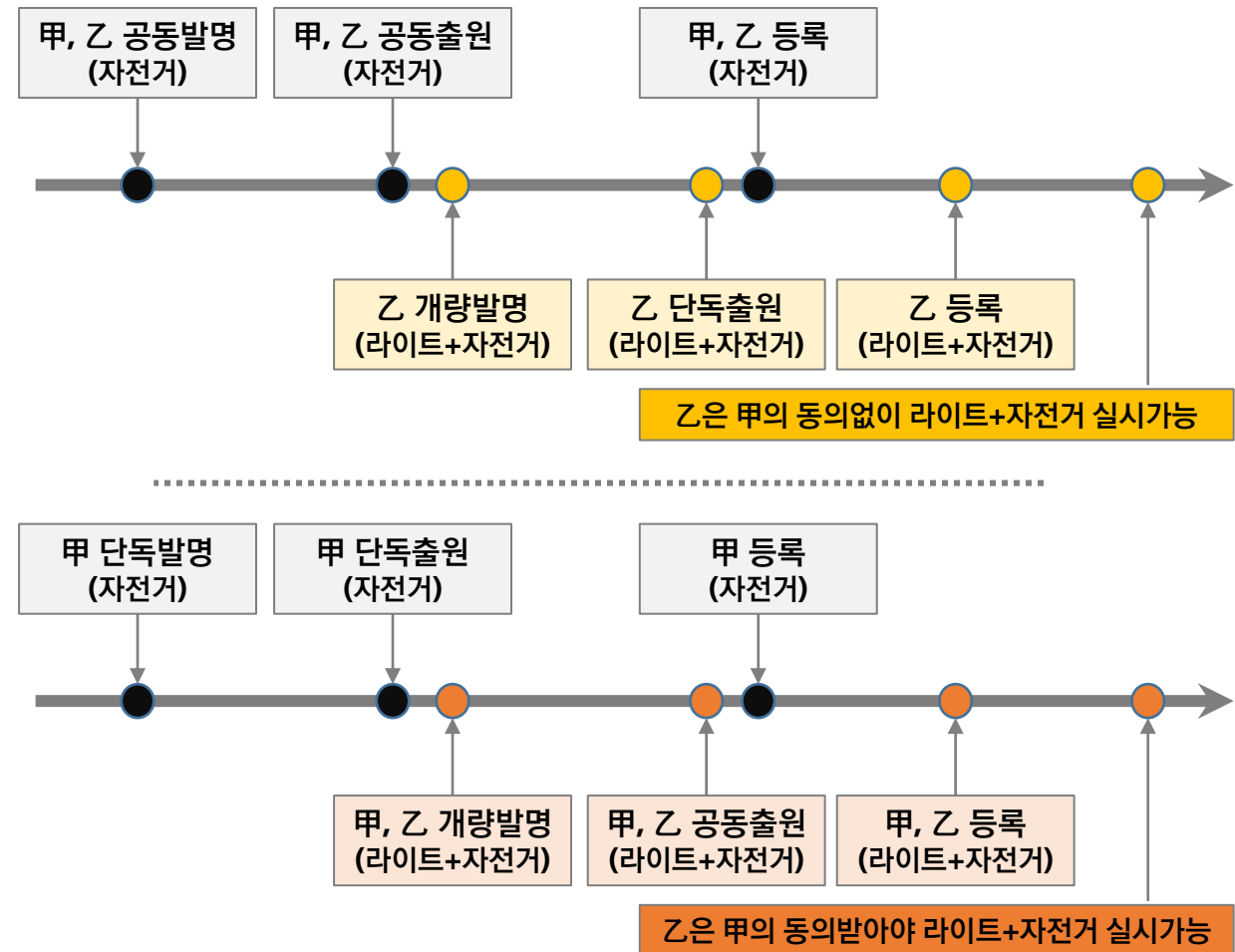
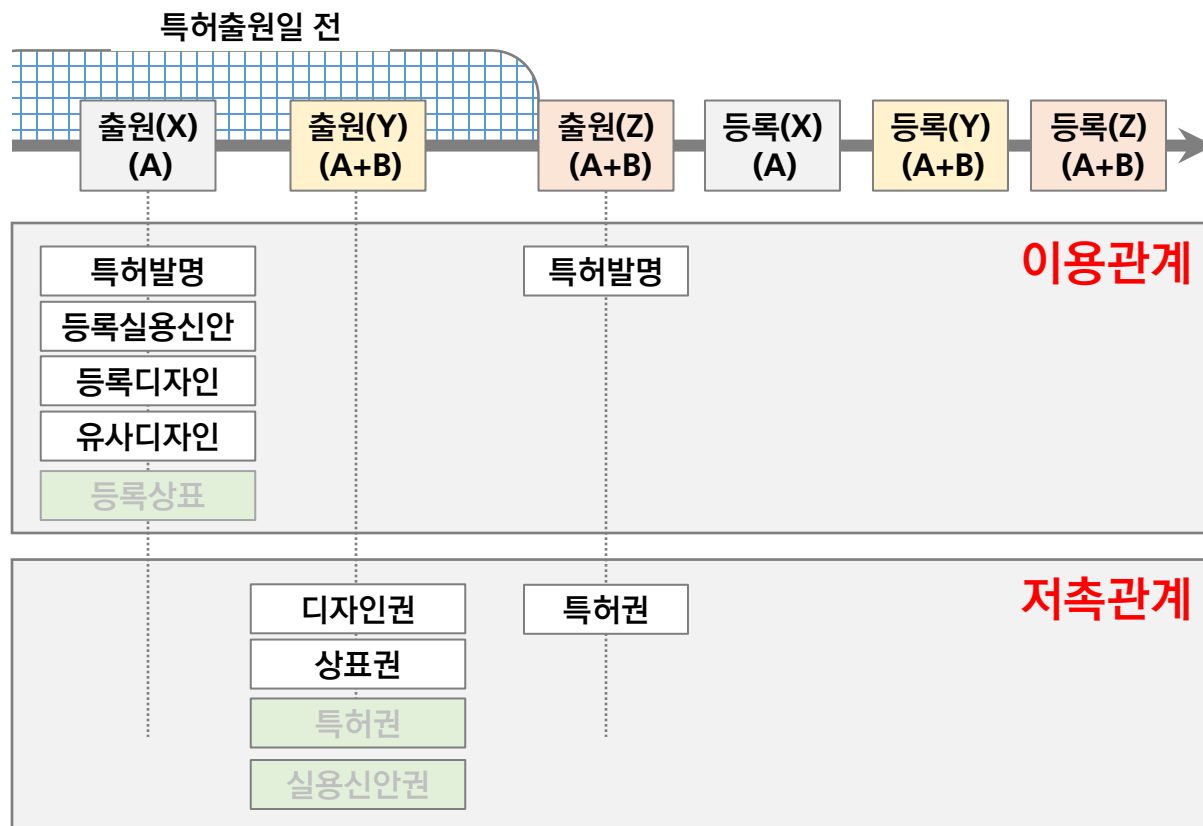
구별기준



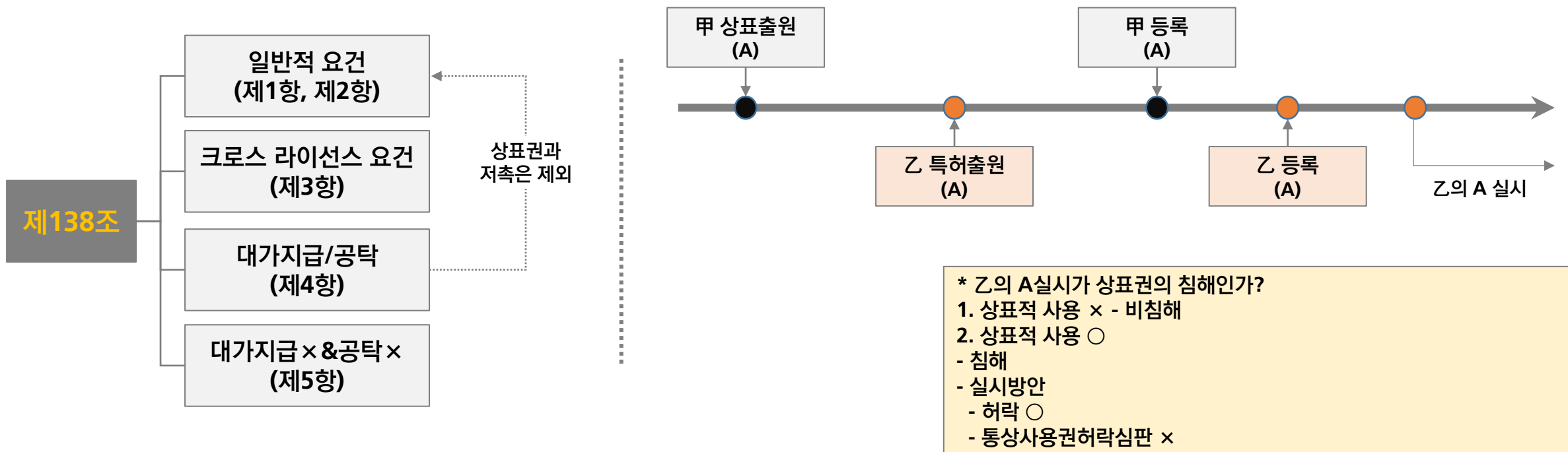
종속발명

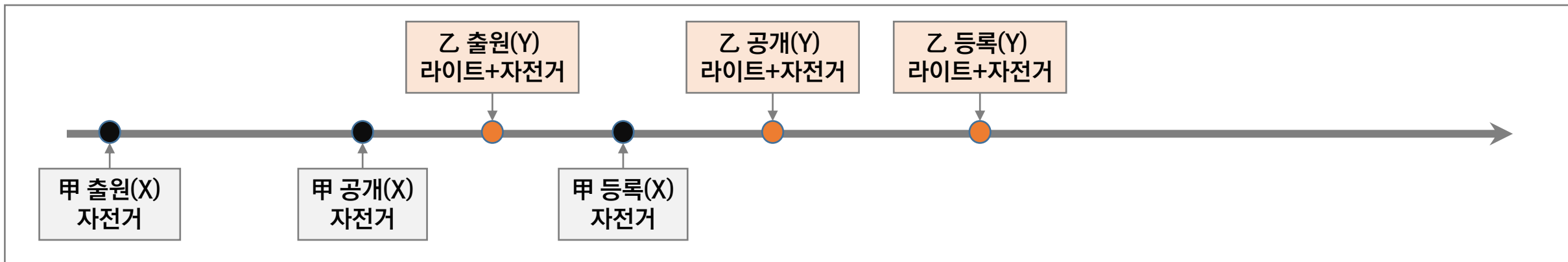
구분	등록가능성 판단	침해 판단
결합 발명	제29조제1항위반 × 제29조제2항위반 △	침해 ○ - 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 : × - 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 : ○
선택 발명	제29조제1항위반 × 제29조제2항위반 △	침해 ○ - 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960 : ×
신규 제법 발명	제29조제1항위반 × 제29조제2항위반 △	침해 ○ (물건생산의 청약은 제외)

제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 **특허출원일 전에 출원된** 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 **특허출원일 전에 출원된** 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.



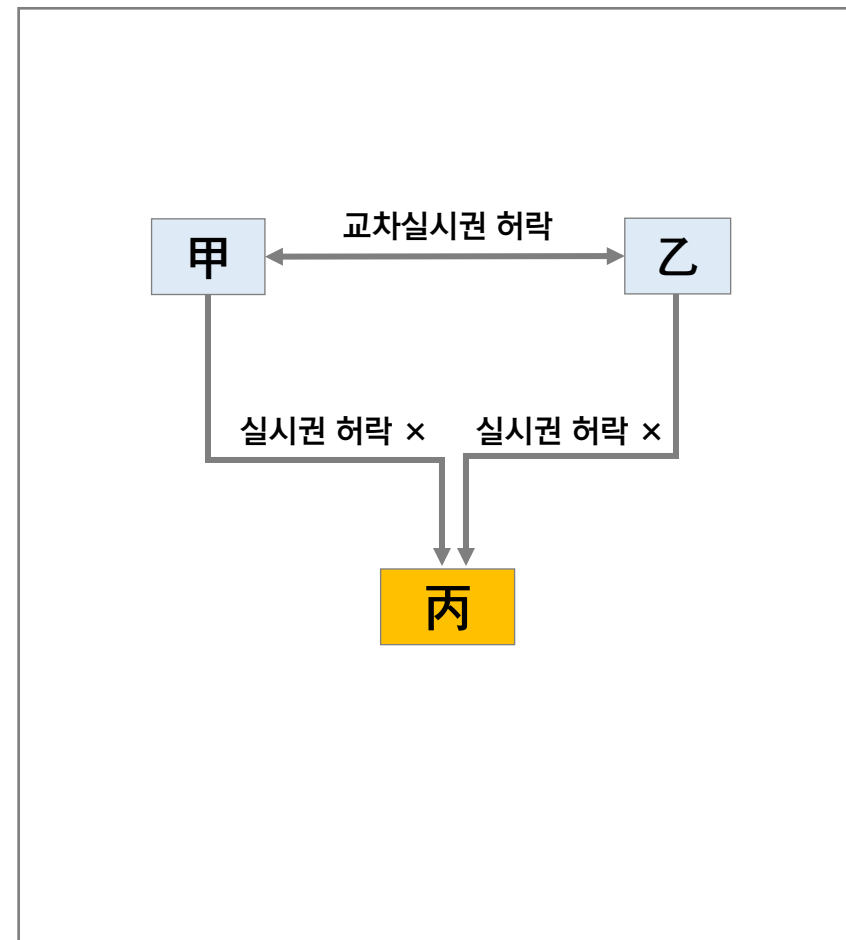
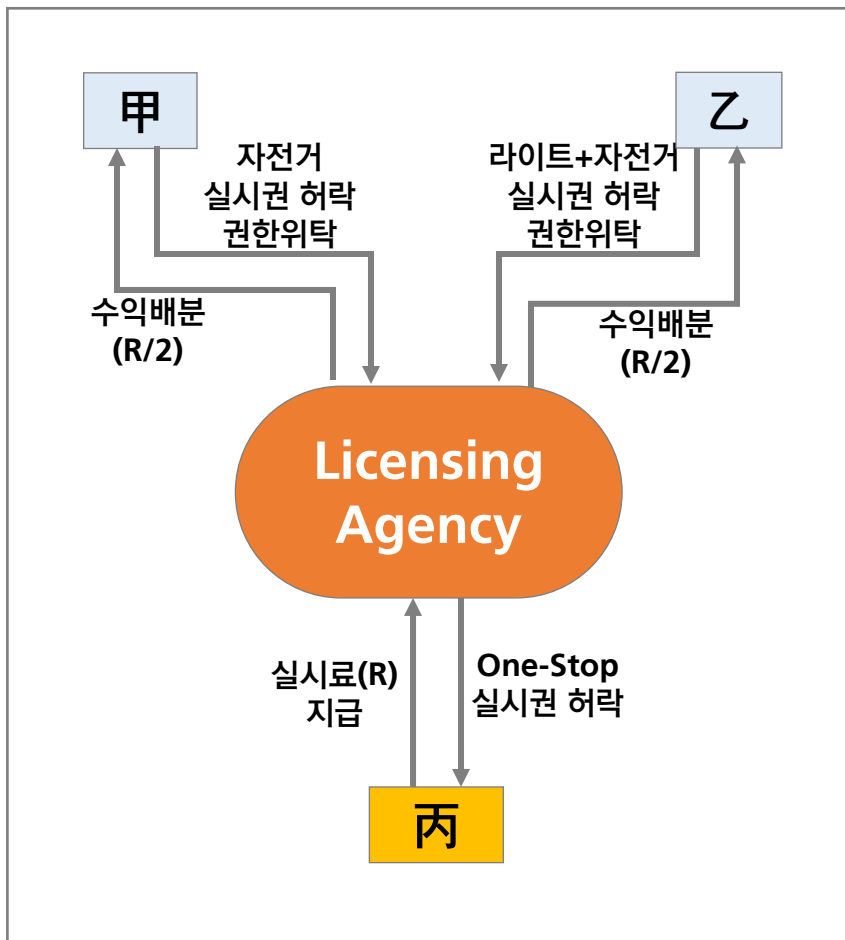
- 제138조(통상실시권 허락의 심판)** ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시상 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.
- ③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.





주체	판매	甲 특허 침해여부 및 실시방안			乙 특허 침해여부 및 실시방안		
		침해여부	실시방안		침해여부	실시방안	
			허락	통상실시권 허락심판청구		허락	통상실시권 허락심판청구
甲	자전거				×	-	-
	라이트+자전거				○	○	○
乙	자전거	○	○	×			
	라이트+자전거	○	○	○			
丙	자전거	○	○	×	×	-	-
	라이트+자전거	○	○	×	○	○	×

丙이 라이트+자전거 발명을 실시하기 위해서는 甲과 乙의 허락을 모두 얻어야만 한다. 이 경우, 甲과 乙은 자전거 및 라이트+자전거 특허에 대한 특허권을 결성하고, 실시권허락 대행기관을 통해 丙에게 한 번에 실시권을 허락(one-stop license)할 수 있다. 또한, 甲과 乙은 제3자인 丙에게 실시권을 허락하지 아니하여 丙의 특허제품(자전거나 라이트+자전거) 판매의 진입장벽으로 특허를 활용하는 한편, 甲과 乙 상호간에만 실시권을 허락하여 甲과 乙만 특허발명을 실시할 수도 있다.



특허권의 효력

특허법 제94조 (특허권의 효력)

① 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제 100조 제2항의 규정에 의하여 전실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.

특허법에서 소극적 효력 근거규정을 두는 것이 필요

독점: 적극적 효력

반대급부
(동전의 양면)

배타: 소극적 효력

침해

성립요건

종류

조치

직접침해

간접침해

민사

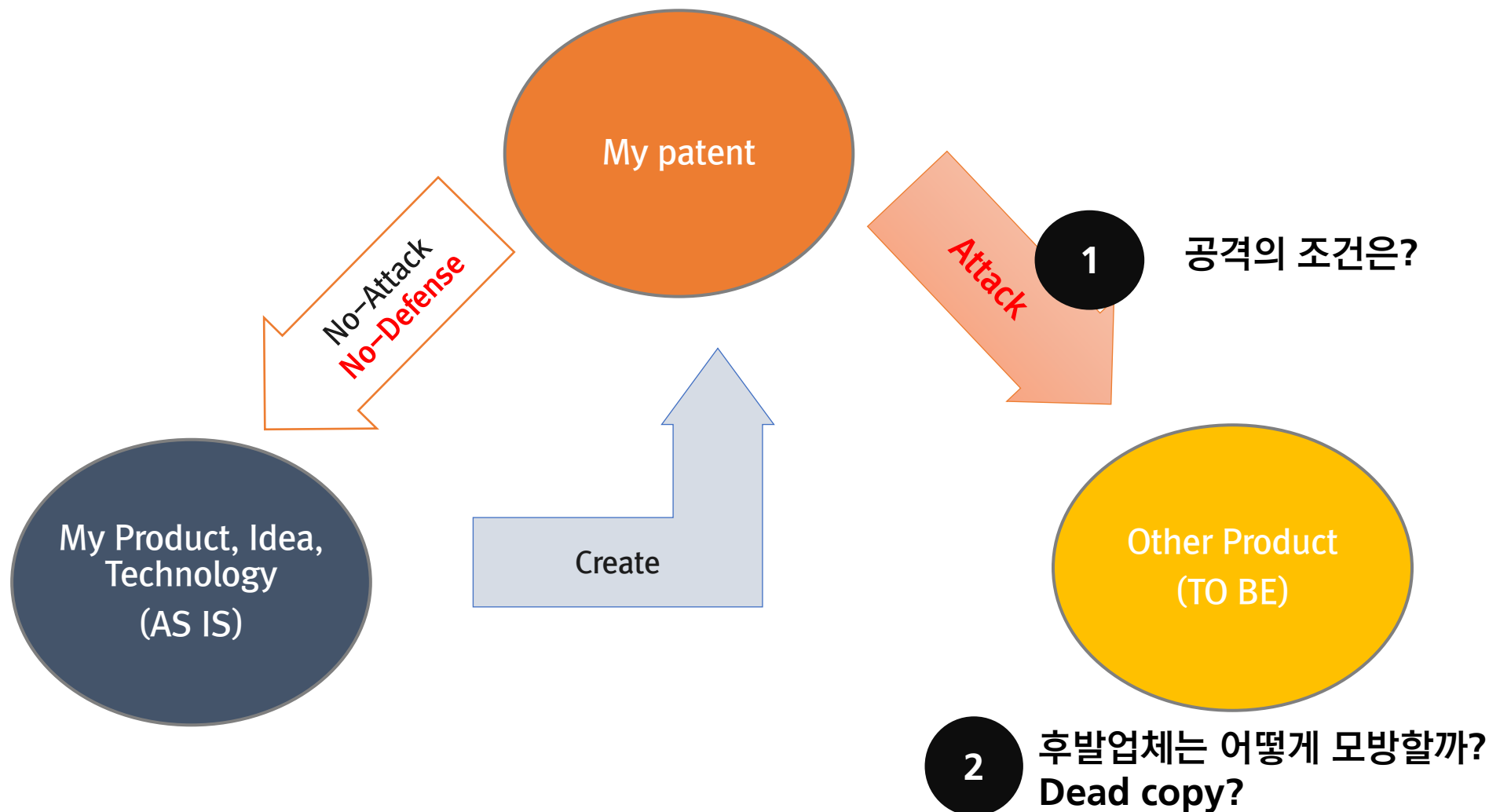
형사

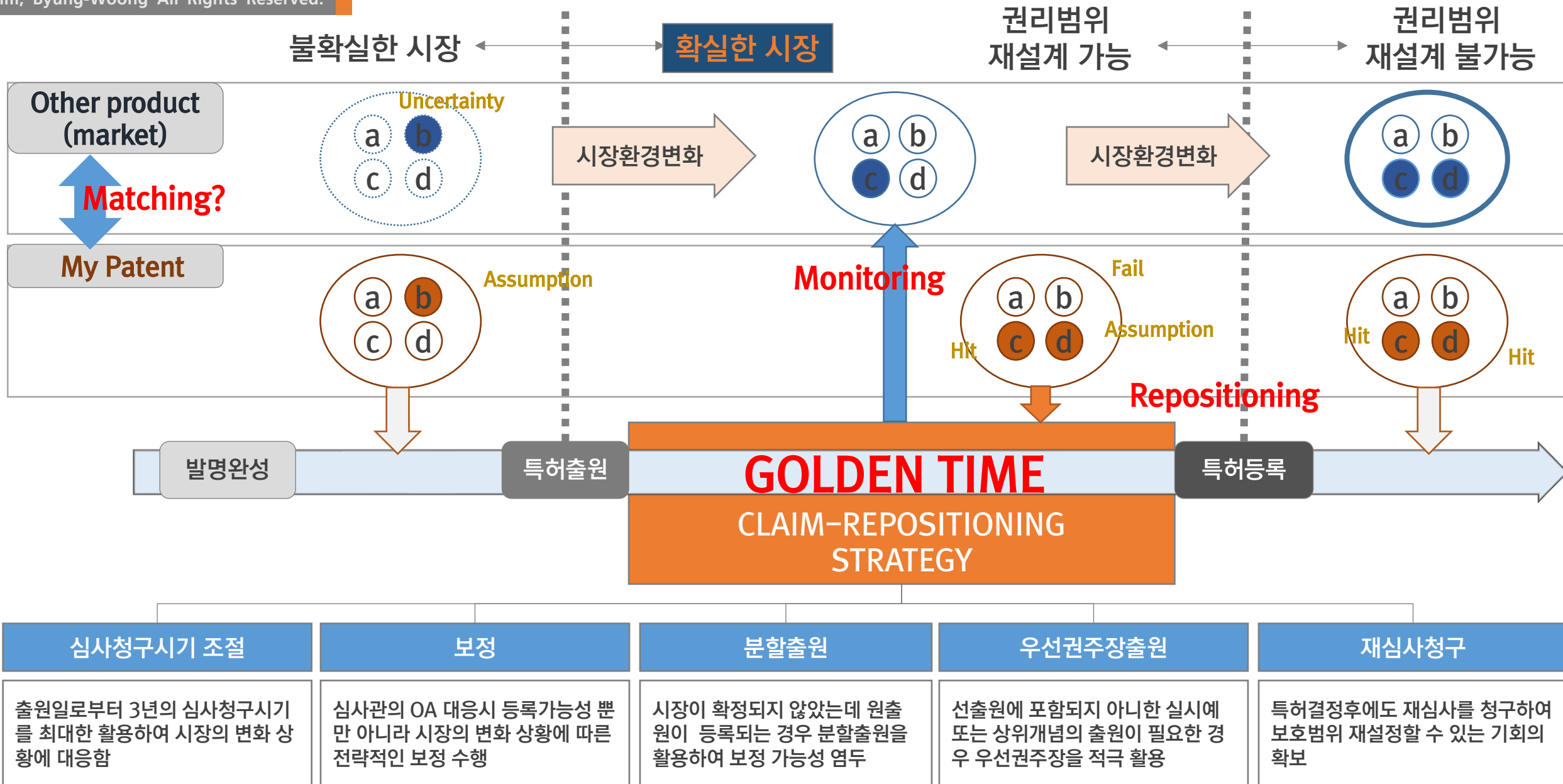
예외: 이용자촉발명

특허법 제98조 (타인의 특허발명등과의 관계)

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

나의 특허는 나의 제품(기술, 아이디어)로부터 창출되지만, **나의 제품을 보호하기 위한 방패는 아니며 아직 확정되지 않은 상대방의 제품을 공격하기 위한 창**이다.
(다만, 이용, 저촉에 해당하는 경우 나의 특허로 인해 통상실시권을 확보할 수 있는 기회를 얻게 된다.)







침해
성립요건

특허권 존속 中	- 특허출원중의 실시 또는 특허료의 불납, 존속기간의 만료, 특허권의 포기, 상속인 부존재 등으로 인해 특허권의 소멸된 후의 실시는 특허권의 비침해 - 일단 설정등록에 의하여 특허권이 발생한 이상 특허요건의 흠결이 있다고 할지라도 특허취소신청에 의한 취소결정이나 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전까지는 특허권이 존속중인 것으로 간주
정당한 권원 없는 자	실시권의 존재, 권리소진이 적용되는 경우 등 정당한 권원이 있기 때문에 비침해
특허발명의 보호범위에 속하는 발명	- 제1단계: 특허발명의 특정 - 청구범위 기준의 원칙, 발명의 설명 참작의 원칙, 공지기술참작의 원칙, 출원경과참작의 원칙, 특허권 하자 참작의 원칙 - 제2단계: 확인대상발명의 특정 - 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 특정(청구취지로서 특정) & 서로 대비할 수 있을 정도로 특정(청구원인으로서 특정) - 제3단계: 특허발명의 실시인지 판단 - 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)과 균등론(Doctrine of Equivalent)을 적용 - 제4단계: 법률의 제한(法 81의3④, 96, 181), 확장(法 127)을 고려
업으로서 실시	- 개인적, 가정적 실시를 제외하고는 업으로서의 실시로 해석 - 실시행위의 독립성
고의 또는 과실 不要	- 침해의 성립 자체에는 고의나 과실이 불요(단, 방법의 사용을 청약하는 행위는 고의 필요) - 다만, 고의나 과실이 있는 경우 민사상 손해배상, 신용회복을, 고의가 있는 경우 형사상 침해죄 적용가능(반의사불벌죄)

특허발명의 실시이면서 법률의 제한에 해당하지 않은 경우
(직접침해)

특허발명의 실시가 아니지만 법률의 확장에 해당하는 경우
(간접침해)

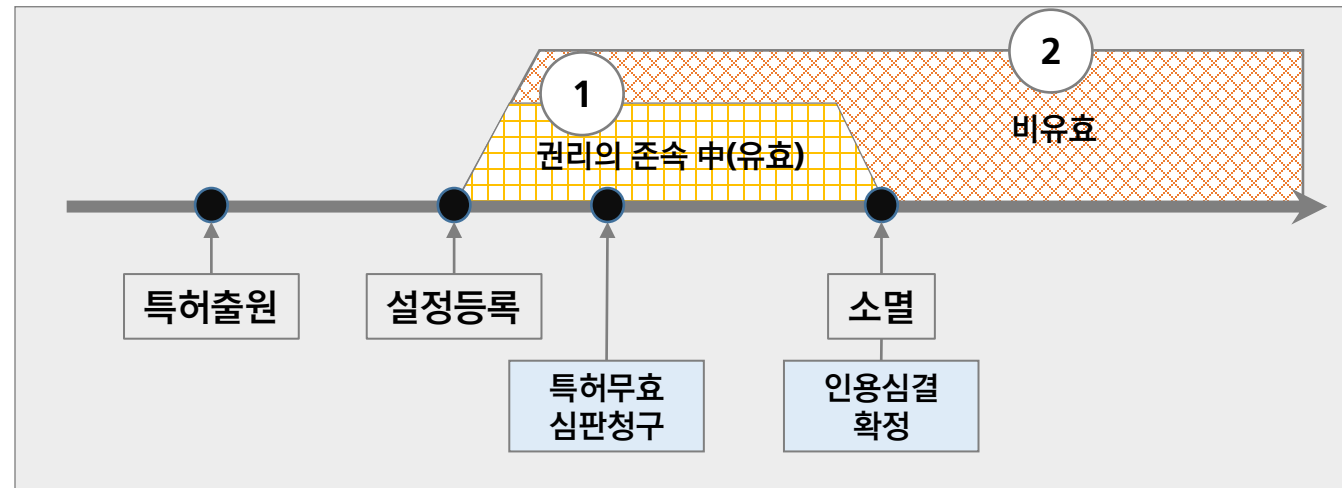
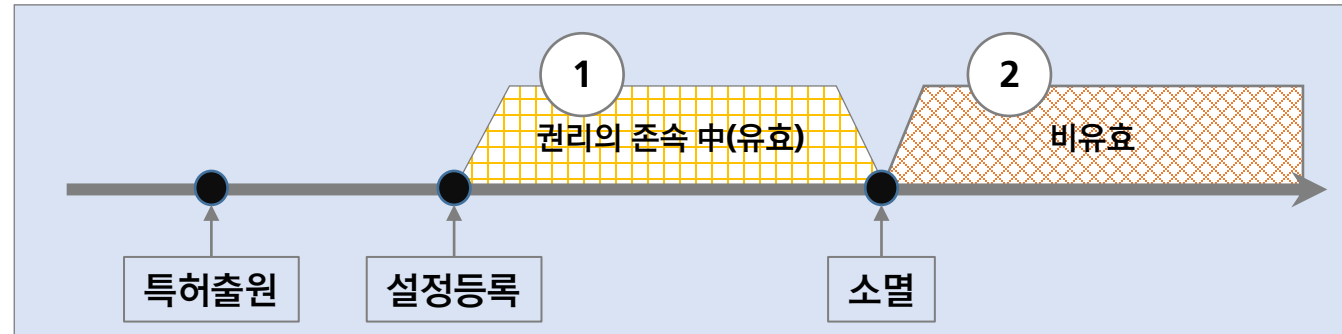
소멸
원인

장래를 향해 소멸

- 특허료 불납
- 존속기간 만료
- 특허권의 포기
- 상속인 없는 경우

소급하여 소멸

- 특허취소신청에 의한 취소결정의 확정
- 특허무효심판에 의한 인용심결의 확정(단, 후발적 사유는 제외)



특허법원 2009. 2. 18. 선고 2007허12961

일반적으로 하자있는 행정처분이 당연무효가 되기 위해서는 그 하자가 법규의 중요한 부분을 위반한 중대한 것으로서 객관적으로 명백한 것이어야 하며, 하자가 중대하고 명백한지 여부를 판별함에 있어서는 그 법규의 목적, 의미, 기능 등을 목적론적으로 고찰함과 동시에 구체적 사안 자체의 특수성에 관하여도 합리적으로 고찰함을 요하는바, 행정처분의 대상이 되지 아니하는 어떤 법률관계나 사실관계에 대하여 이를 처분의 대상이 되는 것으로 오인할 만한 객관적인 사정이 있는 경우로서 그것이 처분대상이 되는지의 여부가 그 사실관계를 정확히 조사하여야 비로소 밝혀질 수 있는 때에는 비록 이를 오인한 하자가 중대하다고 할지라도 외관상 명백하다고 할 수 없다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006다83802 판결 등 참조). 그런데 지식재산처 심사관이 특허결정을 함에 있어서는 엄격한 선행기술의 조사, 거절이유의 통지 등의 절차를 거쳐 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에 한하여 이루어지는 점, 특허무효사유 가운데는 신규성 또는 진보성 결여와 같이 단순한 사실확정의 문제에서 나아가 법적 평가의 성격을 지니는 것들이 적지 않은데다가 대체로 그 판단이 반드시 자명하지는 않은 점 등에 비추어 보면, 특허법 소정의 특허무효사유는 원칙적으로 행정법상의 당연무효사유에 해당한다고 보기는 어렵고 단순한 취소사유에 불과하다고 봄이 타당하다.

서울고등법원 2017. 8. 21. 선고 2015라20296 결정

특허 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니므로, 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것으로 된다(이른바 '구성요소 완비의 원칙'). 다만, 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, i) 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배, 관리하고, 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배, 관리하면서 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로, ii) 복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 특허발명의 전체 구성요소를 나누어 실시하는 경우에는 이들 복수 주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.

* 甲 또는 乙에게 책임을 물을 수 있는가?

청구항

--- A 단계;

--- B 단계;

--- C 단계;

甲 실시

--- D 단계; 및

--- E 단계를 포함하는 것

乙 실시

을 특징으로 하는 OO방법

간접침해

OO 방법의 실시에만 사용되는 물건이라면 甲 또는 乙의 간접침해

직접침해

단독침해

甲이 乙의 실시를 지배, 관리하면서 영업상의 이익을 얻고 있다면 甲의 단독 직접침해

공동침해

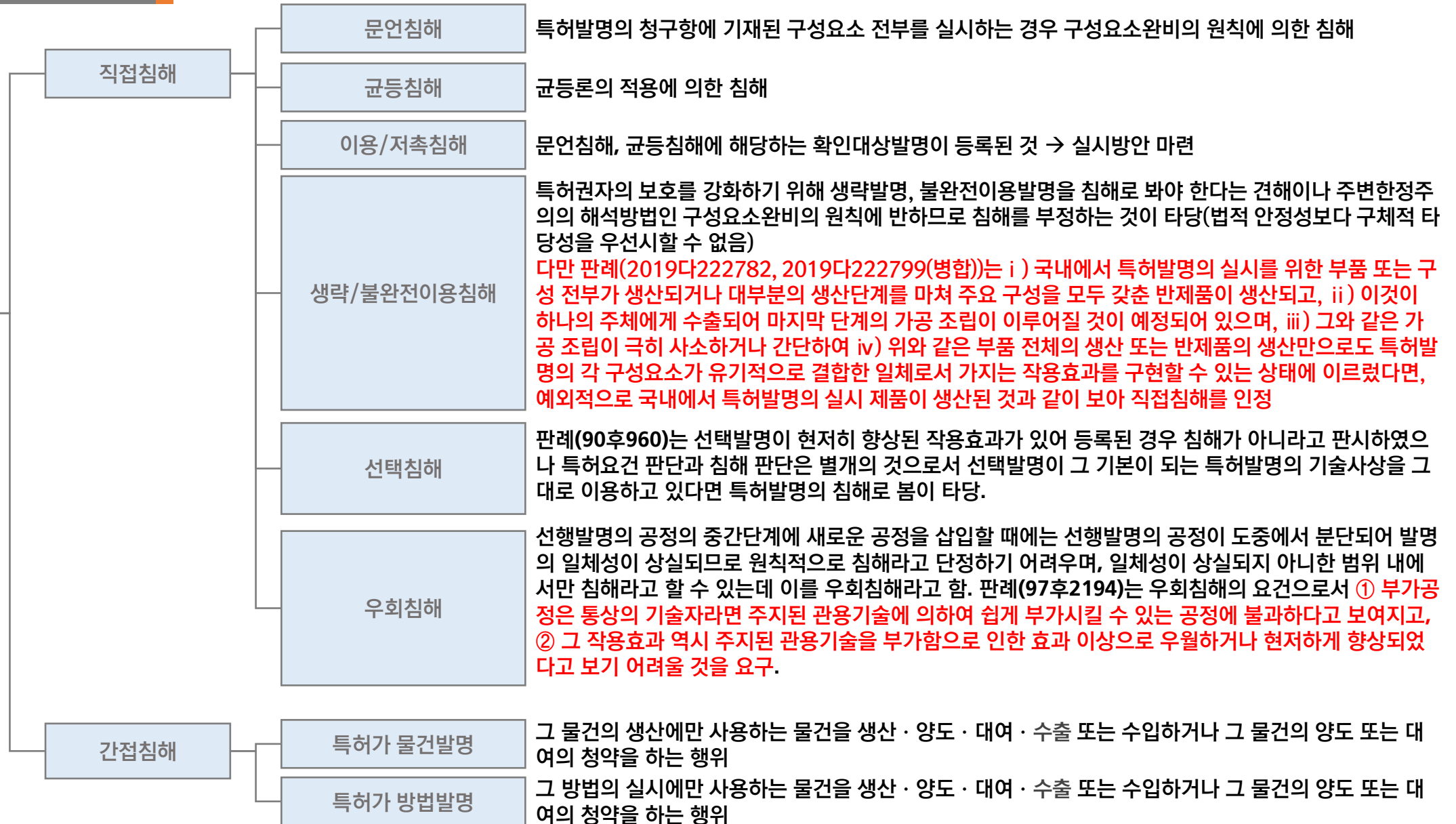
甲과 乙이 OO 방법발명의 구성요소를 나누어 실시하고, 甲과 乙이 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사*가 있다면 甲과 乙의 공동 직접침해

민법상
불법행위

각 행위가 독립하여 불법행위의 요건을 갖추고 있으면서 객관적으로 관련되고 공동하여 위법하게 피해자에게 손해를 가한 것으로 인정되어야 하나, 甲과 乙 각자의 행위 자체가 불법행위(침해)에 해당한다고 보기 어려움

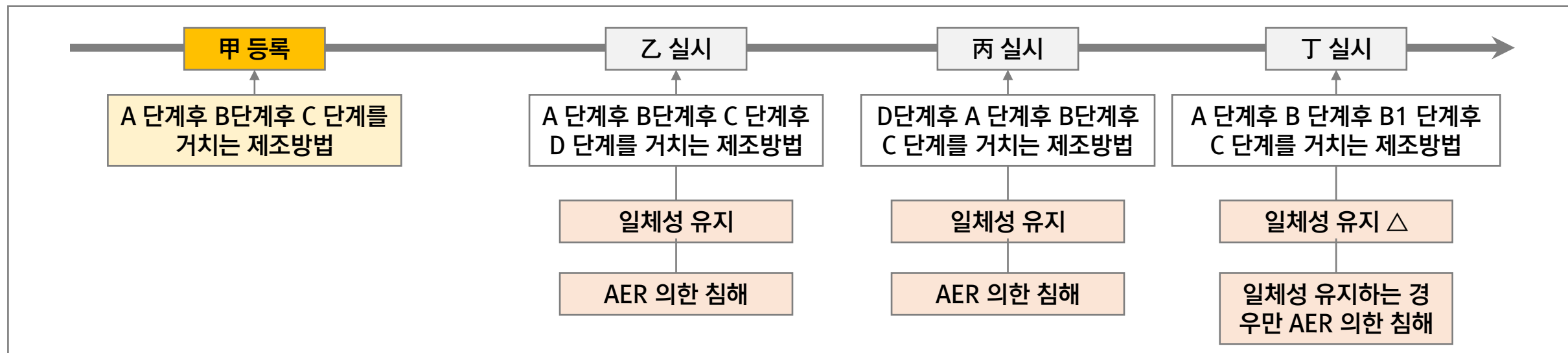
* i) 甲과 乙이 계속적인 거래관계가 있는 경우, 조인트 벤처 등을 형성하여 실시하는 경우와 같이 일체가 되어 결과를 발생시키려는 의사로 각자 구성요소의 일부를 실시하고 이를 행위를 합하면 구성요소 전부를 충족하는 경우, 또는 ii) 甲이 자신의 행위와 乙의 행위가 결합하여 특허권 침해하는 결과가 발생할 것을 예상하고 乙도 역시 그러한 경우

침해의 종류



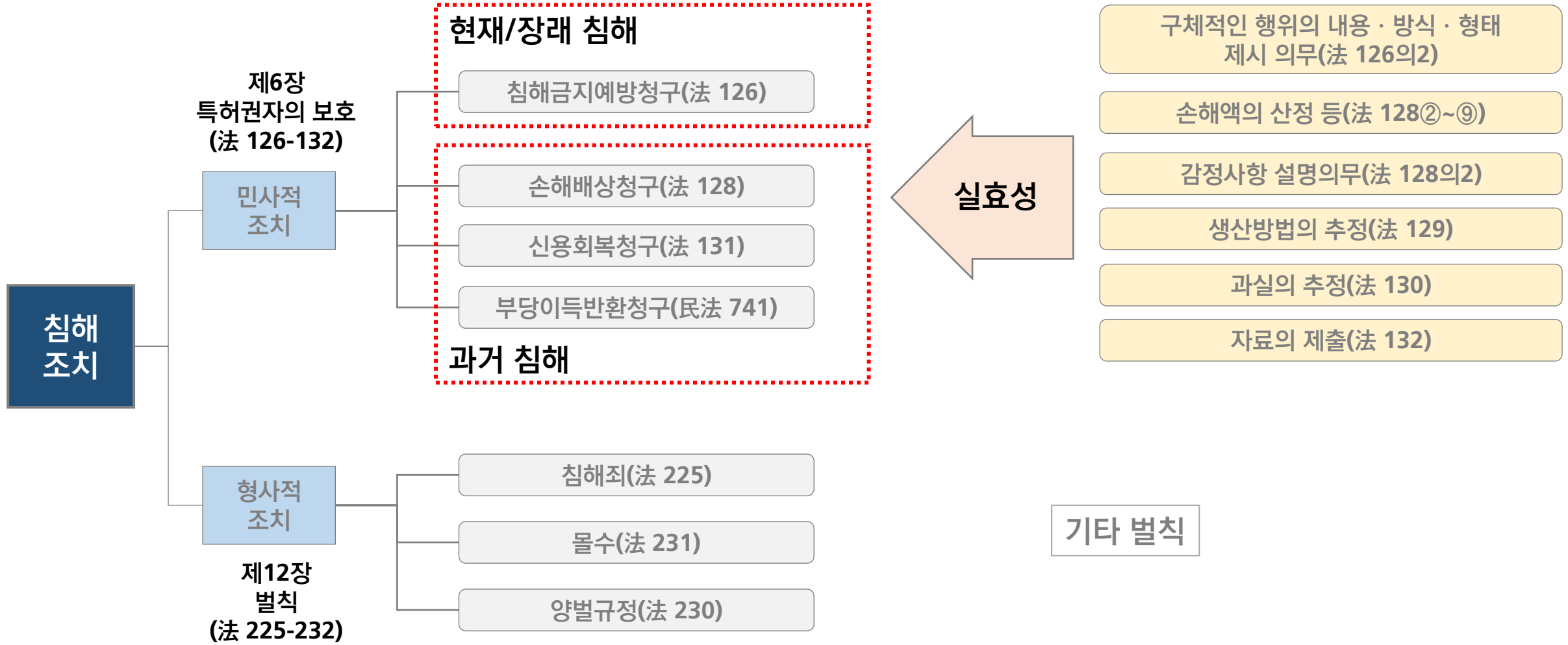
구 분	특허발명	확인대상발명	대법원 판례	비 고
문언침해	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C}$	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C}$	침해	최근 판례는 개별 구성요소의 중요성을 강화하는 방향으로 나아감(생략침해나 불완전이용침해의 인정여부와 상관관계 있음)
	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C}$	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C} + \boxed{D}$	침해	촉매를 이용한 화학발명의 이용침해의 해당 여부에 대한 중요한 판례의 변화가 있음
균등침해	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C}$	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C'}$	침해	과제의 해결원리의 동일성, 출원금반언의 원칙 등 적용범위의 해석 확립 필요
	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C}$	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C'} + \boxed{D}$	침해	균등물을 기초로 한 이용발명을 침해로 인정함
생략침해	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C}$	$\boxed{A} + \boxed{B}$	최근 대법원 판례는 침해 부정	침해를 문언침해와 균등론적 침해로 나누고 개별적 구성요소의 존재를 중요시하는 최근 판례의 동향과 관련하여 그 존재의 의의 및 별도의 침해이론으로서의 인정여부를 심도있게 논의하여 나가야 함. 최근에는 균등침해의 하나의 유형으로 인정하려는 경향이 있음
불완전이용침해	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C}$	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{} + \boxed{D}$	대법원 판례 없음	
선택침해	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C}$	$\boxed{a} + \boxed{B} + \boxed{C}$	침해를 부정한 과거의 판례는 존재하나 논란 있음	최근 판례의 경향에 따라 이용침해의 한 유형으로서 파악해야 한다는 주장이 강하게 제기되고 있음
우회침해	$\boxed{A} + \boxed{B} + \boxed{C}$	$\boxed{A} + \boxed{B1} + \boxed{B} + \boxed{C}$	침해	균등침해와의 관계 정립 필요

우회발명이란 선행의 특허발명과 기술사상을 같이 하는 것이면서 그 보호범위를 벗어나기 위하여 무용의 물질이나 공정을 부가하여 일부러 우회의 길을 가는 것으로서, 결국 발명으로서의 동일한 것으로 귀착되는 관계에 있는 발명을 말한다. 선행발명의 공정에 부가가 있는 경우로서 공정의 부가가 선행발명의 공정 전 또는 완료 후에 있을 때에는 침해라고 볼 여지가 있으나, 선행발명의 공정의 중간단계에 새로운 공정을 삽입할 때에는 선행발명의 공정이 도중에서 분단되어 발명의 일체성이 상실되므로 원칙적으로 침해라고 단정하기 어려우며, 일체성이 상실되지 아니하는 범위에서만 침해라고 할 수 있을 것이다.

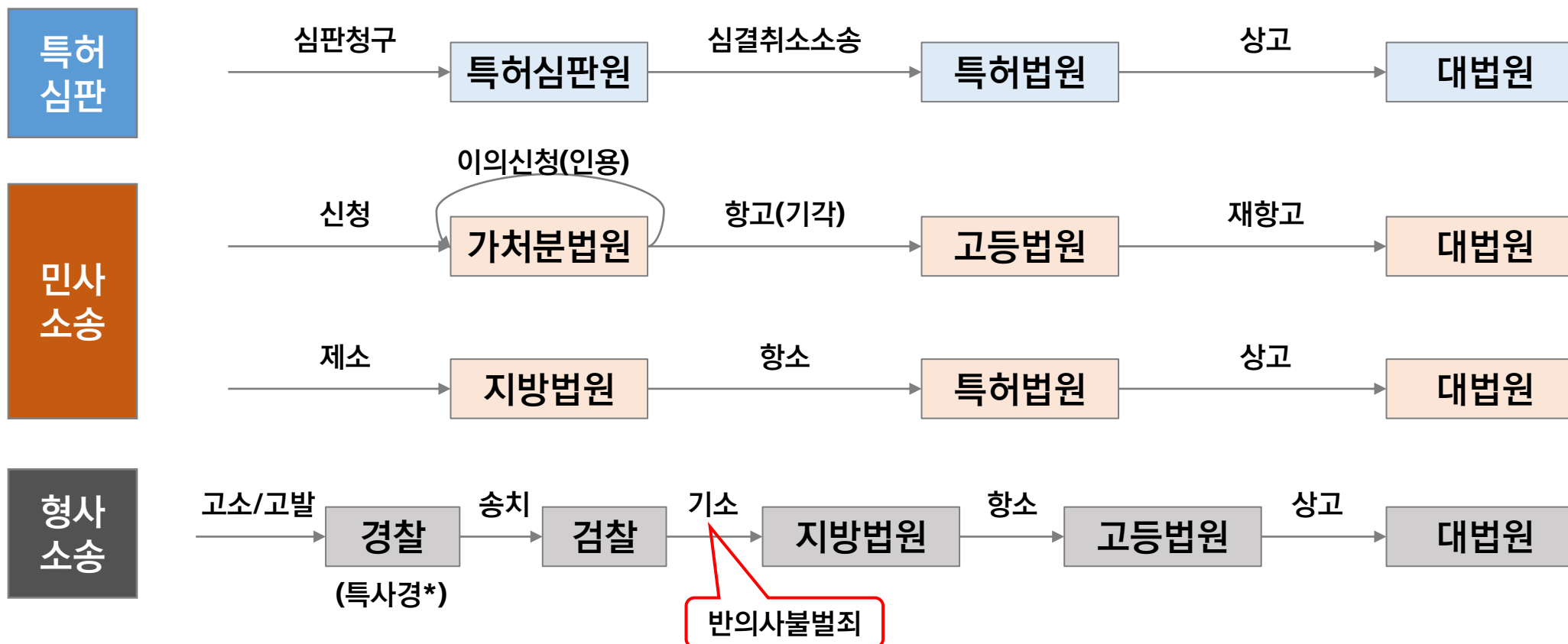


대법원 2000. 7. 4. 선고 97후2194

확인대상발명은 그 출발물질, 반응물질(피페라진) 및 목적물질이 이 사건 특허발명과 동일하고 그 제조방법도 반응물질인 피페라진을 출발물질의 C-7 위치에 결합시켜 목적물질을 만드는 이 사건 특허발명의 주반응의 반응기전(reaction mechanism)을 그대로 이용한다는 점에서 그 기술적 사상과 핵심적인 구성이 동일하며, 다만 확인대상발명이 출발물질에 알루미늄클로라이드를 반응시켜 중간체를 거치는 구성을 부가한 차이가 있기는 하지만, 이 부가공정은 이 사건 양 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 주지된 관용기술(보호기의 사용)에 의하여 용이하게 부가시킬 수 있는 공정에 불과하다고 보여지고, 그 작용효과 역시 주지된 관용기술을 부가함으로써 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어려우므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없어 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

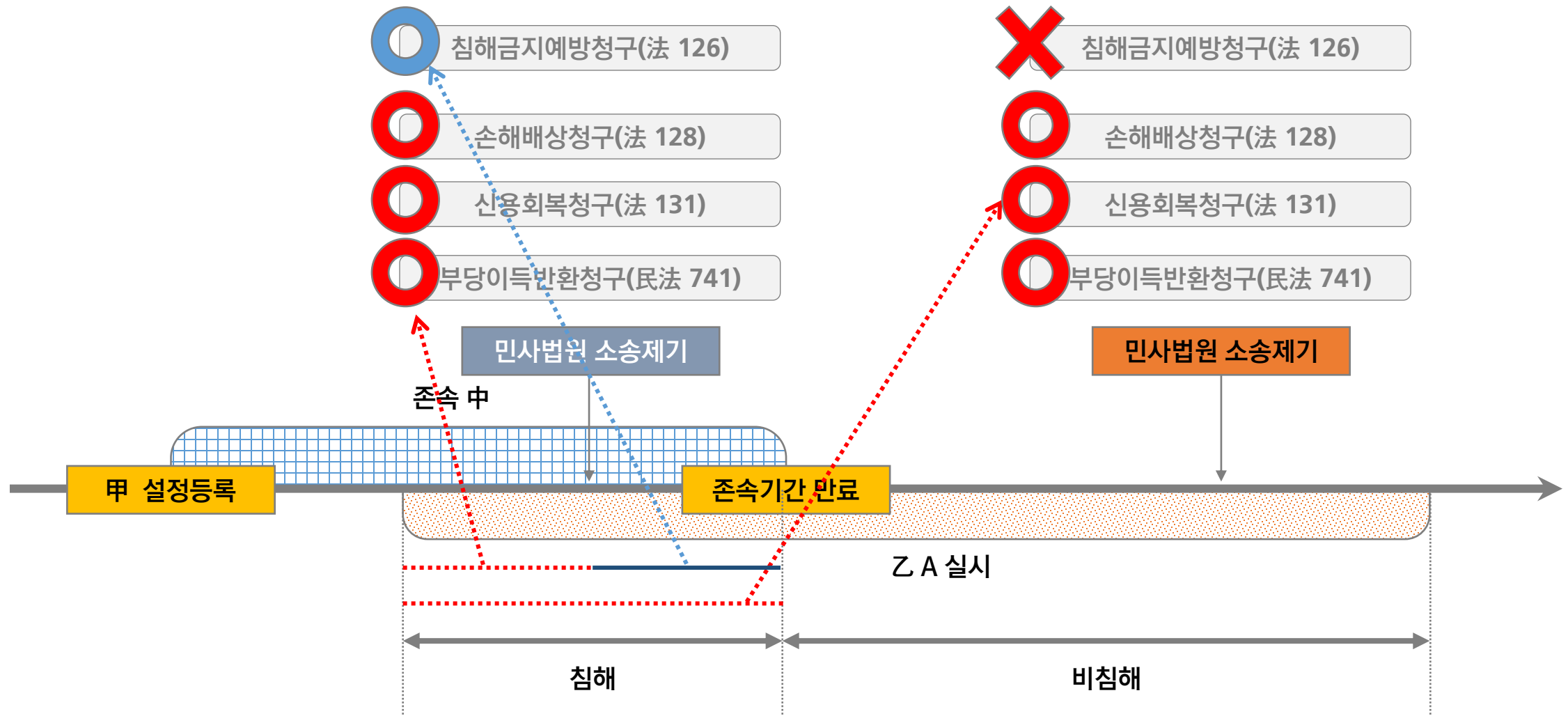


2016년 1월 1일부터는 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권) 침해 민사본안소송의 관할을 1심은 고등법원 소재지가 있는 6개 지방법원(서울중앙지방법원, 대구지방법원, 대전지방법원, 광주지방법원, 부산지방법원, 수원지방법원(2019년 3월 1일 추가))이 전속적으로 맡고, 2심은 특허법원으로 집중하게 되도록 민사소송법 및 법원조직법이 개정되었다. 기존에는 침해소송의 1심을 58개 지방법원과 지원에서, 2심을 고등법원과 지방법원 항소부에서 맡는 한편, 심결취소소송을 특허법원에서 맡고 있어서 관할이 분산되어 있었다. 이번 개정은 특허소송의 관할을 특허법원으로 집중해 특허권 등의 분쟁 해결에 있어 법원의 전문성, 효율성 및 신속성을 제고하는 한편, 소송당사자에게 보다 신속하고 전문적인 재판을 보장함으로써 지식재산권 보호의 실효성을 높이고자 하는 취지를 담고 있다.



*특사경(특별사법경찰)이란 전문성이 필요한분야나 접근이 제한된 공간에서 발생하는 범죄등 일반 경찰의 접근이 어려운 범죄, 행정기관이 더 효율적으로 처리할 수 있는 범죄에 대해 행정공무원이 경찰의 권한을 부여받아 행사하는 제도를 말한다.

침해금지 및 예방청구권은 현재 또는 장래의 침해에 대하여 행사하는 점에서, 과거의 침해에 대하여 행사하는 손해배상, 부당이득반환 등의 청구권과 다르고 특허권 침해에 대한 구제수단으로서 가장 유효하고 직접적인 것이다. 다만, **특허권의 존속기간이 만료된 후에는 침해금지청구권을 행사할 수 없다.**



침해금지청구의 본안소송 확정 전 현저한 손해를 받거나 급박한 방해를 방지할 수 없는 등 긴급한 행위가 필요한 경우에 침해금지를 위한 임시적 지위설정을 위해 침해금지청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분 신청을 할 수 있다. **가처분이 인정되기 위해서는 침해 사실 외에 처분의 긴급성이 필요하다. 한편, 가처분결정이 있는 후 가처분 집행권자가 본안소송에서 패소확정되었다면 그 가처분으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대해서는 채권자에게 고의 또는 과실이 없다는 반증이 없는 한 배상할 책임이 있다.**

	가처분	본안소송
집행력	결정에 따라 심급별로 4개월 소요되며 통상 10개월~1년 소요	확정이 필요하므로 심급별로 1년 정도 소요되며 통상 2-3년 소요
절차	심문절차/소명/결정	변론/증명/판결
요건	침해 사실외에 처분의 긴급성 추가 필요	침해사실

대법원 2007. 6. 4 선고 2006마907

임시의 지위를 정하기 위한 가처분을 필요로 하는지 여부는 **가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것이므로 가처분채권자가 신청 당시에 실제법상의 권리를 가지고 있다 하더라도 그 권리가 가까운 장래에 소멸하여 본안소송에서 패소판결을 받으리라는 점이 현재에 있어 충분히 예상되는 경우에는 필요성이 없다고 풀이하는 것이 상당하고, 더구나 특허권침해의 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 보전의 필요성 유무를 더욱 신중하게 결정하여야 할 것으로서 만일 가처분신청 당시 채무자가 지식재산처에 별도로 제기한 심판절차에 의하여 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있는 경우나, 무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것이다.**

제128조(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액
2. 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

③ 삭제

④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

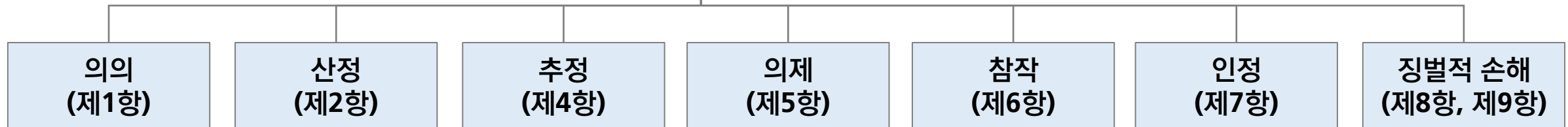
⑦ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

손해배상청구권 (제128조)



소극적 손해로는 i) 특허권자의 매상감소, ii) 특허제품의 가격하락 또는 iii) 실시료 수입의 감소가 있을 수 있는데, 침해행위에 의해서만 발생한 것이라는 인과관계의 증명은 통상적으로 다음과 같이 상당히 어렵다. 따라서 손해배상청구의 실효성 확보를 위해 인과관계를 증명하지 않더라도, **매상감소에 의한 일실이익에 관해서는 제128조제2항제1호 및 제4항에서, 실시료 수입의 감소에 대해서는 제128조제2항제2호 및 제5항에서 별도의 규정에 의하고 있다.** 한편, 그 외의 적극적 손해, 정신적 손해, 제품가격 인하로 인한 일실이익 등의 손해에 대한 손해배상청구는 제128조제1항의 일반적인 손해배상의 법리에 의한다.

소극적 손해	계산식	비고
매상감소	감소된 판매수량 × 특허권자 제품의 단위수량당 이익액	감소된 판매수량이 침해자 때문이라는 것을 증명해야 함 (침해외의 사유로 감소된 수량의 경우 손해액에서 제외)
제품가격 인하	(원가격-인하된 가격) × 판매수량	가격 인하가 영업상의 문제가 아니라 침해자 때문이라는 것을 증명해야 함 (침해외의 사유로 가격 인하된 경우 손해액에서 제외)
실시료 수입의 감소	침해품 판매수량 × 실시권자 판매가격 × 약정실시료율	침해자 때문에 침해품 판매수량만큼 실시권자가 판매하지 못하였음을 증명해야 함 (침해외의 사유로 실시권자가 판매하지 못한 경우 손해액에서 제외)

손해액의 산정

손해액 1과 손해액 2의 합계액을 손해액으로 산정가능

손해액 1: 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액(法 128② I)

- i) 특허권자 생산능력 범위내에서 침해자의 양도수량을 특허권자의 판매 감소량으로 간주할 수 있게 되었다는 점, ii) 특허권자 등이 침해자의 양도수량만 확인하면 침해자의 단위수량당 이익액을 알 수 없다고 하더라도 특허권자 등의 단위수량당 이익액을 이용할 수 있으므로 계산이 용이하다는 점에서 의미가 있음
- 단위수량당 이익액은 한계 이익(매출액-변동경비)(2005다36830)
- 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있다는 것을 침해자가 증명하면 양도수량 중 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량은 빼야 함
- 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이란 침해자의 시장개발 노력, 판매망, 침해자의 상표, 광고, 선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 디자인권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 디자인권을 침해하지 않으면서 디자인권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경합제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등을 말함(2005다36830).

손해액 2: 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액(法 128② II)

- i) 오늘날 특허권을 활용한 제품의 제조방식이 OEM 등 다양한 방식으로 이루어지는 점, ii) 설령 생산을 하지 않더라도 특허권자는 수많은 제조업자에게 실시계약을 체결하여 실시할 가능성이 열려 있는 점 등 특허권의 특성을 고려하였을 때, 침해자가 특허권자의 생산능력을 초과하여 취득한 이익을 응당 특허권자가 얻을 수 있었던 이익으로 볼 필요가 있음
- 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 것을 침해자가 증명하면 해당 수량은 초과수량에서 빼야 함

손해액의 추정(法 128④): 침해행위로 인한 이익액

손해액의 추정

- 침해자의 단위수량당 이익액이 특허권자 등의 단위수량당 이익액보다 더 높을 때 원용됨
- 침해행위로 인한 이익액은 한계 이익(매출액-변동경비)(2002가합30683호)
- 손해는 “매상감소에 의한 일실이익(逸失利益)”이고 **특허권자의 생산능력 범위 내에서 손해의 한도를 제한하는 것으로 해석되기 때문에 특허권자 또는 전용실시권자가 스스로 실시하고 있지 아니한 경우와 같이 특허권자의 생산능력이 없는 경우에는 손해의 발생 자체를 관념할 수 없으므로 이 추정규정은 부적용.**
[(침해자의 양도수량과 생산능력범위수량 중 작은 값) * 침해자의 단위수량당 이익액]
- 침해품의 일부가 특허의 침해인 경우 그 물건에서 침해된 특허가 차지하는 비중, 즉 그 특허가 유발하는 구매동기의 정도를 기여율로 평가하여 물건 전체가 특허의 대상이 되는 경우에 산정되는 손해액에 위 기여율을 곱하여 계산되는 금액을 손해액으로 해야 한다는 견해가 다수설

손해액의
의제**손해액의 의제(法 128⑤): 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 액**

- 특허권의 침해가 있는 경우 그로 인해 특허권자가 별도로 실시 계약을 체결할 수 있는 기회를 상실하게 되어 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 액의 손해를 입게 되기 때문에 그러한 금액을 손해액으로 인정한 것으로서, 「손해의 하한액」을 정함
- 이 규정은 특허권의 침해가 손해액의 추정 규정(法 128④)과는 달리 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않아 매상감소의 일실이익(逸失利益)이 없는 경우에도 적용된다는 점에 그 의의가 있다. 특허권자는 손해발생에 대하여 주장·증명을 할 필요가 없고, 권리침해사실과 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 주장·증명하면 된다.

손해액의
참작**손해액의 참작(法 128⑥): 손해액 의제 초과액에 대해서도 청구가능/고의·중과실이 없으면 참작가능**

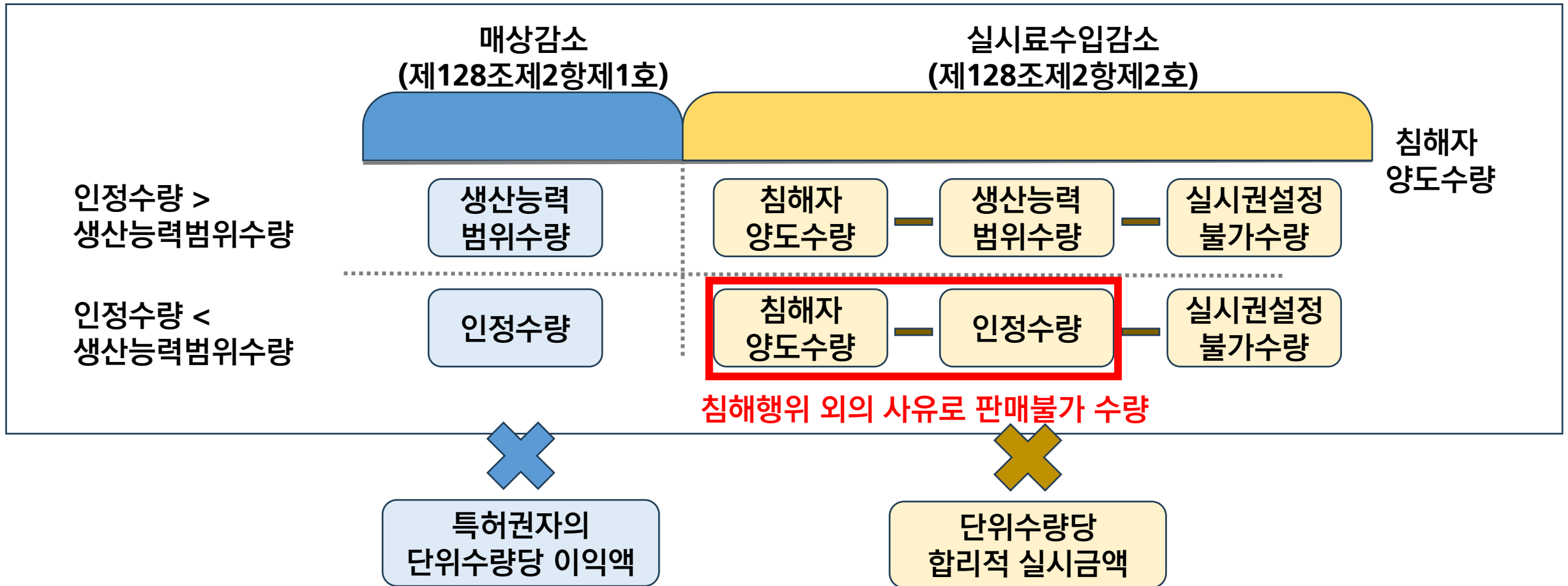
- 다만, 이 경우에도 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 액보다 적은 금액까지 경감 불가

손해액의
인정**손해액의 인정(法 128⑦): 변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과에 기초하여 상당 손해액 인정**

- 다만, 이는 자유심증주의하에서 손해가 발생한 것은 인정되나 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도 원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하려는 데 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수증할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(2010다58728).
- 제132조(자료의 제출)의 실효성 확보 가능하고, 영업비밀 누설 우려에 대해서는 비밀유지명령제도(法 224의3)를 통해 보완

징벌적
손해배상**징벌적 손해배상(法 128⑧): 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액 인정 가능**

- 법원은 배상액을 판단할 때 다음의 사항을 고려(法 128⑨)
 - i) 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부,
 - ii) 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
 - iii) 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모,
 - iv) 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
 - v) 침해행위의 기간·횟수 등,
 - vi) 침해행위에 따른 벌금
 - vii) 침해행위를 한 자의 재산상태,
 - viii) 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도



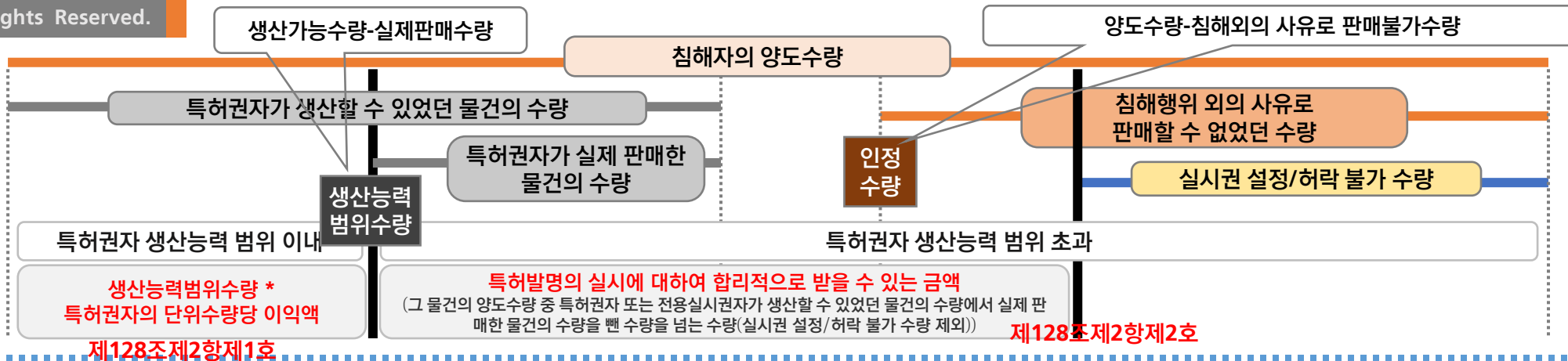
인정수량

침해자의 양도수량 - 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량

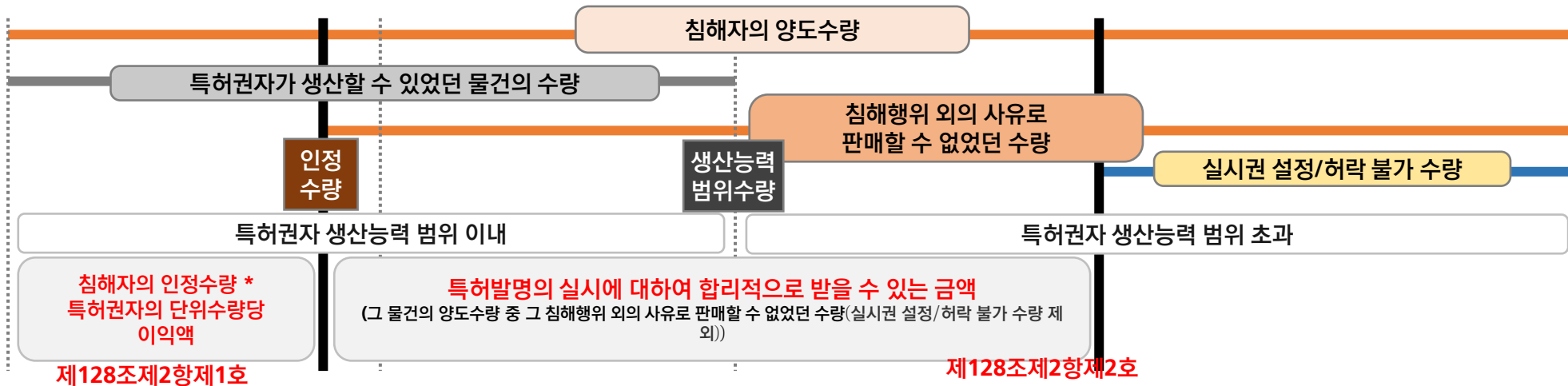
생산능력
범위수량

특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량 - 실제 판매한 물건의 수량

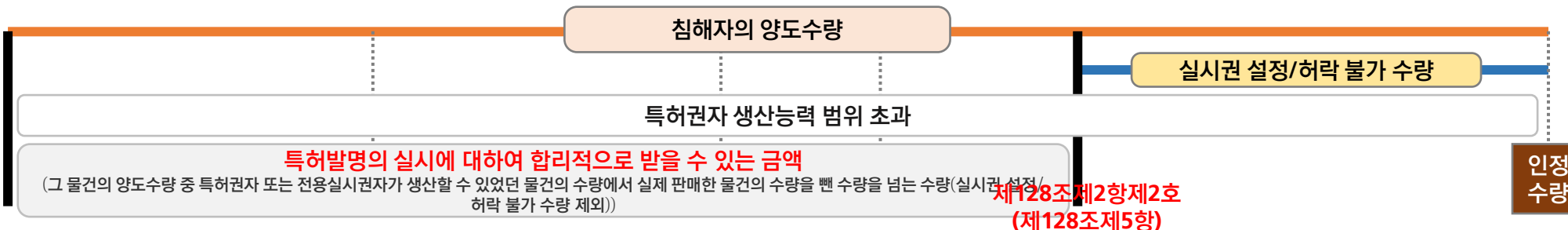
CASE 1

인정수량이 생산능력
범위수량 초과인 경우

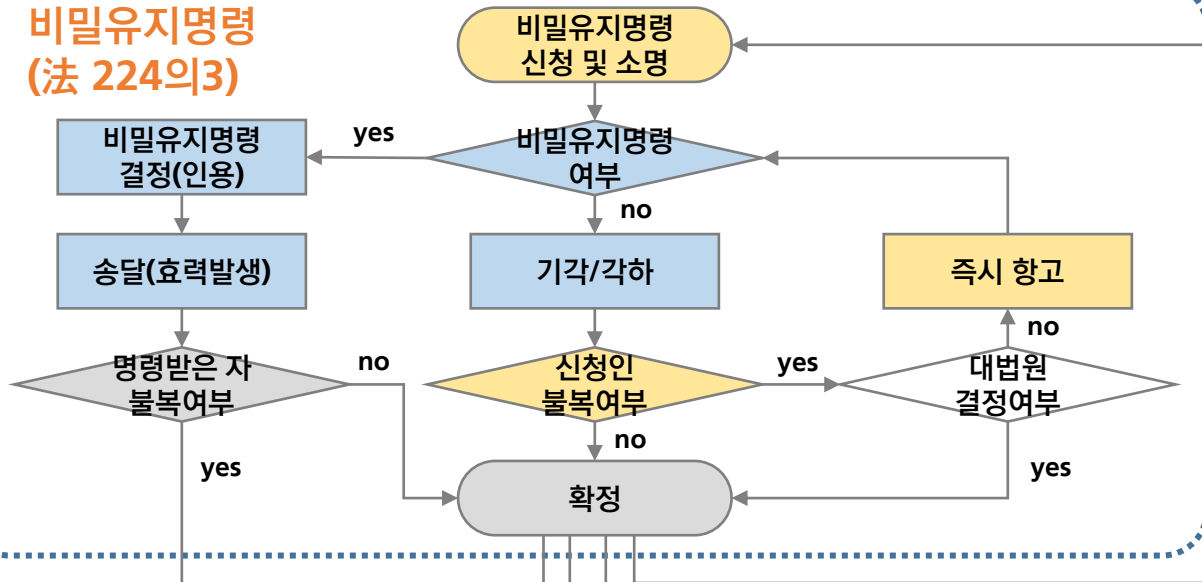
CASE 2

인정수량이 생산능력
범위수량 이내인 경우

CASE 3

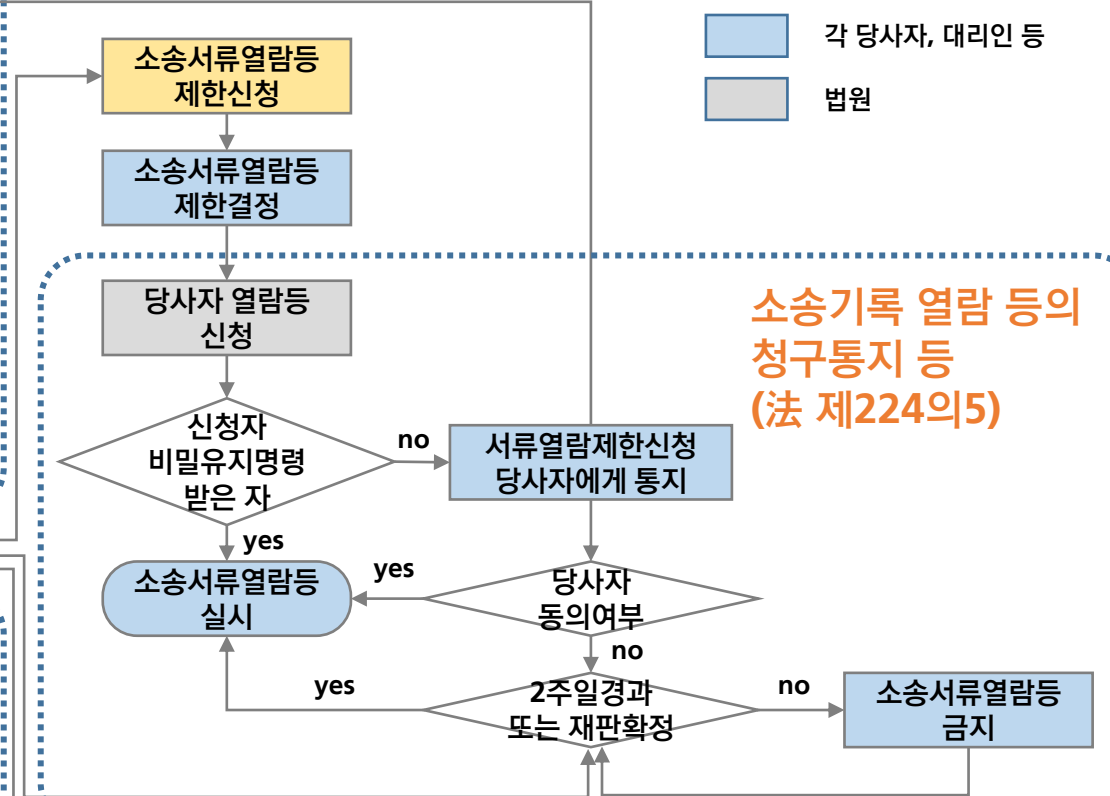
생산능력범위수량이
없는 경우

비밀유지명령 (法 224의3)

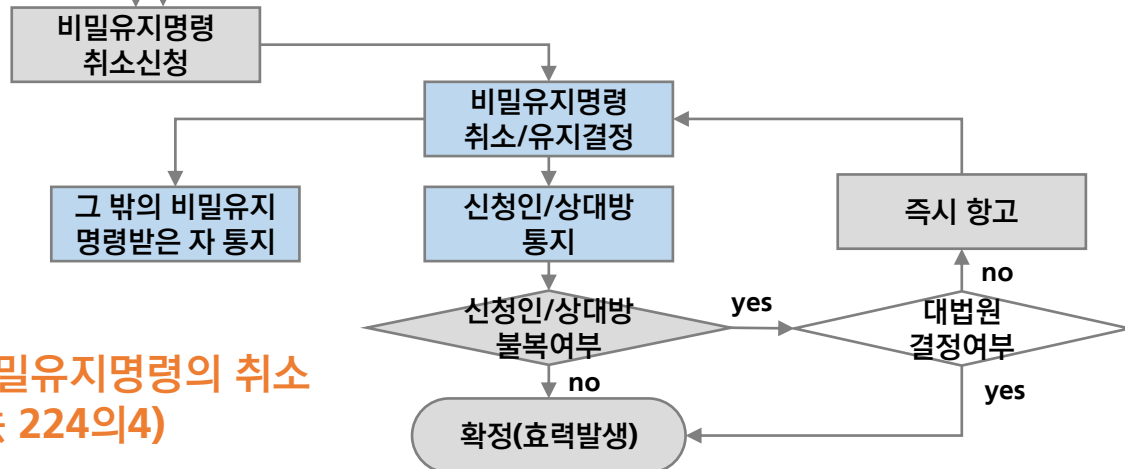


- 신청당사자
- 각 당사자, 대리인 등
- 법원

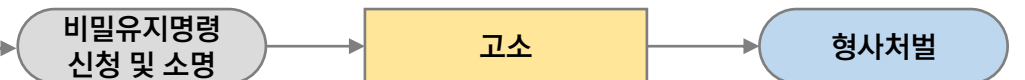
소송기록 열람 등의 청구통지 등 (法 제224의5)



비밀유지명령의 취소 (法 224의4)



비밀유지명령 위반죄(法 229의2)

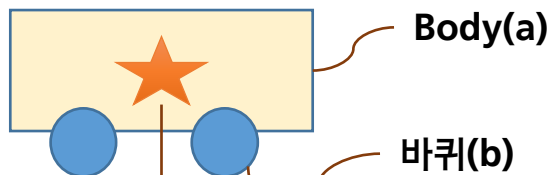


제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

甲-벤틀리의 특허권자

벤틀리의 구성요소: $a+b+c$

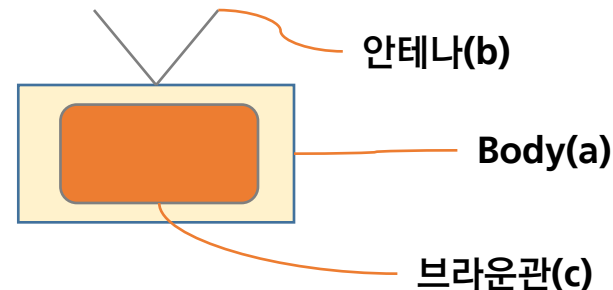


오직 벤틀리의 생산에만 사용되는 엔진(c)

- 乙이 c를 생산하는 행위는 침해인가?
- 乙이 c를 사용하는 행위는 침해인가?
- 甲으로부터 乙이 c를 구입하여 c를 사용하는 행위는 침해인가?

甲-TV의 특허권자

TV의 구성요소: $a+b+c$



- 乙, 丙의 행위는 직접침해인가?
- 어떻게 이를 막을 수 있는가?

乙

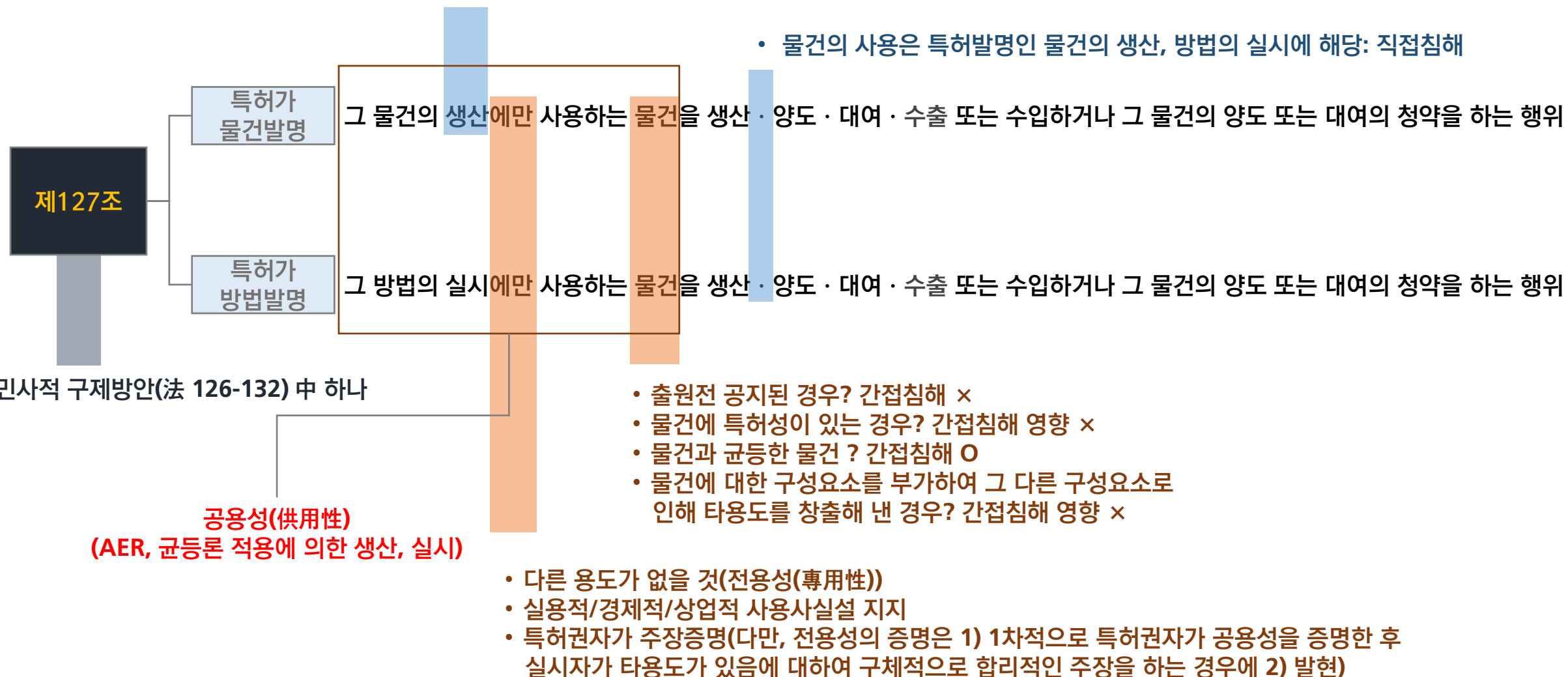
TV의 조립세트 판매

丙

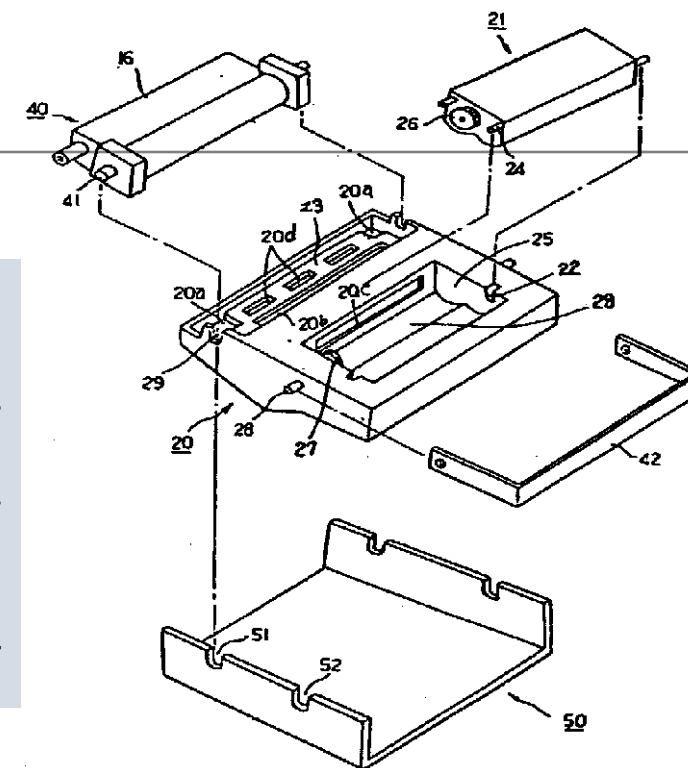
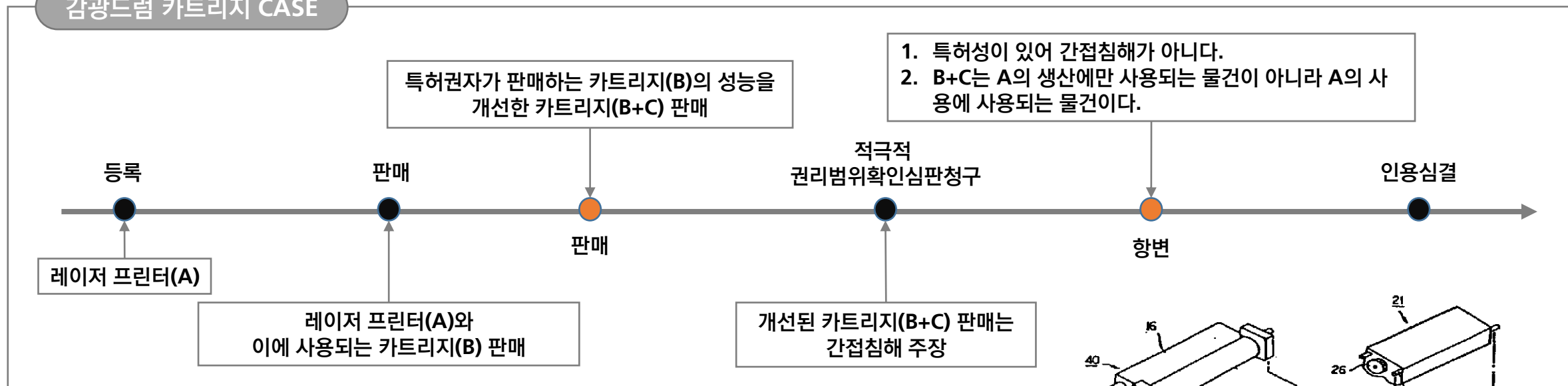
구입 후 집에서 조립 & 시청

- 부품의 교체가 생산에 해당하는지 여부: 소모품, 비소모품을 달리함/다만 최근 판례는 제품의 동일성 유지 관점 적용
- 국내에서의 생산만 해당(반제품 사건)

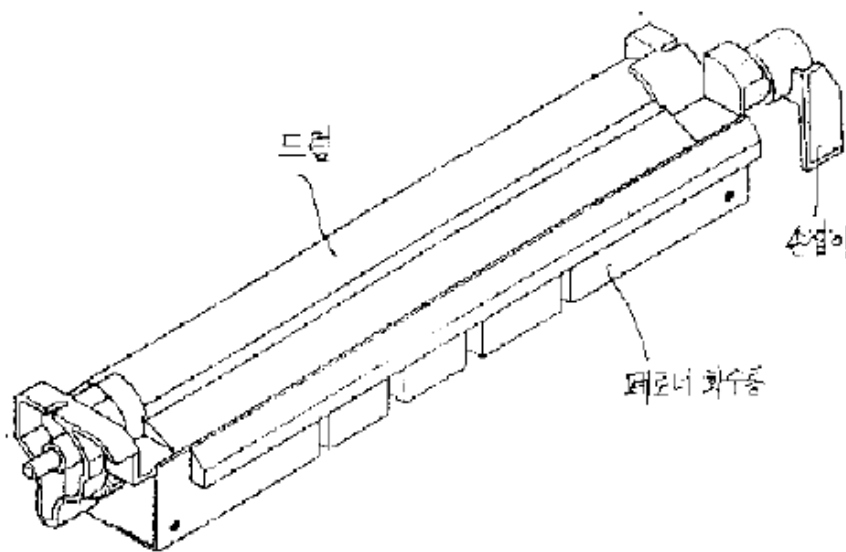
• 물건의 사용은 특허발명인 물건의 생산, 방법의 실시에 해당: 직접침해



감광드럼 카트리지 CASE

특허발명
구성

전자사진 방식의 화상기록 장치에 있어서,
 감광드럼(4), 트리닝부(16) 및 대전기(5)를 일체로 유니트화한 **감광드럼유니트(40)**와,
 상기 감광드럼유니트(40)를 수납하는 드럼섹션(23)과 토너박스(21)를 착탈 가능하도록 하는
 토너섹션(28)을 가진 **현상유니트(20)**와,
 상기 감광드럼유니트(40)의 위치결정 부재(41)와 상기 현상 유니트(20)의 위치결정부재(28)를
 가이드하는 가이드홈(51,52)을 가진 기기 **본체 프레임(50)**을 가지도록 구성하여,
 소모품인 감광드럼유니트, 토너박스, 현상유니트를 별도로 가져 경제적으로 합과 동시에 현상유니트의
 위에 감광드럼유니트, 토너박스가 수납가능 하도록 하여 사용자의 취급을 편리하게 한 것을 특징으로
 하는 화상기록 장치



확인대상발명 구성

(가)호도면에 도시된 드럼 카트리지는, 페토너통을 별도로 구비하고 있는 여타의 드럼 카트리지들이 갖는 문제점을 개선하기 위해서, 페토너 적재공간을 드럼유니크와 일체로 형성시켜 놓았는데, 특히 상기 드럼의 사용수명과 상기 드럼주변의 여유공간을 감안하여 상기 페토너 적재공간을 적정크기로 형성시킴으로써 사용중에 페토너 회수통을 교환해야 하는 불편함을 배제한다. 즉, (가)호도면에 도시된 드럼 카트리지를 사용하는 경우는 드럼을 교체할 때까지 별도로 페토너를 회수할 필요가 없고, 상기한 바와 같은 (가)호도면의 드럼 카트리지로 교체하는 것에 의해 일괄적으로 교체가 이루어지도록 한다.

대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580

[1] 특허법 규정에서 말하는 「생산」이란 특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물건(物件)을 만들어 내는 모든 행위를 의미하고 공업적 생산물의 생산 이외에도 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계 본체에 장착하는 것도 포함한다 할 것이며, 특허발명의 대상 또는 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자 측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 「생산」 「에만」 사용하는 물건에 해당한다고 보아야 할 것이다.

▶ 생산에만에 해당하기 위한 요건으로 1) 본질적인 구성요소에 해당할 것, 2) 다른 용도로 사용되지 않을 것, 3) 널리 쉽게 구할 수 없는 물품일 것, 4) 교체가 예정되어 있을 것, 5) 특허권자가 제조 판매하고 있을 것의 5가지 요건을 설시

[2] 확인대상발명의 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, 확인대상발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 페토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도, 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다.

▶ 특허요건 판단과 침해 판단은 무관함을 설시

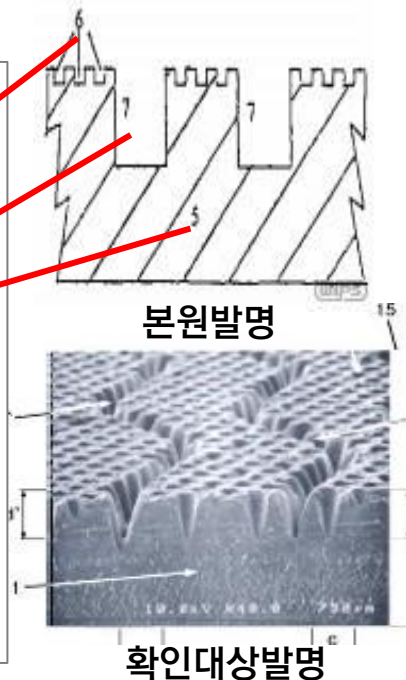
대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 【권리범위확인(특)】

확인대상발명은 소형유동채널이 결여되어 있고 마이크로 홀이 부가되어 있는 점에서 차이가 있다.

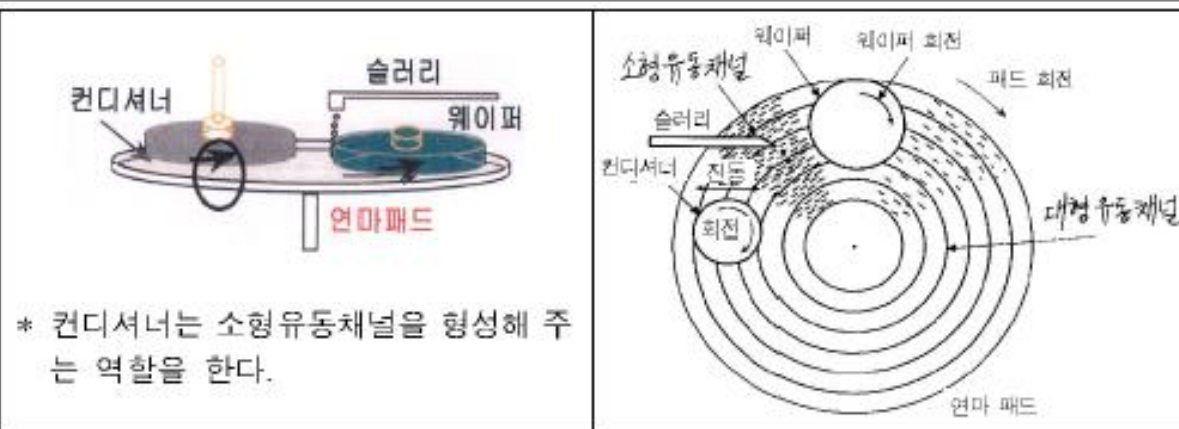
그러나 확인대상발명의 물건을 공급받은 사람이 연마패드를 사용하여 화학적 기계적 평탄화(chemical mechanical planarization, 통상 'CMP'로 약칭된다) 공정을 수행하는 때에는 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정(이하 '컨디셔닝 공정'이라 약칭한다)이 필수적으로 부가되고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 **확인대상발명의 연마패드에는 이 사건 특허의 소형유동채널의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고서 연마슬러리를 이동시키는 통로로 작용함으로써 이 사건 특허의 소형유동채널과 동일한 구조와 기능을 하는 원심 판시 줄무늬 홀이 반드시 형성된다.** 그러므로 확인대상발명의 물건은 이 사건 특허 물건의 생산에만 사용되는 것이어서 원고가 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 이 사건 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 하여 이 사건 특허권에 대한 간접침해에 해당된다고 할 것이다. 그 외에 컨디셔닝이 연마패드의 표면에 미치는 영향 내지 변화의 유무와 정도는 컨디셔너의 종류, 연마패드의 경도, 사용하는 슬러리의 종류 및 슬러리에 포함된 연마입자의 종류, 컨디셔너에 의하여 연마패드에 가하여지는 압력의 정도 등 여러 가지 요소에 따라 달라질 수 있다는 점(단순한 가능성에 불과), **확인대상발명이 마이크로 홀이라는 기술수단에 의하여 이 사건 특허 발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있어 진보된 발명일 수 있다는 점** 등의 사정은 그러한 결론에 영향이 없다는 것이다.

특허발명의 청구항 1항

입자를 함유하는 연마 슬러리를 연마 패드의 전체 표면에 걸쳐 함께 이동시키는 **대형 유동 채널**과 **소형 유동 채널**을 둘 다 포함하는 **표면 텍스처(texture)** 또는 패턴 (여기서, 표면 텍스처는 외부 수단에 의해서만 균일한 고체 중합체 시트의 표면에 형성된다)을 사용하는 동안 보유하는, 슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능을 지니지 않는 균일한 고체 중합체 시트를 포함하는 개선된 연마 패드.



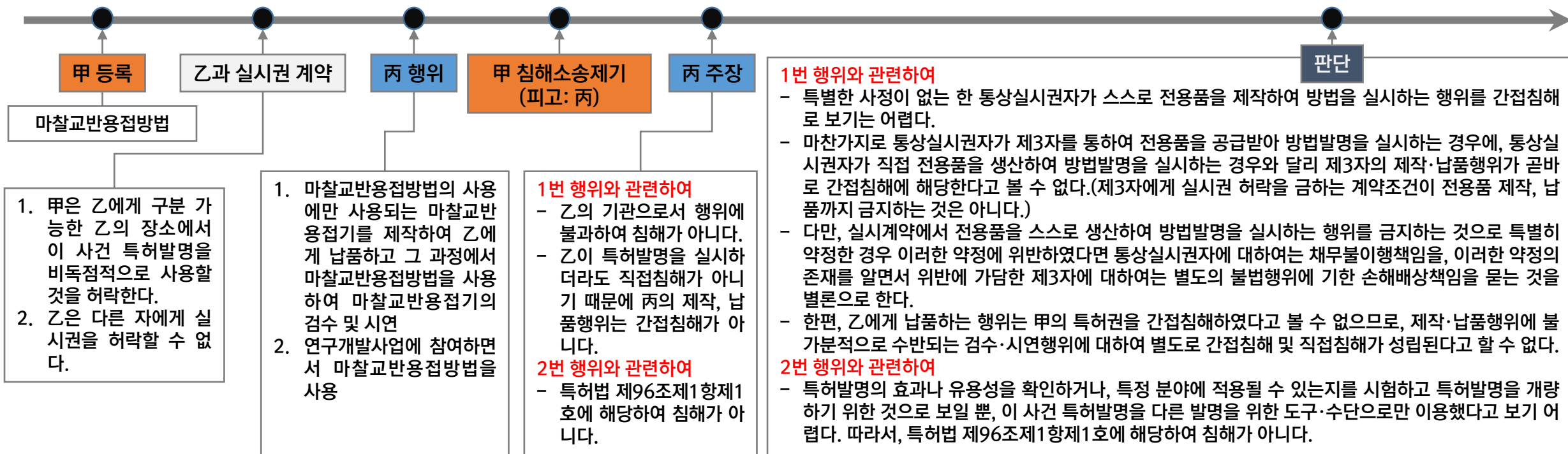
CMP 공정이란 연마패드 대상물(웨이퍼)을 연마패드의 표면 위에 접촉시킨 상태에서 연마 대상물과 연마패드를 각각 독립적으로 고속회전시키면서 미세한 연마입자를 포함하는 슬러리 용액을 연마패드에 떨어뜨려 연마패드와 대상물의 표면 사이로 흘러 들어가게 함으로써 슬러리 용액의 화학성분으로 대상물 표면을 연화시키면서 슬러리 내 연마입자의 유동을 통해 대상물의 표면을 연마하는 공정을 말한다.



* 컨디셔너는 소형유동채널을 형성해 주는 역할을 한다.

대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결 【손해배상(지)】

방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 ‘전용품’이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다. 또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.



실시권, 권리소진이 적용되는 물건 등과 같이 정당한 권원을 가진 자가 특허발명을 실시하거나 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96) 등에서 특허발명을 실시하여 직접침해가 아닌데, 그 자에게 간접침해행위에 해당하는 물건을 생산하여 양도 등을 하는 행위

중

방법의 발명(이하 '방법발명'이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 '전용품'이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다. 또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290025).

특허발명의 실시를 국외에서 하여 직접침해가 아닌데, 그 자에게 국내에서 간접침해행위에 해당하는 물건을 생산하여 양도 등을 하는 행위

중

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110).

1) 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 2) 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 3) 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 4) 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합)).

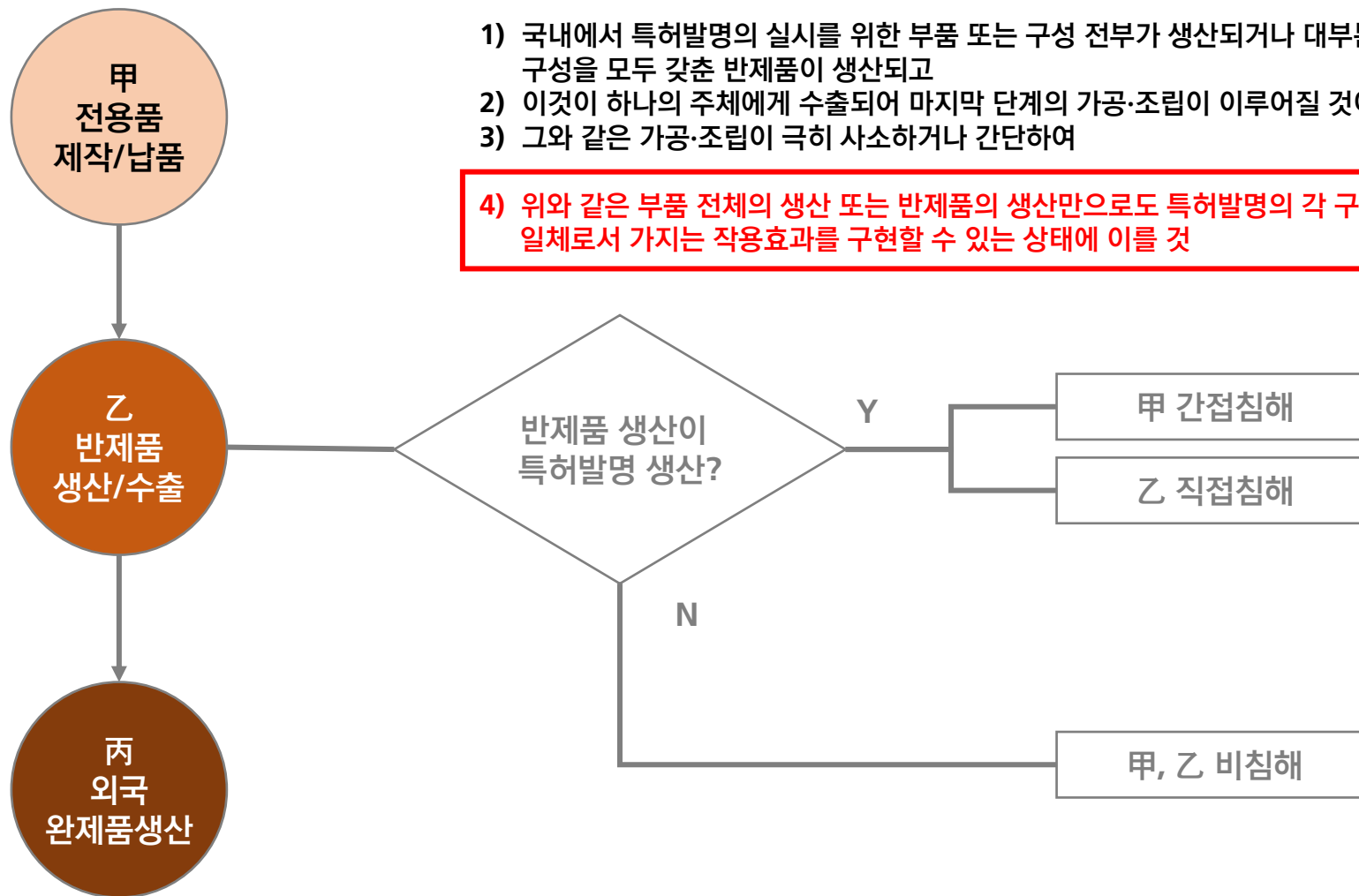
최종 특허발명의 실시를 업이 아닌 개인적, 가정적으로 유도하여 직접침해가 아닌데, 그 자에게 간접침해행위에 해당하는 물건을 생산하여 양도 등을 하는 행위

독

특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 확인대상발명의 감광드럼카트리지가 특허발명의 본질적 구성요소이고 타용도로는 사용되지도 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라 레이저 프린터 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고 특허권자가 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 벗어날 수 없다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후 2580).

속지주의의 원칙

속지주의의 원칙의 예외 인정

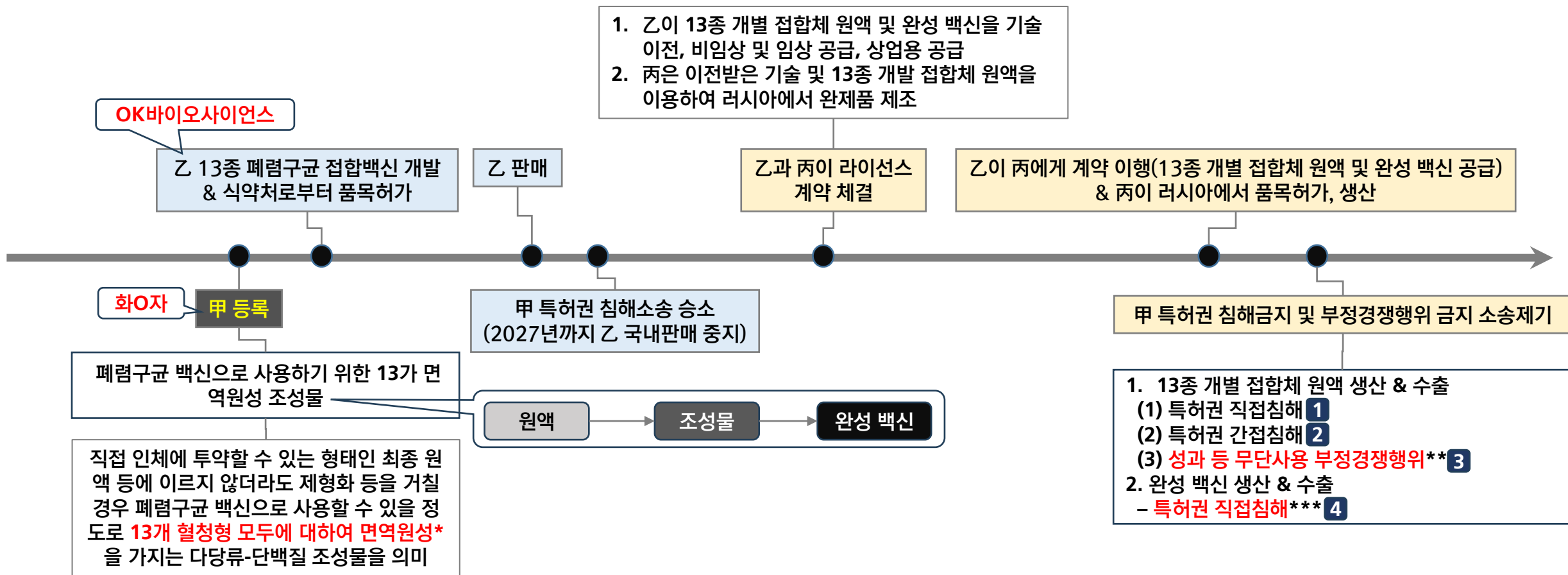


- 1) 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고
- 2) 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며
- 3) 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여

4) 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이를 것

일체성을 유지하여,
All Elements Rule을
적용할 수 있는 상태

특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙
을 고려하여 엄격하게 판단



* 폐렴구균 다가 접합체 백신을 연구·개발하는 기술 분야에서 기술적 어려움으로 인식되어 오던 **가수의 증가에 따른 면역반응 저하 내지 억제** 등을 극복하고, 13종의 폐렴구균 항원에 대해 면역원성을 가지는 조성물을 발명함으로써, 폐렴구균 백신의 적용범위(coverage)를 넓힘

** 부정경쟁방지법 제2조제1호(파)목: 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

*** 제96조제1항제1호가 쟁점이 된 사건으로, 원고 甲은 1) 乙이 연구·시험의 주체인 丙과 별개의 법적 지위에서 자신의 경제적 이익을 위하여 제1차 내지 제4차 백신을 생산하였고 연구·시험 결과에 대한 직접적 이익은 오로지 丙에게만 귀속되었으므로 특허법 제96조제1항제1호가 적용될 수 없다는 취지의 주장과 2) 특허법 제96조 제1항 제1호에서 말하는 연구·시험은 특허법의 속지주의 원칙에 따라 **국내**에서의 연구·시험을 의미하므로, 러시아에서의 품목허가를 위하여 생산된 제1차 내지 제4차 백신에는 특허법 제96조제1항제1호가 적용될 수 없다고 주장 및 3) 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구 또는 시험에 해당한다고 하기 위해서는 특허발명의 실시 행위 자체가 연구·시험을 하기 위한 경우, 예컨대 특허성의 확인이나 개량발명 등을 목적으로 한 것이어야 하는데, 丙이 러시아에서 수행한 비임상시험 또는 임상시험 등의 목적은 러시아에서 의약품 품목허가를 취득하여 궁극적으로 **상업적 이익**을 얻기 위한 것이므로, 위 규정의 연구 또는 시험으로 볼 수 없다고 주장하였다.

1 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치고(이른바 '특허권의 속지주의 원칙'), 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 물건이 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 한다(이른바 '구성요소 완비의 원칙'). 한편 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다. **이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.**

1) 13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하는 공정 과정에서 **13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율 및 혼합순서, 혼합할 때의 pH, 온도, 교반속도, 교반시간 등 혼합조건은 폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물을 구현하는 데에 적지 않은 영향**을 미칠 수 있으므로, 13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하여 13가 면역원성 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없다.
 2) 위 혼합 공정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율, 혼합순서, 혼합조건이 제대로 갖춰지지 않으면 **13가 면역원성이 구현되지 않을 수 있으므로**, 13종 개별 접합체 원액의 생산만으로도 이 사건 제1항 발명의 작용효과인 13가 면역원성을 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 할 수 없다.
 3) 피고가 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 이 사건 특허권에 대한 직접침해에 해당하지 않는다.

2 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).

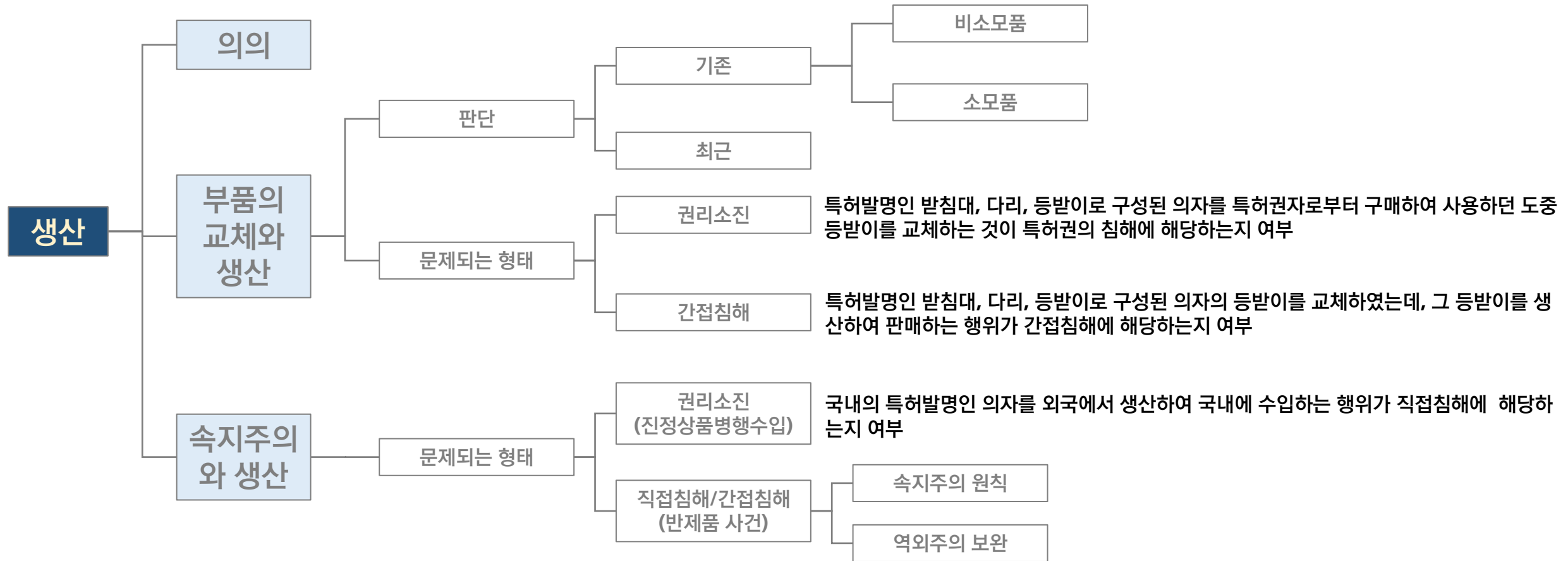
피고가 생산한 13종 개별 접합체 원액은 **모두 수출되어 국외에서 완성품으로 생산**되었으므로 이 사건 특허권에 대한 간접침해가 성립하지 않는다

3 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목은 보호대상인 '성과 등'의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과 등'을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 이러한 성과 등이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진' 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다. 또한 위 (파)목이 정하는 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 6. 25. 선고 2019다282449 판결, 대법원 2022. 10. 14. 선고 2020다268807 판결 등 참조).

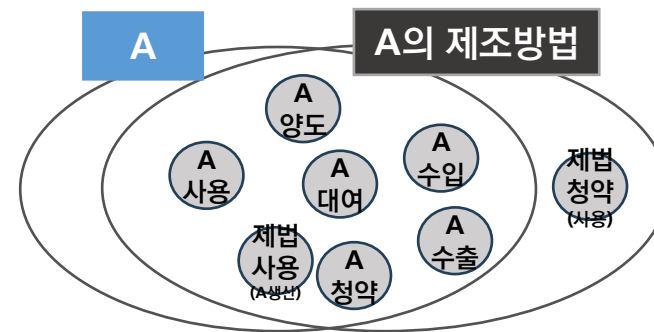
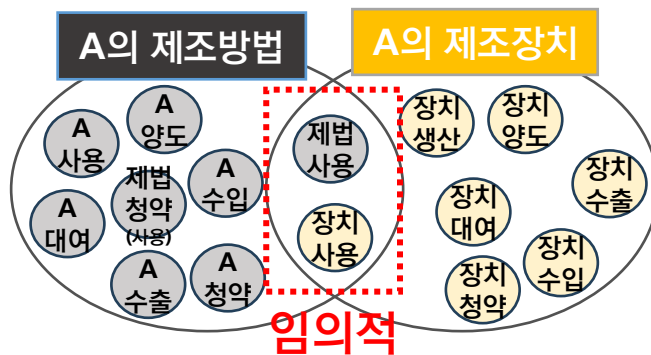
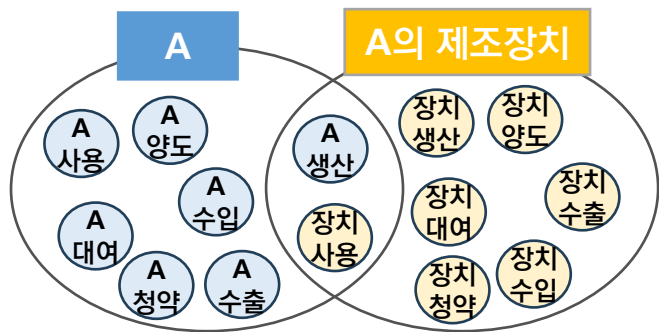
1) 13종 개별 접합체를 생산하는 것은 **누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역**에 속한다고 보아야 하므로, 13종의 각 개별 접합체 그 자체는 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등이라고 할 수 없다.
 2) 설령 13종 개별 접합체가 원고의 '성과 등'에 해당한다고 하더라도, 원고들이 제출한 증거만으로는 피고가 원고의 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하였다고 인정하기에도 부족하다.
 3) 피고가 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호(파)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

4 특허법은 발명을 보호·장려하는 한편 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조). 이에 특허법은 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 하면서도(특허법 제94조 제1항 본문) 제96조 제1항 제1호에서 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다. 이하 같다)을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다. 특허법 제96조 제1항 제1호는 특허권의 효력이 미치지 않는 특허발명 실시의 요건으로 **그 실시의 목적이 연구 또는 시험일 것을 정하고 있을 뿐이다.** 다만 이는 누구든지 특허발명을 연구 또는 시험하여 그 내용을 확인·검증하고 더욱 개량된 발명을 이어나갈 수 있도록 특허권의 효력을 제한함으로써 특허법이 추구하는 '발명의 보호'와 '발명의 이용 도모' 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이므로, 위 규정의 적용 여부를 판단할 때에는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 특허권자 등의 정당한 이익도 함께 고려할 필요가 있다. 이와 같은 규정의 문언과 취지 등을 종합하면, 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을 연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.

1) 피고는 2018. 11. 7.부터 2020. 5. 27.까지 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하는 제1차부터 제4차까지 네 차례 백신을 생산하여 러시아 제약회사인 丙에 무상으로 제공하였다.
 2) 제1, 2, 4차 백신은 모두 완성 백신의 유효성과 안정성 등을 확인하는 **러시아에서의 비임상시험 또는 임상시험에 사용하기 위하여 생산**되었고, 제3차 백신은 **완성 백신 제조기술이 丙에게 제대로 이전되었는지를 확인하는 분석시험에 사용하기 위하여 생산**되었다.
 3) 피고는 丙에 제4차까지 **네 차례 백신을 제공하면서 그 백신의 용도가 연구 또는 시험을 위한 것이고 판매용이나 유통용이 아님을 표시**하였다.
 4) 제1차부터 제4차까지 백신이 판매용이나 유통용으로 제공되었다거나, 피고가 위 제4차까지의 백신 이외에 다른 완성 백신을 생산하였다고 볼 만한 자료는 없다.
 5) 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고가 위와 같이 네 차례 백신을 생산한 행위는 특허발명인 이 사건 제1항 발명을 연구 또는 시험하기 위하여 그 특허발명을 실시한 것에 해당하고, 그로 인하여 특허권자 또는 전용실시권자인 원고들의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하였다고 보기는 어려우므로, 피고의 위 행위에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용되어 특허권의 효력이 미치지 않는다.



국내의 특허발명인 받침대, 다리, 등받이로 구성된 의자의 구성 대부분을 국내에서 생산하여 수출한 후, 최종 가공, 조립만이 외국에서 이루어진 경우 국내에서 생산하는 것이 직접침해/간접침해에 해당하는지 여부



특허발명	A	A의 제조방법(方1)	A의 제조장치(裝1)
실시중			
A	직접침해	- 方1의 실시: 직접침해 - 다른 方의 실시: 비침해	- A의 생산 - 裝1의 사용: 직접침해 - 다른 裝의 사용: 비침해 - A의 사용 · 양도 · 대여 · 수출 · 수입 · 청약: 비침해
A의 제조방법(方1)	직접침해(∵ A의 제조방법의 실시는 물건생산의 청약을 제외하고는 모두 A의 실시에 해당함)	직접침해	- A의 제조방법의 사용 - 裝1의 사용: 직접침해 - 다른 裝의 사용: 비침해 - A의 제조방법의 사용에 의한 A의 사용 · 양도 · 대여 · 수출 · 수입 · 청약: 비침해
A의 제조장치(裝1)	- A의 제조장치의 사용 – 직접침해 (∵ A의 생산에 해당) - A의 제조장치의 생산 · 양도 · 대여 · 수출 · 수입 · 청약 - 타용도가 있는 경우: 비침해 - 타용도가 없는 경우: 간접침해	- A의 제조장치의 사용 - 方1의 사용: 직접침해 - 다른 方의 사용: 비침해 - A의 제조장치의 생산 · 양도 · 대여 · 수출 · 수입 · 청약 - 타용도가 있는 경우: 비침해 - 타용도가 없는 경우: 간접침해	직접침해

제132조(자료의 제출) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 **해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정**에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 **영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)**에 해당하나 **침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는** 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출 명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 **자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.**

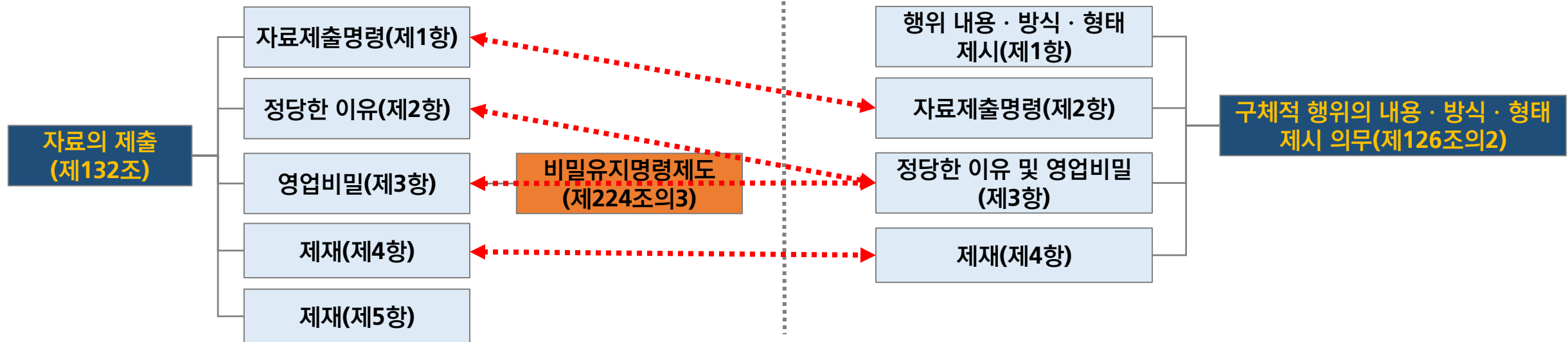
⑤ 제4항에 해당하는 경우 **자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는** 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

제126조의2(구체적 행위의 내용·방식·형태 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하여야 한다.

② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시할 수 없는 **정당한 이유**가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 **정당한 이유**가 있으면 그러하지 아니하다.

③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 “침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때”를 “구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”로 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 진실한 것으로 인정할 수 있다.



죄명	구성요건	처벌		반의사 불벌죄	친고죄	양벌규정	비고
		징역/금고	벌금				
침해죄 (法 225)	특허권 또는 전용실시권을 침해한자	7년이하 징역	1억원 이하	○	×	○	물수* · 교부
비밀누설죄 (法 226, 226의2)	지식재산처 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원 (전문기관 또는 전담기관 의 임직원이거나 임직원이었던 사람 포함)이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우	5년이하 징역	5천만원 이하	×	×	×	
	전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중 에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우*	2년이하 징역/ 금고	1천만원 이하	×	×	×	
위증죄 (法 227)	이 법에 따라 선서한 증인 · 감정인 또는 통역인이 특허심판원 에 대하여 허위의 진술 · 감정 또는 통역을 한 경우	5년이하 징역	5천만원 이하	×	×	×	특허취소신청에 대한 결정 또는 심결 확정전 자수시 감경. 면제
허위표시죄 (法 228)	허위표시의 금지(法 224)에 위반한 자	3년이하 징역	3천만원 이하	×	×	○	
거짓행위죄 (法 229)	거짓이나 그 밖의 부정한 행위로써 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자	3년이하 징역	3천만원 이하	×	×	○	
비밀유지명령 위반죄 (法 229의2)	국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3 제1항에 따른 비밀 유지명령을 위반한 자	5년이하 징역	5천만원 이하	×	○	×	
외국에의특허출원금지/ 비밀취급명령 위반죄 (法 229의3)	제41조제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 을 위반한 자	5년이하 징역	5천만원 이하	×	×	○	×

* 특허법은 필요적 물수, 실용신안법은 임의적 물수

** 실용신안법은 전문심리위원에 대한 벌칙 규정이 없음

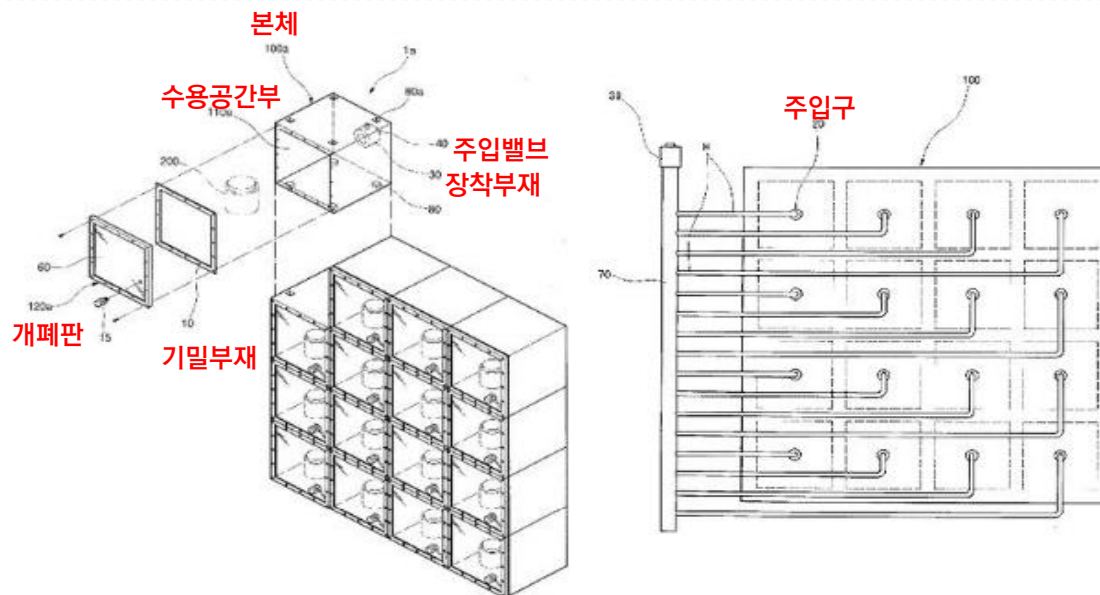
대법원 2015. 8. 13. 선고 2013도10265 판결 【특허법 위반】

특허법 제224조 제3호는 같은 조 제1호의 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건을 생산·사용·양도하기 위하여 광고 등에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시(이하 ‘특허된 것 등으로 표시’라 한다)를 하는 행위를 금지하고 있다. 위 규정의 취지는 **특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호**하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다.

【청구항 9】

일면이 개방된 수용공간부로 유골이 놓여진 납골함을 안치한 후, 위 수용공간부의 전면으로 그 수용공간부와 대응되는 개폐판이 결합되는 본체로 구성된 납골함 안치대에 있어서, 위 개폐판(120a)과 수용공간부(110a)의 테두리 본체(100a) 사이에는 기밀부재(10)를 구비하여 위 개폐판이 볼트에 의해 결합되고, 위 수용공간부의 본체 후방면에는 그 수용공간부와 통하도록 돌출되게 형성된 주입구(20)와,

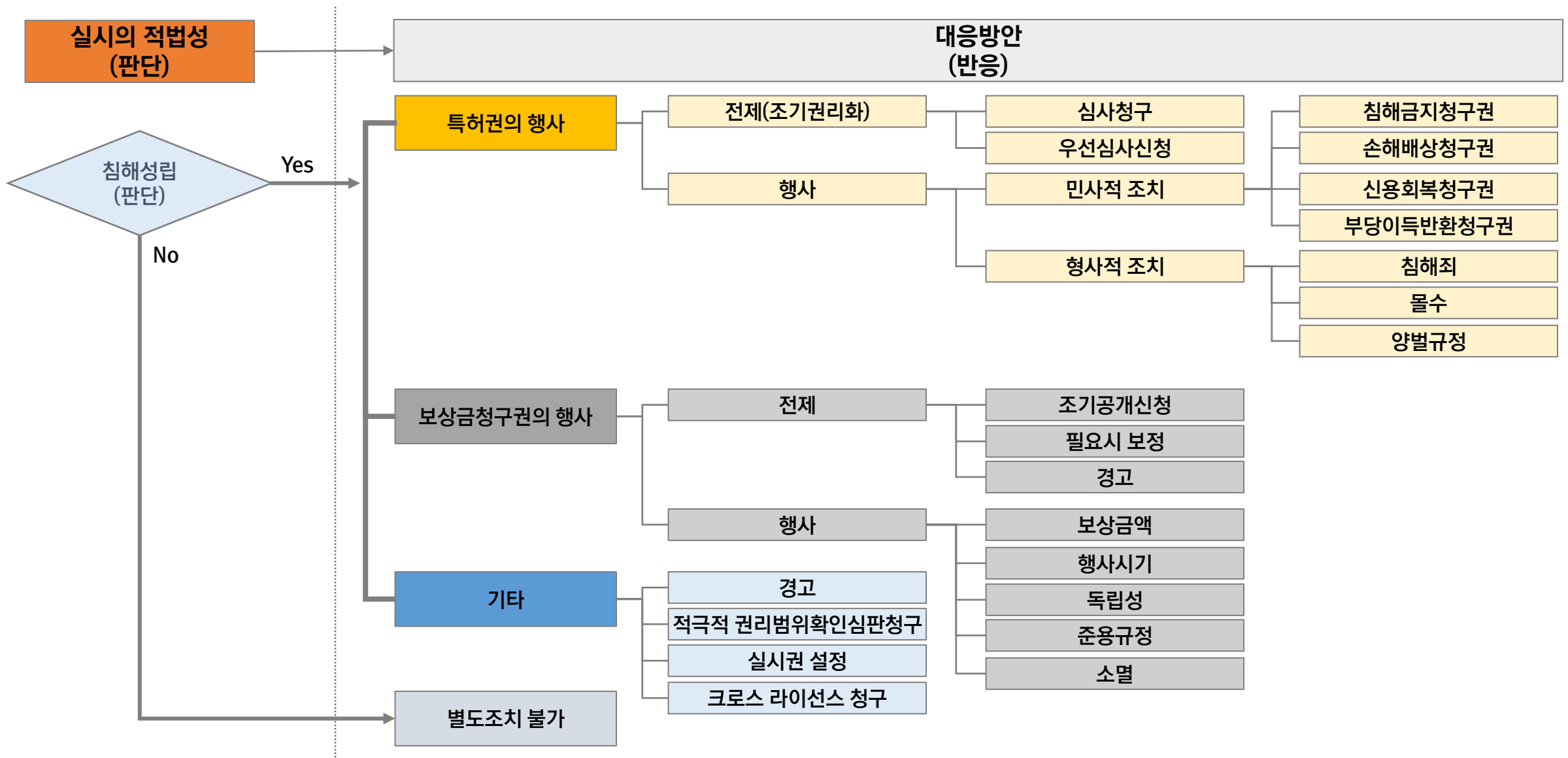
위 주입구에 중앙으로 그 주입구와 통하여 가스가 주입되어 지는 주입밸브(40)가 결합되는 장착부재(30)가 장착되는 것을 특징으로 하는 납골함 안치대

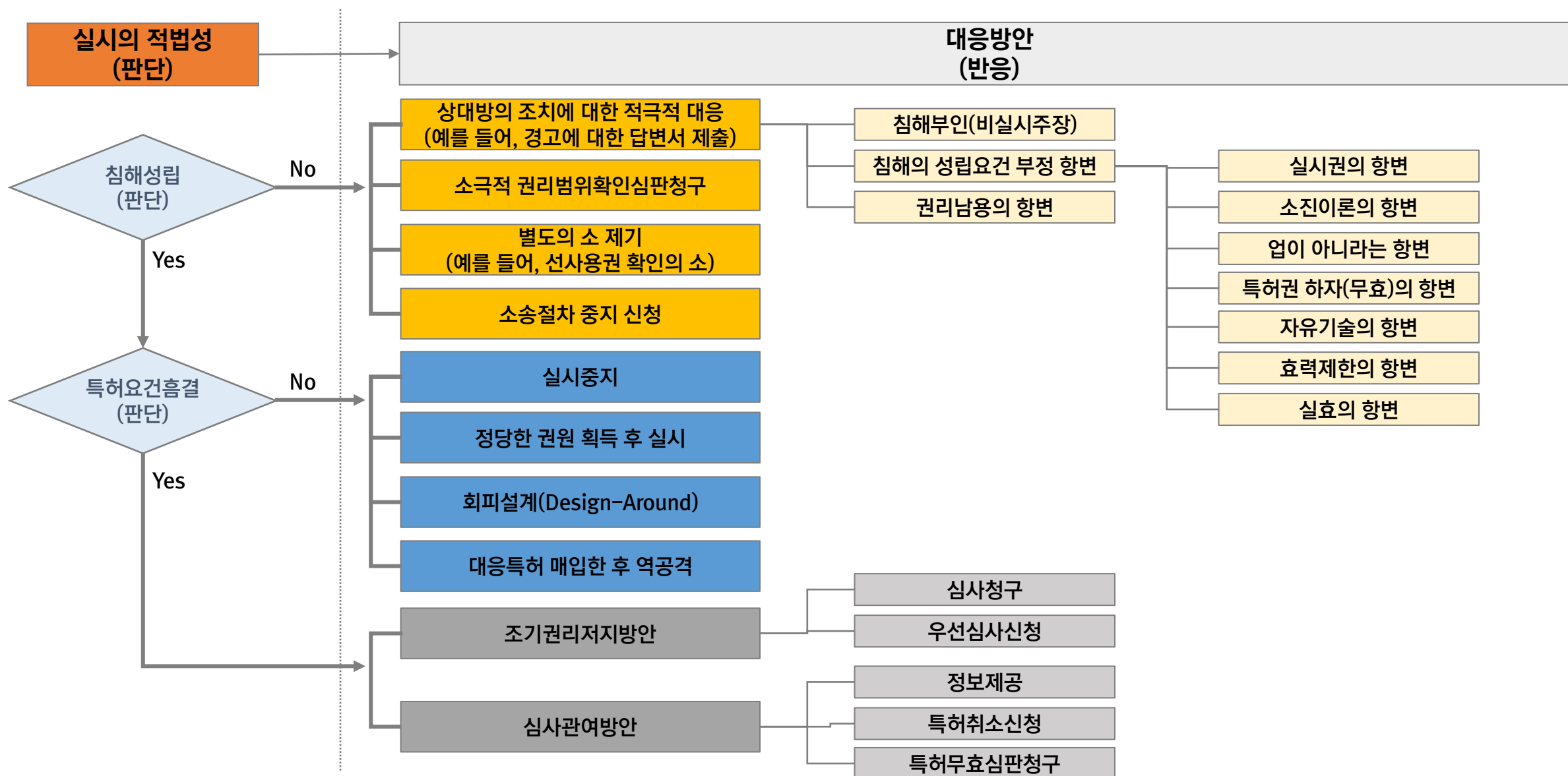


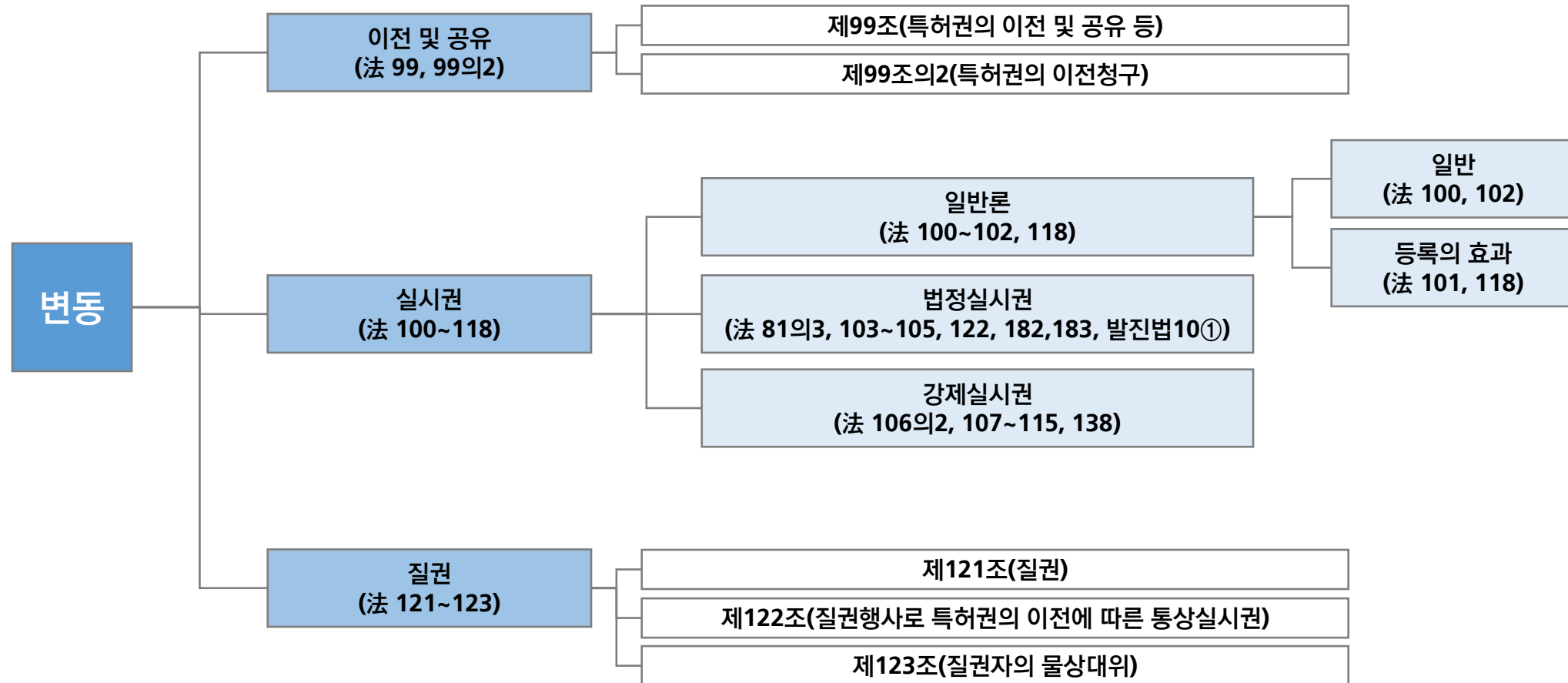
허위, 과장광고에 대하여 대법원 1993. 8.13. 선고 92다52665 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007다44194 판결 등은 “상품의 선전·광고에 있어 다소의 과장이나 허위가 수반되는 것은 그것이 일반 상거래의 관행과 신의칙에 비추어 시인될 수 있는 한 기망성이 결여된다고 하겠으나, 거래에 있어서 중요한 사항에 관하여 구체적 사실을 신의성실의 의무에 비추어 비난받을 정도의 방법으로 허위로 고지한 경우에는 기망행위에 해당한다.”고 판시하고 있다. 위와 같은 판결의 취지에 따르면, 모든 허위 표시 행위가 처벌의 대상이 되는 것은 아니고, 일반 수요자의 관점에서 신의칙에 비추어 비난받을 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단되어야 한다. 따라서, 특허법 제228조, 제224조의 허위표시의 죄에 있어서도 위 입법 취지와 일반법리를 고려하면 “일반 공중의 오인 우려 여부”가 그 판단 기준이 될 수 있다.

(3) 피고인들이 실제 제조한 물건을 이 사건 제9항 발명과 대비하여 보면 가스주입구와 주입밸브가 수용공간부 ‘전방면’에 형성되어 있다는 점에서만 차이가 있고 나머지 구성은 동일하다.

(5) 이 사건 제9항 발명의 핵심적인 기술적 과제는 간이한 구조로 납골함 보관공간을 진공 또는 고압력(질소충전) 상태로 유지하여 유골의 부패와 변질을 최소화하는 데에 있고, 가스주입구와 주입밸브의 설치 위치 변경은 통상의 기술자가 보통 채용하는 정도의 기술적 구성의 변경에 불과하며, 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니한다고 보인다.







일반승계(상속)+
특정승계(양도)

제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등)

- ① 특허를 받을 수 있는 권리는 **이전**할 수 있다.
- ② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.
- ③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

효력

제38조

제99조(특허권의 이전 및 공유 등)

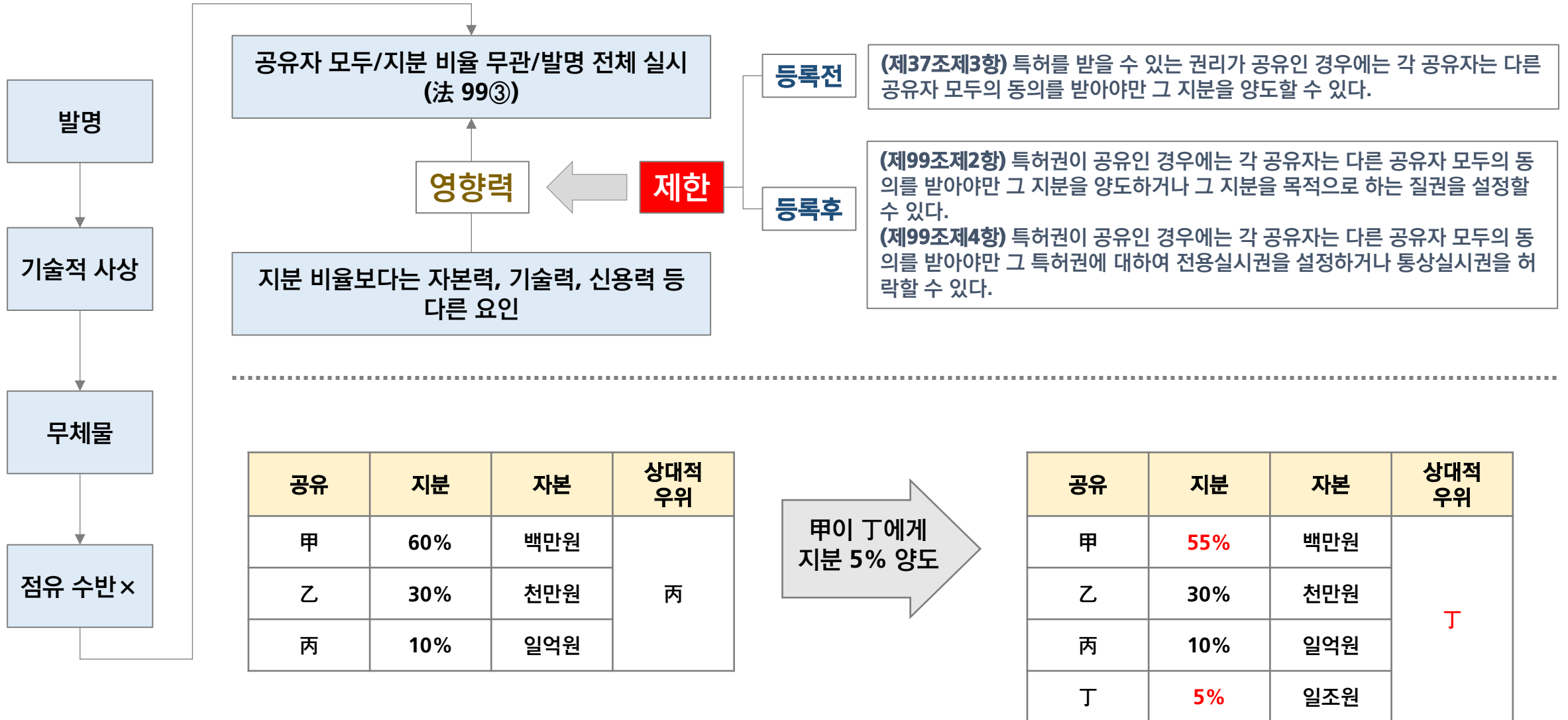
제101조제1항제1호, 제2항

효력

- ① 특허권은 **이전**할 수 있다.
- ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 **그 지분**을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
- ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
- ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 **그 특허권**에 대하여 전용실시권을 **설정**하거나 통상실시권을 **허락**할 수 있다.

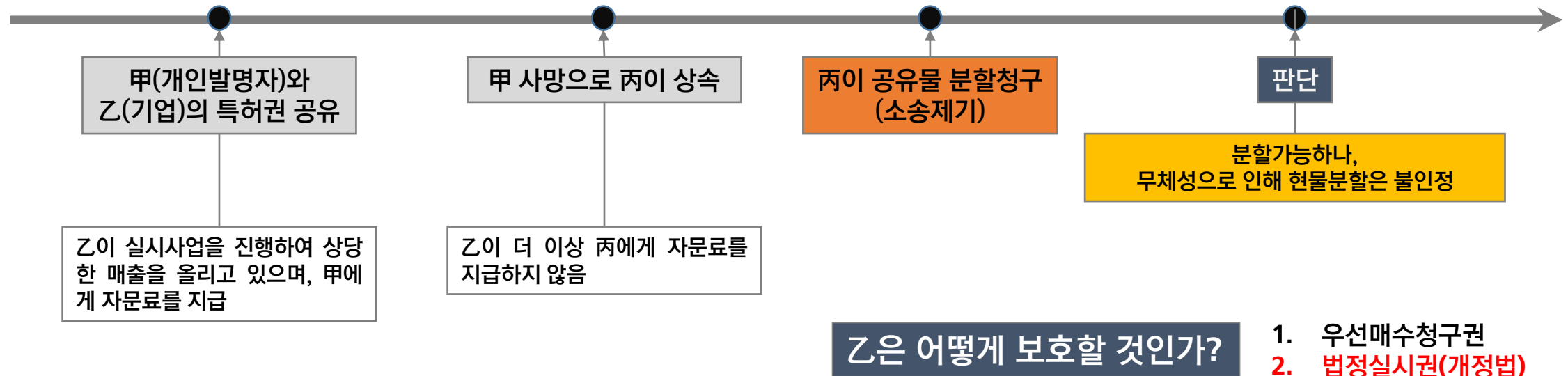
특허권 일부 지분에 대한
실시권 설정/허락은 불가

계약+등록을
의미



대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 【공유물분할】

특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 그 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동이 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다. 그렇다면 1) 특허권의 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물 분할청구권을 인정하더라도 **공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 위 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 2) 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다**



제122조(질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

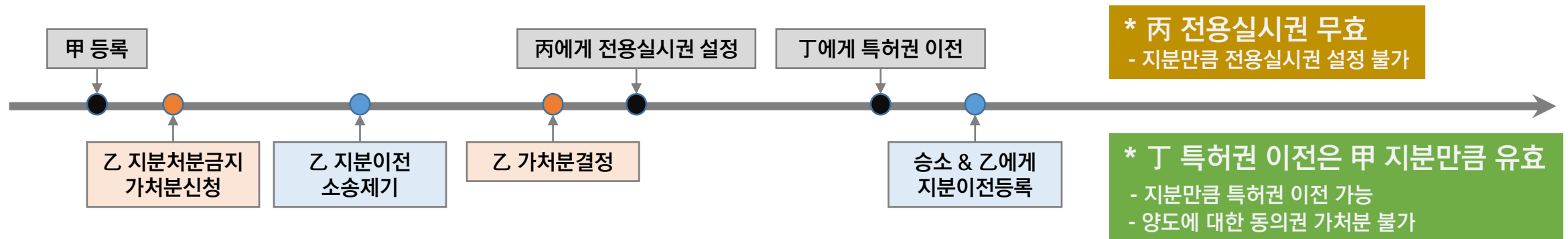
대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결 【특허권이전등록말소등】

[1] 특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

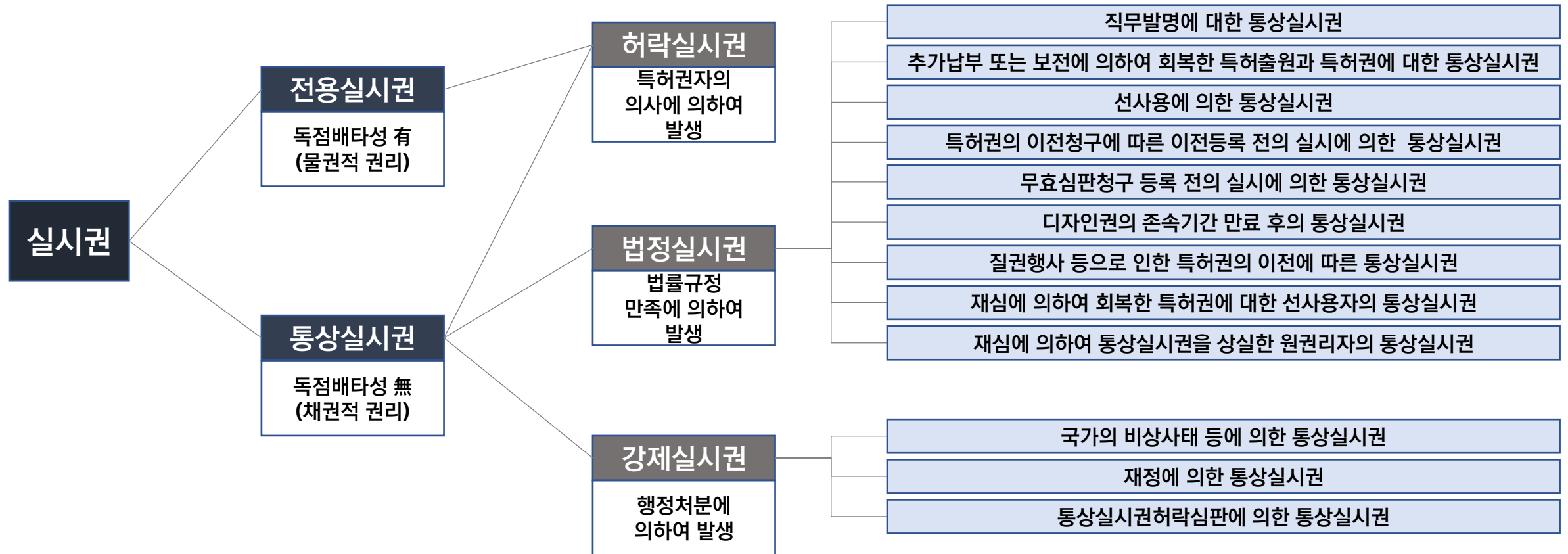
[2] 특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

[3] 특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

[4] 특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.



실시권이란 특허권자 이외의 자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다. 실시권은 **특허권의 침해가 되지 아니한 정당한 권원 중 하나**로서 특허권에 **부수적인 권리**이기 때문에 특허권이 존재하여야만 발생할 수 있고, 특허권이 소멸하면 실시권도 소멸한다.



대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결, 2016다260707 【손해배상(지)】

[1] 원고가 독점적 통상실시권자인지 여부:

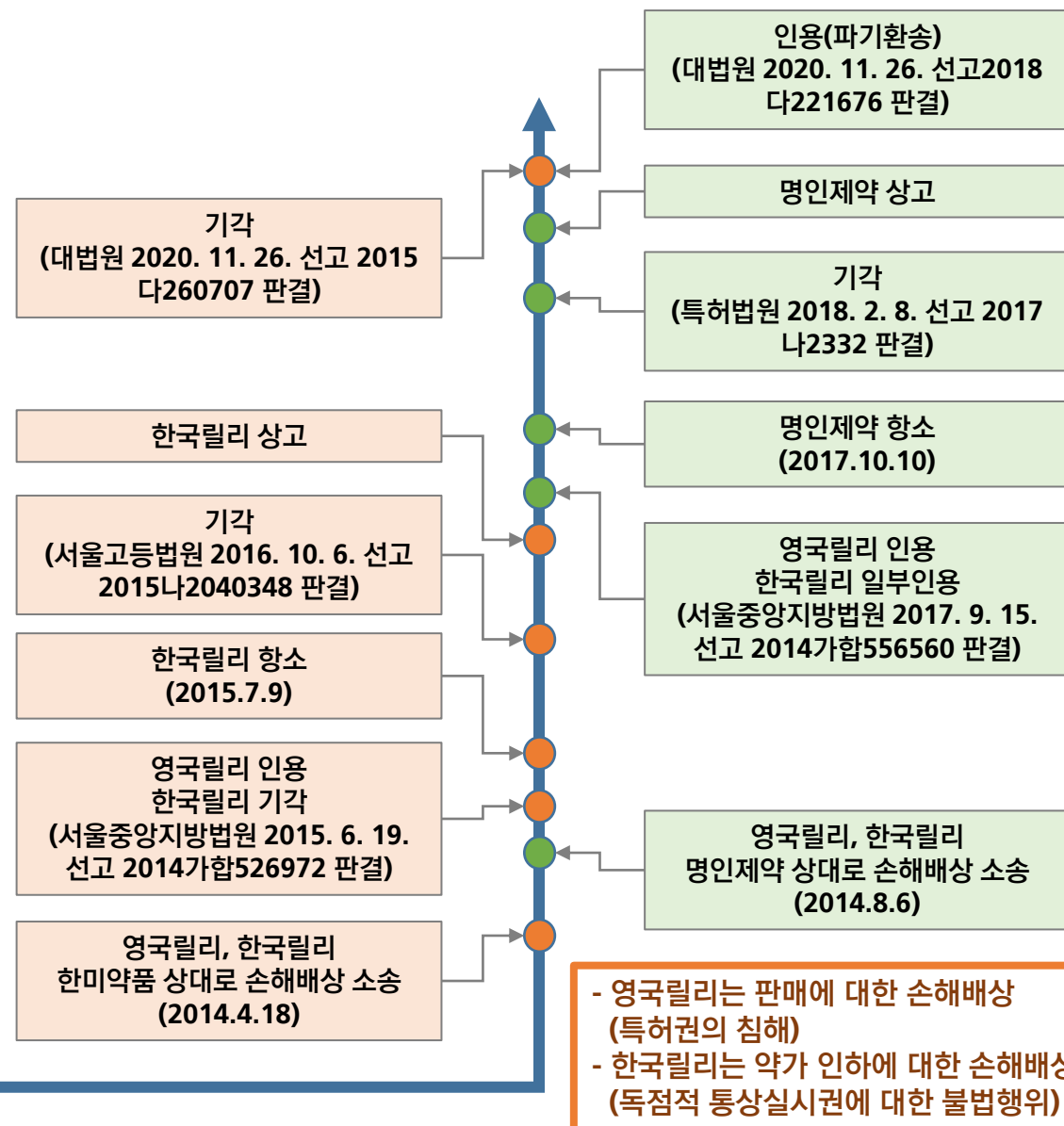
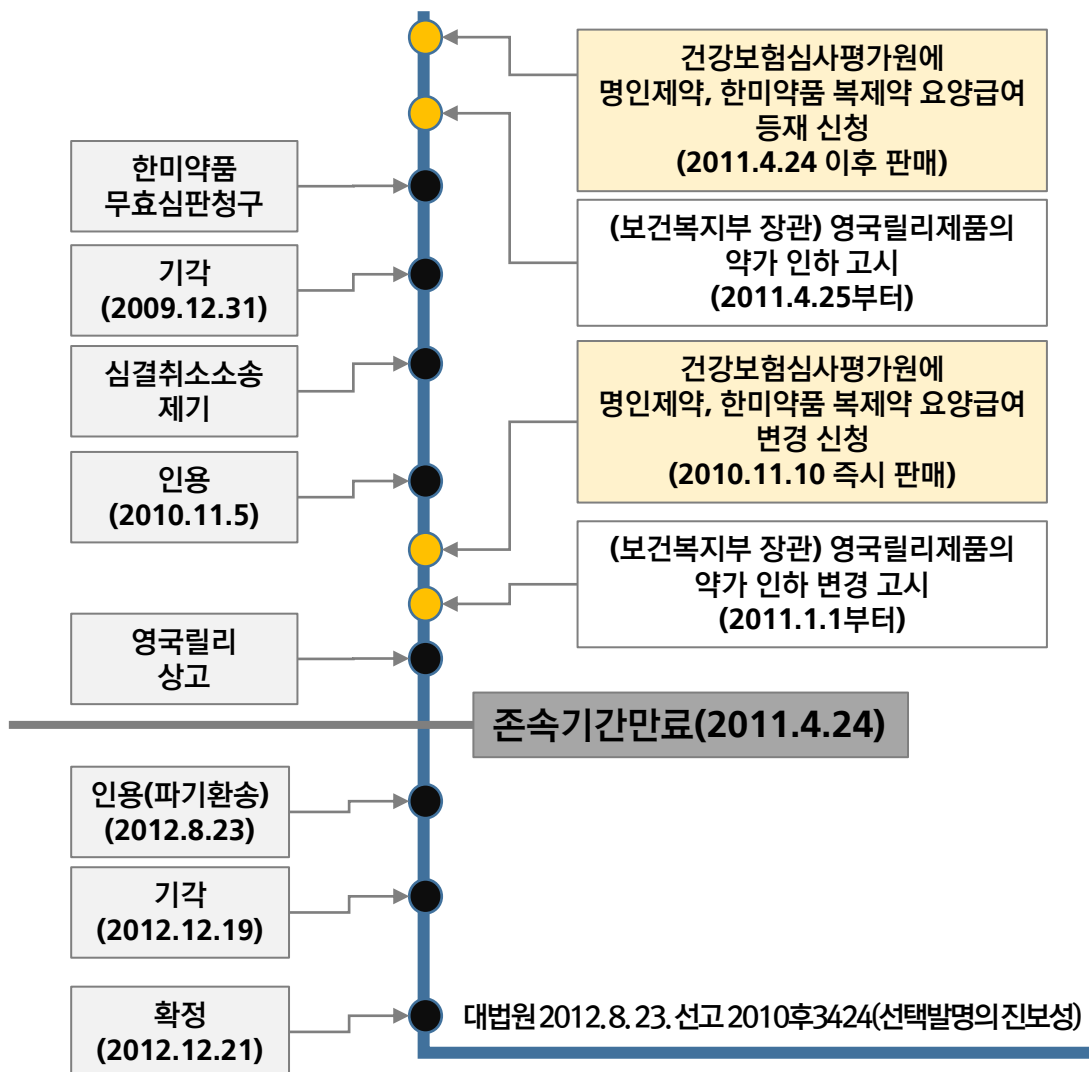
- 가. 원고와 특허권자 릴리 리미티드는 모두 일라이 릴리 앤드 컴퍼니(이하 '릴리 컴퍼니'라고 한다)의 자회사로서 서로 계열회사 관계에 있고, 원고만이 이 사건 특허발명의 특허권 존속기간 동안 특허제품인 원고 제품을 국내로 수입·판매해 왔으므로, 원고가 유일하게 이 사건 특허발명의 국내 수입·양도에 관한 허락을 받았다고 볼 수는 있다.
- 나. 그러나 제출된 증거만으로는 특허권자인 릴리 리미티드가 원고에 대하여 원고 외의 제3자에게 이 사건 특허발명의 특허권에 대한 통상실시권을 부여하지 않을 부작위 의무를 부담하기로 약정하였다고 보기 어렵다. 원고가 원고 제품에 관한 수입품목 허가를 받고 이를 국내에서 수입·판매할 수 있었던 근거는 릴리 컴퍼니와 체결한 공급유통 기본계약 제2.4조(Section 2.4) 등에 따른 것으로 보이는데, 위 **공급유통 기본계약은 이 사건 특허발명의 특허권에 대한 실시허락계약이 아니다**. 릴리 리미티드에게 특허 실시에 관한 대가인 실시료를 지급한 주체는 원고가 아니라 일라이 릴리 에스에이(Eli Lilly S.A.)이고 실시료율이나 실시료 액수를 알 수 있는 객관적인 자료도 없어, **릴리 리미티드가 원고에 대하여 위와 같은 부작위 의무를 부담하는 대가로 원고로부터 높은 실시료를 받아왔다고 보기도 어렵다**. 릴리 리미티드가 원고에 대하여 원고 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 않을 부작위 의무까지 부담할 사정을 찾기 어렵다.
- 다. 위와 같은 사정을 관련 법리에 비추어 살펴보면, **특허권자 릴리 리미티드가 원고에 대하여 원고 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 않을 부작위 의무를 부담하기로 명시적 또는 묵시적으로 약정했다고 단정하기 어렵으므로**, 원고를 이 사건 특허발명의 독점적 통상실시권자로 볼 수는 없다.

특허권자와 실시권자 사이에 체결된 계약이 독점적 통상실시권을 부여하는 계약에 해당하기 위해서는 계약의 내용상 특허권자가 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 아니할 의무를 부담하여야 하고, 단지 특허권자가 어느 한 실시권자에게만 실시권을 부여함에 따라 그 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하고 있다는 사정만으로 그러한 계약이 있었다고 보기 어렵다. 그러나 등록하여야만 그 효력이 발생하는 전용실시권 설정과 달리, 독점적 통상실시권의 허락은 당사자 간 의사 합의만 있으면 성립되고, 이러한 의사의 합치는 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다(특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332).

[2] 피고가 위법행위로 원고에게 원고 제품의 상한금액 인하라는 손해를 가하였는지 여부에 관하여(위법성과 인과관계):

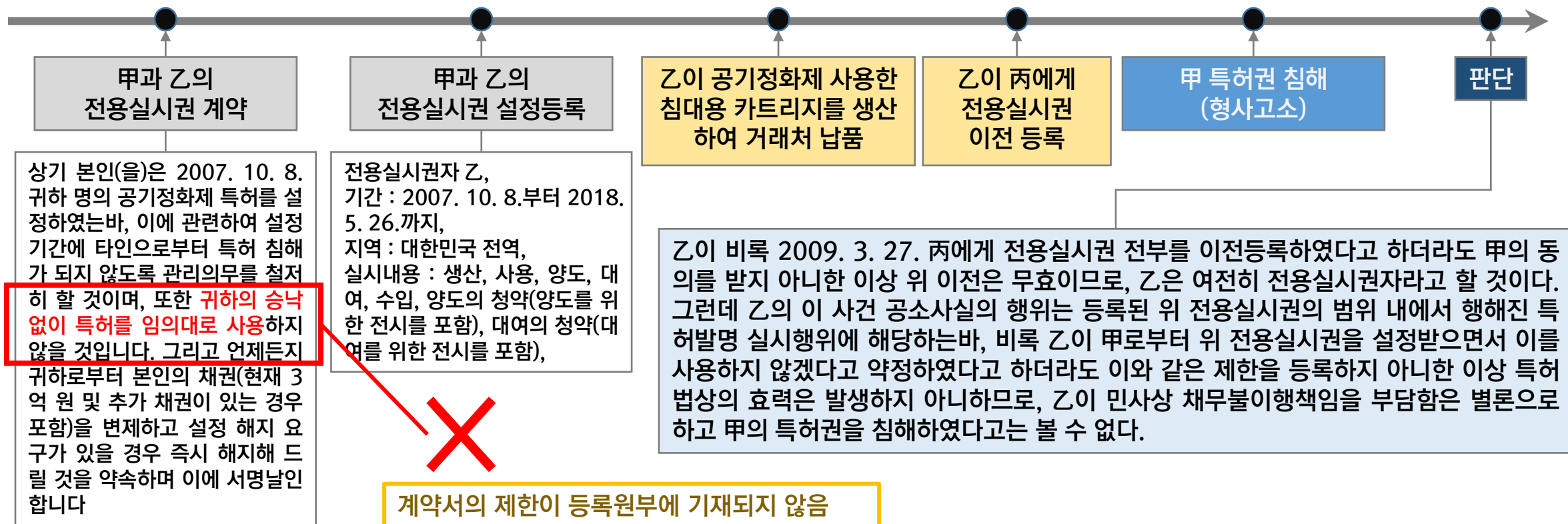
- 가. 원고가 약제급여목록표에 등재된 원고 제품의 상한금액에 관하여 가지는 이익은 국민건강보험법에서 정한 약제 상한금액 조정사유가 있는 경우 보건복지부장관의 적법한 조정에 따라 변동될 수도 있는 이익이다.
- 나. 피고는 원래 피고 제품을 이 사건 특허발명의 특허권 존속기간 만료 후 요양급여대상 약제로 판매하고자 이 사건 요양급여대상 결정신청을 하여 피고 제품이 약제급여목록표에 등재·고시되었고, 이는 관련 규정에 따른 것으로서 피고의 이 사건 요양급여대상 결정신청이 위법하다고 할 수 없다.
- 다. 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되어야 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되므로(특허법 제133조 제3항), 특허무효심결이 확정되기 전까지는 특허는 무효가 아니다. 그렇지만 피고는 특허법원이 진보성을 부정하는 판결을 선고하자 이를 근거로 관련 규정에서 원고 제품의 특허권에도 불구하고 피고 제품을 약제급여목록표 등재 후 즉시 요양급여대상 약제로 판매할 수 있는 사유로 예시한 **'특허분쟁의 승소가능성 등'**을 소명하여 **이 사건 판매예정시기 변경신청을 한 것으로, 이러한 피고의 행위를 위법하다고 평가하기는 어렵다**.
- 라. 피고 제품의 제조판매품목 신고 이전에 보건복지가족부 고시 제2009-182호로 원고 제품의 상한금액이 특허권 존속기간 만료일 다음날에 인하될 예정이라고 고시된 것은 피고가 아닌 다른 업체가 원고 제품의 제네릭 의약품의 요양급여대상으로 결정신청하였기 때문으로 보인다. 또한 피고의 이 사건 판매예정시기 변경신청은 원고 제품의 상한금액을 인하해 달라는 약제 상한금액 조정신청이 아니고, 제네릭 의약품인 피고 제품의 상한금액은 관련 규정에 따라 최초등재제품인 원고 제품 상한금액의 일정 비율로 정해지므로, 피고가 원고에게 원고 제품의 상한금액 인하라는 손해를 가할 의도로 이 사건 판매예정시기 변경신청을 했다고 보기도 어렵다. 나아가 원고 제품의 상한금액 인하 시행시기를 언제로 정할 지는 보건복지부장관의 재량에 달려 있다는 점은 앞서 본 바와 같다.
- 마. 원고 제품의 상한금액이 2011. 2. 1.부터 인하된 것은 보건복지부장관이 이 사건 고시를 했기 때문이지 피고가 피고 제품을 제조·판매했기 때문이 아니므로, 원고가 주장하는 일련의 피고 제품 출시행위 중 피고 제품의 제조·판매행위를 원고 제품 상한금액 인하의 원인이라고 볼 수 없다.
- 바. **피고가 제네릭 의약품인 피고 제품에 관하여 이 사건 요양급여대상 결정신청과 이 사건 판매예정시기 변경신청을 한 이후 보건복지부장관이 이 사건 고시으로써 원고 제품의 상한금액 인하 시행시기를 변경하여 원고가 원고 제품의 상한금액 인하라는 불이익을 입게 된 측면은 있다. 그렇지만 피고의 신청행위를 위법하다고 보기 어려운 점, 보건복지부장관의 이 사건 고시를 위법한 처분이라고 볼만한 자료도 없는 점, 관련 규정의 취지가 국민건강보험 재정을 건전화하여 원활한 요양급여를 지속적으로 보장하는 데에 있다는 점과 국민건강보험제도의 공익적 성격 등을 고려하면, 위와 같은 원고의 불이익은 제네릭 의약품의 요양급여대상 결정신청이 있으면 보건복지부장관이 최초등재제품의 상한금액을 인하할 수 있고, 최초등재제품 특허의 무효가능성이 소명되면 제네릭 의약품의 약제급여목록표 등재 후 즉시 요양급여대상 약제로 판매할 수 있도록 한 관련 제도를 채택한 결과에 따른 것이다. 결국 원고가 원고 제품의 상한금액에 관하여 갖는 이익은 이러한 제도의 테두리 내에서 보호될 수 있는 것에 불과하고, 그 제도에서 정한 절차에 따른 결과가 원고에게 불리하게 작용하더라도 이를 피고의 책임으로 돌릴 것은 아니다.**
- 사. 따라서 피고의 행위가 위법하다거나 피고의 행위와 원고 제품의 상한금액 인하 사이에 상당인과관계가 있다고 볼 수 없다.

- 영국릴리는 '울란자핀' 특허발명(특허번호 제195566호, 특허권 존속기간 2011. 4. 24.)의 특허권자
- 한국릴리는 1997년 이후로 국내 유일한 수입자로서 원고 제품을 국내에 수입, 판매



대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결 【특허법위반】

특허법 제101조 제1항은 “다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 하면서, 제2호에 “전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한”을 규정하고 있다. 따라서 **설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.**



제136조제8항

제119조(특허권 등의 포기의 제한) ① 특허권자는 다음 각 호의 모두의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다.

1. 전용실시권자
2. 질권자
3. 제100조제4항에 따른 통상실시권자
4. 제102조제1항에 따른 통상실시권자
5. 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자

② 전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다.

③ 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다.

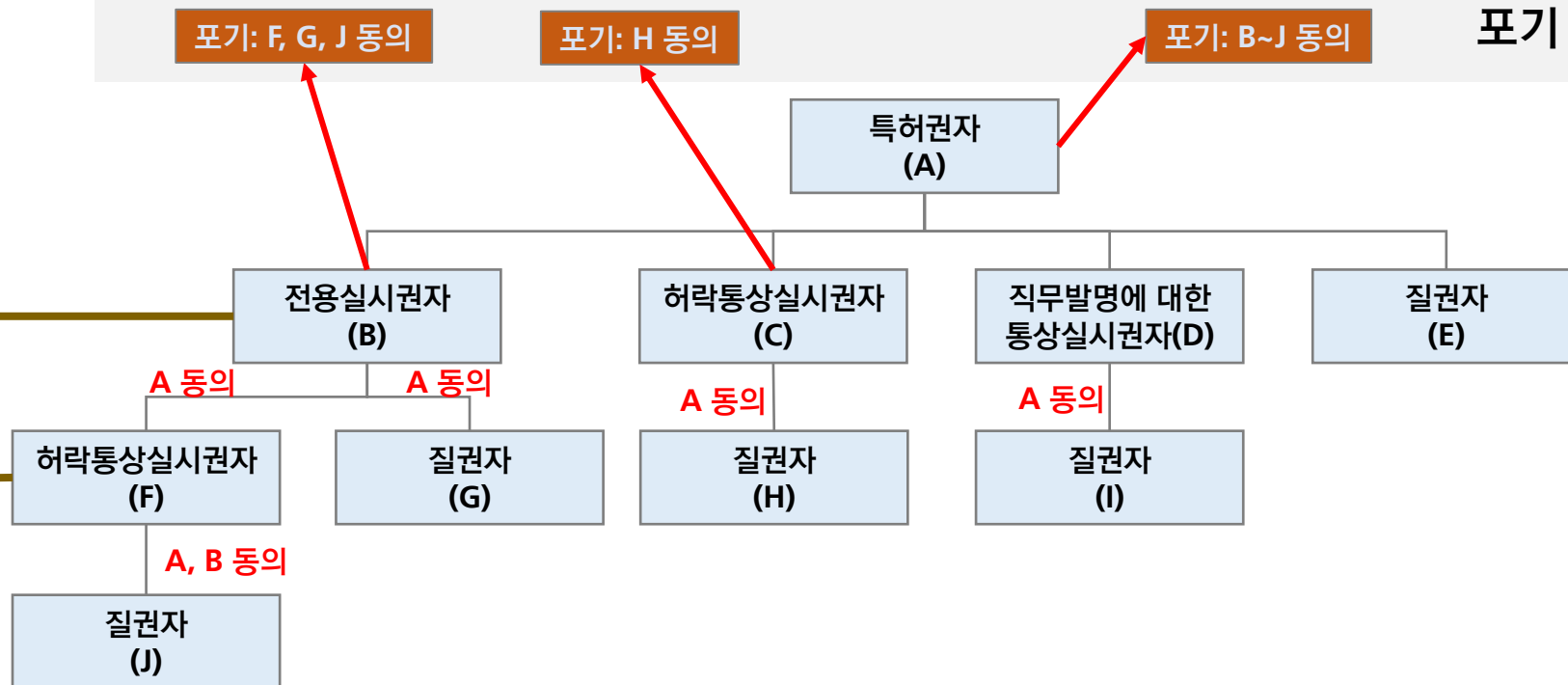
제120조(포기의 효과) 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 포기한 때에는 특허권·전용실시권 또는 통상실시권은 그때부터 소멸된다.

- 장래효: 특허료 불납, 존속기간 만료, 특허권의 포기, 상속인 부존재
- 소급효: 취소결정확정, 무효심결확정(단, 후발적 사유는 제외)

이전

이전: A 동의
(단 실시사업과 함께/
상속은 제외)

이전: A, B 동의
(단 실시사업과 함께/
상속은 제외)



소멸

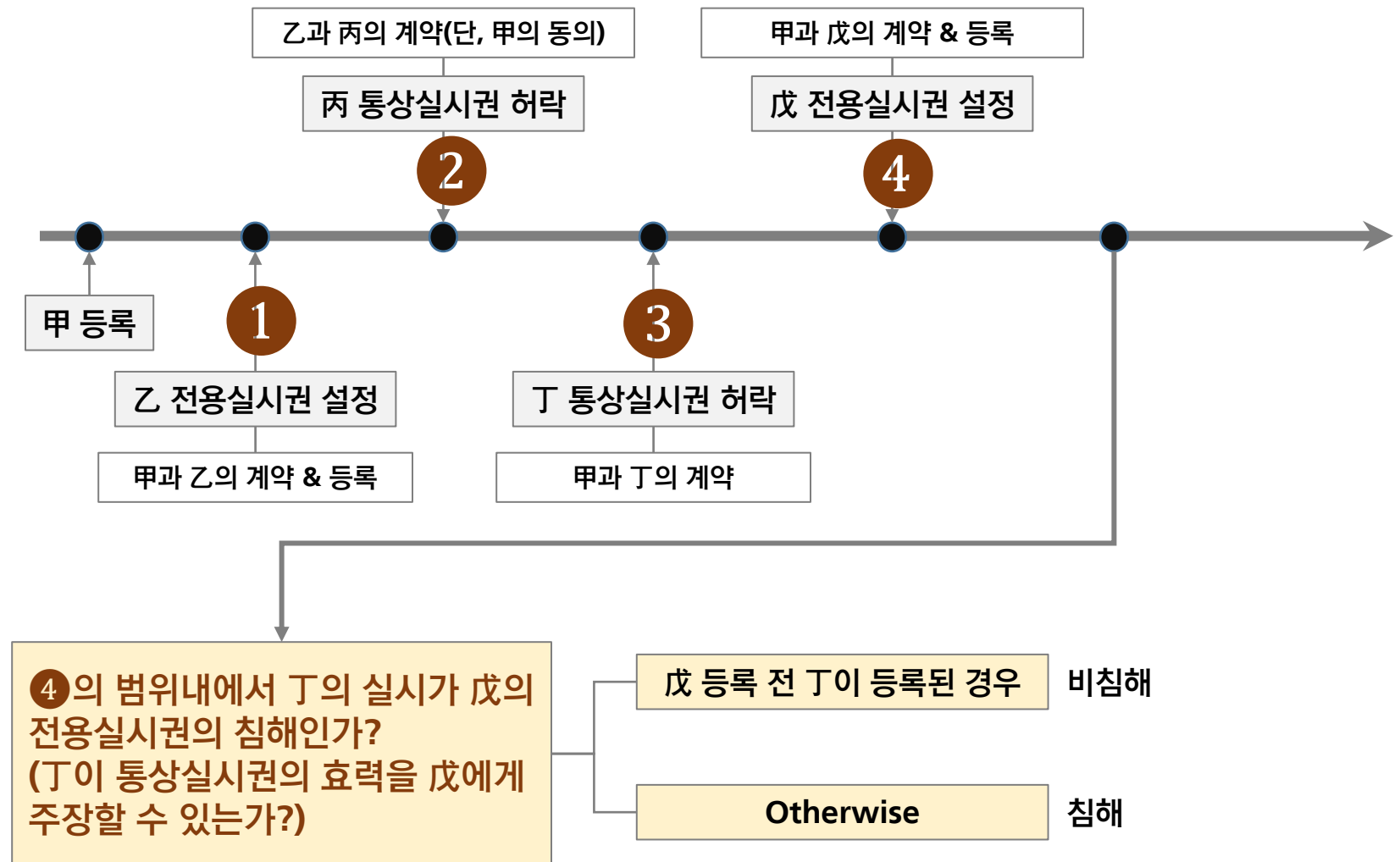
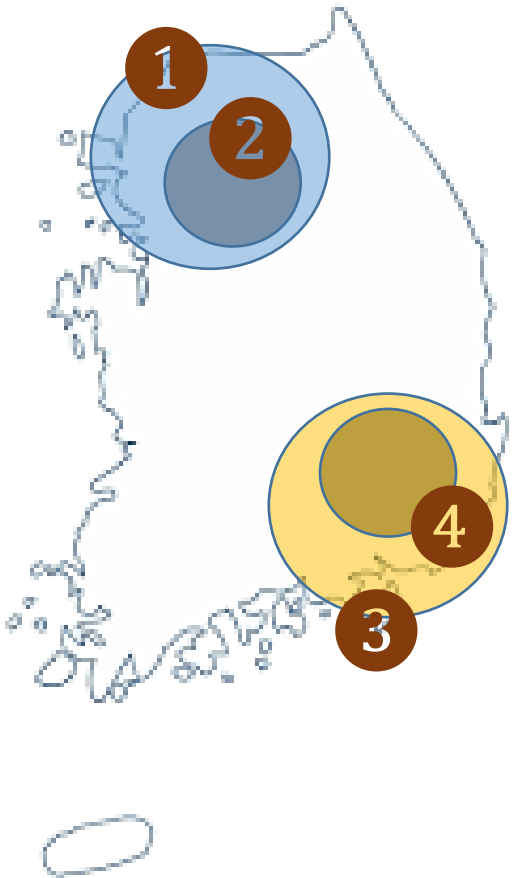
소멸원인

특허권의 수용

자체의 소멸원인

자체의 소멸원인

통상실시권은 특허권에 부수적인 권리이며, 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 없는 채권적 권리이다. 따라서 통상실시권을 허락한 후에도 중복되는 범위에서
 i) 특허권자가 스스로 실시할 수 있고, ii) 같은 내용의 복수의 통상실시권이 동시에 존재할 수 있으며, iii) 특허권자가 다시 전용실시권을 설정할 수도 있다.



구 분		성립요건	효력범위	효력내용
특수한 경우 (규칙×)	發振法 10①	1. 직무발명일 것 2. 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 것 3. 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 예약승계에 해당 하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하였을 것	특허발명 전체	
	法 105	1. 특허출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록되었을 것 2. 디자인권이 특허권과 저촉될 것 3. 존속기간 만료로 소멸할 것	1. 디자인권자 → 원디자인권의 범위 2. 등록된 실시권자(단, 법정실시권은 등록 不要) → 원실시권의 범위	
	法 122	1. 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)가 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있을 것 2. 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전될 것	특허발명전체(무제한설이 통설)	
일반적인 경우 (규칙○)	시기적	1. 法 81의3⑤ → 효력제한기간중(추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날로부터 납부하거나 보전한 날) 2. 法 103 → 특허출원 시 3. 法 103의2 → 특허권의 이전등록이 있기 전 4. 法 104 → 무효심판청구의 등록전에 5. 法 182 → ① 무효가 된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우, ② 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우 및 ③ 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우, ④ 취소가 된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우 결정/심결확정후 재심청구등록전 6. 法 183 → 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이에 상반되는 심결의 확정이 있는 경우에 심결확정후 재심청구등록전	1. 法 81의3⑤, 103, 103의2, 104, 182 → 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위 2. 法 183 → 원통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위	통상 실시권
	주체적	1. 선의일 것 2. 선의의 해석 ① 法 103 → 그 특허출원된 발명의 내용의 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 된 자 ② 法 103의2 - 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 - 취득할 수 있는 자(法 103의2①각호)에 해당 ③ 法 104 - 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 - 취득할 수 있는 자(法 104①각호)에 해당		
	지역적	국내		
	객체적	실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있을 것		
대가		發振法 10①, 法 103, 法 105(원디자인권자에 한함), 法 182의 경우 무상		

「선의」란 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 된 것을 말한다. 타인으로부터 발명을 알게 된 경우에 그것이 선의인 한 그 발명을 알게 된 경로(route)는 문제되지 않으나, 선사용되는 발명의 과도한 보호를 방지하기 위하여 특허출원한 발명자로부터 발명을 알게 된 경우는 제외되는 것으로 해석함이 일반적이다. 한편, 정당한 권리자인 발명자 또는 이로부터 발명을 알게 된 자가 실시사업 등을 하고 있는 경우 모인하여 특허출원되고 특허된 무권리자의 특허에 대하여 선사용권이 인정되는지와 관련하여, 무권리자의 특허가 제33조제1항 본문의 특허요건의 흠결이 있다고 하더라도 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전까지는 유효한 권리이므로 선사용권이 인정된다고 해석된다.

선의

원칙: 발명루트가 다른 경우

甲 발명

乙이 甲으로부터 지득

乙이 국내에서
실시사업 또는 사업준비

甲 출원

甲 등록

甲 침해소송제기

乙이 선사용권 항변: 불인정

乙이 발명한 甲으로부터 알게 됨
(같은 발명루트)예외: 발명루트가 같은 경우
(은수저 제작방법 사건)丙 은수저 제작
& 제작방법 발명丙이 은수저 제작방법을 사용
하여 실시사업/사업준비

丙이 선사용권 항변: 인정

甲이 丙에게
은수저 제작 의뢰丙이 甲에게 납품하면서 발명 매수
의사 타진하였으나 甲이 거부甲&乙 명의로
은수저 제작방법
출원

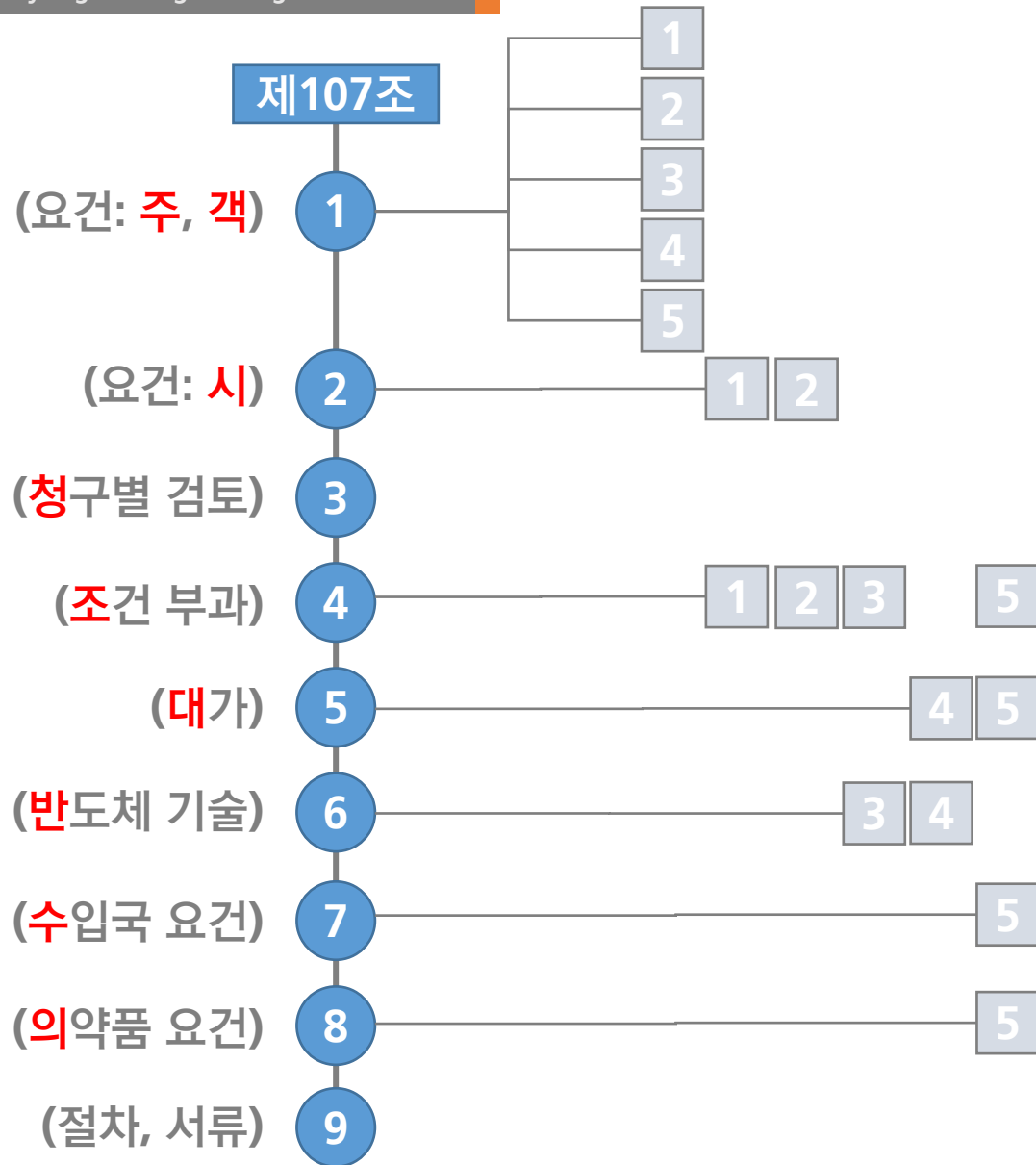
등록 후 丁에게 양도

丁이 침해소송제기

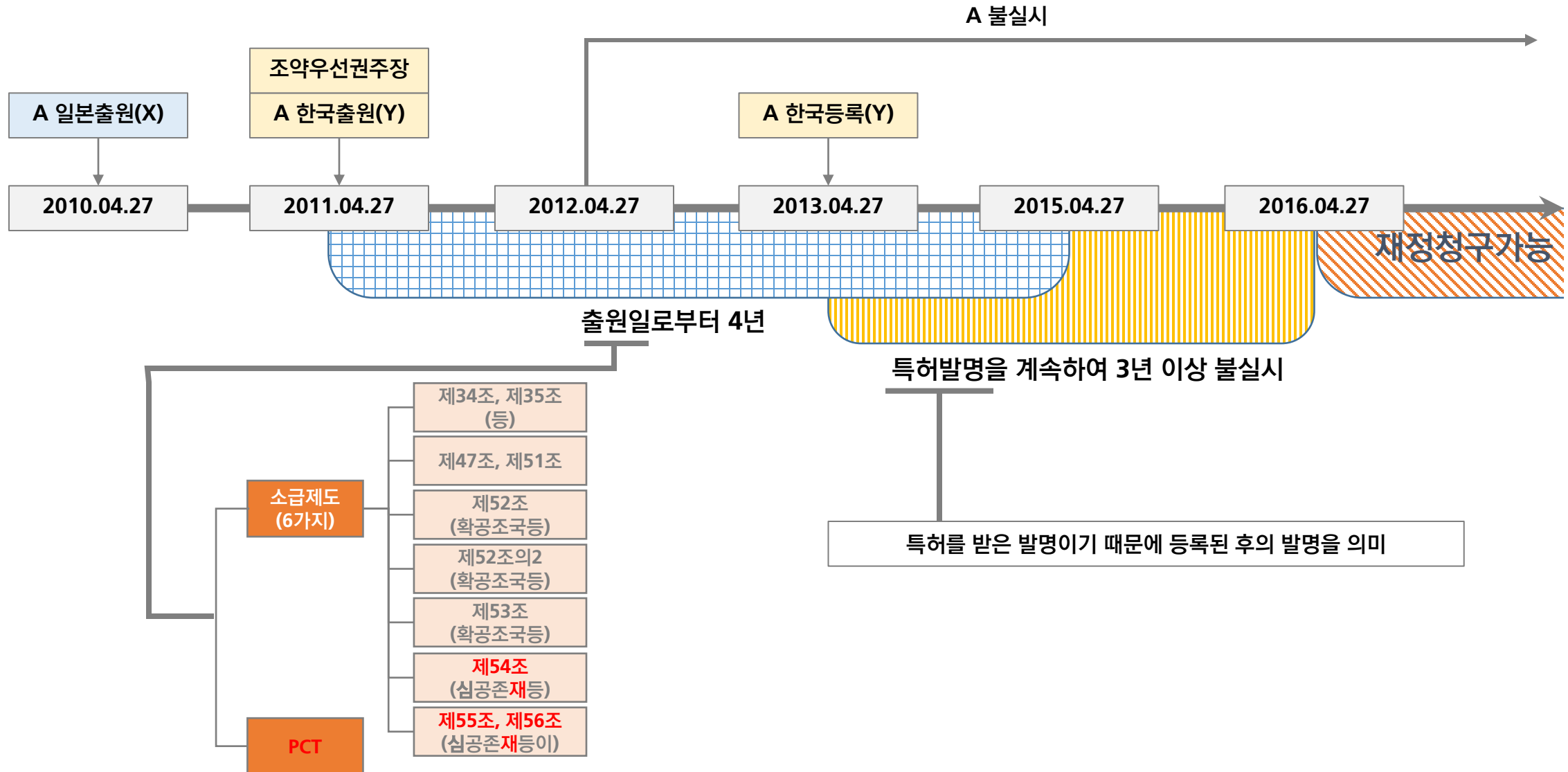
丙은 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 스스로 발명한 자에 해당함
(정당한 권리자가 실시사업 또는 사업준비하고 있는데 무권리자가 출원하여 착오로 등록된 경우)

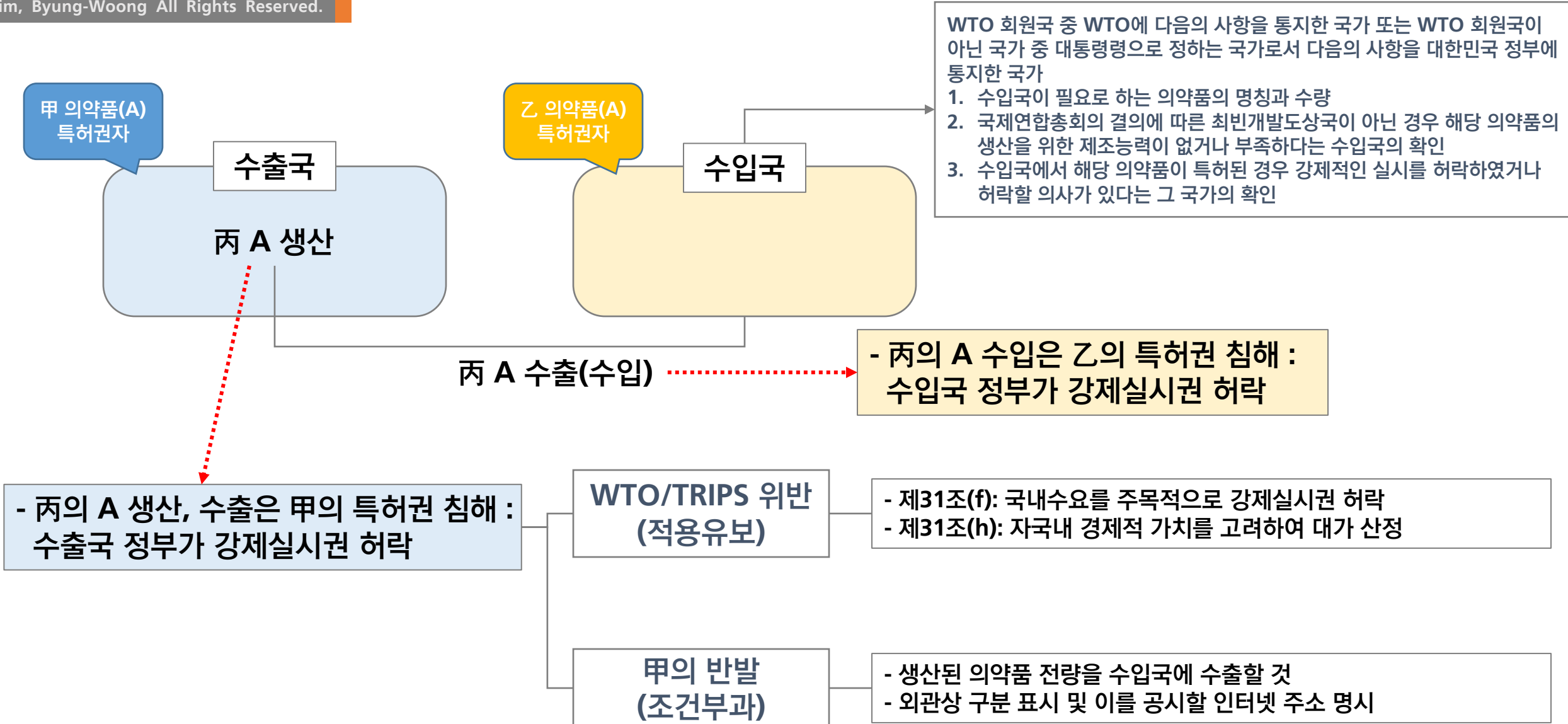
제107조(통상실시권 설정의 재정) ① 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 "협의"라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 지식재산처장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호에 해당하는 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다.

1. 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우
 2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우
 3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
 4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
 5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
- ② 특허출원일부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 제1항제1호 및 제2호를 적용하지 아니한다.
- ③ 지식재산처장은 재정을 하는 경우 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.
- ④ 지식재산처장은 제1항제1호부터 제3호까지 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우 재정을 받는 자에게 다음 각 호의 조건을 붙여야 한다.
1. 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 재정의 경우에는 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것
 2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것
- ⑤ 지식재산처장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제1항제4호 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 대가 결정에 고려할 수 있다.
1. 제1항제4호에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지
 2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치
- ⑥ 반도체 기술에 대해서는 제1항제3호(공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우만 해당한다) 또는 제4호의 경우에만 재정을 청구할 수 있다.
- ⑦ 수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가의 경우만 해당한다.
1. 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량
 2. 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인
 3. 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인
- ⑧ 제1항제5호에 따른 의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.
1. 특허된 의약품
 2. 특허된 제조방법으로 생산된 의약품
 3. 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분
 4. 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트
- ⑨ 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.



구분	불 실시	불충분 실시	공공의 이익 실시		불공정거래행위 시정 실시	수입국에 수출 실시
			상업적	비상업적		
협약 (제107조제1항)	○	○	○	×	×	○
기간경과 (제107조제2항)	○	○	×	×	×	×
청구별 검토 (제107조제3항)	○					
조건부과 (제107조제4항)	국내수요충족				-	생산된 의약품 전량을 수입국에 수출
대가참작 (제107조제5항)	-				불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지	그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치
반도체기술 (제107조제6항)	×	×	×	○	○	×
수입국요건 (제107조제7항)	×	×	×	×	×	○
의약품요건 (제107조제8항)	×	×	×	×	×	○





제108조(답변서의 제출) 지식재산처장은 재정의 청구가 있으면 그 청구서의 부분(副本)을 그 청구에 관련된 특허권자·전용 실시권자, 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

제109조(산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취) 지식재산처장은 재정을 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회(이하 “조정위원회”라 한다) 및 관계 부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다.

제110조(재정의 방식 등) ① 재정은 서면으로 하고, 그 이유를 구체적으로 적어야 한다.

② 제1항에 따른 재정에는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 적어야 한다.

1. 통상실시권의 범위 및 기간
 2. 대가와 그 지급방법 및 지급시기
 3. 제107조제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소
 4. 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시할 경우 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항
- ③ 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6개월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다.
- ④ 제107조제1항제5호에 따른 재정청구가 같은 조 제7항 및 제8항에 해당하고 같은 조 제9항에 따른 서류가 모두 제출된 경우에는 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다.

제111조(재정서등본의 송달) ① 지식재산처장은 재정을 한 경우에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서등본을 송달하여야 한다.

② 제1항에 따라 당사자에게 재정서등본이 송달되었을 때에는 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 본다.

제111조의2(재정서의 변경) ① 재정을 받은 자는 재정서에 적혀 있는 제110조제2항제3호의 사항에 관하여 변경이 필요하면 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 변경청구를 할 수 있다.

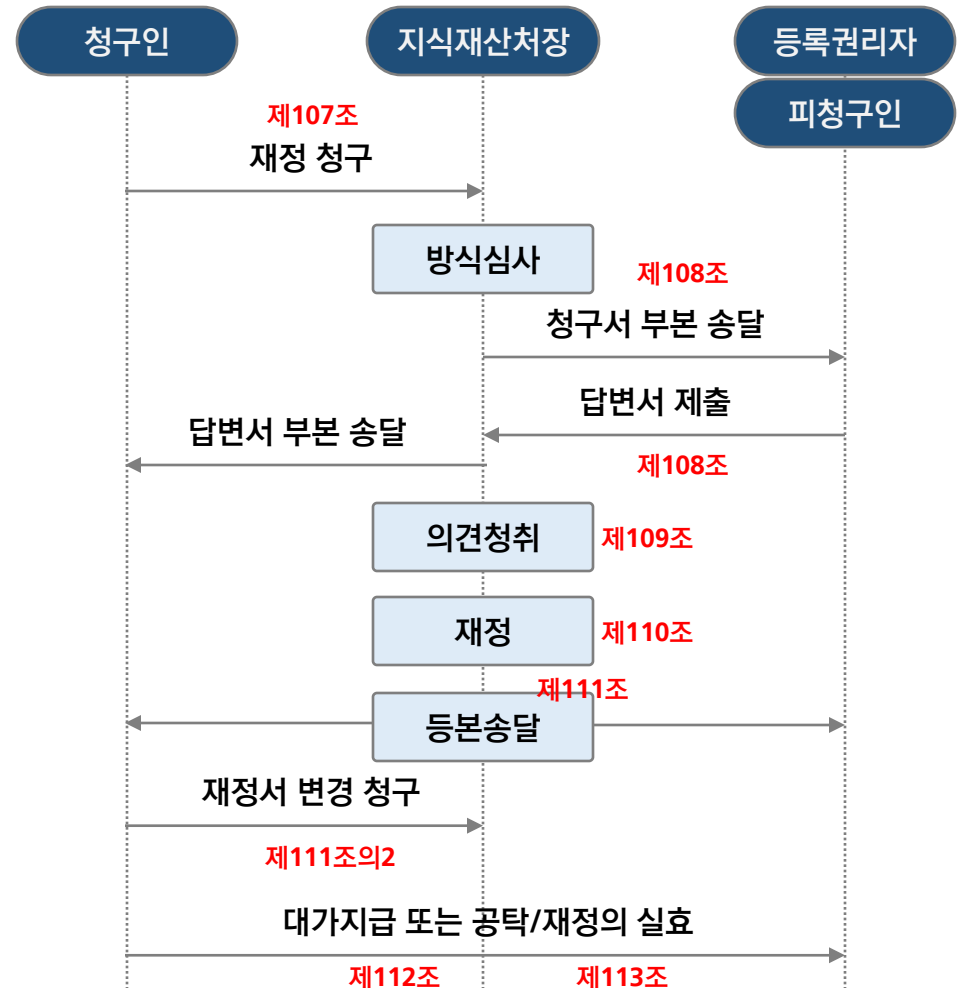
② 지식재산처장은 제1항에 따른 청구가 이유있다고 인정되면 재정서에 적혀 있는 사항을 변경할 수 있다. 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다.

③ 제2항의 경우에 관하여는 제111조를 준용한다.

제112조(대가의 공탁) 제110조제2항제2호에 따른 대가를 지급하여야 하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 대가를 공탁(供託)하여야 한다.

1. 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우
2. 대가에 대하여 제190조제1항에 따른 소송이 제기된 경우
3. 해당 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우. 다만, 질권자의 동의를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

제113조(재정의 실효) 재정을 받은 자가 제110조제2항제2호에 따른 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 효력을 잃는다.

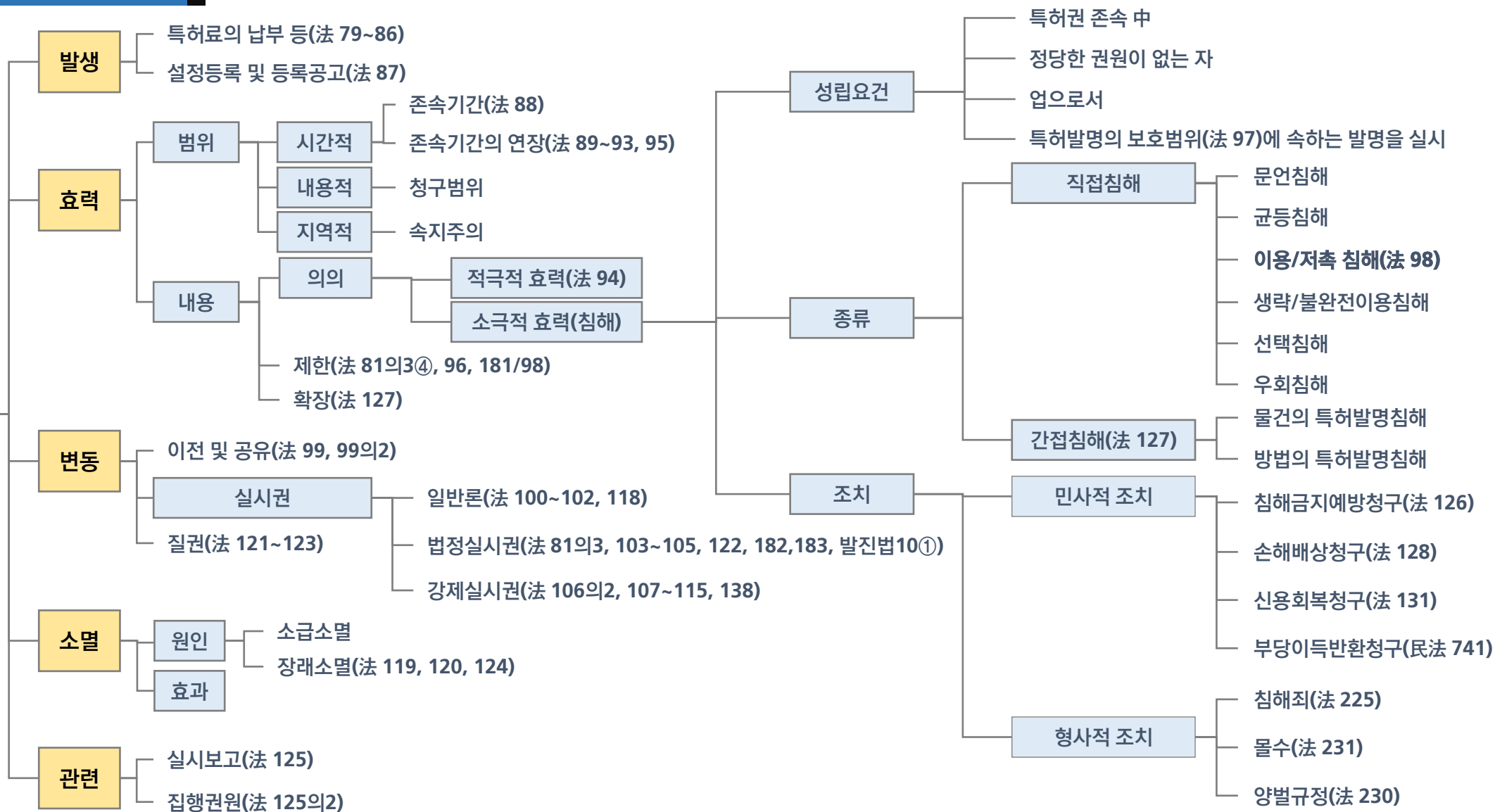


비교	전용실시권	통상실시권
일반	제100조 【전용실시권】 ① (발생) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. ② (효력) 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다. ③ (변동: 이전) 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다. 1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우 2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우 ④ (변동: 질권설정·통상실시권허락) 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다. ⑤ (공유) 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.	제102조 【통상실시권】 ① (발생) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. ② (효력) 통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다. ③ (변동: 재정실시권의 이전) 제107조에 따른 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다. ④ (변동: 통상실시권허락심판에 의한 실시권의 이전) 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다. ⑤ (변동: 이전) 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다. ⑥ (변동: 질권설정) 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다. ⑦ (공유) 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항을 준용한다.
특별	제101조 【특허권 및 전용실시권의 등록의 효력】 ① (등록의 효력) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다. 1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한 2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한 3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한 ② (상속이나 그 밖의 일반승계) 제1항 각 호에 따른 특허권·전용실시권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.	제118조 【통상실시권의 등록의 효력】 ① (설정등록의 효력) 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다. ② (법정실시권 설정등록 不要) 제81조의3제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다. ③ (그 밖의 등록의 효력) 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

구분		전용실시권	통상실시권
발생		제100조제1항	제102조제1항
효력		제100조제2항	제102조제2항
변동	이전	제100조제3항	제102조제3항 내지 제5항
	통상실시권	제100조제4항	-
	질권	제100조제4항	제102조제6항
소멸		-	-
공유		제100조제5항	제102조제7항
등록의 효력		제101조제1항제2호	제118조

구분	장래를 향해 소멸	소급하여 소멸
원인	- 특허료 불납 - 존속기간의 만료 - 특허권의 포기(法 119, 120) - 상속인 부존재(청산절차가 진행 중인 법인의 특허권을 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다)까지 이전등록하지 아니한 경우 그 다음 날 소멸)(法 124)	- 특허취소신청에 의한 취소결정의 확정 - 특허무효심판에 의한 무효심결의 확정(후발적 무효사유는 제외)
효과	1. 특허권 존속기간 만료 후의 디자인보호법상 법정실시권 인정(디자인 103 ③④) 2. 특허권 존속기간 만료 후의 상표법상 법정사용권 인정(商標 98) 3. 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권의 효력 제한 및 법정실시권 인정(法 81의3)	1. 보상금청구권의 소멸(法 65⑥) 2. 소급 소멸 전 침해소송은 재심의 대상이며, 특허권자에게는 손해배상책임 또는 부당이득반환청구 가능 3. 특허취소결정 또는 무효심결 확정 후 재심에 의하여 상반된 결정 또는 심결이 확정된 경우 효력 제한 및 법정실시권 인정(法 181, 182) 4. 무효심결확정된 경우 중용권의 발생(法 104) 5. 무권리자의 특허가 무효심결확정된 경우 정당한 권리자 출원 가능(法 35) 6. 특허취소결정 또는 무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분의 반환 청구 가능(法 84)

특허권



권리		특허권	실시권	
			전용권	통상권
서	의의	발명이라는 기술적 사상의 창작에 대하여 법률에 의하여 부여된 독점배타권	특허권자 이외의 자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리	
	취지	새로운 발명을 공개시킨 자에게 그 대가로서 독점배타권을 부여하여 산업발전에 이바지	1.실시장려를 통한 산업발전 이바지 2.특허권의 재산적 가치 존중	
	성질	무체재산권	1.부수적 2.물권적(전용권) vs 채권적(통상권)	
발생		1.특허결정(法 66) 2.특허료 납부(法 79~86) 3.설정등록 및 등록공고(法 87)	계약&등록	1.허락 - 계약 2.법정 - 법률규정 만족 3.강제 - 행정처분
효력	범위	1.시간적- ①존속기간(法 88)/②존속기간의 연장(法 89~93, 95) 2.내용적-청구범위 3.지역적-속지주의	사적자치	1.허락 - 사적자치 2.법정 - 법률규정 3.강제 - 행정처분
	내용	1.의의(法 94) 2.제한(法 81의3④, 96, 181/98) 3.확장(法 127) 4.침해-①성립요건/②종류(法 97, 98, 1227)/③조치(法 126~132, 225~232)	실시효 + 실시금지효	실시효
변동	이전	이전가능(法 99①)	특허권자의 동의(단, 일반승계, 실시사업과 함께는 동의 不要)	
	실시권	1.전용실시권(法 100, 102) 2.통상실시권(法 101, 118, 103~116)	특허권자의 동의 얻어 可	①法 107-실시사업과 함께만 ②法 138-원권리와 함께 이전하고, 원권리와 함께 소멸 不可
	질권	1.질권자 실시 不可(法 121) 2.질권행사로 특허권 이전에 따른 법정실시권(法 122) 3.물상대위(法 123)	특허권자의 동의	法 107, 138은 不可
소멸	원인	1.소급하여 소멸-무효심결의 확정(후발적 사유는 제외), 취소결정의 확정 2.장래를 향해 소멸-특허료 불납, 존속기간의 만료, 특허권의 포기(法 119, 120), 상속인이 없는 경우(法 124)	1.특허권의 소멸, 수용 2.실시권 자체의 소멸	
	효과	1.소급하여 소멸/2.장래를 향해 소멸		
공유		1.다른 공유자 동의 받아야만 지분 양도, 지분에 대한 질권설정 可(法 99②) 2.다른 공유자 동의없이 지분비율에 무관하게 특허발명 전체 실시 可(法 99③) 3.다른 공유자 동의 받아야만 특허권에 대한 전용권설정, 통상권허락 可(法 99④)	法 99②~④ 준용	法 99②③ 준용

권리		특허를 받을 수 있는 권리	보상금청구권
서	의의	발명의 완성에 의하여 발생하고, 특허출원에 대한 거절결정확정이나 설정등록이 있기 전까지 인정되는 권리	출원공개가 있은후 경고받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 경고받거나 알았을 때부터 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있는 권리
	취지	특허권 발생이전에 발명자 또는 출원인 보호	공개로 인해 상실된 이익의 보전
	성질	사권(재산권)과 공권(특허부여요구권)을 병합	1.해제조건부 권리 2.채권적 권리 3.특허권과 독립적인 권리
발생		발명의 완성에 의하여 발생	1.출원공개가 있을 것 2.경고받거나 알고 있을 것 3.정당한 권원없는 제3자가 업으로서 출원발명을 실시할 것
효력	범위	1.특허부여요구권 ①권리부여의 요구-특허출원(法42) ②타인출원의 등록금지	1.보상금액(法65②)-경고받거나 알았을 때부터 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구 2.행사시기(法65③)-등록 후 3.독립성(法65④)-특허권과 별개 4.준용규정(法65⑤) ①특허법상-간(法 127), 생(法 129), 자(法 132) ②민법상-공(民法 760), 소(民法 766)
	내용	2.발명자권 ①인격권 ②재산권	
변동	이전	1.이전가능(法 37①) 2.특박권의 승계(法 38)	
	실시권		
	질권	불가(法 37②)	
소멸	원인	1.권리능력 상실(상속인 부존재도 포함) 2.출원계속의 소멸	1.특허등록이 되지 않은 경우 2.특허등록이 되더라도 소급 소멸하는 경우
	효과	1.공개전 소멸-등록금지적 효력X 2.공개후 소멸-공지기술의 지위, 확선의 지위	1.고의과실○-손배청구 2.고의과실×-부당이득반환청구
공유		다른 공유자 동의 받아야만 지분양도 可(法 99③)	

총칙/
보칙

특허
요건

이익
제도

심사
(제도)

특허권

심판/
소송

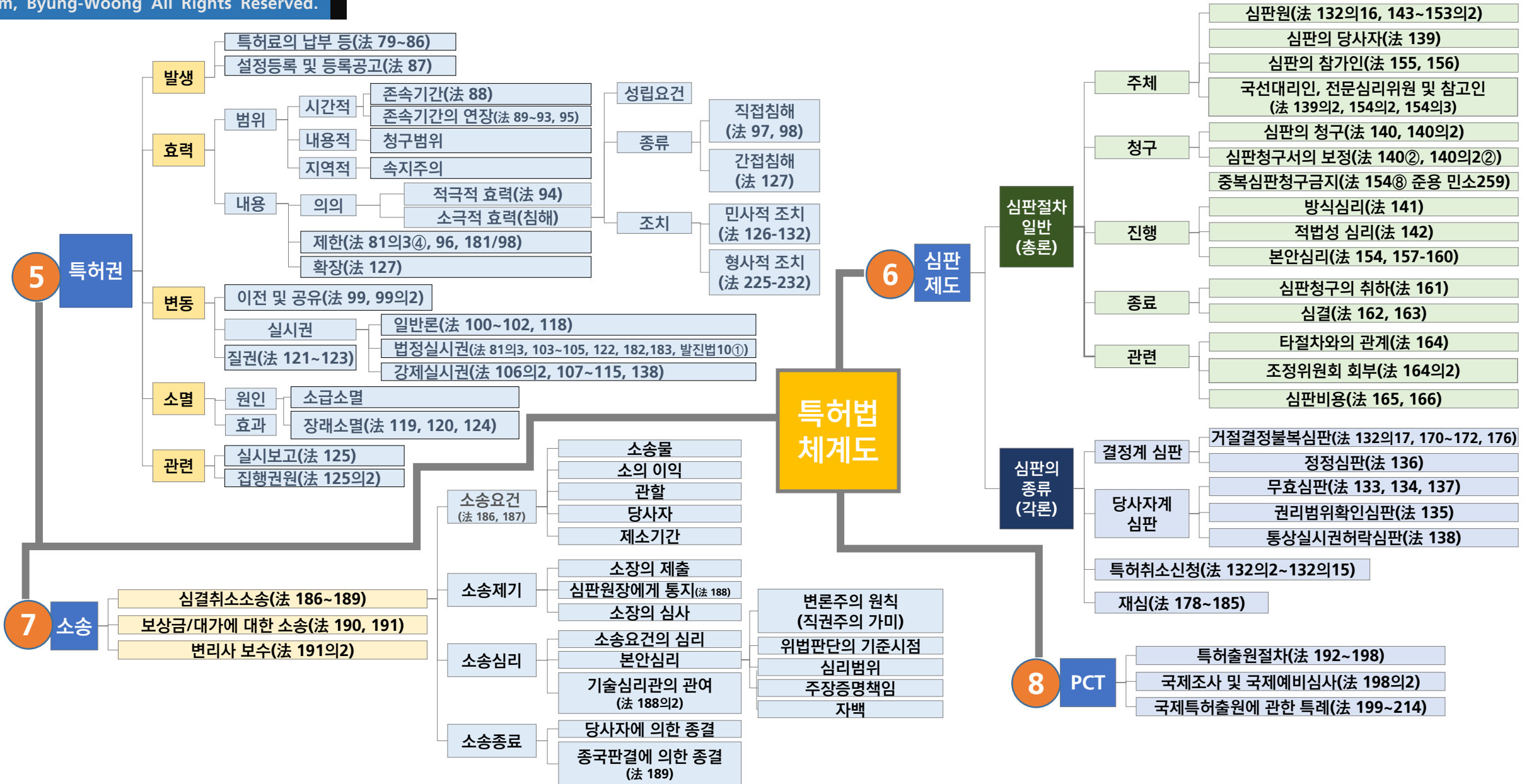
PCT

특허법 강의노트

Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

2026





심판 제도

심판절차 일반 (총론)

주체

심판원(法 132의16, 143~153의2)

심판의 당사자(法 139)

심판의 참가인(法 155, 156)

국선대리인, 전문심리위원 및 참고인
(法 139의2, 154의2, 154의3)

심판원의 조직과 구성

심판관의 제척, 기피 및 회피

당사자 참가인

보조 참가인

청구

심판의 청구(法 140, 140의2)

심판청구서의 보정(法 140②, 140의2②)

중복심판청구금지(法 154⑧ 준용 민소259)

진행

방식심리(法 141)

적법성 심리(法 142)

본안심리

심리방식의 선택(法 154)

직권주의(法 157-160)

직권진행주의(法 158, 158의2, 160)

직권참지주의(法 157, 159)

종료

심판청구의 취하(法 161)

심결(法 162, 163)

관련

타절차와의 관계(法 164)

조정위원회 회부(法 164의2)

심판비용(法 165, 166)

심판의 종류 (각론)

결정계 심판

거절결정불복심판(法 132의17, 170~172, 176)

정정심판(法 136)

무효심판

특허무효심판(法 133, 133의2)

연장등록무효심판(法 134)

정정무효심판(法 137)

당사자계 심판

권리범위확인심판(法 135)

통상실시권허락심판(法 138)

특허취소신청(法 132의2~132의15)

재심(法 178~185)

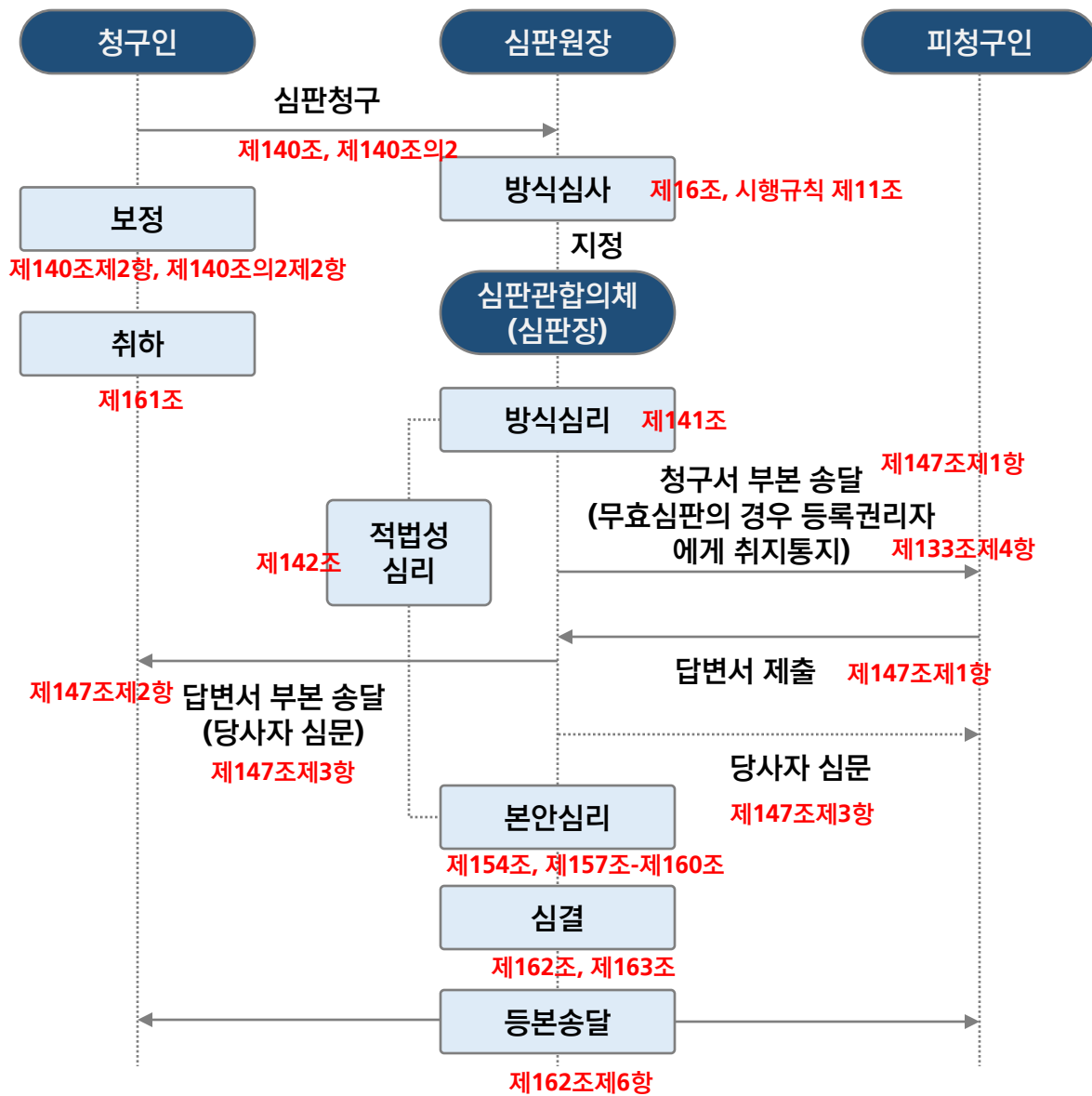
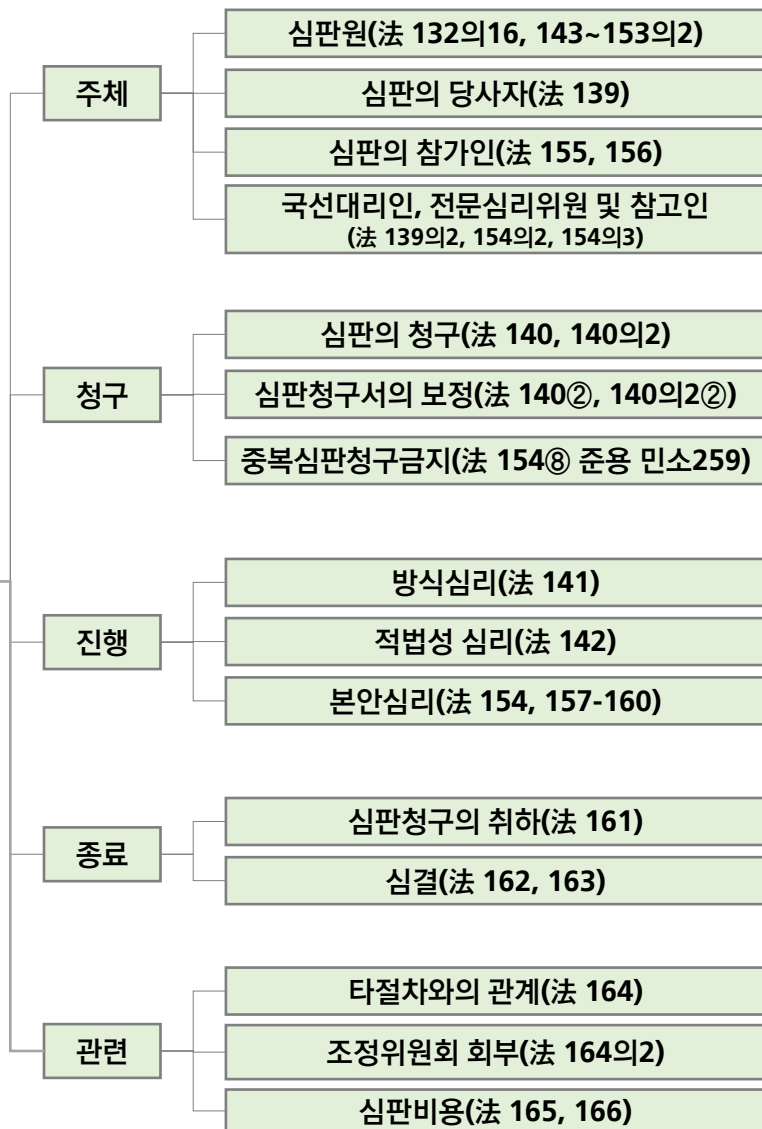
심판절차는 형식적으로는 특허에 관한 분쟁을 해결하기 위하여 특허심판원의 심판관합의체에 의하여 심리·결정되는 행정상의 쟁송절차라 할 수 있지만, 사실상 특허법원의 전심절차로서 민사소송에 준하는 엄격한 절차를 거쳐 판단되는 준사법적 성질을 가진다.

구분	민사소송	특허심판
관할	민사법원	특허심판원
직무	산업재산권 관련 침해금지, 손해배상소송 등	산업재산권의 발생, 변경, 소멸 및 그 효력범위에 관한 분쟁
신분보장	신분상 + 직무상 독립	직무상 독립
심리방법	변론주의*	직권주의**
심리진행	구술심리	구술심리 + 서면심리
기속력	당사자	당사자 + 제3자
재판상 화해, 포기, 인락	인정	불인정

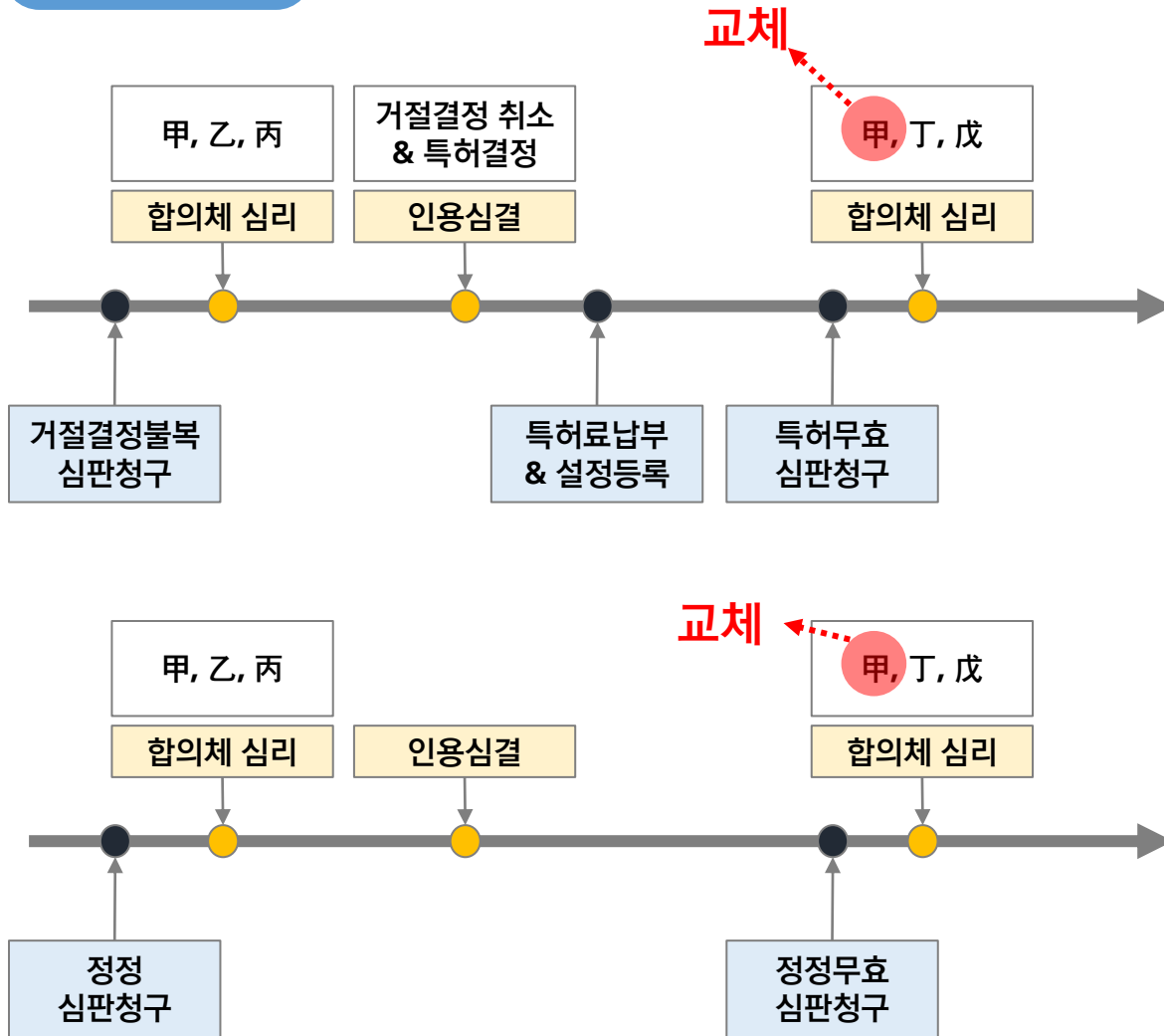
* 소송자료 즉, 사실과 증거의 수집 및 제출의 책임을 당사자에게 맡기고 당사자가 수집, 제출한 소송자료만을 재판의 기초로 삼아야 한다는 원칙

** 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대해서도 직권심리 & 직권으로 증거조사, 증거보전 가능

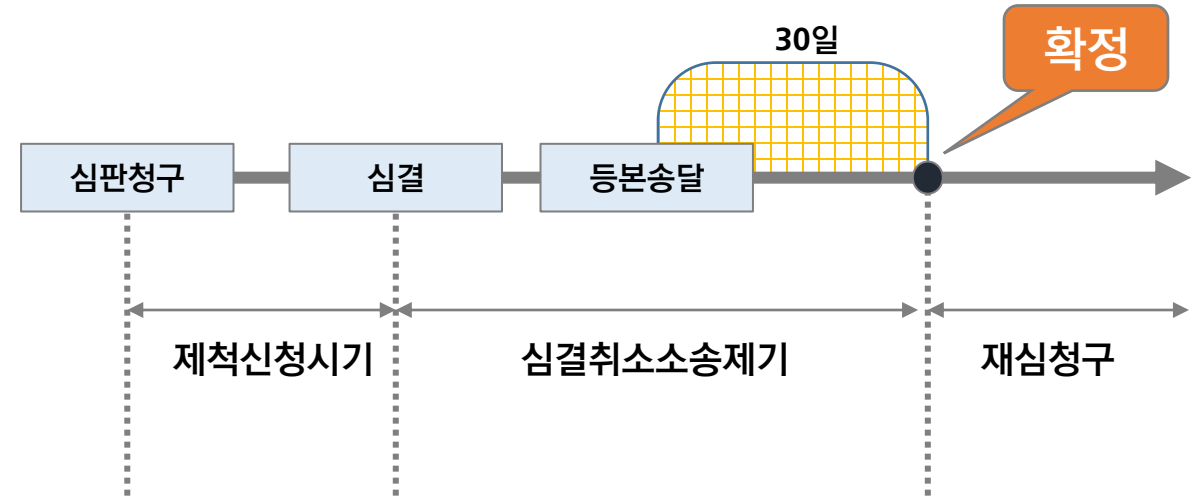
심판절차 일반 (총론)



전심관여



시 기



실체법적
측면

출원인

권리능력자 中 권리적격자

권리능력자

내국인

외국인

재내자

재외자

권리적격자

발명자

승계인

지식재산처/심판원 직원

복수 출원인

절차법적
측면

당사자

당사자능력자 中 당사자적격자

당사자능력자

권리능력자 + 비법인 사단/재단(法 4)

당사자적격자

복수 당사자

출원, 심판청구 및 소송

출원(法 44, 90, 92의3)

심판청구(法 139)

소송

그 밖의 절차

대표자 선정(法 11①본문)

대표자 선정(法 11①단서)

구 분		청구인	피청구인
거절결정불복심판(法 132의17)		출원인	-
정정심판(法 136)		특허권자	-
무효심판 (法 133, 134, 137)		이해관계인 또는 심사관 (다만, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하여 제33조 제1항 본문을 위반한 경우나 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 제44조를 위반한 경우에는 심사관 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자 가 특허무효심판(法 133) 청구 가능)	특허권자
권리범위 확인심판 (法 135)	적극적	특허권자, 전용실시권자	과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 이해관계인 (실시할 예정이 있는 이해관계인 제외)
	소극적	과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 자 뿐만 아니라 실시할 예정이 있는 이해관계인	특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 사람 특허권자 (전용실시권자 제외)
통상실시권 허락심판 (法 138)	일반적	후출원 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자	선출원 특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는 디자인권자 (상표권자 제외)
	CROSS-LICENSE	선출원 특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는 디자인권자	후출원 특허권자, 전용실시권자 (통상실시권자 제외)

당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람

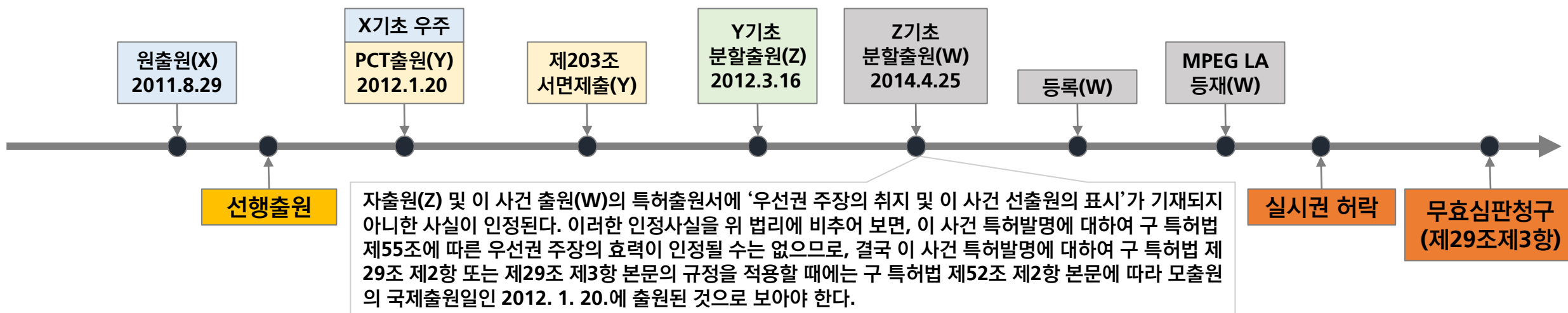
특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 사람

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 【등록무효(특)】

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, **이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.**

그 이유는 다음과 같다. 특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다. 그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, **실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.**

이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

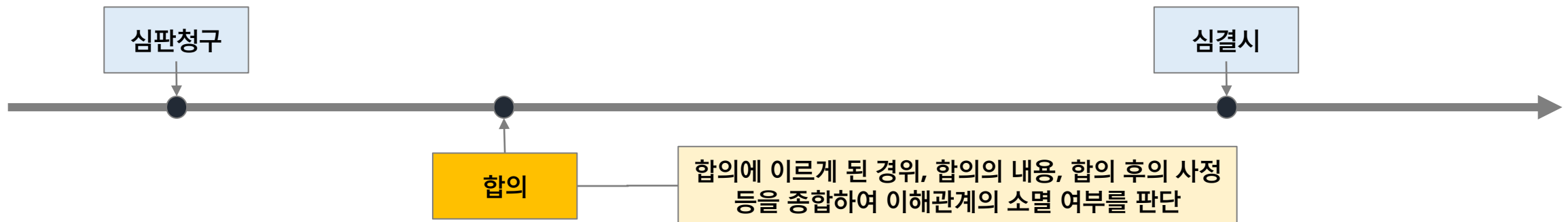


* 단, 2022.4.20. 시행되는 개정법(제18505호)에 의하면 자동주장간주

이해관계의 판단시점

심결 시*를 기준으로 이해관계의 존부를 판단한다. 따라서 심판청구 당시에는 이해관계가 없는 경우라도 심결 시에 이해관계가 있으면 적법한 심판청구로 인정되며, 심판청구 시에는 이해관계가 성립되었던 심판청구도 그 심결 시에 이해관계가 소멸된 경우에는 부적법한 심판청구로서 심결각하된다. 예를 들어, 심판계속 중에 당사자의 합의가 있거나 화해를 한 경우 또는 청구인이 심판의 대상인 권리를 양도받음으로써 혼동이 있는 경우에는 이해관계가 소멸된 것으로 본다. 다만 합의가 있었다는 사실만으로 곧바로 이해관계가 소멸하였다고 볼 수는 없고, 각각의 심판별로 합의에 이르게 된 경위, 합의의 내용, 합의 후의 사정 등을 종합하여 이해관계의 소멸 여부를 판단하여야 한다. 합의의 내용을 일례로 들면, 대법원 1979. 3. 13. 선고 77후50 판결에서는 “특정의 이해관계인이 특허권리자와 간에 특허에 관한 분쟁을 일체 아니하기로 화해한 경우에는 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위를 상실한 결과가 된다”라고 판시하였고, 대법원 1996. 12. 6. 선고 95후1050 판결에서는 “등록고안의 실용신안권자 甲과 그로부터 실용신안권 침해의 고소를 당한 乙 사이에 乙이 그 등록고안의 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 않는다는 내용의 약정을 하였다 하더라도, 문언상으로는 그 합의의 취지를 乙이 甲의 등록고안에 대한 정당한 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 아니하기로 한 것으로 볼 수 있을 뿐이어서, 그 합의로써 곧바로 乙이 자신이 실시했던 특정 고안이 그 등록고안의 권리범위에 속함을 인정하였다거나 그 등록고안의 권리범위를 확인하는 심판청구권까지를 포기하기로 한 것으로 볼 수 없으므로, 그와 같은 합의가 있었다는 사정만으로 심판청구인의 권리범위확인심판에 관한 이해관계가 소멸하였다고 할 수는 없다”라고 하여 단순히 상대방의 권리를 인정하는 내용의 합의로는 권리범위확인심판청구의 이해관계가 소멸하지 않는다고 하였다. 또한, 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331 판결에서는 “등록디자인의 디자인권자 甲과 그로부터 디자인권 침해의 고소를 당한 乙 사이의 합의서에 乙이 디자인등록 제품을 제작한 것에 대하여 사과하고, 추후 디자인등록 제품을 제작하지 않겠으며, 기존 디자인등록 제품을 폐기하겠다는 내용만 포함되어 있을 뿐 당시 계속중이던 디자인등록 무효심판청구사건의 처리에 관하여는 아무런 기재가 없는 경우, 위 합의의 내용과 경위를 고려할 때, 위 합의는 乙이 자신이 제작하였던 물품이 甲의 등록디자인권의 권리범위에 속한다는 사실을 인정한 것일 뿐 그 등록디자인권의 효력에 대하여도 무효심판절차를 통하여 일체 다투지 않겠다는 취지까지 포함된 것으로 보기 어렵고, 디자인등록의 무효심판의 공익적 성격을 고려하여 위와 같은 합의만으로 그 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다”라고 하여 권리범위에 속함을 인정한다는 합의는 권리범위확인심판에서의 이해관계를 소멸시키지만, 이것이 특허무효심판의 이해관계까지 소멸시킨다고 볼 수는 없다고 하였다.

*제133조 특허무효심판의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자인지 여부도 심결시 기준(대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814)

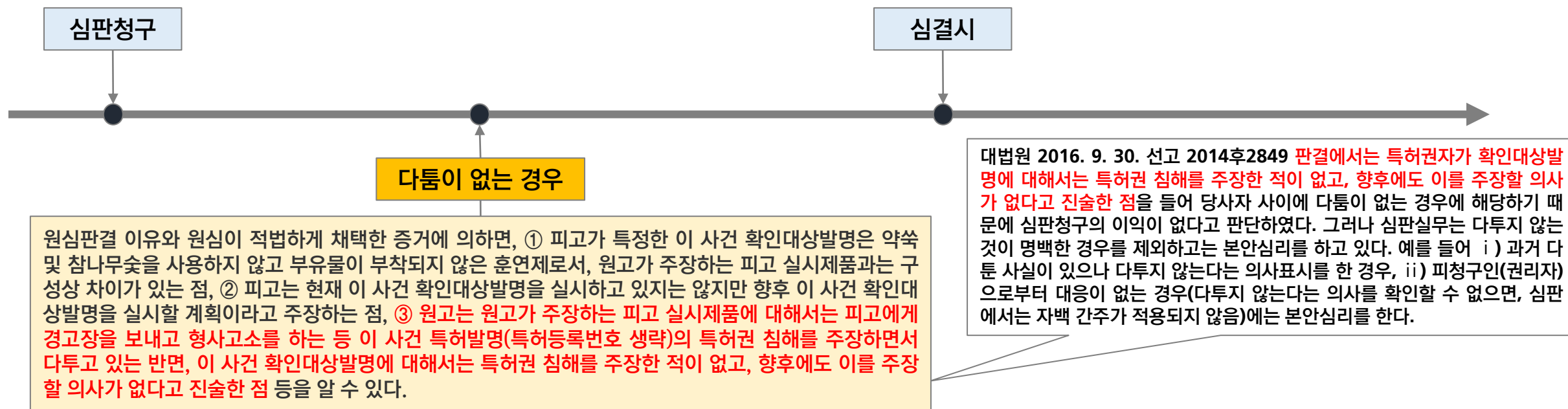


이해관계의 판단시점: 다툼이 없는 경우

Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결 【권리범위확인(특)】

소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.



(비판견해) 민사소송의 확인의 소에서는 피고가 원고의 청구 취지에 대한 주장을 그대로 인정하는 경우에는 인용 판결의 효력을 갖는 인낙조서를 작성하여 소를 종결시키는데 비해, 특허법원 판결은 소극적 권리범위 확인심판에서 당사자 간 다툼이 없는 경우에는 심판 청구인의 법적 불안이 없는 것이어서 확인의 이익이 없다고 판단하였다. 그러나, 심판 피청구인이 심판 청구인의 주장을 그대로 인정한다고 하더라도 추후 심판 피청구인은 자신의 주장을 반복하여 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는데, 일사부재리 효력을 갖지 아니한 각하심결로는 심판 피청구인의 심판 청구를 막을 수 없어 심판 청구인은 불측의 피해를 볼 수 있으므로 당사자 간 다툼이 없다는 사실만으로는 심판 청구인의 법적 불안이 없다고 볼 수 없고, 따라서 확인의 이익을 부정해서는 안된다(김병필, “특허심판에서 당사자 간 다툼이 없는 경우 확인의 이익-소극적 권리범위확인심판을 중심으로-”, 지식과권리(제16호), 2013, 대한변리사회, 74-89면 요약).

「당사자 참가」란 제139조제1항에 따라 공동으로 심판을 청구할 수 있는 자가 타인간의 계속 중인 심판에 참가하는 것을 말하며, 심판청구인 측에만 참가할 수 있다(法 155①). 즉, 특허무효심판(法 133), 특허권의 존속기간연장등록무효심판(法 134), 정정무효심판(法 137), 권리범위확인심판(法 135)을 청구하는 자가 **2명 이상**이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수도 있으나, 일부만이 심판을 청구할 수도 있다. 이 경우에 당사자적격이 있는 나머지 사람은 당사자로서 그 심판에 참가할 수 있다. 아래의 예시에서 이해관계인 甲과 乙은 공동으로 심판을 청구할 수도 있고(1), 각자가 심판을 청구할 수도 있다(2, 3). 또한, 일부만(甲)이 심판을 청구하고, 심판을 청구하지 아니한 다른 당사자(乙)은 그 심판에 참가할 수 있다(4).

甲, 乙 : 이해관계인, 丙 : 특허권자 일 때 甲과 乙이 무효심판을 청구할 수 있는 방법은?

1 甲, 乙(청구인) vs 丙(피청구인)

2 甲(청구인) vs 丙(피청구인)

3 乙(청구인) vs 丙(피청구인)

4 甲(청구인) vs 丙(피청구인)

↑ 당사자 참가

乙(참가인)

1 甲, 乙(청구인) vs 丙(피청구인)

甲 심판청구 취하

3 乙(청구인) vs 丙(피청구인)

심판의분류		공통기재사항	추가기재사항및 첨부사항
결정 계	거절결정 불복심판	- 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) - 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) - 심판사건의 표시 - 청구의 취지 및 그 이유	- 출원일 및 출원번호 - 발명의 명칭 - 특허거절결정일
	정정심판		- 정정한 명세서 또는 도면을 첨부
당사 자 계	무효심판		-
	권리범위 확인심판		- 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부
	통상실시권 허락심판		- 실시하려는 자기의 특허의 번호 및 명칭 - 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록 연월일 - 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가

【청구의 취지】

1. **확인대상발명** "~~파사게 신도 효과를 제공하는 아이폰 12 프로~~"는 특허등록 제10-0822832호의 제1항, 제3항, 제6항 및 제7항의 권리범위에 속한다.

2. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다.
라는 심결을 구합니다.

【청구의 이유】

1. 심판청구의 적법성(이해관계 여부)

2. 이 사건 특허의 요지

3. **확인대상발명**의 요지

4. 권리범위에 속하는지 판단

가. 청구항 제1항의 판단

나. 청구항 제3항의 판단

다. 청구항 제6항의 판단

라. 청구항 제7항의 판단

5. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 확인대상발명은 이 건 특허의 권리범위에 속한다고 할 것입니다. 따라서 심판관님께서서는 부디 청구취지와 같은 심결을 내려주시기 바랍니다.

* 청구취지의 일부를 구성

- 확인대상발명의 보정은 요지변경 불가
- 일사부재리의 효력이 미치는 영역을 명확히 하기 위하여 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있도록 특정 필요

* 청구원인의 일부를 구성

- 특허발명과 서로 대비할 수 있을 정도로 특정 필요

적극적
권리범위
확인심판의
청구취지와
그 이유

심판청구인의 실수로 인해 심판이 각하되는 사례를 방지하기 위해 심판의 당사자 중 특허권자나 거절결정불복심판의 청구인 기재에 대한 보정을 자유롭게 허용하고 있다(法 140② I, 140의② I). 다만, 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 하는데(法 139③) 단독으로 심판을 청구했다면, 사후적으로라도 다른 공유자의 동의가 있는 경우에 한해 추가할 수 있도록 제한하고 있다.

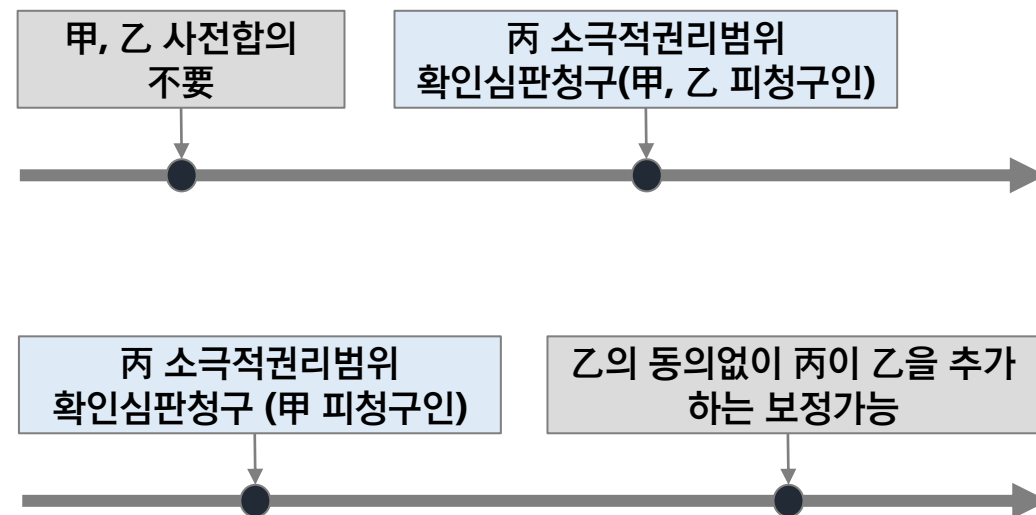
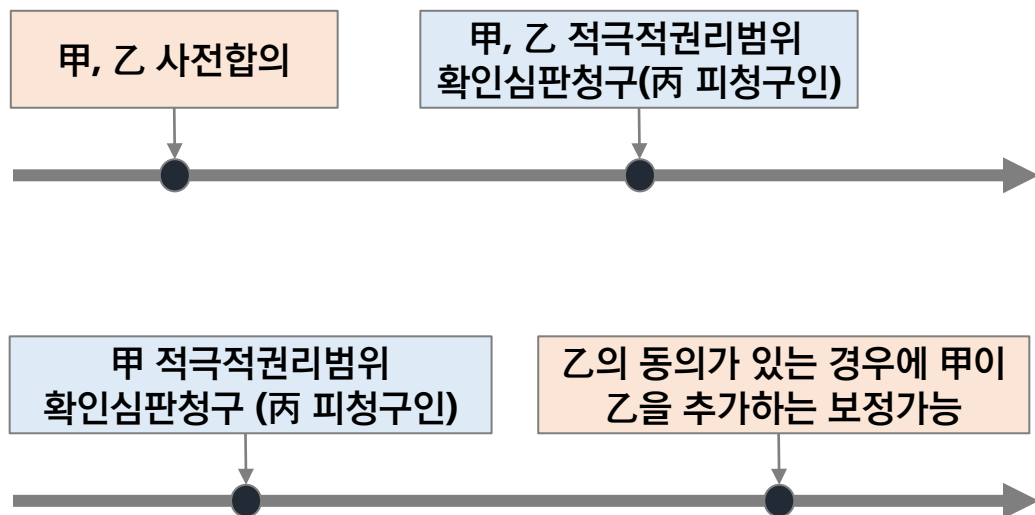
제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항·제2항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

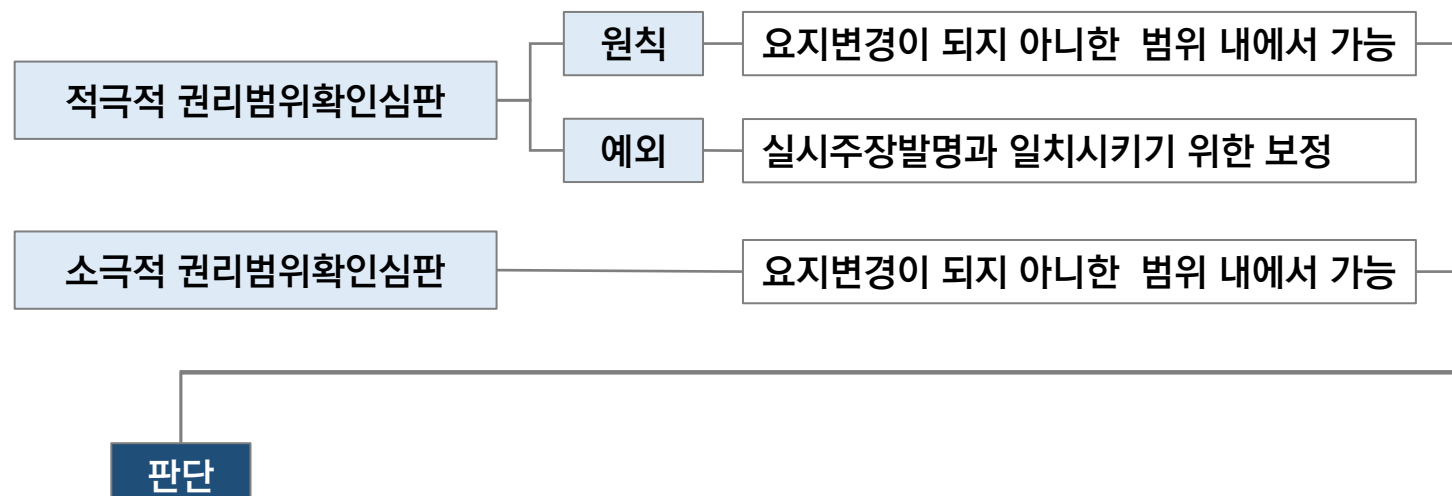
② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.

③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

甲, 乙 : 특허권자, 丙 : 이해관계인

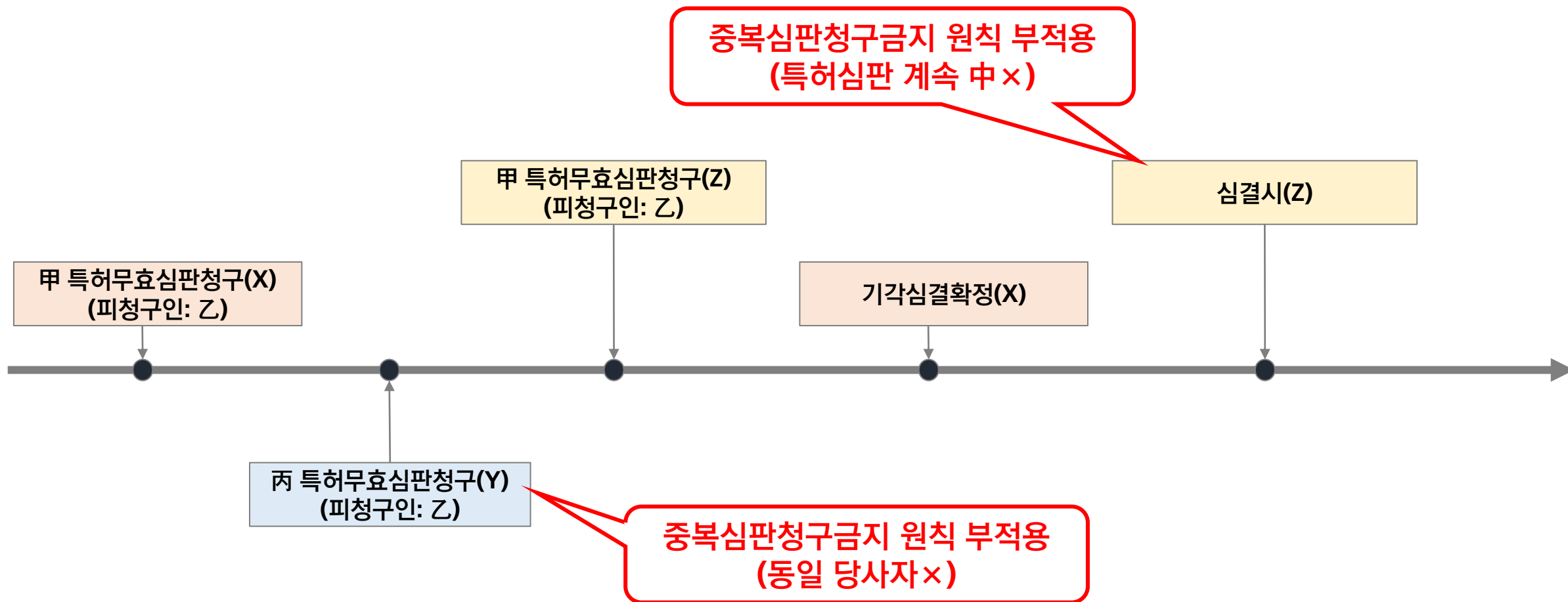




- i) 도면에 도시된 구성을 설명서에 부가하는 경우(대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344),
- ii) 특허발명과 대비될 수 있는 구성의 부가하는 경우(특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252),
- iii) 확인대상발명에 상품명 · 제품번호 또는 실물사진이 제출되었는데 그와 동일하게 보정하는 경우(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356),
- iv) 청구이유 및 심판청구서에 첨부된 증거자료에 기재된 구성의 부가하는 경우(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후61)

확인대상발명의 보정은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우로서 i) 심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 불명확한 부분을 구체화하는 것이거나, ii) 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것이라면 요지변경에 해당되지 아니한다. 확인대상발명의 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 “동일성” 개념은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있는가라고 하는 견지에서 파악되는 것으로서, 신규성, 선출원주의 등의 특허요건에서의 개념과는 그 고찰의 근거가 다르다. 예를 들어, 권리범위확인심판에서 심판청구서의 설명란에 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성에 관한 기재가 생략되었거나 확인대상발명과 대비되는 특허발명의 청구범위에 기재되어 있는 구성요소에 상응하는 구성에 대한 발명의 설명이 없었음에도, 이러한 구성에 관한 기재를 추가하거나 변경하는 보정은, 설사 특허요건에서의 발명의 동일성의 범위를 벗어나거나, 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는 것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다(특허법원 2007. 6. 1. 선고 2006허010661). 결국, 심판단계에서 확인대상발명의 보정이 이루어진 경우, 그 보정이 요지의 변경에 해당하는지의 여부는 보정 전후 확인대상발명에서 변경된 구성요소의 중요도, 보정의 경위(보정의 시기, 보정명령에 따른 것인지), 보정 후 피심판청구인이 방어권을 행사하였는가 등의 여러 사정을 고려하여 규범적으로 판단하여야 할 것이다(한동수, “확인대상고안의 보정시 요지변경의 의미”, 한국특허법학회 편, 「특허판례연구」, 박영사, 2009, 616면).

특허심판이 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구하지 못한다(法 154⑧ 준용 民訴 259). 이미 계속되고 있는 사건에 대하여 다시 심판 청구를 허용함은 심판제도의 남용이고, 심판원이나 당사자에게 시간·노력·비용을 이중으로 낭비시키는 것이어서 심판경제상 바람직하지 않고, 심결이 서로 모순·저촉될 염려가 있기 때문이다.

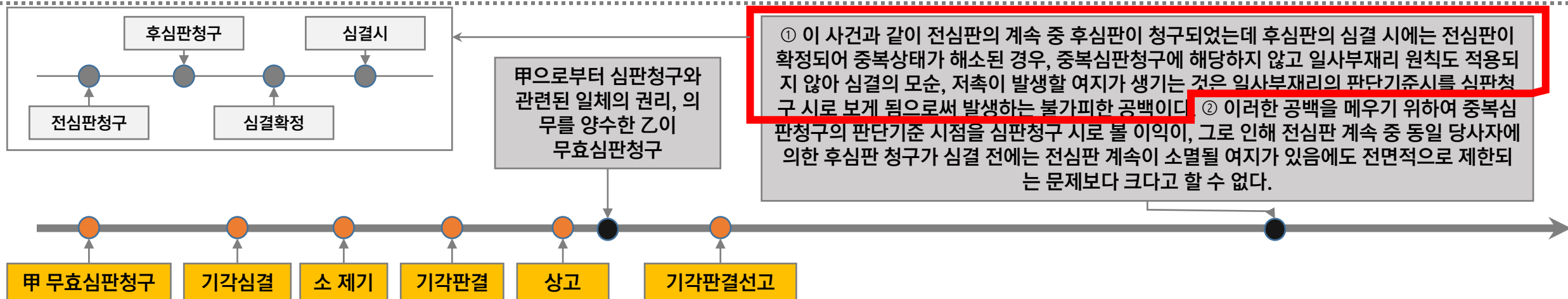


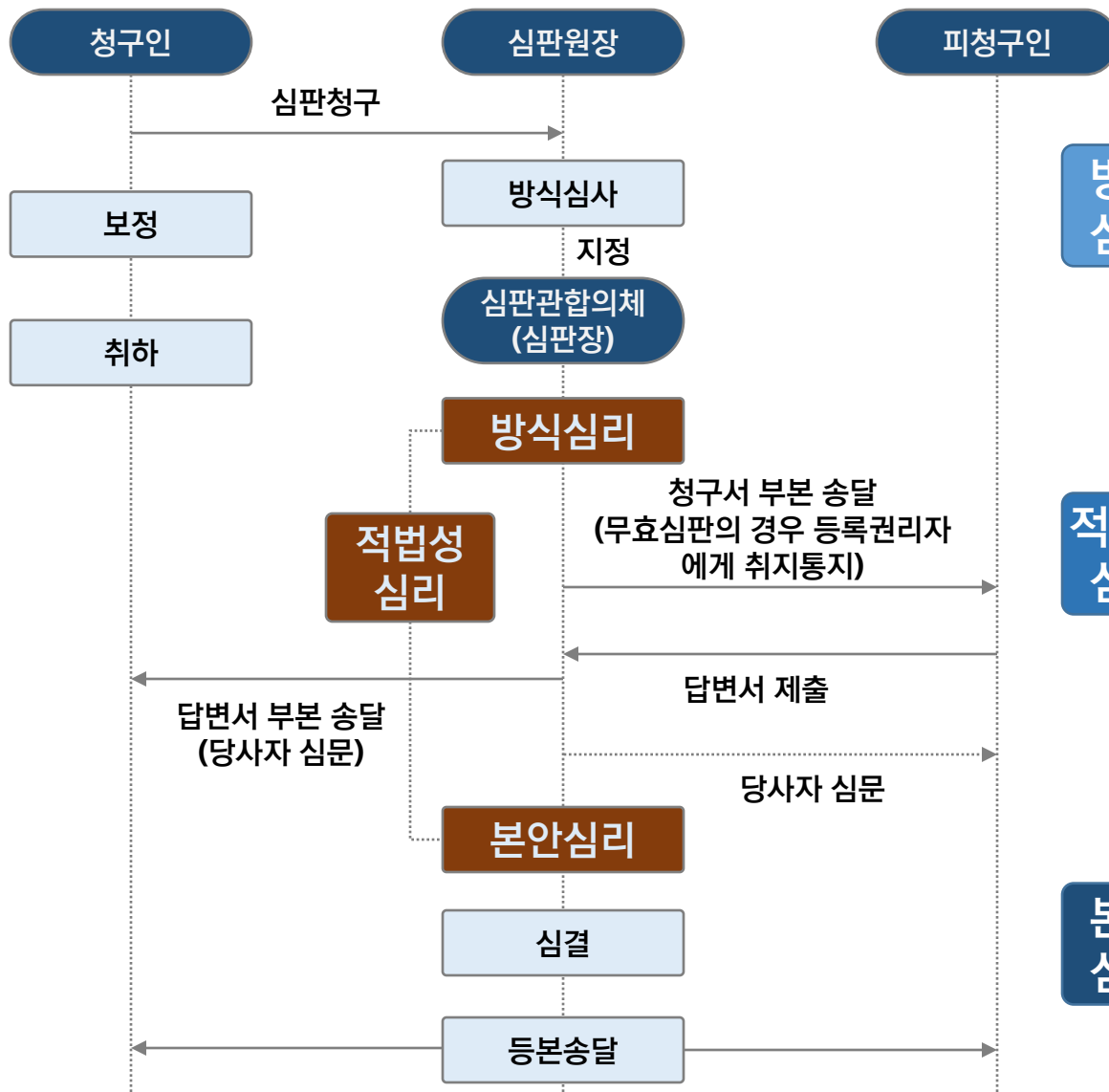
대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결 【등록무효(특)】

민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.

1) 민사소송에서 중복제소금지 는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066 판결 등 참조). 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

2) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조). **중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.**



방식
심리

- 심판장이 심판청구의 형식(심판청구서)이 본안심리 받기에 적절한지 여부를 검토
- 위반시 심판장이 심판청구서를 결정각하

적법성
심리

- 심판관합의체가 심판청구의 내용(심판청구)이 본안심리 받기에 적절한지 여부를 검토
- 위반시 심판관합의체가 심판청구를 심결각하
- 방식심리에서 본안심리하는 과정에서 적법성 심리를 함 (일반적으로 피청구인에게 부분송달하여 답변서 제출기회를 준 후 본안심리하는 과정에서 적법성 심리를 하여 심결각하하나, 피청구인에게 답변서 제출기회를 주지 않고 방식심리하는 과정에서 적법성 심리를 하여 심결각하할 수 있음)

본안
심리

- 심판관합의체가 심판청구의 내용(심판청구)이 타당한지(이유 있는지) 여부를 검토
- 심판관합의체는 심판청구를 인용심결(타당O) 또는 기각심결(타당X)

심사단계에서의 직권보정(제66조의2)	심판단계에서의 직권보정(제141조)
제66조의2(직권보정 등) ① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제47조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다. ② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다. ③ 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. ④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다. 다만, 특허출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다. ⑤ 삭제 ⑥ 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.	제141조(심판청구서 등의 각하) ① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. 다만, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다. 1. 심판청구서가 제140조제1항 및 제3항부터 제5항까지 또는 제140조의2제1항을 위반한 경우 2. 심판에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우 나. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우 다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우 ② 심판장은 제1항 본문에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제140조제2항 또는 제140조의2제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다. ③ 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. ④ 심판장은 제1항 단서에 따라 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다. ⑤ 청구인은 제1항 단서에 따른 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 심판장에게 제출하여야 한다. ⑥ 청구인이 제5항에 따라 의견서를 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다. ⑦ 제1항 단서에 따른 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

제도	심사단계에서의 직권보정(제66조의2)	심판단계에서의 직권보정(제141조)
요건	특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우. 단, 신규사항이 추가되지 아니한 범위에서 가능	심판청구서의 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우
절차	1. 심사관이 직권보정을 하려면 특허결정의 등본 송달과 함께 출원인에게 통지 2. 특허출원인은 직권보정 사항의 일부 또는 전부를 받아들일 수 없으면 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 지식재산처장에게 제출	1. 심판장이 청구인에게 통지 2. 청구인이 받아들일 수 없으면 통지를 받은 날로부터 7일 이내 의견서를 심판장에게 제출
효과	1. 의견서 제출한 경우 ① 해당 직권보정사항은 처음부터 없었던 것으로 간주 ② 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 간주. 다만, 요약서에 관한 직권보정 사항만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우는 제외 2. 의견서를 제출하지 않은 경우 직권보정 수용한 것으로 취급. 단, 직권보정사항이 신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 처음부터 없었던 것으로 간주	1. 의견서 제출한 경우 해당 직권보정사항은 처음부터 없었던 것으로 간주 2. 의견서를 제출하지 않은 경우 직권보정 수용한 것으로 취급. 단, 직권보정사항이 명백히 잘못된 경우 처음부터 없었던 것으로 간주

제154조(심리 등) ① 심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.

② 삭제

③ 구술심리는 공개하여야 한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋날 우려가 있으면 그러하지 아니하다.

④ 심판장은 제1항에 따라 구술심리로 심판을 할 경우에는 그 기일 및 장소를 정하고, 그 취지를 적은 서면을 당사자 및 참가인에게 송달하여야 한다. 다만, 해당 사건의 이전 심리에 출석한 당사자 및 참가인에게 알렸을 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 심판장은 제1항에 따라 구술심리로 심판을 할 경우에는 특허심판원장이 지정한 직원에게 기일마다 심리의 요지와 그 밖에 필요한 사항을 적은 조서를 작성하게 하여야 한다.

⑥ 제5항의 조서에는 심판의 심판장 및 조서를 작성한 직원이 기명날인하여야 한다.

⑦ 제5항의 조서에 관하여는 「민사소송법」 제153조·제154조 및 제156조부터 제160조까지의 규정을 준용한다

⑧ 심판에 관하여는 「민사소송법」 제143조·제259조·제299조 및 제367조를 준용한다.

⑨ 심판장은 구술심리 중 심판정 내의 질서를 유지한다.

심판정

심판관

심판장

심판관

직원

청구인

대리인

대리인

피청구인

증언대

방청석

	구술심리	기술설명회
대상	- 무효심판, 권리범위확인심판 등	- 주로 기술분야 특허사건
절차	- 공개주의 - 기일, 장소 통지 - 조서 작성(기명날인) - 속기 또는 녹취(조서의 일부)	- 비공개원칙 -쟁점정리

직권
주의

직권진행주의

제158조(심판의 진행) 심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간에 절차를 밟지 아니하거나 제154조제4항에 따른 기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다.

제158조의2(적시제출주의) 심판절차에서의 주장이나 증거의 제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조, 제147조 및 제149조를 준용한다.

민사소송법 제146조, 제147조 및 제149조

제146조(적시제출주의)

공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다.

제147조(제출기간의 제한)

① 재판장은 당사자의 의견을 들어 한 쪽 또는 양 쪽 당사자에 대하여 특정한 사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 정할 수 있다.

② 당사자가 제1항의 기간을 넘긴 때에는 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없다. 다만, 당사자가 정당한 사유로 그 기간 이내에 제출 또는 신청하지 못하였다는 것을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다.

제149조(실기한 공격·방어방법의 각하)

① 당사자가 제146조의 규정을 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정할 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

② 당사자가 제출한 공격 또는 방어방법의 취지가 분명하지 아니한 경우에, 당사자가 필요한 설명을 하지 아니하거나 설명할 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

제160조(심리·심결의 병합 또는 분리) 심판관은 당사자 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다.

직권탐지주의

제157조(증거조사 및 증거보전) ① 심판에서는 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 증거조사 및 증거보전에 관하여는 「민사소송법」 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다. 다만, 심판관은 다음 각 호의 행위는 하지 못한다.

1. 과태료의 결정

2. 구인(拘引)을 명하는 행위

3. 보증금을 공탁하게 하는 행위

③ 증거보전신청은 심판청구 전에는 특허심판원장에게 하고, 심판계속 중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다.

④ 특허심판원장은 심판청구 전에 제1항에 따른 증거보전신청이 있으면 그 신청에 관여할 심판관을 지정한다.

⑤ 심판장은 제1항에 따라 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

제159조(직권심리) ① 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

② 심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다.

심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다(法 159②). 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 관하여 심리를 하는 것은 청구인의 의사에 반하여 청구의 취지를 변경하는 것으로서, 민사소송법상의 처분권주의에 반하는 것이기 때문이다. 예를 들어, 소극적 권리범위확인심판청구가 이유가 없으면 그 청구를 배척함에 그쳐야 하고 나아가 적극적으로 그것이 권리범위에 속한다는 내용의 심결을 한 것은 위법이다. 또한, 다항의 청구항 중 하나의 청구항에 대해서 특허무효심판이 청구된 경우 다른 청구항에 대해서 특허무효의 이유가 발견되었다고 하더라도 심판관이 이를 심리할 수는 없다. 특허무효심판의 경우 청구항을 달리 하면 청구취지를 달리 하기 때문이다. 이는 소송법이 강조하는 「訴 없으면 裁判 없다」는 不告不理의 원칙과 일맥상통한다. 한편, 정정심판을 청구한 것은 일체불가분의 1개의 정정사항으로 하여 정정심판을 청구한 것으로 본다. 그러므로 명세서의 일부에 대하여 정정을 인정 또는 불인정하는 것은 결국 1개의 기술적 사상인 발명을 분리하여 판단하는 것이 되며, 청구인이 신청하지 아니한 취지에 대하여 심리하는 것이 되므로 일부인용 또는 일부기각심결은 인정되지 아니한다고 할 것이다.

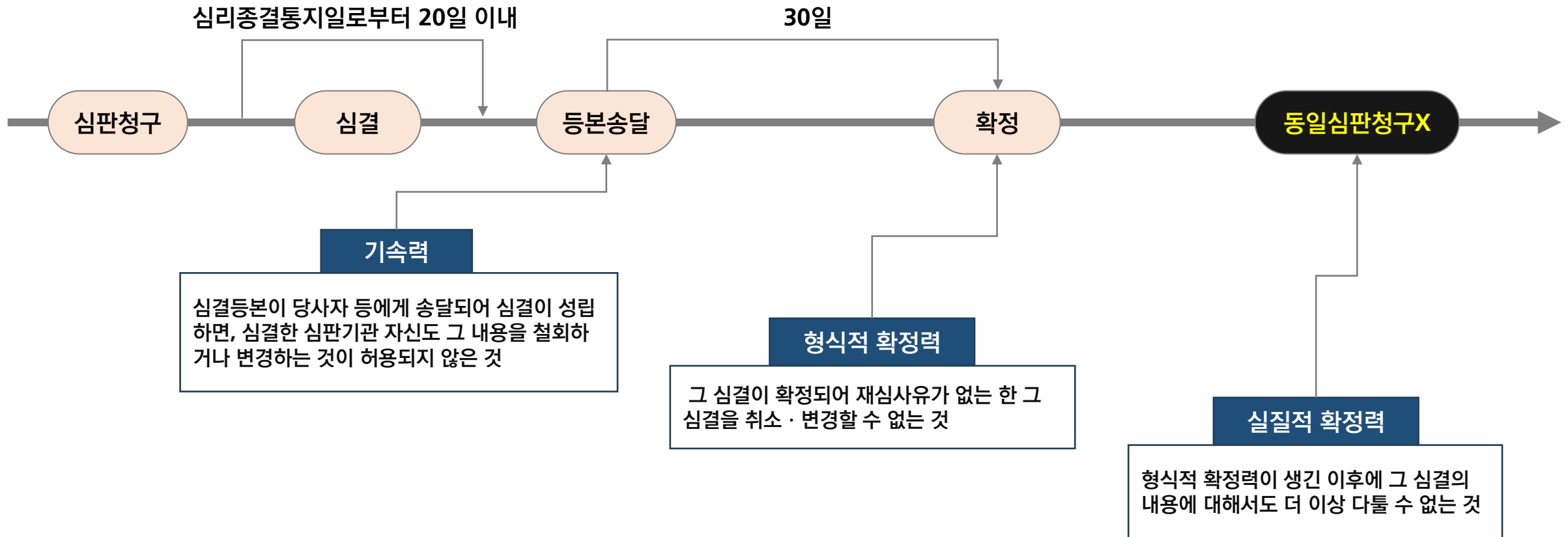
심판청구서

- 청구인 성명 및 주소
- 피청구인 성명 및 주소
- 심판사건의 표시: 특허 제1234567호의 무효심판
- 청구의 취지:
 - 제1항 내지 제3항은 무효이다.
 - 심판비용은 피청구인이 부담한다.
- 청구의 이유
 - 제1항: 제42조제4항제2호 위반
 - 제2항 및 제3항: 제29조제1항 위반

직권
심리제1항이 제42조제8항 위반이다. 제2항이 제29조제2항 위반이다. 제4항이 제29조제2항 위반이다. 

특허무효사유 제외

신청하지 아니한 취지

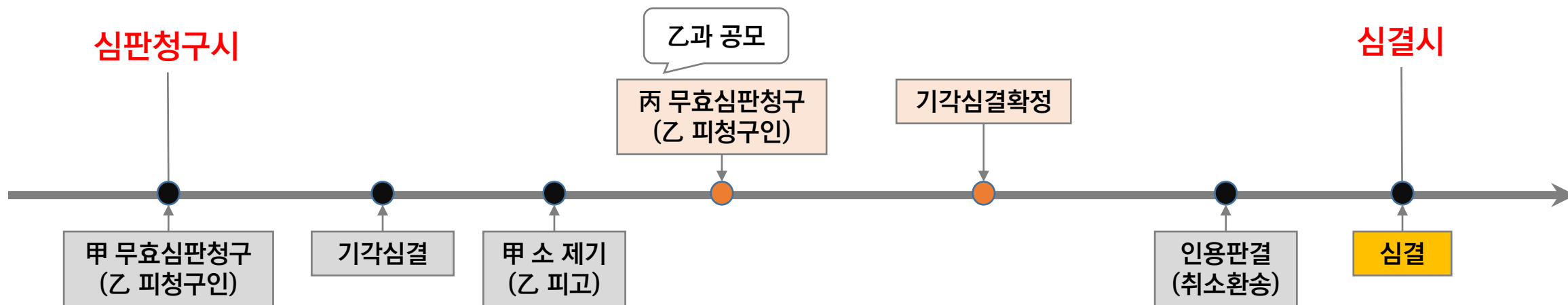


중복심판청구금지의 원칙 vs 일사부재리의 원칙

요건		일사부재리	중복심판청구
내용		본안심결 확정	특허심판이 계속 중 (특허법원, 대법원 계속 중도 포함(2013허9805))
		누구든지	동일 당사자
		동일사실 및 동일증거	-
		동일심판 (적극적 vs 소극적 권리범위확인심판을 동일심판으로 인정(75후18))	동일심판 (적극적 vs 소극적 권리범위확인심판이 동일심판인지에 대하여 판례 나뉨(2008허12289, 2016허2249))
판단	주체	심판관합의체	
	객체	당사자계 심판	당사자계 심판+결정계 심판
	시기	심결시(2018후11360) 단, 선행심결의 확정시점은 심판청구시(2009후2234)	심결시(2016후2317)
	방법	직권조사사항	
조치		심결각하	

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결 【등록무효(특)】

1) 이는 관련 확정 심결의 등록*이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 **국민의 재판청구권을 과도하게 침해**할 우려가 있고, 2) 그 심판에 대한 특허심판원의 심결을 취소한 **법원의 판결을 무의미**하게 하는 불합리가 발생하게 된다. 3) 나아가 구 특허법 제163조의 취지는 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있다. 그러나 위 규정은 일사부재리의 효력이 미치는 인적범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, **함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과**가 될 것이다. 그런데 구 특허법 제163조는 위와 같이 ‘그 심판을 청구할 수 없다’라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 아니한다고 해석될 뿐이다. 그러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 이미 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에까지 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다.

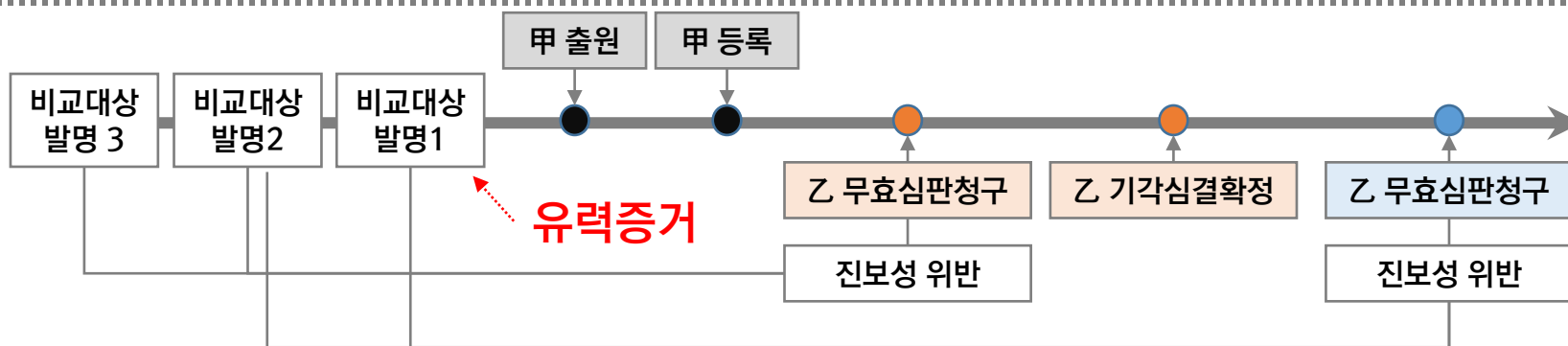


* 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제163조는 “이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.”라고 규정하고 있었는데, 개정법은 등록되지 않은 심결에도 일사부재리가 적용되는 것으로 변경하였고, 1998. 3. 1. 특허법원 설립 이후의 특허법원 판결이나 대법원 판결 및 실체 심리가 없는 각하심결에도 일사부재리가 적용되는지에 관한 해석상의 다툼에 대하여 ‘판결이 확정된 때’ 부분을 삭제하고, 단서 규정을 신설함으로써 다툼의 여지가 없게 하였다(김신, “확정심결의 일사부재리”, 「특허소송연구」 제7집, 특허법원, 2017, 154면).

대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결 【등록무효(특)】

[1] 일사부재리의 원칙을 정한 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제163조는 “심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.”고 하여 일사부재리의 원칙을 규정하고 있으나, **확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거가 새로이 제출된 경우에는 위와 같은 일사부재리의 원칙에 저촉되지 아니한다.**

[2] 동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 **전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 않으나, 1) 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 않았던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 2) 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 3) 등과 같이 4) 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.**



원심은 이 사건 특허발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의해서 부정된다고 판단하고, 부가적으로 비교대상발명 1과 이전 확정심결의 선행기술이었던 비교대상발명 2(원심 절차에서 추가되었다)의 결합에 의해서도 그 진보성이 부정된다고 판단하였다. 그런데 원심의 위 부가적 판단은 전체적으로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 이전 비교대상발명과 달리 비교대상발명 1에 추가로 구비되어 있는 ‘보조인출체(8)에 설치된 보조피이더(9)’구성으로부터 이 사건 특허발명의 기술적 특징을 이루는 구성 2의 ‘부정제피이더(72)’구성을 용이하게 도출할 수 있다는 전제 아래, **통상의 기술자라면 여기에 비교대상발명 2를 추가적, 보충적으로 결합함으로써 이 사건 특허발명을 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다는 취지라고 할 것이다.** 따라서 원심의 이 부분 판단 내용은 앞서 본 바와 같은 **이전 확정심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없으므로, 비록 비교대상발명 2에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단한 이전 확정심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.**

다른 CASE(특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207): 원고는 2012년경 피고들의 특허가 **선행발명 3, 4**에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 기각하고 그 심결은 확정되었다. 원고는 2016년에 이르러 다시 피고들을 상대로 **선행발명 1내지 5**에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 선행발명 1, 2, 5는 새로운 증거이므로 심판청구가 일사부재리의 원칙에 저촉되는 것은 아니지만, 선행발명 1 내지 5에 의하더라도 진보성이 부정되지 않는다고 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 그런데 원고가 제출한 위 증거들 중 선행발명 3, 4는 확정된 종전 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로서 동일 증거에 해당한다. 나아가 **선행발명 1, 2, 5 내지 8도 확정된 종전 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 할 수 없으므로 확정된 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.** 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조의 일사부재리 원칙에 위배되어 허용될 수 없는 것이다. 따라서 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되지 않은 것으로 보아 이를 각하하지 않고 본안으로 나아가 판단한 나머지 이를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

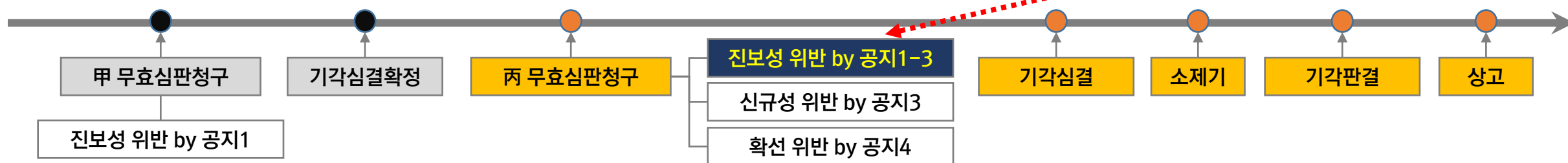
일사부재리 적용 CASE: 동일사실

대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 [등록무효(실)]

[1] 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다. 그리고 **청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다.** 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 **명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.** 다만 특허심사는 지식재산처 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다. 그렇다면 **명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정**함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 반복될 수 있다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[2] 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다. 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다.

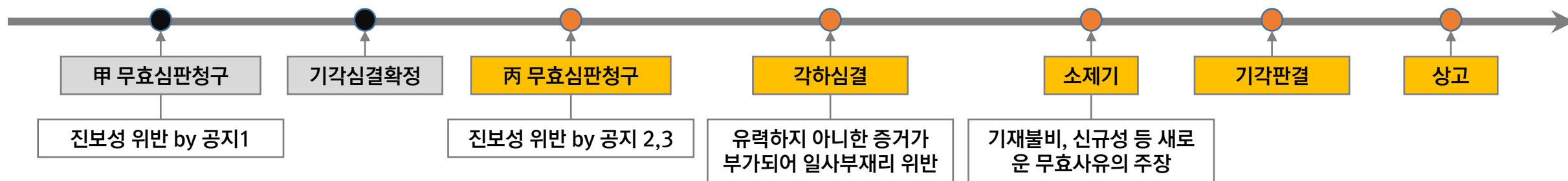
심판을 각하하지 않고 진보성 위반에 대해서는 실권효를 인정하여 본안심리x



대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 【등록무효(특)】

[1] 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다. 심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다. 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

[2] 심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·증명할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불이익의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).



일사부재리 원칙 위반을 이유로 한 각하 심결에 대한 심결취소소송에서 심판청구인이 동일사실 및 동일증거가 아님을 주장하는 새로운 주장 및 증거제출은 허용되나, 심판절차에서 심결시까지 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않고, 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없으며, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

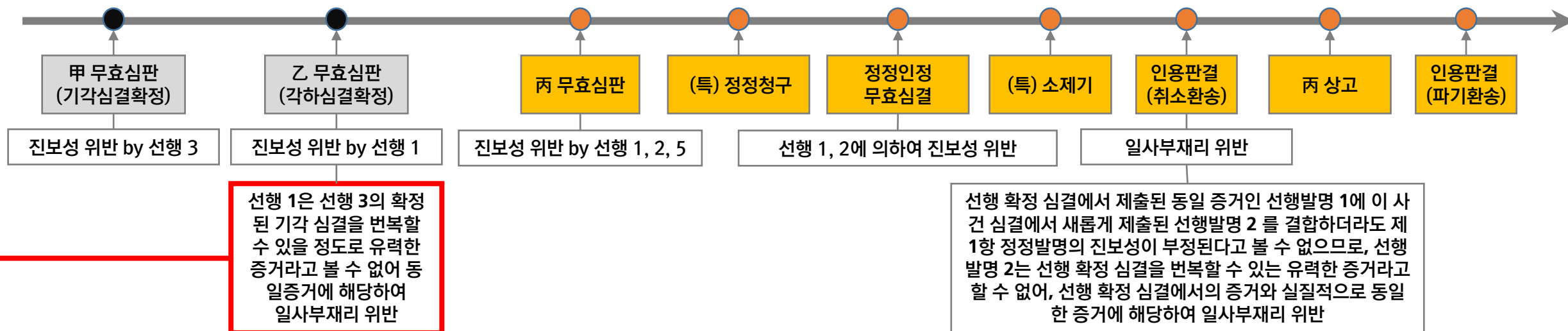
대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결 【등록무효(특)】

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다. 따라서, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다. 다음과 같은 점을 고려하면, 위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

가. 종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

나. 특허법 제163조의 ‘동일 증거’라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조). 이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리, 판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다. 하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

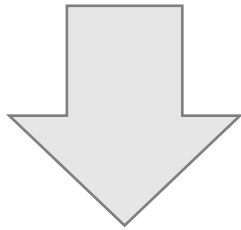
다. 심판청구의 남용을 막고, 모순저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 1) 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 2) 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.



제170조(심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용) ① 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호, 같은 조 제4항, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용한다. 이 경우 제51조제1항 본문 중 "제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정"은 "제47조제1항제2호에 따른 보정(제132조의17의 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)"으로, 제63조의2 본문 중 "지식재산처장"은 "특허심판원장"으로 본다.

② 제1항에 따라 준용되는 제63조는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다.

제47조제1항제2호 및 제3호에
따른 보정



최후거절이유통지

제47조제1항제2호에 따른 보정
(제132조의17의 특허거절결정에
대한 심판청구 전에 한 것은 제외
한다)

심판청구 전 부적법한 보정이 심판청구 후 발견

제47조제1항제3호 시기에 보정 범위 위반

심판청구 전 제47조제1항제2호 시기에 보정 범위 위반

심판청구 후 제47조제1항제2호 시기에 보정 범위 위반

제외

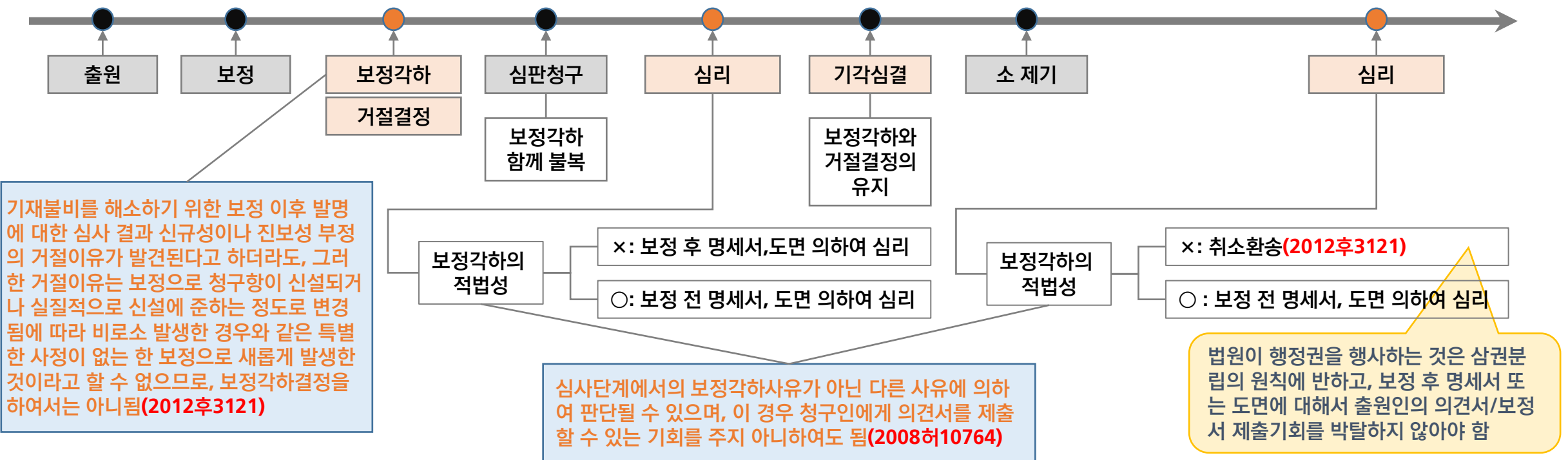
제외

포함

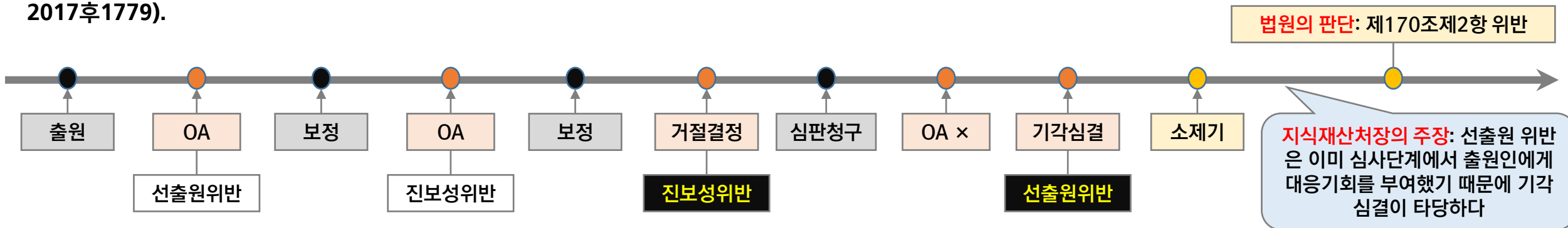
보정각하의 타당성에 대한 심리

지식재산처는 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없다(특허법원 2009. 7. 10. 선고 2008허10764).

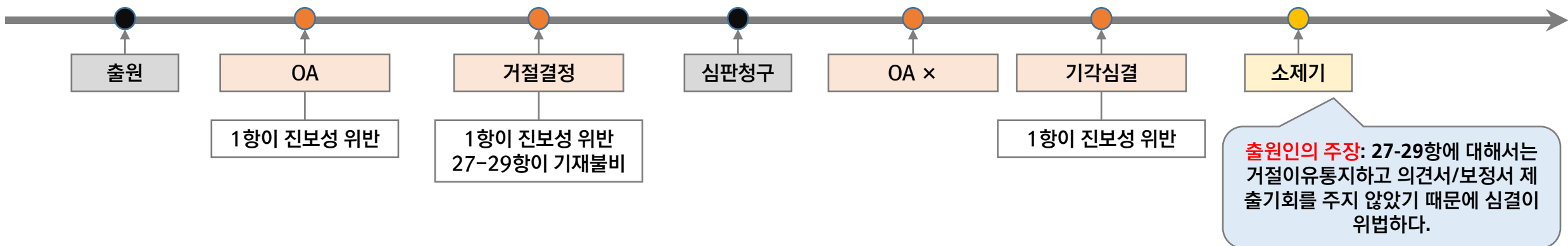
특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 ‘보정 전의 특허출원’에 대하여 거절결정을 하였 고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 그 심결취소소송에 서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출 원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121).



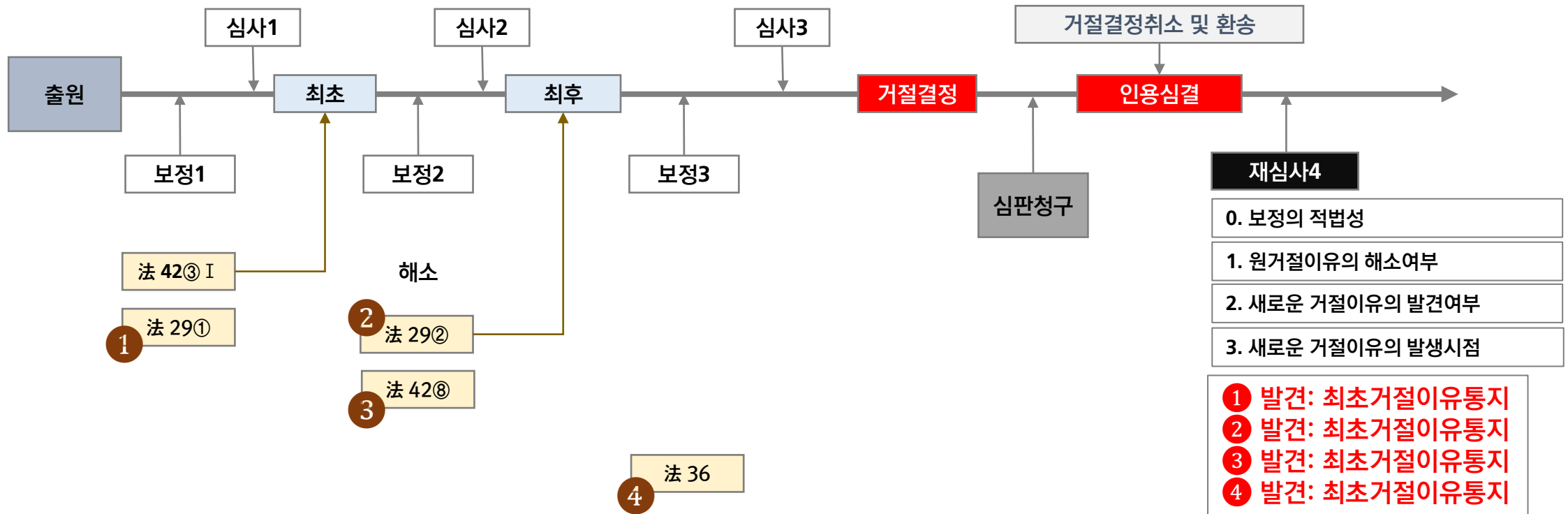
거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 예를 들어, 심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다(대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779).



특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로 거절이유통지를 하지 않고 한 심결을 위법하다고 할 수 없다.(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820).

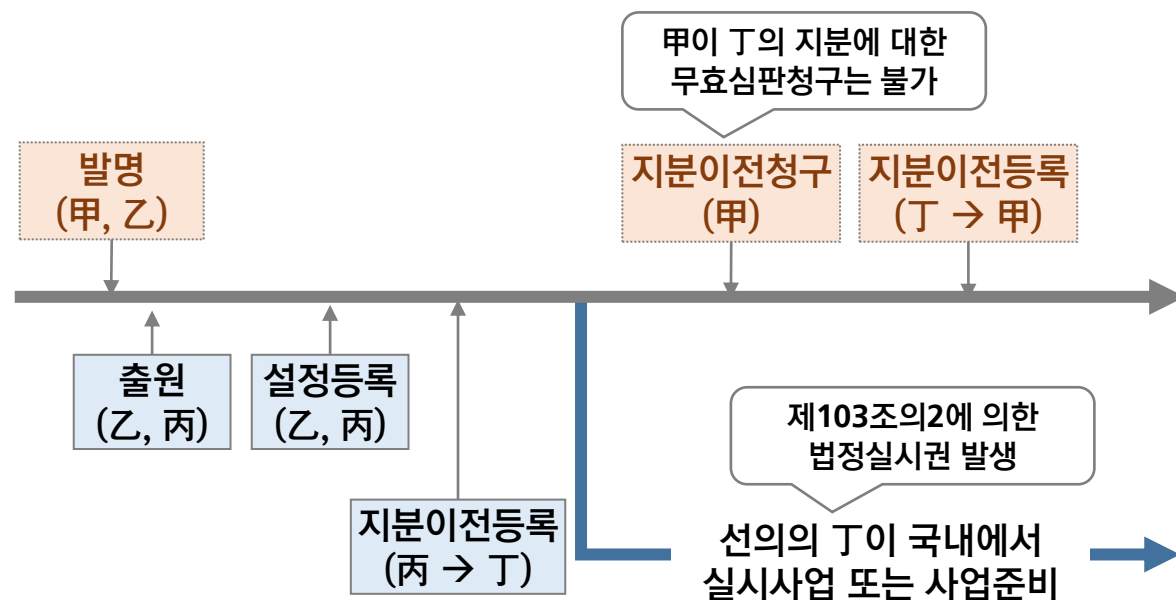


취소환송된 출원은 거절결정 또는 보정각하결정만 취소되었을 뿐 그 결정에 앞서 행해진 심사에서 밝힌 특허에 관한 절차 및 심사관이 행한 절차는 모두 유효하므로 거절결정이나 보정각하결정만 없던 것으로 보고 통상의 심사와 동일하게 심사한다. 다만, 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유를 통지하는 경우에는, 심사관의 잘못된 거절결정으로 절차의 지연이라는 불이익을 감수하였던 출원인에게 다시 보정의 범위를 제한하는 것이 가혹하다는 점, 특허법 제66조의3에 따른 직권 재심사에서도 취소통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유를 통지하는 경우에 최초거절이유를 통지한다는 점을 고려하여, 통지하는 거절이유를 **최초거절이유**로 한다.

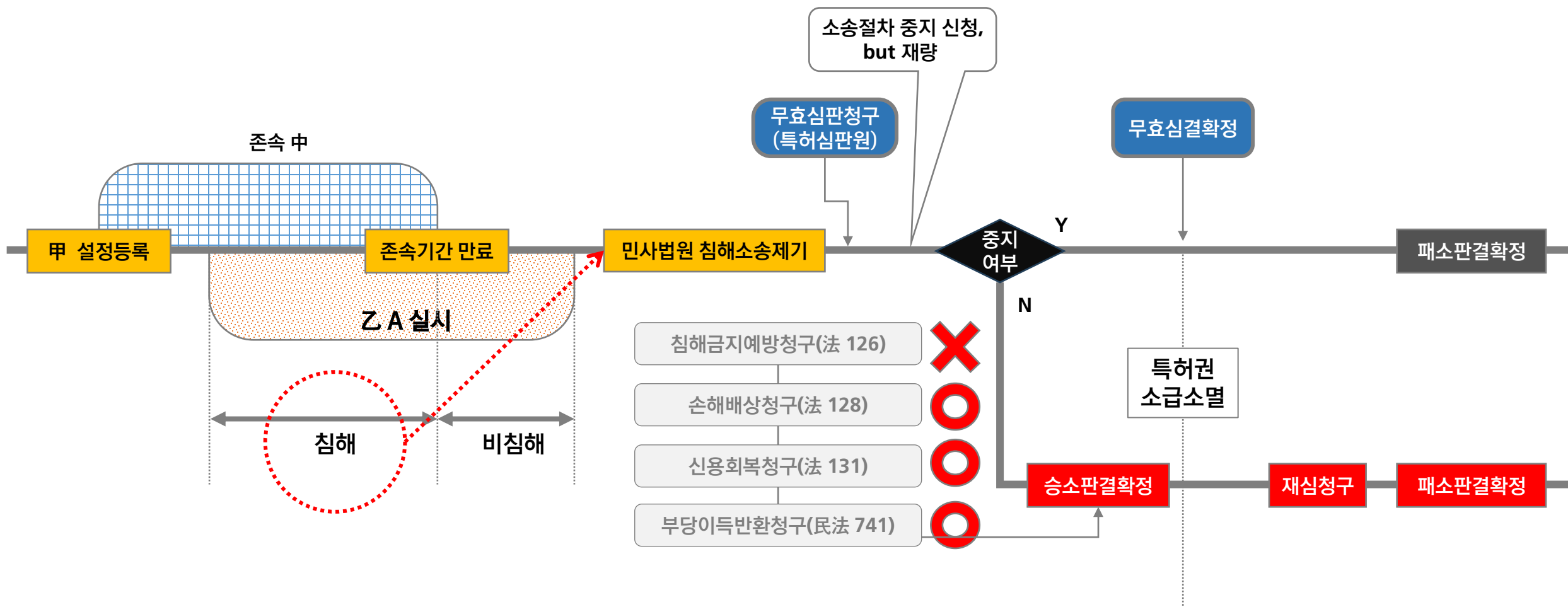


특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432). 이 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 무효심판을 청구하지 않고 무권리자를 상대로 공유 특허권의 지분을 이전을 직접 청구할 수 있다(法 99의2). 원심판결인 특허법원 2012. 6. 22. 선고 2011허11750 판결에서는 i) 특허법은 제133조제1항에서 '청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 무효심판을 청구할 수 있다'고 규정하면서도, 공유인 특허권의 일부 지분권에 대하여는 무효심판청구가 가능하다는 취지의 규정을 두고 있지 않고 있는 점, ii) 특허법 제139조제2항은 '공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피심판 청구인으로 하여 청구하여야 한다.'고 규정하는 있는 점, iii) 특허법 제44조, 제62조제1호, 제133조제1항제2호 등의 규정에 의하면, 특허법은 다수가 특허권을 공유하는 경우에도 그 특허권이 일체로서 발생, 소멸하는 것을 전제로 권리관계를 규정하고 있다고 볼 수 있는 점, iv) 특허법 제139조제2항에도 불구하고 공유자 중 일부가 나머지 공유자를 상대로 하는 특허권의 지분권에 대한 무효심판청구를 허용할 경우, 무효심판이 확정된 지분권은 소급적으로 그 효력이 소멸될 뿐이고 무효심판이 확정되지 아니한 다른 지분권의 권리자에게 그 소멸된 지분권이 귀속된다고 보기 어려우며, 소멸된 지분권에 대해서는 권리자가 새로이 특허출원을 하더라도 특허법 제44조를 위배한 것이어서 거절결정이 될 수밖에 없게 되는 등 복잡한 문제가 발생하는 점 등에 비추어 특허권의 공유자 중 일부를 상대로 그 지분권만의 무효심판을 청구하는 것을 허용될 수 없다고 판시하였다.

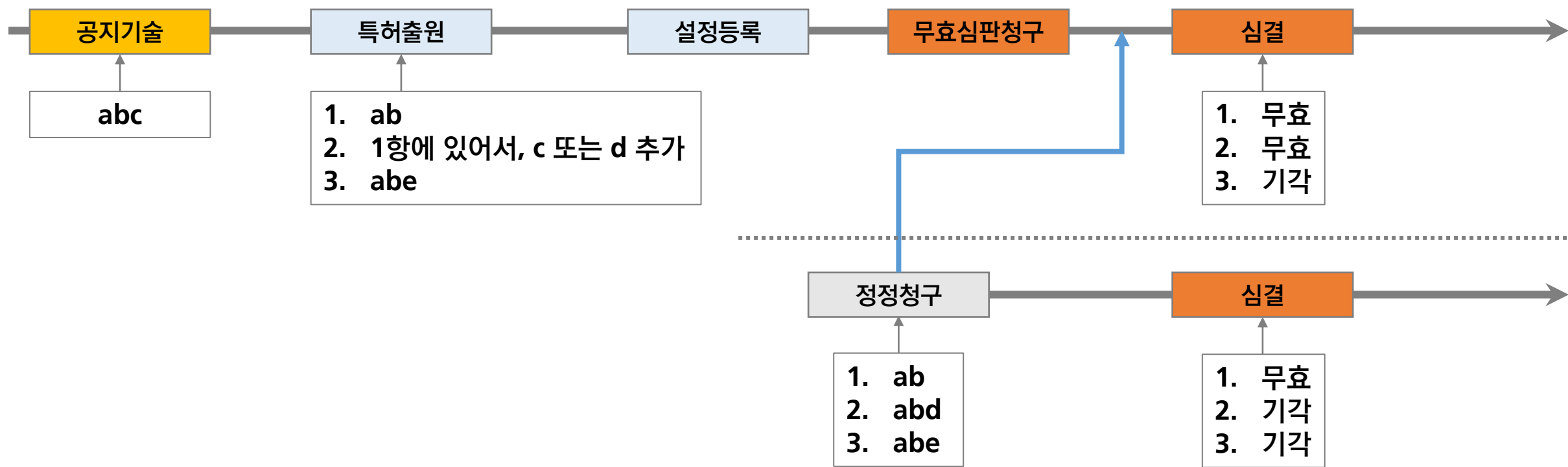
제44조 위반	출원일의 소급효	특허권(특허출원)의 이전청구
출원	×	○(해석상)
특허	×	○(法 99의2)
	-지분에 대한 무효심판청구불가	-무효사유에서 제외(法 133①Ⅱ단서) -특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 103의2) 인정가능



특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구의 이익이 있는 한 특허무효심판을 청구할 수 있다(法 133②). 특허권이 소멸된 후라도 소멸되기 전의 제3자의 실시에 대해서는 특허권자가 손해배상청구를 할 수 있기 때문에 특허를 무효 시킬 실익이 있다. 이 때 제3자가 특허무효심판청구에 의하여 무효심결이 확정 되면 손해배상을 할 필요가 없어진다. 다만, 특허권이 무효심결확정에 의하여 소급하여 소멸한 경우에는 특허무효심판을 청구할 실익이 없으며 청구한 무효심판은 심결각하된다. 한편, 후발적 사유에 의하여 무효가 된 경우에는 그 이전의 것에 대해서는 무효심판을 청구할 수 있다.

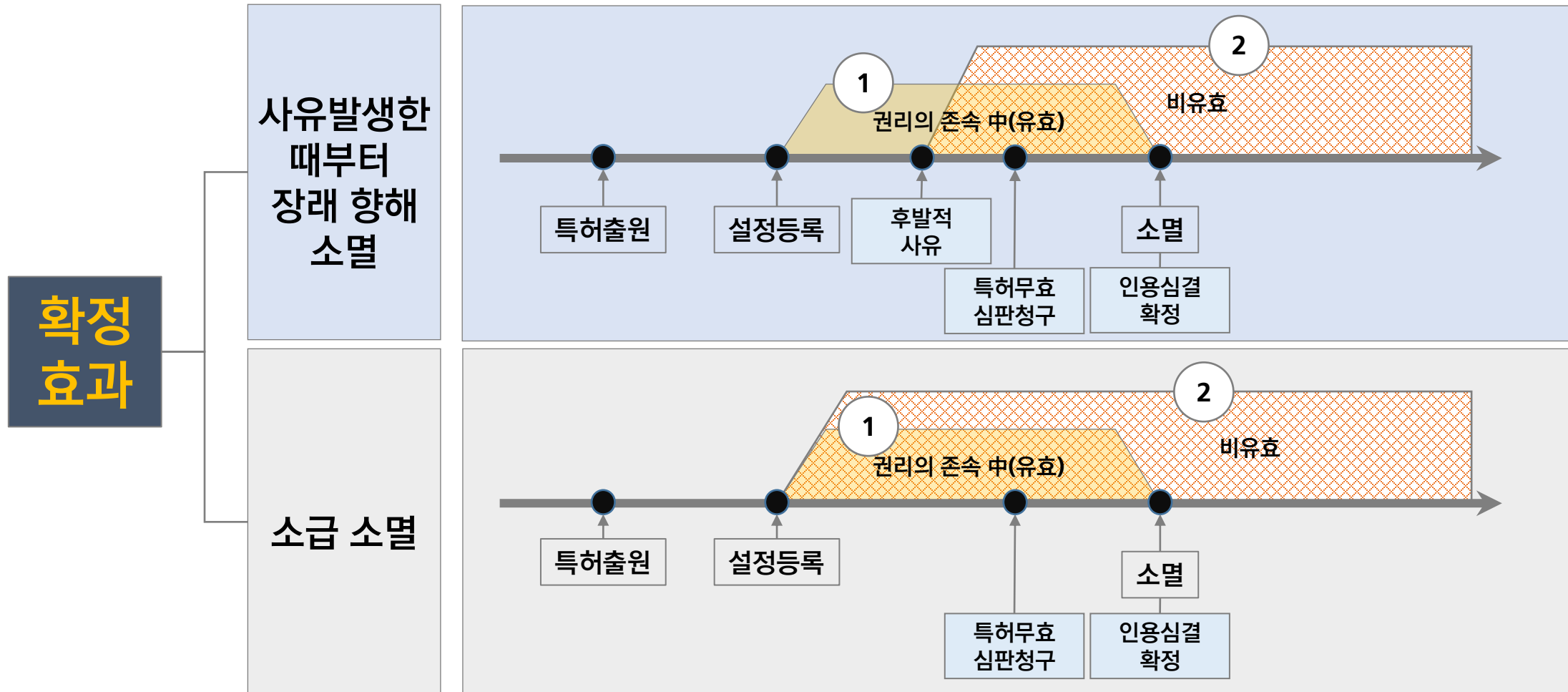


심판관은 i) 특허무효사유에 해당되지 아니하여 심판청구의 이유가 타당하지 않다고 인정된 때에는 기각심결을 하며, ii) 특허무효사유에 해당되어 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때에는 인용심결을 하여야 한다. 한편, 심판관은 특허무효심판을 청구한 여러 청구항 중 일부 청구항에 대해서만 특허무효사유가 있는 경우 **일부인용·일부기각**심결을 할 수 있다. 다만, 하나의 청구항에 여러 개의 발명이 포함되어 있고 그 중 일부가 무효라면 **그 청구항 전체를 무효**로 하여야 하는 것이지 청구항에 포함된 일부 발명만을 무효로 할 수는 없다.



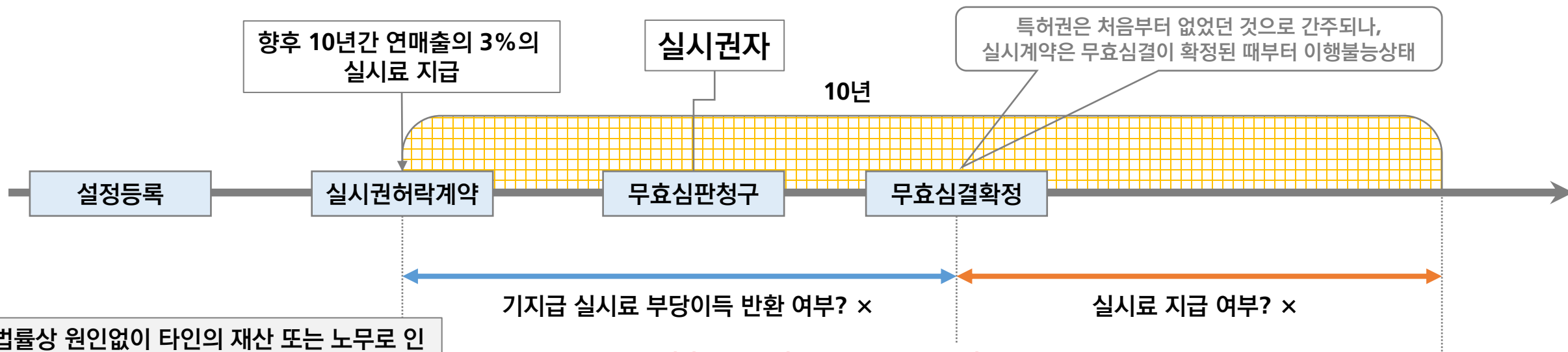
* abd, abe는 무효사유가 부존재

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 133①본문). 그러나 후발적 무효사유 즉, 특허된 후에 특허권자가 제25조(외국인의 권리능력)에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자가 되거나 그 특허가 조약을 위반하여 무효심결이 확정된 경우에는 소급효가 인정되지 않고, 특허권은 그 특허가 무효사유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(法 133③단서).



당사자 간에 실시료 불반환 합의와 같은 특약이 없는 경우 무효심결이 확정된 특허권에 대하여 지급된 실시료를 부당이득으로서 반환청구가 될 수 있는지와 관련하여 견해의 대립이 있었으나, 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결은 “특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제 3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.”고 하여 특별한 사정이 없는 한 부당이득의 반환 의무를 부정하였다. 또한, 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결에서는 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다고 판시하였다.

특허무효의 소급효라는 공법상 효력에 의하여 실시계약이라는 사법상의 법률관계까지 원시적 무효로 보기는 어렵다



법률상 원인없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 합니다 (민법 제741조).

기지급 실시료는 유효하게 존속하는 실시계약에 기하여 받은 것이므로 법률상 원인이 있고, 실시권자는 특허를 배타적으로 사용함에 따른 경제적 이익을 얻었으므로 손해도 없어 부당이득반환청구는 이유 없다.

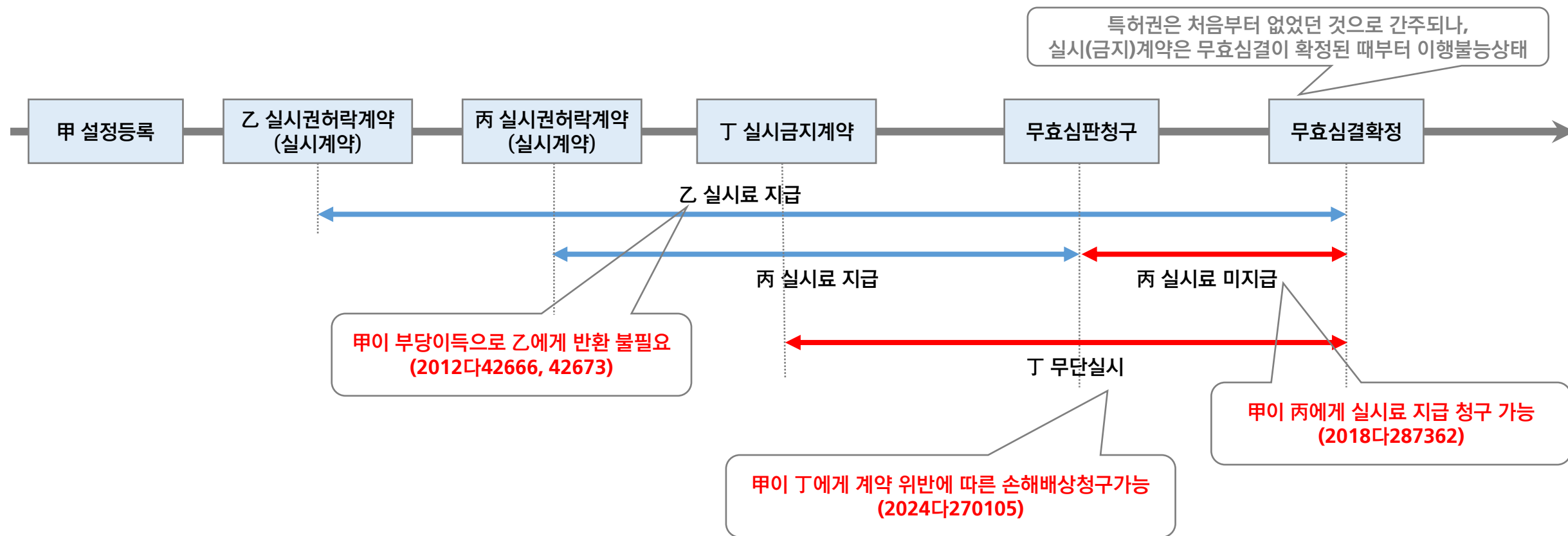
실시료 반환여부에 대한 학설*

임상민, “특허의 소급 무효와 기지급 실시료의 반환 여부 -대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결을 중심으로-”, 과학기술과 법 제6권 제2호(2015. 12)

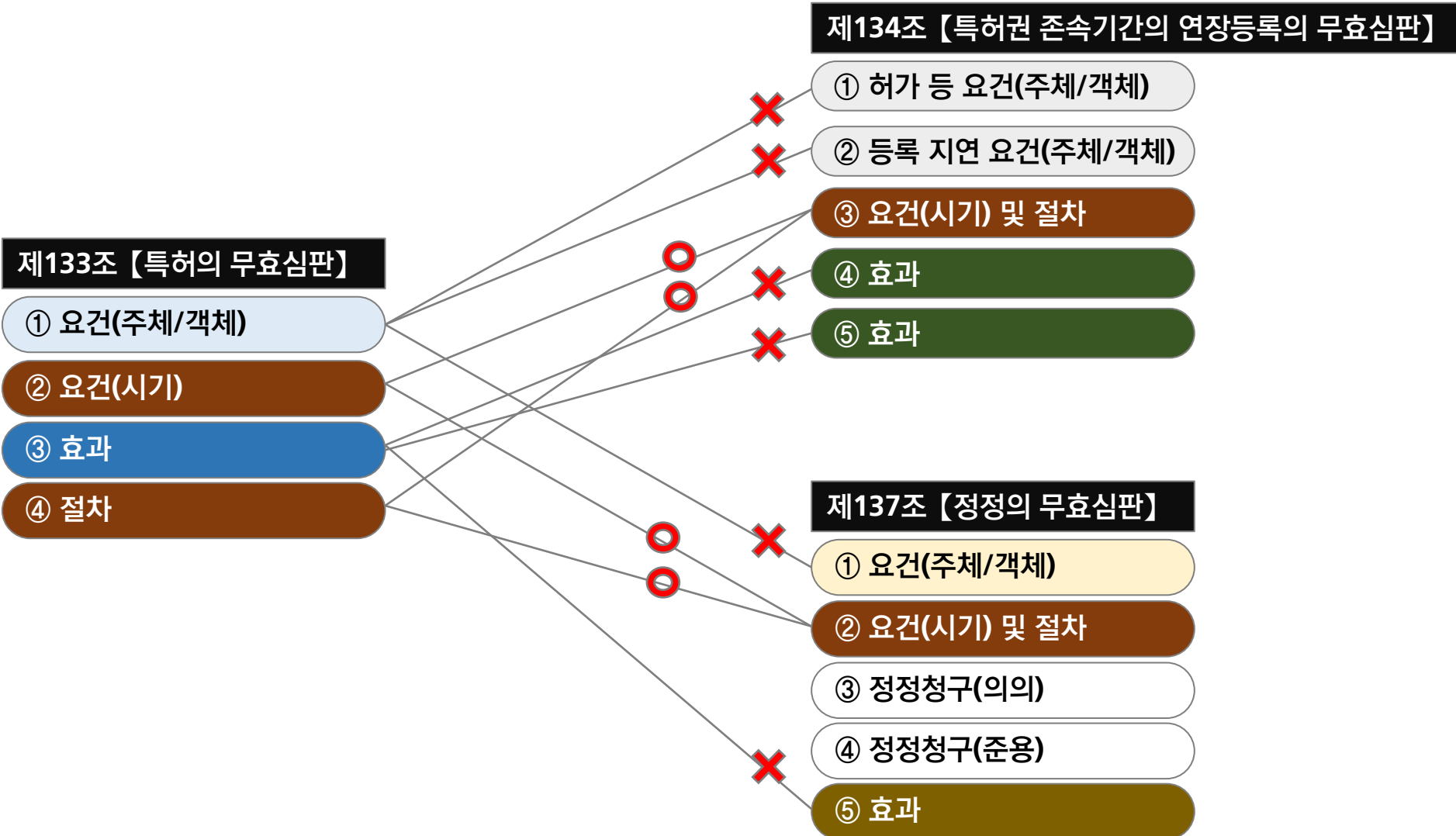
구분	부정설	긍정설
부당이득 반환 청구권 요건	- 특허실시계약의 목적인 급부는 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 채무의 이행이라 할 것인데, 그러한 급부가 무효 확정시까지 계약 내용대로 이행되었다. 그 결과 특허권자가 받은 실시료에 대한 ‘법률상 원인’이 존재한다. - 특허실시계약자는 특허의 무효 확정시까지 특허를 독점·배타적으로 사용함에 따른 경제적 이익을 향유하였으므로 ‘손해’가 발생하였다고 볼 수도 없다.	- 특허권자는 당초에 금지권을 행사할 여지가 없었기 때문에 금지권을 행사하지 아니할 부작위의무를 이행할 수 없었고, 오히려 특허실시계약자는 만인의 공유재(public domain)인 특허대상 기술을 사용할 권한이 있었으므로 부작위의무의 이행을 인정할 수 없다. - 특허권자는 당초부터 금지청구를 할 권능이 없었고 통상실시계약자는 특허권자로부터 금지청구를 받지 않고 발명을 실시할 권능이 있었으므로 어떠한 사실상의 이익을 누렸다고 보기 어렵다.
무효 소급효 해석	- 특허무효의 소급효는 사법상의 법률관계에 어떠한 영향을 주는 것은 아니다. - 특허실시계약의 당사자들은 향후 특허가 소급하여 무효가 되더라도 실시료 반환 청구를 하지 아니하겠다는 취지로 의사 합치를 하였다고 해석함이 상당하다.	- 특허무효의 소급효에 의하여 특허권이 처음부터 존재하지 않은 것으로 되기 때문에, 특허권의 존재를 전제로 한 실시계약에 영향을 미친다. 따라서, 명시적 합의가 없는 한 특허가 소급 무효가 됨에 따라 특허실시계약 또한 소급하여 무효로 되도록 해석함이 타당하다. - 특허법 제100조와 제102조에서 특허실시계약의 목적을 유효한 특허권을 전제한 급부로 규정하고 있고, 당사자 또한 특허를 실시계약의 목적으로 규정하고 있을 뿐 달리 특허가 무효일 경우에 대하여 별도의 약정을 하지 아니한 이상, 특허실시계약의 목적인 급부는 특허권자의 유효한 부작위의무의 이행 내지 전용실시권의 설정으로 한정함이 타당하다.
정책적 측면	특허실시계약 체결 경위에도 불구하고 기지급 실시료의 반환을 허용하는 것은 특허 무효의 위험성을 전적으로 특허권자에게만 부담시키는 것이 되어 형평에 반한다.	- 특허권자가 특허를 무단으로 사용하고 있는 자에 대하여 손해배상청구를 하여 승소하고 이에 기하여 손해배상을 지급받았는데 이후 특허가 소급무효로 된 경우라면, 특허권자는 결국 고의, 과실이 없더라도 지급받은 손해배상금을 부당이득으로서 반환하여야 한다. 이와 비교하여 볼 때, 특허실시계약을 체결한 자는 무단실시자보다 사회의 법질서를 존중하는 사람으로서 보호의 필요성이 더 큼에도 불구하고, 반환의무 부정설은 오히려 특허실시계약자는 보호하지 아니하는 한편 무단실시자는 보호하는 불공평을 초래하게 된다. - 특허무효심결이 언제 확정되느냐에 따라 향후 실시료 지급의무의 범위가 달라지기 때문에, 특허권자로서는 소송을 최대한 지연하고자 노력할 것이고, 결국 반환의무 부정설은 소송을 조기에 종결시키지 못하는 하나의 원인으로 작용할 수 있다.
	특허권자로 하여금 특허실시계약의 체결을 장려하고 특허실시계약자로 하여금 무효의 소지가 있는 특허에 관하여 조기에 무효소송을 제기하도록 독려하는 효과도 얻을 수 있다.	기지급 실시료의 반환을 부정하면 특허실시계약자가 될 자가 특허실시계약을 체결하기보다는 무단실시를 선호하도록 조장할 수 있고, 결국 잠재적인 특허실시계약 예정자로 하여금 무단실시가 아닌 적법한 특허실시계약을 체결하도록 유도하려면 특허가 소급하여 무효로 된 경우 기지급 실시료의 반환을 인정해 줄 필요가 있다.

대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결 【손해배상(기)】

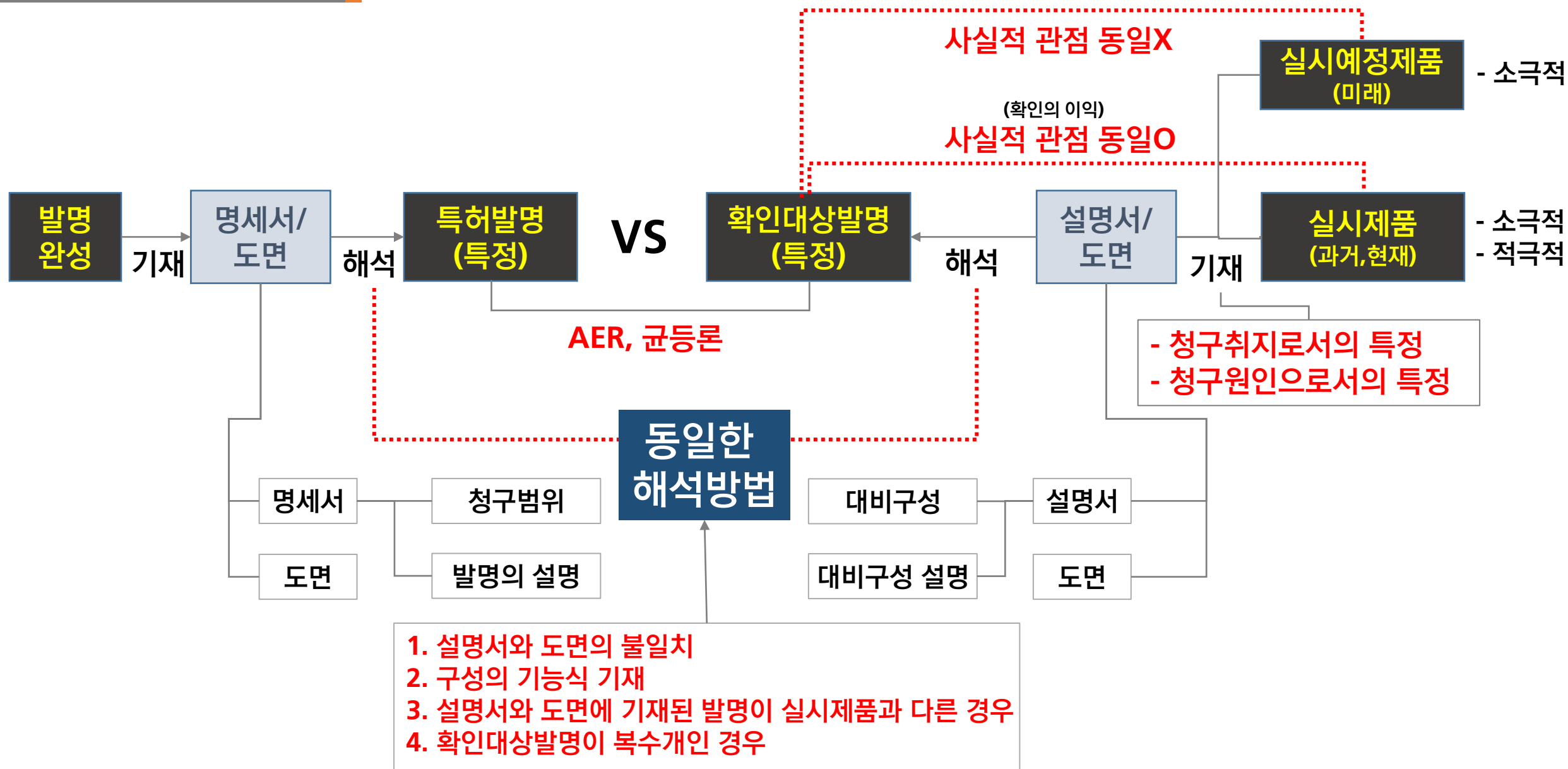
특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 ‘특허발명 실시금지계약’이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조). 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조). 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.



특허무효심판	존속기간연장등록무효심판	정정무효심판
제133조 【특허의 무효심판】 ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다. 3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우 5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우 6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우 7. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우 8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우 ② 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. ③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. ④ 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.	제134조 【특허권 존속기간의 연장등록의 무효심판】 ① 이해관계인 또는 심사관은 제92조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 1. 특허발명을 실시하기 위하여 제89조에 따른 허가 등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 2. 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조에 따른 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 3. 연장등록에 따라 연장된 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하는 경우 4. 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 5. 제90조제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 6. 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우 ② 이해관계인 또는 심사관은 제92조의5에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 무효심판을 청구할 수 있다. 1. 연장등록에 따라 연장된 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우 2. 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 3. 제92조의3제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 ③ 제1항 및 제2항에 따른 심판의 청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다. ④ 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다. 1. 연장등록이 제1항제3호에 해당하여 무효로 된 경우: 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간 2. 연장등록이 제2항제1호에 해당하여 무효로 된 경우: 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간 ⑤ 연장등록이 제1항제6호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 본다.	제137조 【정정의 무효심판】 ① 이해관계인 또는 심사관은 제132조의3제1항, 제133조의2제1항, 제136조제1항 또는 이 조 제3항에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우에는 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. 1. 제136조제1항 각 호의 어느 하나의 규정 2. 제136조제3항부터 제5항까지의 규정(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다) ② 제1항에 따른 심판청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다. ③ 제1항에 따른 무효심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. ④ 제3항에 따른 정정청구에 관하여는 제133조의2제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제133조의2제3항 중 "제133조제1항"은 "제137조제1항"으로 보고, 같은 조 제4항 후단 중 "제133조의2제1항"을 "제137조제3항"으로 보며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 "제1항"을 각각 "제3항"으로 본다. ⑤ 제1항에 따라 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.



특허발명 vs 확인대상발명 vs 실시제품



확인대상발명의 특정 정도: 구별 vs 대비 vs 대응

특정 정도

청구취지로서 특정

“확인대상발명은 특허 제0000000호의 특허 발명의 권리범위에 속한다.”
라는 심결을 구합니다.

- 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정

- 특정이 불명확하다면 일사부재리의 효과가 미치는 범위가 명확하지 않기 때문에 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라도 심판청구를 심결각하

* 구체적인 특정방법

- 상품명, 모델번호, 형식번호에 의한 제품의 특정, 현장사진, 제품카탈로그, 전기제품에 내장된 회로도, 사양서 등에 의한 특정

- 확인대상명의 구성요소를 명확히 기재

특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 **다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면**, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등 조치를 취해야 하며, 그럼에도 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 **심판의 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356).**

청구원인으로서 특정

확인대상발명은 특허발명과 대비하여 구성요소완비의 원칙, 균등론이 적용된다.

- 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정

- 청구취지로서 특정이 명확하다면 일사부재리의 효과가 미치는 범위가 명확하기 때문에 청구원인으로서 특정이 불명확하다고 할지라도 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 각하심결하지 않고 본안심결 가능

* 구체적인 특정방법

- 권리범위에 속하는 판단할 수 없게 애매하게 기재된 경우나 특정결과에 따라 결론이 달라지는 경우에는 불특정

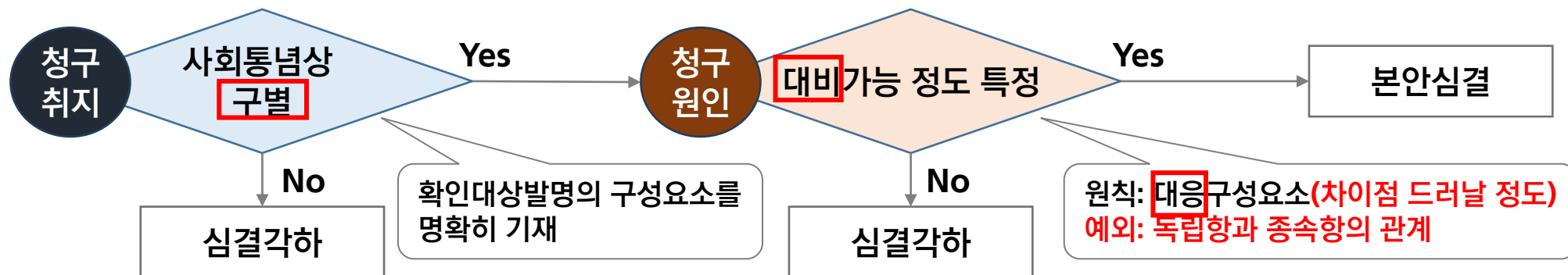
- 원칙: 특허발명과 대응되는 부분의 구성을 대비하여 **차이점을 판단함에 필요할 정도로 기재**(대응하지 않은 구성은 추가적 기재되더라도 권리범위 영향 없음)

- 예외: 독립항과 비교하여 권리범위에 속하지 않음을 판단할 수 있는 경우에는 종속항에 대응되는 구성요소가 기재되지 않더라도 대비가능하도록 특정 인정

- 예외: 발명의 범주가 다른 확인대상발명의 특정

특허권의 권리범위 확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 **서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정**되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조). 다만, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 **확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291).**

독립항과 종속항의 관계에 있어서 특정 정도



1

복수의 청구항에 대해 권리범위확인심판을 청구할 때 특허심판원이나 법원은 청구항별로 독립적으로 권리범위에 속하는지 여부를 판단하게 된다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후17). 청구범위가 복수 개의 청구항으로 된 경우에 있어서 각 청구항은 그것이 독립항이든 종속항이든 관계없이 상호 독립되어 각 청구항마다 권리범위가 정하여지는 것이기 때문이다(특허법원 2004. 7. 2. 선고 2003허6043). 따라서 독립항과 종속항의 관계에서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을, 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항으로 제한하여 해석할 수 없다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후 934).

2

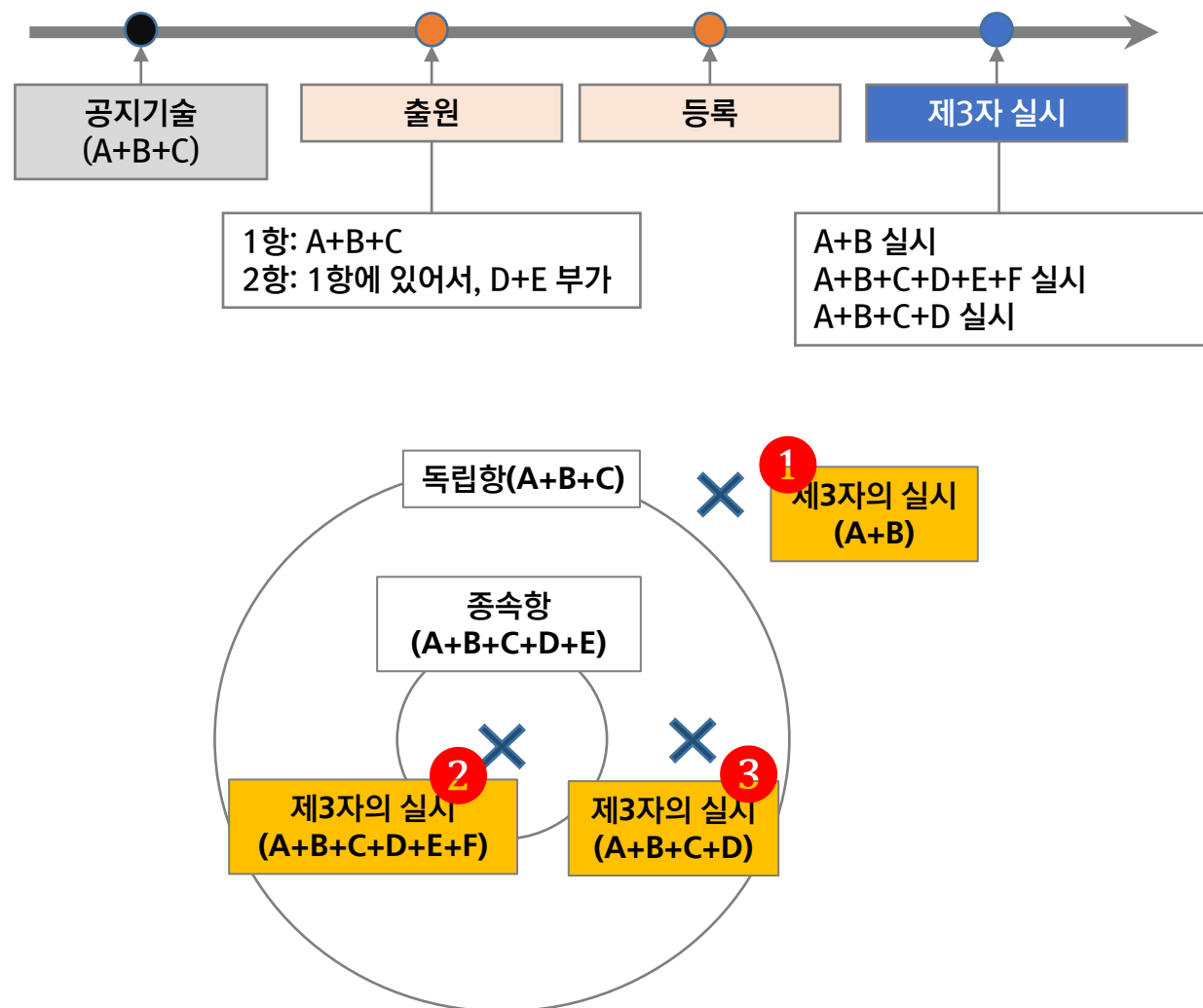
종속항은 독립항을 구체화한 청구항이기 때문에 독립항의 권리범위가 종속항의 권리범위보다 더 넓을 수밖에 없다. 따라서 확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하지 아니한 경우 독립항보다 권리범위가 좁은 종속항의 권리범위에도 속하지 않게 된다. 그 결과, 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하지 아니하면 종속항에 대응되는 부분의 구성이 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성(독립항의 구성)만으로 확인대상발명이 종속항의 권리범위에도 속하지 아니한다고 판단할 수 있어서 확인대상발명이 특정된 것으로 볼 수 있다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296).

3

한편, 확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하는 경우 종속항의 권리범위에 속하는지 여부는 개별적으로 판단되어야 한다. 또한 이는 독립항의 권리범위가 인정됨을 전제로 하는 것으로서 만일 독립항이 신규성, 선출원주의 위반 등으로 권리범위가 인정되지 않는다면 독립항의 권리범위에 속하지 않더라도 종속항의 권리범위에 속할 수도 있기 때문에 종속항의 권리범위에 속하는지 여부를 개별적으로 판단해야 한다. 따라서 종속항에 대해서도 권리범위확인을 구하는 심판을 청구한 것이라면 종속항에 대응되는 부분의 구성이 반드시 기재되어야 한다. 만약 종속항에 대응되는 부분의 구성이 기재되지 아니한 경우 보정명령을 하여 대응되는 구성을 기재하도록 해야 한다. 이때 심판청구인이 구성을 추가하는 보정을 하는 것은 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 요지변경이 아니다.

독립항의 권리범위 vs 종속항의 권리범위

독립항의 권리범위에 속하지 아니한 경우 종속항의 권리범위에도 속하지 아니한다. 다만, 예외적으로 독립항이 신규성 위반, 선출원주의 위반, 확대된 선출원 위반, 실시불가능한 경우, 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우인데 착오로 등록되어 권리범위를 인정할 수 없는 경우에는 종속항의 권리범위에 속할 수 있다.



독립항의 권리범위가 인정되는 경우

- 독립항의 권리범위에 속하지 아니하면 종속항의 권리범위에도 속하지 아니한다(①).
- 독립항의 권리범위에 속하면 종속항의 권리범위에 속하는지 여부는 개별적으로 판단해야 한다(②③).

종속항에 대응되는 구성 불필요

독립항의 권리범위가 인정되지 아니한 경우

- 독립항의 권리범위에 속하지 아니하더라도 종속항의 권리범위에 속하는지 여부는 개별적으로 판단해야 한다(②③).

종속항에 대응되는 구성 필요

확인대상발명 vs 실시(예정)제품: 다르지 않는 경우

적극적

적극적 권리범위확인심판에서는 청구인인 특허권자 또는 전용실시권자가 주장한 실시 형태가 피청구인이 실제로 실시하고 있는 형태와 동일성이 인정되지 않으면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 **확인의 이익**이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419). 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 하며(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626), 요지가 동일하여 균등관계에 있다고 할지라도 확인대상발명이 특정되었다고 볼 수 없다(대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247).

사실적 관점 동일
(요지 동일 X)

확인대상발명

실시제품

소극적

소극적 권리범위확인 심판의 대상이 되는 확인대상발명에는 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 장래 실시 예정인 발명도 포함되나(대법원 2000. 4. 11. 선고 7후3241 판결 참조), 그러한 경우에도 확인대상발명의 적법한 특정 여부, 심결절차의 안정성 및 효율성, 심결의 효력 범위를 명확히 하기 위하여 **권리범위의 확인을 구하는 심판을 청구한 자는 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 예정인지 여부를 적어도 심결시까지 명확히 밝혀야 하고, 심판청구인이 심결시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다.**

또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 **직권으로 조사**하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 참조). 따라서, 피고가 이 사건 심결절차를 통하여 확인을 받으려고 한 대상인 피고가 실제 실시하고 있는 제품과 피고가 특정한 확인대상발명이 사실적 관점에서 같지 않다면, 앞서 본 법리에 따라 특허심판원으로서 피고가 특정한 확인대상발명이 피고가 실제 실시하고 있는 발명과 다를 수 지적하여 이를 보정할 수 있는 기회를 부여하여야 하고, 피고가 그러한 기회를 제공받았음에도 이를 보정하지 않았다면 장차 위와 같이 잘못 특정된 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되었다고 그 기판력이 확인대상발명과 다른 피고가 실제 실시하고 있는 발명에 미친다고 볼 수 없으므로 이를 각하하여야 할 것이다(대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결 참조). 그리고 특허심판원이 위와 같이 보정기회를 부여하여야 함에도 그러한 기회를 부여함이 없이 실제 실시하고 있는 발명과 다른 확인대상발명에 관하여 심결을 하였다면 그러한 심결은 심판대상이 아닌 발명을 심판한 잘못이 있어 위법하고, 이후 **그 심결의 취소를 구하는 소송절차에서 사후적으로 심결에서 승소한 일방 당사자가 위 확인대상발명에 관하여도 확인을 구할 의사가 있다는 의사를 표시하였다고 하여 그 하자가 치유된다고 보기도 어렵다**(특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301).

사실적 관점 동일
(요지 동일 X)

확인대상발명

실시제품

폭넓게 인정

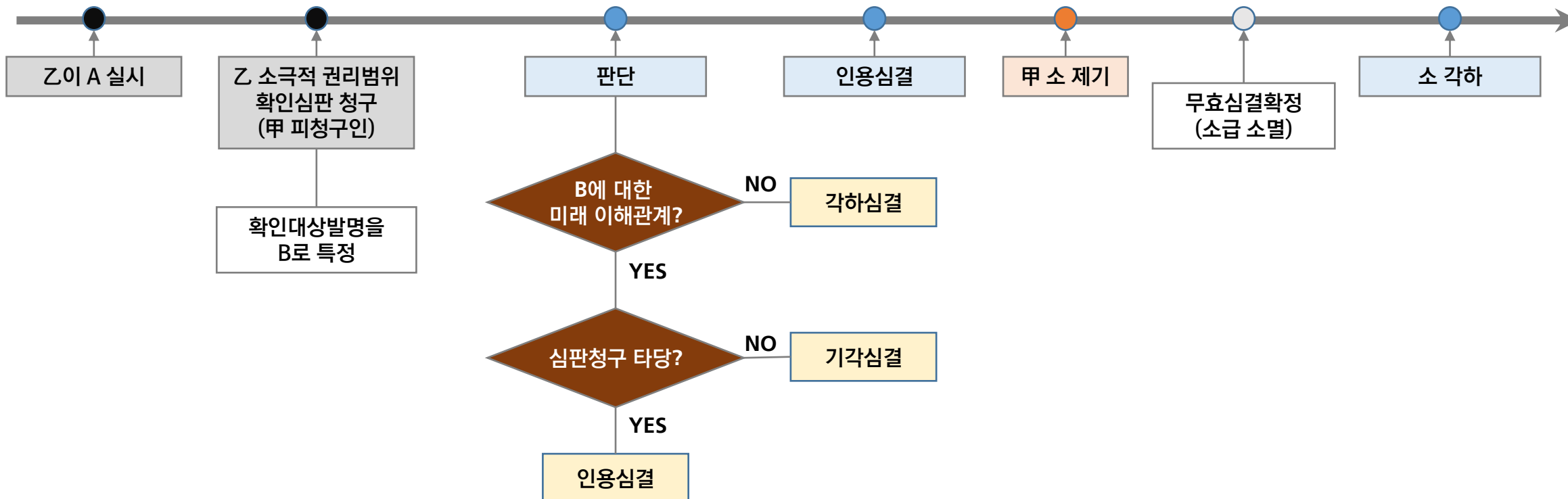
실시에정제품

심결 시까지 명확히 구분

확인대상발명 vs 실시(예정)제품: 다른 경우

대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결 【권리범위확인(특)】

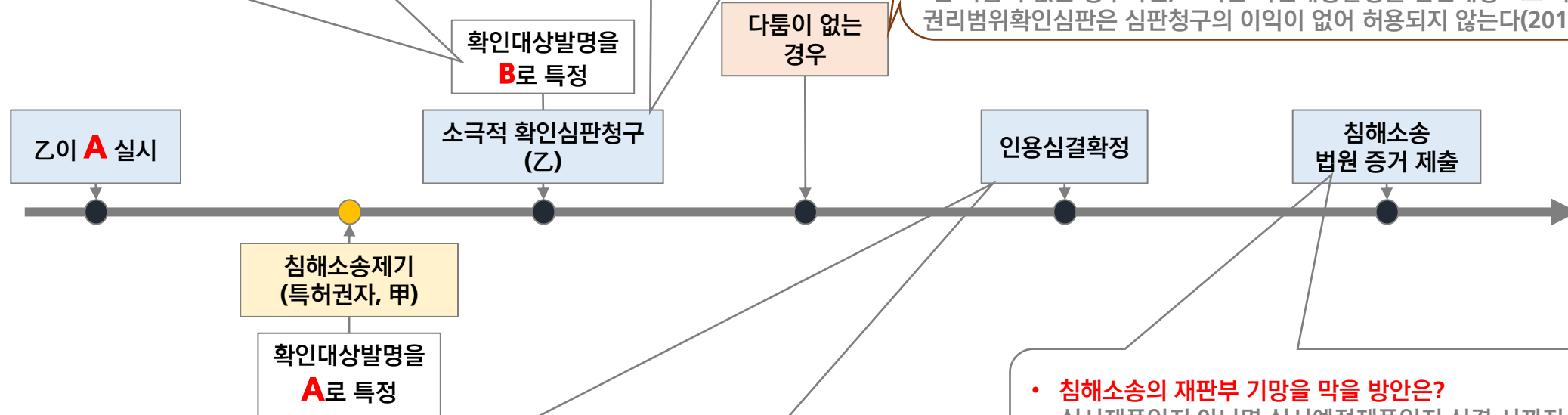
권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다. 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.



소극적 권리범위확인심판의 가장 중요한 기능은 분쟁의 예방이고, 실시할 가능성을 너무 엄격하게 적용하면 소극적 권리범위확인심판의 효용성은 크게 떨어질 것이기 때문에 그러한 예방적 기능을 충분히 보장하기 위해서는 장래 실시할 계획이 있다고 주장되는 확인대상발명의 확인의 이익을 폭넓게 인정(85후48, 49)

침해소송과 권리범위확인심판은 별개이기 때문에 침해소송이 제기된 후에 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우 심판청구의 이익을 긍정 (2016후328): 근거는 권리범위확인심판의 고유기능과 제164조

소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다(2014후2849).



소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단(2020후11813)

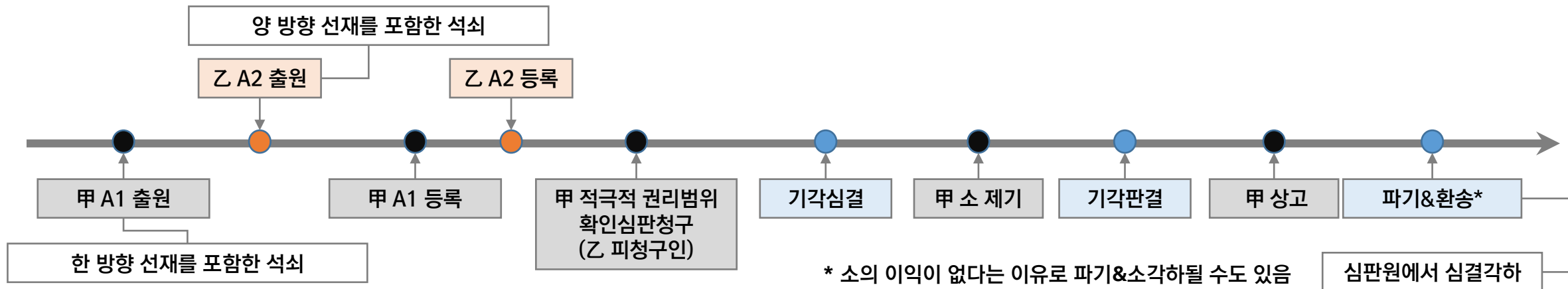
- **침해소송의 재판부 기망을 막을 방안은?**
 - 실시제품인지 아니면 실시예정제품인지 심결 시까지 밝혀야 함
 - 심결문에 이를 기재

권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판 CASE

대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 【권리범위확인(특)】

[1] 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 참조). 한편 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 참조).

[2] 제30항 발명은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대 등의 효과를 위하여 선재를 한 방향으로만 형성한 것인 데 비하여, 확인대상발명은 하나의 석쇠틀에서 가로, 세로 방향으로 선재가 교차되는 양방향 구성을 채택하고 있었다. 심결과 원심은 이용관계에 있다고 판단하여 일단 본안판단으로 나아간 후 막상 권리범위 속부 실체 판단에서는 확인대상발명의 구성이 제30항 발명의 권리범위에서 의식적 제외된 구성이라고 보아 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 그러나 대법원은, 이용관계 해당 여부에 관한 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결의 판단기준을 인용한 다음, 하나의 석쇠틀에서 가로, 세로 방향으로 선재가 교차되는 확인대상발명의 양방향 구성은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대와 같은 한 방향 구성의 효과를 나타낼 수 없어 제30항 발명과 상이한 구성이라고 할 것이고, 확인대상발명 내에서 제30항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수도 없어 두 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 권리범위확인심판 청구는 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다는 사례

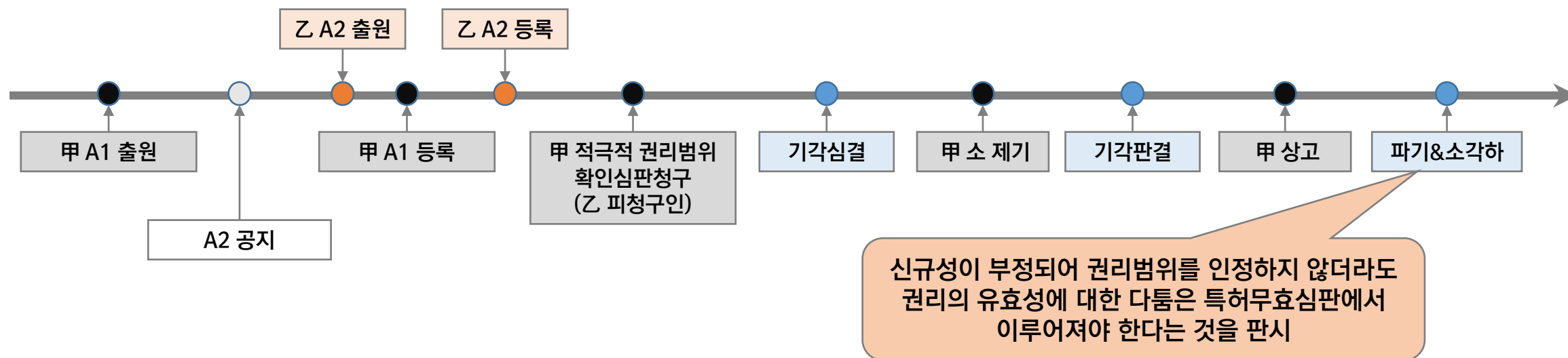


권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판 CASE

대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결 【권리범위확인(특)】

선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다는 취지인 점에 비추어 볼 때 후등록 특허발명의 신규성 인정 여하에 따라 이러한 원칙적인 법리의 적용 여부가 달라진다고 볼 수는 없다.

- 신규성 부정은 권리범위를 불인정하는 것이지 권리의 유효성을 부정하지는 않음
- 권리의 유효성에 대한 다툼은 무효심판의 전권사항이므로 권리범위확인심판에서 다룰 수 없고, 따라서 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판은 권리의 유효성을 부정하지 않는 이용관계만 가능하고, 권리의 유효성을 부정하는 저촉관계는 불가능함
- 그 결과 이용관계가 아닌 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판은 각하되어야 하나, 기각이나 각하나 심판청구인이 심판에서 지는 것은 매한가지이기 때문에 유리한 심결을 받을 가능성이 없고, 따라서 본 사안은 소각하함



권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판 CASE

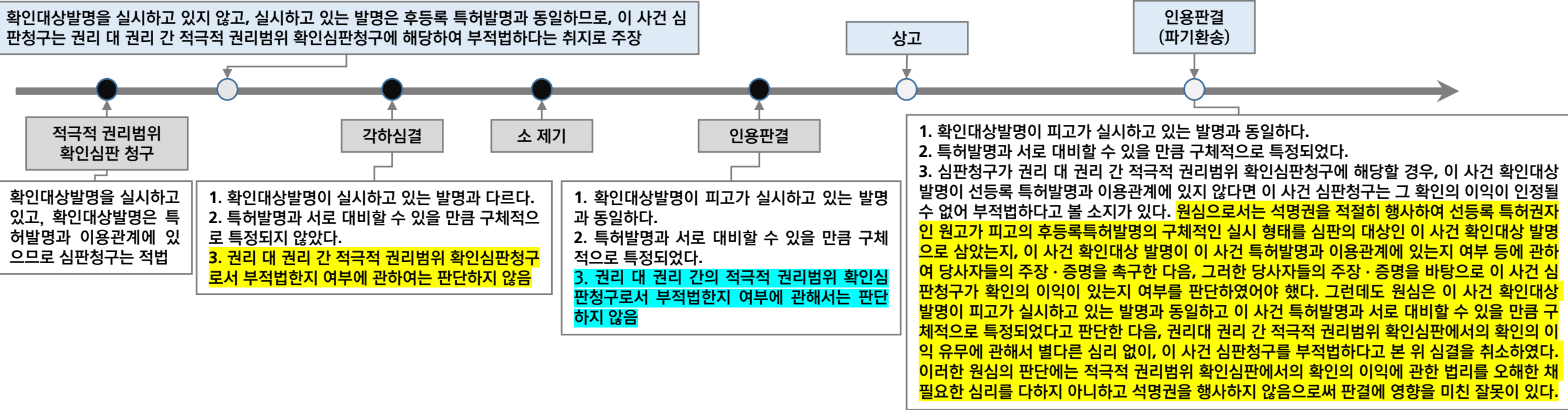
대법원 2025. 9. 11. 선고 2024후10436 판결 【권리범위확인(특)】

[1] 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그렇지만 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고, 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 된다. 또한 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결, 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결 등 참조)

[2] 특허권자가 심판을 청구하는 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도, 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 이와 같이 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조). 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상 발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에는 그 동일성을 인정할 수 있다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).

[3] 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 후등록 특허발명을 확인대상 발명으로 삼아 선등록 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판청구는, 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 확인의 이익이 인정될 수 없으므로 원칙적으로 부적법하다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결 등 참조). 다만 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조). 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익 유무는 심판청구의 적법 요건에 관한 것으로서 직권조사사항이므로, 법원은 그 판단의 기초자료인 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없다고 하더라도 이미 제출된 자료들에 의하여 그 확인의 이익이 있는지 의심이 갈 만한 사정이 보인다면, 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 이에 관하여 심리·조사할 의무가 있다.

확인대상발명을 실시하고 있지 않고, 실시하고 있는 발명은 후등록 특허발명과 동일하므로, 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당하여 부적법하다는 취지로 주장



대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결【권리범위확인(실)】

1) 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 2) 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 3) 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안된다. 다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 등 참조), 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 이와 달리 특허발명 또는 등록실용신안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 판시한 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1468, 1475(병합) 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후 2583 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

한편, 대법원은 특허권침해소송에서 특허권자의 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다는 법리를 선언한 바 있다(위 2010다95390 전원합의체 판결 참조). 그런데 4) 특허권침해소송에서 권리남용의 항변을 받아들여 특허권 침해를 부정하는 것은 권리의 부존재나 무효가 아닌 권리행사의 제한사유를 이유로 하여 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 그 판결의 효력도 소송 당사자 사이에서만 미친다. 반면에 권리범위확인심판은 어디까지나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미를 가질 뿐 특허권침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해주는 것이 아니고, 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다. 따라서 특허권침해소송에서 권리남용의 항변의 내용으로서 진보성이 없다는 주장을 인정하더라도 이는 특허의 대세적 효력을 특허무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 특허법의 기본 구조와 상충되지 않지만, 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 특허법의 기본 구조와 상충된다. 그러므로 권리범위확인심판에서는 특허권 침해소송에서와는 달리 진보성 여부를 특허무효사유로 주장할 수 없고, 이로 인하여 권리범위확인심판과 특허권침해소송에서의 결론이 마치 상반되는 듯이 보인다고 하여 서로 모순될 수 없다.

권리범위확인심판의 심리범위 vs 침해소송의 심리범위



구분		피의자의 항변	침해소송	권리범위확인심판
침해의 성립요건	특허권 존속 中	특허권 당연무효의 항변(행정처분의 공정력 부정)	불인정	불인정
	정당한 권원 없는 자	실시권의 항변	인정	불인정
		권리소진의 항변	인정	불인정
	업으로서	업이 아니라는 항변	인정	불인정
	특허발명의 보호범위에 속하는 발명 실시	특허권 하자(무효)의 항변	인정	인정
		자유기술의 항변	인정	인정
		효력 제한(法 81의3④, 96, 181)의 항변	인정	인정
조치		권리남용의 항변	인정	불인정

청구범위의 감축과 실질적 변경

청구범위의 감축이란 청구항을 삭제하거나 청구항을 한정 또는 부가하는 경우를 말한다. 청구항을 삭제하는 경우는 실질적 변경이 아니지만, 청구항을 한정(상위개념의 기재를 하위개념의 기재로 변경하는 내적부가) 또는 부가(구성요소의 직렬적 부가인 외적부가)하는 경우는 **청구범위의 감축일지라도 새로운 목적 및 효과를 갖게 되어 실질적 변경에 해당한다면** 정정을 허용할 수 없다.

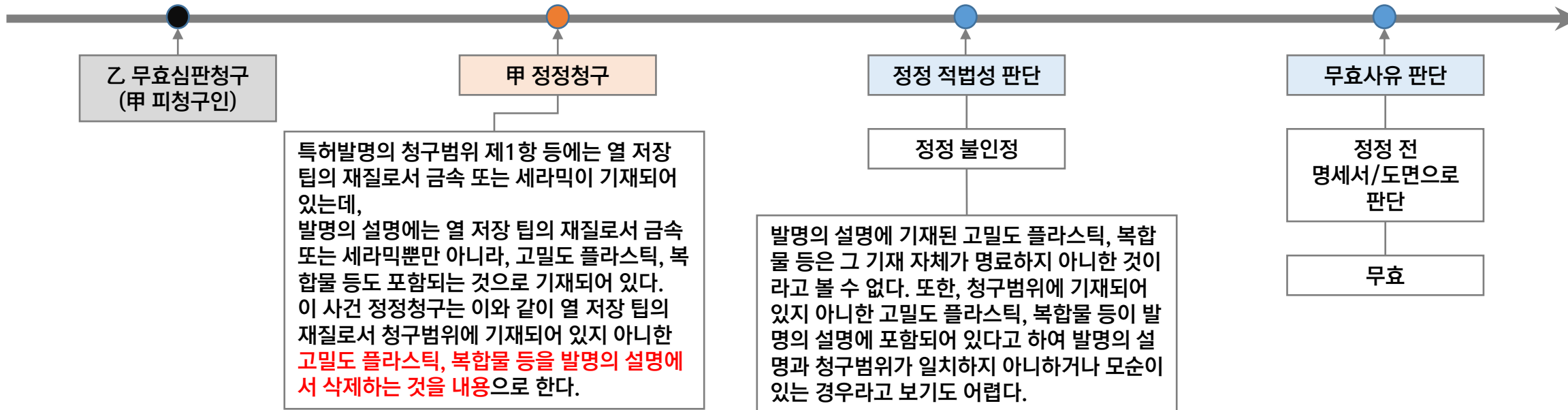
청구범위의 감축		원칙	예외
청구항 삭제		실질적 변경×	-
청구항 범위 축소	한정	실질적 변경×	실질적 변경○
	부가	실질적 변경○	실질적 변경×

선택발명이 되어 특허성을 가지게 되고
또 그 하위개념의 발명이 특허명세서에
기재가 되어 있지 아니한 경우

새로운 목적 및 효과를 갖는지 여부

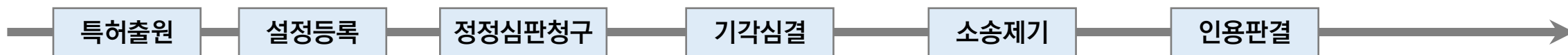
대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 【등록무효(특)】

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지에 비추어 보면, 오류의 정정에는 1) 청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 2) 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다고 해석된다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결, 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3193 판결 등 참조). 한편, 청구범위는 발명의 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.



특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있을 것(제136조제5항)

청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다 (法 136⑤). 정정 후의 청구범위에 기재된 발명이 제62조의 거절이유에 해당하지 않아야 한다. 다만 거절이유 중 배경기술의 기재(法 42③Ⅱ), 다항제 기재방법(法 42⑧), 하나의 특허출원의 범위(法 45)는 심사의 신속성을 위한 절차적 특허요건이고, 특허무효사유가 아니므로 이 요건을 적용하지 않는 것이 타당하다. 한편 청구 범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에만 본 요건에 해당하는지 여부를 판단하고, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에는 본 요건에 해당하는지 여부를 판단하지 아니한다. 따라서 정정대상으로 삼지 아니한 다른 부분에 분명하지 아니한 기재가 있다고 하더라도, 이는 원칙적으로 별도의 정정 심판이나 특허무효심판절차에서 다룰 사항에 불과하고 해당 정정을 불인정할 사유는 되지 못한다고 할 것이다. 이는 정정한 명세서 또는 도면의 전체에 의하여 정정의 인정 여부를 판단하는데, 정정대상으로 삼지 아니한 다른 부분에 분명하지 아니한 기재가 본 요건을 만족하지 못해 정정을 인정해 줄 수 없게 된다면, 정정의 인정 범위를 너무 좁혀 특허권자의 입장에서 실효적인 대응수단으로 작동할 수 없게 되기 때문인 것으로 사료된다.



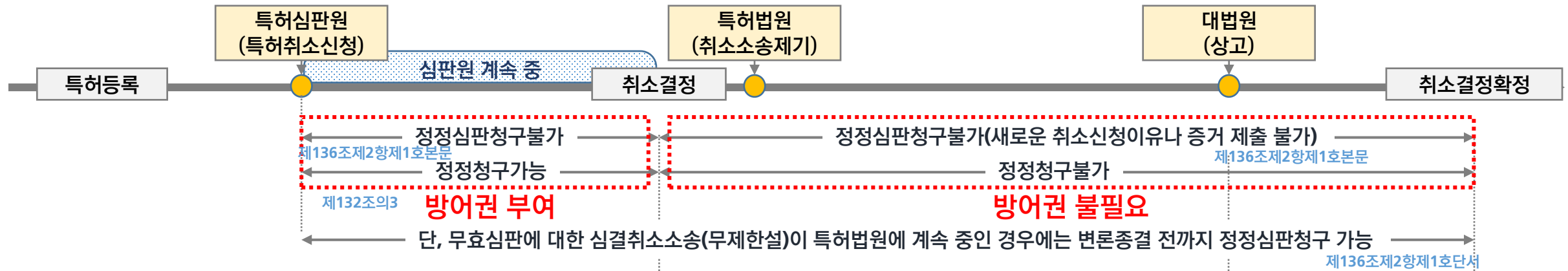
특허법원 2012. 10. 25. 선고 2012허6342

구분	정정대상	정정심판전 청구범위	정정심판후 청구범위
정정 사항1	발명의 명칭	워드프로세서의 단어목록 원도	워드프로세서의 단어목록 원도를 나타내는 방법
정정 사항2	청구항 1 내지 청구항 4	 단어들(우선순위가 높은 단어들)을 화면에 나타내 주게 됨을 특징으로 하는 워드프로세서의 단어목록 원도	 단어들(우선순위가 높은 단 어들)을 화면에 나타내 주게 됨을 특징으로 하는 워드프로세서의 단 어목록 원도를 나타내는 방법

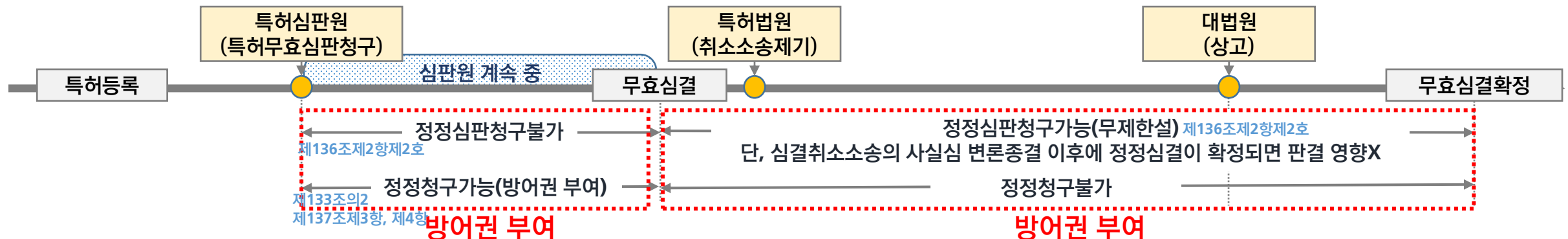
[1] 구 특허법상의 정정심판 제도는 특허발명의 명세서나 도면에 잘못된 기재 또는 분명하지 아니한 기재가 있는 경우에 이를 바로 잡아 특허무효를 미리 방지할 뿐만 아니라, 특허권 분쟁이 있는 경우에 그 권리관계를 명확히 하고자 하는데 그 의의가 있는 것이므로, 구 특허법 제136조 제1항 제3호의 불명료한 기재에는 청구범위의 기재 내용 자체의 의미는 명백하더라도 발명의 카테고리가 분명하지 아니하여 발명의 내용을 명백히 확정할 수 없는 경우도 포함된다고 봄이 타당하다.

[2] 구 특허법 제136조 제1항 제3호는 명세서나 도면에 대하여 ‘불명료하게 기재된 것을 석명하는 경우’라고만 규정하고 있을 뿐이고, 1) ‘명세서나 도면에 대하여 불명료하게 기재된 부분 전체를 석명하는 경우’라고 한정하고 있지 않은 점, 2) 정정심판청구는 횟수의 제한이 없어 여러 차례에 걸쳐 할 수 있는 점, 3) 구 특허법은 정정심판과 관련하여 청구범위를 감축하는 경우에만 정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 특허 출원시 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다고 규정하고 있을 뿐이고(제136조 제3항), 불명료한 기재를 석명하는 경우까지도 위와 같은 특허요건을 구비해야 한다고 규정하고 있지 않은 점 등을 고려하면, 정정심판청구에서 그 정정대상으로 삼지 않은 다른 부분에 불명료한 기재가 있다고 하더라도, 이는 원칙적으로 별도의 정정심판이나 무효심판절차에서 다룰 사항에 불과하고 당해 정정심판청구를 기각할 사유는 되지 못한다고 보아야 한다.

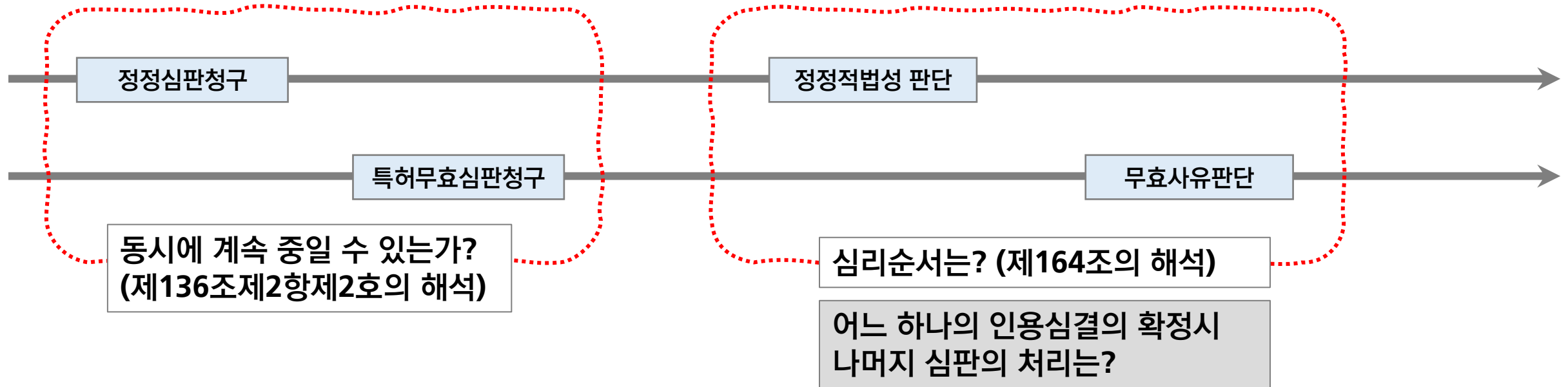
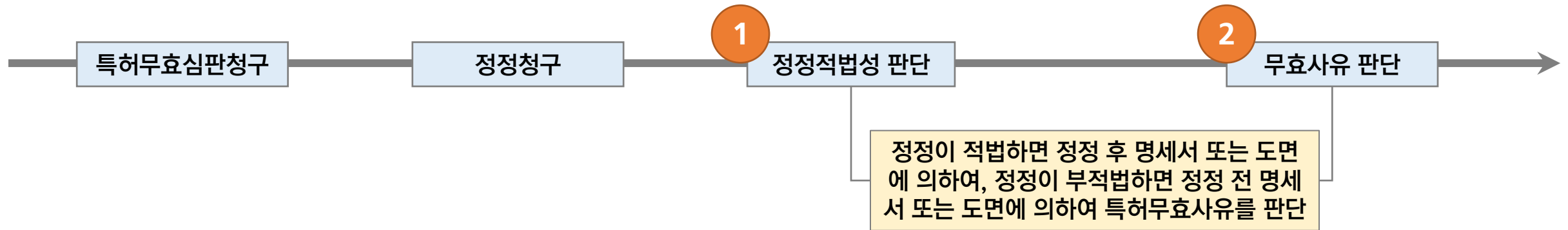
특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다(法 136② I 본문). 이는 특허취소신청에 대한 심판의 신속한 처리를 위한 것으로, 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 경우에는 특허권자가 특허의 정정청구를 할 수 있으므로 특허권자에게 방어권이 주어지고, 특허법원, 대법원에 계속 중인 경우에는 지식재산처장이 특허심판원에 제출하지 않았던 새로운 특허취소신청의 이유나 증거를 제출할 수 없을 것이므로 정정심판을 청구하지 못하더라도 특허권자의 방어권 행사를 제한하는 것은 아니기 때문이다. **다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다(法 136② I 단서).**



특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다(法 136②II). 이는 해당 절차 내에서 인정되는 특허의 정정청구를 하는 것이 절차의 신속한 진행과 심결 또는 결정의 모순·저속을 피할 수 있기 때문이다. 그러나 특허법원 또는 대법원에 계속되어 있는 경우에는 정정심판을 청구할 수 있다. 이는 특허법원의 심리범위는 원칙적으로 무제한설을 채택하고 있기 때문에 무효심판청구인은 소송단계에서 그 전에 제출하였던 증거보다 더 확실한 새로운 증거를 제출할 수 있으므로 특허권자에게도 그 새로운 증거에 대한 대응방법으로서 정정심판을 제기할 수 있도록 한 것이다.



정정심판의 청구 vs 무효심판의 청구(취소신청)



정정청구시기 vs 정정심판청구시기

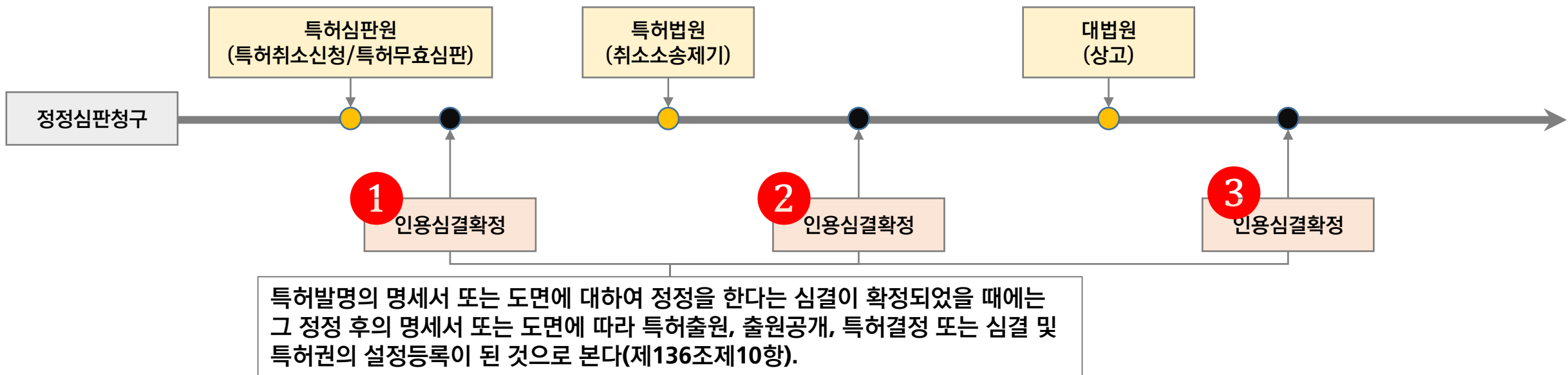
특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간이나 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 정정 심판을 청구할 수 없지만(法 136②), 특허취소신청, 특허무효심판청구 전에 정정심판이 청구된 때는 특허취소신청, 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에서 동시에 계속되게 된다. 또한, 등록무효심결에 대한 취소소송이 특허법원이나 대법원에 계속 중인 경우(특허취소신청의 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고로 말한다)된 날까지)에는 독립하여 그 정정심판을 청구할 수 있다. 이 경우 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허취소신청, 특허무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니다. 한편 특허취소신청, 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에는 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이다.

시기	종류	정정청구	정정심판청구
심판원 계속 중	특허취소신청	○(法 132의3)	△*
	특허무효심판	○(法 133의2)	×
	정정무효심판	○(法 137③④)	×
특허법원 / 대법원 계속 중	특허취소신청	×	△*
	특허무효심판	×	○
	정정무효심판	×	○
계속 중이지 아니한 경우		×	○

* 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판청구 가능

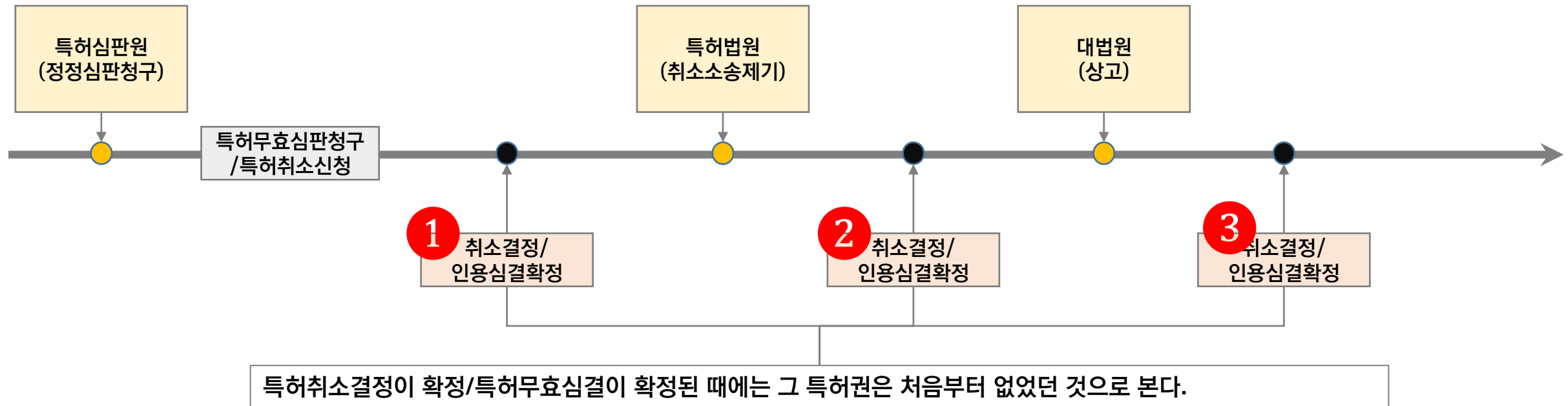
정정심판과 특허취소신청, 특허무효심판의 관계

구분	1 특허심판원에 계속 중	2 특허법원에 계속 중	3 대법원에 계속 중
정정심판에 대한 인용심결이 확정된 경우	정정된 특허발명에 의하여 특허취소사유, 특허무효사유를 심리	1. 특허취소신청의 경우 (사실심 변론종결 전 한함) - 취소환송(사실심, 단 특허권자의 대응기회(정정청구 기회) 확보 위해 정정된 특허발명에 대하여 심리 불가) 2. 특허무효심판의 경우 (사실심 변론종결 전 한함) - 정정된 특허발명에 의하여 특허무효사유를 심리(사실심, 무제한설)	정정 전 특허발명에 의하여 법령 위반이 존재하는지 판단(특허법원의 사실심 변론종결 후 포함)



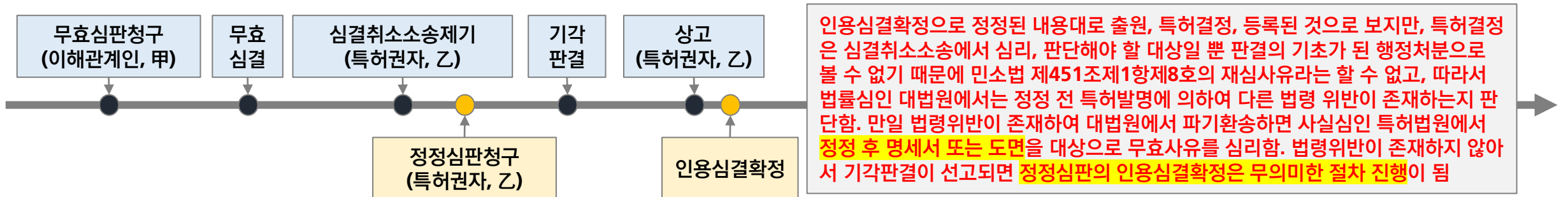
정정심판과 특허취소신청, 특허무효심판의 관계

구분	1 특허심판원에 계속 중	2 특허법원에 계속 중	3 대법원에 계속 중
특허무효심판에 대한 인용심결/특허취소신청에 대한 취소결정이 확정되어 소급소멸한 경우	정정심판은 심결각하	정정심판은 소각하	정정심판은 파기소각하



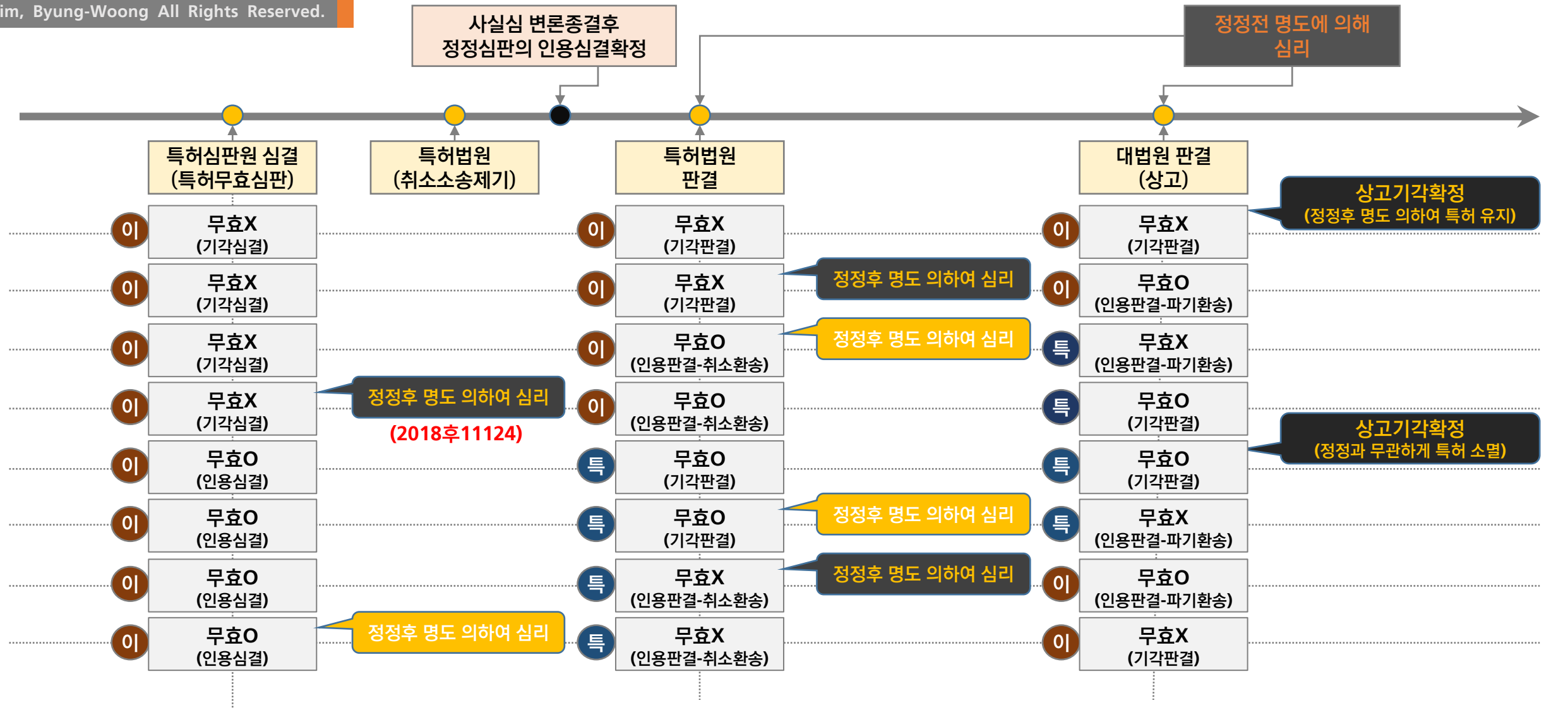
대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 【정정심판(특)】

재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결 등 참조). 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조). 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.



민사소송법 제451조 제1항 제8호의 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”라는 재심사유는, 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, i) 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 ii) 확정적·iii) 소급적으로 변경된 경우를 말하는 것인데, i) 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상이지 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없다는 점, ii) 정정이 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것이고, 정정심결이 확정되더라도 일사부재리가 적용되지 않고, 정정무효심판에 의해 다룰 수 있기 때문에 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없는 점, iii) 특허법 제136조 제10항에서 규정한 정정의 소급효는 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사·심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다는 점, iv) 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것인데, 민사소송법 제1조 제1항에서 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다.”라고 규정한 공정·신속·경제라는 민사소송의 이상에 비취 당사자에 의한 소송지연을 적절히 방지할 필요성이 있다는 점을 그 근거로 하고 있다.

대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체



대법원 판단이 도움됨 (Supreme Court decision helpful)

대법원 판단이 무용함 (Supreme Court decision useless)

대법원에서 정정 전 특허발명에 의해서 무효가 아니라고 판시하였으나, 특허법원에서는 감축 등을 한 정정 후 특허발명에 의해서 무효가 아니라고 판시할 가능성이 높음

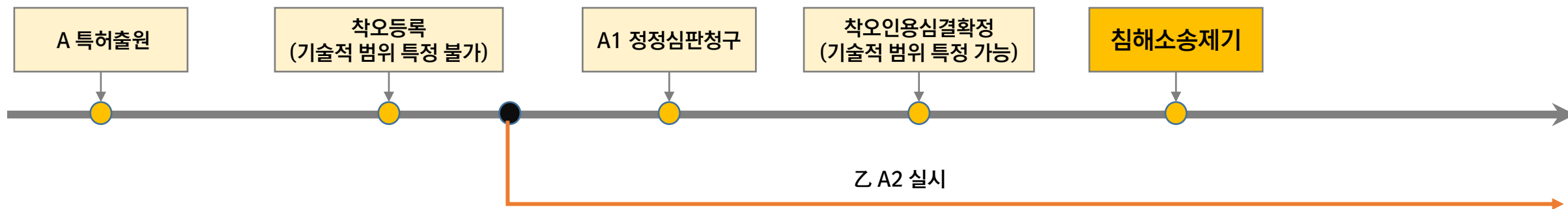
대법원에서 정정 전 특허발명에 의해서 무효라고 판시하였으나, 특허법원에서는 감축 등을 한 정정 후 특허발명에 의해서 무효일지 여부를 다시 판단해야 함

취소신청과 무효심판 계속 중 정정청구/정정심판청구

취소신청 무효심판	심판원 계속 中	특허법원 계속 中	대법원 계속 中
심판원 계속 中	정정청구 가능(法 132의3, 133의2)	정정청구 가능(法 133의2)	정정청구 가능(法 133의2)
특허법원 계속 中	정정청구 가능(法 132의3) 정정심판청구 가능 (단, 변론종결전까지) (法 136① I 단서)	정정심판청구 가능 (단, 변론종결전까지) (法 136① I 단서)	정정심판청구 가능 (단, 변론종결전까지) (法 136① I 단서)
대법원 계속 中	정정청구 가능(法 132의3)	×	×

대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 【특허법위반】

청구범위에 기재불비의 하자가 있어 권리범위를 인정할 수 없었던 특허발명에 대하여 그 청구범위를 정정하는 심결이 확정된 경우, 정정 전에 행하여진 피고인의 제품 제조, 판매행위가 특허권 침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 **정정 전의 청구범위를 침해대상 특허발명**으로 하여야 한다. 이와 같은 정정심결이 확정된 경우 그 정정이 별도의 정정무효심판절차에 의하여 무효로 되지 아니하는 한, 그 특허발명은 처음부터 정정된 청구범위에 따라 특허권 설정등록이 된 것으로 보아야 하지만, 헌법 제13조제1항, 형법 제1조제1항의 입법 취지 및 특허발명의 청구범위는 특허권자가 독점하여 실시할 수 있는 영역과 제3자가 침해해서는 아니 되는 영역을 객관적으로 확정하여 대외적으로 공시하는 규범적 효력이 있는 점에 비추어 보면, 피고인의 행위가 특허권 침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 후의 청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없기 때문이다.



1 정정무효심판에 의하여 무효심결이 확정되기 전까지 타 절차에서 당연무효라고 할 수 없다.

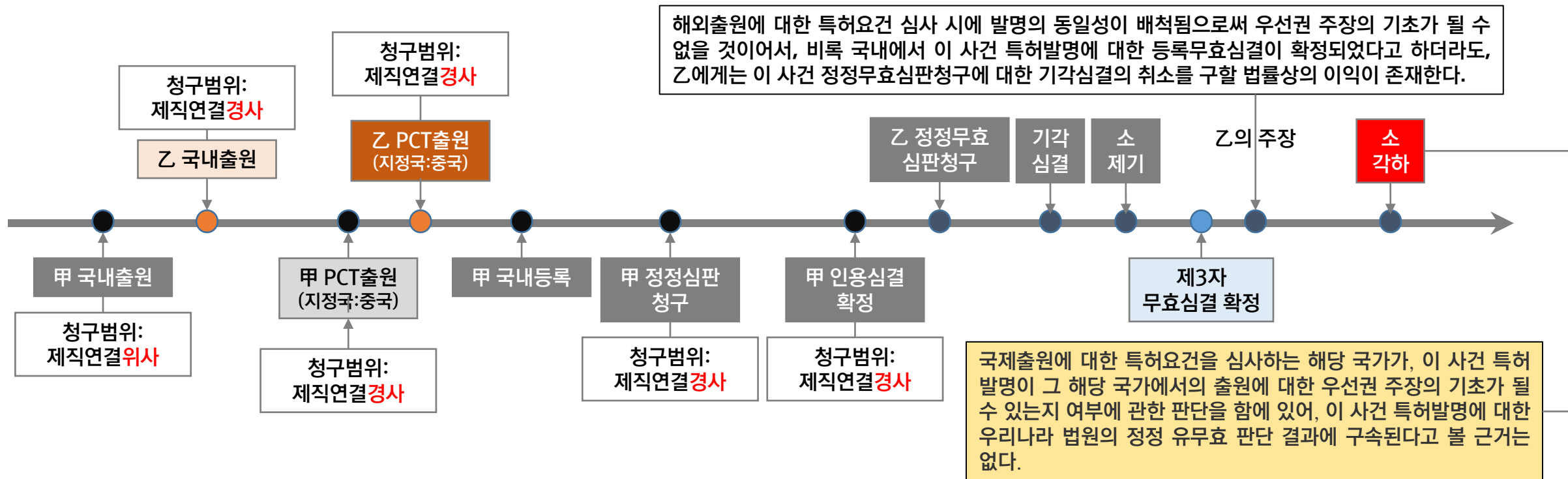
2 정정 후 청구범위(A1)만 침해인 경우에는 침해죄를 물을 수 없다.

침해 성립요건(A1)을 만족함을
전제로 침해죄(A)에 해당하는지 판단

대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후620 판결 【취소결정(특)심결취소의소】

[1] 특허를 무효로 하는 심결이 확정되었음에도 불구하고 정정무효심판청구에 대한 기각심결의 취소를 구할 법률상의 이익이 존재하는지 여부(소극): 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 무효로 된 특허에 대한 정정의 무효를 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정 자체의 무효를 구할 이익도 없어진다고 할 것이다.

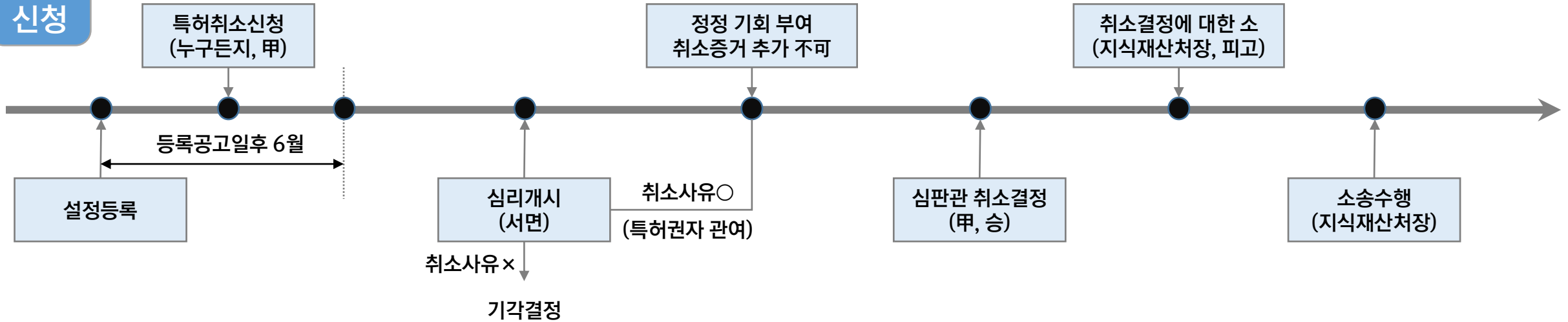
[2] 특허법 제136조 제8항에 의하여 정정심결이 확정된 때에는 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원되고 이후 이에 입각하여 특허권 설정등록까지의 절차가 이루어진 것으로 간주하는 것은 무효부분을 포함하는 특허를 본래 유효로 되어야 할 범위 내에서 존속시키기 위한 것이므로, 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 최초의 출원서 또는 출원공개된 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 그 후 정정되었다 하더라도, **그 정정내용이 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 발명의 내용 또는 신규성, 진보성 판단에 제공되는 선행기술로서의 발명의 내용에 영향을 미칠 수 없다.** 따라서 이와 다른 전제에서 특허가 무효로 된 이후에도 여전히 그 정정의 무효심판을 청구할 이익이 있다는 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.



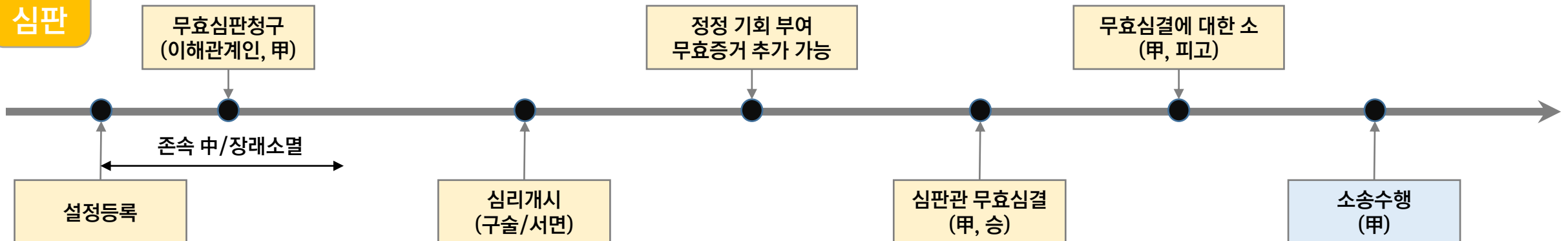
제도		거절결정불복심판	정정심판	권리범위확인심판
요건	청구인	출원인	특허권자	1. 적극적 - 특허권자 또는 전용실시권자 2. 소극적 - 실시한 적/하고 있거나 예정이 있는 이해관계인
	피 청구인	×	×	1. 적극적 - 실시한 적/실시하고 있는 이해관계인 2. 소극적 - 특허권자
	대상	거절결정	1. 청구범위의 감축, 잘못 기재된 사항의 정정 및 분명하지 아니하게 기재된 사항의 명확화 중 어느 하나 2. 특허발명의 명세서·도면(단, 잘못 기재된 사항의 정정은 최초 명세서·도면) 3. 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것 4. 청구범위의 감축, 잘못 기재된 사항의 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있을 것	청구항마다 가능
	시기	등본송달받은 날로부터 3개월 이내(연장, 추후보완 가능)	1. 존속기간 중은 물론 장래를 향해 소멸한 경우도 가능 2. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간(단, 특허/정정무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고로 말한다)된 날까지 가능)과 특허/정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 불가	특허권 존속기간 중에만 가능
절차	청구	출원일 및 출원번호, 발명의 명칭, 특허거절결정일을 추가 기재	1. 정정한 명세서 또는 도면의 첨부 2. 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 대한 통상실시권자 및 질권자의 동의서를 첨부(단, 동의받아야 하는 자가 무효심판청구한 경우 제외)	1. 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면의 첨부 2. 부분 송달 및 답변서 제출기회 부여
	진행	1. 보정각하도 함께 불복한 경우 심리범위 포함 2. 심사에서 밝은 절차의 효력이 심판에도 미침 3. 거절이유 전면적 심리	1. 정정사유를 만족하는지 직권심리 후 의견서를 제출할 수 있는 기회 부여 2. 심리종결통지 전까지 정정명세서 또는 도면의 보정	확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 심리
	종료	1. 심판청구가 타당한 경우 원거절결정을 취소하고 재판(특허심결) 또는 환송 2. 환송 시 심사관의 기속	일부인용 · 기각 불가	1. 심판청구가 타당하지 않은 경우 기각한다고 하여야 되며, 청구 취지에 반하는 심결을 해서는 안됨 2. 청구항별 취하 가능
확정효과	인용	1. 특허결정된 경우 특허료 내면 특허권 발생 2. 연장등록결정된 경우 지식재산처장이 특허원부 등록/특허공보 게재	1. 정정된 내용대로 출원 · 공개 · 결정 · 심결 · 등록된 것으로 간주 2. 심판원장이 지식재산처장에게 알리면, 지식재산처장이 특허공보에 게재 3. 침해되는 정정 전 청구범위 기준 판단 4. 정정전후 과실 추정 불변	보호범위의 공적 확인/단, 법원의 기속력 불인정
	기각	거절결정 확정	정정의 불인정	
심판비용		청구인		패심자
일사부재리		부적용		적용(적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판)
참가여부		불허(단, 정보제공 가능)		허용
비고			정정심판과 특허취소신청/특허무효심판의 관계	권리 사이의 권리범위확인심판

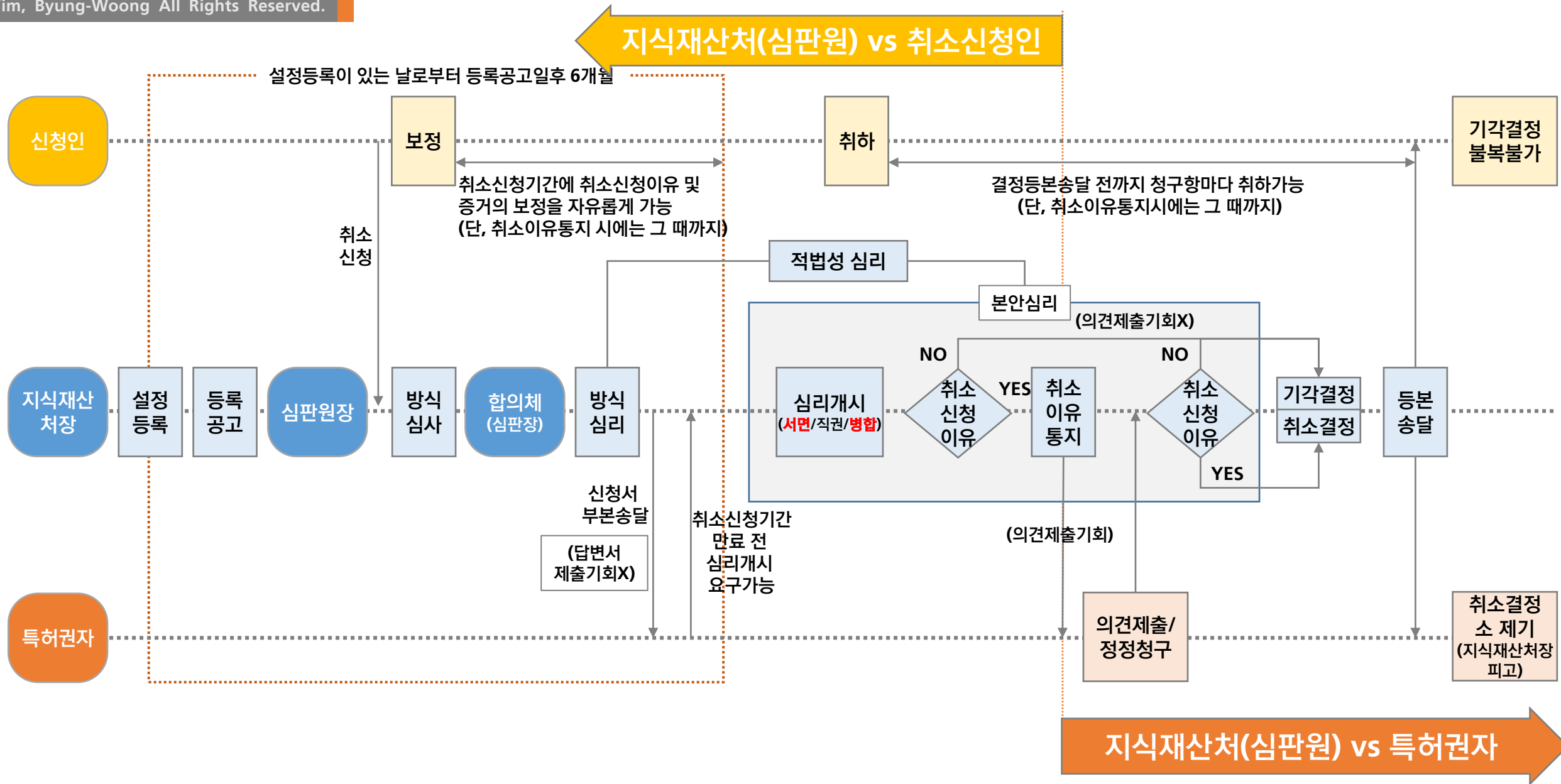
제도	특허무효심판	연장등록무효심판	정정무효심판	통상실시권허락심판
요건	청구인	이해관계인(제2호 본문의 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자) 또는 심사관	이해관계인 또는 심사관	1. 일반적 - 후출원 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자 2. 크로스 라이선스 - 통상실시권을 허락한 선출원 권리자
	피 청구인	특허권자		1. 일반적 - 선출원 특허권자, 전용실시권자, 실용실안권자, 디자인권자 2. 크로스 라이선스 - 통상실시권을 허락받은 후출원 특허권자, 전용실시권자
	대상	청구항마다 특허무효사유에 해당함을 이유로 청구	허가 등/등록지연에 따른 연장등록이 연장등록무효사유(거절이유와 동일)에 해당함을 이유로 청구	1. 이용·저촉관계 2. 실시허락 × 3. 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 이내일 것 4. 선출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 기술상의 진보가 있을 것
	시기	존속기간 중은 물론 장래를 향해 소멸한 경우도 가능		타방 권리 존속 중에만 가능
절차	청구	1. 부분 송달 및 답변서 제출기회 부여 2. 등록된 권리자에게 취지 통지		1. 청구서에 자기의 권리, 타인의 권리 특정과 범위·기간·대가의 추가 기재 2. 부분 송달 및 답변서 제출기회 부여
	진행	신청한 청구항에 대해서 특허무효사유가 있는지 심리	연장등록무효사유가 있는지 심리	이용·저촉관계에 있는지, 기술적 진보 여부, 범위·기간·대가·지급시기·지급방법 등에 관해 심리
	종료	1. 청구항마다 일부인용·기각 가능 2. 청구항별 취하 가능		심결의 주문에 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 구체적으로 명시하여 인용심결
확정효과	인용	특허권이 처음부터 없었던 것으로 간주(단, 후발적 무효사유는 발생 시부터 장래효)	1. 연장등록이 처음부터 없었던 것으로 간주(단, 연장기간을 초과하여 등록된 경우에는 초과된 기간에 대해서만 연장등록 불인정) 2. 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 간주	1. 통상실시권 허락 2. 실시권은 해당 특허권과 함께 이전하며, 함께 소멸 3. 대가 지급하지 않거나 공탁하지 않으면 실시불가
	기각	특허권의 유지	연장등록의 유지	정정의 유지
심판비용	패심자			청구인
일사부재리	적용(전부무효심판과 일부무효심판)	적용		
참가여부	허용			보조 참가만이 허용
비고	특허무효심판이 심판원에 계속 중 정정청구 가능		정정무효심판이 심판원에 계속 중 정정청구 가능	크로스 라이선스 요건 - 통상실시권허락심판에 의하여 실시권허락 - 후출원 권리자가 실시허락 × - 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위 이내일 것

취소 신청



무효 심판





특허취소신청	특허무효심판
제132조의2 【특허취소신청】 ① (요건) 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다. - 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우 - 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우 ② (예외) 제1항에도 불구하고 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이 유로는 특허취소신청을 할 수 없다.	제133조 【특허의 무효심판】 ① (주체적 및 객체적 요건) 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. - 제25조[외국인의 권리능력], 제29조[특허요건], 제32조[특허를 받을 수 없는 발명], 제36조제1항부터 제3항까지[선출원], 제42조제3항제1호[일반적인 발명의 설명 기재방법] 또는 같은 조 제4항[청구범위 기재 방법: 기재원칙]을 위반한 경우 - 제33조제1항 본문[특허를 받을 수 있는 자]에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조[공동출원]를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다. - 제33조제1항 단서[특허를 받을 수 없는 자]에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 - 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우 - 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우 - 제47조제2항 전단[신규사항추가금지: 외국어특허출원의 경우 원문의 범위만]에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우 - 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우 - 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우 ② (시기적 요건) 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. ③ 생략 ④ 생략

특허취소신청

제132조의3 【특허취소신청절차에서의 특허의 정정】

① **(요건)** 특허취소신청절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제132조의13제2항[**특허취소결정하려고 특허의 취소이유를 통지하고 의견서 제출기회 부여**]에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다.

② **(여러 차례 정정이 있는 경우)** 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.

③ **(준용규정)** 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지[**정정심판의 객체적 요건**], 제8항[**정정심판의 주체적 요건**], 제10항부터 제13항까지[**소급효, 명세서 또는 도면의 보정, 통보 및 특허공보에 게재**], 제139조제3항[**공동심판청구**] 및 제140조제1항·제2항·제5항[**정정심판의 청구 및 보정**]을 준용한다. 이 경우 제136조제11항[**명세서 또는 도면의 보정**] 중 "제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에"는 "제132조의13제2항[**정정청구가 가능기간**] 또는 제136조제6항[**정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간**]에 따라 지정된 기간에"로 본다.

④ **(정정청구의 취하)** 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.

1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
2. 제3항에서 준용하는 제136조제6항[**정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간**]에 따라 지정된 기간

⑤ **(특허출원하였을 때 특허를 받을 수 있을 것의 판단)** 제3항을 적용할 때 제132조의2에 따라 특허취소신청이 된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

특허무효심판

제133조의2 【특허무효심판절차에서의 특허의 정정】

① **(요건)** 제133조제1항[**특허무효심판**]에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항[**답변서 제출기간**] 또는 제159조제1항 후단[**의견서 제출기간**]에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.

② **(여러 차례 정정이 있는 경우)** 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.

③ **(송달)** 심판장은 제1항에 따른 정정청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 제133조제1항에 따른 심판의 청구인에게 송달하여야 한다.

④ **(준용규정)** 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지[**정정심판의 객체적 요건**], 제8항[**정정심판의 주체적 요건**] 및 제10항부터 제13항까지[**소급효, 명세서 또는 도면의 보정, 통보 및 특허공보에 게재**], 제139조제3항[**공동심판청구**] 및 제140조제1항·제2항·제5항[**정정심판의 청구 및 보정**]을 준용한다. 이 경우 제136조제11항[**명세서 또는 도면의 보정**] 중 "제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에"는 "제133조의2제1항[**정정청구가 가능기간**] 또는 제136조제6항[**정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간**]에 따라 지정된 기간에"로 본다.

⑤ **(정정청구의 취하)** 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.

1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항[**정정심판의 직권심리에 대한 의견서 제출기간**]에 따라 지정된 기간

⑥ **(특허출원하였을 때 특허를 받을 수 있을 것의 판단)** 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

특허취소신청	특허무효심판
제132조의4 【특허취소신청의 방식 등】 ① (취소신청서의 제출) 특허취소신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 1. 신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명] 3. 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시 4. 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시 ② (취소신청서의 보정) 제1항에 따라 제출된 특허취소신청서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제132조의2제1항에 따른 기간(그 기간 중 제132조의13제2항특허취소결정하려고 특허의 취소이유를 통지하고 의견서 제출기회 부여에 따른 통지가 있는 경우에는 통지한 때까지로 한정한다)에 제1항제4호의 사항을 보정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ (부분 송달) 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 신청서의 부분을 특허권자에게 송달하여야 한다. ④ (통지) 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 사실을 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.	제140조 【심판청구방식】 ① (심판청구서의 제출) 심판을 청구하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명] 3. 심판사건의 표시 4. 청구의 취지 및 그 이유 ② (심판청구서의 보정) 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우 2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우 3. 생략 제147조 【답변서 제출 등】 ① (부분 송달 및 답변서 제출기회의 부여) 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. ② (답변서 부분 송달) 심판장은 제1항의 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다. 제133조 【특허의 무효심판】 ④ (통지) 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

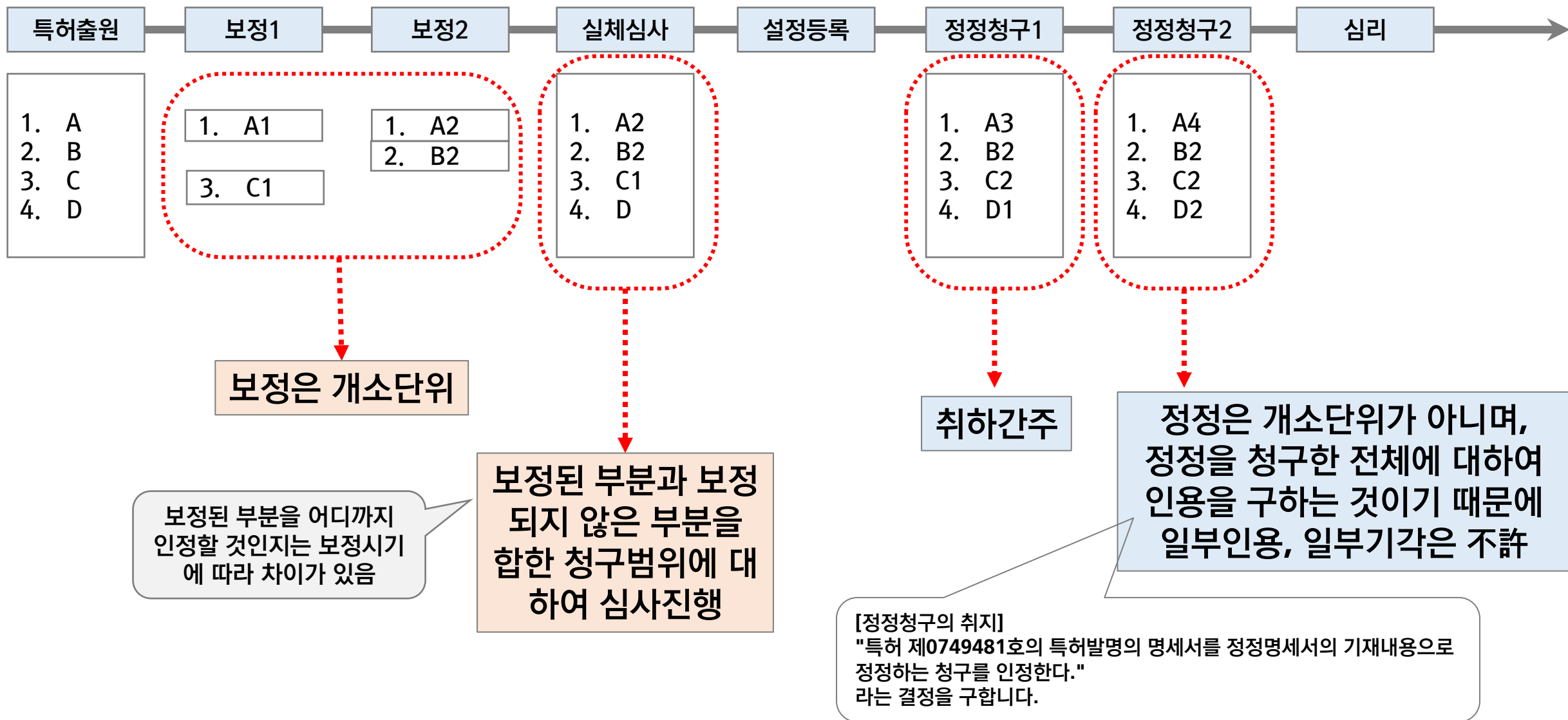
특허취소신청	특허무효심판
제132조의5 【특허취소신청서 등의 보정 · 각하】 ① (대상) 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. 1. 특허취소신청서가 제132조의4제1항(같은 항 제4호는 제외한다)을 위반한 경우 2. 특허취소신청에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우 나. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우 다. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우 ② (각하결정) 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제132조의4제2항을 위반한 경우에는 특허취소신청서 또는 해당 절차와 관련된 청구 또는 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다. ③ (방식) 제2항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.	제141조 【심판청구서 등의 각하】 ① (대상) 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. 다만, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다. 1. 심판청구서가 제140조제1항 및 제3항부터 제5항까지 또는 제140조의2제1항심판청구서 기재에 위반한 경우 2. 심판에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 제3조제1항[미성년자 등의 행위능력] 또는 제6조[대리권의 범위]를 위반한 경우 나. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우 다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우 ② (각하결정) 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제140조제2항 또는 제140조의2제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다. ③ (방식) 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. ④ (직권보정의 절차: 통지) 심판장은 제1항 단서에 따라 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다 ⑤ (직권보정의 절차: 의견서의 제출) 청구인은 제1항 단서에 따른 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 심판장에게 제출하여야 한다. ⑥ (직권보정의 효과: 의견서가 제출된 경우) 청구인이 제5항에 따라 의견서를 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다. ⑦ (직권보정의 효과: 명백히 잘못된 경우) 제1항 단서에 따른 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

특허취소신청	특허무효심판
제132조의6 【보정할 수 없는 특허취소신청의 각하결정】 ① (대상) 제132조의7제1항에 따른 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 제132조의4제3항에도 불구하고 특허권자에게 특허취소신청서의 부분을 송달하지 아니하고, 결정으로 그 특허취소신청을 각하할 수 있다. ② (불복) 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다.	제142조 【보정할 수 없는 심판청구의 심결각하】 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다.
제132조의7 【특허취소신청의 합의체 등】 ① (심판의 주체) 특허취소신청은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 결정한다. ② (준용) 제1항의 합의체 및 이를 구성하는 심판관에 관하여는 제143조부터 제145조까지【심판관, 심판장의 자격 및 지정】, 제146조제2항·제3항【심판관합의체의 합의】, 제148조부터 제153조까지 및 제153조의2【심판관의 제척, 기피 및 회피】를 준용한다. 이 경우 제148조제6호 중 "심결"은 "특허취소결정"으로 본다.	제146조 【심판의 합의체】 ① (심판의 주체) 심판은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 한다. ② (합의: 과반수) 제1항의 합의체의 합의는 과반수로 결정한다. ③ (합의: 비공개) 심판의 합의는 공개하지 아니한다.
제132조의8 【심리의 방식 등】 ① (서면심리) 특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 한다. ② (특허권자 1인에게 절차의 정지원인이 있는 경우) 공유인 특허권의 특허권자 중 1인에게 특허취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.	제154조 【심리 등】 ① (심리방식의 선택) 심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다. 제139조 【공동심판의 청구 등】 ④ (청구인·피청구인 1인의 정지원인이 있는 경우) 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

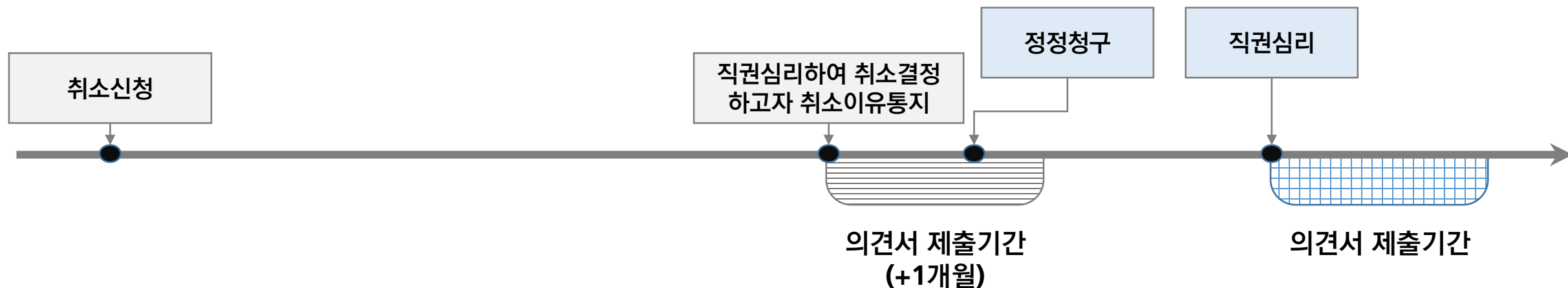
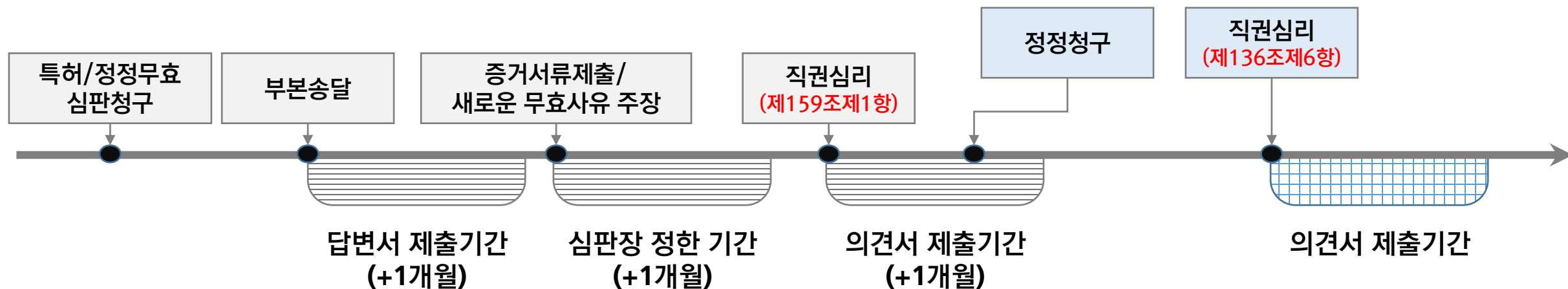
특허취소신청	특허무효심판
제132조의9 【참가】 ① (보조참가의 요건) 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다. ② (준용) 제1항의 참가에 관하여는 제155조제4항[보조참가의 효과]·제5항[참가인 1인에게 정지원인이 있는 경우] 및 제156조[참가의 절차]를 준용한다.	제155조 【참가】 ① (당사자 참가 요건) 제139조제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다. ② (당사자 참가 효과) 제1항에 따른 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다. ③ (보조 참가 요건) 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다. ④ (보조 참가 효과) 제3항에 따른 참가인은 모든 심판절차를 밟을 수 있다. ⑤ (참가인 1인에게 정지원인이 있는 경우) 제1항 또는 제3항에 따른 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다. 제156조 【참가의 신청 및 결정】 ① (신청서 제출) 심판에 참가하려는 자는 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다. ② (의견서 제출기회의 부여) 심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서 부분을 당사자 및 다른 참가인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. ③ (참가여부의 결정) 참가신청이 있는 경우에는 심판으로 그 참가 여부를 결정하여야 한다. ④ (방식) 제3항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. ⑤ (불복 불가) 제3항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다.
제132조의10 【특허취소신청의 심리에서의 직권심리】 ① (범위) 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. ② (한계) 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다.	제159조 【직권심리】 ① (범위) 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. (의견서 제출기회의 부여) 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다. ② (한계) 심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다.

특허취소신청	특허무효심판
제132조의11 【특허취소신청의 병합 또는 분리】 ① (병합) 심판관 합의체는 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리를 병합하여 결정하여야 한다. ② (분리) 심판관 합의체는 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다.	제160조 【심리·심결의 병합 또는 분리】 심판관은 당사자 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다.
제132조의12 【특허취소신청의 취하】 ① (시기적 요건) 특허취소신청은 제132조의14제2항에 따라 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있다. 다만, 제132조의13제2항에 따라 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다. ② (객체적 요건) 둘 이상의 청구항에 관하여 특허취소신청이 있는 경우에는 청구항마다 취하할 수 있다. ③ (효과) 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 특허취소신청 또는 그 청구항에 대한 특허취소신청은 처음부터 없었던 것으로 본다.	제161조 【심판청구의 취하】 ① (주체적 및 시기적 요건) 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 답변서가 제출된 후에는 상대방의 동의를 받아야 한다. ② (객체적 요건) 둘 이상의 청구항에 관하여 제133조제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위 확인심판을 청구하였을 때에는 청구항마다 취하할 수 있다. ③ (효과) 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.
제132조의13 【특허취소신청에 대한 결정】 ① (취소결정: 의의) 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 "특허취소결정"이라 한다)을 하여야 한다. ② (취소결정: 절차) 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. ③ (취소결정: 효과) 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. ④ (기각결정: 의의) 심판관 합의체는 특허취소신청이 제132조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다. ⑤ (기각결정: 불복) 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.	제162조 【심결】 ① (심결에 의한 종료) 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다. 제159조 【직권심리】 ① (범위) 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. (의견서 제출기회의 부여) 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다. 제133조 【특허의 무효심판】 ③ (효과) 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. 제162조 【심결】 ① (심결에 의한 종료) 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.

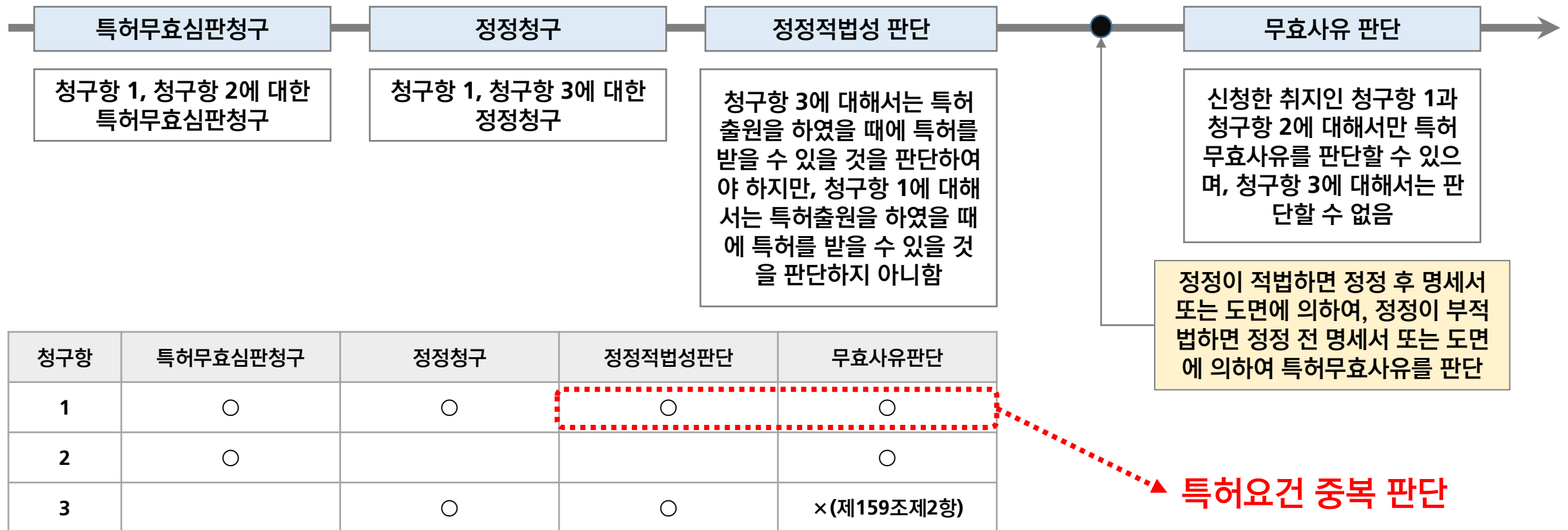
특허취소신청	특허무효심판
제132조의14 【특허취소신청의 결정 방식】 ① (결정의 방식) 특허취소신청에 대한 결정은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 결정을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다. 1. 특허취소신청사건의 번호 2. 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명] 4. 결정에 관련된 특허의 표시 5. 결정의 결론 및 이유 6. 결정연월일 ② (송달) 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.	제162조 【심결】 ① (심결에 의한 종료) 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다. ② (심결의 방식) 제1항의 심결은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 심결을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다. 1. 심판의 번호 2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명] 4. 심판사건의 표시 5. 심결의 주문(제138조에 따른 심판의 경우에는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다) 6. 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다) 7. 심결연월일 ③ (심리종결통지) 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다. ④ (심리재개) 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다. ⑤ (심결시기) 심결은 제3항에 따른 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 한다. ⑥ (송달) 심판장은 심결 또는 결정이 있으면 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.
제132조의15 【심판규정의 특허취소신청에의 준용】 특허취소신청의 심리·결정에 관하여는 제147조제3항[당사자 심문], 제157조[증거조사 및 증거보전], 제158조[심판의 진행], 제164조[소송과의 관계], 제165조제3항부터 제6항까지[청구인의 심판비용 부담] 및 제166조[심판비용액 또는 대가에 대한 집행권원]를 준용한다.	

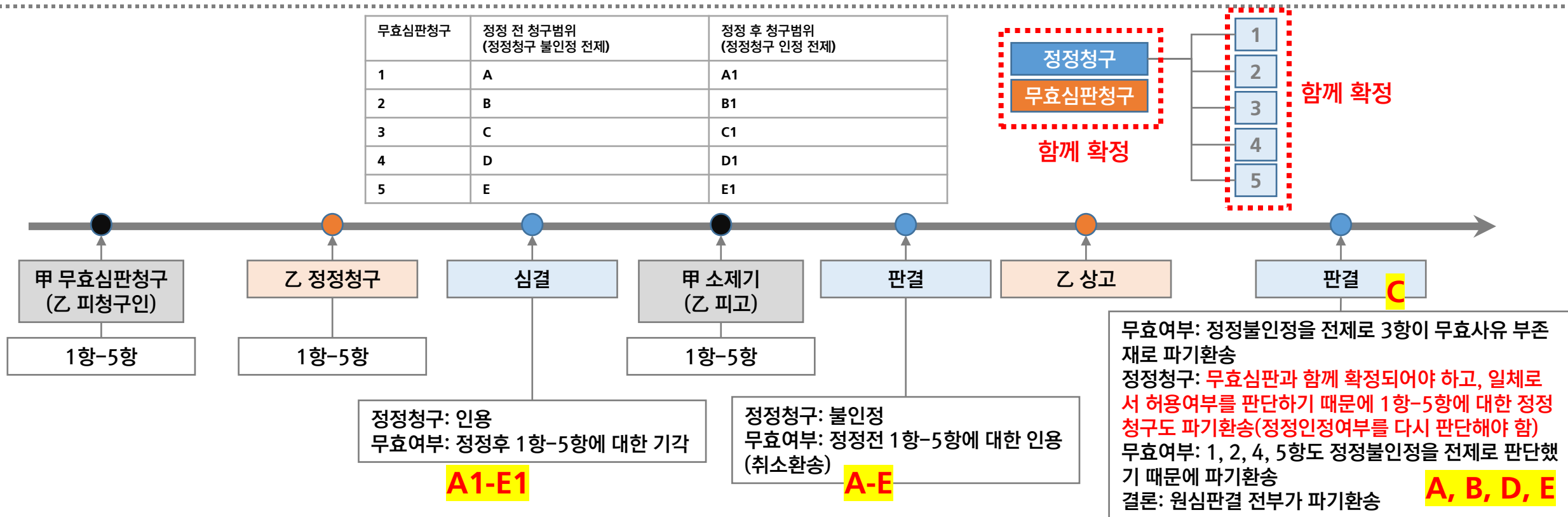


정정청구는 i) 정정청구를 할 수 있는 기간(法 132의3①, 133의2①, 137③)과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간, ii) 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 중 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다(法 132의3④, 133의2⑤, 137④ 준용 133의2⑤). 이는 인정된 정정청구를 취하하면 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판의 심리 대상이 바뀌어 심리 지연의 문제가 발생하기 때문에 취하의 시기를 제한하는 것이다.



청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다(法 132의3③ 및 133의2④ 준용 136⑤, 137④ 준용 133의2④). 다만, 특허취소신청, 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 「특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것」은 적용되지 아니한다(法 132의3⑤, 133의2⑥). 이는 특허취소신청, 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대하여 해당 청구항의 「특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것」을 판단한 후 특허취소신청, 특허무효심판 대상 청구항에 대하여 다시 특허취소사유, 특허무효사유의 유무를 판단하는 것은 실질적으로 동일한 내용을 중복적으로 판단하여 심리의 부담이 가중되고, 특허취소신청, 특허무효심판의 최종적 판단사항인 취소이유, 무효이유를 심결(결정) 전에 미리 알려주는 결과가 되어 이로 인하여 심리의 지연이 초래되는 문제점이 있기 때문이다. 한편, 특허취소신청, 특허무효심판이 청구되지 아니한 청구항을 정정하는 경우에는 이와 같은 요건을 판단하여야 함은 자명하다.





무효심판에서의 정정청구 CASE

대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11487 판결 【등록무효(특)】

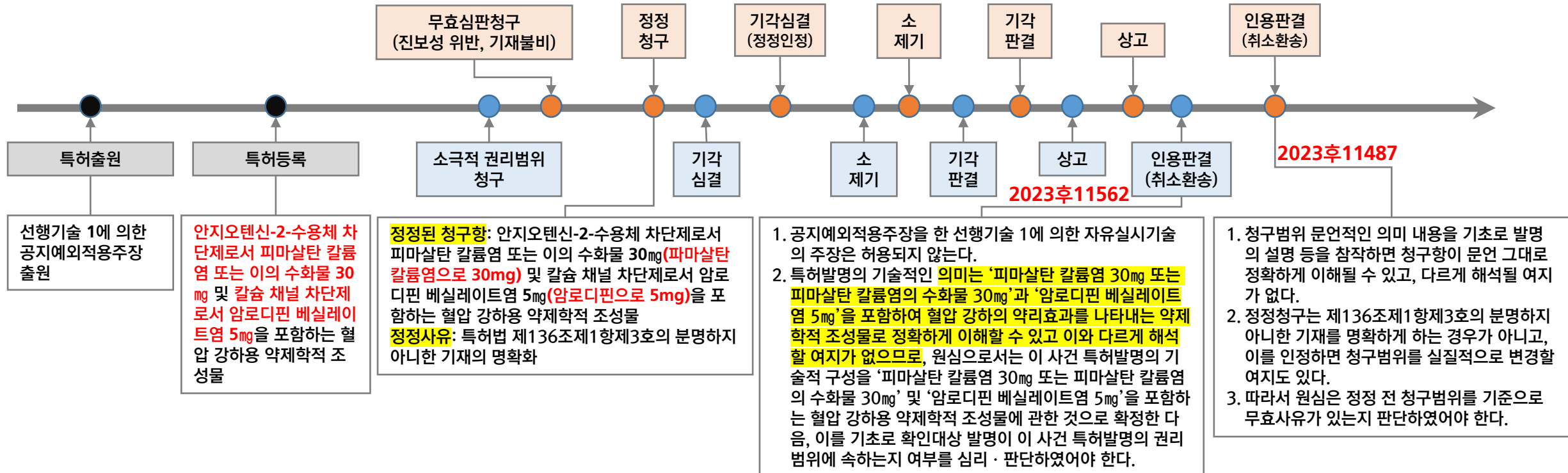
특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).

한편 특허법 제136조 제1항, 제4항에서는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 한하여 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있도록 하면서 이에 따른 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다.

대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562 판결 【권리범위확인(특)】

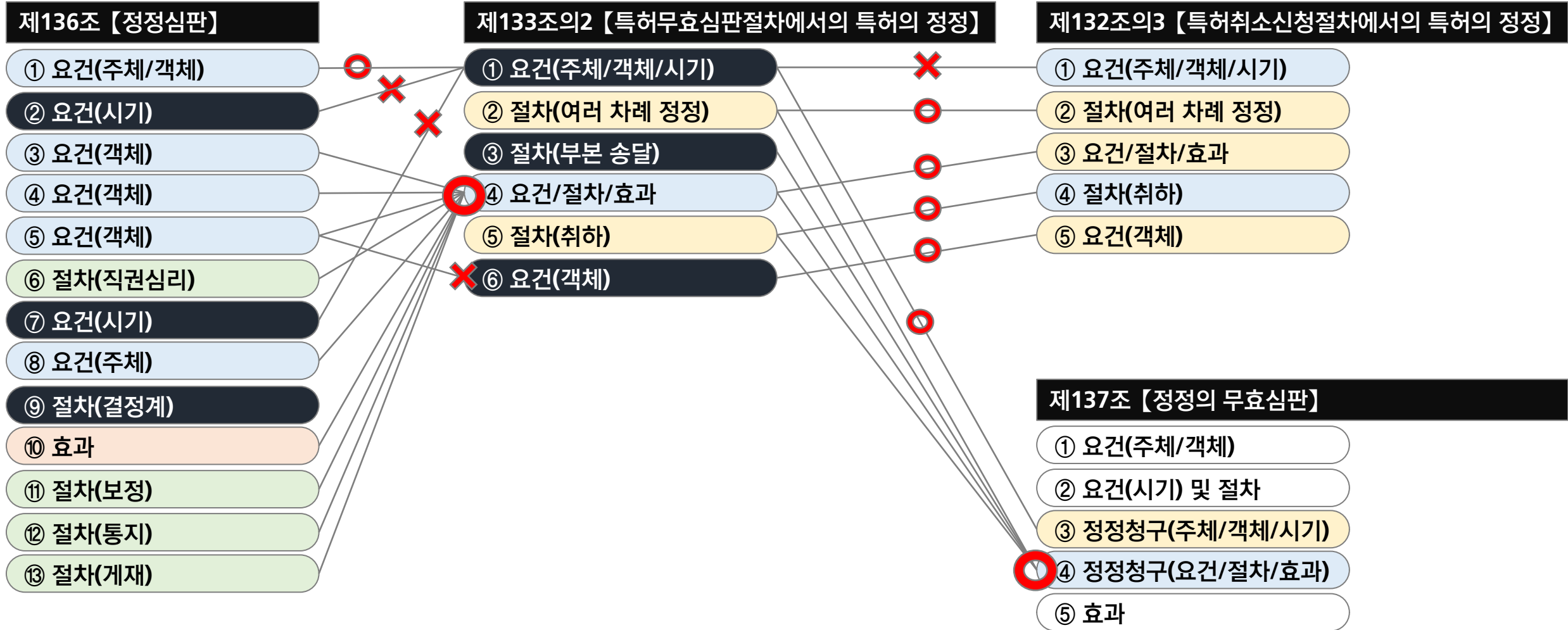
구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것) 제30조 제1항에서 정한 공지에외 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시기술 범리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 공지에외 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상 발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때에는 자유실시기술 주장 즉, '발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 공지에외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다'는 주장은 허용되지 않는다고 보아야 한다.

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).



정정심판(제136조)	특허무효심판절차에서의 특허의 정정(제133조의2)
제136조 【정정심판】 ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 1. 청구범위를 감축하는 경우 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. 1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다. 2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간 ③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. ④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. ⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. ⑥ 심판관은 제1항에 따른 심판청구가 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 경우 2. 제3항에 따른 범위를 벗어난 경우 3. 제4항 또는 제5항을 위반한 경우 ⑦ 제1항에 따른 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(제133조제1항제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다. ⑧ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다. ⑨ 제1항에 따른 정정심판에는 제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조를 적용하지 아니한다. ⑩ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. ⑪ 청구인은 제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에 제140조제5항에 따른 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다. ⑫ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 한다. ⑬ 지식재산처장은 제12항에 따른 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재하여야 한다.	제133조의2 【특허무효심판절차에서의 특허의 정정】 ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. ② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다. ③ 심판장은 제1항에 따른 정정청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 제133조제1항에 따른 심판의 청구인에게 송달하여야 한다. ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항 및 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 "제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에"는 "제133조의2제1항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에"로 본다. ⑤ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다. 1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간 2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간 ⑥ 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

특허취소신청절차에서의 특허의 정정(제132조의3)	특허무효심판절차에서의 특허의 정정(제133조의2)	정정무효심판절차에서의 특허의 정정(제137조제3항, 제4항)
제132조의3 【특허취소신청절차에서의 특허의 정정】 ① 특허취소신청절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제132조의13제2항에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. ② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다. X ← ③ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항, 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 “제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에”는 “제132조의13제2항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에”로 본다. ④ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다. 1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간 2. 제3항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간 ⑤ 제3항을 적용할 때 제132조의2에 따라 특허취소신청이 된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.	제133조의2 【특허무효심판절차에서의 특허의 정정】 ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. ② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다. ③ 심판장은 제1항에 따른 정정청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 제133조제1항에 따른 심판의 청구인에게 송달하여야 한다. ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항 및 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 “제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에”는 “제133조의2제1항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에”로 본다. ⑤ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다. 1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간 2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간 ⑥ 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.	제137조 【정정의 무효심판】 ③ 제1항에 따른 무효심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. ④ 제3항에 따른 정정청구에 관하여는 제133조의2제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제133조의2제3항 중 “제133조제1항”은 “제137조제1항”으로 보고, 같은 조 제4항 후단 중 “제133조의2제1항”을 “제137조제3항”으로 보며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 “제1항”을 각각 “제3항”으로 본다. X →



제178조(재심의 청구) ① 당사자는 확정된 특허취소결정 또는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>

② 제1항의 재심청구에 관하여는 「민사소송법」 제451조 및 제453조를 준용한다.

제179조(제3자에 의한 재심청구) ① 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리나 이익을 사해(詐害)할 목적으로 심결을 하게 하였을 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.

② 제1항의 재심청구의 경우에는 심판의 당사자를 공동피청구인으로 한다.

제180조(재심청구의 기간) ① 당사자는 특허취소결정 또는 심결 확정 후 재심사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다. <개정 2016.2.29.>

② 대리권의 흠을 이유로 재심을 청구하는 경우에 제1항의 기간은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다.

③ 특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년이 지나면 재심을 청구할 수 없다.

④ 재심사유가 특허취소결정 또는 심결 확정 후에 생겼을 때에는 제3항의 기간은 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 기산한다.

⑤ 제1항 및 제3항은 해당 심결 이전의 확정심결에 저촉된다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 적용하지 아니한다.

제181조(재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심 청구 등록 전에 선의로 수출 또는 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다.

1. 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우
2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우
3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우
4. 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 미치지 아니한다.

1. 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 해당 발명의 선의의 실시
2. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
3. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 청약하는 행위

제182조(재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권) 제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다.

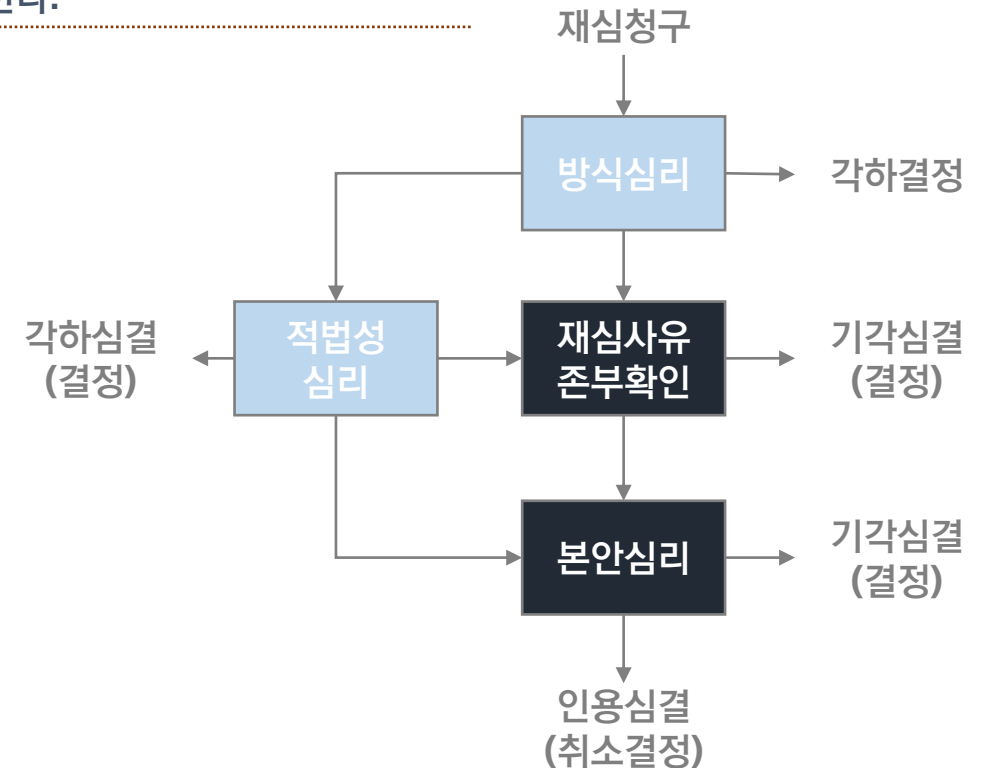
제183조(재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권) ① 제138조제1항 또는 제3항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에는 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 원(原)통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제184조(재심에서의 심판규정 등의 준용) 특허취소결정 또는 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 특허취소신청 또는 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다.

제185조(「민사소송법」의 준용) 재심청구에 관하여는 「민사소송법」 제459조제1항을 준용한다.

구분		내 용	
의의		1. 확정된 특허취소결정 또는 심결에 대한 비상의 불복방법(法 178①) 2. 원특허취소결정 또는 심결의 취소와 재심판을 구함	
취지		법적 안정성의 바탕 위에 구체적 타당성(재심)의 확보	
요건	관할	특허심판원(法 178② 준용 民訴法 453)	
	재심사유	1. 일반재심사유(法 178② 준용 民訴法 451) 2. 사해심결에 대한 재심사유(法 179)	
	재심청구 기간	1. 원칙 - 法 180①③ 2. 예외 - 法 180②④⑤	
절차 및 효과	공통점		
	차이 점	절차	1. 심리순서 - 방식심리, 적법성 심리, 재심사유의 존부확인(원특허취소결정 또는 심결의 취소), 본안심리(재심판) 2. 재심사유의 존부확인 - 재심청구이유에 한함(法 185)
		효과	원심판 효과 이외에 plus 효과 발생 - 法 181, 182(심결확정(3), 취소결정확정(1)) - 法 183(심결확정(1)): 제98조, 제138조



- 제180조(재심청구의 기간)** ① 당사자는 특허취소결정 또는 심결 확정 후 재심사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다.
 ② 대리권의 흠을 이유로 재심을 청구하는 경우에 제1항의 기간은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다.
 ③ 특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년이 지나면 재심을 청구할 수 없다.
 ④ 재심사유가 특허취소결정 또는 심결 확정 후에 생겼을 때에는 제3항의 기간은 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 기산한다.
 ⑤ 제1항 및 제3항은 해당 심결 이전의 확정심결에 저촉된다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 적용하지 아니한다.

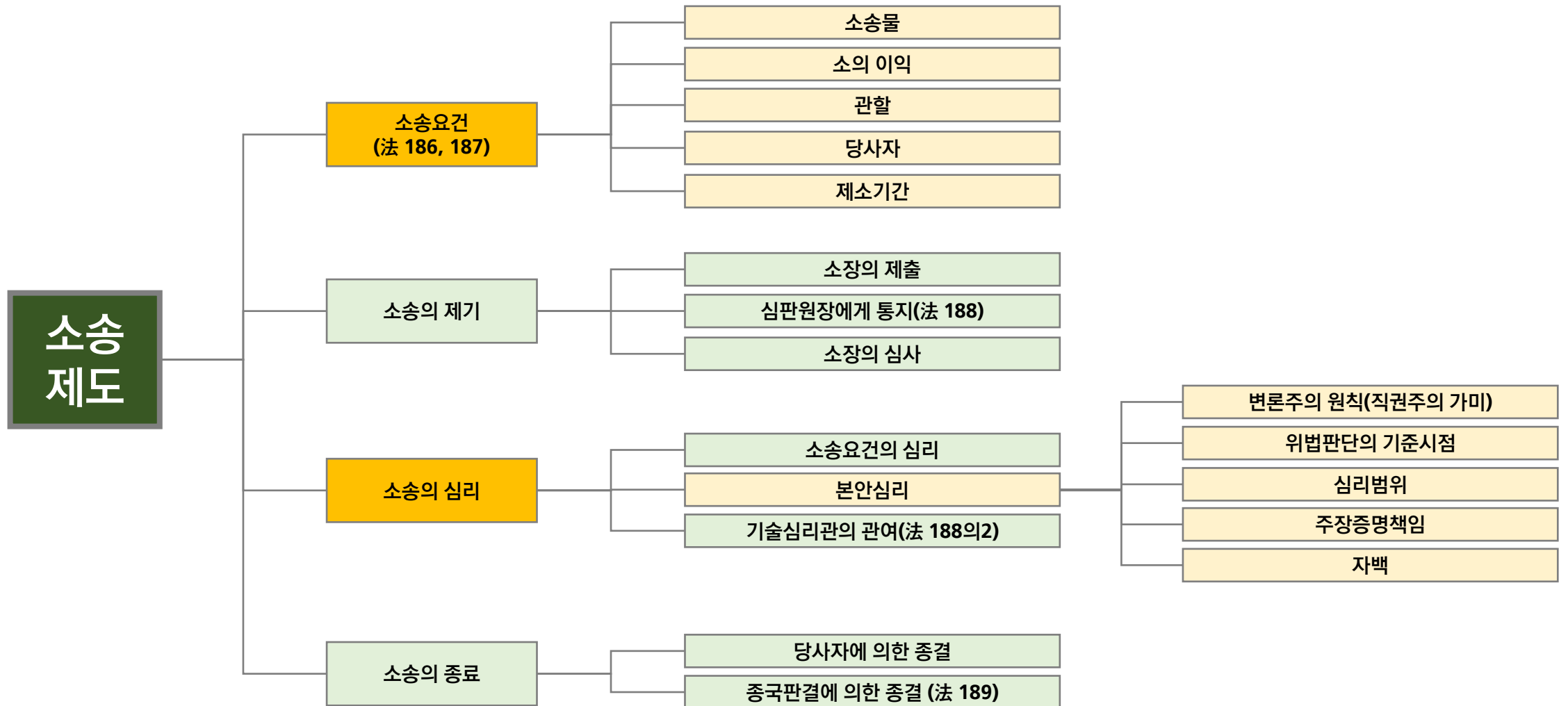
확정심결과 저촉(제180조제5항) 기간 제한×

재심사유를 안 날부터 30일 이내(제180조제1항) 및 특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년(제180조제3항)

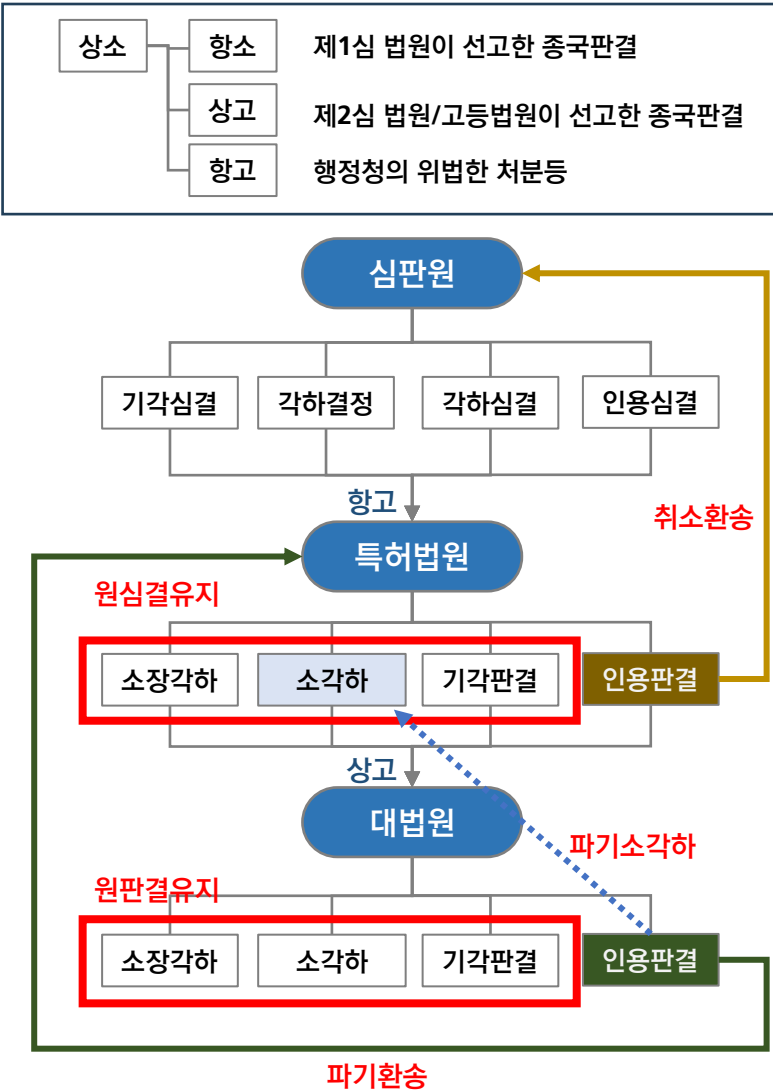
추후보완 가능(제17조)

대리권의 흠을 이유로 재심을 청구(제180조제2항) 등본 송달일의 다음 날 기산

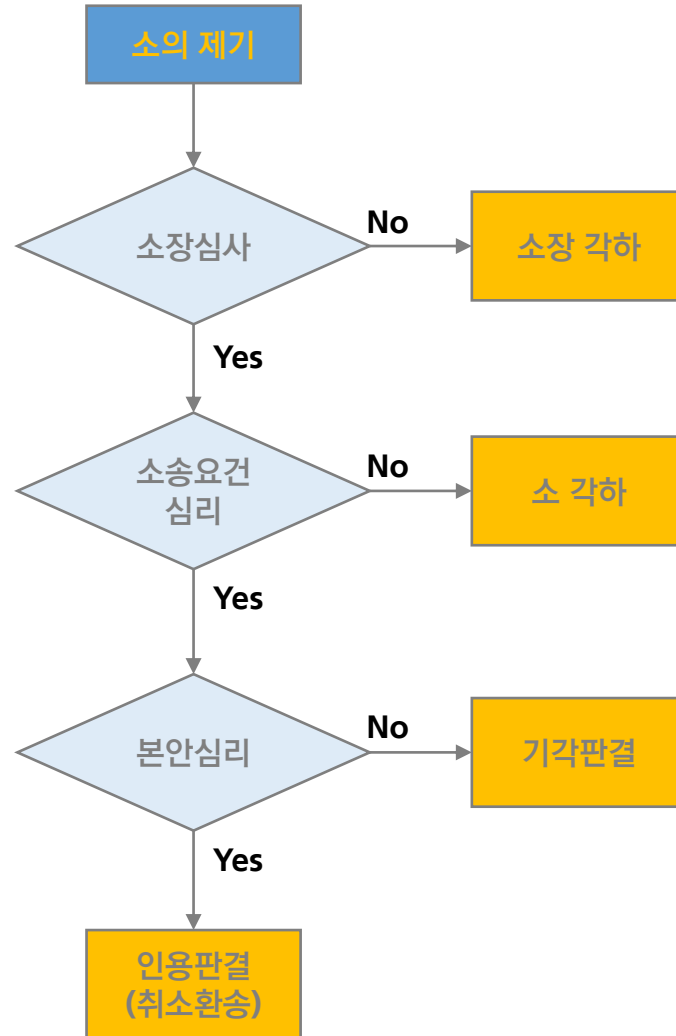
확정 후에 재심사유 발생(제180조제4항) 사유발생일의 다음 날 기산



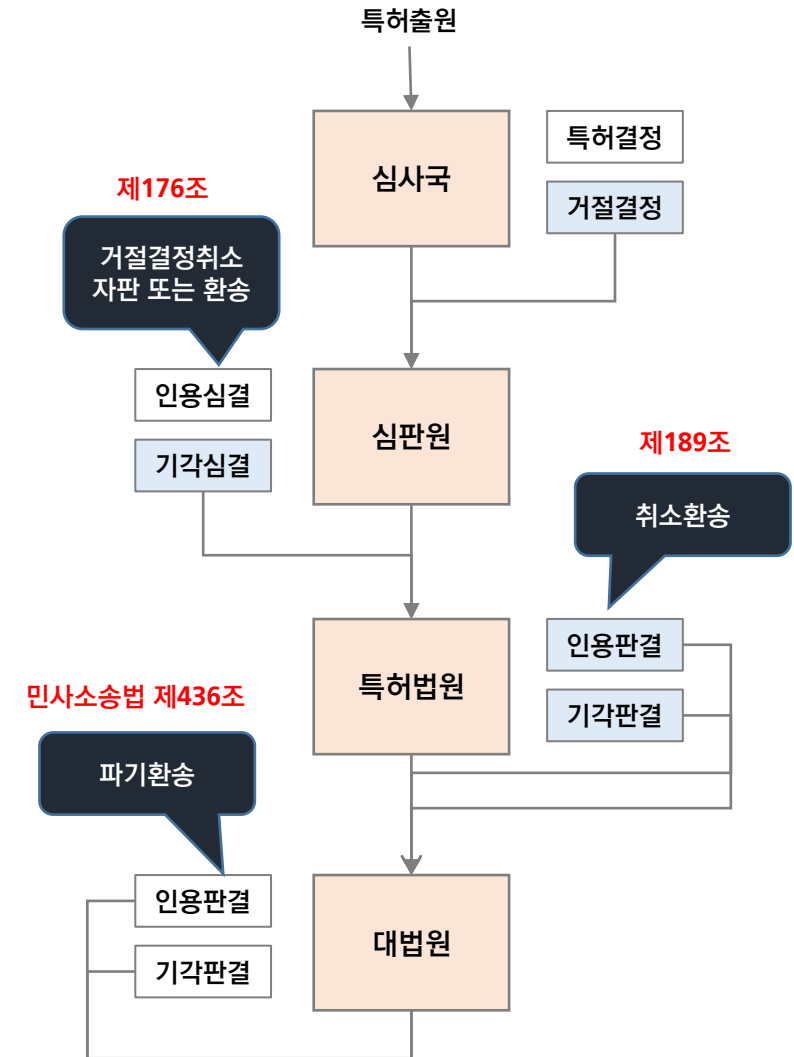
특허소송절차의 개괄



특허법원의 절차진행



거절결정불복심판 사례



의의

- * 원고가 소를 통해 심결을 취소하고자 하는 이익
- * 소의 이익이 부정되는 경우 소각하

내용

- * 원칙: 소의 이익 긍정
- * 예외: 다음의 경우 부정
 - **사정변경**에 심결 자체가 무의미하게 된 경우
 - 심결을 취소하더라도 유리한 심결을 받을 가능성이 없는 경우(**각하되어야 할 심결이 기각된 경우**)

판단

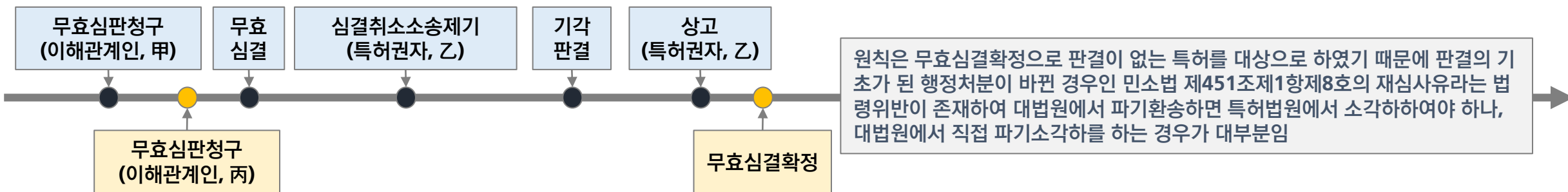
- * **변론종결 시**를 기준으로 판단
- * 다만, **상고심 계속 중에 생긴 사정도** 고려

비고

- * 소의 이익이 있음을 전제로 본안심리
- * 사정변경에 의하여 소의 이익과 심결이 모두 위법한 경우에는 소각하

사정변경의 CASE

(대법원 2001. 5. 8. 선고 98후1921) 특허를 무효로 한 심결에 대한 심결취소소송에서 원고의 청구가 기각되어 상고심에 계속 중, 제3자가 제기한 특허무효심판에서 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 않은 특허를 대상으로 판단한 심결은 위법하게 되나, 특허가 무효로 확정된 이상 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하다.



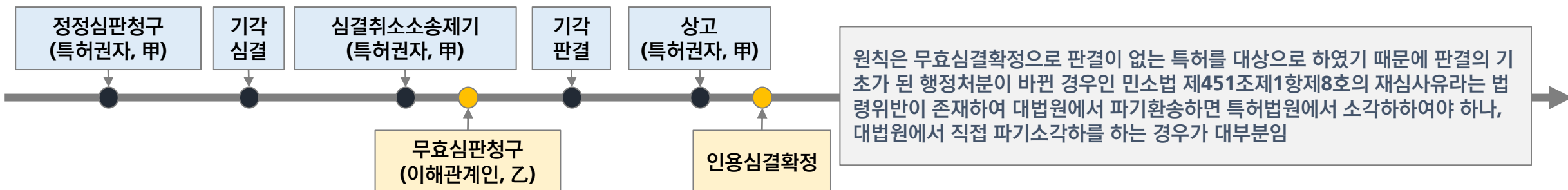
유리한 심결을 받을 가능성이 없는 CASE

당사자 간의 합의가 심결 이후에 있으면 소의 이익이 없으므로 소를 각하하여야 하나, 심판단계에서 당사자 간의 합의가 이루어질 경우에는 심판의 이익이 없으므로 심판청구를 각하하여야 함에도 불구하고 실제 판단을 한 심결은 위법하므로 그 심결은 취소되어야 한다. 다만, 예외적으로 권리범위확인심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서는 소의 이익을 인정하기가 곤란할 것이다. 법원에서 원고 청구를 인용하여 심결을 취소하더라도 특허심판원은 어차피 원고의 권리범위확인심판청구를 각하할 것이므로, 굳이 기각심결의 취소를 구할 이익이 없기 때문이다.



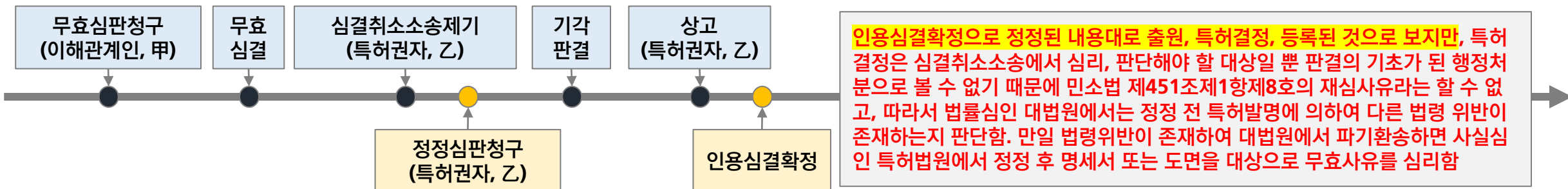
사정변경의 CASE

(특허법원 2009. 10. 12. 선고 2008허9498) 특허발명의 전체 청구항에 대한 무효심결이 확정되어 소급하여 소멸한 경우 정정을 구하는 정정심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정심판을 구할 이익도 없게 되고, 특허발명이 소급하여 무효로 된 이상 정정심결의 취소를 구할 법률상의 이익도 없게 되기 때문에 특허법원에 계속 중이거나 대법원에 계속 중인 경우 심결취소 소송의 소는 각하된다.



참고

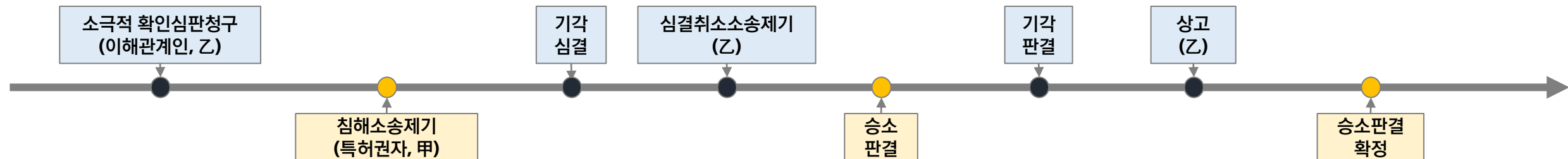
(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체) 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조). 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소 소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.



권리범위확인심판의 소의 이익: 대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결 【권리범위확인(상)】

소의 이익 CASE

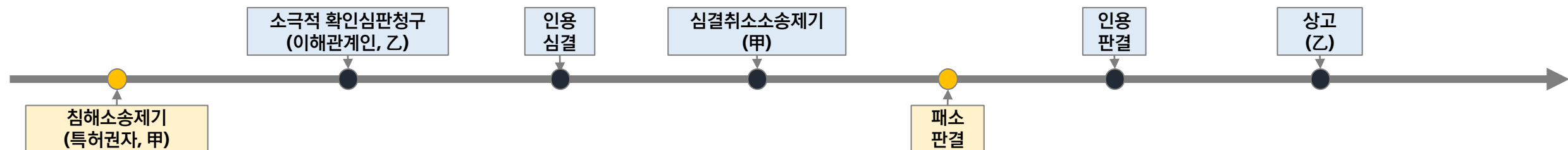
2007. 3. 21. 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 제기하였으나 특허심판원이 2008. 4. 28. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 청구를 기각하는 심결(이하 “이 사건 심결”이라 한다)을 한 점, 비록 피고가 이 사건 등록상표의 상표권 침해와 관련된 민사소송을 2006. 7. 11. 제기하여 2008. 7. 25. 원고 승소판결이 선고되었고, 그 과정에서 이 사건 심결이 먼저 내려져 위 민사판결에 고려될 수 있었으며 이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5. 13. 그대로 확정되었다고 하더라도 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이다.



권리범위확인심판의 심판의 이익: 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결 【권리범위확인(특)】

심판의 이익 CASE

권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 ‘침해소송’이라 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, **간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능**을 가진다. 특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다. 이와 같은 **권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정 내용과 취지 등에 비추어 보면**, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.



제186조(심결 등에 대한 소) ① 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.

제187조(피고적격) 제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 지식재산처장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조제1항·제2항, 제137조제1항 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.

취소결정, 결정계 심판의 심결, 서의 각하결정

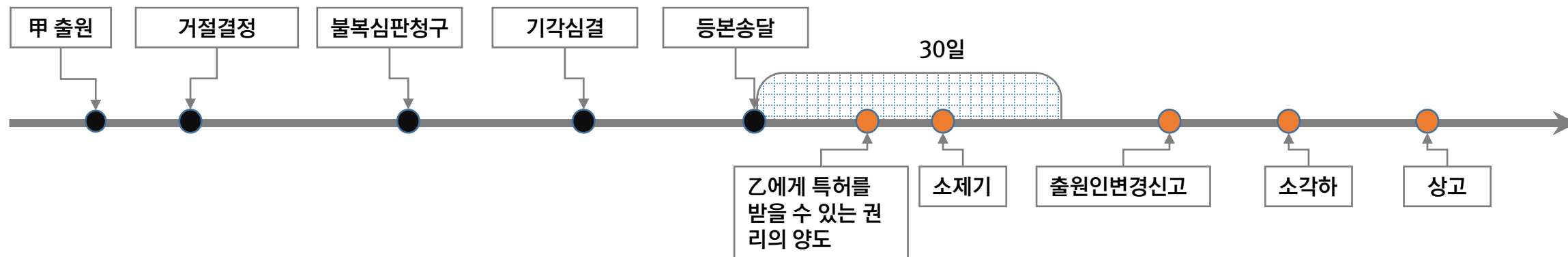
심판의 종류	결정/심결	원고	피고
특허취소신청	취소신청서 각하결정(심판장)	특허취소신청인	지식재산처장
	취소신청 각하결정(심판관합의체)	불복×	
	취소신청 취소결정	특허권자	지식재산처장
	취소신청 기각결정	불복×	
당사자계 심판	심판청구서 각하결정	심판청구인	지식재산처장
	심판청구 각하심결	심판청구인	심판피청구인
	심판청구 인용심결	심판피청구인	심판청구인
	심판청구 기각심결	심판청구인	심판피청구인
결정계 심판	심판청구서 각하결정	심판청구인	지식재산처장
	심판청구 각하심결	심판청구인	지식재산처장
	심판청구 인용심결	불복×	
	심판청구 기각심결	심판청구인	지식재산처장

복수 당사자의 원피고 적격

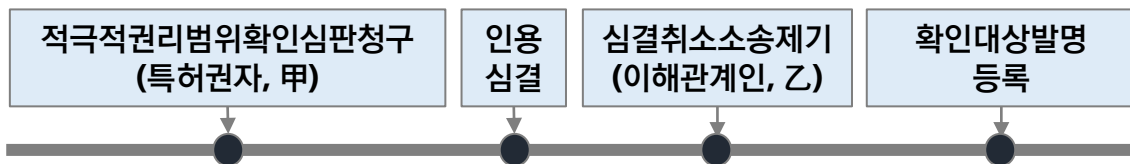
구분	원고	피고
공유특허권자 중 1명	判例가 긍정 (1) 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 볼 수 없기 때문(승소할 경우에는 그 취소판결의 효력은 행정소송법 제29조제1항에 의하여 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개됨으로써 충족되고, 그 소송에서 패소하더라도 이미 심판절차에서 패소한 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 아니함) (2) 모두가 제기해야 한다면 소 제기에 협력할 수 없거나 이해관계가 달라 협력하지 않은 경우에 소 제기를 할 수 없어 부당하게 재산권 침해	判例가 부정 모두를 대상으로 하여야 한다고 해석하더라도 공유자가 원고인 경우와 달리 특별히 부당한 결과가 발생하는 것이 아니기 때문
공동심판청구인 중 1명	학설이 긍정 심결이 있는 후 공동심판청구인 모두에 대하여 출소기간이 지나야 심결이 확정되므로 1명이라도 심결취소소송을 제기하면 심결은 확정되지 않고, 출소기간을 지난 공동심판청구인은 스스로 심결취소소송을 제기할 수는 없지만, 심결이 확정되지는 않았으므로 승소의 확정판결에 의하여 다시 심판이 계속되면 그 심판에서 심결취소소송을 제기하지 아니한 공동심판청구인도 심판청구인의 지위를 유지	判例가 긍정 (1) 1명의 피고를 상대로 심결취소소송을 제기함으로써 그 심결은 확정되지 아니한 것이 되고, 원고가 패소판결이 확정된 경우에만 비로소 심결이 확정됨 (2) 나머지 피고를 추가하는 보정 불인정

대법원 2017. 11. 23. 선고 2015후321 판결 【거절결정(특)】

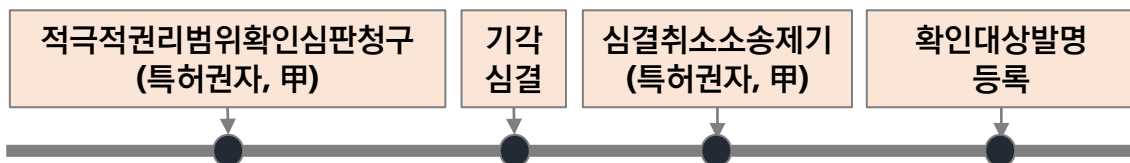
특허법 제186조는 제2항에서 특허심판원의 심결에 대한 취소의 소는 당사자, 참가인, 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자가 제기할 수 있다고 규정하고, 제3항에서 그 취소의 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다고 규정하고 있다. 한편 특허법 제38조 제4항은 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있다. 이러한 규정들에 의하면, 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다. 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지이다.



심결취소소송에 있어서도 심결의 위법 여부는 **심결 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단**하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있는 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 하여서는 아니 된다. 예컨대, 심결 시 이후에 발생한 확인대상발명의 특허등록사실을 고려하여 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판의 위법 여부 판단의 근거로서 활용될 수 없다. 즉, 심판계속 중 확인대상발명이 등록된 경우에는 특허권(실용신안권) 사이의 저촉관계를 확인하는 적극적 권리범위확인심판은 부적법한 것으로 되지만, 인용심결이 있는 후에 그 심결에 대한 취소소송 계속 중에 확인대상발명이 등록된 경우에는 그 심판 자체가 부적법한 것으로 되는 것은 아니게 된다. 이 경우 특허법원에서 심결의 위법성 여부에 대한 실체판단 후 심결이 위법하면 그 심결을 취소환송하게 되고, 심판원에서 심판청구를 심결각하하게 된다. 만약 심결이 위법하지 않으면 기각판결을 하게 되고 그 결과 최종적으로 심판원의 인용심결이 확정될 수 있다. 이는 의도치 않게 특허권 사이의 저촉관계를 확인하는 적극적 권리범위확인심판의 인용심결이 확정된 경우로서 어쩔 수 없는 상황이라 할 것이다. 다만, **적극적 권리범위확인심판을 기각하는 심결인 경우에** 소의 이익을 긍정할 것인지 여부에 대하여 소의 이익이 부정된다고 하면 기각심결이 확정되는데, 적극적 권리범위확인심판을 구하는 대상이 등록되었다가 후에 등록무효심결에 따라 소급하여 소멸한 경우에는 위 **기각심결이 일사부재리의 효력을 갖게 되어 더 이상 다툴 수 없게 되는 문제가 발생하므로, 소의 이익이 긍정된다는 견해**가 있으나, 판례는 **단순히 각하되어야 할 것이 기각된 것에 불과하여 심결취소를 구할 법률상 이익이 인정되지 아니하여 소의 이익이 부정된다는 입장**이다.



이해관계인 乙의 입장에서는 확인대상발명등록 여부와 무관하게 인용심결을 취소할 필요가 있기 때문에 소의 이익이 긍정된다. 따라서, 심결의 위법성 여부를 판단하게 되는데, 확인대상발명의 등록은 심결시 이후에 발생한 사실이기 때문에 그 판단에 영향을 미치지 아니한다. 구체적으로 심결이 위법하지 않으면 기각판결되어 인용심결이 확정되고, 심결이 위법하면 취소환송되고 특허심판원에서 심결각하하게 된다.



특허권자 甲의 입장에서는 소의 이익이 긍정되고 본안심리에서 인용(파기환송)되더라도 특허심판원에서 심결각하하게 된다. 그런데, 특허권자 입장에서 기각이든지 각하든지 심판에서 지는 것은 매한가지이기 때문에 법원은 소 각하를 하여 기각심결을 확정시키고 있다.

거절결정불복심판 심결취소소송의 심리범위

일반
법리

대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054

특허출원에 대한 심사단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 지식재산처장은 심사 또는 심판단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다.

CASE
1

대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054

다만 거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 지식재산처장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다. 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.

CASE
2

대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121

특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 '보정 전의 특허출원'에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 그 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 '보정 이후의 특허출원'에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.

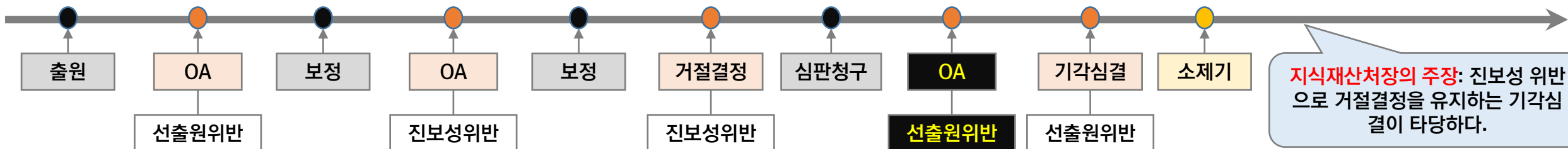
거절결정불복심판 심결취소소송의 심리범위

Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

CASE
3

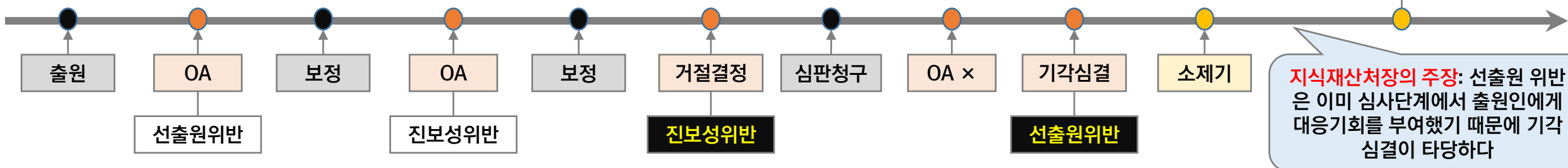
대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997

거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 지식재산처장은 거절결정의 이유 외에도 심사나 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다

CASE
4

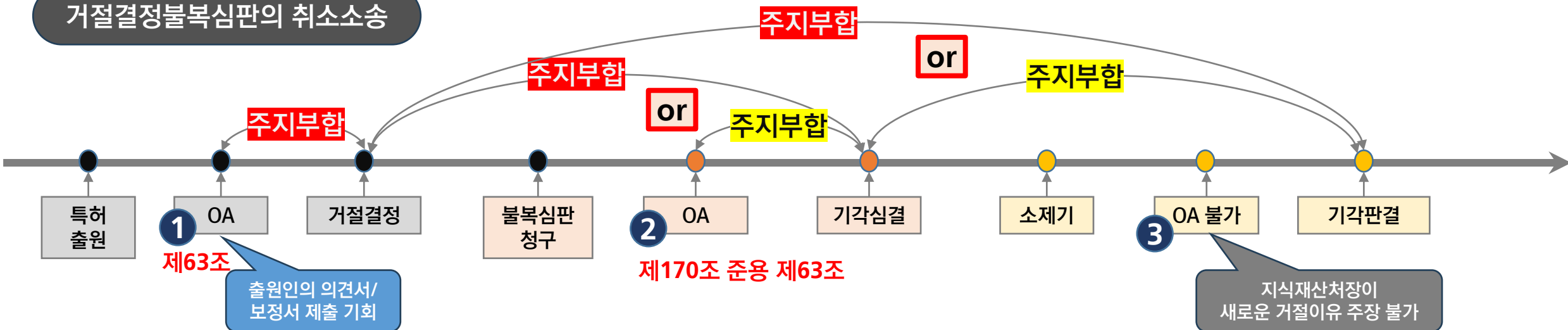
대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779

거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 예를 들어, 심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다.



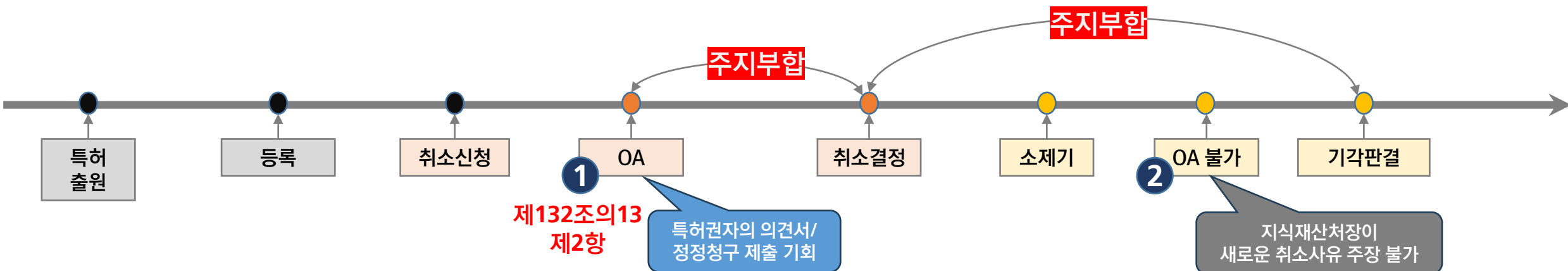
강행규정(제63조, 제136조제6항, 제132조의13제2항)과 심리범위

거절결정불복심판의 취소소송



특허취소결정의 취소소송

특허취소결정에 대한 취소소송에서도, 피고인 지식재산처장이 특허취소결정 당시 취소신청이유로 삼지 아니한 새로운 사유를 주장할 수 있다면 특허권자는 새로운 취소신청이유에 대하여 의견서를 제출하거나 정정청구를 할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 이를 제한함이 바람직할 것이다.



지식재산처의 심사 및 특허심판원의 심판절차에서는, 주지관용기술이 심사관, 심판관 사이에 현저한 사실이므로 별도의 증거없이 이를 인정할 수 있다. 구체적으로 심사관, 심판관은 주지관용기술에 해당된다고 인정되는 경우 증거자료를 첨부하지 않고 거절이유를 통지할 수 있으나, 출원인이 주지관용기술이 아니라고 주장하는 경우 심사관, 심판관은 원칙적으로 그 거절이유에 대한 증거자료를 제시하여야 한다. 다만, 문헌 등에 의한 증거자료의 제시가 곤란한 경우라면 심사관은 주지관용기술이라는 점에 관하여 충분히 설명하거나 주지관용기술이 아니라는 출원인의 주장이 적절하지 아니한 이유를 지적하여 거절할 수 있다. 주지관용기술임을 나타내는 증거자료로는 교과서, 초학자를 대상으로 하는 서적, 기술 표준 사전, 해당 기술분야의 국가표준(KS) 규격 등이 있다.

그러나 심결취소소송절차에서는 주지관용기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 증명을 필요로 한다(변론주의 원칙). 다만, 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있으나(직권주의 가미), 변론종결 후 제출된 참고자료까지 여기의 증거 등 기록에 나타난 자료에 포함된다고 볼 수는 없다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436). 변론종결 후 제출된 참고자료까지 근거로 삼아 주지관용기술을 인정한다면 이는 서면심리에 의하여 판단하는 특허심판원 절차와 별반 다를 것이 없어지고, 소송절차로서의 본질에 반한다는 문제가 있다. 심결취소소송은 원칙적으로 민사소송절차에 따라 구술변론과 증거조사를 통해 심결의 위법 여부를 심리, 판단하는 절차이지, 서면심리에 의하여 판단하는 절차가 아니다. 또한 아무리 정식으로 증거조사된 것 이외의 자료를 판단의 근거로 삼는다고 하더라도 이는 어디까지나 상대방에게 송달 등의 방법으로 현출되어 다룰 수 있는 기회가 부여됨을 전제로 하는 것이지, 이러한 기회 부여도 없이 함부로 주지관용기술 판단의 근거로 삼을 수는 없다고 할 것이다.

거절결정불복심판에 대한 심결취소소송의 심리범위

출원인의 대응기회 확보 위해 새로운 거절이유 심리 불가
다만, 이미 통지한 거절이유를 보충하는 정도는 가능

진보성 위반이라는 거절이유를 보충하는 것으로서, 주지관용기술의 경우 불요증사실*이 아니라면 지식재산처장이 증명(변론주의의 원칙)
다만, 변론종결전까지 제출된 증거 등 기록에 나타낸 자료를 통해 인정 가능(직권주의 가미)

* 민사소송법 제288조(불요증사실)

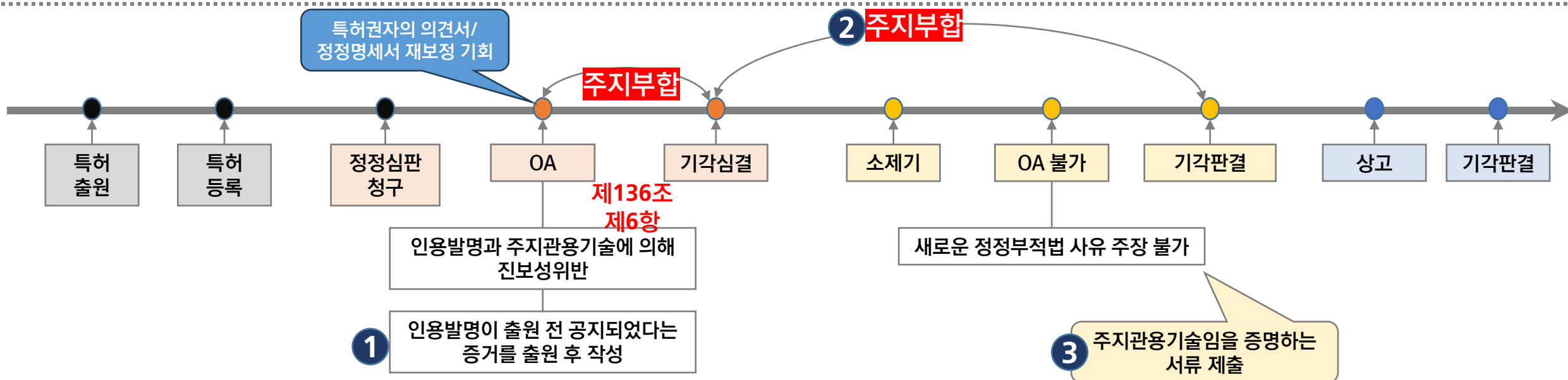
법원에서 당사자가 자백한 사실과 현저한 사실은 증명을 필요로 하지 아니한다. 다만, 진실에 어긋나는 자백은 그것이 착오로 말미암은 것임을 증명한 때에는 취소할 수 있다.

대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결 【정정(특)】

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제1항 제1호 소정의 '특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'에서 '특허출원 전'의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 인정할 수 있다.

[2] 의견서 제출기회를 부여하는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제4항은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하나, 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용된다.

[3] 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아니라도 정정거절이유를 보충하는 것이라면 새로운 정정거절이유라고 할 수 없으므로, 특허법원이 그 증거를 채용하여 정정청구를 기각한 심결이 정당하다는 사유의 하나로 삼았다고 하여 심리범위를 일탈하였다고 할 수 없다.



특허법이나 행정소송법에 자백 또는 자백간주에 대하여 아무런 특별규정을 두고 있지 않으므로 심결취소소송에 민사소송법의 자백 또는 자백간주 규정이 준용되는지 문제이다. 이에 대하여 대법원 2000. 12. 12. 선고 2000후1542 판결은 “행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되고, 따라서 자백 또는 자백간주도 인정되나, 자백의 대상은 사실이고 이러한 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 아니한다.”고 하여, 「사실」과 「법적 판단 내지 평가」를 구분하고 있다. 다만, 어떤 개념이 사실개념인지 아니면 평가개념인지에 대한 구별은 쉽지 아니하다. 사실에 대한 진술인지 아니면 법적 판단 내지 평가에 관한 진술 인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

특허심판	사실	법적 판단 내지 평가
특허심판원 계속중	자백 불인정	자백 불인정
특허법원 계속중	자백 인정	자백 불인정

- 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지 여부 (대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905)
- 피심판청구인의 확인대상발명 실시 여부 (특허법원 2012. 7. 26. 선고 2011허11255)
- 침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지 여부 (대법원 2022. 01. 27. 선고 2019다277751)

- 등록고안과 확인대상고안의 동일 여부 (특허법원 1999. 3. 5. 선고 98허4883)
- 신규성 또는 진보성이 있는지 여부 (특허법원 2000. 3. 31. 선고 99허6640)
- 특허청구항의 해석(특허법원 2000. 9. 21. 선고 99허5654)
- 정정요건에 해당하는지 여부(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238)
- 침해대상제품의 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등한지 여부 (대법원 2022. 01. 27. 선고 2019다277751)

대법원 2022. 01. 27. 선고 2019다277751 판결 【특허권 침해금지 청구의 소】

[1] 침해대상발명이 특허발명의 특정 구성요소 포함하고 있다는 진술로 자백이 성립하였는지, 자백이 성립하였다면 그 자백이 적법하게 취소되었는지: 특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 ‘침해대상제품’이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결 등 참조). “침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다.”는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소*되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다(대법원 2018. 10. 4. 선고 2016다41869 판결 등 참조).

* 민사소송법 제288조(불요증사실) 법원에서 당사자가 자백한 사실과 현저한 사실은 증명을 필요로 하지 아니한다. 다만, 진실에 어긋나는 자백은 그것이 착오로 말미암은 것임을 증명한 때에는 취소할 수 있다.

[2] 이 사건 특허발명이 명세서 기재요건 중 명확성 요건을 충족하는지: 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다는 점에서(특허법 제97조) 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).

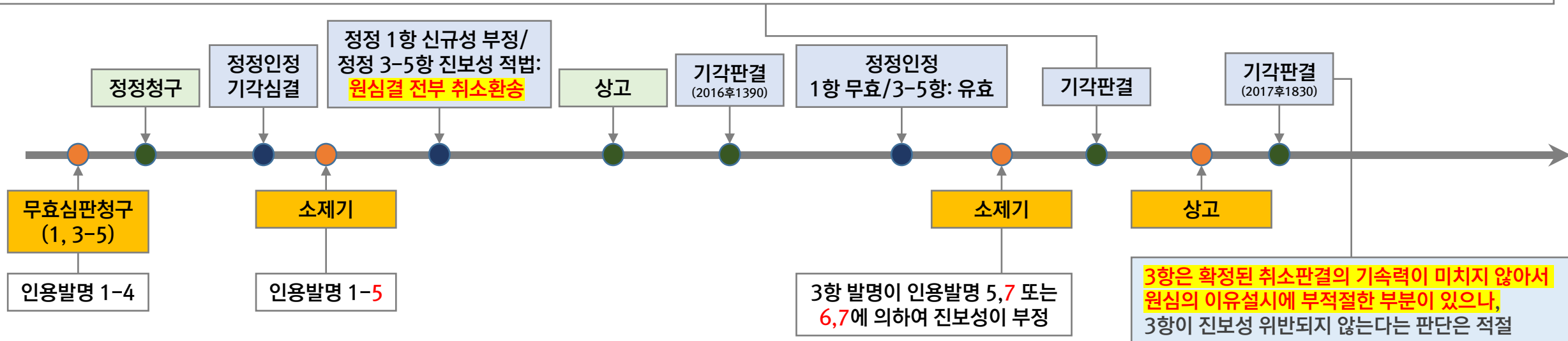
확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위

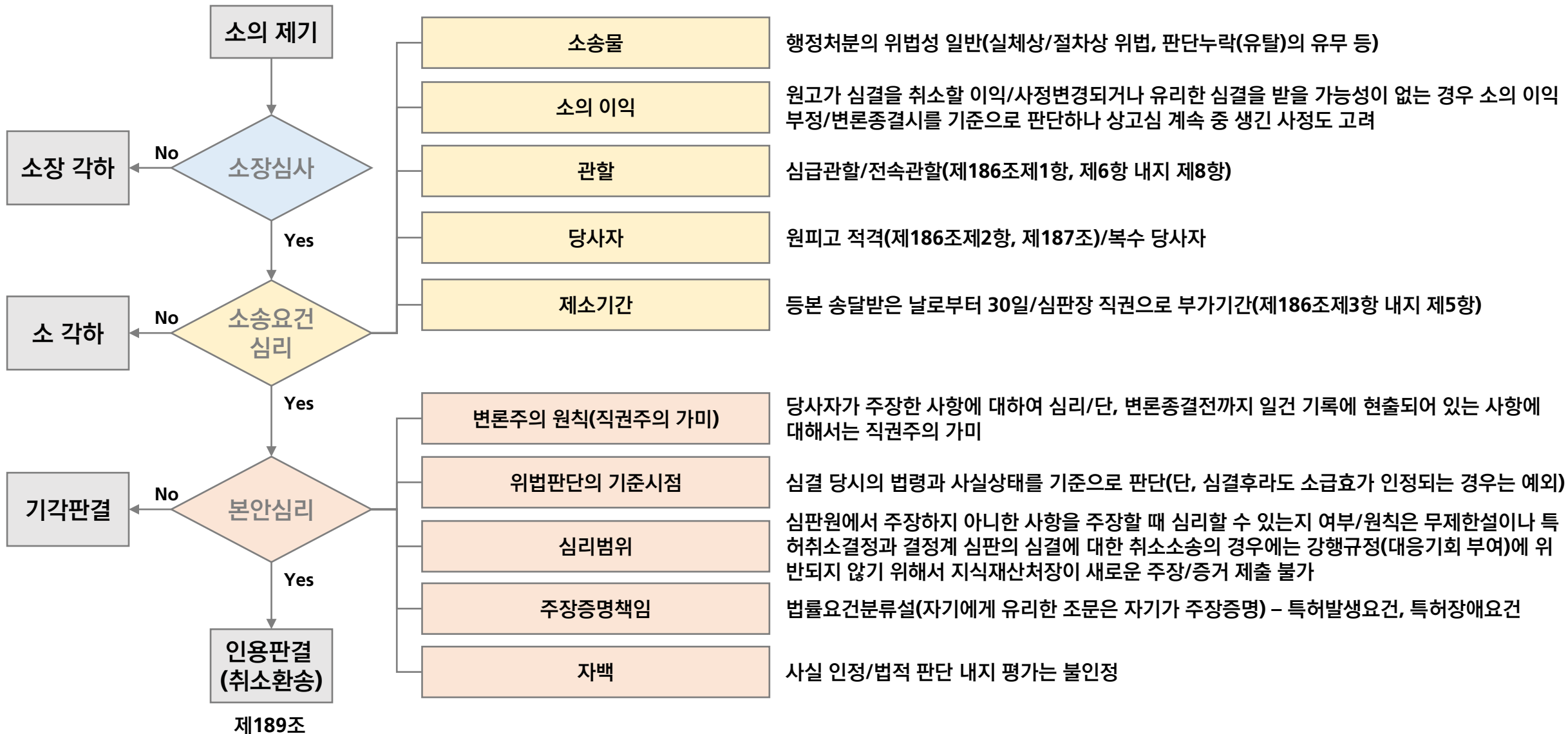
Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결 【등록무효(특)】

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99후2860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 등 참조). 위 법리에 비추어 이 사건에서 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위에 관하여 본다. 확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다. 따라서 확정된 취소판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결). 그런데, 인용발명 6, 7은 원판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 갖는 증거라고 보기도 어렵다.



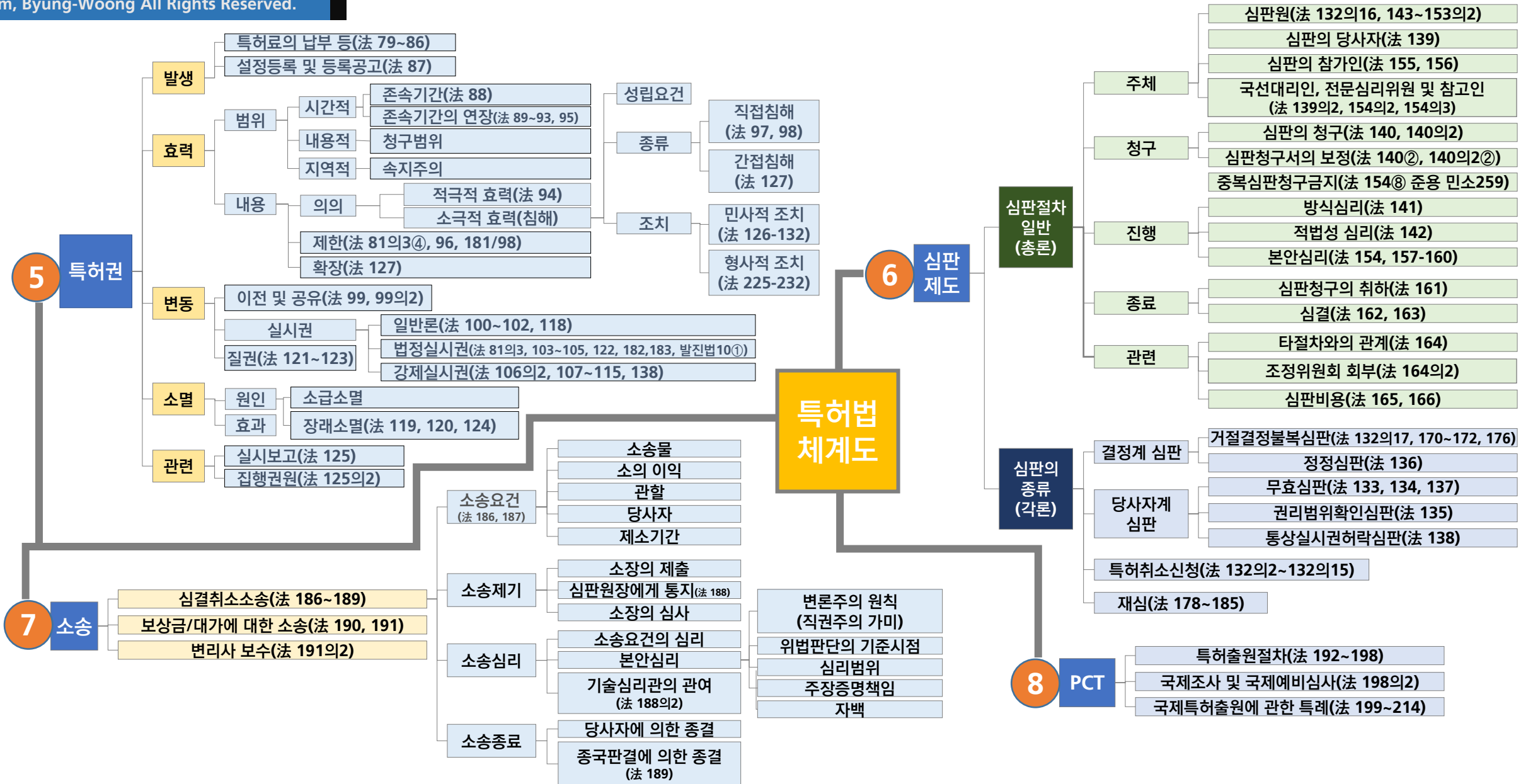


특허법 강의노트

Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

2026



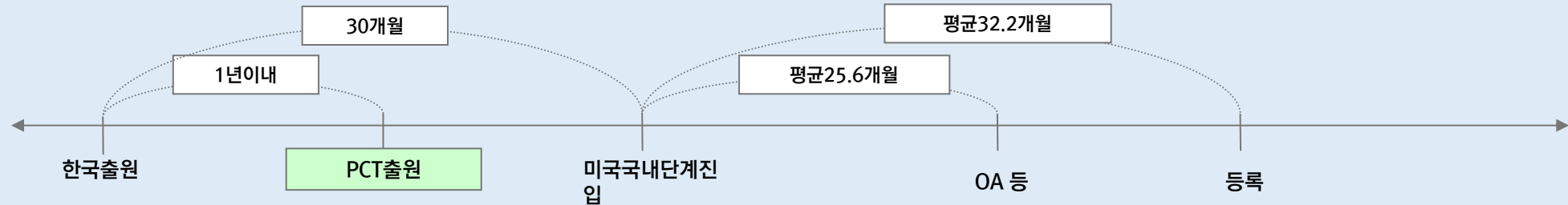


한국의 경우 특허등록까지 건당 400~600만원, PCT 출원의 경우 400~800만원, 개별국가의 경우 특허등록까지 건당 1200~3000만원의 비용이 소요되기 때문에 ROI(Return On Invest)를 고려해야 한다.

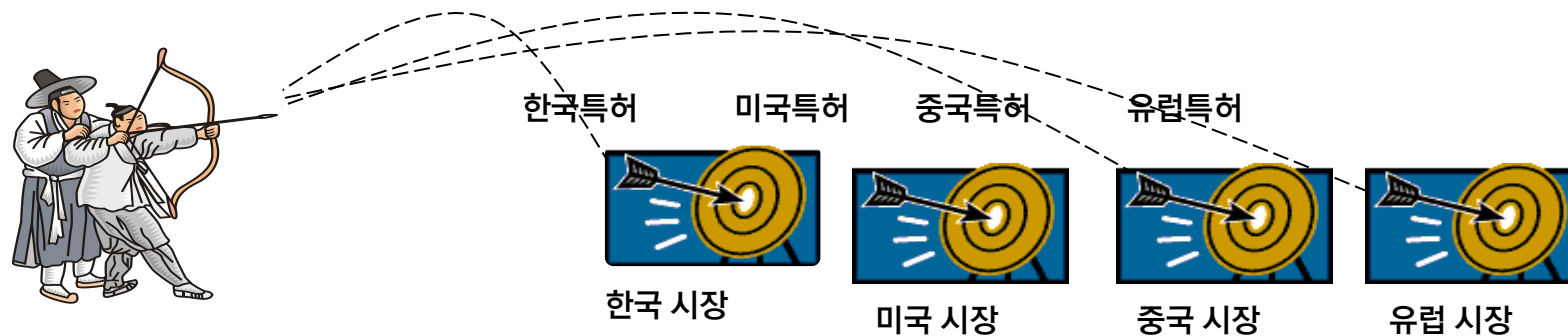
(단위: 만원)

구분	단계	국내대리인	현지대리인	관납료	계
PCT	출원단계	200~400	-	160~250	360~650
	19조 보정	20~50	-		20~50
	국제예비심사	7~30	-	34~53	41~83
	34조 보정	20~50	-		20~50
	계	247~530		194~303	441~833
개별국 (1국기준)	번역료		200~400		200~400
	출원단계	80~300	200~800	150~500	430~1600
	OA	20~150	200~500		220~650
	등록단계	80~200	100~500	150~700	330~1400
	계	180~550	700~2200	300~1200	1180~3950

국가별로 시장이 상이하며, 시장은 고정되어 있지 않고 계속 변화되어 가기 때문에 시장을 정조준할 수 있는 출원전략이 필요하다.

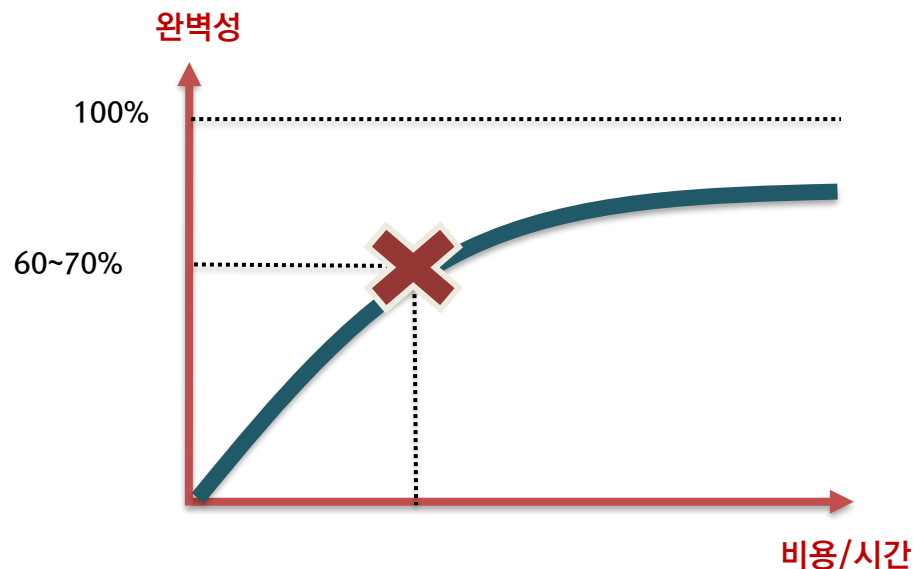


PCT를 경유하여 미국에서 특허를 받는 경우 대략 5년의 시간이 필요하다. 5년 후에도 미국에서 특허에 대한 시장이 있을까?



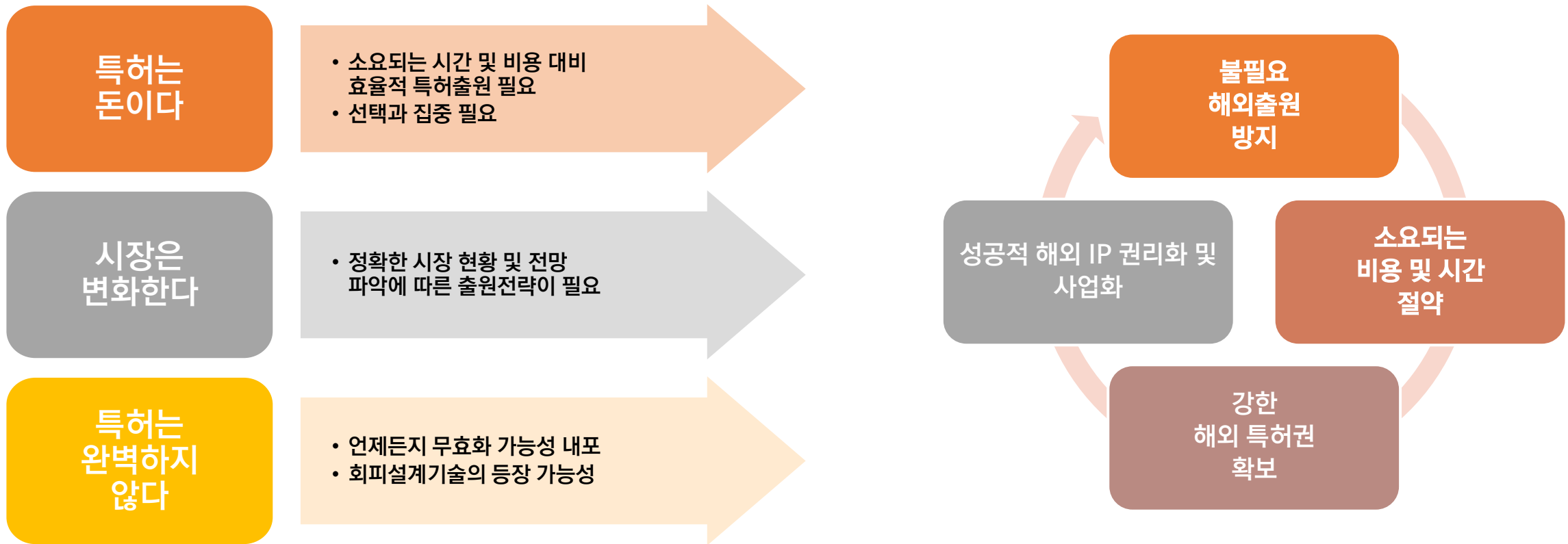
특허는 항상 무효화 가능성을 내포하고 있기 때문에, 1~2건의 특허에 의해서 침해소송에서 승소하기는 어렵다. 따라서 강력한 특허포트폴리오를 구축해야 한다.

특허의 완벽성

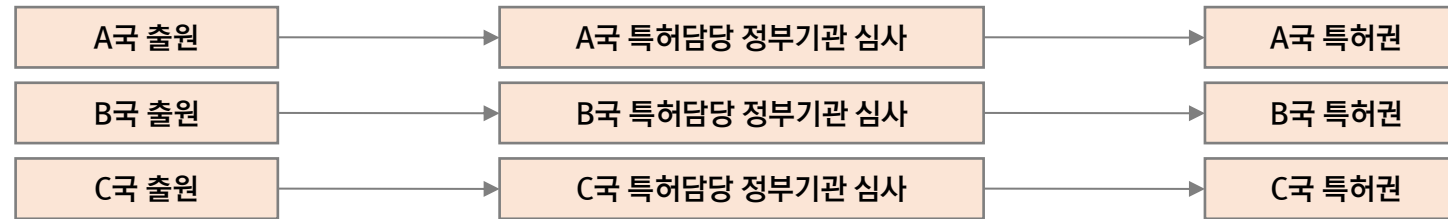


애플맨닷컴 vs 프라운호프

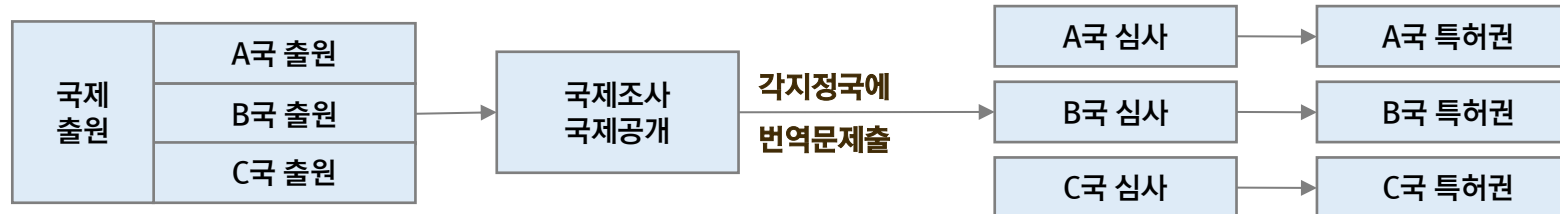
애플맨닷컴	프라운호프
▪ MP3에 활용되는 파일 압축기술은 80년대 초 독일의 프라운호프가 개발했으나, 이를 오디오에 활용한 것은 한국 기업이 최초 ▪ 관련 특허 2건 확보 ▪ 후발 주자가 특허 무효 소송으로 대응하며 로열티 지불 거부	▪ MP3에 활용되는 파일 압축기술 개발 ▪ 관련 특허 40여개 특허 확보 ▪ MP3 제조업체로부터 대당 25센트~1달러 로열티 지급



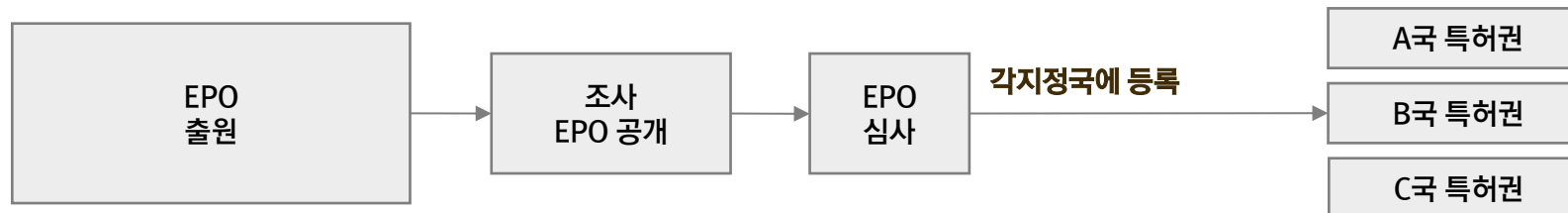
직접해외출원

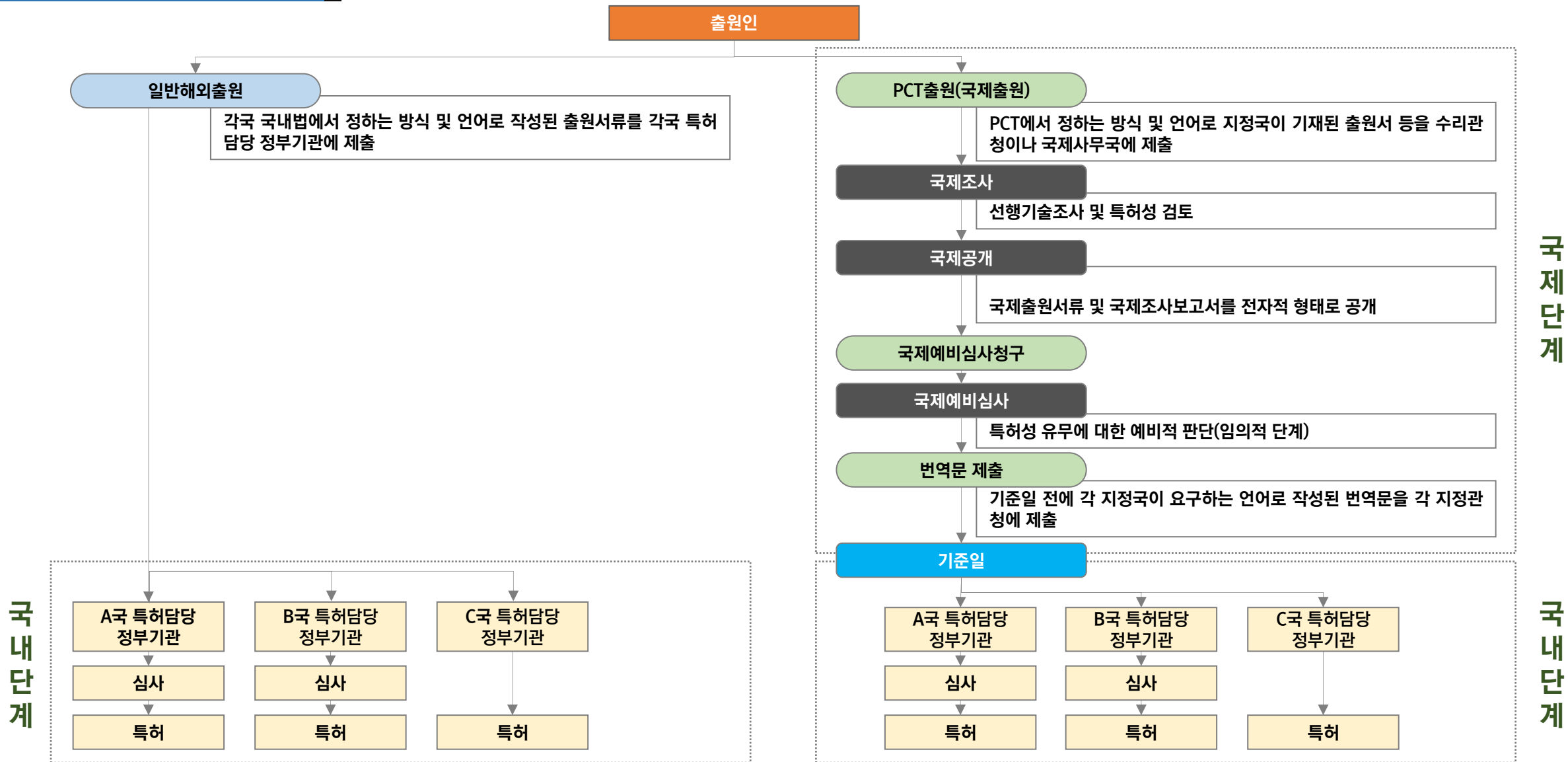


PCT출원(=국제출원)



EPO출원

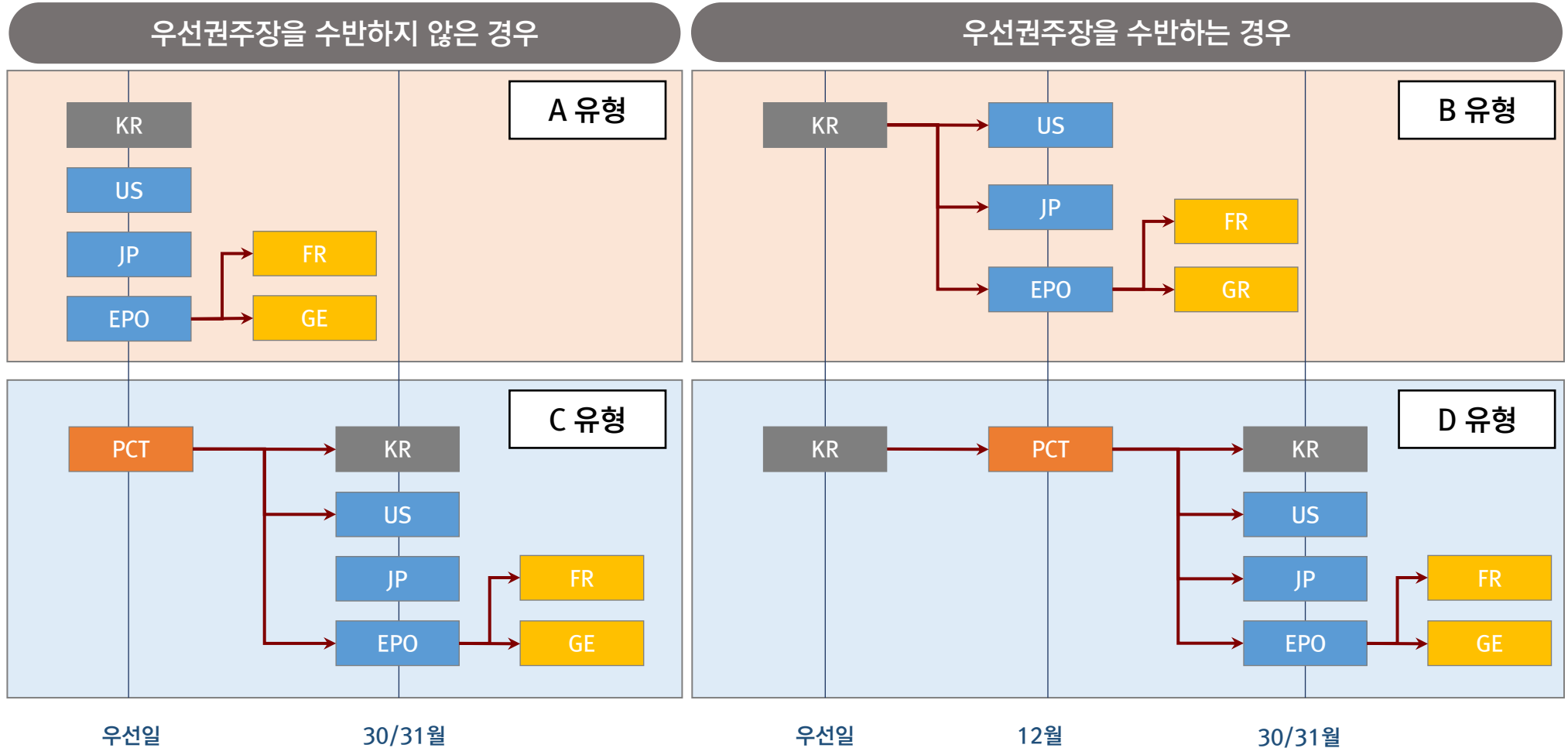




해외출원할 수 있는 4가지 방법 中 우선기간의 이익을 최대한 활용한 D 유형이 가장 많이 이용되고 있으며, 그 다음 순으로는 B 유형→ C 유형→ A 유형이 활용되고 있다.

일반
해외
출원

PCT
출원



항목		PCT 해외 출원	일반 해외 출원
출원단계	출원	하나의 방식으로 PCT 출원을 하면 세계 여러 국가에 출원 되는 효과 발생	각 국가의 국내법에서 정하는 방식 및 언어로 각 국가에 개별 출원
	우선기간이용	우선일로부터 1년 이내 PCT 출원	우선일로부터 1년 이내 각 국가에 모두 출원
국제단계	국내단계진입 기간확보	국내단계진입기간(30/31개월)의 확보로 무분별한 해외출원 방지: 사업화 및 시장국가 예측이 곤란한 경우 최종적인 결정의 연기 가능	-
	비용	국제단계 + 국내단계	국내단계
	소요비용분산	국내단계 진입 시기를 달리하여 소요되는 비용의 분산	소요비용의 분산이 되지 않음
	보고서 활용	- 국제단계에서 국제조사보고서, 국제예비심사보고서를 활용하여 국내단계진입여부 결정가능 - 등록 가능성이 없는 경우 국내단계진입을 포기하여 불필요한 비용의 절감가능	국내 단계 진입 전에 특허성과 관련하여 참고할 수 있는 공적 보고서 없음
	보정	국제단계에서 PCT 제19조 보정, PCT 제34조 보정을 통해 등록 가능성 향상 가능	-
국내단계	조기권리화	국내단계절차진행이 지연되어 등록까지 오랜 시간 소요	-
기타	PCT 가입	-	대만 등과 같이 PCT 가입국이 아닌 경우 일반 해외출원만 가능

기술의 사업방향, 경쟁사 동향 (출원건수, 등록건수 등), 개별사정(계약, 예산 등), 당해 국가의 기초 자료(인구, GNP, 기술력 등) 등을 고려하여 특허활용가능성이 있는 국가를 선택하며, 핵심적인 선택기준은 시장이 있거나 생산 가능성이 있는 국가인지 여부이다.

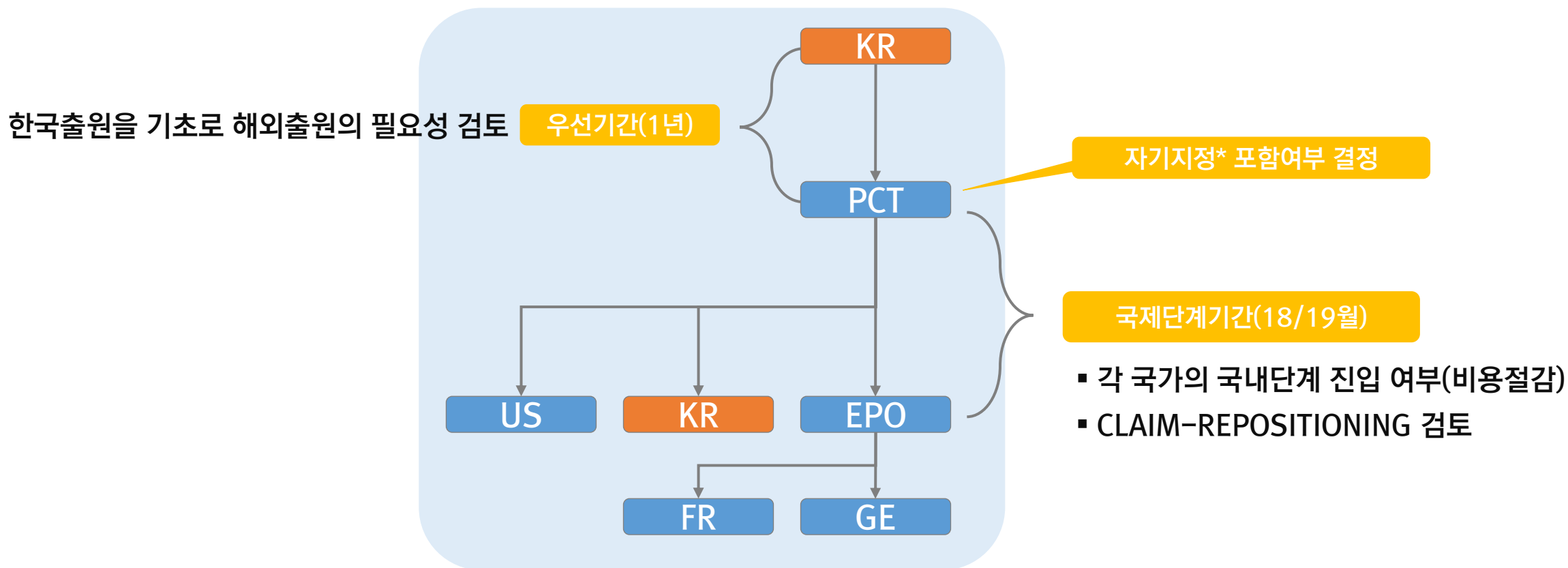
해외출원국가의 선택시 고려사항

1. 해당 국가에서 예측되는 수익이 권리화 소요 비용을 상회하는가?
2. 수익성 있는 Licensing이 가능한가?
3. 국가 특허로 또는 지역 특허로 할 것 인가?
4. 발명의 economic lifecycle이 권리화 소요 기간에 비하여 충분히 긴가?
5. 해당 국가에서 해당 발명의 보호 및 권리 행사가 가능한가?
6. 특허권자가 특허권 행사할 의사가 있는가?
7. 경쟁기업과 관련된 사항 - Where do competitors manufacture and sell? - Is the competition global or local? - How difficult or simple would it be to detect infringement?
8. 권리화로 인해 가격 인상 가능한가?
9. 권리화로 인해 틈새 시장 공격 가능한가?

핵심적인 선택기준

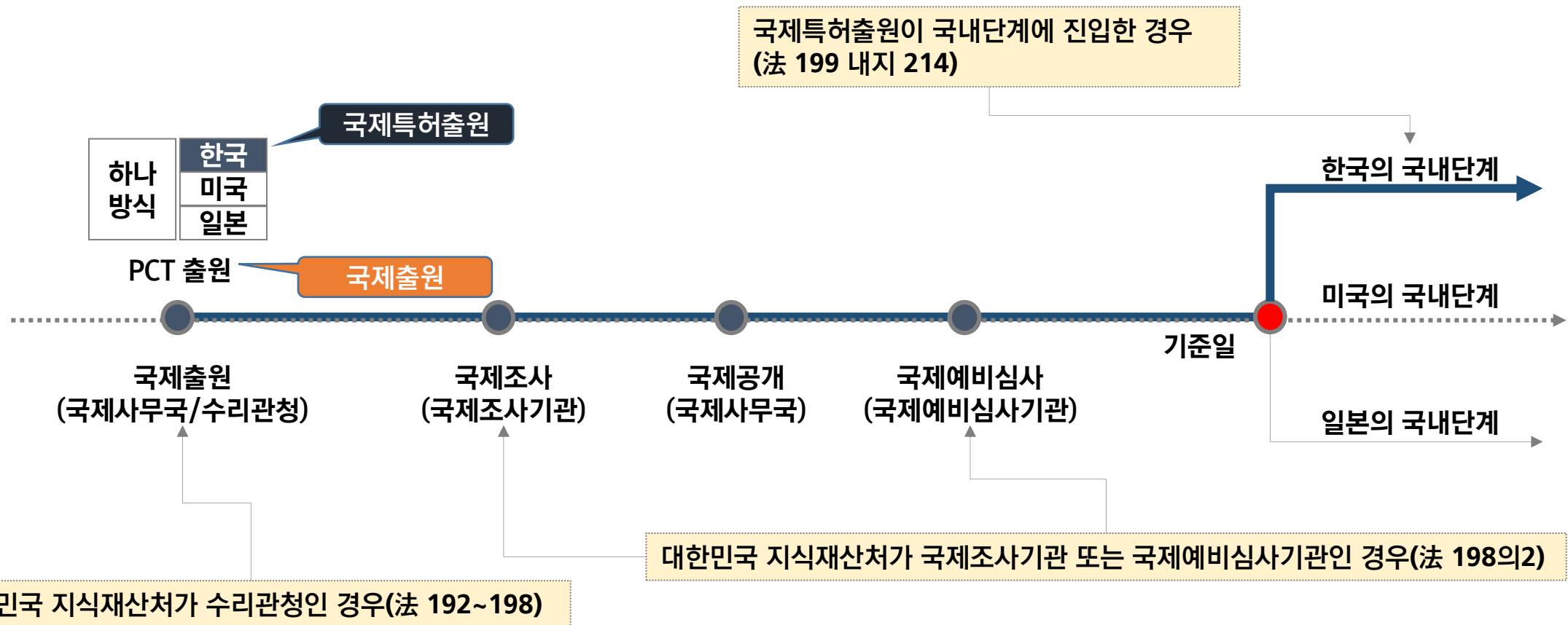
구분	출원 목적/효과
자사 현재 시장 국가	자사 사업의 유지 확대
타사 현재 시장 국가	타사 사업 견제 및 로열티 수입 획득
자사/타사 잠재 시장 국가	신규 시장 개척
자사 생산(예정) 국가	- 자사 사업의 보호 - 자회사로부터의 기술료 회수 - 타사 생산 진입의 견제
타사 생산(예정) 국가	- 타사 생산의 금지/저지 - 기술 로열티 획득

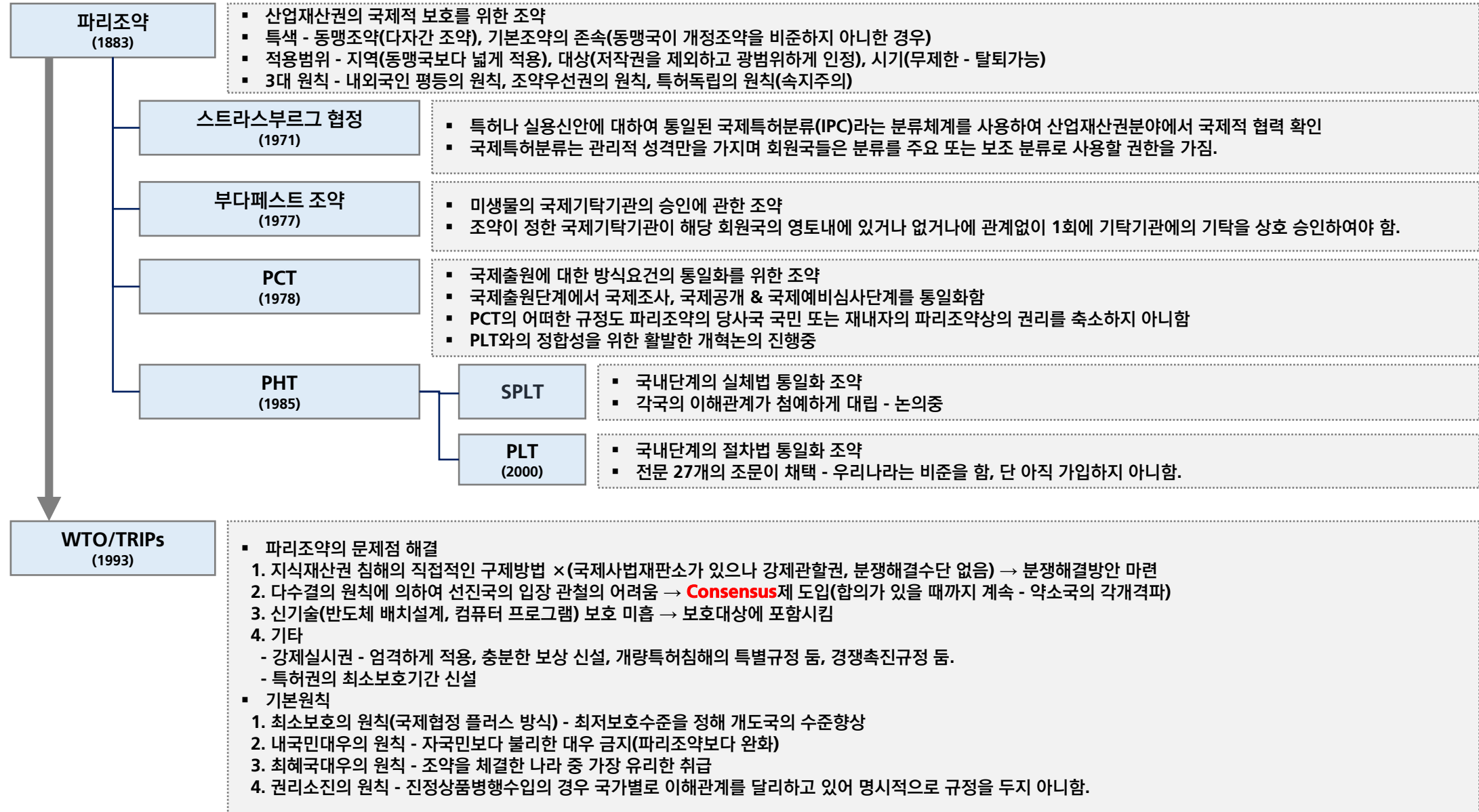
PCT 출원시 자기지정제도와 국제단계의 기간이익을 적극 활용하면, 시장의 변화에 대응할 수 있다. 국제단계기간 동안 해외시장의 상황을 모니터링 하면서 각 국가별 국내단계 진입을 결정하되, 각 국가별 권리범위 재설계의 필요성을 검토한다.

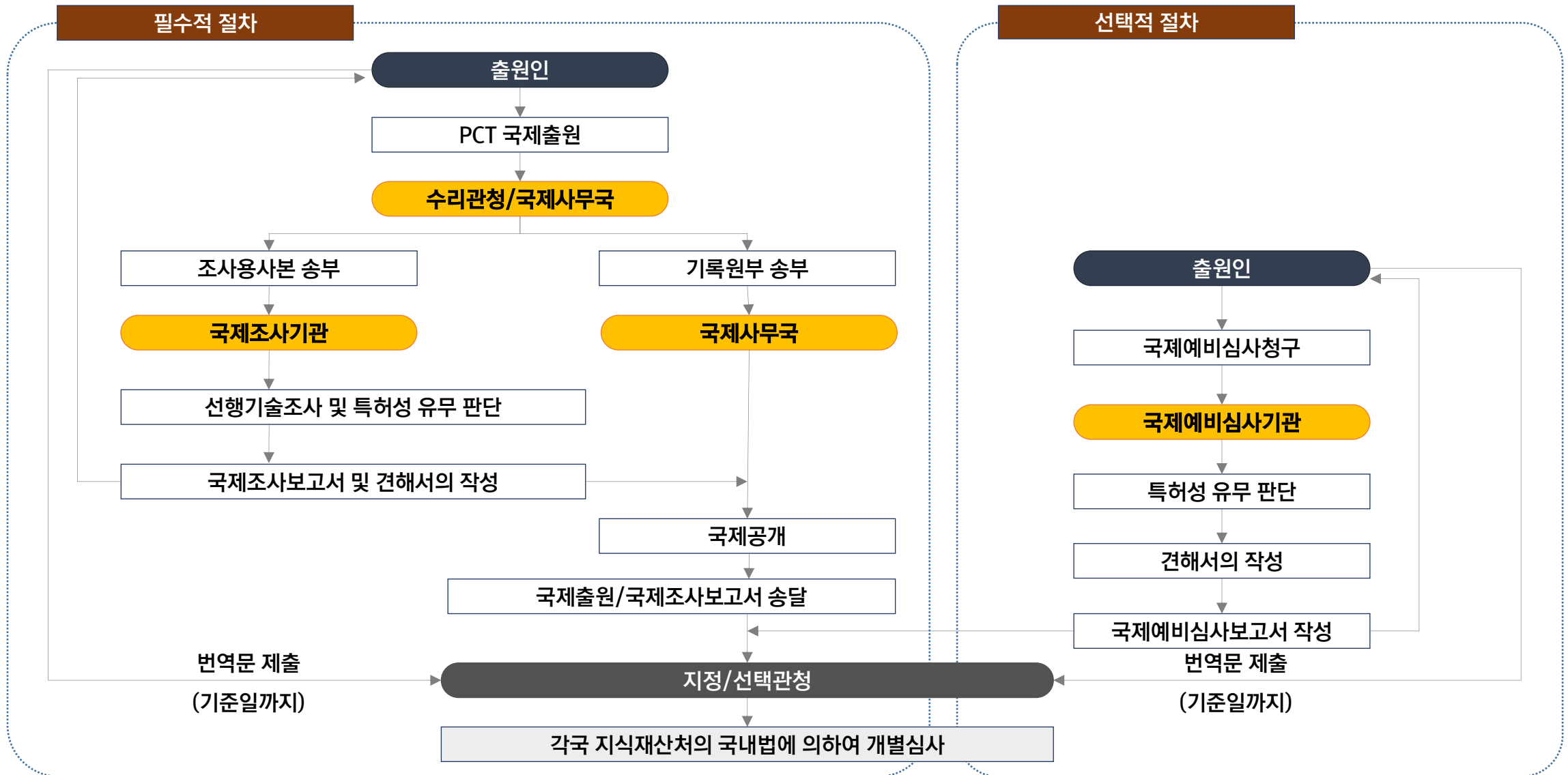


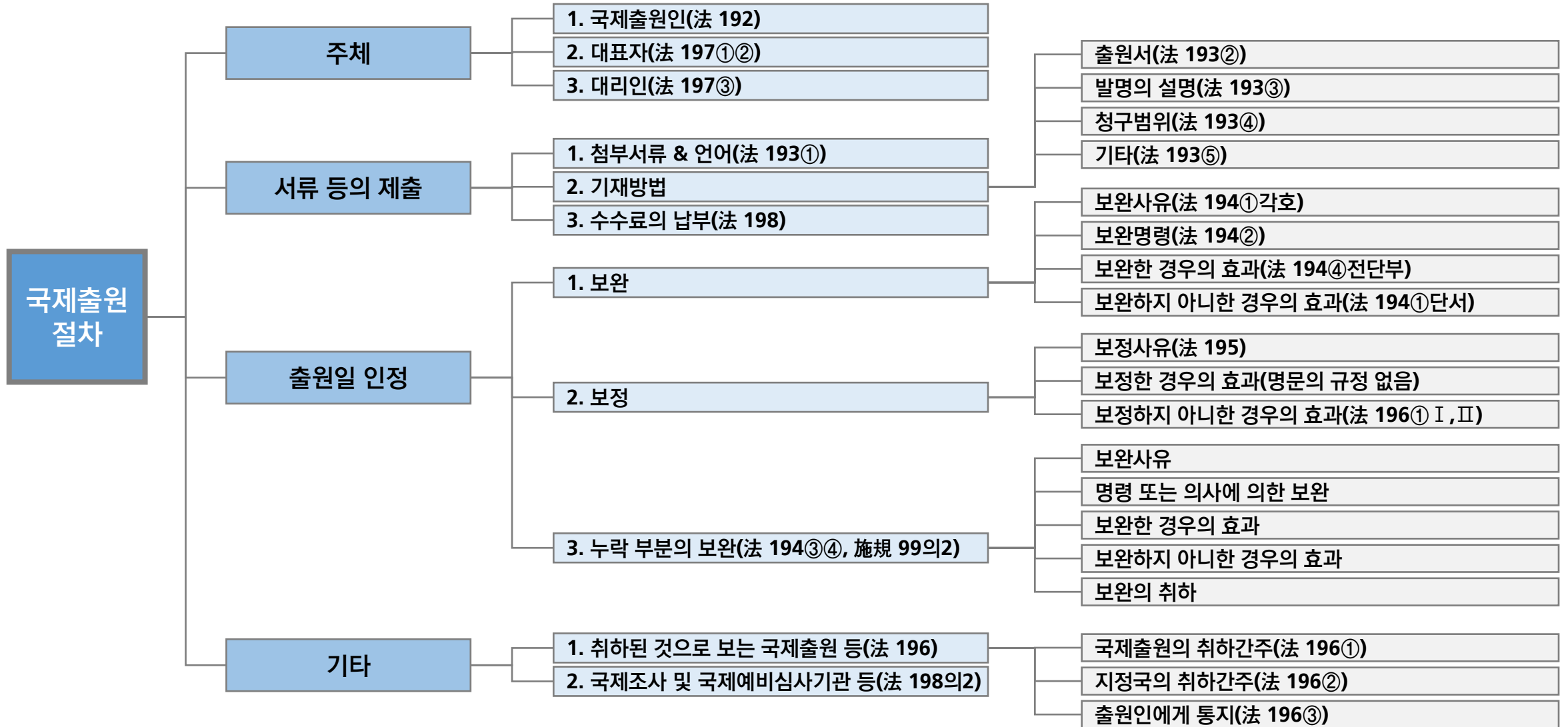
* 자기지정: KR의 선출원을 기초로 우선권주장을 수반한 PCT 출원을 하면서 KR을 지정국에 포함시키는 것을 말함

우리나라 특허법상 특허협력조약에 의한 국제출원은 i) 국제출원절차(法 192 내지 198의2)와 ii) 국제특허출원에 관한 특례(法 199 내지 214)로 구분되어 있다. 여기서 국제출원절차(法 192 내지 198)는 어느 나라를 지정국으로 했는지 여부와 관계없이 우리나라를 수리관청으로 하여 국제출원할 때 적용되는 규정이고, 국제특허출원에 관한 특례(法 199 내지 214)는 어느 나라를 수리관청으로 했는지 여부와 관계없이 우리나라를 지정국으로 한 국제출원(이를 “국제특허출원”이라 한다)이 국내단계로 진입시 적용되는 규정이다. 한편, 제198조의2는 우리나라가 국제조사 및 국제예비심사기관인 경우에 적용되는 규정이다.

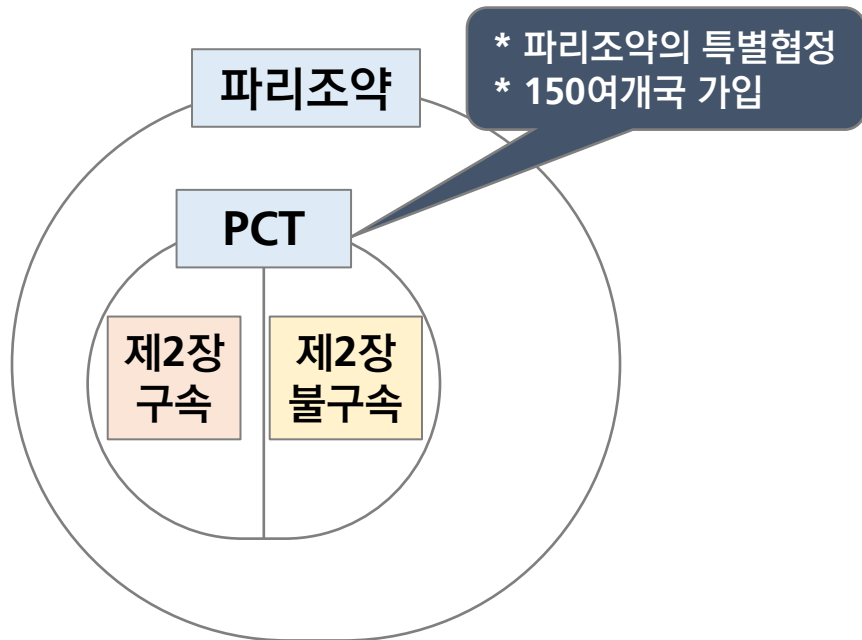








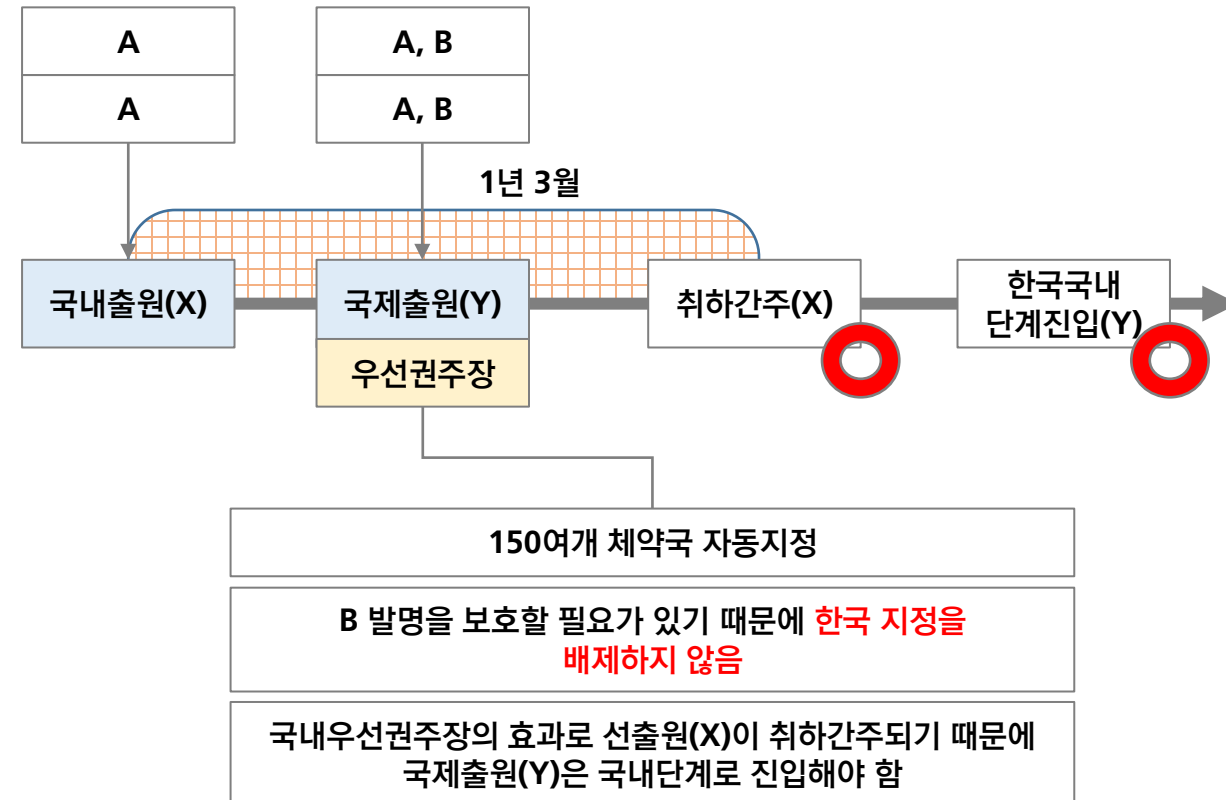
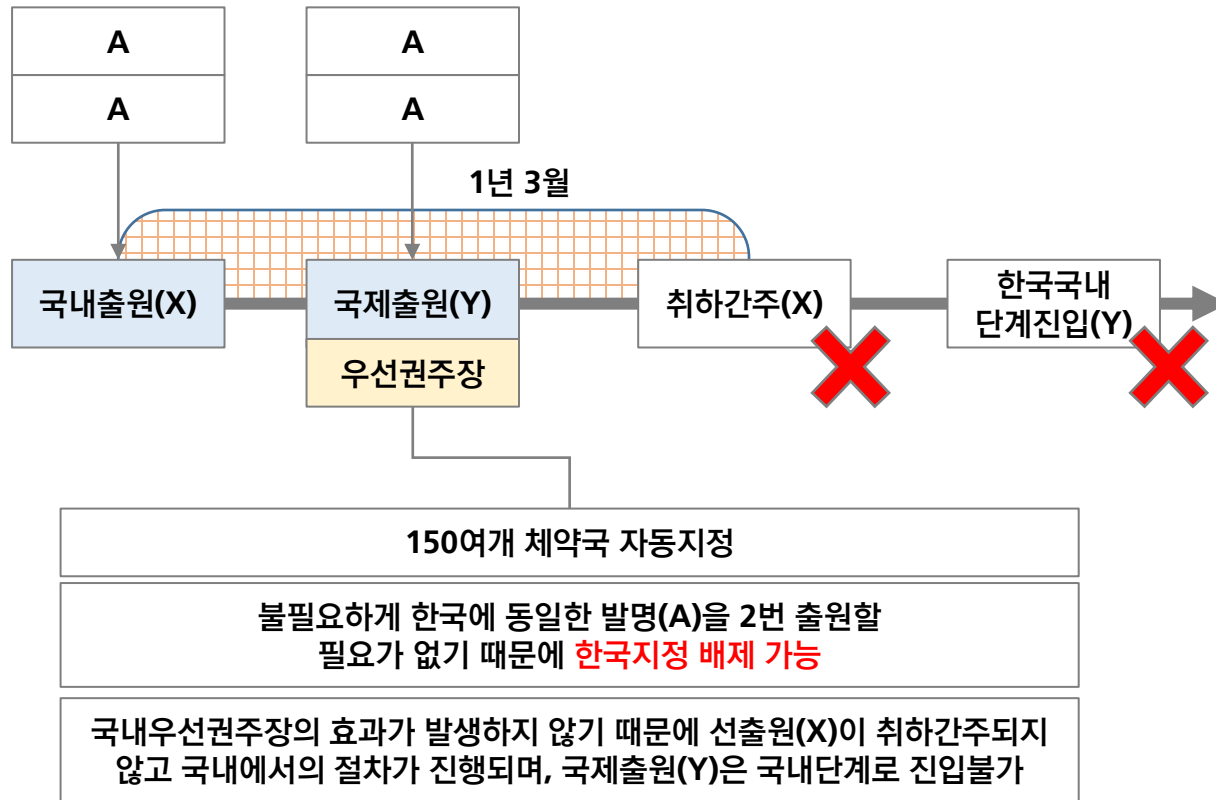
총회는 PCT의 당사국은 아니나 파리조약의 당사국인 어느 국가의 거주자와 국민이 국제출원을 하는 것을 인정하도록 결정할 수 있다(PCT 9(2)). 한편, 총회는 국제출원을 할 자격을 가지는 자에 대하여 동인(同人)이 본 조약의 비당사국 또는 PCT 제2장의 규정(국제예비심사)에 구속되지 아니한 당사국의 거주자나 국민인 경우에 있어서도 국제예비심사의 청구를 허용하도록 결정할 수 있다(PCT 31, PCT 규칙 54.2).



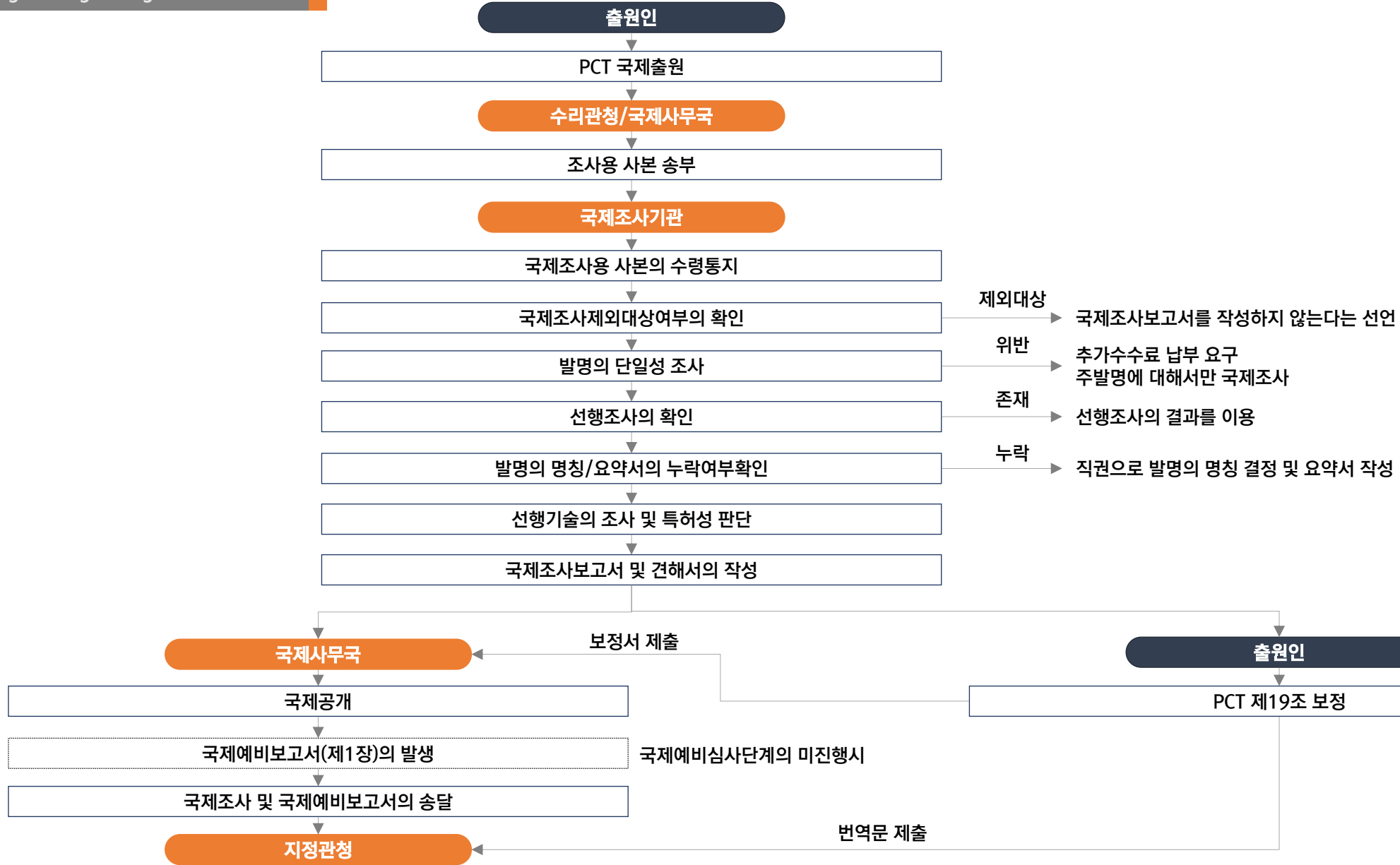
구분		국제출원할 수 있는 자	국제예비심사청구할 수 있는 자
파리조약 당사국		총회의 결정 (국민/재내자)	총회의 결정 (국민/재내자)
PCT 당사국	제2장 구속	- 국민 - 재내자 - 둘 중 한 명 이상을 대표자로 하는 자 - 둘 중 한 명 이상과 공동출원하는 자	좌동
	제2장 불구속		총회의 결정 (국민/재내자)

국제출원의 출원서 등이 제출된 경우에는 다음의 사항이 행하여진 것으로 본다(施規 93의2).

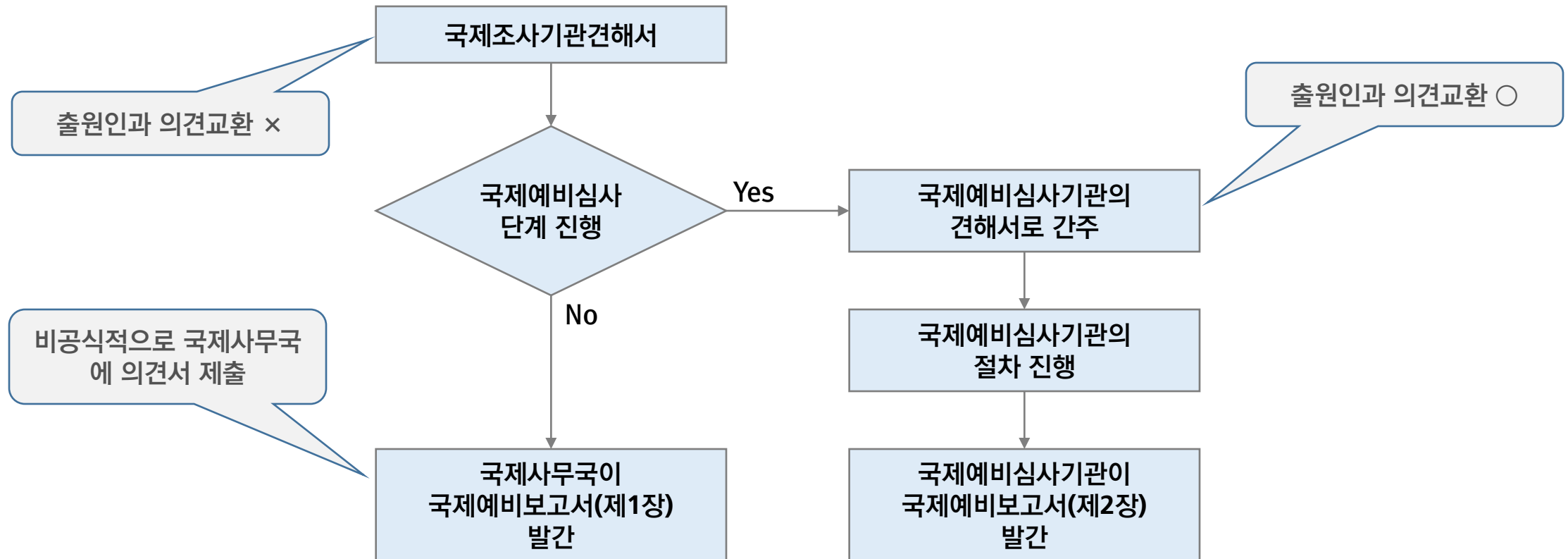
- i) 조약 제11조에 따른 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 계약국의 지정(이를 자동지정제도로 한다.) 다만, 조약규칙 4.9(b)에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 자 국내 선출원에 대하여 취하되는 효과를 규정하고 있는 계약국에 대해서는 국제출원의 출원인은 해당 계약국의 지정을 제외할 수 있다.
- ii) 지정국 중 조약 제43조 또는 제44조가 적용되는 각 지정국에서 얻을 수 있는 모든 종류의 권리를 위한 것이라는 표시
- iii) 조약 제45조(1)이 적용되는 각 지역구의 지역특허[조약 제2조(iv)에 따른 특허를 말한다] 및 국내특허[조약 제45조(2)가 적용되는 경우를 제외한다]를 위한 것이라는 표시

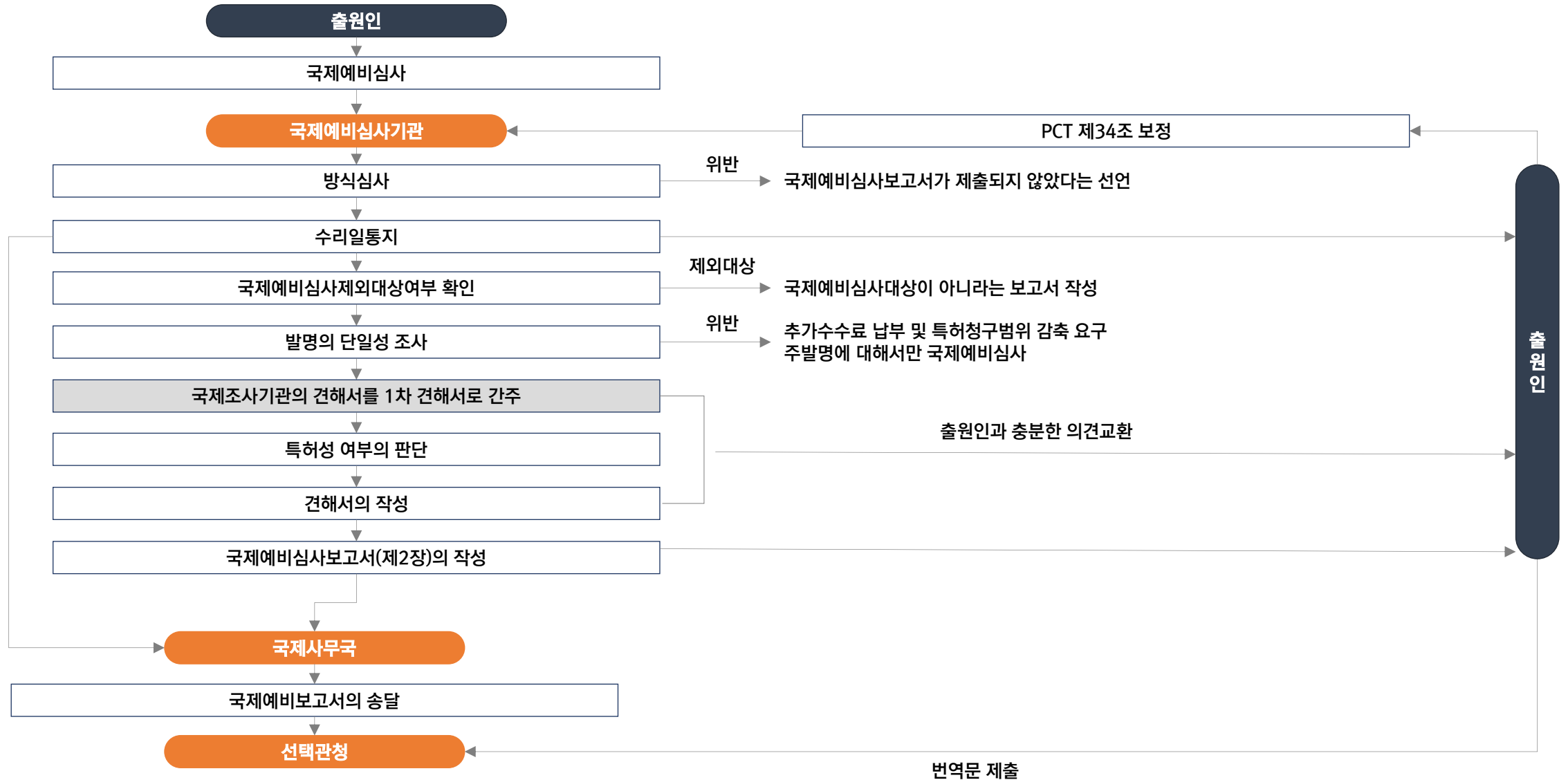


구분		보완	보정	누락된 부분 등의 보완
사유		1.국제출원서에 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우 2.출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우 3.대한민국에 국제출원할 수 있는 자격(法 192)을 갖추지 아니한 자가 출원한 경우 4.국제출원서에 특허협력조약에 따른 국제출원이라는 표시가 되어 있지 아니한 경우 5.국제출원이 총리령으로 정하는 언어(국어, 영어 또는 일어)로 작성되지 아니한 경우 6.해당 출원된 발명의 보호가 필요한 특허협력조약 체결국의 지정을 하지 아니한 경우	1.발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우 2.요약서가 제출되지 아니한 경우 3.행위제한능력자가 법정대리인에 의하지 않고 절차를 밟거나 선임된 임의대리인이 변리사가 아닌 경우 4.총리령으로 정하는 방식에 위반된 경우 5.국제출원을 한 자가 수수료를 해당 기간에 내지 아니한 경우	1.발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우는 제외한다)되어 있거나 잘못 제출된 경우 2.도면의 전부 또는 일부가 누락되어 있거나 잘못 제출된 경우
절차	의사	-	국제출원 계속 중	국제출원의 접수일로부터 2개월 이내 보완(施規 99의2②③)
	명령	지식재산처장은 기간을 정하여 보완명령(法 194②)	지식재산처장은 기간을 정하여 보정명령(法 195)	지식재산처장은 통지일로부터 2개월 이내 보완명령(施規 99의2③④)
효과	적법	보완서 도달일을 국제출원일로 인정(法 194④전단부)	보정된 내용대로 출원한 것으로 간주	1.접수일(도달일)을 국제출원일로 인정(단, 국제출원일 통지일로부터 1개월 이내 보완 취하지 국제출원일 정정 없었던 것으로 간주)(施規 99의2⑥본문) 2.제194조제4항에 따라 국제출원일로 인정되는 날보다 앞서는 경우는 그러하지 아니함(施規 99의2⑥단서)
	부적법	국제출원일 불인정(法 194①단서)	국제출원의 취하간주(法 196① I II)	1.국제출원절차 진행하고 나중에 기재불비 등의 거절이유가 발생할 가능성 존재 2.도면에 관하여 기재하고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니함에도 불구하고, 출원인이 기간에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 간주(法 194④)



국제예비심사보고서가 작성되지 않았거나 예정이 없는 경우 국제사무국은 국제조사기관의 견해서와 동일한 내용의 보고서를 국제조사기관을 대신하여 발행하여야 한다. 그 보고서에는 국제조사기관을 대신하여 국제사무국이 발행한다는 표시와 함께 「특허성에 관한 국제예비보고서(특허협력조약 제1장)」라는 명칭을 붙여야 한다. 그 후 국제사무국은 출원인과 지정관청에 국제예비보고서를 송달하여야 한다(PCT 규칙 44의2.2). 한편, 이에 대한 특별한 규정은 없으나 **국제출원인은 국제조사기관이 작성한 견해서에 대해서 비공식적으로 의견서를 국제사무국에 제출할 수 있도록 하여 출원인이 국제예비심사를 청구하지 아니한 경우 국제조사기관이 작성한 견해서에 대하여 출원인에게 반박할 기회를 부여하고 있다.** 이는 국제예비심사를 청구하지 아니한 경우 국제조사기관의 견해서의 내용이 국제사무국에 의하여 「국제예비보고서(특허협력조약 제1장)」로 발간되어 출원인에게 불이익을 줄 수 있기 때문이다.

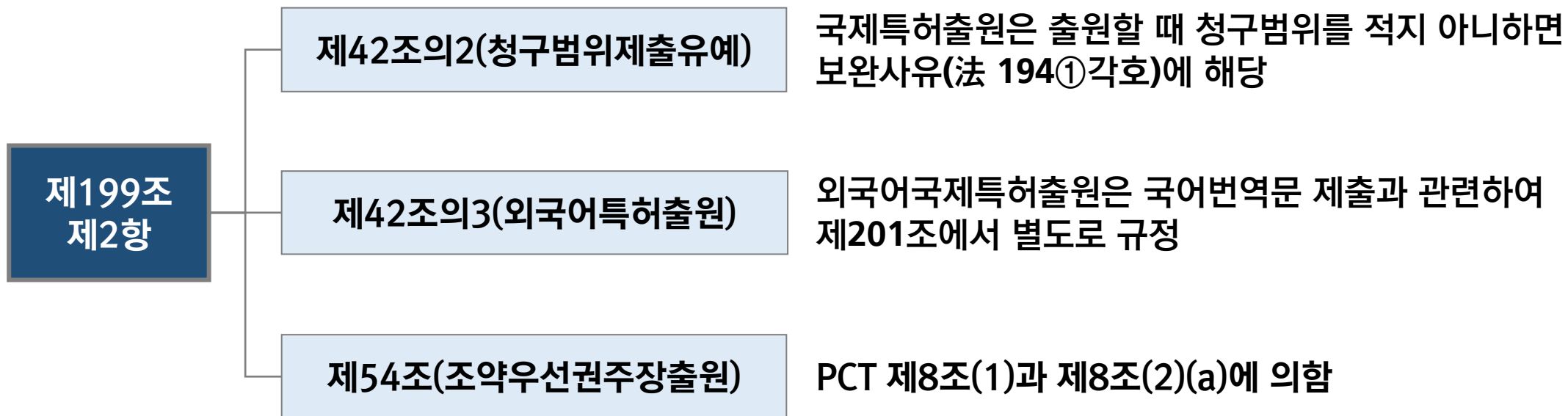




구 분	국제조사	국제예비심사
목 적	- 국제조사기관이 국제출원과 관련된 선행기술의 존재여부의 발견 - 국제조사기관이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 인정여부에 대하여 예비적이고 구속력이 없는 견해를 표시	국제예비심사기관이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 인정여부에 대하여 예비적이며 구속력이 없는 견해를 표시
대 상	모든 국제출원이 국제조사의 대상	국제조사와는 달리 출원인의 선택에 의한 임의적 절차로 국제출원의 청구범위에 기재되어 있는 발명
범 위	발명의 설명, 도면에 타당한 고려를 하여 청구범위를 기초	청구범위와 발명의 설명, 도면을 기초
이용할 수 있는 자	국제출원을 할 수 있는 자	PCT 제2장 규정에 구속된 체약국의 거주자 또는 국민으로서 그러한 체약국을 위해 행동하는 수리관청에 출원한 경우
지정/선택	출원서 제출로 출원일의 모든 체약국의 지정을 구성	청구서 제출로 조약 제2장에 구속되는 모든 지정국의 선택을 구성
의견교환	불리한 보고서 작성 전에 예고받을 권리가 없으며 원칙적으로 국제조사기관과 출원인간의 의견교환 불허용	불리한 보고서 작성 전에 예고받을 권리(견해서 송부)있으며 국제예비심사기관과 출원인간의 구두 또는 서면에 의한 의견교환 허용
보정의 범위	- 국제조사 보고서를 송달받은 후 국제사무국에 대하여 1회에 한해 청구범위에 대하여 보정(PCT 19) - 동시에 설명서 제출 가능	국제예비심사 보고서가 작성 전까지 국제예비심사기관에 대하여 청구범위, 발명의 설명 및 도면에 대하여 횟수의 제한없이 보정(PCT 34)
발명의 단일성	- 추가수수료의 납부를 요구 - 주발명에 관계되는 국제출원 부분과 추가수수료가 소정의 기간에 지불된 발명에 관계되는 국제출원 부분에 관하여 국제조사보고서를 작성	- 출원인에게 그의 선택에 따라 요건을 충족하도록 청구범위를 제한하거나 추가수수료를 낼 것을 요구 - 주발명에 관계되는 국제출원 부분과 추가수수료가 소정의 기간에 지불된 발명에 관계되는 국제출원 부분에 관하여 국제예비심사보고서를 작성
공개여부	국제조사보고서와 견해서는 국제출원의 공개시에 전자적 형태로 공개	국제예비심사보고서는 비공개(선택관청은 제외)
종료형식	국제조사보고서의 작성 또는 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 선언 / 견해서의 작성	국제예비심사보고서의 작성

제199조(국제출원에 의한 특허출원) ① 「특허협력조약」에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다.

② 제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(이하 "국제특허출원"이라 한다)에 관하여는 제42조의2, 제42조의3 및 제54조를 적용하지 아니한다.



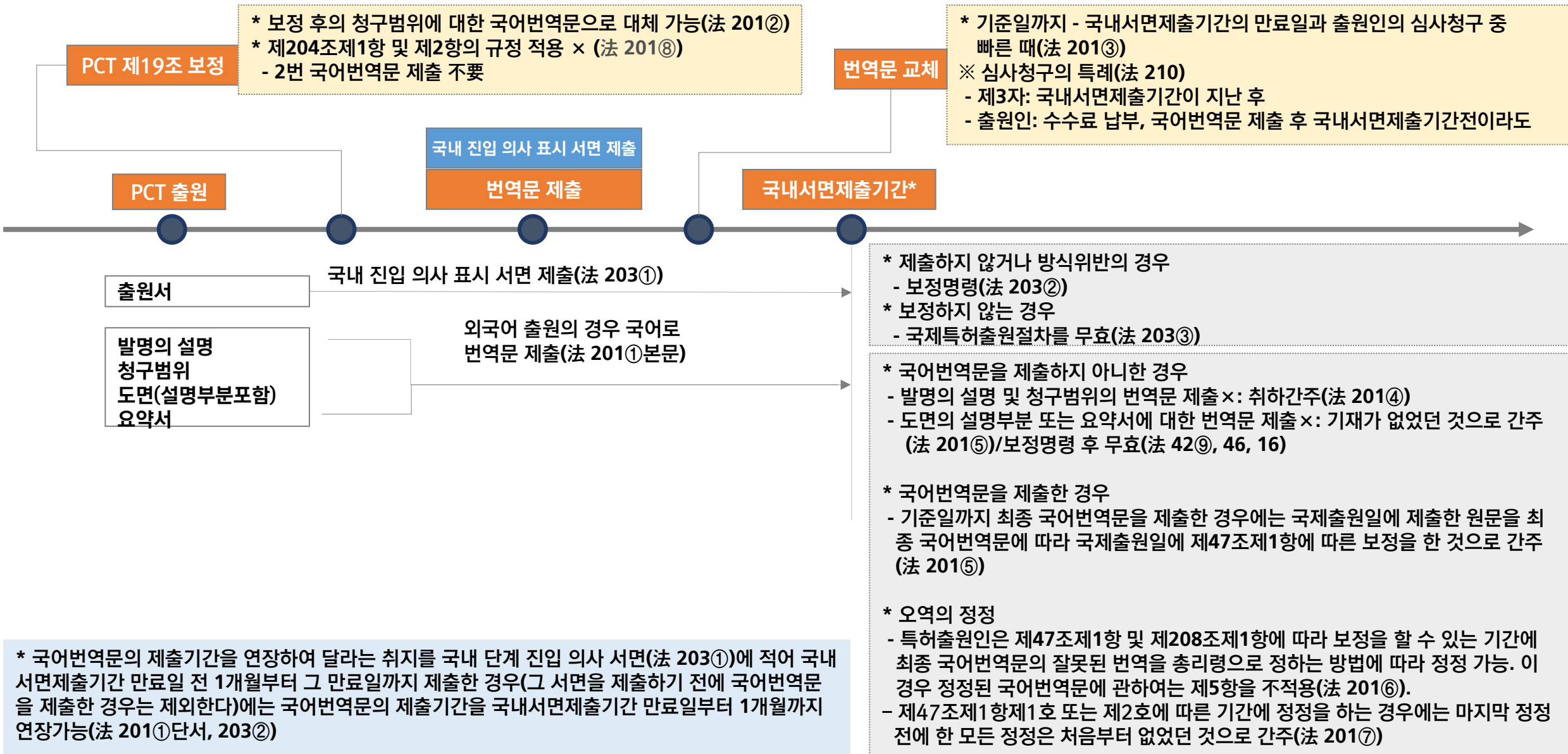
- 제200조의2(국제특허출원의 출원서 등)** ① 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조제1항에 따라 제출된 특허출원서로 본다.
- ② 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면으로 본다.
- ③ 국제특허출원에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 요약서 또는 국어번역문을 제42조제2항에 따른 요약서로 본다.
1. 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우: 국제특허출원의 요약서
 2. 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우: 제201조제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문(제201조제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 말한다)

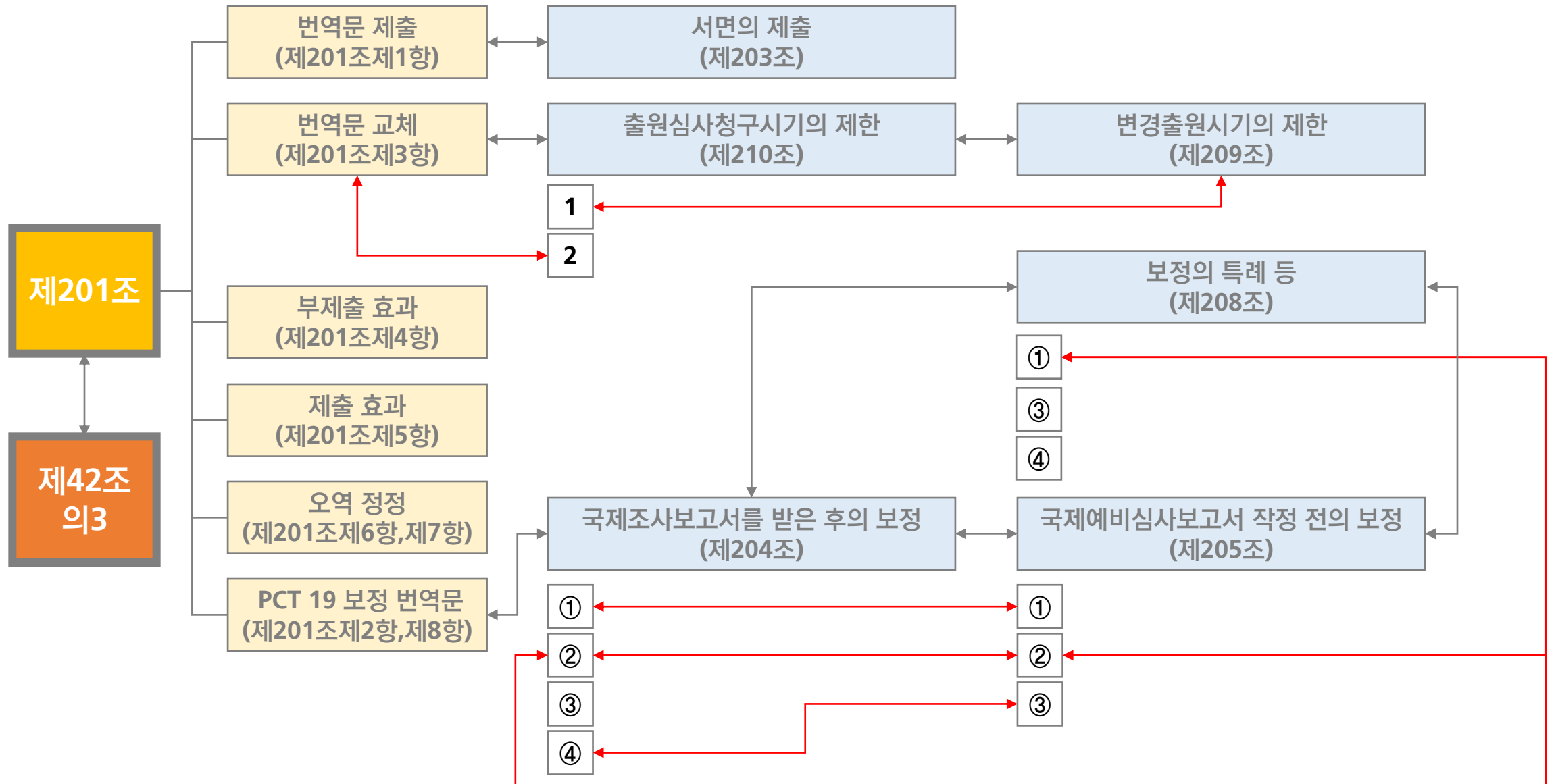


제201조(국제특허출원의 국어번역문) ① 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7개월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 다음 각 호의 국어번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다.

1. 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문
 2. 국제특허출원의 요약서의 국어번역문
- ② 제1항에도 불구하고 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항에 따른 출원인이 국내서면제출기간에 제1항에 따른 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다.
- ⑤ 특허출원인이 국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 "기준일"이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 "최종 국어번역문"이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다.
- ⑥ 특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.
- ⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ⑧ 제2항에 따라 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.







제203조(서면의 제출) ① 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간에 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항에 따른 국어번역문을 함께 제출하여야 한다.

1. 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 발명의 명칭
4. 발명자의 성명 및 주소
5. 국제출원일 및 국제출원번호

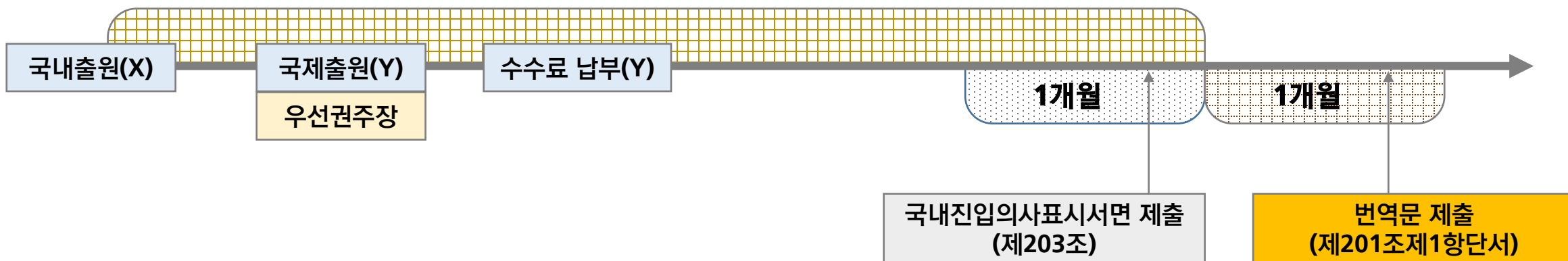
② 제1항 후단에도 불구하고 제201조제1항 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 제1항 전단에 따른 서면을 제출하는 경우에는 국어번역문을 함께 제출하지 아니할 수 있다.

③ 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

1. 제1항 전단에 따른 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우
2. 제1항 전단에 따라 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반되는 경우

④ 제3항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 지식재산처장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다.

31개월(국내서면제출기간의 만료일)



번역문 교체시기

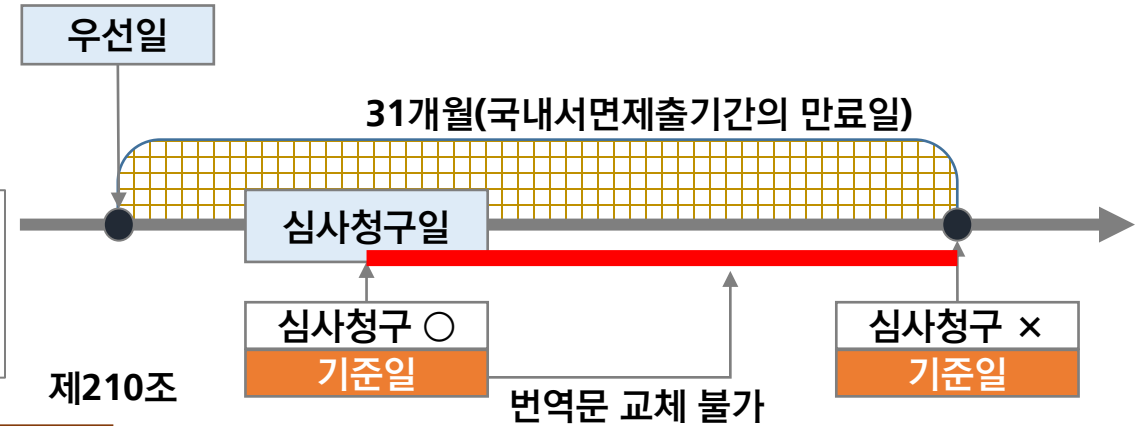
기준일까지 가능

1. 국제단계에서 국내단계로 진입시점
2. 국어번역문의 확정일(기준일이 지난 후에는 더 이상 번역문 교체 불가)
3. **국내서면제출기간**의 만료일과 **출원인의 심사청구** 중 빠른 때

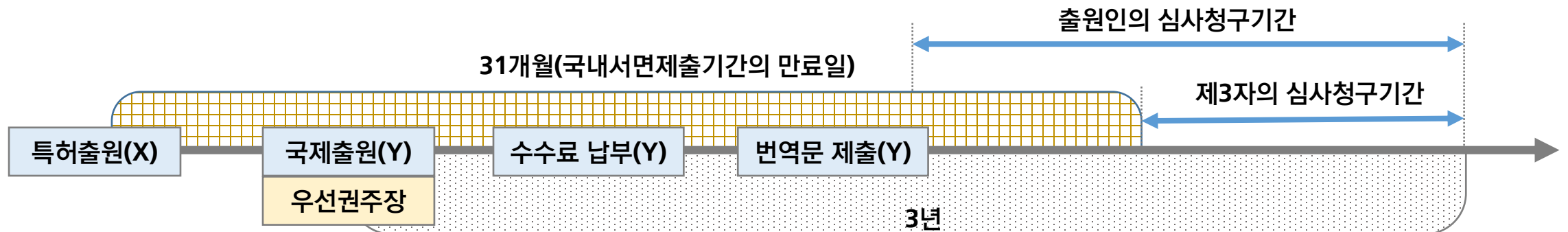
1. 번역문 제출기간
2. **우선일**로부터 2년 7월

1. 국제출원이 우선권주장을 수반하는 경우 - 우선권주장의 최우선일
2. 국제출원이 우선권주장을 수반하지 아니한 경우 - 국제출원일

* 일반적으로 조약/국내우선권주장의 판단시점이 소급하는 경우 PCT 출원은 우선일 기준, 그렇지 아니한 경우 국제출원일 기준으로 함

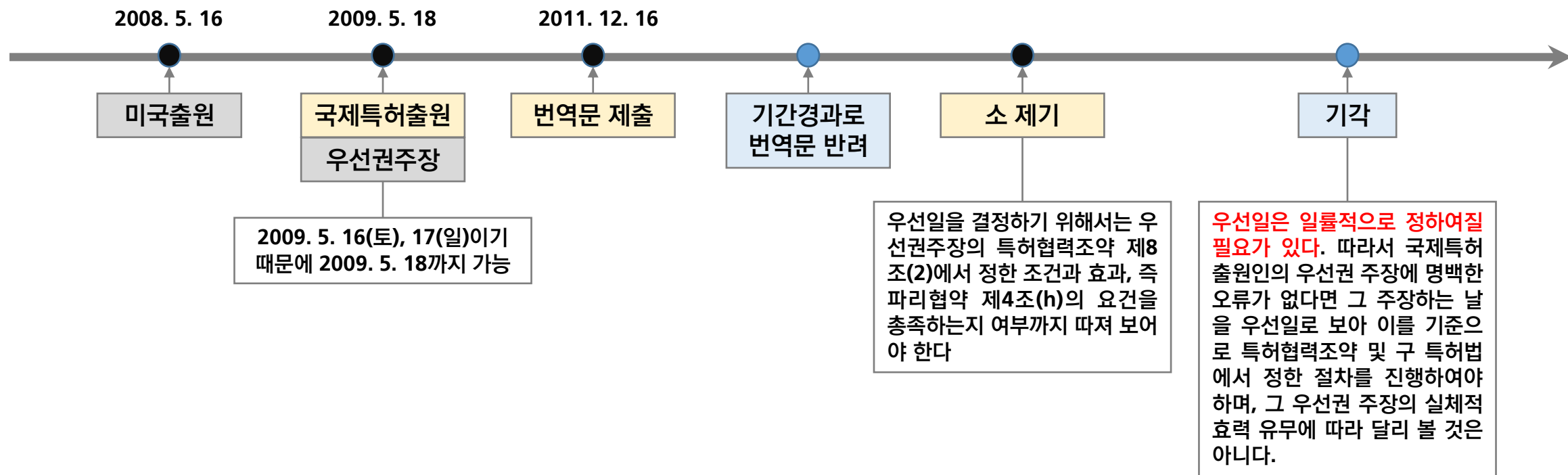


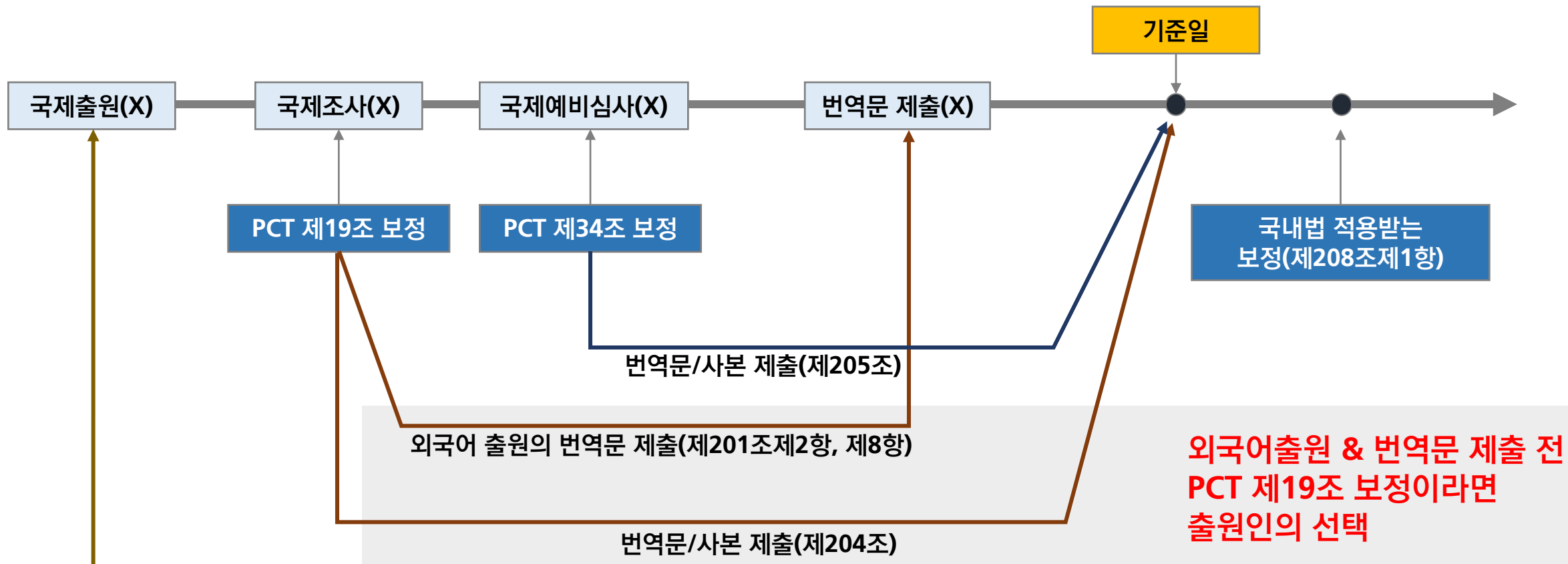
1. 출원인 - 수수료 납부와 번역문을 제출한 경우에만 심사청구가 가능 (최소한 심사를 받기 위한 요건): 변경출원시기의 제한(제209조)도 동일
2. 제3자 - 국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다)이 지난 후 국제출원일로부터 3년 이내 심사청구가 가능



대법원 2017. 4. 28. 선고 2014두42490 판결 【반려처분 취소청구】

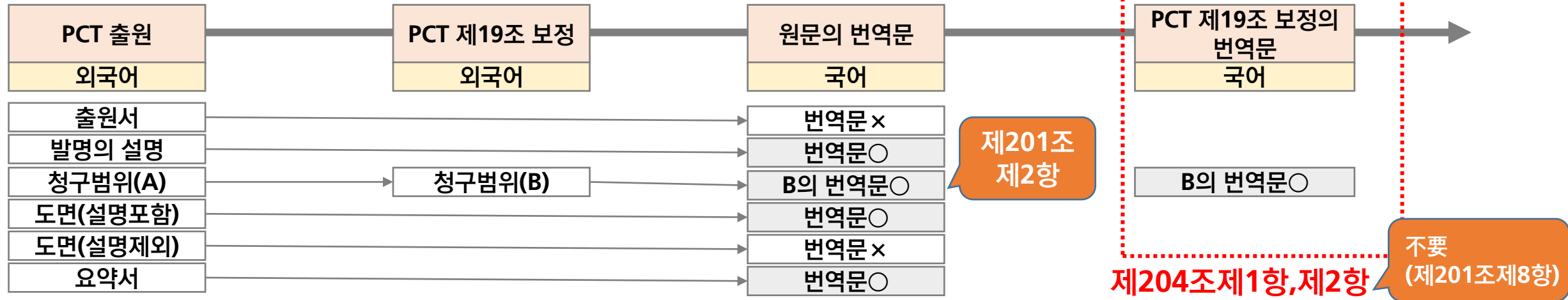
특허법과 특허협력조약의 규정들에 의하면, 출원인이 국제특허출원을 하면서 파리협약의 당사국에서 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하였다면 구 특허법 제201조 제1항 본문의 우선일은 국제특허출원의 제출일이 아니라 우선권을 주장한 선출원의 제출일이 된다. 그리고 **우선일은 특허협력조약과 그 규칙에서 국제특허출원의 국제공개, 국제조사, 국제예비심사 청구 등 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준으로 되어 있고, 구 특허법에서도 명세서 및 청구의 범위 등에 관한 번역문의 제출기한의 기준일로 되어 있는 등, 출원 관계 기관의 업무와 관련자들의 이해관계에 중대한 영향을 미치게 되므로, 우선일은 일률적으로 정하여질 필요가 있다.** 따라서 국제특허출원인의 우선권 주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 특허협력조약 및 구 특허법에서 정한 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권 주장의 실체적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아니다.



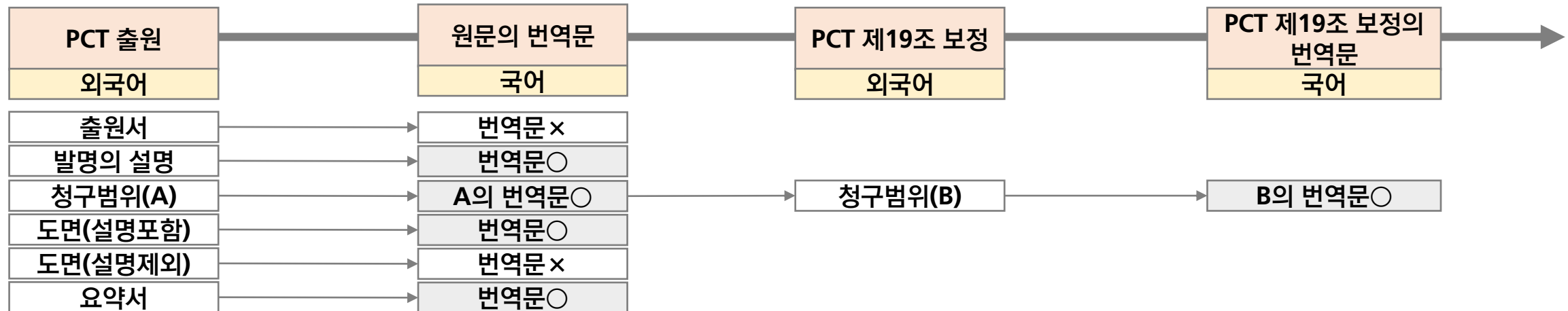


1. 보완(法 194①②④)
2. 보정(法 195, 196①)
3. 누락 부분의 보완(法 194③④, 施規 99의2)

원문에 대한 국어번역문 제출 전 PCT 19 보정



원문에 대한 국어번역문 제출 후 PCT 19 보정



국제조사보고서를 받은 후의 보정	국제예비심사보고서 작성 전의 보정
제204조(국제조사보고서를 받은 후의 보정) ① 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구범위에 관하여 보정을 한 경우 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다. 이하 이 조 및 제205조에서 같다) 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 보정서의 국어번역문 2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 보정서의 사본 ② 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다. ③ 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 설명서를 국제사무국에 제출한 경우 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 기준일까지 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 설명서의 국어번역문 2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 설명서의 사본 ④ 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항 또는 제3항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다.	제205조(국제예비심사보고서 작성 전의 보정) ① 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따라 국제특허출원의 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우 기준일까지 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 1. 외국어로 작성된 보정서인 경우: 그 보정서의 국어번역문 2. 국어로 작성된 보정서인 경우: 그 보정서의 사본 ② 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다. ③ 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따른 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다.

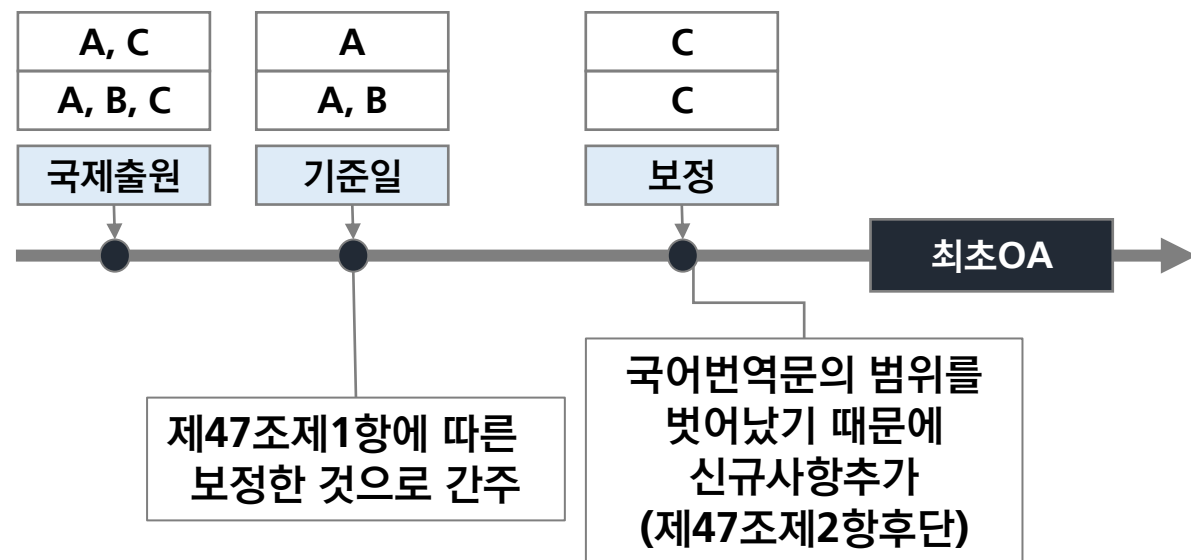
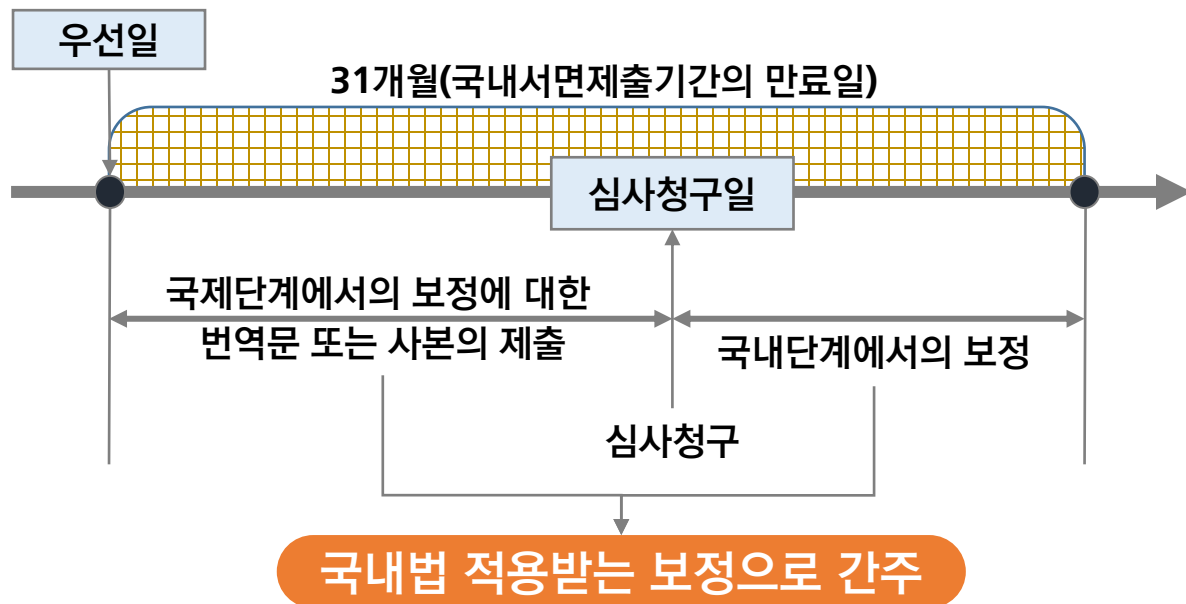
제208조(보정의 특례 등) ① 국제특허출원에 관하여는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추지 아니하면 제47조제1항에도 불구하고 보정(제204조제2항 및 제205조제2항에 따른 보정은 제외한다)을 할 수 없다.

1. 제82조제1항에 따른 수수료를 낼 것
2. 제201조제1항에 따른 국어번역문을 제출할 것. 다만, 국어로 출원된 국제특허출원인 경우는 그러하지 아니하다.
3. 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사를 청구한 때를 말한다)이 지날 것

② 삭제

③ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 전단을 적용할 때에는 "특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"으로 본다.

④ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 후단을 적용할 때에는 "외국어특허출원"은 "외국어로 출원된 국제특허출원"으로, "최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)"은 "제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)"으로 본다.



구분	외국어특허출원(法 42의3)	외국어국제특허출원(法 201)
제출	- 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 총리령으로 정하는 언어(영어)로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다(法 42의3①). - 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다(法 42의3②).	- 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 우선일부터 2년 7개월(이하 "국내서면 제출기간"이라 한다) 이내에 다음의 국어번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면 제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다(法 201①). i) 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정)의 국어번역문 ii) 국제특허출원의 요약서의 국어번역문 - 제1항에도 불구하고 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다(法 201②). 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다(法 201⑧).
교체	국어번역문을 제출한 특허출원인은 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다(法 42의3③). i) 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외)한 경우 ii) 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우	국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다(法 201③).

구분	외국어특허출원(法 42의3)	외국어국제특허출원(法 201)
부제출 효과	특허출원인이 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(法 42의3④).	출원인이 국내서면제출기간에 제1항에 따른 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다(法 201④).
제출 효과	특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 42의3⑤).	특허출원인이 국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 "기준일"이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 "최종 국어번역문"이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다(法 201⑤).
오역의 정정	특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다(法 42의3⑥). 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅰ) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ)에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 42의3⑦).	특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다(法 201⑥). 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅰ) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ)에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 201⑦).

다른 출원이 국제특허출원인 경우

제29조제5항, 제7항

Yim, Byung-Woong All Rights Reserved.

제29조(특허요건) ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 **출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면**에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

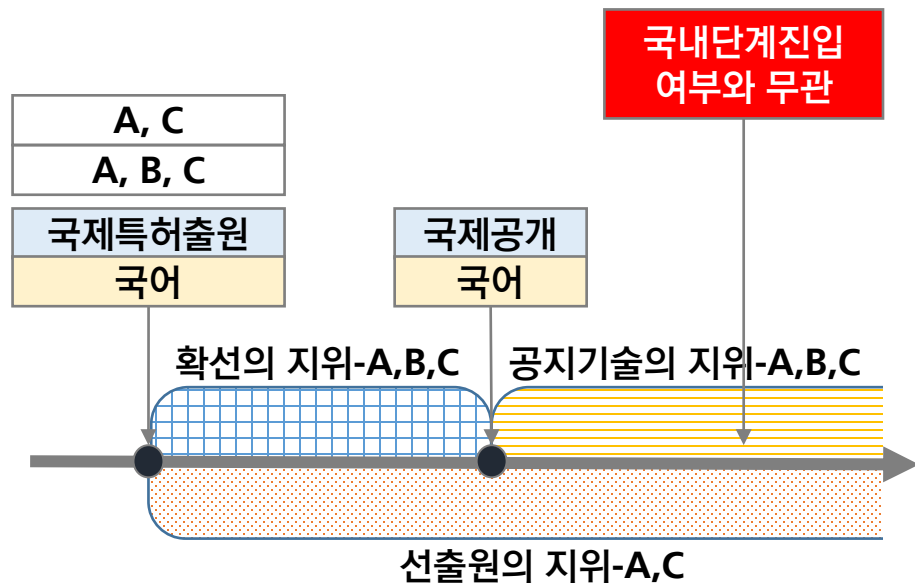
1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것

2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 **출원공개**되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것

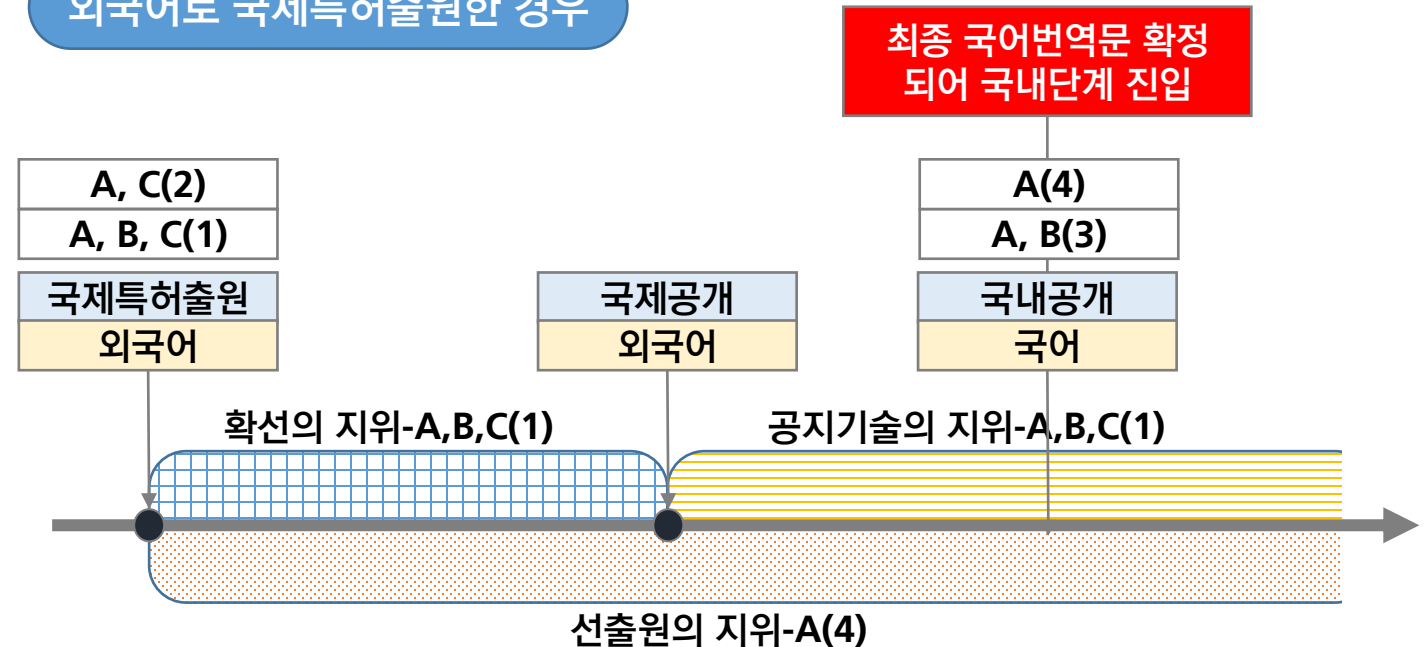
⑤ 제3항을 적용할 때 다른 **특허출원**이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 "**출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면**"은 "국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"으로, 같은 항 제2호 중 "**출원공개**"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개"로 본다.

⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.

국어로 국제특허출원한 경우



외국어로 국제특허출원한 경우



제200조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 특례) 국제특허출원된 발명에 관하여 제30조제1항제1호를 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 같은 조 제2항에도 불구하고 총리령으로 정하는 기간에 지식재산처장에게 제출할 수 있다.

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

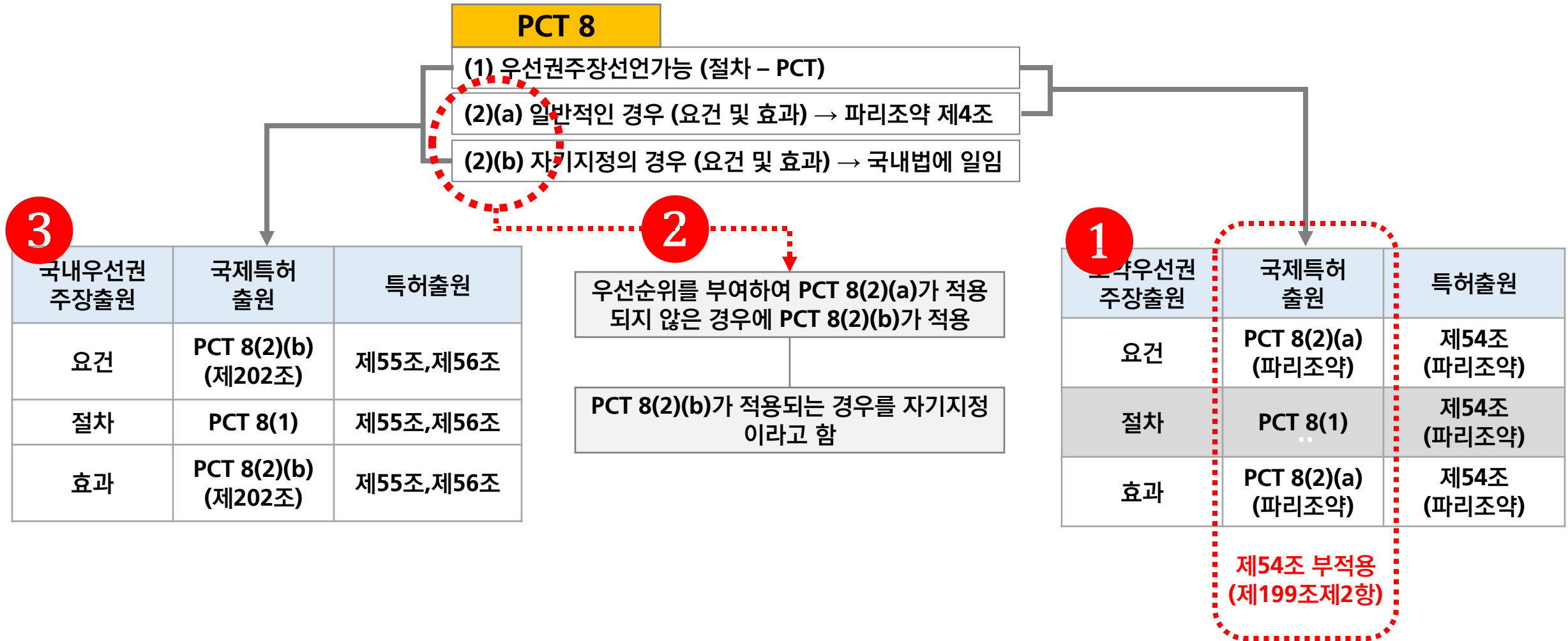
② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 총리령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 총리령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다

1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간

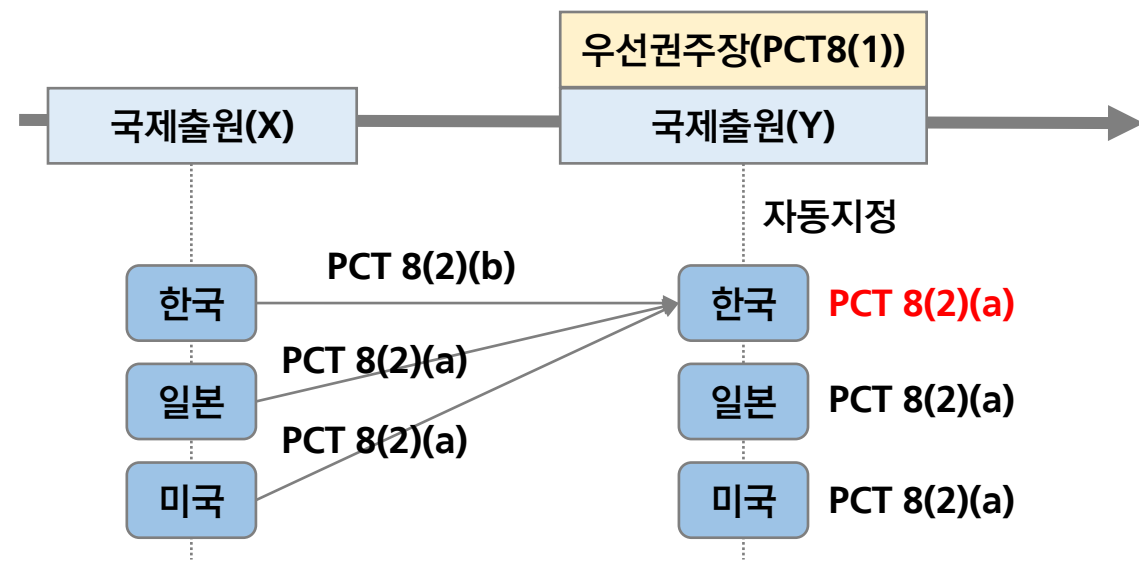
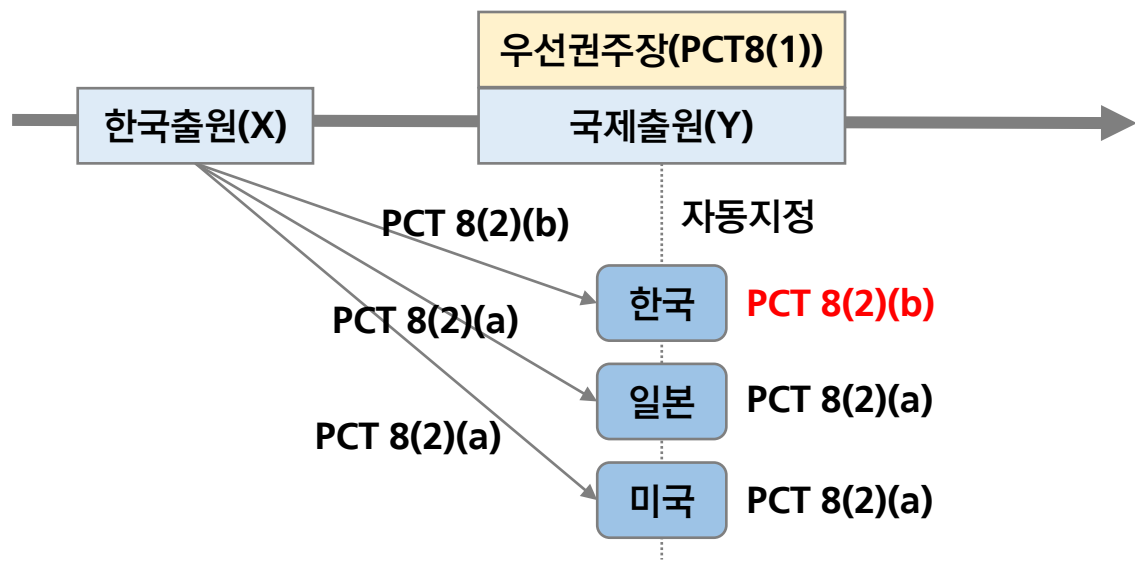
2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간





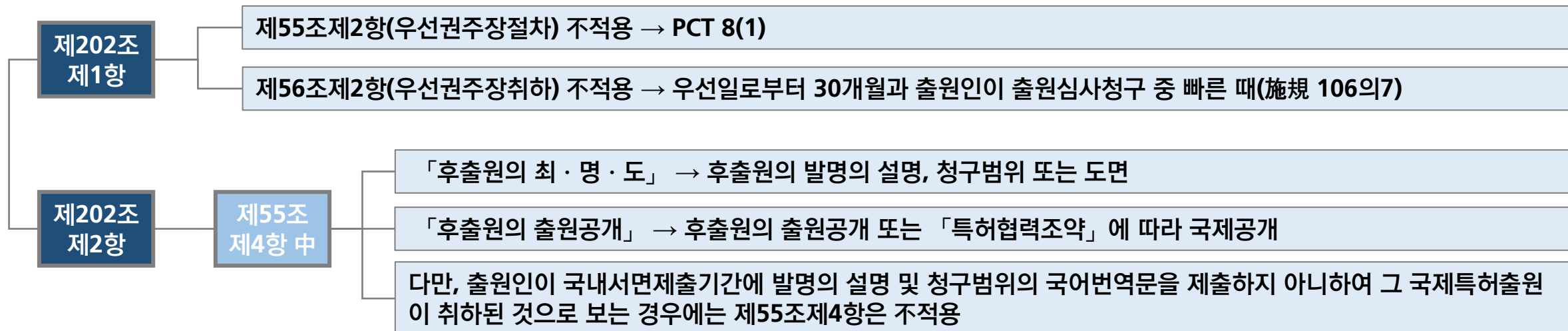
「자기지정」이란 어느 체약국에서 또는 어느 체약국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권주장을 수반하는 국제출원에 해당 체약국의 지정을 포함하는 것을 말한다. 국제출원이 어느 지정국에서 또는 어느 지정국에 대하여 행하여진 국내출원에 의한 우선권주장을 수반하는 경우 또는 하나의 국가만의 지정을 포함한 국제출원에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 해당 지정국에서의 요건 및 효과는 해당 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다(PCT 8(2)(b)).

구 분	선출원	후출원(우선권주장출원)	비 고
자기지정 ○	한국	PCT(한국, 미국, 일본 등)	지정국 한국에 대해서는 PCT 8(1),(2)b가 적용이 되며, 한국이 아닌 지정국에 대해서는 PCT 8(1),(2)a가 적용
	PCT(한국)	PCT(한국, 미국, 일본 등)	
자기지정 ×	PCT(한국, 미국, 일본 등)	PCT(한국, 미국, 일본 등)	PCT 8(1),(2)a에 의한 조약우선권주장의 요건 및 효과 적용
	PCT(한국, 미국, 일본 등)	한국	출원인의 의사에 의하여 조약우선권주장(法 54) 또는 국내우선권주장(法 55) 중 선택가능
해 설	PCT 출원서에서는 우선권주장을 체크하는 란은 있지만 국내우선권과 조약우선권을 구별하는 란이 존재하지 아니한다. 따라서 우선권주장을 체크하였을 때, 원칙은 PCT 8(1),(2)a가 적용이 되며, 이를 적용할 수 없는 경우에만 예외적으로 PCT 8(1),(2)b가 적용되는 것이다. 한편, 국내출원서에는 출원 시 조약우선권주장(法 54) 또는 국내우선권주장(法 55)을 선택하여 적을 수 있다.		



제202조(특허출원 등에 의한 우선권 주장의 특례) ① 국제특허출원에 관하여는 제55조제2항 및 제56조제2항을 적용하지 아니한다.
 ② 제55조제4항을 적용할 때 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 국제특허출원인 경우에는 같은 항 중 "특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"으로, "출원공개되거나"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나"로 본다. 다만, 그 국제특허출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우에는 제55조제4항을 적용하지 아니한다.

제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ② 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.
 ④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다.
제56조(선출원의 취하 등) ② 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일로부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취할 수 없다.



제202조(특허출원 등에 의한 우선권 주장의 특례) ③ 제55조제1항, 같은 조 제3항부터 제5항까지 및 제56조제1항을 적용할 때 선출원이 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. **제55조제1항** 각 호 외의 부분 본문, 같은 조 **제3항** 및 **제5항** 각 호 외의 부분 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.

가. 선출원이 국제특허출원인 경우: "국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"

나. 선출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우: "국제출원일까지 제출된 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"

2. **제55조제4항** 중 "선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 보고, "선출원에 관하여 출원공개"는 "선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개"로 본다.

가. 선출원이 국제특허출원인 경우: "선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"

나. 선출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우: "선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"

3. **제56조제1항** 각 호 외의 부분 본문 중 "그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때"는 "국제출원일부터 1년 3개월이 지난 때 또는 제201조제5항이나 「실용신안법」 제35조제5항에 따른 기준일 중 늦은 때"로 본다.

제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우

2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원이나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우

3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우

4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 및 제136조제5항(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. <개정 2016.2.29.>

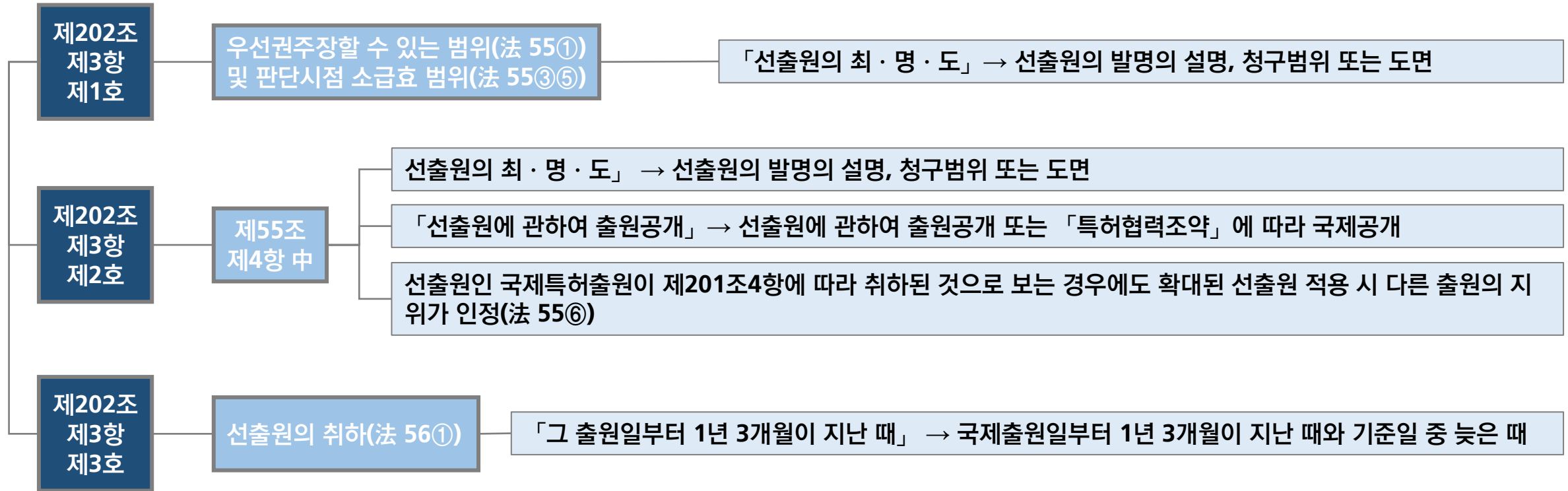
④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다.

⑤ 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다.

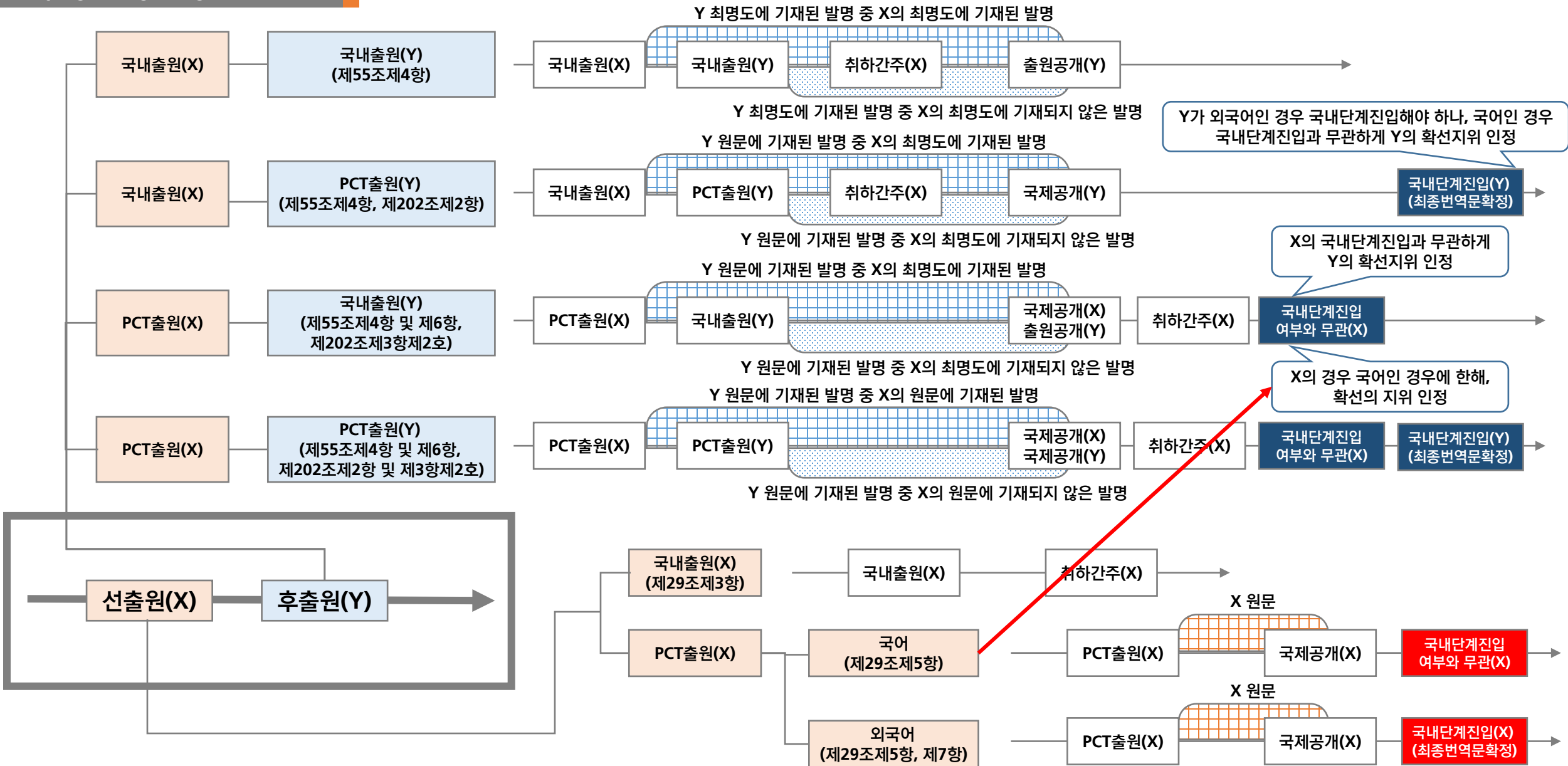
1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우

2. 선출원이 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우

제56조(선출원의 취하 등) ① 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다



구분	유형		적용법률	국내우선권 주장절차	국내우선권주장의 취하	선출원의 취하	확대된 선출원
	선출원	후출원					
자기 지정 ×	국내	국내	제55조 제56조	특허출원 시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시 (法 55②)	선출원의 출원일로부터 1년 3개월을 지나기 전까지 취하 가능(法 56②)	선출원일로부터 1년 3개월이 지난 후 취하간주(法 56①)	후출원의 최·명·도에 기재된 발명 중 선출원의 최·명·도에 기재된 발명과 같은 발명은 후출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때에 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 간주
	PCT (지정국: 한국, 일본등)	국내 (국내우선권 선택)	제55조 제56조 제202조제3항				1. 후출원의 최·명·도에 기재된 발명 중 선출원의 「국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명」과 같은 발명은 후출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때에 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」된 것으로 간주 2. 선출원인 국제특허출원이 제201조4항에 따라 취하된 것으로 보는 경우에도 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위가 인정된다(法 55⑥).
자기 지정 ○	PCT (지정국: 한국)	PCT (지정국: 한국, 일본등)	제55조 제56조 제202조제1항-제3항	PCT 제8조에 의하여 국제출원서에 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시(法 202①)	우선일로부터 2년 6개월을 지나기 전과 출원인이 출원심사청구를 하기 전 중 빠른 때까지 우선권 주장의 일부 또는 전부 취하 가능(施規 106의7)	국제출원일로부터 1년 3개월이 지난 때와 기준일 중 늦은 때 취하간주 (法 202③)	1. 후출원의 「국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명 중 선출원의 「국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명과 같은 발명은 후출원이 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나」 또는 등록공고되었을 때에 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」된 것으로 간주 2. 선출원인 국제특허출원이 제201조4항에 따라 취하된 것으로 보는 경우에도 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위가 인정된다(法 55⑥). 3. 후출원인 국제특허출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우에는 확대된 선출원(法 55④) 부적용(法 202②단서).
	국내	PCT (지정국: 한국, 일본등)	제55조 제56조 제202조제1항-제2항				선출원일로부터 1년 3개월이 지난 후 취하간주(法 56①)
비고(판단방법)				※ 국내우선권주장의 절차, 국내우선권주장의 취하 → 후출원을 기준으로 판단 ※ 선출원의 취하간주시기 → 선출원을 기준으로 판단			



제206조(재외자의 특허관리인의 특례) ① 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.

② 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 총리령으로 정하는 기간에 특허관리인을 선임하여 지식재산처장에게 신고하여야 한다.

③ 제2항에 따른 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

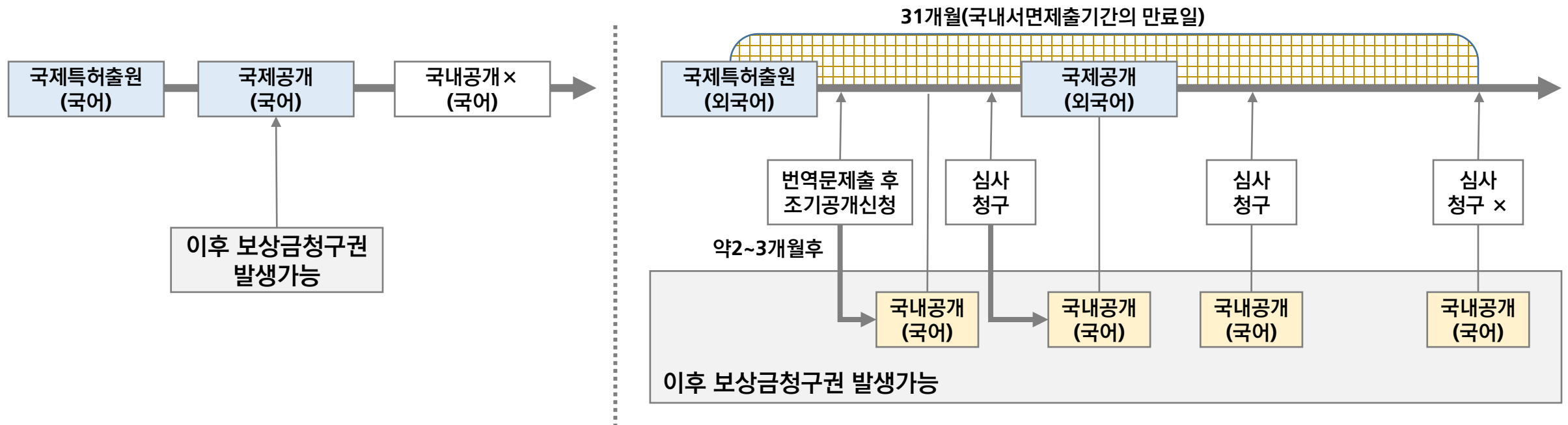
제5조(재외자의 특허관리인) ① 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 "재외자"라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다.

제207조(출원공개시기 및 효과의 특례) ① 국제특허출원의 출원공개에 관하여 제64조제1항을 적용하는 경우에는 "다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후"는 "국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장해 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 항에서 같다)이 지난 후(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개된 경우에는 우선일부터 1년 6개월이 되는 날 또는 출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후)"로 본다.

② 제1항에도 불구하고 **국어로 출원한 국제특허출원**에 관하여 제1항에 따른 출원공개 전에 이미 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는 그 국제공개가 된 때에 출원공개가 된 것으로 본다.

③ 국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여 **출원공개(국어로 출원한 국제특허출원인 경우 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개를 말한다. 이하 이 조에서 같다)**가 있는 후 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고할 수 있다.

④ 국제특허출원의 출원인은 제3항에 따른 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고도 그 국제특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 **합리적으로** 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 해당 특허출원이 특허권의 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.



제211조(국제조사보고서 등에 기재된 문헌의 제출명령) 지식재산처장은 국제특허출원의 출원인에 대하여 기간을 정하여 「특허협력조약」 제18조의 국제조사보고서 또는 같은 조약 제35조의 국제예비심사보고서에 적혀 있는 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다.

PCT에 의하면 지정관청 또는 출원인은 국제조사기관에 대하여 국제조사보고서에서 인용된 문헌의 사본을 제출토록 요구할 수 있으며(PCT 제20조(3)), 국제예비심사기관에 대하여 국제예비심사보고서에 인용되었으나 국제조사보고서에서는 인용되지 아니한 문헌의 사본을 제출토록 요구할 수 있다(PC지식재산처36조(4)). 이에 따라, 특허법은 출원인을 통하여 문헌의 사본을 제출받도록 규정하고 있는 것이다. **물론 지식재산처는 국제조사기관이나 국제예비심사기관에 대하여 직접 문헌 사본의 제출을 요구할 수도 있다.**

제214조(결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원) ① 국제출원의 출원인은 「특허협력조약」 제4조(1)(ii)의 지정국에 대한민국을 포함하는 국제출원(특허출원만 해당한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 총리령으로 정하는 기간에 총리령으로 정하는 바에 따라 지식재산처장에게 같은 조약 제25조(2)(a)에 따른 결정을 하여줄 것을 신청할 수 있다.

1. 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a)에 따른 거부를 한 경우
2. 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a) 또는 (b)에 따른 선언을 한 경우
3. 국제사무국이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a)에 따른 인정을 한 경우

② 제1항의 신청을 하려는 자는 그 신청 시 발명의 설명, 청구범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한정한다), 그 밖에 총리령으로 정하는 국제출원에 관한 서류의 국어번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

③ 지식재산처장은 제1항의 신청이 있으면 그 신청에 관한 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 같은 조약규칙에 따라 정당하게 된 것인지에 관하여 결정을 하여야 한다.

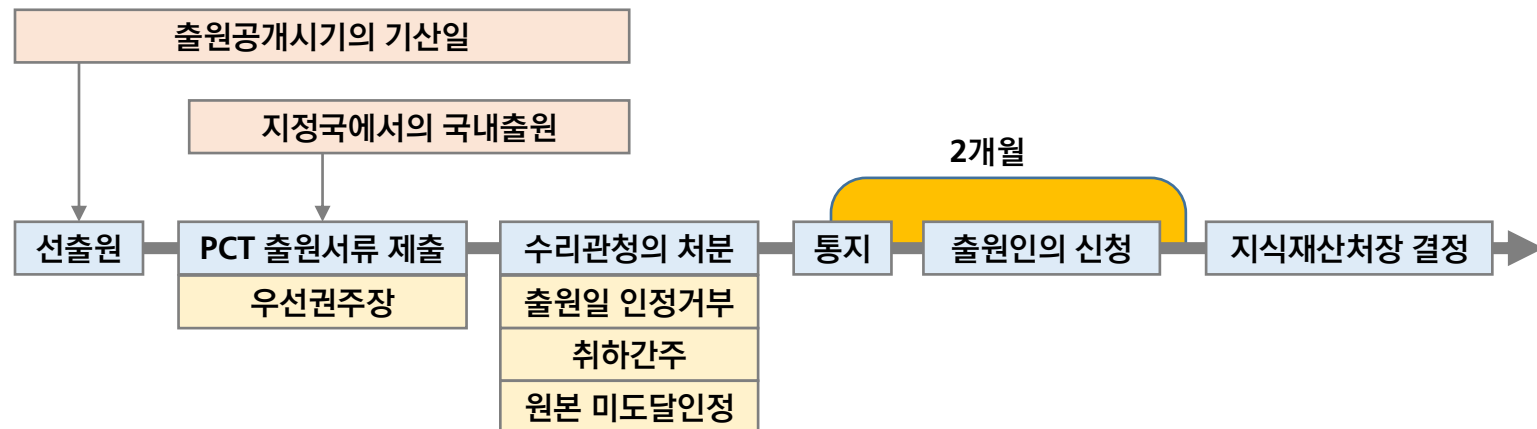
④ 지식재산처장은 제3항에 따라 그 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 같은 조약규칙에 따라 정당하게 된 것이 아니라고 결정을 한 경우에는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 본다.

⑤ 지식재산처장은 제3항에 따른 정당성 여부의 결정을 하는 경우에는 그 결정의 등본을 국제출원의 출원인에게 송달하여야 한다.

⑥ 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관하여는 제199조제2항, 제200조, 제200조의2, 제201조제5항부터 제8항까지, 제202조제1항·제2항, 제208조 및 제210조를 준용한다.

⑦ 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관한 출원공개에 관하여는 제64조제1항 중 "다음 각 호의 구분에 따른 날"을 "제201조제1항의 우선일"로 본다.

구 분	경미 흠결	중대 흠결	비고
국내 출원	무효	불수리	• 불복의 대상이 있기 때문에 독립하여 행정소송이나 행정심판으로 불복가능
국제 출원	취하간주	국제출원일 불인정	• 불복의 대상이 없기 때문에 독립하여 불복 불가능 • 단, 지정국에서의 구제방법(法 214)에 의한 구제 가능



구분		특허법	실용신안법
보호대상		발명(방법발명, 물질발명, 용도발명도 특허 가능)	물품의 형상·구조·조합에 관한 고안(·물품성질, 방법 또는 물질에 관한 고안은 등록불가)
성립요건		고도성 要	고도성 不要
등록 요건	진보성	용이성	「극히 용이성」(즉, 낮은 수준의 진보성)
	부등록사유	공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명	1. 공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 고안 2. 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안
출원 및 심사	도면첨부	필요한 경우에만 첨부	필수적으로 첨부 / 미첨부시 불수리
	우선심사대상 의상이	1. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원 3. 반도체 등 국민지식재산처 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(지식 재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다) 4. 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원 5. 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관장과 우선심사하기로 합의한 특허출원 6. 지역특화발전특구에 대한 규제특례법 제36조의8에 따라 규제특례가 적용된 특허사업과 직접 관련된 특허출원 7. 첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주 의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련한 특허출원	1. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원
효력	존속기간	특허권 설정등록을 한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지	실용신안권 설정등록을 한 날부터 실용신안등록출원일 후 10년이 되는 날까지
	존속기간연장	허가 등에 따른 연장 + 등록지연에 따른 연장 가능	등록지연에 따른 연장만 가능
	효력범위제한	의약, 의약제법방법 적용 可(法 96②)	의약, 의약제법방법 적용 不可
	간접침해	물건발명, 방법발명 모두 적용 可能	방법발명 / 물질발명은 적용 不可
	생산방법추정	有	無
	물수규정	필요적 물수	임의적 물수
PCT	도면의 제출	도면의 설명부분에 대한 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 도면의 설명부분에 대한 기재가 없었던 것으로 본다(法 201⑤)	1. 국제실용신안등록출원이 도면(도면에 간단한 설명을 포함)을 포함하지 아니한 경우 「기준일」까지 이를 제출(實用 36①) 2. 미제출시 지식재산처장은 기간을 정하여 도면 및 도면의 설명부분의 국어번역문의 제출을 명령(實用 36②) 3. 지식재산처장의 명령에도 불구하고 도면을 제출하지 아니한 경우 그 국제실용신안등록출원을 무효로 할 수 있다(實用 36③). 4. 제출된 도면 및 도면의 설명부분의 국어번역문은 「특허법」 제47조제1항에 따른 보정으로 간주(단, 보정기간은 부적용)(實用 36④).

